제1강 기본권 일반론

♣ 학습목표

기본권 보장의 역사적 전개를 설명할 수 있다.
근대 시민헌법의 특징을 설명할 수 있다.
현대 기본권의 특징을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

기본권 보장의 역사
근대 시민헌법의 특징
현대 기본권의 특징
제3세대 인권

♣ 사전테스트

1. 인권이 실정헌법에 최초로 규정된 것은 버지니아 권리장전이다.

정답 : O
해설 : 미국의 버지니아 권리장전(1776)에서 인간의 천부적·생래적 인권(자연권)이 실정헌법에 최초로 규정되었고, 프랑스 인권선언(1789)에서 재확인되었다.

2. 기본권과 인권은 동일한 개념이다.

정답 : X
해설 : 기본권은 헌법이 보장하는 국민의 권리, 인권은 인간의 천부적 권리이다.

3. 제3세대 인권에서는 연대권이 강조되고 있다.

정답 : O

♣ 돌발퀴즈

기본권은 천부적으로 주어진 권리이다.

[정답] X
[해설] 기본권은 개인의 자유와 권리를 침해하고 부당하게 차별하는 기득권계층과 국가권력 및 특정 사회의 지배이데올로기를 신봉하는 세력으로부터 끊임없이 투쟁하여 얻은 결과물이다.

♣ 강의내용

1. 개관

헌법의 역사와 정치사는 일반적으로 대략 한 세대 정도의 시간차이가 나는 것으로 알려져 있다. 이런 관점에서 보면, 역사는 역사학자들에게서 철학자들에게 그리고 법학자들에게로 대략 30년에서 50년의 시간차이를 두고 점진적으로 역사변혁, 정치사상, 정치제도 그리고 법률과 그 밖의 법적수단들에게 받아들여진다고 한다.[1] 즉, 역사적 사건이 전개되고, 새로운 철학의 사조가 태동하면, 그러한 사상은 한 세대가 흐르는 동안 사회조직에서 받아들여지게 되고, 다음 세대 또는 그 다음 세대에서 그것을 사회질서의 한 부분인 법질서로 받아들이게 된다는 것이다.[2]

예컨대, 노예제도를 자연법 위반이라 질타한 빅토리아(Francisco de Victoria : 1485~1546)의 주장은 후대 링컨(Abraham Lincoln : 1809년~1865년)에 의해 미국 헌법 수정 제13조를 통한 노예제 폐지를 이끌어냈고, 언론의 자유와 검열제 폐지를 주장한 밀턴(John Milton : 1608년~1674년)은 1644년 '아레오파기티카' (Areopagitica)를 발표하여, '사상의 공개시장' 또는 '자동조정 작용(the self-righting process)'과 같은 현대적 언론자유의 개념을 주장하여 1695년 검열법(The Licensing Act)의 폐지를 이끌어냈으며, 1776년 버지니아권리장전 제12조(언론·출판의 자유를 제한하는 것은 전제적 정부라 할 수 있다), 1791년 미국수정헌법 제1조(연방의회는 언론·출판의 자유를 제한하거나 평온한 집회권, 청원권을 침해하는 법률을 제정할 수 없다)에서 법률로도 제한할 수 없는 절대적 자유권으로 규정되기에 이른다.

이외에도 절대군주제를 주장한 홉스(Thomas Hobbes : 1588년~1679년)에 반대하여 가능하면 방해받지 않고 자연적 자유(생명, 자유, 재산)를 향유하기 위해 국가를 창설했다고 주장한 로크(John Locke : 1632년~1677년)는 영국의 이권분립 즉, 의회제도의 정착에 영향을 주었으며, 사상의 자유와 표현의 자유를 주장한 스피노자(Baruch de Spinoza : 1632년~1677년), 인간을 존엄의 주체로 파악하여 군주가 자연법에 반하여 국민의 자유와 생명 그리고 재산을 침해한 경우 저항권을 인정한 푸펜도르프(Samuel Pufendorf : 1632년~1694년), 기본권의 발전에 영향을 준 독일 자연법론자인 토마지우스(Christian Thomasius : 1655년~1728년)와 볼프(Christian Wolff : 1679년~1754년) 등 이루 헤아릴 수 없을 정도로 많은 역사적 사실이 존재한다.

한편, 오늘날 헌법전에 규정되어 있는 기본권 목록들 중에는 위에서 본 것처럼 그 사상적 유래가 명확한 것들도 있지만 그렇지 않은 것들도 있다. 예컨대, 환경권이나 건강권 등이 바로 그것이다. 그러나 기본권사상이 인권사상에서 비롯되었다는 것만은 확실하다. 특히, 근대적 의미의 기본권사상은 개인적 자유와 정치질서 사이의 관계에서 언제나 같은 것으로 남아 있는 기본적 문제에 대한 대답으로서 대략 17~18세기에 자연법과 이성법을 주장한 계몽주의철학자들에게서 발전되었다.[3]

그러나 앞서 보았듯이 그러한 사상들이 헌법전에 성문화된 것은 많은 시간이 흐르고 난 후이며, 그것도 그냥 얻어진 것이 아니라 여러 차례의 정치적·혁명적 투쟁을 통해 이룩된 것들이 대부분이다. 이러한 투쟁은 절대적 국가권력이 지배자의 의사가 아닌 법에 구속될 것을 요구한 자연법(근대의 시민적 헌법)을 쟁취하기 위한 투쟁의 역사인 것이다.[4]

계몽주의철학자들은 인간을 이성적인 존재, 양도될 수 없는 자연적 권리를 가진 존재로 생각하였다. 그러나 이러한 사상은 당시 절대주의국가관에서는 받아들여질 수가 없었다. 왜냐하면 절대주의 국가관에 따르면 국가권력은 무제한적인 것이자 전적으로 군주의 사유물인 것으로 간

---

1) O. Kimminich, Menchenrechte-Versagen und Hoffnung, 1973, S. 13ff.
2) M. Hauriou, Sozialordnung, Gerechttigkeit und Recht, in : R. Schnur(Hrsg.), Die Theorie der Institution und zwei andere Aufsätze von Maurice Hauriou, 1965, S. 64ff.(74).
3) 홍성방, 「헌법학」(상), 박영사, 2013, 251면 참조.
4) 홍성방, 전게서, 251~252면 참조.

주되었기 때문이다. 따라서 군주의 자의적 의사에 대해 신민(Untertan)은 무기력 할 수밖에 없었다. 그러나 18세기 급격하게 성장한 상공업에 힘입어 시민계급은 경제적 부를 축적할 수 있었다. 이로써 자유권을 성문화할 수 있는 조건과 그 필요성이 성립되었다. 이러한 시민계급은 그들의 자유와 평등 그리고 재산권의 보장이 군주에 의해 자의적으로 침해되는 상황에 저항하기 시작하였다.

즉, 시민이 자연적 권리를 국가에 대해 주장할 수 있도록 그것을 자의적으로 변경할 수 없고 정부의 침해에 대해서도 안전할 수 있도록 헌법에 기본권으로 보장하는 것이 필요하게 되었다. 그러한 필요성은 산업화를 통해 더욱 촉진되었다. 왜냐하면 주도적으로 기업을 운영하기 위해서는 특정한 자유를 보장받는 것이 필수적인 것으로 되었기 때문이다.

결국 국가산업의 주도자가 된 시민계급은 법질서의 안정을 요구함과 동시에 국가적 조치들이 예견가능할 것을 요구하였고, 거기에서 더 나아가 국가가 자의적 행위를 중지할 것을 요구하게 되었다. 여기에 특권과는 관계없이 인간의 자기완성력을 신봉하여 경제질서를 개혁하고자 한 중농주의학파가 이론적 기초를 제공하였다.

2. 역사적 전개

근대국가 이전에 국가와 개인의 관계는 개인에 대한 국가의 일방적인 지배와 국가에 대한 개인의 전적인 복종관계를 특징으로 하였다. 즉 개인은 국가에 대하여 권리의 주체가 될 수 없고, 단지 지배의 대상에 불과했다. 이러한 국가와 개인 간의 복종관계에 대해 개인에게 자유와 평등이라는 천부적 인권이 존재한다는 사상은 받아들여지기 어려웠다. 그 결과 천부인권사상은 지배세력의 이념과 충돌하게 되는데 그것이 바로 시민혁명이다. 세계 3대 시민 혁명은 영국의 명예혁명(1688)과 프랑스 대혁명(1789), 미국의 독립 전쟁(1776)을 들 수 있다.[5)]

<기본권 보장의 역사>

1215년 : 영국의 마그나카르타(대헌장) 63개조
1628년 : 영국의 권리청원 12개조 (과세의 의회승인, 신체의 자유)
1679년 : 영국의 인신 보호율(인신보호영장제, 구속적부심사제)
1689년 : 영국의 권리 장전(의회주의)
1776년 : 미국의 버지니아 권리 장전(천부인권, 생명, 자유, 재산권 보장, 저항권 규정)
1789년 : 프랑스 인권선언(인간과 시민의 권리선언)
1919년 : 독일의 바이마르 헌법(사회권 규정)
1948년 : 세계 인권 선언
1966년 : UN 시민적 정치적 권리에 관한 규약(한국 1990년 가입)
1967년 : UN 부녀자에 대한 차별 철폐 선언
1976년 : UN 경제적 사회적 문화적 권리에 관한 규약(한국 1990년 가입)

5) 청교도 혁명(1642)은 프랑스 혁명보다 시기적으로 100년이나 앞서나 시민계급이 주도했다기보다는 지배집단 사이의 내란에 가깝기 때문에 시민혁명의 범주에 포함시키기 어렵다; 기본권의 연혁에 대한 자세한 내용은 杉原泰雄, 『人間の歷史』, 岩波書店, 1992 참조.

3. 근대시민헌법의 특징

자유와 법적안정성에 대한 요구는 당시로서는 혁명적인 것이었으며 절대주의 권력구조와는 대립되는 것이었다. 따라서 기본권(무제약, 철회불가능, 시간적·내용적 무제한)은 '주권에의 경향'에 대한 대답인 동시에 인간의 기본적 자유에 봉사하도록 주권을 거부하는 것이었다.[6)]

⑴ 목적으로서의 인권과 수단으로서의 국가

시민혁명 이전에 국민은 전적으로 국가의 지배를 받는 신민에 불과하였다. 개인은 통치의 객체였고, 국가와 개인의 관계는 지배와 복종의 관계에 불과했다. 미국의 독립선언은 모든 사람은 조물주에 의해 불가양의 천부적 권리를 부여받았으며, 여기에는 생명, 자유와 행복을 추구할 권리가 포함되어 있다는 것을 명시하였다.

⑵ 자유권중심의 인권사상

국가의 간섭을 배제하는 자유권 보장이 특징이다. 개인의 생명, 자유, 재산권의 보장이 대표적이다. 또한, 경제활동의 자유, 정신활동의 자유, 사법절차적 기본권 등이 구현되었다.

⑶ 인권의 불가침성

어떠한 권력도 자연권인 인권을 침해할 수 없다. 타인도 인권을 가지므로 인권을 내세워 타인의 권리를 침해할 수 없다.

⑷ 형식적 평등권

국민은 법적으로 평등하게 취급되었다. 그러나 이는 봉건제로부터 해방되어 형식적으로 평등하다는 것이지 사회의 불평등을 제거하는 등 실질적 평등을 보장한다는 의미는 아니다.

⑸ 참정권

보통선거가 부인되어 일정 금액 이상의 납세자에게 선거권이 부여되었다. 따라서 제한선거제도였고, 직접민주제는 원칙적으로 인정되지 않았다. 프랑스에서는 신흥시민계급을 중심으로 국민주권원리가 발전하였다. 그러나 국민은 추상적·관념적 존재이기 때문에 자연인과 같은 통일적인 의사결정능력이 없고, 주권의 소유와 행사는 분리될 수 있으며, 자유위임이어서 위임을 받은 사람은 국민 의사에 기속되지 않았다.

⑹ 문제점

성에 의한 차별은 존속하였다. 예컨대, 나폴레옹 민법전은 처를 무능력자라고 하여 남편에게 종속된 자여서 남편에게 복종하고, 처의 간통은 3개월에서 2년의 금고에 처하며, 남편은 집에 간통상대를 데리고 온 경우에만 100프랑에서 2000프랑의 벌금을 부과한다는 차별적 규정이 있었다.

---

6) M. Kriele, Zur Geschichte der Grund und Menschenrechte, in : Öffentlich Recht und Politik. Festschrift für H. U. Scupin, 1973, S. 187ff.(195).

또한, 국가가 소극국가, 야경국가를 지향하여 자유방임문제가 발생하였다. 예컨대, 국가가 근로자와 사용자간 힘의 불균형 문제에 제대로 대응하지 않아 사용자에게 지나치게 유리한 계약이 체결됨으로써 근로자들의 노동조건이 더욱 악화되고, 저임금, 장시간 노동, 아동착취 등의 사회문제가 심각해졌다. 프랑스에서는 노동자와 사용주의 단결권금지법이[7] 제정되기도 하였다.

이러한 사회문제로 인해 1871년 3월 18일 파리코뮌이 개최되어 비참한 임금제도 및 빈곤과 영원한 결별할 것과 권력은 만인의 것이며, 참정권보장, 법관까지도 선거제 확대, 국민소환제도, 각 코뮌단위의 국민통치 등을 요구하였으나 같은 해 5월 28일 진압되었다.

4. 현대 기본권의 특징

기본권은 천부적으로 주어진 권리가 아니라 개인의 자유와 권리를 침해하고 부당하게 차별하는 기득권계층과 국가권력 및 특정 사회의 지배이데올로기를 신봉하는 세력으로부터 끊임없이 투쟁하여 얻은 결과물이다. 이런 기본권을 위한 투쟁은 현재에도 계속 진행형이다.

---

7) 르샤플리에(Le Chapelier) 법(1791년 6월 14일)

제1조 프랑스 헌법의 근본 토대 중 하나가 동종의 업 또는 직업에 종사하는 시민의 길드를 어떤 종류이건 폐지하는 데 있다는 점에서, 어떠한 명목 및 어떠한 형태로든지 그것의 재건은 금지된다.

제2조 동종의 업 또는 직업의 시민, 기업가, 상점을 세운 사람, 숙련도를 불문하고 노동자와 직인은 회합하여 의장, 서기, 또는 이사를 임명, 결의안을 통과시키거나 자신들의 공통된 이해라 주장할 것에 관한 규정을 기초할 수 없다.

제3조 모든 행정 및 시 조직은 직업의 이름으로 된 어떠한 성명이나 청원도 접수하거나 그에 대한 답변을 하는 것이 금지된다. 추가로, 그렇게 작성된 결의안은 무엇이건 무효라고 선언할 의무가 있으며 그에 따른 아무런 효력이나 집행력이 없음을 확실히 해야 한다.

제4조 자신들의 산업 또는 노동의 가격을 정하기 위해 동종 직업, 기술, 업에 종사하는 시민들이 자기들끼리 협약을 협의하거나 맺는 것은 자유의 원칙과 헌법에 반하는 것이다. 서약이 동반되었건 아니건 간에 그러한 협의와 협약이 체결되면 위헌이며 자유와 인간의 권리 선언(Declaration of the Rights of Man)을 침해하는 것으로 선언되고 무효화된다. 행정 및 시 조직은 그런 협약을 위헌이며 무효로서 선포할 것이 요구된다. 그러한 협약을 선동하고, 기초하거나 주재한 작가, 지도자, 선동가들에 대해서는 경찰이 죄를 묻고, 시 검사의 기소로 500 리브르(livres)의 벌금형에 처하며, 능동시민으로서의 모든 권리의 향유가 1년 간 유예되며, 기초 의회에 대한 입장이 금지된다.

제5조 언급한 협의 또는 협약을 선동하거나 그에 서명한 기업가들, 노동자, 직인들이 자신들의 동의로 경찰 법원의 기록원에 출두하여 그 협약을 철회하거나 부인하지 않는다면, 그 구성원들이 단독적인 이름을 사용한다 할지라도, 모든 행정 및 시 조직은 그들의 직업을 어떠한 공무에서도 고용하거나 인정하거나 인정되도록 허용하는 것이 금지된다.

제6조 언급한 협의 또는 회의, 전달된 포스터, 또는 회람된 편지가 기업가, 기술자, 노동자, 또는 그곳에서 일하는 외국인 날품 노동자에 대한 위협이나 낮은 임금을 수용하는 사람들에 대한 위협을 담고 있다면, 그러한 행위나 글을 쓴 모든 작가, 선동가, 서명자들은 각각 1천 리브르의 벌금에 처하며 3개월 간 구금된다.

제7조 헌법으로 보장된 노동과 산업에 대한 자유를 이용하고 있는 노동자들에 대하여 위협이나 폭력을 사용하는 자들은 형사처벌을 받으며, 공공 평화의 교란자로서 법의 최대한도까지 처벌받는다.

제8조 어떤 종류의 사람에게나 속하며 상호 동의하의 모든 상황에 속하는 산업과 노동의 자유로운 행사에 역행하고, 경찰 행위와 그와 연관된 판단의 집행에 반할 뿐 아니라 다양한 기업에 대한 공매와 파산선고에 반하는 기능공, 노동자, 직인, 날품노동자 또는 그들의 선동을 받은 자들의 모든 회합은 치안방해로 간주되고, 그에 따른 법적 영장에 근거하여 법의 수호자들에게 해산되고, 언급한 회합과 관련된 작가, 선동가, 지도자들, 비난과 폭력 행위를 저지른 모든 자들은 법이 정한 최대한도까지 처벌받는다.

⑴ 사회적 기본권의 확대와 자유권의 사회적 기본권화

사회적 기본권은 바이마르헌법에서 최초로 규정되었지만 사실상 효력을 가지지 못했고, 제2차 세계대전 이후 서구 헌법에 본격적으로 수용되었다. 즉 노동3권, 인간다운 생활을 할 권리, 재산권의 사회적 제약, 경제활동의 자유제한(독과점금지 및 예외적인 재산권의 국·공유화), 아동·노약자·부녀자의 보호 등이 실정헌법에 규정되었다.

또한, 근대헌법에서 보장된 재판청구권, 손실보상청구권, 청원권 이외에 형사보상청구권, 국가배상청구권 등의 청구권적 기본권이 추가되었고, 입법자에 의한 기본권의 침해를 막기 위하여 위헌법률심판제 및 헌법재판제도가 수용되었다.

자유권의 영역에서도 근대 헌법에서는 볼 수 없었던 학문·예술·과학의 자유가 명시적으로 규정되었고, 자유권이 단순히 방어권이 아니라 국가의 급부 내지 활동을 요구할 수 있는 사회권으로 확장되었으며, 기본권 보장을 위한 제도와 절차를 형성할 권리가 인정되었다.

우리나라 헌법 제10조는 "모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다"고 규정하고 있다.[8)]

⑵ 인권보장의 세계화

1) 1단계 : 국제연합헌장(1945), 세계인권선언(1948)

2) 2단계 : 지역적 인권규약(유럽인권조약(1953), 유럽사회헌장(1961))

3) 3단계 : 국제인권규약

시민적·정치적 권리(자유권)에 관한 규약[A규약]과 경제적·사회적·문화적 권리(사회권)에 관한 규약[B규약]으로 나뉘며, 1976년 발효되었다. 우리나라는 1990년 '시민적·정치적 권리에 관한 규약[A규약]'은 유보없이 가입하였으나 '경제적·사회적·문화적 권리에 관한 규약[B규약]'에 대해서는 일부 조항을 유보하고 가입하였다.[9)] 자유권 규약의 경우, 인권위원회에 제소할 수 있는 선택의정서를 채택한 반면, 사회권 규약은 구체적인 실행방법이 없다. 다만, 필요한 경우 특별조정위원회를 구성하여 우호적으로 해결할 수 있도록 규정하고 있을 뿐이다(제42조).

4) 4단계 : UNESCO의 제3세대 인권(연대권 강조)

근대 입헌주의헌법이 보장하는 추상적 자유와 평등의 보장이 제1세대 인권이라면, 실질적 자유를 보장하기 위한 사회적 기본권의 발전을 제2세대 인권이라고 할 수 있다. 제1세대 및 제2세대 인권은 개인이 그가 속한 국가에 대하여 주장하는 권리인데 반하여, 제3세대 인권은 국경을 초월하여 개인이 국제공동체에 주장하는 권리로 평화를 향유할 권리, 건강한 환경을 향유할 권리, 인류의 공동유산을 향유할 권리, 국경을 넘어서 교신할 권리, 인도적 원조를 받을 권리, 자결을 향유할 권리, 경제적 사회적 발전을 향유할 권리가 있으며, 1981년의 아프리카 인권헌장은 대부분의 제3세대 인권을 규정하고 있다.[10)]

---

8) 1962년 제5차 개정 헌법에서 처음 추가되었으며, 행복추구권은 1980년 제8차 개정 헌법에서 추가되었다.

9) B규약에 국내법과 저촉되는 4개항 중 3개항 ①1991년 3월 15일 B규약 제23조 4항(혼인, 이혼 등의 배우자 평등), ②1993년 1월 21일 B규약 제14조 7항(이중처벌금지), ③2007년 4월 2일 B규약 제14조 5항(상급심 재판 받을 권리)의 유보는 철회되었다. 그러나 제22조(누구든지 노조의 설립과 참여)에 대해서는 일부 공무원의 노조의 설립과 참여가 제한되고 있어 아직까지 유보된 상태이다.

10) 제3세대 인권은 1948년 12월 10일 국제연합 세계인권선언 이후에도 끊임없는 전쟁, 사망, 빈곤, 기아

⑶ 기본권의 효력범위 확장

기본권은 종래에는 대국가적인 권리로서만 인식되었으나 기본권의 양면성의 인정과 기본권의 실효적 측면을 강화하려는 노력으로 인해 대사인적 효력이 인정되게 되었다.

⑷ 정보통신기술과 생명공학의 발달로 인한 인권보호영역의 확대

정보화시대가 도래함에 따라 개인의 사생활 침해 등 기본권의 침해가능성이 높아지고 있다. 실제로 정보의 왜곡이나 사생활의 공개 및 독점 등의 문제가 발생하고 있어 이에 대한 보호의 필요성이 크다.

⑸ 국민의 정치적 참여의 확대

국민의 정치적 관심을 증대시키고, 참여를 확대시킴으로써 국민 개개인의 기본권에 대한 인식을 앙양시킬 수 있다.

♣ 문제풀이

1. 다음 기본권에 대한 기술 중 바르지 못한 것은?

① 근대 시민사회의 양축은 자유와 평등이었다.
② 사회적 기본권은 제2차 세계대전 이후 각국 헌법에 본격적으로 수용되기 시작하였다.
③ 오늘날 헌법에는 자유권적 기본권이외에도 사회적 기본권이 대거 수용됨으로써 기본권목록이 대폭 확장되었다.
④ 오늘날 국민의 기본권은 국가권력을 제한·축소함으로써 폭 넓게 보장될 수 있다.
⑤ 기본권은 국가와 개인 간의 관계뿐만 아니라 개인 상호간의 관계에도 영향을 미친다.

[정답] ④

[해설] 근대 국가가 소극국가, 야경국가를 지향하여 자유방임문제가 발생하였다. 예컨대, 국가가 근로자와 사용자간 힘의 불균형 문제에 제대로 대응하지 않아 사용자에게 지나치게 유리한 계약이 체결됨으로써 근로자들의 노동조건이 더욱 악화되고, 저임금, 장시간 노동, 아동착취 등의 사회문제가 심각해졌다. 따라서 국가의 적극적인 견제와 조정노력이 요청된다.

와 자연적 생활기반의 악화, 유전공학분야의 신기술의 예측불가능의 문제들을 해결하고자 주장되었다. 1972년 바작(Karl Vasak)은 국제 인권법의 내용을 이루고 있는 시민적 정치적 권리를 제1세대 인권으로, 경제, 사회, 문화적 권리를 2세대 인권이라 부르고, 3세대 인권에 연대권(경제발전권, 환경권, 평화권, 인류공동의 유산에 대한 소유권, 의사소통권)을 첨부하자고 주장하였다. 이후 제20차 유네스코 총회의 결정에 따라 1980년 8월 멕시코시티에서 '새로운 인권에 대한 전문가토론회'에서 그 외에 서로 다를 수 있는 권리, 인도주의적인 도움을 청구할 권리가 추가 논의되었다. 이러한 제3세대 인권은 인간의 사회생활의 기본적 요청들과 관계가 있기 때문에 제1세대 인권과 제2세대 인권에 비하여 정치적 색체가 적고, 사회동반자, 즉 개인, 국가, 공사단체, 국제공동체의 연대책임을 인정하고 있어 인권문제를 국제적 차원에서 인정할 것을 요청하고 있으며, 개인이 아닌 민족이나 국가 또는 집단에 대해서 1, 2세대 인권이 해결하지 못하는 문제에 대해 보충하는 것으로 지금도 생성 중에 있고, 이러한 것들을 인정하자고 주장하고 있다.

2. 다음 인권과 기본권에 대한 기술 중 바르지 못한 것은?

① 기본권과 인권개념은 상호배타적인 것이 아니라 상호의존·보완하고 있다.
② 인권개념은 프랑스 인권선언을 통하여 최초로 성문화되었다.
③ 우리나라는 헌법재판소법 제68조 제1항 제1문에서 기본권이라는 용어를 처음으로 사용하였다.
④ 기본권은 인권사상에서 출발하였지만 인권의 최소한의 영역이 기본권이라거나 인권이 특정 국가에서 실정화된 것이 기본권이라는 견해는 정확한 표현은 아니다.
⑤ 기본권은 초국가적인 천부적 인권사상으로부터 시작되었지만, 기본권 가운데는 참정권이나 사회적 기본권과 같이 외국인에게 인정되지 않는 권리가 있다.

[정답] ②

[해설] 미국의 버지니아 권리장전(1776)에서 인간의 천부적·생래적 인권(자연권)이 실정헌법에 최초로 규정되었고, 프랑스 인권선언(1789)에서 재확인되었다.

3. 다음 국제인권규약에 대한 기술 중 바르지 못한 것은?

① 우리나라는 '시민적·정치적 권리에 관한 규약[A규약]'은 유보 없이 가입하였으나 '경제적·사회적·문화적 권리에 관한 규약[B규약]'에 대해서는 일부 조항을 유보하고 가입하였다.
② 우리나라는 '경제적·사회적·문화적 권리에 관한 규약[B규약]' 제23조 4항의 혼인, 이혼 등의 배우자 평등조항의 유보를 철회하였다.
③ 우리나라는 '경제적·사회적·문화적 권리에 관한 규약[B규약]' 제14조 5항의 상급심 재판 받을 권리조항의 유보를 철회하였다.
④ 우리나라는 '경제적·사회적·문화적 권리에 관한 규약[B규약]' 제14조 7항의 이중처벌금지조항의 유보를 철회하였다.
⑤ 우리나라는 '경제적·사회적·문화적 권리에 관한 규약[B규약]' 제22조 누구든지 노조의 설립과 참여에 대한 조항의 유보를 철회하였다.

[정답] ⑤

[해설] 우리 헌법재판소는 모든 사람에게 노동조합결성권을 보장한 '경제적·사회적·문화적 권리에 관한 규약[B규약]' 제22조를 직접적으로 국내법적 효력을 가지는 것이 아니라고 판시한 바 있다(헌법재판소 1991. 7. 22. 89헌가 106).

♣ 요점정리

1. 기본권이란 헌법이 보장하는 개인 내지는 국민의 기본적 권리를 의미하며, 외국인에게도 보장되는 인간의 권리(인권)와 국민에게만 인정되는 권리(시민권)가 포함된다. 여기서 시민권은 한 국가의 구성원인 국민에게 인정되는 권리로서 외국인은 향유할 수 없는 권리를 의미한다. 참정권이 대표적인 시민권이다.

2. 기본권은 인권사상으로부터 비롯되는데, 인권이란 인간이 천부적으로 당연히 가지는 권리를 의미한다.

3. 우리나라는 1988년 제정된 헌법재판소법 제68조 제1항 제1문에서 "공권력의 행사 또는 불행사로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 법원의 재판을 제외하고는 헌법재판

소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다"고 규정하여 기본권이라는 용어를 처음으로 사용하였다.

4. 우리나라는 경제적·사회적·문화적 권리(사회권)에 관한 규약[B규약] 제22조(누구든지 노조의 설립과 참여)에 대해서는 일부 공무원의 노조의 설립과 참여가 제한되고 있어 아직까지 유보된 상태이다.

5. 제3세대 인권은 국경을 초월하여 개인이 국제공동체에 주장하는 권리로 평화를 향유할 권리, 건강한 환경을 향유할 권리, 인류의 공동유산을 향유할 권리, 국경을 넘어서 교신할 권리, 인도적 원조를 받을 권리, 자결을 향유할 권리, 경제적 사회적 발전을 향유할 권리가 있으며, 1981년의 아프리카 인권헌장은 대부분의 제3세대인권을 규정하고 있다.

제2강 자유권적 기본권

♣ 학습목표

영국에서의 역사적 전개를 설명할 수 있다.
미국에서의 역사적 전개를 설명할 수 있다.
프랑스에서의 역사적 전개를 설명할 수 있다.
독일에서의 역사적 전개를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

영국의 대헌장, 권리청원, 권리장전, 인신보호령
버지니아권리장전
프랑스 인권선언
바이마르헌법

♣ 사전테스트

1. 기본권을 헌법문서에 성문화된 권리라고 규정한 최초는 영국의 대헌장이다.

정답 : X
해설 : 1679년 인신보호령이다.

2. 펜실베니아 헌법은 전국가적 자연법사상에 기초한 기본적 인권을 확인한 최초의 기본권목록으로 평가된다.

정답 : X
해설 : 버지니아 권리장전이 기본적 인권을 확인한 최초의 기본권목록으로 평가된다.

3. 미국의 인권선언 또는 기본권규정은 헌법의 우위를 보여준다.

정답 : O
해설 : 따라서 위헌법률을 내용적으로 심사할 수 있었다(Mabury v. Madison 1 Cranch 713, 1803).

♣ 돌발퀴즈

독일의 바이마르헌법에서 사회적 기본권이 최초로 규정되었다.

[정답] O
[해설] 1919년 바이마르공화국 헌법에서 사회적 기본권이 최초로 규정되었다.

♣ 강의내용

1. 영국에서의 전개

⑴ 개관

기본권을 헌법문서에 성문화된 권리라고 규정한 최초의 기본권은 1679년 '인신보호령'(Habeas Corpus Act)에 규정된 자의적인 체포 및 형사소추로부터 보호를 받을 권리, 즉 인신의 보호에 대한 권리라 할 수 있다. 그리고 이러한 인신의 보호에 대한 권리에 견인차적 역할을 한 것은 전문 63개 조항으로 구성된 1215년 6월 15일의 영국의 '자유대헌장'(Magna Charta Libertatum) 제39조에 규정된 신체의 자유라 해야 할 것이다.[11] 이는 코크(Edward Coke : 1552년~1634년)가 실정법의 근거로 그가 생래의 권리로 생각한 '정당한 권리와 자유'인 개인적 자유와 생명 및 재산권을 발전시키고자 이러한 권리를 '보통법'(Common Law) 또는 '법의 공정한 절차'(Due Process of Law)에 의하여 보장받는 것이라고 하면서 그 근거로 대헌장 제39조를 원용하였기 때문이다.[12]

이러한 대헌장은 존왕이 영국의 귀족들에게 특히 법원의 절차 및 재산과 관련된 자유와 권리를 확인해 준 문서이다. 그렇게 때문에 이 문서의 성격에 대해서는 견해가 나누어진다.

첫 번째는 대헌장의 기본권보장성을 부인하는 견해이다. 이는 모든 사람을 위하여 기본권을 성문화한 것이 아니라 특정신분, 즉 귀족들을 위하여 자유와 특권을 문서로 확인한 것에 지나지 않으며, 그것은 후일 유럽대륙에서 종종 체결된 지배계약의 예에 지나지 않는다. 더구나 중세에는 자유란 지배로부터의 자유가 아닌 특권을 의미하였다. 그 밖에도 개인이 대헌장에 의한 보호를 받았는지도 의심스러울 뿐만 아니라 오히려 등족회의가[13] 자신의 소속원, 즉 귀족을 보호한 일종의 제도에 지나지 않는다. 따라서 대헌장은 기본권을 보장한 것이라기보다는 오히려 특권적 예외를 선언한 것으로 보는 것이다.[14]

두 번째는 대헌장이 현대적 의미의 성문헌법이라는 점은 부정하면서도 근대적 인권선언의 조상격인 역할을 인정하려는 견해이다. 즉, 대헌장과 권리청원, 권리장전에서 보장된 권리 내지 자유는 봉건귀족의 봉건적 지배권의 재확인 또는 특히 영국인이 고래로부터 향유하고 있었다고 생각된 것이며, 인간성으로부터 논리필연적으로 개개 인간에게 부착된 생래의 권리가 아니다. 그리고 또 이와 같은 영국의 역사적 문서는 성문헌법과 일체가 되는 것은 아니었다. 이러한 점에서 영국의 이들 문서는 근대적 인권선언이 특색으로 하는 제1, 제2의 성격을 가지고 있지 않

---

11) 자유인은 누구라도 같은 신분의 사람에 의한 적법한 심판이나 국법에 정한 경우를 제외하고는 체포, 구금, 재산권박탈, 추방, 법외방치되거나 다른 방법으로 처벌되지 아니하며 짐(朕)도 불리한 조치를 하거나 그를 체포하지 않을 것이다.

12) "모든 사람은 대헌장의 의미에서 자유인이다"(K. LöW, Die Grundrechte, 2. Aufl., 1982, S. 59, S. 422.).

13) 중세 말기의 유럽에 형성되어 절대 국가의 성립 때까지 존재했던 의회를 말하며, 성직자, 귀족, 시민의 신분별로 구성되었다. 영국의 경우 의회제도는 등족회의에 그 기원을 두며, 의회의 명칭이 정해진 것은 1246년의 일이었다. 이 후, 1295년 에드워드 2세가 고승, 대귀족, 일반승려단, 각 주(州)의 기사, 각 도시의 대표자 등을 소집하여 이것을 전형국회(典型國會)라 불렀으나 1330년 일반승려들이 이탈함으로써 고승과 귀족은 귀족원에서, 기사와 시민은 서민원(House of Common)에서 각기 따로 회의를 소집하여 양원제의 틀을 갖추게 되었다. 청교도혁명 이후 국민주권을 바탕으로 하는 '국민협약'이 군사회의에 제출되고, 1688년 명예혁명 이후 예산에 대한 의결권이 확립되었으며, 15세기 중엽에 청원권이 입법의 발안권으로 확립되었다. 이후 의원내각제가 성립하게 되면서 다수당이 내각을 조직하고, 그에 대립하는 야당이 정권교체의 기회를 가지게 되는 관례가 생기게 되었다.

14) I. v. Munch, Grundbegriffe des Staatsrechts Ⅰ, 1979, S. 77; B. Pieroth/B. Schlink, Grundrechte. Staatsrecht Ⅱ, 1985, S. 6.

다. 그렇다고 하여 영국의 대헌장, 권리청원, 권리장전이 국왕의 절대적 권력에 의한 침해에서부터 국민의 권리를 방어하고 보장하였던 역사적 의의까지를 부인하는 것은 아니며, 이들 문서의 역사적 역할로 볼 때에는 근대적 인권선언의 조상이었다고 할 수 있을 것이라고 한다.[15]

세 번째는 대헌장 제39조를 모든 기본권의 모태로 간주하는 견해이다. 이는 자의에 의한 체포 또는 형사소추를 당하지 않을 권리야말로 기본권의 원형이요 자유의 근원으로 보아야 한다고 한다. 그 이유는 이러한 기본권이 존재하지 않는 경우 인간은 끊임없는 위협에 직면하게 되고, 그 내용이 정신적인 것이든 정치적인 것이든 또는 종교적인 것이든 일체의 의사표시나 행동에는 개인적 자유의 상실이라는 높은 대가가 뒤따르게 되며, 공포는 결국 사람들의 입을 봉해버리고 말기 때문이라는 것이다. 따라서 역사적 관점에서 보든 내용적 측면에서 보든 자의적인 체포로부터 보호를 받을 권리야말로 모든 기본권의 모태라는 것이다.[16]

이러한 문제에서 오늘날의 기본권개념에 지나치게 집착할 필요는 없고, 헌법문서에 성문화되었고, 오늘날까지도 기본권의 발달에 계속적인 영향력을 행사하고 있다면 그것으로 충분하다고 할 것이다. 따라서 세 번째 견해가 타당하다고 할 것이다.[17]

⑵ 인권 및 기본권의 발전

영국의 17세기는 한편으로는 인권발전사에 커다란 영향을 끼친 3명의 위대한 국가철학자 겸 법학자(코크, 밀턴, 로크)를 배출했는가 하면, 다른 한편으로는 커다란 역사적 의미를 가지는 3가지 헌법문서(권리청원, 인신보호령, 권리장전)를 남겼다.

1628년 영국의 의회는 왕의 자의적인 통치에 대하여 대헌장을 내세워 신민의 자유와 권리를 재확인하는 '권리청원'(Petition of Right)에 대한 승인을 찰스1세로부터 얻어냈다. 권리청원은 코크가 기초한 것으로 특히 의회의 동의 없는 과세와 자의적인 체포를 금지하였다.

1679년 찰스2세가 서명한 '인신보호령'(Habeas Corpus Act)은 문서로 된 체포영장 없이는 영국신민의 인신을 체포하는 것을 금지하였으며, 체포된 자는 늦어도 30일 이내에 법관에게 구인되어 그 체포가 허용되는 것인가의 여부를 심사할 것을 명하고 있다. 따라서 인신보호령의 가장 중심적인 의도는 빠른 시일 내에 해당 법관에게 출두할 수 있는 구속된 자의 권리를 분명히 하기 위한 것이었다.

1689년 12월 16일의 '권리장전'(Bill of Rights)은 1688/89년의 무혈 명예혁명의 결과였다. 즉, 의회의 동의 없이 법률을 제정하거나 폐지하는 것을 금지하였고, 대표자를 자유로운 선거에 의해 선출할 것 등을 규정하였다. 이로서 통치자의 권력은 매우 제한되게 되었다.

1690년에 로크(J. Locke : 1632년~1704년)는 시민정부이론(Two Treatises on Civil Government)에서 인권에 대하여 최초로 학문적인 서술을 함으로써 기본권을 체계화시켰다. 이후, 블랙스톤(William Blackstone : 1723년~1780년)이 로크의 사상을 계승하여 신분적 특권을 영국인의 일반적 권리로 만든 '인신보호령'과 '권리장전'의 이론적 기초 및 이러한 권리보장이 가지는 정치적 결과를 정리하였다.

⑶ 인권 및 기본권의 특색

영국의 헌법발전과 기본권발전에 있어서 본질적인 점은 대정부투쟁과 종교투쟁의 결과 일반적인 권리와 자유를 개인에게 국민의 권리로서 보장하고 그를 위하여 국가권력을 제한한 것이

---

15) K. Löw, a. a. O., S. 58; 대헌장을 헌법적으로 보장된 기본권의 선구자로 파악하기도 한다(P. Badura, Staatsrecht. Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 1986, S. 64).

16) M. Kriele, a. a. O., S. 133.

17) 홍성방, 「헌법학」(상), 박영사, 2013, 256면.

었다. 이러한 자유권의 보장과 국가권력의 제한은 후세 모범이 되었으며, 그 이후의 모든 인권 발전에 영향을 주었다.

2. 미국에서의 전개

(1) 인권 및 기본권 전개

영국의 인권선언이 신분적 자유와 권리를 개별 헌법문서에 보장한 것과는 달리 미국에서는 천부불가침의 자연권을 선언하고 근대적 의미의 기본권목록을 최초로 헌법전에 성문화하였다.

전문 16개 조항으로 구성된 1776년 '버지니아권리장전'(Virginia Bill of Rights)은[18] 천부불가양의 권리(inherent, unalienable rights)에 대하여 언급하고 있다. 따라서 버지니아 권리장전은 전국가적 자연법사상에 기초한 기본적 인권을 확인한 최초의 기본권목록으로 평가된다. 주요내용으로는 제1조에서 사람은 '생래의 권리'(inherent rights)를 가지며, 그것은 전국가적인 권리라는 것이며, 제2조에서 주권은 국민에게 있고, 제3조에서 정부가 그 목적에 반할 때에는 혁명권이 인정되며, 제4조에서 특권이나 세습은 부정되며, 제8조~제11조에 공정한 형사소송절차와 배심제도를 보장하고, 제12조에서 언론의 자유를 인정하며, 제16조에 종교의 자유 등을 규정하였다.[19]

1776년 7월 4일의 '미국독립선언'(Declaration of Independence, The Unanimous Declaration of the Thirteen United States of America)은 엄격한 의미에서 인권선언의 성격을 가지는 것은 아니었다. 그러나 로크가 주장한 자연법사상에 기초한 자유주의적 국가관을 공표한 것으로 자연권적 인권의 승인, 국가계약설, 국민주권, 혁명권 등을 선언하고 있다. 특히, 둘째 절에서 "우리는 자명의 진리로서 모든 인간은 평등하게 창조되고 조물주에 의하여 일정한 양도될 수 없는 권리를 부여받고 있으며, 그 가운데 생명·자유와 행복추구가 포함되어 있는 것을 믿는다. 그리고 이 권리를 확보하기 위하여 사람들 사이에 정부가 설정되었다는 것, 정부의 정당한 권력은 피치자의 동의에 유래하는 것임을 믿는다. 어떠한 정부의 형식도 이들 목적을 파괴하는 것으로 될 때에는 그것을 변경 또는 폐지하고 그들의 안전과 행복을 가져오기에 가장 적합한 원리에 기하여 또 그러한 형식으로 권력을 조직하여 새로운 정부를 만드는 것은 인민의 권리이다"라고 선언하였다.

1789년 9월 17일에 제정된 미연방헌법은 처음에는 권리장전에 대한 부분이 없었으나 발효 직후인 1791년에 권리장전에 해당하는 수정헌법 제1조~제10조를 증보하였다(Federal Bill of Rights). 그 주요내용은 종교·언론·출판·집회의 자유, 신체의 자유, 적법절차, 사유재산의 보장 등으로 버지니아권리장전에 선언된 것과 거의 비슷한 것이었다. 그 후, 시대의 변화와 더불어 수정헌법 제5조의 적법절차조항을 주(州)에도 적용하도록 한 것은 미국의 인권보장사에 중요한 계기를 부여하였다.[20]

---

18) 버지니아에서는 1776년 6월에 세계최초의 것으로 유명한 '인권선언'(Bill of Rights)을 채택하고 그 직후 '헌법'(Constitution)이라는 이름을 붙인 통치기구에 관한 기초적 규정을 채택하였다. 즉, 버지니아에서는 별개의 문서로 된 인권선언을 채택하고, 통치기구의 기초적 규정을 제정하였다. 보통 두 개를 포함하여 '버지니아헌법'이라고 한다(한동섭, 「헌법」, 박영사, 1969, 73면). 이 후, 펜실베니아헌법은 기본권과 통치조직의 두 부분으로 구성된 최초의 근대적 의미의 헌법을 탄생시켰다.

19) Fr. Hartung, Die Entwicklung der Menschen und Bürgerrechte von 1776 bis zur Gegenwart, 4. Aufl., 1972, S. 41ff.

20) 조지형, 「미국헌법의 탄생」, 서해문집, 2012 참조.

⑵ 인권 및 기본권의 특색

미국의 제인권선언의 사상적 기초로서는 종교개혁과 그 후의 신앙자유의 투쟁, 인간주의와 국가계약설에 의하여 전형적으로 표현되는 자유주의국가관에 기초한 자연권사상이다.[21] 프랭클린은(Benjamin Franklin : 1706년~1790년) "사상의 자유가 없다면 지혜는 존재하지 않는다. 그리고 언론의 자유가 없다면 공적자유도 존재하지 않는다"고 하였다.[22] 그리고 제퍼슨(Thomas Jefferson : 1743년~1826년)은 "나는 다수의 인간은 등에 말안장을 지고 태어났고, 소수의 선택된 자들은 신의 은총을 입어 다수의 인간의 등 위에 올라탈 권리를 가지고 장화와 박차를 가지고 태어났다고 생각하지는 않는다"고 하였다.[23]

미국의 인권선언 또는 기본권규정에서 다른 나라에서는 볼 수 없었던 특이성을 볼 수 있다. 그것은 권리장전과 헌법이 의회가 아닌 특별한 회의체에서 통과되었으며, 그 개정은 입법부로부터 구별되는 헌법개정기관에 의해서만 가능한 것으로 간주됨으로써 헌법의 우위가 확립되었다는 것이다.

헌법은 '최고법'(paramount law)의 우위가 확보된 결과 위헌법률을 내용적으로 심사할 수 있게 되었다. 실제로 미연방대법원은 1803년 Marbury v. Madison, 1 Cranch 713, 1803에서 위헌법률심사권을 행사하였다.

이렇듯 위헌법률심사를 제도화한 것은 미국인들이 식민통지하에서 보낸 경험의 산물로서 의회도 국민에게 부정을 행할 수 있다는 것을 영국의회제정법으로부터 배운 결과입니다. 그래서 그들은 헌법에 규정된 기본권들이 정부뿐만 아니라 의회다수파에 의해서 침해되는 것을 방지하고자 한 것이다.[24]

3. 프랑스에서의 전개

⑴ 인간과 시민의 권리선언

18세기 프랑스에는 입헌운동과 자유주의운동에 동기를 부여한 통찰력이 풍부한 냉소주의자 볼테르(Voltaire : 1694년~1778년)와 국가권력을 3분할할 것을 정치적으로 주장한 몽테스키외(Montesquieu : 1689~1755년), '사회계약론'에서 불가양의 국민주권과 개인의 자유가 사회계약의 목적이라 주장한 루소(Rousseau : 1712년~1778년)와 기본권이라는 용어의 성립에 절대적 영향력을 미친 미라보(Mirabeau : 1715년~1789년)가 있었다.

이러한 사상의 영향을 받은 프랑스 국민의회는 1789년 8월 26일 '인간과 시민의 권리선언'을 선포하였으며, 이는 인간성(자유, 평등, 형제애)에 대한 것이었다. 라파예트(Marquis de la Fayette : 1757년~1834년)가 제퍼슨의 도움을 받아 작성한 전문 17개 조항으로 구성된 인권선언 전문에는 인권의 자연권성, 불가양성, 신성성을 선언하는 것으로 시작된다. 주요내용은 제1조에서 인간은 자유이고 평등한 존재로서 출생하고 존재한다. 제2조에서 모든 정치적 결사의 목적은 인간의 '소멸되지 아니하는 자연의 권리'를 보호하기 위한 것이다. 제3조에서 국민주권의 원리, 제6조에서 법률은 일반의지의 표현, 제10조에서 종교의 자유, 제11조에서 언론의 자유, 제16조에서 권리의 보장과 권력의 분립은 근대적 헌법의 필수적 내용이라는 것, 제17조에서 재산권은 신성불가침의 권리이며, 법률로 규정된 공적 필요성을 위하여 사전의 정의로운 보상을 통해서만 침해될 수 있다는 것 등을 규정하였다.

---

21) 한동섭, 전게서, 75면.
22) B. Franklin, Sein Leben von ihm selbst erzählt, 1947.
23) D. Bruce, Von Washington bis Lincoln, 1959. S. 131f.
24) B. Pieroth/B. Schlink, a. a. O., S. 8.

이러한 인권선언은 인권의 자연권성과 불가양성을 거듭하여 강조하고 권력이 분립되지 않은 사회는 자유로운 입헌국가가 아니라는 것을 강조한 이유는 프랑스가 오랫동안 절대군주의 전제지배하에 있었기 때문이었다.[25] 또한, 인권선언은 2년 후에 제정된 1791년 프랑스헌법에 편입되어 헌법의 구성요소가 되었다.

프랑스 인권선언은 미국의 인권선언과 많은 공통성을 보이고 있다. 그러나 프랑스의 역사적 여건이 미국과는 달랐기 때문에 구체적인 내용에서는 차이가 드러난다. 그리고 미국의 인권선언의 표현보다 한층 진보되어 수미일관되게 논리적으로 철저하게, 보편타당하고 간결하게 표현되었다고 한다.[26]

⑵ 인간과 시민의 권리선언 이후

1791년 프랑스헌법은 정치적 결사(국가)의 궁극적인 목적은 프랑스 국민에 한정되지 않는 모든 인간의 자연적·절대적 인권을 보장하는 데 있다는 것을 명시적으로 규정하였다. 따라서 1789년 선언된 권리 이외에도 거주·이전의 자유, 결사권, 청원권 및 언론의 자유와 예배의 자유가 추가되었다.

1793년 헌법은 인권의 자연성, 불가양성을 강조하면서 35개 조항의 인권목록을 규정하였다. 그러나 당시의 난국타개를 위해 혁명정부의 독재가 필요하다고 하여 평화가 도래할 때까지 시행이 보류되었다. 나아가 공안위원회의 독재를 정당화하는 수단으로 전락하였다. 그 결과 단두대와 공포정치가 이어져 이 기간 동안 프랑스는 왕정하에서 보다 더 자유롭지 못하게 되었다.[27]

1795년 8월 22일의 제1공화국 헌법에서는 기본권의 수가 축소되어 22개 조항의 권리와 9개 조항의 의무가 규정되었고, 그 성격도 보수적으로 변하였다.[28] 이는 신분질서와 특권질서가 제거되자 인권에는 정착된 시민질서를 정당화하는 새로운 기능이 주어졌기 때문이다. 그에 따라 이제는 자연적·불가양적 인권이 아닌 공동체 내에서의 권리로 변모하기 시작하였다. 인간은 자유롭고 평등한 권리를 가지고 태어났다는 조항은 법 앞의 형식적 평등으로 대치되었으며, 법원의 절차라는 법치국가적 보장이 강화되었다. 또한, 사회적 의무가 추가되었다.[29]

이 후, 이러한 헌법마저도 나폴레옹의 쿠데타로 폐기되고, 1799년 12월 13일의 헌법에는 기본권에 대한 규정이 아예 제외되었다. 나폴레옹의 몰락 후, 1814년 6월 4일의 헌법에는 기본권 규정이 있었으나 왕정복고헌법이라는 성격상 그 내용은 보수적인 것이었다.[30] 그 뒤를 이은 1848년 11월 4일 제2공화국 헌법에 규정된 기본권들도 같은 성격의 것이었다.[31] 또한, 1875년 2월 25일 제3공화국 헌법은 아예 기본권규정을 두지 않았다.[32]

프랑스 헌법에서 현대적 의미의 기본권이 채택된 것은 1946년 10월 13일 제4공화국과 1958년 9월 28일 제5공화국에서였다.

---

25) G. Östreich, Die Idee der Menschen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1961, S. 29f.
26) H. Hofmann, Die Grundrechte 1789-1949-1989, NJW, 1989, S. 3177ff.
27) H. Maier, Münchner Katholische Kirchenzeitung, 21. März, 1975, S. 3.
28) Fr. Hartung, a. a. O., S. 57ff.
29) B. Pieroth/B. Schlink, a. a. O., S. 9.
30) Fr. Hartung, a. a. O., S. 61ff.
31) Fr. Hartung, a. a. O., S. 79ff.
32) G. Franz, Staatverfassungen, 1969, S. 299. 396ff.

4. 독일에서의 전개

⑴ 독일의 특수한 상황

독일에는 푸펜도르프(Samuel Purfendorf : 1632년~1694년), 토마지우스(Christian Thomasius : 1655년~1716년), 볼프(Christian Wolff : 1679년~1754년)과 같은 자연법 사상가들이 있었다.[33] 그러나 이들의 자연법사상이 독일의 기본권발전에 기여한 정도는 다른 나라에 비하면 제약된 것이었다. 독일에서는 18세기 중반까지만 하더라도 절대주의 국가건설이 문제되었기 때문에 그 때가 돼서야 지배를 제한한다는 사상이 나타나게 되었다. 그러나 그것도 지배자의 도덕적 의무를 통한 자기구속의 형태였다. 절대적인 효력을 가진 인권사상은 18세기 말에야 유럽 다른 나라들의 수준에 도달하였다. 그리고 이러한 생각도 19세기에는 입헌주의라는 독일 특유의 현상으로 다시 후퇴하였다.[34]

또한, 독일은 1789년 프랑스혁명과 인권선언이 혁명 후의 공포정치로 인해 부정적이라는 인식을 가지게 되었다. 오히려 독일의 시민계급들은 국민이 국가권력의 행사에 참여할 것과 전독일이 민족국가로 통합될 것을 요구하는 시기였다.

⑵ 인권과 기본권의 전개

독일에서의 인권발전의 실마리는 1807년 나폴레옹에 의해 세워진 베스트팔렌왕국이 프랑스 헌법을 모방하여 헌법을 제정하면서 종교의 자유와 평등규정을 규정한대서 비롯된다.[35] 나폴레옹 몰락 후, 프랑스에서 제정된 1814년의 왕정복고헌법의 영향을 받아 남독일의 몇 개 지역에서 헌법을 제정하였는바, 1818년 5월 26일 바이에른헌법은 흠정헌법이었고,[36] 1818년 8월 22일 바덴의 대공국헌법은 협약헌법이었다.[37]

그러나 이러한 헌법들에 규정된 기본권들은 국가 이전의 권리가 아니라 신민의 권리에 지나지 않았다. 즉, 이러한 권리들은 오래전 독일적 전통, 자유는 국가에 의해서만 보장될 수 있다는 생각을 반영한 것이 지나지 않는다.[38] 따라서 이러한 헌법들에 규정된 기본권들은 근대적 의미의 기본권과는 거리가 멀고, 한정된 지역에서 제정된 것으로 큰 의미를 가진다고 보기는 어렵다.[39]

나폴레옹 몰락 후, 유럽은 1815년 빈회의를 통해 복고세력에 의한 새로운 질서가 형성되었다. 그러나 이 질서는 자유주의 시민세력과 계속해서 갈등을 일으키게 되고, 독일에서도 1848년 자유주의자들의 혁명으로 프랑크푸르트 국민회의가 소집되었다. 그 결과 1849년 3월 28일 프랑크푸르트헌법에서 '독일국민의 기본권'이라는 표현을 처음으로 사용함과 동시에 자유주의적 기본권을 60개 조항에 달하는 포괄적인 것으로 목록화하였다. 주요내용은 매우 진보적인 것으로

---

33) 인간이 만든 실정법에 대하여 보다 고차원적인 판단기준인 자연법이 존재한다고 주장하는 이론이다. 자연법론자들은 실정법과 대립적이며 이들을 평가하는 규범을 제공하는 이상적 또는 윤리적인 법이 인간들의 일시적인 필요보다 포괄적·일반적·지속적인 어떤 것에 근거하고 있다고 생각한다. 그것은 바로 '자연'에 근거하고 있으며 이에 대한 다양한 해석들 간의 다툼과 인식체계의 변화가 자연법론의 역사를 이루고 있다.

34) B. Pieroth/B. Schlink, a. a. O., S. 7f.

35) E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgechichte Bd. Ⅰ, 2. Aufl., 1960, S. 88ff.

36) 군주의 단독 의사로 제정된 헌법으로 1814년 프랑스 헌법, 19세기 독일 헌법, 일본의 메이지 헌법 등이 이에 속한다.

37) 군주와 국민의 합의에 의하여 제정된 헌법으로 흠정헌법과 민정헌법의 중간에 해당한다.

38) E. R. Huber, a. a. O., S. 312ff.

39) 홍성방, 전게서, 263~264면 참조.

평등권, 거주이전의 자유, 영업의 자유, 언론의 자유, 출판의 자유, 재산권 등이 보장되었을 뿐만 아니라 출국의 자유(제136조), 외교관에 대한 보호(제189조)도 규정하였다.

또한, 이들 권리들에 대한 제한은 헌법에 명시적으로 인정한 경우에만 가능하도록 하고, 헌법소원에 대해서도 규정하였다.[40] 그러나 발효되고 못하고 1851년 폐지되었으나 1919년 바이마르헌법에 큰 영향을 미쳤다.

1850년 1월 30일 프러시아헌법은 기본권규정을 두었으나 흠정헌법이었고, 1871년 비스마르크헌법은 기본권목록을 수용하지 않았다. 이는 독일통일에 필요한 실용적인 조항만을 수록하고 통일에 방해되는 내용은 규정하지 않았기 때문이다.

1919년 바이마르헌법에서 비로소 모든 기본권을 규정하였고, 사회적 기본권을 최초로 규정하였다. 이 후, 나치정권에 의해 유린된 기본권은 1949년 5월 23일 제정된 독일기본법 제1조에서 인간의 존엄성을 규정하고 국가와 국가권력은 인간의 존엄성존중을 위해 존재한다는 것을 규정하였다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 1787년 미연방헌법에 규정되어 있지 않은 것은?

① 기본권보장에 관한 규정
② 행정부에 관한 규정
③ 입법부에 관한 규정
④ 연방과 주에 관한 규정
⑤ 사법부에 관한 규정

[정답] ①
[해설] 처음에는 권리장전에 대한 부분이 없었으나 1791년 추가되었다.

2. 다음 중 프랑스 인권선언에 포함되지 않은 것은?

① 종교의 자유
② 법 앞의 평등
③ 국민주권의 원리
④ 일반의지의 표현으로서 헌법
⑤ 권력분립

[정답] ②
[해설] 법 앞의 평등은 1793년 헌법에 처음으로 규정되었다.

3. 권리의 보장이 확보되지 아니하고 권력분립이 규정되어 있지 않은 사회는 헌법을 가진 것이 아니라는 규정을 둔 것은?

① 대헌장
② 미국수정헌법 제1조
③ 프랑스인권선언
④ 바미마르헌법
⑤ 세계인권선언

---

40) K. Löw, a. a. O., S. 71f.

[정답] ③
[해설] 제16조의 내용이다.

♣ 요점정리

1. 기본권을 헌법문서에 성문화된 권리라고 규정한 최초의 기본권은 1679년 '인신보호령'(Habeas Copus Act)이다.

2. 버지니아 권리장전은 전국가적 자연법사상에 기초한 기본적 인권을 확인한 최초의 기본권목록으로 평가된다.

3. 미국의 인권선언 또는 기본권규정에서 다른 나라에서는 볼 수 없었던 특이성은 권리장전과 헌법이 의회가 아닌 특별한 회의체에서 통과되었으며, 그 개정은 입법부로부터 구별되는 헌법개정기관에 의해서만 가능한 것으로 간주됨으로써 헌법의 우위가 확립되었다는 것이다.

4. 프랑스 인권선언에서는 인권의 자연권성과 불가양성을 규정하고, 권력이 분립되지 않은 사회는 자유로운 입헌국가가 아니라는 것을 강조하였다.

5. 1919년 바이마르헌법에서 사회적 기본권을 최초로 규정하였다.

제3강 사회권적 기본권

♣ 학습목표

사회적 기본권의 등장과 전개를 설명할 수 있다.
프랑스에서의 역사적 전개를 설명할 수 있다.
영국에서의 역사적 전개를 설명할 수 있다.
독일에서의 역사적 전개를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

사회적 기본권의 등장과 전개
프랑스 대혁명, 자코뱅당 헌법초안
영국의 차티즘운동
프랑크푸르트헌법, 바이마르헌법
그리스도 교회의 사회윤리

♣ 사전테스트

1. 1789년 8월의 '인간과 시민의 권리선언'은 자유·평등·형제애라는 프랑스 대혁명의 3대 구호와 함께 사회권을 언급하고 있다.
정답 : X
해설 : 1789년 8월의 '인간과 시민의 권리선언'은 자유·평등·형제애라는 프랑스 대혁명의 3대 구호에도 불구하고 전적으로 자유권만을 수용했을 뿐 사회권에 대해서는 전혀 언급하고 있지 않다.

2. 1776년 2월의 프랑스 루이 16세의 포고문에서 근로를 청구할 권리를 선언했다.
정답 : X
해설 : '근로를 청구할 권리'라는 표현 대신에 '근로에의 권리'와 직업의 자유를 선언했다.

3. 최초의 사회권에 대한 헌법규정들은 적극적 권리로서 사회권을 규정하였다.
정답 : X
해설 : 최초의 사회권에 대한 헌법규정들은 구체적으로는 아무것도 보장하지 않고 그 구체화와 실현을 입법과 행정에 위임하고, 의무를 선언하는 데 그친 강령규정에 지나지 않았다.

♣ 돌발퀴즈

바이마르헌법은 사회적 권리를 전통적인 시민권과 융합시키는데 성공하였다.

[정답] X
[해설] 바이마르헌법이 시도한 사회적 권리를 전통적인 시민권과 융합시키려는 헌법적 시도는 실패하였다.

♣ 강의내용

1. 등장과 전개

사회권은 산업사회의 등장에 따라 새로운 시대를 특징짓는 법 발전 단계이다. 전통적인 시민권 일반과 마찬가지로 사회권도 기존의 사회질서와 '정의의 명령의 집대성'인 자연법사상 사이의 투쟁의 한 부분이고, 이러한 사회권의 문제점은 언제나 위기시에는 시야에 들어왔다가 안정기나 회복기에는 사라진다는 것이다.[41]

사회변화가 법에 영향을 미친다는 것은 일반적으로 인정되고 있다.[42] 기술적, 경제적, 사회적 변화는 많은 경우 형성적 영향력을 발휘하는 매개체로서 법체계에 작용한다.[43] 공동생활의 변화된 규범이 주는 점증적인 압력 때문에 생활사실과 법 사이에는 깊은 간격이 형성되게 된다. 그렇게 되면 법은 그러한 간격에 대하여 대응하지 않으면 안 된다. 사회가 변화하면 정의에 대한 새로운 가늠자가 필요해지게 된다. 법이 가지는 형식상의 불의나 모순은 시정되어야 한다.[44]

그러므로 끊임없이 기술·경제상의 새로운 발전과 법과 사회의 일반적 견해에 적응하도록 법정책적 고찰이 요구된다.[45] 사회질서의 가장 중요한 도구라는 자신의 기능을 제대로 수행하고자 하는 한 법은 사회변화를 항상 염두에 두지 않으면 안 된다.[46]

그렇다면 사회권을 등장하게 한 사회변화는 어떤 것인가 또는 어떤 변화가 반영되어 있는가라는 질문에 사회학은 더 자세한 대답을 할 수 있을 것이나 법학적 관점에서는 사회권에는 여러 인권선언 이후 사회적 대변혁, 즉 기술과 산업적 분업, 인구의 증가, 독점자본주의의 등장. 세계경제의 흥망, 양차 세계대전, 환경오염 그리고 중립적 권력인 국가에 부여된 통합역할 등이 시대의 사회상황에 반영되어 있다.[47]

2. 프랑스에서의 전개

⑴ 루이16세의 포고문

사회적 문제가 처음으로 국가문서에 나타난 것은 유럽의 인권문서 중 초기의 것 가운데 하나인 1776년 2월의 프랑스 루이 16세의 포고문에서였다.[48] 이 포고문에서는 동업조합(길드)을 폐지함과 동시에 종농학파의 영향을 받아 근로의 권리를 제일의 가장 신성하고 없어서는 안 될 인권으로 공포하였다. 그러나 이 포고문에 포함된 근로의 권리는 사회권이라 보기보다는 방어권으로 파악하는 것이 오히려 정당할 것이다. 왜냐하면 '근로를 청구할 권리'라는 표현 대신에 '근로에의 권리'와 직업의 자유를 선언했기 때문이다.[49]

---

41) H. Scholler, Die sozialen Grundrechte in der Paulskirche, Der Staat Bd. 13, 1974, S. 51ff.
42) E. Benda, Rechtsstaat im Wandel, AöR Bd. 101, 1976, S. 497ff.(505ff.).
43) Th. Steinmark, Rechtspolitik und sozialer Wandel. Zum Schußgutachten der Kommission für wirtschaftlichen und sozialen Wandel, ZRP, 1977, S. 170ff.
44) W. Freidmann, Recht und sozialer Wandel, 1969, S. 32.
45) Th. Steinmark, a. a. O., S. 171.
46) W. Freidmann, a. a. O., S. 7.
47) K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 18. Aufl., 1991, S. 85ff.(Rndr. 207ff.).
48) P. Krause, Die Entwicklung der sozialen Rechte, in : G. Birtsch(Hrsg.), Grund und Freiheitsrechte im Wandel von Gesellschaft und Geschichte. Beiträge zur Geschichte Grund und Freiheitsrechte vom Ausgang des Mittelalters bis zur Revolution von 1848, 1981, S. 402ff.
49) P. Krause, a. a. O., S. 403.

⑵ 프랑스 대혁명

1789년 8월의 '인간과 시민의 권리선언'은 자유·평등·형제애라는 프랑스 대혁명의 3대 구호에도 불구하고 전적으로 자유권만을 수용했을 뿐 사회권에 대해서는 전혀 언급하고 있지 않다. 또한, 1791년 9월 3일 프랑스 헌법에서도 마찬가지이다.

1789년 8월의 '인간과 시민의 권리선언'에 사회권이 수용되지 않은 것은 프랑스 국민의회가 원칙적으로 사회권을 경원시했다는 것을 의미하지는 않으나 정치적으로 현실적인 문제를 다루고자 하여 사회권을 제외한 결과이다.[50] 그러나 이러한 움직임에 대해 푸리에(François Marie Charles : 1772년~1837년)는 재산이 없는 자들에게는 자유의 현실적 기초가 결여되어 있다는 것을 지적하면서 사회권을 제외한 것을 비판하였다.[51]

⑶ 자코뱅당의 헌법초안

사회적 문제를 헌법상의 권리로 보장하여야 한다는 생각은 프랑스 대혁명의 주체세력 중 과격주의자들의 헌법초안에서 처음으로 성문화되었다. 즉, 1793년 6월 24일 자코뱅당 헌법초안 제21조와[52] 제22조에서 근로의 권리, 공적구호 청구권, 교육을 받을 권리 등을 처음으로 규정하였다.[53] 특히, 제21조는 지롱드당의 헌법초안 제24항과 Herault de Sechelles의 초안을 결합한 것이었다.[54]

이러한 최초의 사회권에 대한 헌법규정들은 구체적으로는 아무것도 보장하지 않고 그 구체화와 실현을 입법과 행정에 위임하고, 의무를 선언하는 데 그친 '강령규정'(Programmsatz)에 지나지 않았다.[55] 뿐만 아니라 이 헌법은 1793년 7월 '사회복지'(salut public)를 명분으로 연기되었고,[56] 급기야는 기본권목록에 사회권을 규정하지 않은 1795년 8월 22일 헌법에 의해 대치되었다. 이 후, 나폴레옹 헌법은 사회권을 규정조차하지 않았고, 왕정복고기에도 마찬가지였으며, 1848년까지 계속되었다.[57]

그러나 1793년 자코뱅당 헌법초안은 로베스피에르(Robespierre : 1758년~1794년)의 '인간과 시민의 권리선언초안'과[58] 더불어 1830년 프랑스 7월 혁명 이후 시기의 프랑스와 독일의 기본권 논의에 영향을 미쳤으며, 독일의 사회운동에 영향을 끼쳤다.[59]

⑷ 1848년 프랑스혁명

사회권의 문제는 1848년의 프랑스 혁명기간 중 다시금 정치적 논의의 대상이 되었다. 사회권의 문제는 이 혁명기간에는 이전에 비해 더 높은 강도로 그리고 다른 방법으로 제기되었다. 즉, 가진 자와 가지지 못한 자의 대립은 개인 사이의 우연한 대립이 아니라 근대자본주의 사회의 필연적 계급구조의 결과로 간주되기 시작하였다. 그와 동시에 가지지 못한 자라는 용어는 노동자와 동의어로 통용되기 시작한다.[60]

---

50) P. Krause, a. a. O., S. 411f.
51) G. Östreich, Die Idee der Menschen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1961, S. 32.
52) 공적구호업무는 신성한 의무이다. 공동체는 근로의 기회를 마련해 주거나 또는 근로의 능력이 없는 자들에게 생계비를 지급함으로써 불행에 빠진 시민을 원조할 의무가 있다.
53) 자유로운 직업선택권, 자유로운 직장선택권, 근로의 권리, 근로무능력시 부조청구권, 강의청구권 등의 사회적 권리들을 포함하였다고 한다(B. Pieroth/B. Schlink, Grundrechte. Staatsrecht II, 1985, S. 9).
54) P. Krause, a. a. O., S. 415.
55) E. Fosthoff, Begriff und Wesen des sozialen Rechtsstsstes, VVDStRL, Heft. 12, 1954, S. 10.
56) B. Pieroth/B. Schlink, a. a. O., S. 9.
57) P. Krause, a. a. O., S. 416ff.
58) 제2조 : 인간의 기본권은 인간의 생존과 인간의 자유를 위한 것이다.
59) P. Krause, a. a. O., S. 416.

1848년 2월 25일 국가가 최저임금과 완전고용 그리고 단결의 자유를 보장하겠다는 훈령이 공표되었다.[61] 그러나 얼마 안가서 공적으로 근로의 기회를 제공하는 일이 완전고용에 턱없이 모자라게 되었기 때문에 자유사회국가는 실패한 것으로 판명이 났다. 1848년 11월 4일의 헌법은 제13조에서 근로의 자유와 영업의 자유를 보장하는 것에 만족할 수밖에 없었다.[62]

그런데 1848년 11월 헌법에 규정된 근로자의 자유와 영업의 자유는 1793년 자코뱅헌법 제21조, 제22조와 마찬가지로 단순한 강령에 지나지 않았다.

3. 영국에서의 전개

영국에서 사회권과 사회입법에 대하여 여러 가지 기여를 한 디스랠리(Benjamin Disraeli : 1804년~1881년)는 1834년 제정된 빈민구호법에 대하여 '가난한 자에 대한 구호는 자선이라는 원리에서 계속되었다. 그러나 그것은 권리라고 말한다'고 하여 사회권에 대해 인식한 정치가가 없었던 것은 아니다. 그러나 영국의 사회권은 차티즘운동에서 다른 나라들과는 다른 방향으로 전개되었다.

19세기 전반기에 초기 자본주의에 그 원인을 찾을 수 있는 빈고(貧苦)와 불의, 부자유(예속)를 처음으로 알게 된 영국의 노동자들은 유럽최초의 거대한 사회운동인 차티즘운동에서 자신들의 권리를 주장하였다. 차티스트들의 주된 목적은 노동자들에게 선거권을 부여하여 스스로를 의회 내에서 대변하게 함으로써 사회변혁의 전제요건을 확보하여 무산자를 정치적으로 해산시키려는 것이었다.[63]

차티즘운동은 영국적 기반위에서 인간의 권리와 시민의 권리가 노동자의 권리와 조화를 이룬 것으로 이러한 점은 후일 새로운 사회·경제질서에 영향을 주었다.[64]

4. 독일에서의 전개

(1) 1848/49년의 프랑크푸르트헌법

독일에서는 이미 1800년에 피히테(Johann Gottlieb Fichte : 1762년~1814년)가 철학자로서 '폐쇄적인 상업국가'(Der geschlossene Handelsstaat)에서[65] 근로의 권리와 실업자에 대한 국가부조를 인정한 바 있다.[66] 그러나 본격적으로 사회권이 논의의 대상이 된 것은 그로부터 반세기가 지난 후이다.

---

60) P. Krause, a. a. O., S. 419.
61) P. Krause, a. a. O., S. 420.
62) Fr. Hartung, Die Entwicklung der Menschen und Bürgerrechte von 1776 bis zur Gegenwart, 4. Aufl., 1972, S. 78ff.
63) P. Badura, Staatsrecht. Systematische Erläuterung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 1986, S. 19.
64) G. Östreich, Die Idee der Menschen in ihrer geschichtlichen Entwicklung, 1961, S. 36.
65) 이는 단순한 법치국가의 관점을 넘어서 모든 사람이 자신의 노동에 의하여 생활할 수 있도록 국가조직이 노동을 창출해 내는 '이성국가'(Vernunftstaat)를 주장하였다. '왜냐하면 모든 사람은 노동과 인간의 존엄에 합당한 생활을 할 불가양의 권리를 가지고 있기 때문이다. 인간은 마땅히 노동하여야 한다. 그러나 마치 가축처럼 일해서는 안 된다' 이러한 목적을 달성하기 위해서 국가는 스스로 수입과 수출을 관장하여야 한다. 이를 폐쇄적 상업국가라 한다. 예컨대, 식품을 균등하게 분배할 것 등을 주장하였다.
66) P. Krause, a. a. O., S. 419.

1848년 5월 18일 프랑크푸르트의 바오로교회에서 회동한 독일국민회의는 독일헌정사에서는 처음으로 사회권을 헌법에 수용하는 문제를 논의하였다.[67] 프랑크푸르트 선의회(先議會)는 몇몇 사회권을 헌법에 수용할 것을 권고하였으나 국민회의 내에서의 토론에 커다란 영향을 준 17인 위원회의 헌법초안에는 사회권에 대한 규정은 제외됐다.[68]

17인위원회에서는 사회권 중 가장 중요한 근로의 권리에 대해서만 최소한의 생활을 보장함으로써 보장되어야 하는 것으로, 또한 생존의 자유로 이해되었으며, 국가는 마지막 피난처라고 하여 약간의 언급만 되었을 뿐이다.[69] 또한, 근로의 권리는 개인의 필요에 근거를 두고 고정적이며 움직일 수 없는 그리고 인간의 법률을 통하여 부여되거나 제한될 수 없는 자연권으로 간주되었다.[70] 이러한 언급을 통하여 국민회의에서는 근로의 권리와 관련하여 특히 생활수단을 가지지 못한 실업자에 대한 사전배려, 생계비청구권 및 근로능력 없는 빈곤자에 대한 배려와 같은 사회권들을 헌법에 성문화할 것이 제안되었다.[71]

이러한 견해에 대하여 국가가 후견인을 자임할 수 없을 뿐만 아니라 그러한 권리를 보장하게 되면 소유를 증대시키려는 동기가 잠들게 될 것이라는 반대견해가 제기되었다. 그런가 하면 몰(Robert von Mohl : 1779년~1875년)은 국가의 원조를 청구할 권리는 직접 소의 대상이 될 수 없을 것이라 하여 국가의 원조를 청구할 권리를 헌법에 수용하는 것에 반대하였다. 그 결과 1848년 2월 9일 회의에서 사회권을 헌법에 수용하려는 제안은 317대 114로 부결되었다.[72]

이러한 결과로 1848년 기본권에 대한 논의가 지연되어 새롭게 국가를 건설하려는 시도가 실패하게 되는 원인이 되었을 뿐만 아니라 기본권의 법적성격이 충분히 인식되지 못했기 때문에 독일의 기본권 발달사에서 커다란 역할을 하지 못하였다. 후버(E. R. Huber)는 '바오로 교회에 모인 국민회의는 사회국가적 개혁이 이미 오래 전부터 사회적 보수주의자와 사회적 자유주의자 및 사회적 과격주의자들 사이에서 활기 띤 논의의 대상이었음에도 불구하고 사회국가적 개혁을 거부하였다'고 비난하였다.[73]

그러나 바오로교회에서 채택된 헌법은 교육제도와 관련해서는 독일청소년의 교육은 강령으로 고양되었으며, 등록금이 부분적으로 면제되어 진일보하였다.[74] 그 결과 초등학교와 하급실업학교에서 무료로 교육을 받을 권리가 1849년 3월 28일 헌법 제157조에 명문화되었다. 무료초등교육은 1850년 1월 30일 프로이센헌법 제25조 제3항에도 규정되었다.[75]

⑵ 바이마르헌법

1) 성립배경

1919년 8월 11일 바이마르헌법은[76] 사회권의 헌법적 수용과 관련하여 결정적인 역할을 수행한 헌법으로 평가받고 있다.[77] 이러한 바이마르헌법은 사회적 요청, 즉 국가의 사회적 과제와

---

67) J. Franke, Das Wesen der Grundrechte von 1948/49 im System der Entwicklung der Menschen und Grundrechte, 1971; H. Scholler, Die Grundrechtsdiskussion in der Paulskirche, 1973.
68) P. Krause, a. a. O., S. 422ff.
69) H. Scholler, a. a. O., S. 66f.
70) H. Scholler, a. a. O., S. 70f.
71) P. Krause, a. a. O., S. 424.
72) P. Krause, Ibid.
73) E. R. Huber, Deutsche Verfassungsgechichte Bd. Ⅰ, 2. Aufl., 1960, S. 777.
74) H. F. Zacher, Freiheits und Sozialrecht im modernen Verfassungsstaat, in : S. -E. Szydzik(Hrsg.), Christliches Gesellschaftsdenken im Umbruch, 1977, S. 75ff.
75) P. Krause, a. a. O., S. 424.
76) Verfassung des Deutschland Reiches vom 11. August 1919.
77) 바이마르헌법은 기본권과 기본의무를 결합시키고, 기본권편의 경제생활에 사회적 기본권을 규정하였다. 그러나 이러한 포괄적인 기본권목록에도 불구하고 제48조 제2항에서 대통령에게 긴급명령권을 부여하고, 긴급명령을 근거로 기본권목록에 열거된 권리, 예컨대 인신의 자유, 의사표현의 자유, 집회의

국민의 사회적 연대성을[78] 권리, 강령, 의무로 규정함으로써 전통적 자유적·민주적 권리들과 융합시키려고 하였다.

이렇듯 기본권적 사고를 사회적 보장과 객관적 질서에 확대시킨 것은 국가의 과제를 사회국가적으로 확장시키려는 것과 직접적인 관련이 있으며, 국가과제의 변천은 개인적 자유의 조건의 변화, 즉 기본권의 변화와 필연적인 관련이 있다.[79]

국민회의의 헌법위원회에서는 소수의 조항으로써 전래된 의미의 기본적 권리들만을 헌법에 수용하자는 견해가 있었으나[80] 1918년 러시아의 '공장노동자와 착취당하는 자들의 권리선언'에 영향을 받은 나우만(Freidrich Naumann)은 반대하였다. 나우만은 1919년 3월 31일 개최된 헌법위원회에서 '국민이 납득할 수 있는 기본권을 규정할 것'울 제안하였다.[81] 그는 정부초안에 포함된 몇 안 되는 권리에 대한 규정들을 골동품이라 하면서 이전 법문화의 박물관에나 전시할 조항이라 하고 '현대의 최신헌법, 즉 1918년 7월 5일 볼셰비키·러시아 헌법이야말로 우리가 지금 작성하려는 헌법의 직접적 상대이다'고 하였다.[82] 따라서 나우만에게는 시대의 필요를 해결하고 혁명사회주의의 결과를 방지하기 위하여 개인주의적 자유주의는 사회적으로 구속을 받는 자유라는 원리를 통해 극복되지 않으면 안 되었다.[83] 즉, 시민적·개인주의적 국민국가도 아니고 볼셰비키적·사회주의적 국민국가도 아닌 '사회적 민주국가'의 헌법을 주장하였다. 그리고 그는 이러한 국가가 성립되지 못한다면 그것은 '우리가 다시 재건하고자 하는 국가의 결함'이 될 것이라 주장하였다.

이러한 나우만의 윤리적·정치적 주장에 대하여 헌법위원회의 법률가들, 특히 바이얼레(K. Beyerle)는 반대하였다.[84] 열띤 논쟁의 결과 처음의 계획과는 반대로 방대한 규모의 바이마르헌법 제2편 '독일인의 기본권과 기본의무'가 성립되었다.[85]

2) 바이마르헌법의 규정

바이마르헌법 전문에서 사회적 진보를 추진한다는 목표를 선언하였다. 그리고 제2편 제2장(공동체생활, 제119조 이하), 제4장(교육과 학교, 제142조 이하), 제5장(경제생활, 제151조 이하)에서 새로운 국가는 더 이상 개인적 자유에 대한 적대자가 아니라 물질적 자유의 보증인으로 그리고 경제적·사회적 영역에서 생활의 형성자로 등장하게 되었다. 그러나 이곳에서 강조해야 할 점은 전통적 기본권 이외에도 사회적 강령과 사회권이 헌법에 자리잡게 되었다는 점이다.[86]

공동체의 생활에 대한 규정들에서는 혼인 외의 자와 혼인 중의 자의 지위를 같게 하고(제121조), 착취와 무보호 상태에서 보호하였다(제122조). 그런가하면 제119조는 서구 헌정사상 처음으로 헌법에 혼인제도를 보장하였으며, 특히 자녀가 많은 가정에 대한 국가적 보호와 배려 및 모성보호청구권을 규정하였다.

바이마르헌법 제2편 제5장 경제생활에서 사회권적 규정들에 대하여 매우 상세하게 규정하고 있다. 그 중에서 중요한 규정은 경제생활의 질서를 통한 모든 사람들의 인간다운 생활보장(제

자유, 결사의 자유 등을 일시적으로 제한하거나 부분적으로 실효시킬 수 있도록 했다는 점에서는 부정적인 측면도 있다(홍성방, 「헌법학」(상), 박영사, 2013, 273면).

78) P. Badura, a. a. O., S. 19.
79) P. Badura, a. a. O., S. 66.
80) G. Östreich, a. a. O., S. 98.
81) P. Badura, a. a. O., S. 66.
82) G. Östreich, a. a. O., S. 98.
83) P. Badura, a. a. O., S. 66.
84) G. Östreich, a. a. O., S. 100.
85) 제1장 개별인, 제2장 공동체생활, 제3장 종교와 종교공동체, 제4장 교육과 학교, 제5장 경제생활로 구성되었다. 제1장과 제2장에는 전통적·자유주의적 시민적 자유권이 규정되었고, 제3장에는 종교의 자유와 양심의 자유, 국가와 교회의 관계, 국교의 부인이 규정되었고, 제4장과 제5장에는 사회적 기본권이 주로 규정되었다.
86) 홍성방, 전게서, 274면.

151조)을 선두로 노동력의 보호(제157조), 근로조건과 경제조건을 향상시키기 위한 적극적 단결권의 의미에서의 단결의 자유보호(제159조), 근로보호와 피보험자 참여하의 사회보장의 구성에 대한 강령(제163조), 근로자에 의한 경제조건과 근로조건의 공동형성(제165조)이 규정되었으며, '제국은 인류 가운데 전체노동계급을 위하여 일반적인 사회권의 최소척도를 추구하는 노동자의 법률관계를 국가 사이에서 조정하는 것을 옹호한다'는 강령(제162조 이하)을 두었다.

3) 평가

이러한 규정들에서 현대의 사회적 요청을 고려하며 자유주의적 법치국가의 자유를 제한하려는 경향이 두드러지게 나타났다. 그럼에도 불구하고 사회적 권리를 전통적인 시민권과 융합시키려는 헌법적 시도는 실패하였다.[87] 바이마르헌법의 기본권들은[88] 한 번도 독일국민의 실제 법생활의 일부가 되지 못했다. 그런가 하면 독일헌법학은 바이마르헌법에 규정된 기본권들을 공동화시키고, 직접적으로 의무를 부과할 수 없는 규정 또는 직접적으로 권리를 부여하지 않는 강령규정 또는 기술적으로 이해되는 행정법적 유형의 규정으로 해석하여 헌법에서 기본권이 가지고 있는 본래의 가치를 떨어뜨렸다.[89] 즉, 개인적 자유를 내용으로 한 기본권규범은 점점 더 법관에 의한 심사권을 인정받음으로써 효력이 강화된데 반하여, 경제적·사회적 권리들은 주로 단순한 강령규정으로 강등되었다. 이렇게 된 이유는 부분적으로는 헌법본문이 원인을 제공하였다. 왜냐하면 자유주의적 자유권들은 오랜 전통과 완성된 도그마틱으로 무장되어 있었기 때문에 정확하게 표현되어 문제없이 적용될 수 있었던 반면, 새로운 규정들은 그러한 전제가 결여되어 있었기 때문에 선언적 효력만을 가졌기 때문이다. 그 밖에도 헌법학은 이 새로운 규정들을 적당하게 이식시키려는 노력을 하지 않았다. 또한, 헌법하위의 법 규정들은 전반적으로 변화에 저항하였다고 한다.

사회적 권리들은 현실적 효력을 가지는 권리라기보다는 오히려 윤리적·정치적 호소에 가까운 것이었으며, 헌법재판을 통하여 제소될 수 없는 것이었다.[90] 그렇기 때문에 사회적 권리들은 간접적인 효력을 가질 수 있기 위하여 또한, 개인에게 주관적 공권을 부여하기 위하여 법률을 통한 구체화가 필요하였다. 그러나 그러한 법률들은 제정되지 못하였다.

5. 그리스도교회의 사회윤리

사회권의 발달에는 그리스도교회의 사회윤리 또한 커다란 영향력을 행사하였다. 즉, 19세기의 사회적 문제에 대하여 그리스도교는 자신의 입장을 표명하지 않을 수 없었는데, 이는 1891년 레오13세 교황의 '노동헌장'으로 나타났다. 이것은 후일 비오11세 교황의 회칙과 '어머니요 교사(1961년)', '지상의 평화(1963년)', '민족들의 발전(1967년)' 등의 여러 회칙에서 확장되고 새롭게 체계화되었다. 이들은 사회정책과 사회배려에 대한 국가의 의무를 강조하였으며, 세계복지국가를 가톨릭 사회윤리의 이념형으로 공포하였다. 그리스도교회의 사회윤리에서는 노동자의 단결권은 자연권으로 이해된다. 이로써 그리스도교의 자연법은 사회의 발전에 따른 시대에 적합한 표현방법을 찾아냈고, 이론과 실무에서 기본권 문제의 모든 영역에 영향을 미칠 수 있게 되었다.[91]

---

87) 바이마르헌법은 사회권과 자유권을 결합시키려는 시도에 있어서만 실패한 것이 아니라 전반적으로 실패한 헌법으로 평가된다. 이는 헌법의 구조상 결함이라기보다는 여러 계층의 국민들이 자신들을 바이마르공화국과 동일시할 준비가 되어 있지 않았기 때문이고, 군소정당의 난립으로 의회가 정부를 구성하는데 필요한 다수를 구성하지 못하였던 것도 원인이 되었다(홍성방, 전게서, 275면).

88) Fr. K. Fromme, Von der Weimarer Verfassung zum Bonner Grundgesetz, 2. Aufl., 1962.

89) B. Pieroth/B. Schlink, a. a. O., S. 13.

90) G. Östreich, a. a. O., S. 38.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 자유주의 헌법들이 가장 늦게 인정한 것은?

① 영리단체의 설립
② 정치결사의 설립
③ 노동조직의 설립
④ 문화단체의 설립
⑤ 종교단체의 설립

[정답] ②
[해설] 정당은 제2차 세계대전 이후 헌법에 규정되기 시작하였다.

2. 다음 중 자유, 재산, 압제에 대한 저항권을 선언한 것은?

① 유엔헌장
② 미국 독립선언
③ 영국의 권리장전
④ 프랑스 인권선언
⑤ 마그나카르타

[정답] ④
[해설] 프랑스 인권선언의 내용이다.

3. 다음 중 바이마르헌법의 규정내용이 아닌 것은?

① 인간다운 생활의 보장
② 단결의 자유보호
③ 노동력의 보호
④ 사회보장의 구성에 대한 강령
⑤ 무료로 교육을 받을 권리

[정답] ⑤
[해설] 1849년 3월 28일 헌법 제157조와 1850년 프로이센헌법 제25조 제3항.

♣ 요점정리

1. 1789년 8월의 '인간과 시민의 권리선언'은 자유·평등·형제애라는 프랑스 대혁명의 3대 구호에도 불구하고 전적으로 자유권만을 수용했을 뿐 사회권에 대해서는 전혀 언급하고 있지 않다.

2. 최초의 사회권에 대한 헌법규정들은 구체적으로는 아무것도 보장하지 않고 그 구체화와 실현을 입법과 행정에 위임하고, 의무를 선언하는 데 그친 '강령규정'(Programmsatz)에 지나지 않았다.

---

91) G. Östreich, a. a. O., S. 103.

3. 차티즘운동은 영국적 기반위에서 인간의 권리와 시민의 권리가 노동자의 권리와 조화를 이룬 것으로 이러한 점은 후일 새로운 사회·경제질서에 영향을 주었다.

4. 바이마르헌법은 경제생활의 질서를 통한 모든 사람들의 인간다운 생활보장(제151조), 노동력의 보호(제157조), 단결의 자유보호(제159조), 사회보장의 구성에 대한 강령(제163조), 근로자에 의한 경제조건과 근로조건의 공동형성(제165조)이 규정되었으며, '제국은 인류 가운데 전체노동계급을 위하여 일반적인 사회권의 최소척도를 추구하는 노동자의 법률관계를 국가 사이에서 조정하는 것을 옹호한다'는 강령(제162조 이하)을 두었다.

5. 자유주의적 자유권들은 오랜 전통과 완성된 도그마틱으로 무장되어 있었기 때문에 정확하게 표현되어 문제없이 적용될 수 있었던 반면, 새로운 규정들은 그러한 전제가 결여되어 있었기 때문에 선언적 효력만을 가졌다.

제4강 기본권의 의의

♣ 학습목표

인권과 기본권을 구별하여 설명할 수 있다.
기본권과 기본가치의 관계를 설명할 수 있다.
국민의 권리와 외국인의 권리를 구별하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

기본권의 개념
인권의 개념
인권의 속성
기본권과 인권의 구별
기본권과 기본가치의 관계
국민의 권리와 외국인의 권리

♣ 사전테스트

1. 기본권과 인권은 서로 대립되는 개념이다.

정답 : X
해설 : 기본권은 인권사상으로부터 비롯된다. 실정헌법에 의하여 개인의 자유와 권리가 보장되면서 국가권력을 제한하는 개인 내지 국민의 권리를 '기본권'이라고 부른다.

2. 1919년 바이마르헌법은 인권을 실정헌법에 최초로 규정하였다.

정답 : X
해설 : 미국의 버지니아 권리장전(1776)에서 인간의 천부적·생래적 인권(자연권)이 실정헌법에 최초로 규정되었다.

3. 한 국가의 구성원인 국민에게 인정되는 권리를 기본권이라고 한다.

정답 : X
해설 : 국민의 권리라고 한다. 기본권에는 인간의 권리와 국민의 권리가 포함된다.

♣ 돌발퀴즈

헌법은 특정의 세계관에 봉사하거나 특정의 세계관을 지지하거나 또는 특정의 세계관에 적대적인 태도를 취하지 않고, 가치에 대해서도 중립적인 태도를 취하고 있다.

[정답] X
[해설] 헌법은 방어적 민주주의, 즉 제8조 제4항과 같은 규정에서 특정 가치를 배격하기도 한다.

♣ 강의내용

1. 기본권의 개념과 인권의 개념 및 속성

⑴ 기본권의 개념

기본권은 협의로는 기본권을 주관적 공권에 한정하여 개별 국민을 위하여 헌법문서, 즉 객관적 법에 포함되어 있는 보장으로 국민들이 국가에 대하여 그것을 존중할 것을 요구하는 경우에 따라서는 사법적인 방법으로 관철할 수 있는 보장이라고 한다.[92] 이러한 협의의 기본권 개념은 헌법이 명시적 또는 묵시적으로 기본권에 인정하고 있는 특정의 법적결과를 결합시킨 것이다. 따라서 협의의 기본권 개념을 법기술적 의미의 기본권 개념이라고도 한다. 우리 헌법학계의 일반적인 기본권개념으로 받아들여지고 있다.

또한, 광의로는 기본권을 비기술적 의미, 즉 필립 헤크(Philipp Heck : 1858년~1943년)의 의미에서 순수질서개념으로 이해한 것이다. 광의의 기본권 개념은 특정의 법적결과를 고려함이 없이 동일한 문제를 발생시키는 부분영역을 총괄한다. 이 경우, 기본권은 '국가에 대한 국민의 관계(또는 지위)를 규율하는 객관적 헌법규범'으로 정의된다.[93]

따라서 기본권(Grundrecht)이란 헌법이 보장하는 개인 내지는 국민의 기본적 권리를 의미한다. 이러한 기본권은 외국인에게도 보장되는 권리(인권)와 국민에게만 인정되는 권리(시민권)가 포함된다.

이러한 기본권은 인권사상으로부터 비롯되는데, 인권이란 인간이 천부적으로 가지는 권리를 의미한다. 고대 그리스에서는 개인을 국가공동체의 단순한 구성분자로 보고, 국가 속의 자유만이 주장되었으나 로마시대에 이르러 개인의 자유에 바탕을 둔 국가론이 정립되었다.[94] 이러한 인권사상은 18세기에 이르러 계몽주의적 자연법론자와 사회계약론자들에 의해 천부적 인권론이 주장되면서 체계화되었다. 그 후 신흥시민계층의 정치적 영향력이 증대되면서 인권의 내용은 점차 헌법전에 수용되었다. 이렇듯 실정헌법에 의하여 개인의 자유와 권리가 보장되면서 국가권력을 제한하는 개인 내지 국민의 권리를 '기본권'이라고 부른다.

미국의 버지니아 권리장전(1776)에서 인간의 천부적·생래적 인권(자연권)이 실정헌법에 최초로 규정되었고, 프랑스 인권선언(1789)에서 재확인되었다.

⑵ 인권의 개념과 속성

1) 개념

인권은 인간으로서 마땅히 가져야 하는 권리를 의미하며, 이러한 인권논의의 근본목적은 개인의 생활에서 항상 존재하는 전형적인 위협행위(국가, 기업조직, 집단 등에 의한 생명, 안전, 재산, 활동, 생존수단 등에 대한 항상적인 심각한 침해)를 방어하고 신체적으로나 정신적으로, 정치적으로나 경제적으로 더욱 안전한 상태에서 인간다운 삶을 영위할 수 있게 하자는 데 있다. 전형적인 위협행위에 대하여 최소한의 사회적 방어장치 역할을 하는 인권은 인류가 지향하는 가치들 중 최저선을 설정해 놓은 것이다.

---

92) B. Pieroth/B. Schlink, Grundrechte. Staatsrecht Ⅱ, 1985, S. 19.

93) A. Bleckmann, Allgemeine Grundrechtslehren, 1979, S. 41f.

94) 키케로(Marcus Tullius Cicero : BC 106~AD 43 : 로마시대의 정치가, 웅변가, 문학가이자 철학자)에 의해 정립되었다(Hans Meier/Horst Denzer, Klassiker des politischen Denkens Ⅰ, Von Plato bis Hobbes, C. H. Beck Verlag, München 2001, S. 69~84.).

따라서 어떤 내용과 가치들을 인권의 대상으로 분류할 수 있는지, 어떤 의무들을 누구에게 할당할 것인지 그리고 이들을 현실에서 어떻게 실현할 수 있는지와 같은 문제들이 인권론의 가장 중요한 쟁점이 된다. 정의의 문제가 '재화의, 또는 이익과 손해의 올바른 배분, 그리고 피해의 올바른 회복'이라고 한다면, 인권의 내용과 범위를 확정하는 문제는 가장 근본적인 재화들과 가치들의 평등한 배분이라는 점에서 '최소한의 정의'의 문제이기도 하다. 이 '최소한의 제도적 정의영역'에 속하는 정의원리들은 도덕적 권리일 뿐 아니라, 이미 그 자체에 '국가에 대하여 제도화해 줄 것을 요구할 수 있는 도덕적 권리'를 포함한다.

예컨대, 어떤 특정한 관점에서 동일한 특성을 갖는 자들을 평등하게 취급하는 것은 평등하다는 것은 무엇보다도 각 개인들의 본질적 가치가 동등하다는 점, 즉 동등한 인간존엄성의 원리에 있으므로 그 정당한 몫을 빼앗기거나 보장받지 못하는 당사자들은 분노를 느끼고, 여러 가지 사회적 불이익을 감수하면서까지 이에 항의하거나 저항하고, 어느 정도 공정한 제3자는 이에 대해 공감을 가지게 되는 도덕적 정당성을 보유하게 된다. 따라서 도덕적 권리란 '도덕적인 관점에서 보았을 때 마땅히 우리에게 주어져야 하는 것'을 지칭하는 것이므로, 권리주장을 할 때 우리는 이미 정당성을 확언하고, 주장하며, 무엇인가를 요구할 마땅한 자격을 가지고 있고, 타인은 이를 수용하고 보장할 의무가 있음을 동시에 표출하고 있는 것이다. 이처럼 도덕적 권리의 언어는 다른 도덕언어들이 가지고 있지 못한 특수한 지위를 누리고 있다.

'최소한의 제도적 정의'를 내용으로 하는 근본적인 도덕적 권리의 범주에 속하는 인권은 법체계의 '최후의 경계'를 이루는 '보편적으로 타당한 정의의 본질적 가치' 또는 '정의의 근본원리들'의 핵심을 구성한다. 이러한 점에서 우리 헌법 제10조에서 말하는 '불가침의 기본적 인권'은 이러한 근본적인 도덕적 권리를 지칭하는 표현이라고 보아도 무방하다. 즉 우리 헌법 체계에 이미 인권의 제도화와 보장에 대한 권리가 들어와 있다는 점을 헌법 제10조가 천명한다고 보면, 우리 사회에서 인권 논의는 더 이상 도덕적인 차원에서만 이루어질 것이 아니라 실정법의 차원에서 제도화될 지위를 가지는 것이므로, 국가와 사회구성원들은 인권을 구체적으로 실현할 의무를 지고 잇다는 인식에서 출발해야 한다고 본다.

2) 속성

가. 권리주체의 보편성과 권리상대방의 일반성

인권은 개인으로서의 모든 인간에게 당연히 부여된 권리로서(자신의 노력이건, 품성이건, 제도적 승인이건 어떤 후천적 기준을 충족함으로서) 획득되는 권리가 아니다. 그리고 인권을 실현하여야 할 의무상대방은 모든 개인뿐만 아니라 집단, 사회, 국가 등을 포함하고 있다.

나. 도덕적 정당성

어떤 규범이 모든 개인에 대하여 정당화 될 수 있다면, 도덕적으로 정당한 규범이다. 어떤 권리의 내용이 긴급하고도 중요하여 모든 개인에 대하여 정당화될 수 있다면 그 권리는 인권이다. 보편적으로 정당하기 때문에 인권은 국가와 사회에 대하여 제도화할 것을 요구할 수 있는 강한 의미의 권리이다. 즉 인권은 실정법적 권리로 곧바로 전환될 수 있고, 전환되어야만 하는 권리이다. 어떤 권리를 보장하는 규범이 법적으로 효력을 가진다면 그 권리는 법적 권리이다. 인권은 그 내용과 효력을 실정법이 '확인'하고, 보장해야 할 의무를 가지는 '준-실정법적 권리'이다.

다. 권리내용의 근본적 중요성

인권의 내용을 이루는 대상은 긴요하고도 근본적인 속성을 가지고 있다. 개인이 인간으로서 가지는 근본적인 이익들과 욕구들이 인권의 대상이 된다는 점에서, 어떤 권리의 대상이 되는 이익과 욕구가 근본적이면 근본적일수록 인권으로서의 정당화는 보다 손쉬울 것이다. 그렇다면 인

간이 신체적 안전, 최소한의 생존, 자주성의 핵심영역보장을 누리기 위해서 반드시 필수적인 '근본적으로 필요하고 긴박한 재화들이나 가치들'이 인권의 내용이 될 수 있을 것이다.

라. 실정법에 대한 우선성

인권은 제도적 권리 및 실정법적 권리에 우선하는 지위를 갖는다. 실정(법)적 권리가 인권형성과 평가의 규준이 되는 것이 아니라, 인권이 실정법적 권리의 내용을 형성하고 평가하는 규준이 된다는 의미에서 인권은 실정법에 대한 우선성이라는 속성을 갖는다. 인권을 침해하는 실정법은 내용상으로 정당하지 못하게 되며, 이 부정당함은 단순히 도덕적 부당함에 지나지 않는 것이 아니라 법적인 성격을 가지게 된다. 즉, '불법적 법률'(국가에 의해서 제정되고 적용되는 실정법이기는 하지만 법은 아니라는 의미)이라는 것이다. 제2차 세계대전이 끝나고 독일의 법철학자 라드브루흐가 나치시대의 법체계와 법률들을 평가하면서 사용했던 이 견해는 인권의 특징을 잡아내는 데 매우 중요하다. 즉, 인권을 의도적으로 침해하는 법률들은 극도로 부정의한 실정법으로서 법이 아니라는 것이다. 이처럼 실정법에 대하여 갖는 강한 우선성이 인권의 속성이라고 할 수 있다.

마. 의무의 관점에서 바라본 인권의 실현

인권이 강한 의미의 청구권이라면 '권리-의무의 대응' 공식에 따라서 국가와 사회구성원들은 청구권의 내용에 대응하는 의무를 지게 된다. 일반적으로 권리의 실현여부는 바로 권리상대방이 그에 대응하는 의무를 이행하는가에 따라서 결정된다. 이는 권리의 문제를 의무의 측면에서 고찰해야 할 필요성이 있음을 나타낸다. 인권 역시 마찬가지이다. 인권의 실현 여부는 인권의 상대방인 다른 사람들이나 국가가 지는 의무들을 어느 정도로, 그리고 어떤 방식으로 수행하는가에 따라서 판별된다.

또한, 법적 권리이든 도덕적 권리이든 현실에서 의미가 있으려면 실현되어야 한다. 즉, 국가는 첫째, 권리보유자의 권리를 침해하지 않을 의무(침해금지의무), 둘째, 다른 사람들이 권리보유자의 권리를 침해하는 것으로부터 권리보유자를 보호할 의무(보호의무), 셋째, 자신의 권리를 침해당한 권리보유자를 구조할 의무(구조의무)라는 삼중의 의무를 진다는 것이다. 만일 국가가 이 세 가지 의무를 온전히 수행하고 있지 않다면, 권리는 보장되고 있지 않다고 보아야 한다.

이처럼 인권보장의 의무에는 소극적 의무뿐 아니라 적극적 의무도 포함된다는 점, 개별적인 행위의 의무뿐 아니라 제도설립의 의무까지도 포함한다는 점을 염두에 둔다면 인권이 인권보장의 제도들을 요구할 권리이기도 하다는 명제를 이해하는 데 어려움이 없을 것이다.

2. 인권과 기본권

보통 기본권은 인권사상의 영향을 받아서 실정헌법에 규정된 개인 내지는 국민의 권리를 의미한다. 기본권은 인권사상에서 출발하였지만 인권의 최소한의 영역이 기본권이라거나 인권이 특정국가에서 규범화된 것이 기본권이라는 견해는 정확한 표현은 아니다. 기본권 가운데는 시민권(국민의 권리)이 포함된다. 이는 한 국가의 구성원인 국민에게 인정되는 권리로서 외국인은 향유할 수 없는 권리를 의미한다. 예컨대, 참정권이 대표적인 시민권이다.

⑴ 대상

기본권은 초국가적인 천부적 인권사상으로부터 시작되었지만, 기본권 가운데는 참정권이나 사회적 기본권과 같이 외국인에게 인정되지 않는 권리가 있으며, 특히 국가의 특수성에 따라서

보편성 없이 도입된 권리도 있다(우리 헌법 제72조와 제130조의 국민투표권). 또한, 망명권과 같이 국민에게는 인정되지 않고, 외국인에게만 인정되는 권리도 있다.

⑵ 실정성

인권이라는 용어는 본래 전국가성, 초실정성을 특징으로 하는데 반해, 기본권이라는 용어는 국가내적, 실정적인 권리를 가리킨다. 결국 기본권이란 초국가 내지는 초실정적인 인권이 특정한 국가의 상황에 적합하게 특정국가의 헌법에 의하여 보장된 인간 내지 국민의 기본적 권리라고 할 수 있다.

⑶ 실효성 및 기속대상

인권은 세계적 통치권의 부재로 인해 사실상 실효성이 의문시되고 있으며, 이른바 '비단망치'라 불리고 있다. 즉, 인권보장은 국제사회와 국가가 지향해야 할 이념으로써 겉은 비단과 같이 화려하지만, 주권국가의 국내문제를 특정 강대국이나 국제기구가 개입하는 망치가 될 위험성을 가지고 있다는 의미이다. 이에 반해 기본권은 한 국가 내에서 모든 국가기관과 국민을 직·간접적, 실효적으로 기속한다.

⑷ 보수성과 개혁성

일반적으로 인권은 현행법질서에서 인정되지 않지만 장래 보장되어야 하는 권리를 의미하여 기존의 법질서를 비판하는 시각에서 사용되기도 한다. 예컨대 양심적 집총거부, 동성결혼, 장애인의 이동권 보장 등이 그것이다. 오늘날 인간은 피부색이나 종교, 성별을 불문하고 누구나 불가침의 기본적 인권을 누린다는 사고가 보편화되고 있지만, 아직도 세계 도처에서 비인간적인 고문과 차별이 자행되기도 한다. 이에 반해 기본권은 기존의 법질서에서 인정되는 권리라는 보수적인 관점에서 사용되고 있다.

⑸ 우리나라의 경우

우리나라는 1988년 제정된 헌법재판소법 제68조 제1항 제1문에서 "공권력의 행사 또는 불행사로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 법원의 재판을 제외하고는 헌법재판소에 헌법소원심판을 청구할 수 있다"고 규정하여 기본권이라는 용어를 처음으로 사용하였으며, 2001년에 제정된 국가인권위원회법 제2조 제1호에서는 인권을 "헌법 및 법률에서 보장하거나 대한민국이 가입·비준한 국제인권조약 및 국제관습법에서 인정하는 인간으로서의 존엄과 가치 및 자유와 권리"라고 정의함으로써 인권의 헌법적 보장에 대한 세계적 추세를 반영하였다.

3. 기본권과 기본가치

⑴ 민주국가헌법의 가치관련성

민주주의 국가의 헌법은 세계관에 대해서는 중립적인 태도를 취하고 있다.[95] 이는 헌법이 특정의 세계관에 봉사하거나 특정의 세계관을 지지하거나 또는 특정의 세계관에 적대적인 태도

95) H. Maier, Grundwerte in Staat und Erziehung, 1977. S. 8.

를 취하지 않는 다는 것을 의미한다. 그러나 헌법은 가치에 대해서는 중립적인 태도를 취하고 있지 않다.

⑵ 기본권과 가치의 관계

기본권과 기본가치가 어떠한 관계를 가지는가에 대해서 전혀 상이하다는 견해에 따르면,[96] 첫째, 기본권이라는 단어는 대략 200년 전, 프랑스 혁명기에 생겨난 것임에 반하여, 기본가치란 표현이 언제 생겨났는지에 대해서는 정확하게 연구된 바 없지만 이 단어가 1920년대에 언급된 것을[97] 입증할 수는 있다. 그러나 기본가치가 사회적 관심의 중심이 된 것은 1970년대 중반의 일이다. 둘째, 기본권은 기본법에 실정화되어 있다.[98] 따라서 누구나 기본법의 기본권이 어떤 내용인가를 알아볼 수 있고, 기본권은 개인적 '임의'로부터 자유로우며, 헌법제정자만이 기본법 제79조 제3항의[99] 한계 내에서 새로운 기본권을 만들어 내거나 기본의 기본권을 수정하거나 폐지할 수 있다. 그에 반하여 기본가치가 추구하는 목표는 헤아릴 수 없고, 누구든지 자기 나름의 방식으로 행복할 수 있다. 그러나 기본가치에 대하여는 그것이 언제 존재하는지, 누가 그것을 확정하는지 등에 대해서 폭넓은 합의를 얻어내기 어렵다. 셋째, 기본권은 현저하게 법적인 것인데, 기본권에 대하여 쓴 셀 수도 없이 많은 문헌들에서 기본가치를 언급하는 경우는 거의 없다고 주장하였다.

그러나 첫째, 우리가 기본가치의 개념을 광의로 이해하는가, 협의로 이해하는가와는 무관하게 인간의 존엄이 기본가치에 속한다는 것은 부정할 수 없고, 우리 헌법은 기본권목록 맨 앞에 제10조에서 인간으로서의 존엄과 가치를 선언하고 있을 뿐만 아니라 국가에 대하여 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 부과하고 있다. 둘째, 우리 헌법 제10조가 선언하고 있는 인간의 존엄이 기본가치와 무관한 것이라면 국가에 부과된 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무는 설명할 수가 없다. 셋째, 차별금지와 평등한 취급, 신체의 자유를 비롯한 여러 가지 자유, 재산, 가정과 혼인 등도 중요한 의미를 가지는 가치들인데, 헌법이 이들을 실정화하여 특별히 보호하고 있다. 넷째, 독일연방헌법재판소도 기본법의 '가치질서'(Wertordung), '가치서열질서'(Wertrangordnung), '일반적 가치질서'(allgemeine Wertordnung), '가치체계'(Wertsystem) 등의 표현을 사용하였을 뿐만 아니라 헌법을 통하여 보장된 최고의 '기본가치'에 대하여 판시한 바 있다.[100]

따라서 기본권은 권리이고, 보장이고, 요청이며, 보호하거나 마련해 준다는 의미이다. 그러나 기본권은 보호대상 자체는 아니고 기본권은 기본가치를 보호한다고 할 수 있다.[101]

4. 인간의 권리와 국민의 권리

기본권은 내·외국인을 불문하고 모든 인간에게 인정되는 권리와 국민에게만 인정되는 권리로 구별할 수 있다. 예컨대, 사회권, 참정권, 청구권 등은 국가를 전제로 해서 국가의 구성원인 국

---

96) Th. Schramm, Staatsrecht Bd. II, Grundrechte und ihre verfassungsrechtliche Absicherung, 3. Aufl., 1985, S. 30f.
97) K. Lehmann, Grundwerte und Gottes Gebot, RM 21. 3, 1980, S. 25.
98) 1849년 프랑크푸르트헌법에서 기본권이라는 용어를 처음으로 사용하였다.
99) 연방을 각 지방으로 분할 편성하는 것, 입법에 있어서 지방의 원칙적인 협력 또는 제1조와 제20조에 규정된 원칙들에 저촉되는 기본법 개정은 허용되지 않는다.
100) BverfGE 2, 12.
101) 홍성방, 「헌법학」(상), 박영사, 2013, 296~298면 참조.

민에게만 인정되는 것이므로 인간의 권리라고 보기는 힘들 것이다. 그렇다면 기본권에 실정화된 인권이라는 개념은 존재하기가 어렵다.[102]

이는 법학의 기본적인 두 가지 입장인 자연법론과 법실증주의에 따라 상이한 입장이 있을 것이고, 헌법 문서상으로도 상이하게 판단될 것이다. 첫 번째의 견해에 따르면, 기본권은 국가 이전에 존재하는 것이며, 국가는 그것을 선언하고 인정할 권한만을 가지는 자연적 권리라고 이해하는 것이다. 이는 특히 아우구스티누스(Augustinus : 354~430)가 그의 저서 '신국'(Civitas Dei)에서 기초한 그리스도교 자연법론의 '자연법'과 그리스도교인의 양심의 자유에 대한 종교개혁주의자들의 이론에서 비롯된다. 그에 따르면, 자연법은 세계(현세에 현존하는 '신법'을 의미한다.

그에 반하여 두 번째 견해는 계몽주의 루소에게서 비롯하여 기본권은 헌법에 의하여 보증되는 권리, 즉 국가적 권리라고 이해하는 것이다. 루소는 '일반의지'에 표현된 국가의 의지야말로 국민에게 마치 선물처럼 자유를 보장할 수 있다고 하였다.

이러한 두 가지 견해는 근대초기의 헌법들 속에서 선언된 인간의 권리들을 '자연법적 권리, 양도할 수 없는 권리, 신성한 권리'로 표현되었다. 예컨대, 1791년 9월 30일, 1793년 7월 24일 프랑스헌법 전문에 이러한 표현이 규정되었다. 이것은 자유와 평등의 이념이 정치생활을 강하게 혁명시킨 계몽주의 초기의 일이었다.

그러나 무제한적 낙관주의는 부정적인 영향을 주었는데, 이성을 지나치게 과대평가한 나머지 이성을 모든 것을 투시할 수 있다고 믿게 되었고, 그 결과 다양한 현실 정치적 목표설정과 요구들을 거역할 수 없는 자연질서의 명령으로 주장하게 됨으로써 계몽주의 이성법은 회의주의에 휩싸이게 된다.

따라서 계몽주의의 이성법은 회의주의에 그 자리를 양보하게 되었으며, 법철학과 법실무에서는 계몽주의시대의 자연법이론에 대한 반작용으로 법실증주의가 자리잡게 되었다. 실증주의에 따르면, 인간의 생래의 권리는 없으며, 그러한 권리를 증명할 수도 없다고 한다. 따라서 법실증주의자들은 명시적으로 입법자에 의해 제정된 법만을 인정한다.

결국, 기본권을 인간의 권리와 국민의 권리로 나누는 것은 기본권을 지나치게 수평적으로만 고찰한 결과하는 지적이 있다.[103] 오히려 모든 기본권은 '인권을 핵심'으로 하며 부차적으로 '실정법적 요소'를 가진다고 보아야 한다는 것이다. 그리고 여러 가지 법적결과들을 기본권의 자연법적 핵심에 관련시킬 수 또는 적용시킬 수 있기 위해서는 기본권의 자연법적 핵심과 기본권의 내용을 알게 될 때에만 가능할 것이다. 즉, 어떠한 경우에도 우리 헌법 제10조에 실정화된 '인간의 존엄과 가치'가 자연법적 인권의 핵심내용이라는 것만은 분명하다는 것이다.[104]

나아가 헌법전 내에 규정되어 있는 권리들 가운데서 일반적으로 국민에게만 인정되는 것으로 해석할 수 있는 권리들도 인권과는 관계없이 헌법에 의하여 비로소 창설된 권리라고 할 수는 없는 것이다. 따라서 이러한 권리들을 헌법제정자가 여러 가지 사정을 고려하여 국민인 자만이 그것들을 행사할 수 있도록 주체를 한정한 것으로 해석하면 정당한 것이다. 그것은 비록 기본권의 체계가 역사적으로 근거지어지고 제약을 받는 전체라 하더라고 그 때문에 인권성을 부정할 수 있는 것은 아니라는 주장에 주의를 기울여야 한다.[105] 즉, 자연적 자유와 시민적 자유, 국가로부터의 자유와 국가에의 참여는 상호관련된 것이라는 의미이다.

---

102) 홍성방, 상게서, 298~300면 참조.
103) 홍성방, 전게서, 299면.
104) A. Bleckmann, a. a. O., S. 39.
105) Chr. Link, Menschenrechte und bürgerliche Freiheit, in : Festschrift für W. Geiger, 1974, S. 277ff.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 국민의 권리에 속하는 것은?

① 선거권
② 종교의 자유
③ 양심의 자유
④ 평등권
⑤ 행복추구권

[정답] ①
[해설] 국민의 권리는 대체로 참정권적 기본권, 사회권적 기본권 및 청구권전 기본권이다.

2. 다음 국가와 기본권 보장의 관계에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 국가는 천부적 인권인 기본권을 보장하는데 그 목적이 있다.
② 근대 헌법상의 기본권은 국가권력에 대한 방어적·항의적 권리의 성격이 강하다.
③ 오늘날 국가는 기본권을 침해할 가능성이 있는 존재이기도 하지만 보장할 의무도 있다.
④ 국가권력의 행사는 기본권에 대한 침해가능성을 증가시키므로 국가는 권력행사를 언제나 자제하여야 한다.
⑤ 근대헌법상의 국가는 개인주의와 자유주의가 바탕을 이룬다.

[정답] ④
[해설] 부의불평등, 사회문제 등의 해결에 있어서는 적극적으로 개입하여야 한다.

3. 인권과 기본권에 대한 설명으로 타당하지 않은 것은?

① 우리 헌법에 기본권이라는 용어는 규정되어 있지 않다.
② 인권과 기본권은 동일한 개념으로 이해할 수 없으나 병용되기도 한다.
③ 인권이 인간의 천부적인 권리라면 기본권은 국민의 실정법적 권리이다.
④ 헌법재판소는 EEZ관련 결정에서 기본권이란 용어를 사용한바 있다.
⑤ 정치적 참여권, 청구권적 기본권은 천부인권과 밀접한 관련이 있다.

[정답] ⑤
[해설] 이러한 권리들은 실정권법 권리로서 국민의 권리이다.

♣ 요점정리

1. 실정헌법에 의하여 개인의 자유와 권리가 보장되면서 국가권력을 제한하는 개인 내지 국민의 권리를 기본권이라고 부른다.

2. 미국의 버지니아 권리장전(1776)에서 인간의 천부적·생래적 인권(자연권)이 실정헌법에 최초로 규정되었고, 프랑스 인권선언(1789)에서 재확인되었다.

3. 한 국가의 구성원인 국민에게 인정되는 권리로서 외국인은 향유할 수 없는 권리를 국민의 권리라고 한다.

4. 헌법은 특정의 세계관에 봉사하거나 특정의 세계관을 지지하거나 또는 특정의 세계관에 적대적인 태도를 취하지는 않으나 가치에 대해서는 중립적인 태도를 취하고 있지 않다.

5. 기본권은 내·외국인을 불문하고 모든 인간에게 인정되는 권리와 국민에게만 인정되는 권리로 구별할 수 있다.

제5강 기본권 이론과 기능

♣ 학습목표

기본권 이론을 설명할 수 있다.
기본권의 기능을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

법실증주의, 결단주의, 통합주의
제도적보장론
주관적 공권
객관적 가치질서
기본권의 양면성

♣ 사전테스트

1. 법실증주의이론에 의하면 기본권은 국가에 앞서 선재하는 것이다.

정답 : X
해설 : 기본권은 헌법에 규정되어야만 비로소 권리로 인정된다.

2. 켈젠은 기본권의 권리성을 인정하였지만 지배의 주체로서의 국가와 복종의 주체로서의 개인을 전제로 하여 이론을 전개하였다.

정답 : X
해설 : 옐리네크의 견해이다.

3. 스멘트는 자유를 구체화하고 실현하는 법제도가 없이는 자유는 마치 법적으로 공허한 공간에 지나지 않기 때문에 자유는 어디까지나 제도적인 법적 개념으로 파악해야 된다고 한다.

정답 : X
해설 : 해벌레의 견해이다.

♣ 돌발퀴즈

기본권의 객관적 가치질서라는 것은 필요한 경우에는 소송을 통하여 객관적 법을 관철할 수 있는 힘을 의미한다.

[정답] X
[해설] 기본권의 주관적 공권이란 개인이 국가를 상대로 자신의 자유와 권리를 위해 국가의 부작위와 작위를 요구할 수 있는 권리를 뜻한다.

♣ 강의내용

1. 기본권이론

⑴ 법실증주의

19세기의 실증주의의 영향을 받아서 헌법학의 대상을 실제로 경험 가능한 실정법에 한정하고, 초국가적으로 보편타당한 자연법을 부정하는 견해이다. 즉, 법실증주의의 일차적인 목표는 현재 존재하는 실정법을 근거로 하여서 헌법학의 객관성을 담보하는 데 있으므로 모든 자의적인 법해석을 배제한다. 즉, 법실증주의는 기본권의 실정법 속에서의 자유라는 점에 중심을 두고 있으므로 기본권은 헌법에 규정되어야만 비로소 권리로 인정되므로, 기본권도 국가에 의해 창설되었을 때에만 효력을 갖는다고 본다.

또한, 기본권이 국가권력을 제한하는 것이 아니라 국가권력의 범위 안에서 효력을 갖으며, 기본권은 국가권력을 위하여 존재할 수 있다.

1) H. Kelsen

자신의 순수법론에서 실정법에 관한 일반이론을 구축하는데 목적을 두었으므로 실정법에 대한 일체의 철학적·정치적·역사적·사회적 고찰을 배격하였다. 그의 이론은 순수히 존재하는 법규범에 관한 체계적인 파악에 초점을 두어서, 법의 정당성의 문제에는 관심을 두지 않았다. 따라서 국가란 법질서 그 자체이기 때문에 국민과는 별개의 유리된 완성물일 뿐만 아니라 국가는 법목적이라는 자기목적에 의해 정당화되기 때문에 국민의 자연법적 자유를 존중하고 권리를 보장하기 위한 국가권력의 제한은 있을 수 없고, 국가권력에 의해 허용된 범위 내에서 자유와 권리를 누릴 수 있을 뿐이다.

즉 '국가가 베푸는 은혜로서 자유' 내지 '힘의 자제에 의한 반사적 효과로서의 자유'를 누릴 따름이다. 따라서 켈젠에 의하면 국가로부터의 자유를 요구할 수 있는 권리인 주관적 공권은 있을 수 없게 된다. 이로 인하여 그의 이론은 현실적인 힘의 논리를 정당화시킨다는 비판을 받고 있다. 따라서 국민은 국가의 강제질서에 의해 규제되지 않은 범위 내에서만 자유를 갖으며, 국민은 단지 반사적 이익만을 가질 뿐이라고 한다.

2) G. Jellinek

국가와 개인의 관계를 지배·복종의 관계로 파악한다는 점에서 켈젠과 유사한 경향을 보인다. 그는 '완성된 사실'에 의하여 규범을 만들 수 있다(사실의 규범적 효력)고 하여 힘의 규범정립성을 이론적으로 인정하였다. 국민은 단순히 반사적 이익만을 누리는 것이 아니라, 국가에 대해 일정한 지위를 갖는다는 주관적 공권론을 주장하였다.

옐리네크는 군주주권도 국민주권도 주장할 수 없었던 19세기 독일의 시대적 상황 속에서 일종의 도피이론으로서 국가주권론을 주장하였다. 또한 국가주권론을 주장하기 위한 전제로서 국가법인성을 주장하였다. 그는 기본권의 권리성을 인정하였지만 지배의 주체로서의 국가와 복종의 주체로서의 개인을 전제로 하여 이론을 전개하였으며 개인의 자유는 선국가적인 것이 아니라 국가의 자제에서 나오는 것으로 파악하였다. 켈젠과 같이 국가의 법적 제한 안에서의 자유를 강조하면서도 보다 더 주관적 공권으로서의 성격을 인정하는 방향으로 나아갔다.

이러한 옐리네크의 지위이론에 의하면, 수동적 지위에서는 국민의 국가권력에 대한 복종의 의무가 나오고 소극적, 적극적, 능동적 지위로부터는 국민이 국가권력에 대해 작위 또는 부작위를 요구하거나 국민이 국정에 참여할 것을 요구할 수 있는 '주관적 공권'이 나온다고 한다. 즉, 국민은 원칙적으로 국가 내에서 법질서에 의해서 규제되지 않는 범위 내에서 각자의 자유영역

을 가지는데 이 자유영역을 침해당하지 않기 위해서 국가의 부작위를 요구할 수 있는 이른바 자유권을 가진다고 한다.

또한, 국가의 작위를 요구할 수 있는 주관적 공권은 국가 작용에서 나오는 단순한 '반사적 이익'과는 엄격히 구분해야 된다고 한다. 이처럼 옐리네크는 켈젠과는 달리 국민이 국가에 대해서 주관적 공권을 가질 수 있다는 점을 인정하면서 국민의 자유영역이나 수익권 그리고 국정참여의 가능성을 어느 정도 보장하려고 하는 것은 사실이지만, 사실의 규범적 효력과 국가법인설, 힘의 국가론 등 그의 이론의 일관성에서 문제가 제기된다.

3) 비판

국가란 국민을 떠나서는 존재하는 것도 아니고 또 국민을 떠나서는 그 존재가치도 없다. 국가권력은 이 사회 조직과정에서 비로소 창설되는 것이지 독자적으로 존재하는 것일 수는 없다. 법실증주의적 기본권관은 국민을 국가의 단순한 지배객체나 국가의 단순한 구성요소로 보고 국가를 법질서와 동일시하거나 법인으로 보아 국민의 이해관계를 떠난 것으로 이해함으로써 그 타당성을 인정할 수 없다. 또 자유와 권리를 국가의 부작위에 의한 은혜적인 것 또는 국가권력 자체에서 나오는 단순한 반사적 이익이라고 보는 경우에 기본권은 결국 '통치구조의 장식품'에 불과하다.

⑵ 결단주의

기본권을 초국가적 자연권으로 보아 헌법이전에 인간으로서 가지는 당연한 권리로 파악하여 그 주관적 공권성을 강조한다. 따라서 헌법은 단지 기본권을 재확인한 것이지 권리를 창설한 것은 아니다.

1) C. Schmitt

칼 슈미트에 의하면 기본권은 인간의 천부적이고 선국가적인 자유와 권리로서의 방어권으로 보아, 기본권이 민주주의원리에 의해 지배되는 정치적인 국가작용에 의해서 부당하게 제한되고 침해되는 것을 막기 위해서 비정치적인 법치국가원리가 적용되어야 한다고 한다. 따라서 고유한 의미의 기본권을 자유권으로 이해하여, 기본권의 본질을 '국가로부터의 자유'라고 주장하기 때문에 참정권과 사회적 기본권은 경시하였다. 그러나 칼 슈미트는 법실증주의의 '법률 속의 자유' 개념을 '국가로부터의 자유'의 영역까지 끌어 올린데 그 공이 인정된다.

즉, 슈미트는 헌법을 정치적 구성부분과 비정치적 구성부분으로 구별하고, 각각 민주주의 원리와 법치국가원리가 적용된다고 하면서, 전자를 통치조직의 영역으로, 후자를 기본권의 영역으로 설명한다. 법치국가원리가 지배하는 기본권 영역에서는 국가와 사회의 이원론을 전제로 해서 배분의 원리가 지배한다. 즉, 개인의 자유로운 영역은 국가의 성립 이전부터 존재하는 초국가적인 것이므로 원칙적으로 무제한적인 반면에 이런 자유를 제한하는 국가의 권한은 원칙적으로 제한적이라는 것이다. 따라서 국가권력은 제한적이고, 자유는 무제한적이어서 국가권력에는 한계가 있다는 것이다.

그의 자유권 중심의 기본권관에 따르면 자유권을 초국가적인 인권이자, 천부적이고 선험적(국가이전의 권리)인 권리라고 설명한다. 따라서 결단주의에서 주장하는 기본권은 국가로부터의 자유를 뜻하게 된다(국가에 대하여 인간에 고유한 자유를 방어하는 방어권). 이러한 자유권은 국가(의 침해)로부터의 자유이며, 자유권은 국가의 부작위를 요구하는 권리로서 국가가 침해하는 활동을 하지 않으면 최대한 보장되는 권리라고 설명한다.

참정권, 사회적 기본권은 국가에 의하여 형성된 권리로서 천부적이고 선국가적인 것이 아니라고 하여 자유권 중심의 이론을 펼치고 있다. 천부적인 자유권은 진정기본권이라고 하고 있으며, 실정법에 의해 인정되는 기본권은 부진정기본권이라 하여 양자를 구분한다.

또한, 저항권을 인정하였으며, 치자와 피치자의 동일성을 의제하는 민주주의론(동일성 이론)을 주장하였다.

2) C. Schmitt의 제도보장론

가) 의미

C. Schmitt는 헌법에서 기본권으로 규정하고 있는 경우에도 성질로 보아 자유가 아니라 '공법상의 제도'이거나 '전통적으로 확립된 전형적인 사법상의 제도'를 헌법이 정하고 있는 것이면 이는 진정한 기본권과 구별되는 '제도보장'(institutionelle Garantie)이라고 했다. 그에게서 제도보장의 의미는 공적인 제도(대학의 자치, 복수정당제, 직업공무원제)와 사적인 제도(상속제도, 혼인제도, 사유재산제도 등) 자체의 존립을 입법자로부터 보호하는 것이다.

기본권은 초국가적인 권리로서 그 보장이 무제한한 것이므로 '배분원리'가 적용되지만, 제도보장은 어디까지나 국가의 법질서에 의해서 인정되는 것이므로 '배분원리'는 적용되지 않는다. 제도보장은 입법기관에 의해 법률로서 제한될 수 있으며, 단지 입법자는 제도 그 자체를 폐지하지는 못한다. 헌법상의 제도보장은 최소한의 보장으로서 제도 자체의 폐지를 입법자로부터 보호한다는 점에 헌법상의 의미가 있다.

제도보장은 기본권보장과 같이 집행권과 사법권은 물론 입법권까지도 포함하는 통치권력을 직접적으로 기속하는 효력을 가진다. 그러나 제도보장은 기본권과 같이 헌법개정권력을 기속하지 못한다.

나) 내용

ㄱ. 의미

제도보장이란 객관적 제도를 헌법에 규정함으로써 당해 제도의 본질을 보장하는 것이다. 따라서 입법에 의한 폐지나 본질의 훼손으로부터 이를 보호하려는 데 의의가 있다.

ㄴ. 기본권과 제도보장의 차이

기본권은 주관적인 권리이지만 제도보장은 객관적인 법규범이라 할 수 있다. 제도보장은 특정한 기본권과 연관될 수도 있으나 그 속에 권리를 내포하더라도 법에 의하여 내용이 형성되고 규율되는 국가내적인 것으로서 입법권에 의한 폐지나 본질적 제한을 할 수 없도록 하는 것이다.

ㄷ. 기본권보장과 제도보장의 관계

A. 기본권과 관련이 없이 독자적으로 제도만 보장 : 직업공무원제도, 지방자치제도

B. 기본권과 관련이 있는 유형

① 제도보장의 기본권 수반형 : 기본권보장을 위해 제도보장이 불가피(민주적 선거제도)

② 양자의 보장병립형 : 기본권보장이 특정 제도의 보장을 의미(재산권과 사유재산제도)

③ 기본권의 제도 종속형 : 복수정당제도가 보장됨으로서 부수적으로 개인의 정당설립, 가입, 탈퇴의 자유가 보장된다는 견해도 있다. 그러나 이는 권리와 제도가 병립하는 것으로 보아야 할 것이다.

다) 기본권과 제도보장

우리 헌법재판소는 슈미트의 영향을 받아서 제도적 보장론을 전개한 바 있다.

<헌법재판소 1997. 4. 24. 95헌바48>

헌법 제7조는 공무원의 공무수행의 독자성과 영속성을 유지하기 위하여 공직구조에 대하여 제도적 보장으로서의 직업공무원제도를 마련하도록 규정하고 있다. 제도적 보장은 객관적 제도를 헌법에 규정하여 당해 제도의 본질을 유지하려는 것으로서 헌법제정권자가 특히 중요하고도 가치가 있다고 인정되고 헌법적으로도 보장할 필요가 있다고 생각하는 국가제도를 헌법에 규정함으로써 장래의 법발전, 법형성의 방침과 범주를 미리 규율하려는데 있다. 다시 말하면 이러한 제도적 보장은 주관적 권리가 아닌 객관적 법규범이라는 점에서 기본권과 구별되기는 하지만 헌법에 의하여 일정한 제도가 보장되면 입법자는 그 제도를 설정하고 유지할 입법의무를 지게 될 뿐만 아니라 헌법에 규정되어 있기 때문에 법률로써 이를 폐지할 수 없고, 비록 내용을 제한하더라도 그 본질적 내용을 침해할 수는 없다. 그러나 기본권 보장은 '최대한 보장의 원칙'이 적용됨에 반하여, 제도적 보장은 그 본질적 내용을 침해하지 아니하는 범위 안에서 입법자에게 제도의 구체적 내용과 형태의 형성권을 폭넓게 인정한다는 의미에서 '최소한 보장의 원칙'이 적용될 뿐인 것이다. 이 사건에서 문제된 직업공무원제도는 바로 헌법이 보장하는 제도적 보장중의 하나임이 분명하므로 입법자는 직업공무원제도에 관하여 '최소한 보장'의 원칙의 한계 안에서 폭넓은 입법형성의 자유를 가진다.

<헌법재판소 2005. 3. 31. 2003헌가20>

헌법 제31조 제6항은 교육재정에 관한 기본적인 사항을 법률로 정하도록 하고 있는바, 이는 무상에 의한 교육을 받을 권리의 실효성을 보장하기 위한 최소한의 국가적 책무를 헌법에 정한 것으로서 무상의 의무교육제도가 국민보다는 국가에 대한 의무부과의 측면이 더 강하다는 점을 고려하면, 확보되거나 확보할 일반재정 중 다른 부분을 희생해서라도 헌법과 법률이 정한 의무교육의 무상원칙을 달성하여야 한다는 국가의 의무를 밝힌 것이라고 보아야 한다.

<헌법재판소 1992. 10. 1. 92헌마68등>

헌법 제31조 제4항이 규정하고 있는 교육 자주성, 대학 자율성보장은 대학에 대한 공권력 등 외부세력의 간섭을 배제하고 대학인 자신이 대학을 자주적으로 운영할 수 있도록 함으로써 대학인으로 하여금 연구와 교육을 자유롭게 하여 진리탐구와 지도적 인격의 도야라는 대학의 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 하기 위한 것으로서 이는 학문의 자유의 확실한 보장수단이자 대학에 부여된 헌법상의 기본권이다.

<헌법재판소 2000. 4. 27. 98헌가16, 98헌마429>

헌법 제36조 제1항은 혼인과 가족생활은 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 성립되고 유지되어야 하며, 국가는 이를 보장한다고 하여 혼인 및 그에 기초하여 성립된 부모와 자녀의 생활공동체인 가족생활이 국가의 특별한 보호를 받는다는 것을 규정하고 있다. 이 헌법규정은 소극적으로는 국가권력의 부당한 침해에 대한 개인의 주관적 방어권으로서 국가권력이 혼인과 가정이란 사적인 영역을 침해하는 것을 금지하면서, 적극적으로는 혼인과 가정을 제3자 등으로부터 보호해야 할 뿐이 아니라 개인의 존엄과 양성의 평등을 바탕으로 성립되고 유지되는 혼인·가족제도를 실현해야 할 국가의 과제를 부과하고 있다.

3) 비판

슈미트는 헌법의 구성부분을 임의로 기본권과 통치구조로 양분하여 이념적·기능적 상호 교차관계를 소홀히 했고 기본권의 핵심을 자유권으로 보고 자유권의 본질을 국가로부터의 자유라고 이해함으로써 기본권이 가지는 input기능을 무시했다는 비판을 받는다. 또한, 기본권을 비정치적인 것으로 파악하고 기본권을 비정치적인 법치국가의 헌법적 표현이라고 보는 경우에는 기본권은 '법치행정의 원칙'이 특수화된 '특별한 행정법'에 지나지 않게 되어 기본권이 수행해야할 민주주의적 기능(정치적 기능)이라든지 그 동화적 통합기능은 처음부터 고려 대상이 될 수 없다. 또 기본권의 본질을 국가로부터의 자유라고 보기 때문에 기본권의 대사인적 효력은 애초에 고려해볼 여지조차 없고 기본권이 국가권력에서 나오는 output에 대하여 방어적 기능은 가질지 몰라도 각종 사회적 압력단체에서 나오는 침해에 대해서 속수무책일 수밖에 없다.

⑶ 통합주의(동화적 통합이론)

우리 사회저변의 가치적인 공감대가 바로 기본권의 형식으로 집약된 것이라고 보아야 하기 때문에, 기본권을 단순한 자연권적 성격이라고 파악하기보다는 우리 사회가 통합되어가기 위한 불가결한 전제조건이라고 보아, 기본권의 성격을 국가형성적 기능과 통합 기능에서 찾아야 한다고 주장한다.

1) R. Smend

국가는 다양한 이해관계를 가진 사회구성원이 하나의 정치적인 생활공동체로 동화되고 통합되어가는 부단한 '과정'이라고 이해하는 스멘트의 관점에서 볼 때, 헌법은 통합의 생활형식 내지 법질서를 뜻하고 기본권은 그와 같은 생활형식 내지 바탕이 되는 가치체계로 이해되어진다. 따라서 사회공동체 저변에 깔려 있는 가치질서 내지 문화질서가 그 나라 헌법에 기본권으로 나타나기 때문에, 기본권은 동화적 통합의 실질적 요소라 한다. 이와 같은 스멘트의 시각에서는 기본권은 비정치적인 법치국가원리에 의해서 그리고 통치구조는 민주주의 원리에 의해서 규율되는 별개가 아니라, 기본권과 통치구조는 기능적 연관성을 가지게 된다. 즉, 스멘트에 의하면, 사회공동체의 가치질서를 뜻하는 기본권에 의해서 정치적인 일원체가 형성되고 정당화되기 때문에 기본권은 국가권력의 자제에서 나오는 은혜적인 것일 수 없고, 국가로부터 자유를 뜻할 수도 없다. 오히려 기본권은 국가지향적인 국가창설적 기능을 갖기 때문에 '국가를 향한 자유'가 강조된다. 이와 동시에 사회 구성원은 이 질서(기본권)를 지키고 존중하여 동화적 통합을 실현시킬 책임과 의무를 지게 되는데, 바로 여기서 스멘트는 객관적 질서로서의 기본권을 강조한다.

2) P. Häberle

슈미트는 '자유는 제도가 아니다'라는 전제 밑에서 자유와 제도적 보장을 구별했으나, 해벌레는 슈미트가 자유를 임의의 자유, 무제한의 자유, 주관적인 자유라고 이해한 나머지 자유와 제도를 반대개념으로 단정한다고 비판하며 '자유는 제도일수 밖에 없다'는 시각에서 자유란 법이나 국가를 떠나서 존재하는 것이 아니라 오로지 법속에서만 현실화될 수 있고 충족될 수 있는 것이라 한다. 따라서 자유를 구체화하고 실현하는 법제도가 없이는 자유는 마치 법적으로 공허한 공간에 지나지 않기 때문에 자유는 어디까지나 제도적인 법적 개념으로 파악해야 된다고 한다. 해벌레도 기본권을 개인의 이익과 공공의 이익을 함께 추구하는 것으로 보아 주관적 권리와 객관적 제도로서의 양면성을 인정하고 있다.

3) 비판

기본권의 기능이 국가형성적 기능이 있다고 하여 그것이 기본권의 공권성 내지 자연권성을 부정하는 근거는 될 수 없다. 기본권은 그 역사적 발전과정에서 보아 천부적인 자연권임이 명확

한 것이고, 헌법이 이를 근본 가치로 수용하는 것은 별개의 문제인 것이다. 즉 헌법이 명시하지 않더라도 권리로서 존재하는 것이다. 그리고 스멘트는 기본권의 정치적 의미의 강조에 따른 주관적 권리성을 경시했고, 해벌레는 지나치게 기본권을 제도적인 것으로 이해한다는 비판을 받는다.

2. 기본권의 기능

⑴ 주관적 공권

1) 의미

기본권은 일차적으로 주관적 공권으로서 기능한다. 기본권의 주관적 공권이란 개인이 국가를 상대로 자신의 자유와 권리를 위해 국가의 부작위와 작위를 요구할 수 있는 권리를 뜻한다. 따라서 주관적 권리는 객관적 법을 주장할 수 있는, 즉 필요한 경우에는 소송을 통하여 객관적 법을 관철할 수 있는 힘으로 특정의 개인적 기본권 주체와 결합되어 국가가 기본권을 존중하는 것을 사법적으로 관철시킬 수 있다. 이러한 일은 특히 헌법소원에 의해 분명해진다.

2) 기능

주관적 공권으로서의 기본권의 본질적 기능은 방어권적 기능으로 국가권력을 제한하는데 있다. 방어권으로서 기능하는 기본권은 공권력이 기본권의 보호영역에 간섭하는 것을 배제할 수 있는 법적인 힘을 의미한다.

참여권으로서 기능하는 기본권은 개인이 자신의 권리나 이익과 관련된 결정에 동참할 것을 요구할 수 있는 권리이다. 이러한 의미에서 참여는 민주적 국가형태의 기본적 요소에 속한다. 예컨대, 선거권, 피선거권, 정치적 집회 및 결사의 자유 등이 이에 속한다.

청구권으로서 기능하는 기본권은 청원권, 재판청구권, 국가배상청구권을 들 수 있고, 급부권으로서 기능하는 기본권은 국가적 급부에 시민이 참여하는 것을 보장하는 것으로, 근로의 권리나 교육을 받을 권리와 같은 사회적 기본권이 대표적이다.

3) 사회권적 기본권

가. 사회권적 기본권은 주관적 공권인가

우리헌법 제31조에서 제36조는 사회권을 실현하는 여러 가능성 중에서 여러 사회적 권리들을 기본권의 형태로 규정하고 있다. 그러나 사회권적 기본권이 헌법상 규정을 근거로 급부를 요구할 수 있는지에 관해서는 학설의 대립이 있다. 통설적 견해(기본권 2분설)는 사회권적 기본권만은 그에 관해 구체적 입법이 있는 경우에만 비로소 현실적 권리가 될 수 있는 추상적 권리이고, 그 밖의 기본권은 개개인이 자신을 위하여 현실적으로 국가의 일정한 행위나 부작위를 요구할 수 있는 현실적 구체적 권리로서 모든 국가권력을 직접 구속하는 구체적인 주관적 공권이라고 한다. 한편, 사회적 기본권을 불안전하나마 현실적 구체적 권리로 파악하는 견해도 있고, 단순히 프로그램 규정으로 보는 견해도 있다.

나. 사회권의 특성

이처럼 사회권이 예외적인 경우를 제외하고는 주관적 공권일수 없다는 것은 사회권의 특성에서 보다 분명해 진다. 주관적 공권의 대표적 예인 자유권의 특성과 사회권을 비교해 보면, 첫째, 자유권은 금지를 사회권은 명령을 의미한다. 둘째, 자유권은 국가가 어떠한 경우에도 하여

서는 안 되는 것을 규정하고 있음에 반하여 사회권은 국가가 무엇을 해야 하고 어떠한 목표를 추구해야 하는가를 규정하고 있다. 즉, 자유권은 국가가 침해를 하지 않음으로서 보장되는 개인적 자유와 관련되어 있고 사회권은 국가가 법률 또는 행정처분을 통하여 그 기반을 마련해야 하는 사회 보장과 관련되어 있다. 이에 따라 자유권은 소구 가능한 권리임에 반해 사회권은 국가의 의무에 불과하다. 따라서 우리헌법의 사회적 기본권은 주관적 공권이 아니라, 일차적으로 기본 전제를 형성하라는 입법자에 대한 구속적인 헌법위임규정으로 이해할 수 있다.

⑵ 객관적 가치질서로서의 기본권

1) 기본권의 이중적 성격

기본권은 국민 한사람의 주관적인 권리로서의 성격도 가지고 있지만 국가 공동체에서 반드시 준수되어야 할 민주주의적, 법치주의적, 사회국가적 헌법질서의 기본이 되는 질서적 요소라는 성격도 가지고 있는데, 이를 기본권의 객관적 가치질서성이라 한다. 이처럼 기본권은 주관적으로는 개인의 이익을 위한 대국가적 공권을 의미하면서도 동시에 객관적으로는 국가의 기본적 법질서를 구성하는 요소라 할 수 있는데, 이를 기본권의 이중적 성격 또는 양면성이라 한다. 기본권의 주체가 기본권을 임의로 포기할 수 없는 이유가 바로 기본권의 이와 같은 양면성 때문이다. 예컨대, 법 앞의 평등의 헌법적 보장은 개개인이 국가권력에 대하여 평등한 대우를 요구할 수 있는 개인을 위한 주관적 평등권을 보장한 것이면서 동시에 국가권력에 의한 자의적인 차별금지와 같은 민주 국가적 법질서의 내용이 되는 평등의 원칙을 객관적으로 확인한 것이다.

2) 기본권의 이중적 성격에 대한 이론적 배경

기본권의 성격은 헌법관과 기본권 이론에 따라 다양한 의미로 파악되고 있는데, 그 중 기본권이 사회적 통합을 위한 생활양식 내지는 법질서의 바탕이 되는 가치체계인 동시에 국가 권력의 정당성의 원천으로서 객관적 질서로 이해하는 통합주의적 헌법관에서 기본권의 이중적 성격은 잘 설명 될 수 있다. 통합론자 중에서도, 특히 기본권을 헌법의 객관적 규범으로서 특징지우는 일은 헤세(K.Hesse)가 강조하고 있다. 스멘트(R.Smend)는 기본권의 객관적 질서 측면을 강조하였고, 자유권에는 큰 관심을 보이지 않았으나, 헤세는 기본권의 주관적 권리와 객관적 가치질서 모두를 인정하였다. 그러한 한에서 기본권은 추상적·일반적으로 특정의 법적 상태를 확정하는 객관적 법이며 법적 규정이다. 왜냐하면 기본권은 개인이 주관적 공권과 관계없이 공동체적 질서의 기본적 요소이며 따라서 헌법에 의하여 구성된 법치국가의 기본적 요소이기 때문이다.

3) 견해의 대립

김철수 교수는 우리 헌법은 독일기본법의 제1조 제2항(독일국민은 침범할 수 없고 또 박탈할 수 없는 인권을 모든 인간 공동사회의 기초로서, 세계에 있어서 평화와 정의의 기초로서 정의한다)과 같은 기본권의 양면성을 인정한 규정이 없고, 천부인권으로서의 자연권은 헌법에 규정됨으로써 비로소 헌법규범이 되고 이러한 헌법규범이 국가권력을 구속하기 때문에 자연권은 헌법규범으로서의 성격을 가지고 객관적 질서를 이루는 것이지 인권 자체가 객관적 질서의 성격을 갖는 것은 아니며, 기본권을 주관적 공권인 동시에 객관적 가치질서로 보는 견해는 기본권의 주관적 공권으로서의 성격을 약화시키고 기본권과 제도보장의 구별을 불명료하게 할 우려가 있다고 하여 부정설을 주장한다.

이에 반하여 다수설(권영성 교수, 허영 교수, 홍성방 교수)은 기본권은 국가와 개인 간의 개별적인 지위에 관한 명제로서 의미만을 갖는 것이 아니라 모든 사회구성원과 국가가 준수해야 할 객관적 가치질서의 성격도 갖으며, 객관적 가치질서로서의 기본권은 모든 법 분야에서 적용되기 때문에, 입법과 사법 그리고 행정은 이러한 기본권의 가치질서성에 구속된다. 즉, 법적용

기관들은 기본권에 비추어 법령을 해석하여야 하며 입법자는 기본권에 의해 보호되는 영역과 지위를 침해하면 안 될 뿐만 아니라, 기본권이 위태로워지지 않도록 법상태를 만들 의무를 진다. 예컨대, 헌법 제21조 제1항에 따라 언론의 자유가 보장되기 때문에 입법자는 자유로운 언론이 위험에 처하지 않도록 법령을 정비해야할 의무가 있는 것이다. 따라서 기본권이 객관적 법질서로 작용한다고 해서 기본권의 방어권으로서의 기능이 후퇴한다고 할 수는 없다. 기본권은 여전히 주관적 권리로서 작용한다. 즉, 기본권의 객관적 법질서로서의 기능은 방어권으로부터 독립된, 방어적 기능을 무시하고 인정될 수 있는 독자적인 기능은 아니라고 한다.

4) 헌법재판소 태도

우리 헌법재판소는 국민의 기본권은 국가권력에 의하여 침해되어서는 아니 된다는 의미에서 소극적 방어권으로서의 의미를 가지고 있을 뿐만 아니라, 헌법 제10조에서 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다고 선언함으로써, 국가는 적극적으로 국민의 기본권을 보호할 의무를 부담하고 있다는 의미에서 기본권은 국가권력에 대한 객관적 규범 내지 가치질서로서의 의미를 함께 가지며, 객관적 가치질서로서의 기본권은 입법·사법·행정의 모든 국가기능의 방향을 제시하는 지침으로서 작용하므로 국가기관에게 기본권의 객관적 내용을 실현할 의무를 부여한다고 판시한 바 있으며,[106] 오늘날 자유민주적 기본질서를 유지하기 위한 여론의 형성에서 언론이 차지하는 비중은 결코 과소평가할 수 없고 민주주의를 지키고 발전시켜 나가기 위해 표현의 자유의 우월적 지위는 반드시 보장되어야 한다. 반론권을 인정하는 근거는 공정한 여론형성에 참여할 자유나 객관적 질서로서의 언론제도를 보장하는 데 있다고 판시한 바 있다.[107]

⑶ 기본권 양면성

1) 공동체 질서형성을 위한 기본원칙으로서의 기본권

기본권이 객관적 성격을 띠게 되면서 그 효력의 범위가 국민과 국가의 개별적 관계뿐 아니라 모든 사회질서와 그 질서의 형성에로 확대되었다.

2) 기본권의 대사인적 효력

기본권이 공동체 질서를 형성하는 기능을 수행한다면, 기본권은 보편적 효력을 갖게 되어 그 수범자를 국가기관에 국한하지 않고 모든 사회구성원을 포괄하게 된다.

3) 국가의 기본권 보호의무

국가는 타인의 기본권 침해행위로부터 개인을 보호할 적극적인 보호의무를 지게 된다.

4) 기본권 포기불가

기본권의 객관적 질서적 성격 때문에 기본권 주체가 임의로 기본권을 포기할 수 없게 된다.

5) 내재적 한계이론

기본권이 사회구성원이 합의한 공동체의 가치질서라면, 기본권은 타인의 권리와 공동체의 기본질서를 침해하지 않는 범위 내에서 행사해야 한다는 내재적 한계가 인정된다.

---

106) 헌법재판소 1995. 6. 29. 93헌마45.
107) 헌법재판소 1991. 9. 16. 89헌마165.

⑷ 제도적 보장으로서의 기본권

기본권 중 어떤 것은 제도적 보장으로서의 성격을 가지는데, 우리 헌법 제21조(언론출판의 자유), 제23조(재산권), 제31조 제4항(대학의 자율성보장), 제36조(혼인과 가족생활에 대한 국가의 보장의무) 등을 들 수 있다.

제도보장의 기능은 법질서 내에서 해당되는 법적 제도가 존재할 수 있도록 보증하는 규범의 기본적 존립을 확보하는데 있다. 즉, 제도보장은 인간과 직접 관계를 맺는 것이 아니라 제도 자체만을 보호한다. 예컨대, 혼인제도는 입법자가 제도자체를 폐지할 수 없도록 하는 기능을 할 뿐 개별적인 혼인을 보호하는 것은 아니다. 그러나 제도적 보장은 그러한 제도(혼인제도)를 보장함으로써 해당 기본권(혼인의 자유)이 실현되는데 기여한다. 그와 동시에 그것을 입법자가 마음대로 하지 못하도록 함으로써 해당 제도를 통하여 주어진 구성원리를 보호한다. 그러나 제도적 보장과 관련된 보장은 기본권의 개별적 보호작용으로부터 독립된 것은 아니라 제도보장이 개인의 자유를 보호하는데 이바지한다. 객관적으로 보장된 제도적 보장의 내용이 개인의 자유보호를 위한 법적 제도로 이해되는 한에서만 제도적 보장은 개인의 주관적 권리를 근거 짓는 데 해석의 요소로 생각될 수 있을 것이다.

♣ 문제풀이

1. 다음 설명하는 내용을 주장한 인물은 누구인가?

> 사회적 기본권을 경시하였고, 합법성과 정당성의 차이를 강조하였으며, 자유주의적 기본권 이론을 전개하였다. 또한, 배분의 원리와 조직의 원리를 강조하였고, 기본권과 제도적 보장을 구별하였으며, 정치적 사법작용의 특수성을 강조하였다. 나아가 동일성이론을 주장하였고, 기본권과 통치구조의 이념적 단결을 주장하였다.

① H. Kelsen ② C. Schmitt ③ R. Smend ④ G. Jellinek ⑤ P. Häberle

[정답] ②

[해설] 결단주의 헌법관을 주장한 C. Schmitt의 이론이다.

2. 다음 옐리네크의 기본권관에 관한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 국민은 국가라는 공동체의 구성원적 지위에서 국가에 대하여 주관적 공권을 가진다.
② 기본권의 주관적 공권성으로 인하여 기본권은 국가권력을 구속한다.
③ 권리는 권리주체 상호간의 관계에서만 성립한다.
④ 국가와 개인의 관계를 지배·복종의 관계로 관념한 나머지 기본권을 국가권력과 대립하는 것으로 본다.
⑤ 기본권의 본질적 내용의 침해금지를 인정하지 않는다.

[정답] ②

[해설] 기본권은 국가권력에 의해 언제든지 회수될 수 있는 것으로 보아 기본권이 국가권력을 구속할 수 없다고 보았다.

3. 다음 설명하는 기본권의 기능은 무엇인가?

> 국민의 기본권은 국가권력에 의하여 침해되어서는 아니 된다는 의미에서 소극적 방어권으로서의 의미를 가지고 있을 뿐만 아니라, 국가는 적극적으로 국민의 기본권을 보호할 의무를 부담하고 있다.

① 주관적 공권성 ② 객관적 가치질서성 ③ 제도보장성 ④ 이중성 ⑤ 보호성

[정답] ④
[해설] 기본권의 이중성에 대한 설명이다(헌법재판소 1995. 6. 29. 93헌마45).

♣ 요점정리

1. 법실증주의는 기본권의 실정법 속에서의 자유라는 점에 중심을 두고 있으므로 기본권은 헌법에 규정되어야만 비로소 권리로 인정되므로, 기본권도 국가에 의해 창설되었을 때에만 효력을 갖는다고 본다.

2. 옐리네크는 기본권의 권리성을 인정하였지만 지배의 주체로서의 국가와 복종의 주체로서의 개인을 전제로 하여 이론을 전개하였으며 개인의 자유는 선국가적인 것이 아니라 국가의 자제에서 나오는 것으로 파악하였다.

3. 칼 슈미트에 의하면 기본권은 인간의 천부적이고 선국가적인 자유와 권리로서의 방어권으로 보아, 기본권이 민주주의원리에 의해 지배되는 정치적인 국가작용에 의해서 부당하게 제한되고 침해되는 것을 막기 위해서 비정치적인 법치국가원리가 적용되어야 한다고 한다. 따라서 고유한 의미의 기본권을 자유권으로 이해하여, 기본권의 본질을 '국가로부터의 자유'라고 주장하기 때문에 참정권과 사회적 기본권은 경시하였다.

4. 기본권의 주관적 공권이란 개인이 국가를 상대로 자신의 자유와 권리를 위해 국가의 부작위와 작위를 요구할 수 있는 권리를 뜻한다.

5. 제도보장은 인간과 직접 관계를 맺는 것이 아니라 제도 자체만을 보호한다.

제6강 기본권의 분류

♣ 학습목표

주체에 따른 분류를 설명할 수 있다.
성질에 따른 분류를 설명할 수 있다.
효력에 따른 분류를 설명할 수 있다.
내용에 따른 분류를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

인간의 권리, 국민의 권리
자연인의 권리, 법인의 권리
초국가적 기본권, 국가내적 기본권
절대적 기본권, 상대적 기본권
진정한 기본권, 부진정한 기본권
구체적 기본권, 프로그램적 기본권
대국가적 기본권, 대사인적 기본권
포괄적 기본권, 자유권적 기본권
참정권적 기본권, 청구권적 기본권, 사회적 기본권

♣ 사전테스트

1. 참정권은 인간의 권리이다.

정답 : X
해설 : 참정권, 사회적 기본권 등은 국민의 권리이다.

2. 선거권은 초국가적 기본권이다.

정답 : X
해설 : 국가내적 또는 실정법상 기본권이다.

3. 침묵의 자유는 절대적 기본권이다.

정답 : O
해설 : 행복추구, 생명권, 사생활의 비밀, 양심결정, 침묵, 신앙, 연구의 자유는 절대적 기본권이다.

♣ 돌발퀴즈

법인은 제한된 범위에서 기본권 주체성을 가진다.

[정답] O

[해설] 법인에게는 성질상 인정할 수 없는 기본권을 제외하고, 사죄광고에서의 인격권, 직업선택의 자유, 종교적 의식의 자유, 언론출판의 자유, 재판청구권, 청원권, 거주이전의 자유 등이 인정된다.

♣ 강의내용

1. 주체

⑴ 인간의 권리(자연권) : 평등권, 행복추구권, 양심의 자유, 신앙의 자유 등이 있다.
국민의 권리(실정권) : 외국인을 제외, 참정권, 사회권적 기본권 등이 있다.

⑵ 자연인의 권리 : 국민이든 외국인이든 불문한다.
법인의 권리 : 사죄광고사건에서의 인격권, 직업선택의 자유, 종교적 의식의 자유, 언론 출판의 자유, 재판청구권, 청원권, 거주 이전의 자유 등이 있다.

2. 성질

⑴ 초국가적 기본권 : 행복추구권, 일조권, 인격권, 평등권, 저항권, 사생활 비밀의 자유, 표현의 자유 등이 있다.
국가내적 기본권(실정법상 기본권) : 선거권, 공무담임권, 재판청구권, 사회적 기본권

⑵ 절대적기본권 : 신앙의 자유, 양심의 자유, 학문연구의 자유, 예술창작의 자유 등이 있다.
상대적기본권 : 제한이 불가능한 절대적 기본권과는 달리 경우에 따라 제한가능하다.

⑶ 진정한 기본권 : 국가에 대하여 작위, 부작위를 청구할 수 있는 주관적 공권이다.
부진정한 기본권 : 헌법상의 일정한 제도보장에 의한 반사적 권리이다.
예컨대, 경제질서상의 독과점거부권이 이에 속한다.

3. 효력

⑴ 구체적 기본권 : 국가기관을 직접 구속한다.
프로그램적 기본권 : 구체적인 입법이 있어야 국가를 구속한다.

⑵ 대국가적 기본권 : 국가에 대한 효력을 가진다.
대사인적 기본권 : 사인에 대한 효력을 가진다.

4. 내용

⑴ 포괄적 기본권

1) 인간의 존엄과 가치(제10조)

인간이란 인간의 고유가치를 유지하면서 사회와 긴밀한 관계를 가지고 사회에 구속되는 인간을 말하며, 존엄과 가치란 인간일반에게 고유한 가치로 간주되는 존귀함, 즉 인격성을 의미한다.

인간의 존엄성의 존중의 수단에는 적극적 수단에는 제11조, 제36조(기본권보장이 중요수단) 및 제37조(헌법에 열거되지 아니한 자유와 권리)가 있으며, 소극적 수단에는 학살·고문의 금지, 인간실험, 강제노동의 금지 등이 있다.

2) 행복추구권(제10조)

행복추구권이란 고통이 없는 상태 또는 만족감을 느낄 수 있는 상태를 실현할 수 있는 권리를 의미한다. 행복추구권은 인간의 권리이기 때문에 법인에게는 인정되지 않으며, 자연인에게만 인정되는 권리이다.

행복추구권은 포괄적 기본권이므로 내용이 다양하고, 프라이버시권, 환경권과 헌법에 열거되지 아니한 자유와 권리가 있다. 예컨대, 새로운 인권(생명권, 평화적 생존권, 휴식권, 건강권, 일조권, 액세스권, 국민의 알권리, 신체권, 인격권 등이 있다.

3) 평등권(제11조)

현행헌법은 차별금지 사유 및 차별금지 영역까지 규정하고 있고, 헌법 제11조는 예시규정이다.

차별금지사유에는 성별(생리적 근거 및 합리적 사유에 의한 차별 가능), 종교(종교평등), 사회적 신분(일정한 사회적 평가 : 상습범, 누범, 공범, 남녀, 종교 등은 사회적 신분이 아니다)이 있다.

또한, 차별금지 영역에는 정치적(투표, 선거, 공직취임), 경제적(고용, 임금, 담세율), 문화적(교육의 기회균등, 육체적·정신적 능력), 사회적(주거, 여행, 혼인과 가족생활)생활영역이 있다.

가. 외국인(국제법과 조약, 상호주의)

헌법재판소는 국민과 유사한 지위에 있는 외국인의 기본권 주체성 인정한 바 있다.

출국의 자유, 청원권, 영장제도, 통신의 자유, 근로3권, 다만 입국의 자유는 제한된다.

외국인에 대한 요양급여사건 : 불법행위자의 기본권 주체성이 인정된다.

나. 법인 : 법인격 없는 단체포함, 예컨대 한국영화인 모임 기본권주체성 인정

공법인 : 원칙적 불인정, 구성원 대리 또는 구성원을 위해

예외적 국민 생활에 직접 편입된 경우, 법인 자신을 위해 인정

A. 국립서울대 : 대학입시 일본어 과목제외 합헌

B. KBS : 시청료징수합헌

다. 예외

A. 헌법

정당의 특권, 군사법원에 의한 재판, 대통령과 국회의원의 특권, 공무원과 방위산업체 근로자의 근로3권의 제한, 군인·군무원·경찰의 국가배상 청구권의 제한, 현역군인의 문관임용 제한, 국가유공자의 우선취업기회보장에 의한 예외가 있다.

B. 법률

공무원, 군 관계법, 행형법, 공직선거 및 선거부정방지법(대통령·국회의원), 출입국관리법, 외무공무원법, 외국인토지법(예외적 토지취득허용), 민법(가족법)의 예외, 긴급재정경제처분 및 긴급명령권(명령에 의한 평등권의 제한)에 의한 예외가 있다.

⑵ 자유권적 기본권

자유권이란 개인이 그 자유로운 영역에 관하여 국가권력의 간섭, 침해를 받지 아니할 방어적·소극적 공권(핵심적 권리, 본질적 권리, 포괄적 권리)을 의미한다.

1) 인격적 자유(신체, 거주이전, 직업선택, 주거, 통신의 자유 및 사생활 보장의 비밀 등)

가. 신체에 관한 자유(제12조)

신체의 자유란 법률과 적법절차에 의하지 아니하고는 신체의 안정성과 자율성을 침해당하지 아니할 자유 또는 생존을 위한 최소한의 조건, 즉 기본적 자유 또는 인신의 자유를 의미한다. 예컨대, 불법적인 체포·구속, 압수·수색, 심문·처벌, 보안처분·강제노역을 당하지 않을 권리가 있다.

A. 실체적 보장

ㄱ. 죄형법정주의

성문형법주의, 형벌불소급, 절대부정기형금지, 유추해석금지, 일사부재리의 원칙과 연좌제 금지 등이 있다.

ㄴ. 절차적 보장

영장제도(원칙 : 사전영장제도, 예외 : 사후영장제도)로서 사형, 무기 또는 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하거나, 도주의 염려, 증거인멸의 염려가 있을 때, 구속적부심사제(객관적인 제도 또는 주관적 권리 : 알권리·통지 받을 권리)가 있다.

나. 거주이전의 자유(제14조)

거주이전의 자유란 자기가 원하는 곳에 주거 거주를 정하거나 자유로이 이전 하거나 자기의 사에 반하여 거주지를 옮기지 아니할 자유를 의미한다. 국내에서 거주 이전의 자유는 국내 어디나 자유롭게 주소 및 거소를 이전 가능함을 의미한다. 국외이주와 해외여행의 자유에는 국외 영주, 장기간 해외거주가 포함된다. 귀국의 자유와 외국인의 출국의 자유는 인정되지만 입국의 자유는 인정되지 않는다.

그러나 국가안전보장, 질서유지, 공공복리를 위한 제한, 민사법상의 제한, 특별권력에 의한 제한(수형자, 군인 등)이 있다.

망명권은 제네바의 협정에 따라서 해결, 국적이탈의 자유는 세계인권선언에 명시되어 있으며, 헌법 제5조에 국제평화주의, 국제협조주의를 기초로 인정된다.

다. 직업선택의 자유(제15조)

직업선택의 자유란 사경제적 소득활동을 자기가 원하는 바에 따라 자유로이 선택할 수 있는 자유를 의미한다.

직업선택의 자유의 주체에는 원칙적으로 국민, 외국인(조약 또는 영주허가를 받은 자에 한하여 인정하고, 변호사법, 공증인법, 도선법상 제한이 있다), 사법인(법인설립은 직업선택의 한 방법이기 때문에 인정)이 있다.

라. 주거의 자유(제16조)

주거란 인간이 거주하는 설비로서 사생활의 중심이 되는 장소 또는 사생활의 안전보호, 즉 모든 생활의 근원이 되는 장소를 의미한다.

헌법 제37조 제2항에 의하여 제한이 가능하며, 개별법으로는 우편법, 국세징수법, 경찰관 직무집행법 등이 있다.

마. 통신의 자유(제18조)

통신, 전화, 전신 등에 의한 의사나 정보전달교환이 국가의 공권력에 의해 침해당하지 아니할 자유를 말한다. 통신의 자유의 주체에는 국민, 외국인, 법인이 있다.

바. 사생활 비밀과 자유(제17조)

사생활의 비밀과 자유란 사생활의 내용을 공개 당하지 아니할 권리 또는 사생활의 자유로운 형성과 전개를 방해 당하지 아니할 권리를 의미한다. 개별입법으로 보장하는 국가는 미국과 독일이며, 헌법수준으로 보장하는 국가는 스페인이 있다.

사생활의 비밀의 불가침(개인에 관한 난처한 사적사항의 불가침, 명예나 신용의 불가침, 인격적 징표의 불가침 : 초상, 성명, 경력 등 본인에 고유한 속성)과 사생활의 자유의 불가침(사생활의 평온의 불가침, 자유로운 사생활의 형성과 유지의 불가침)이 있으며, 그 자기정보통제권(자신 등의 정보의 자의적 수집 및 분석행위 : 배제요구권, 정보열람청구권, 정정보도 청구권, 정보무단공표 또는 이용금지요구권 등)이 있다.

2) 정신활동의 자유(양심, 종교, 언론출판, 학문과 예술 및 집회 결사의 자유 등)

가. 양심의 자유(제19조)

양심의 자유란 각자의 판단이나 가치관으로서의 확신을 외부에 표명하도록 강제를 당하지 않을 자유와 양심에 반하는 행위를 강요당하지 않을 자유로서 이는 모든 자유의 근원이며, 최상급(절대적) 기본권이다.

양심(윤리)과 사상(논리적 사고), 신앙(종교)의 범위(사상>윤리>신앙)는 각각 다르다.

양심의 자유의 주체는 자연인이며, 법인은 주체가 될 수가 없다.

나. 종교의 자유(제20조)

종교의 자유란 자기가 원하는 종교를 스스로 원하는 방법으로 신봉하는 것을 말하고, 중세유럽에서 불합리한 제도에 저항(캘빈, 루터 등), 종교의 자유를 획득하기 위한 끊임없는 투쟁에서 쟁취한 결과이다.

신앙의 자유, 종교적 행사의 자유, 종교의 집회·결사의 자유, 종교활동과 종교교육의 자유 등이 이에 해당한다. 종교의 자유에는 무교의 자유도 포함된다.

다. 학문의 자유(제22조)

학문의 자유란 학문적 활동에 관하여 간섭이나 방해를 받지 아니하는 자유를 말하며, 학문은 인간정신의 귀중한 성과 또는 인류문화의 집중적 표현, 학문의 진보는 문화의 선구적 역할, 새로운 지식의 개척, 학문상의 진보나 신발견을 일반의 상식적 견해에 입각하여 반대 또는 박해한 역사적 경험을 토대로 인정되었다. 학문의 자유의 주체는 모든 국민, 외국인, 대학이나 그 밖의 단체도 포함된다.

라. 예술의 자유(제22조)

예술창작의 자유(절대적 기본권), 예술표현의 자유, 예술적 집회·결사의 자유, 예술적 비판(일반적인 표현의 자유는 언론의 자유로 보장)이 있다.

마. 언론출판의 자유(제21조)

인간의 권리이기 때문에 내국인과 외국인에게도 보장되며, 법인(의사표시, 정보수집 등 그 적용 가능한 경우)에는 보장된다.

정보의 유통과정과 그 법적 관계에는 정보원(정보자료의 출처), 정보처리(개인의 사상, 양심, 학문의 자유로 보장된다)와 언론기관(편성권, 편집권, 언론기관의 내부적 자유에 대응), 정보수집(취재의 자유는 사생활비밀보호, 국가나 공공기관의 기밀누설방지, 헌법 제37조 제2항에 의한 제약의 가능성이 있다), 알권리, 모든 정보원으로부터 일반적인 정보를 수집할 수 있는 권리 등이 있다.

바. 집회결사의 자유(제21조)

집회결사의 자유란 다수인이 공동의 목적을 가지고 회합 결합하는 자유 또는 넓은 의미의 표현의 자유의 한 형태로 언론 출판의 자유의 보완적 기능을 하는 것을 의미한다. 집회결사의 자유가 헌법상 보장되는 이유에는 인간 본연의 자연적인 행동양식, 민주정치를 실현하기 위한 불가결한 전제조건, 소수자의 인권과 이익보장을 위해서 필요로 하는 것이다.

집회와 결사의 자유의 예외적 제한으로는 헌법 제76조 긴급명령, 헌법 제77조 계엄 선포에 의한 특별한 제한과 특별권력관계(설립목적에 비추어서 합리적인 범위 내 가능)에 의한 제한이 있다.

3) 재산권 보장의 자유(제23조)

재산권의 주체는 자연인, 법인, 외국인(국제법, 국제조약이 정하는 바에 따른 보장)이 될 수 있고, 재산권의 객체에는 사법상 또는 공법상의 경제적 가치가 있는 모든 권리가 포함된다. 오늘날 재산권은 생활양식, 사회구조의 변화, 사회국가화의 경향 등의 영향으로 폭넓은 제한이 가해지고 있다.

재산권보장의 내용에는 구체적 재산권의 보장(내용과 한계는 법률로 정한다)과 사유재산의 보장(법률로써도 사유재산제의 기본 핵심을 부인 불가능)이 있으며, 소급입법에 의한 재산권 박탈의 금지, 무체재산권의 보장, 경제의 장에 규정된 재산권보장이 있다.

헌법 제23조에 의한 제한(공공필요 : 국가목적실현과 사회정의가 포함), 제37조 제2항(국가안전보장, 질서유지, 공공복리)에 의한 제한이 있다.

국회가 제정하는 형식적 의미의 법률을 의미하며, 법률 이외의 국가 긴급재정경제처분 및 긴급명령권에 의한 제한이 있다. 제한에 있어서는 재산의 처분권 및 사용권에 대한 전면적인 제한은 불가능하지만 사용권만을 일정한 범위 내에서 일시적으로 제한하는 것은 가능하다.

가. 수용

공공필요에 의해 국가 공공단체 등의 사업주체가 특정 재산권을 법률에 의해 강제취득하는 것을 말한다.

나. 사용

일시적 강제적으로 사용(공용사용)하는 것을 말한다.

다. 제한

공법상 제한, 물적 공용부담의 일종(공용제한)을 말한다.

라. 특수한 재산권의 제한

헌법 제122조 내지 제126조의 경제질서에 의한 제한을 말한다.

마. 보상

헌법상으로는 법률에 따른 정당한 보상을 규정하고 있다.

⑶ 참정권적 기본권

넓은 의미로는 정치적 자유, 참정권 및 그 밖의 정치적 활동권을 포함하며, 좁은 의미로는 참정권(국민표결권, 공무담임권, 공무원선거권)만을 의미한다.

이는 인간의 본성에 바탕을 둔 원초적 욕구 인간의 제1차적 욕구로서 헌법개정으로도 폐지가 불가능하다.

1) 참정권

참정권이란 국가의 의사형성에 직접 참여하거나 선거인단 또는 투표인단의 일원으로서 선거투표에 참여하거나 공무원으로 선임될 수 있는 국민의 주관적 공권을 의미한다. 참정권은 간접참정권(선거권, 피선거권, 공무담임권)과 직접참정권(국민투표권)이 있다.

가. 직접적 참정권

국민투표, 국민발안, 국민소환 등이 있다.

나. 간접적 참정권

A. 선거권 : 국가기관으로서의 국민이 각종의 공무원을 선임하는 권리이다.

B. 피선거권 : 공직선거 및 선거부정방지법에서 국회의원 단체장 지방의회의원은 25세, 대통령은 40세로 규정되어 있다.

다. 공무담임권

당선 또는 시험에 합격하는 등 자격을 구비해야 한다.

⑷ 청구권적 기본권(기본권 보장을 위한 기본권)

청구권적 기본권이란 국가에 대해 일정한 행위를 적극적으로 청구할 수 있는 국민의 주관적 공권 또는 권리의 보장을 위한 기본권을 말한다.

1) 청원권

청원권이란 국가기관에 대해 일정한 사항에 관한 희망을 진술하는 권리를 말한다. 청원사항으로는 입법사항, 청원법(공무원 비위시정, 공무원 징계, 처벌 요구, 공공의 제도 또는 시설의 운영, 피해의 구제)에 의한 것이 있다.

청원은 국가기관, 지방자치 단체, 그 밖의 공공단체에 서면(원칙)으로 하며 청원법, 국회법, 지방자치법 등이 이를 규율하고 있다.

2) 국가구조청구권

국가구조청구권이란 타인의 범죄로 인하여 생명 신체에 피해를 입은 국민은 국가에 대하여 구조를 청구할 수 있는 권리이다.

3) 형사보상청구권

형사보상청구권이란 형사피의자 또는 형사피고인으로 구금되었던 자가 검사의 불기소처분 또는 법관의 무죄확정판결을 받은 경우 국가에 대해서 보상을 청구할 수 있는 권리를 말한다. 국가기관의 고의나 과실여부는 불문한다.

4) 국가배상청구권

공무원의 직무상 불법행위로 인하여 손해를 입은 자가 국가 또는 공공단체에 대하여 배상을 청구할 수 있는 권리를 말한다.

5) 손실보상청구권

행정주체의 적법 타당한 공권력의 행사로 인하여 국민이 특별한 희생을 받았을 때 국가에 대하여 청구할 수 있는 권리를 말한다.

6) 재판청구권

재판청구권이란 기본권의 실체적 보장이 실효를 거두기 위하여 기본권이 침해된 경우의 사후의 구제절차가 필요하여, 독립된 법원이 적정, 공평, 신속, 경제의 재판을 하여 기본권보장과 법적정의를 확보하는 것을 말한다.

가. 재판청구권의 제한

A. 군사법원에 의한 제한

군인, 군무원, 일반국민에 대한 제한이 있다.

B. 상고에 의한 제한

비상계엄시 군사재판의 경우 사형을 제외하고 단심제가 원칙이다.

C. 행정소송에 있어서 사전재정

조세사건 등 특정한 경우, 행정심판전치주의가 규정되는 경우가 있다.

D. 제소기간의 한정

행정상 법률관계를 조속히 확정할 필요로 인해 기간을 정하는 것이다.

E. 특별권력관계에 있어서 제소의 제한

직무명령 위반행위는 제소불가능하다.

⑸ 사회권적 기본권(생존권)

사회권이란 인간다운 생활보장을 위하여 국가적 급부(배려)를 요구하는 것을 의미한다. 헌법 제34조는 목적조항이며, 그 이외는 수단조항으로 해석되기도 한다.

1) 교육을 받을 권리

교육을 받을 권리란 교육 받을 수 있도록 국가가 적극적으로 배려하여 주도록 요구할 수 있는 권리를 말한다(사회권). 이를 헌법상 보장하는 이유는 민주정치실현을 위한 자각과 식견(공민권성), 인간다운 생활의 확보(생활권성), 인간의 능력개발의 요청이 있다. 국민과 자연인에게만 인정된다.

구체적으로는 능력에 따라 교육을 받을 권리(정신적, 육체적 능력에 따라 차등), 균등하게 교육을 받을 권리가 있다. 자유권적 측면으로는 성별, 종교, 사회적 신분에 따른 차별금지와 사회권적 측면으로는 취학의 평등, 교육의 외적 조건의 정비요구, 교육을 받을 권리(학교교육, 사회교육, 공민교육, 가정교육, 평생교육)가 있다.

2) 근로의 권리

근로의 권리란 자유로이 근로를 선택(내용, 장소)하고 방해받음이 없이 근로관계를 계속할 권리(취업의 강요 불가능), 가장 유리한 조건으로 노동력을 제공하여 대가를 얻거나 국가에 대한 근로의 기회 제공을 요구할 권리를 말한다. 자연인, 즉 국민이 주체가 된다. 특히 생산수단을 소유하지 못한 근로자 계층을 위하여 인정된다(자영농, 자영사업가는 근로의 주체가 될 수 없다).

3) 환경권

자연이 환경권의 주체이며, 원고적격은 '오염된 환경과 관련이 있는 모든 자'가 된다. 환경권은 개인을 위한 주관적 공권의 보장으로 보호법익은 건강하고 쾌적한 환경에서의 생활이다. 환경권은 깨끗한 환경의 보전과 공해배제 및 환경권보장을 위한 국가적 노력의무, 예컨대 환경보전, 공해배제의 노력, 문화적 주택을 개발 공급할 노력의무 등이 있다.

4) 소비자권리와 보호

소비자가 그들의 인간다운 생활을 영위하기 위하여 공정한 가격으로 양질의 상품 또는 용역을 적절한 유통구조를 통하여 구입 또는 사용할 수 있는 권리를 말한다. 스페인의 경우 헌법에서 명문화하고 있으며, 독일은 부정경쟁방지법이 있고, 일본은 소비자보호기본법이 있다. 우리나라는 소비자보호법이 규정하고 있다.

소비자보호법의 내용에는 안전할 권리, 지식과 정보를 제공받을 권리, 자율권, 소비자가 사용자에게 의사를 전달할 권리, 피해보상청구권, 교육을 받을 권리, 단체를 결성할 권리 등이 규정되어 있다.

5) 혼인과 가족제도의 양성의 평등

인간의 존엄과 양성의 평등을 기초로 하는 혼인제도(축첩, 인신매매에 의한 결혼, 지나친 조혼, 강제결혼 등의 부인)와 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 한 가족생활이 이에 해당한다.

6) 보건권(건강권)

국가가 개개인의 위생과 건강유지에 필요한 시설과 환경을 배려함을 의미한다. 보건소법, 의료법, 전염병예방법, 모자보건법 등이 있다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 우리 헌법에 열거되지 아니했으나 경시되어서는 안 될 권리는?
① 휴식권 ② 재판청구권 ③ 신체의 자유 ④ 사생활의 자유 ⑤ 근로권

[정답] ①
[해설] 휴식권은 헌법에 직접적으로 규정되어 있지 않으나 인정되고 있다.

2. 다음 중 절대적 자유권은 무엇인가?
① 침묵의 자유
② 언론의 자유
③ 종교적 결사의 자유
④ 양심실현의 자유
⑤ 계약의 자유

[정답] ①
[해설] 절대적 자유권이란 어떠한 경우에도 제한할 수 없는 것을 말한다. 행복추구, 생명권, 침묵, 신앙, 연구의 자유 등이 이에 속한다.

3. 다음 중 인간의 권리에 속하지 않는 것은?
① 평등권
② 행복추구권
③ 양심의 자유
④ 신앙의 자유
⑤ 사회권적 기본권

[정답] ⑤
[해설] 사회권적 기본권은 국민의 권리에 속한다.

♣ 요점정리

1. 인간의 권리에는 평등권, 행복추구권, 양심의 자유, 신앙의 자유 등이 있고, 국민의 권리에는 참정권, 사회권적 기본권 등이 있다.

2. 법인에게는 성질상 인정할 수 없는 기본권을 제외하고, 사죄광고에서의 인격권, 직업선택의 자유, 종교적 의식의 자유, 언론출판의 자유, 재판청구권, 청원권, 거주이전의 자유 등이 인정된다.

3. 초국가적 기본권에는 행복추구권, 일조권, 인격권, 평등권, 저항권, 사생활 비밀의 자유, 표현의 자유 등이 있고, 국가내적 기본권(실정법상 기본권)에는 선거권, 공무담임권, 재판청구권, 사회적 기본권 등이 있다.

4. 절대적 기본권에는 신앙의 자유, 양심의 자유, 학문연구의 자유, 예술창작의 자유 등이 있다.

제7강 기본권의 보호영역

♣ 학습목표

기본권의 논증체계를 설명할 수 있다.
기본권 보호영역의 의의와 유형을 설명할 수 있다.
기본권 보호영역의 한계를 설명할 수 있다.
개별기본권에서 보호영역의 해석원칙을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

인적인 보호영역, 내용적인 보호영역
주관적인 보호이익, 객관적인 보호이익
기본권 보호영역의 한계
개별기본권의 보호영역

♣ 사전테스트

1. 기본권 보호영역의 문제는 법률적인 차원에서 다루어지고 있다.
정답 : X
해설 : 입법자가 개별 기본권의 범위를 자의적으로 축소시킬 수 있기 때문에 헌법적인 차원에서 다루어야 한다.

2. 헌법상 보호영역이 입법자의 권한에 위임되는 경우에 입법권자의 권한은 무제한이다.
정답 : X
해설 : 입법권자의 권한도 무제한한 것은 아니다. 만약 재산권자의 모든 재산의 사용 및 처분권을 박탈하는 법률이 제정된다면, 헌법상 보장되는 재산권의 본질을 훼손하게 되므로, 이는 헌법상 허용되는 한계를 일탈한 것이 된다.

3. 종교적인 신앙고백은 의사표현의 자유에 의해서 특별히 보호된다.
정답 : X
해설 : 종교적인 신앙고백은 의사표현의 자유가 아니라 종교의 자유에 의해서 특별히 보호된다.

♣ 돌발퀴즈

기본권의 보호영역과 제한은 밀접한 관련이 있다.

[정답] O
[해설] 기본권의 보호영역이 넓으면 넓을수록 국가에 의한 제한의 가능성이 증가하며, 보호영역이 좁으면 좁을수록 국가에 의한 제한의 가능성이 감소하기 때문에 밀접한 관련이 있다.

♣ 강의내용

1. 의의

기본권 규범의 효력이 미치는 보호영역을 확정하는 것은 기본권에 대한 제한(침해)의 판단에 있어서 선결조건이다. 그런데 헌법상의 개별기본권 규정은 매우 추상적이고, 불확정적이어서 구체화가 필요하다.

이러한 기본권 규범의 구체화는 개별기본권 규정의 문맥 이외에도 그 규정과 관련되는 구체적인 특수성들을 고려하여 해석하는 절차가 필요하다. 예컨대, 헌법상 재산권의 보장은 재산이 갖고 있는 사회적, 경제적 기능을 고려하여 결정될 수 있는 것이다.

또한, 헌법상의 개별기본권 규정은 특정한 사항적·내용적 범위를 가짐으로써 구체화되기도 한다. 예컨대, 양심, 직업이란 개념은 개별적인 보호영역의 해석을 통하여 구체적인 기본권 효력범위를 알 수 있고, 가족, 재산이란 개념은 입법자에 의하여 구체화되기도 한다.

기본권의 보호영역이란 개별 기본권에 특유한 사항적·내용적 범위를 의미한다. 이러한 보호영역을 '구성요건'(Grundrechtstabestand) 또는 '규범영역'(Normbereich)이라고도 한다.[108]

이러한 기본권의 보호영역은 어디까지나 헌법적인 차원에서 이루어지는 것이지 법률적인 차원에서 이루어지는 것은 아니다. 만약 법률적인 차원에서 입법자가 보호영역을 정의할 수 있다면 헌법 제10조 제2문이나 제37조 제2항의 규정은 존립의미가 없다. 왜냐하면 기본권 보장의 범위가 처음부터 입법자의 재량에 의하여 정해지므로 굳이 기본권의 제한이라는 형식에 따를 필요 없이 그 前단계에서 입법자가 개별 기본권의 범위를 자의적으로 축소시킬 수 있기 때문이다. 그러므로 보호영역은 법률적인 차원이 아니라 헌법적인 차원에서 이루어져야 하며, 입법자는 단지 헌법이 허용하는 범위 내에서 개별 기본권의 보호영역을 구체화시킬 수 있다.

그럼에도 불구하고 헌법상 보호영역이 입법자의 권한에 위임되는 경우도 있다. '재산권의 내용과 한계는 법률로 정하며'(제23조 제1항), '환경권의 내용과 행사에 관하여는 법률로 정한다'(제35조 제1항)고 규정되어 있다. 이런 규정은 입법자에게 기본권의 보호영역을 정하는데 있어서 폭넓은 입법형성권을 부여한다. 여기서 보호영역의 범위는 헌법 개정 없이도 법률에 의해서 새롭게 정해질 수 있다는 특징이 있다.

그러나 입법권자의 권한도 무제한한 것은 아니다. 만약 재산권자의 모든 재산의 사용 및 처분권을 박탈하는 법률이 제정된다면, 헌법상 보장되는 재산권의 본질을 훼손하게 되므로, 이는 헌법상 허용되는 한계를 일탈한 것이 된다.

2. 유형

(1) 인적인 보호영역과 내용적인 보호영역

기본권 조항은 외견상 어떠한 조건과도 결부되지 아니한 자명한 권리로 보인다. 그러나 기본권 보장이라는 법적 결과를 위해서는 개별 기본권에 따라 상이한 인적인 보호영역이 요청되기도 한다. 즉, 헌법 제33조의 인적인 보호영역은 노동3권에서는 '근로자'라고 규정하고 있고, 그 이외는 '국민'을 대상으로 하고 있고, 혼인과 가족생활 및 모성보호를 규정한 헌법 제36조 제1

108) 보호영역 대신에 '효력영역'(J. P. Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, 1982, S. 89.) 또는 '규범영역'(Fr. Müller, Juristische Methodik, 1993, S. 117.)이란 용어가 사용되기도 한다.

항과 제2항은 단지 국가의 의무를 규율하고 있으며, 체포 또는 구속을 당한 자의 가족 등에게 그 이유와 일시·장소가 통지 되어야 한다는 헌법 제12조 제5항 제2문과 여자 및 연소자의 근로는 특별한 보호를 받아야 한다는 헌법 제32조 제4항과 제5항 등이 있다.

기본권 보장의 내용적 보호영역은 개별기본권 조항에 따라 다양하기 때문에 일률적으로 파악하기가 어렵다. 기본권의 보호영역에 속하는 개인의 행위는 1차적으로 국가의 권리침해를 방어하거나(예컨대, 신체의 자유에 의하여 국가의 고문을 방지), 국가의 적극적인 행위를 요구하는(예컨대, 인간다운 생활을 할 권리에 의해서 생활보호대상자가 국가에게 생존에 필요한 물품을 제공해 달라고 청구) 주관적인 권리로서 작용한다.

⑵ 주관적 보호이익과 객관적 보호이익

주관적 보호이익은 일정한 영역에서 기본권 주체의 자기결정을 의미한다. 예컨대, 종교의 자유는 종교 자체가 아니라 주관적 보호이익으로서 종교적 사고(신앙), 종교적 표현 및 행위를 할 개인의 자유로운 결정을 보호한다.

이에 대하여 객관적 보호이익은 기본권 주체가 자유로이 결정할 대상이 아니라, 자유의 전제조건(가령 생명)이나 개인의 자유를 둘러싸고 있는 사생활의 보호(주거 및 통신영역)를 가리킨다. 즉, 객관적 보호이익은 생명·신체의 불가훼손성·인간의 존엄·통신의 비밀과 같이 육체적 또는 정신적 실체 그 자체를 의미한다.

이렇게 본다면 주관적 보호이익에서 기본권의 보호영역은 일정한 영역의 지시와 자유보장이라는 두 가지 요소를 가진다. 그러나 객관적 보호이익에서는 단지 육체적 또는 정신적 실체라는 한 가지 요소만으로 구성되어 있다. 예컨대, 신체의 자유에서 신체자체를 대상으로 하는 신체의 불가훼손성은 객관적 보호이익이지만, 신체활동의 임의성은 주관적 보호이익이라고 할 수 있다.

3. 한계

기본권 보호영역의 한계와 관련하여 Müller(내재이론)는[109] 모든 기본권은 이미 자신의 법적 성격으로 인하여 한계를 가지고 있다고 주장하였다. 예컨대, 그림 자체는 예술의 자유에 의해서 보호되지만 교차로에서 그림을 그리는 행위는 기본권에 의하여 특수하게 보호되는 행위형태가 아니므로 이를 제지하는 법률은 기본권을 제한하는 법률이 아니라는 것이다.

그러나 Müller의 이론은 기본권 보호영역을 행사방식에 따라 한계를 설정함으로써 기본권의 보호영역이 기본권의 현실적인 보장이라는 최소한의 영역에 국한되고, 기본권의 제한 내지는 제한의 한계문제를 다룰 필요가 없게 된다. 따라서 이러한 견해는 보호영역을 지나치게 협소하게 파악하는 것으로 기본권을 공동화시킬 위험이 높다.

이와는 다르게 Alexy(외형이론)는[110] 그때그때의 기본권적 원칙이 그 보호에 찬성하는 모든 것을 보호영역에 포함시켜 넓게 파악한다. 따라서 예술활동 및 종교행사라는 단 하나의 특성을 충족시키는 한 교차로에서 그림을 그린다든지 전염병지역에서 종교의식을 갖는 것도 예술 및 종교의 자유에 포함된다고 한다. 예컨대, 근로조건의 향상과 무관한 근로자의 정치적 파업도 단체행동권에 속하고, 살인 및 종교제례에 따르는 살상도 직업의 자유 및 종교의 자유에 포함된다.

---

109) Fr. Müller, Die Positivität der Grundrechte, 1969, S. 41.
110) Robert Alexy, Theorie der Grundrechte, Suhrkamp, 1994, S. 378ff.

그러나 Alexy는 기본권에 관한 문제를 일차적으로 보호영역을 정돈하는 것이 아니라 오히려 기본권의 제한문제로 미루어 문제해결을 더욱 복잡하게 한다. 따라서 보호영역을 과도하게 확장하는 것도 협소하게 해석하는 것만큼이나 문제를 해결하는 데 있어서 도움이 되지 않는다.

기본권은 이를 제한하는 국가권력이 항상 정당성의 근거가 있어야 한다는 점에서 초국가적이지만, 타인과의 공동생활을 전제로 한다는 점에서 초사회적이지는 않다.[111] 그러므로 물리적 폭력행사는 이미 기본권의 보호영역에서 벗어나게 되고, 이를 규제하는 조치는 기본권의 제한이 아니라고 할 수 있다. 예컨대, 유아나 처녀를 제물로 바치는 행위는 처음부터 헌법상 종교의 자유에 속하지 아니하며, 따라서 이를 저지하는 것은 종교의 자유에 대한 제한이 아니라고 할 수 있다.

따라서 공동체 존립의 전제가 되는 기본요소를 파괴하는 물리적인 폭력은 모든 기본권의 보호영역에서 벗어난 행위가 된다(다만, 저항권의 행사라는 초헌법적인 권리는 제외된다). 물리적인 폭력의 금지는 공동체 존립의 전제조건으로서 모든 기본권의 보호영역의 한계를 뜻하는 동시에 헌법과 국가성립의 전제조건이기 때문이다. 폭력행위가 아닌 이상 기본권의 보호영역은 폭넓게 해석하는 것이 기본권의 최대한 보장원칙에 적합하다. 왜냐하면 보호영역은 헌법해석을 통하여 기본권이 최대한으로 보장될 수 있는 부분을 찾는데 그 목적이 있기 때문이다.

4. 개별기본권에서의 보호영역의 해석원칙

개별적인 기본권의 보호영역은 1차적으로 개별기본권의 해석에 따라 정하여진다.

첫째, 인간의 본질이나 사회성을 꼽을 수 있다.[112] 생명이나 신체의 불가훼손성 및 신체활동의 임의성 등이 인간의 본질에 속하는 것이라면, 집회·결사나 언론·출판은 인간의 자연적인 사회성에 속한다. 또한 개별적인 기본권 규정에 따라서 부가된 명문의 조건 및 객관적인 해석을 충족시켜야만 보호영역에 포함된다. 가령 '근로조건의 향상을 위하여' 노동3권이 인정되며(헌법 제33조), 교육을 받을 권리(헌법 제31조)도 능력에 따라서 보호된다.

둘째, 개별기본권 규정에서 보호영역은 객관적이고, 예견가능해야 한다.[113] 그렇지 않다면 국민은 어떠한 행위가 기본권의 행사인가를 예견할 수 없으며, 기본권은 생활규범으로서의 성격을 잃고, 국가권력에 의해 자의적으로 측정될 수 있다. 보호영역의 객관성과 예견가능성이 유지되기 위해서는 가치평가와는 무관하게 보호영역이 결정되어야 함을 의미한다. 예컨대, 알콜 중독자나 사회적 저명인사는 똑같이 신체의 자유를 누리며, 상반된 주장을 펼치는 두 집단은 차별없이 집회의 자유를 누려야 한다. 그러나 기본권 목록 가운데 예외적으로 가치를 개입시키기도

111) 어떤 사람이 폭행치상죄로 고소를 당하였고, 고소를 당한 자는 재판관에게 자유로운 나라에서 사람은 자신의 팔을 흔들 권리조차 없느냐고 질문하였다. 이에 대하여 재판관은 "자유로운 나라에서는 팔을 흔들 권리는 다른 사람의 코가 시작되는 곳에서 끝난다"(In a free country your right to swing your arm end where the other mans nose begins)"고 하였다(Rober Lohan, Amerika Du hast es besser, Ungar, 1946, P. 74.).

112) Höfling, Grundrechtstatbestand-Grundrechtsschranken-Grundrechtsschrankenschranken, Jura, 1994, S. 170f.

113) 강태수, "기본권의 보호영역, 제한 및 제한의 한계", 「한국에서의 기본권이론의 형성과 발전」(허영 박사 화갑기념 논문집), 1997, 108면.

한다. 예컨대, 직업은 세 가지 개념요소인 생활수단성, 계속성 및 공공무해성을 갖는다.[114] 공공무해성은[115] 한 사회의 가치관과 밀접한 관계가 있다.

셋째, 기본권의 보호영역은 개별기본권의 해석뿐만 아니라 다른 기본권 및 그 외의 헌법규정(예를 들어 통치조직에 관한 부분)과의 체계적인 연관성에 의해서 그 윤곽이 분명해질 수 있다. 예컨대, 국회의원이란 공직에 취임할 수 있는 권리는 헌법 제41조, 제42조의 국회의원 선거 및 임기에 관한 조항과 연관되어서 고찰한다면 더욱 분명해진다. 또한, 신체의 자유가 헌법 제12조 제1항과 제13조 제1항에 걸쳐서 규정되듯이 보호영역의 범위는 두 개 이상의 조항을 고찰해서 정해야 하는 경우도 있다. 구체적인 사안에서 두 가지 이상의 기본권이 중첩되어 있는 경우도 있지만 적용해야 할 기본권이 특정되는 경우도 있다. 예컨대, 종교적인 신앙고백은 의사표현의 자유가 아니라 종교의 자유에 의해서 특별히 보호된다. 또한 국회에서 의원이 행한 발언은 의사표현의 자유에 의해 보호되는 것이 아니라, 헌법 국회의원의 면책특권을 규정한 제45조에 의해서 보호된다.

넷째, 국가에서 일정한 급부나 작위를 요구하는 소위 사회적 기본권도 자유권과 같이 개별기본권 조항의 해석에 따라서 원칙적으로 보호영역이 결정된다. 단지 국가의 작위나 급부를 내용으로 하는 기본권은 그 보장의 조치가 무한히 다양하고, 완벽한 보장이 이루어질 수 없기 때문에 헌법해석상 최소한의 보장이 요청되고 있다.

다섯째, 평등권은 특정한 사항적·내용적 범위자체를 대상으로 하지 않으므로 특정한 보호영역이 없다. 헌법 제11조 제1항 제1문의 일반적 평등권은 모든 생활영역에서 적용되며, 근거 없는 불평등을 금지하고 있다. 제11조 제1항 제2문, 제2항 및 제3항은 불평등 취급을 하여서는 아니 되는 차별금지 사유를 규정하고 있으며, 헌법 제31조 제1항(교육의 기회균등), 제32조 제4항(여성 근로자의 차별대우 금지), 제36조 제1항(혼인과 가족생활에서의 남녀평등), 제41조 제1항 및 제67조 제1항(평등선거의 원칙) 등은 개별적 평등권을 규율하고 있다. 다른 기본권에서는 기본권의 보호영역에 속하는 행위나 상태에 대한 제한이 기본권 제한의 한계 내에서 이루어 졌는가가 기본권 심사의 근간을 이룬다. 그러나 평등권은 특정한 보호영역 자체를 대상으로 하지 않으므로 상이한 개인이나 인적집단 및 상황 사이의 비교 가능성을 전제로 하여 불평등 취급 또는 평등한 취급이 자의적으로 이루어 졌는가의 심사가 위헌여부의 기준이 된다.

우리 헌법재판소는 합리성과 자의금지, 정의와 형평 등을 그 기준으로 들고, 합리적 차별여부는 ㈎ 인간의 존엄성 존중이라는 헌법의 최고원리와 ㈏ 정당한 입법목적의 달성 ㈐ 수단의 적정성이라는 세 가지 복합적 요소를 기준으로 판단하고 있다.

<헌법재판소 1994. 2. 24. 92헌바43>

형법 제35조가 누범에 대하여 형을 가중한다고 해서 그것이 인간의 존엄성 존중이라는 헌법의 이념에 반하는 것은 아니며, 누범을 가중하여 처벌하는 것은 사회방위, 범죄의 특별예방 및 일반예방, 더 나아가 사회의 안녕질서의 목적을 달성하기 위한 수단이기도 한 것이므로 이는 합리적 근거가 있는 차별이어서 헌법상의 평등의 원칙에 위배되지 아니한다.

<헌법재판소 1989. 5. 24. 89헌가37>

---

114) 남기환, “직업선택의 자유”, 「월간고시」, 1986. 2, 81면; 대법원은 이적표현물의 복사행위를 함에 있어서 의뢰자로부터 대가를 받았다하여 그와 같은 행위를 직업선택의 자유로 볼 수 없다고 판시한 바 있다(대법원 1990. 7. 24. 89도251).

115) 명의대여행위를 한 건설업자가 더 이상 건설업을 영위하지 못하는 등 손해를 입는다고 하더라도 이를 두고 침해되는 사익이 더 중대하다고 할 수는 없으므로 청구인의 직업수행의 자유 및 재산권은 침해한다고 할 수 없다(헌법재판소 2001. 3. 21. 2000헌바27); 허영 교수는 “매춘행위·도박·밀수행위·마약판매업 등은 공공무해성에 위반되어 직업이라 할 수 없다”고 한다.

차별목적의 정당성·필요성에 있어서나 그 수단의 적정성에 있어서 합리적인 근거가 있어야 한다.

<헌법재판소 1992. 6. 26. 91헌가8>

차별수단의 적정성에 보태어 '피해의 최소성', '법익 형평성' 등을 아울러 고려하여야 한다.

<헌법재판소 1993. 7. 29. 89헌마31>

차별수단이 신중하게 다루어져야 한다는 것을 요구하고 있으며, 자의적인 차별의 금지도 받아들이고 있다.

여섯째, 기본권의 보호영역과 제한은 상호간에 밀접한 관계에 있으므로 보호영역이 때로는 제한의 관점에서 더욱 분명하게 결정되기도 하고, 보호되는 범위를 기술하는 실질적인 측면에서 표현될 수도 있으며, 기본권 제한의 종류를 열거하면서 이러한 제한에 대하여 보호된다는 기능적인 측면에서 규정되기도 한다. 헌법 제12조 제1항, 제2항은 신체의 자유를 제한하는 체포·압수·수색·처벌·보안처분·강제노역·고문 등을[116] 열거하면서 신체의 자유는 이러한 제한으로부터 보호된다는 것을 보여주고 있다. 또한, 헌법 제21조에 의하면 언론·출판은 특히 허가나 검열에 대하여,[117] 집회·결사는 허가에 대하여[118] 보호된다.

---

116) <대법원 1992. 11. 24. 92도2409> 피의자가 경찰 수사단계에서 고문에 의한 자백을 하고 그 임의성 없는 심리상태가 검사의 피의자 신문시까지 계속되었다고 인정되는 경우에는, 피의자 신문시에 자백강요사실이 없었다 할지라도 검찰자백의 임의성을 부정하여야 한다.

117) <헌법재판소 1997. 8. 21. 93헌바51 - 음반 및 비디오물에 관한 법률 제16호 제1항의 위헌제청(위헌)> 헌법 제21조 제2항에서 정하는 허가나 검열은 행정권이 주체가 되어 사상이나 의견 등이 발표되기 이전에 예방적 조치로서 그 내용을 심사·선별하여 발표를 사전에 억제하는, 즉 허가 받지 아니한 것의 발표를 금지하는 제도를 뜻하는바 사전허가금지의 보장은 언론·출판자유의 내재적 본질인 표현의 내용을 보장하는 것을 말한다; <헌법재판소 1996. 10. 31. 94헌가6> 검열 금지의 원칙은 모든 형태의 사전적인 규제를 금지하는 것이 아니고, 의사표현의 발표여부가 오로지 행정권의 허가에 달려있는 사전심사만을 금지하는 것이다. 그리고 검열은 일반적으로 허가를 받기 위한 표현물의 제출의무, 행정권이 주체가 된 사전심사절차, 허가를 받지 아니한 의사표현의 금지 및 심사절차를 관철할 수 있는 강제수단 등의 요건을 갖춘 경우에만 이에 해당되는 것이다; <헌법재판소 1996. 8. 29. 94헌바15 - 영화법 제4조 제1항 등 위헌소원(합헌)> 영화법에서 영화의 제작을 업으로 하고자 하는 자에게 등록의무를 부과하는 것은 영화산업의 육성발전을 촉진하고 영화예술의 질적 향상을 도모하기 위하여 문화체육부장관이 영화제작업자의 실태를 파악하여 이를 건전하게 육성하고 그 기능이 공공의 이익과 질서유지에 합당하게 지속적으로 유지·발전되도록 하기 위한 것이므로, 영화법 제4조 제1항 및 제32조 제1호는 헌법상 보장된 표현의 자유의 내용을 간섭하기 위한 것이 아니라 단순히 주무관청의 기본업무인 행정상의 절차와 행정업무상 필요한 사항을 등록하게 하고 이를 규제하기 위하여 그 위반행위에 대한 벌칙규정을 두고 있는데 불과한 것이다. 따라서 위 법률조항은 입법부가 그러한 규제를 함에 있어서 입법재량을 남용함으로써 과잉금지의 원칙에 위반하는 등 자의적인 입법을 하지 않은 이상 그 규제입법 자체를 위헌이라고 할 수 없다; <헌법재판소 1996. 10. 4. 93헌가13 등 병합결정 - 영화법 제10조 등에 대한 위헌제청 등(위헌)> 영화의 상영으로 인한 실정법 위반의 가능성을 사전에 막고, 청소년 등에 대한 상영이 부적절한 경우 이를 유통단계에서 효과적으로 관리할 수 있도록 미리 등급을 심사하는 것은 사전검열이 아니다; <헌법재판소 1992. 6. 26. 90헌바26 - 정기간행물의 등록 등에 관한 법률 제10조 제1항 등에 대한 헌법소원(합헌)> 납본제는 사전검열이 아니다. 헌법재판소는 정기간행물의 등록 등에 관한 법률 제10조 제1항의 납본제도는 문화정책적인 필요성에 따라 도서관진흥법과 국회도서관법에 규정된 납본제도와는 별개로 언론의 건전한 발전과 정기간행물 출판문화의 건전한 향상을 도모하기 위하여 정기간행물을 효율적으로 관리하고 외형적인 질서를 유지하려는 데 그 목적이 있는 것으로, 등록한 정기간행물은 자유로이 발행할 수 있으되 발행한 후에(지체없이) 그 정기간행물 2부를 납본하도록 하고 있음에 불과하여 정기간행물이 외부에 공개 내기 배포되기 이전에 그 표현내용을 심사하여 그 발행금지 내지 어떤 제한이나 제재가 가해지는 것은 아니라 할 것이며, 결국 발행된 정기 간행물을 공보처에 납본하는 것은 그 정

♣ 문제풀이

1. 다음 기술 중 바르지 못한 것은?

① 기본권 보호영역을 확정하는 것은 기본권 제한을 판단하는 것과 직접적인 관련이 없다.
② 헌법상의 개별기본권 규정은 매우 추상적이고, 불확정적적이어서 구체화가 필요하다.
③ 기본권 규범의 구체화는 개별기본권 규정의 문맥 이외에도 그 규정과 관련되는 구체적인 특수성들을 고려하여 해석하는 절차가 필요하다.
④ 헌법상 재산권의 보장은 재산이 갖고 있는 사회적, 경제적 기능을 고려하여 결정될 수 있다.
⑤ 헌법상의 개별기본권 규정은 입법자에 의하여 구체화되기도 한다.

[정답] ①

[해설] 기본권의 보호영역을 확정하는 것은 개별기본권이 헌법적으로 보호될 수 있는 것인지를 판단하는 기준이 되고, 기본권의 제한문제와 밀접하게 연관된다.

2. 다음 보호영역에 대한 기술 중 바른 것은?

① 기본권 보호영역의 구체화 문제는 법률적인 차원에서 다루어지는 것이다.
② 환경권과 같이 입법자에게 폭넓은 입법형성권이 부여되는 경우 입법자는 보호영역의 범위를 자유롭게 정할 수 있다.
③ 입법자에게 폭넓은 입법형성권이 부여되는 경우 보호영역의 범위는 헌법 개정 없이도 법률에 의해서 새롭게 정해질 수 있다.
④ 헌법에 위임이 있는 경우 재산권자의 모든 재산의 사용 및 처분권을 박탈하는 법률의 제정도 가능하다.
⑤ 모든 물리적인 폭력의 금지는 공동체 존립의 전제조건으로서 모든 기본권의 보호영역의 한계를 뜻하는 동시에 헌법과 국가성립의 전제조건이기 때문이다.

[정답] ③

[해설] ① 입법자의 자의를 방지하기 위해 헌법적인 차원에서 다루어야 한다.
② 입법자는 헌법이 허용하는 범위 내에서 개별 기본권의 보호영역을 구체화시킬 수 있다.
④ 헌법상 보장되는 재산권의 본질을 훼손하게 되므로, 이는 헌법상 허용되는 한계를 일탈한 것이 된다.

기간행물의 내용을 심사하여 이를 공개 내지 배포하는 데 대한 허가나 금지와는 전혀 관계없는 것으로서 사전검열이라고 볼 수 없다.

118) <헌법재판소 1992. 1. 28. 89헌가8 - 국가보안법 제7조 등에 관한 위헌심판(한정합헌)> 현저히 사회적 불안을 야기시킬 우려가 있는 집회 또는 시위를 주관하거나 개최한 자를 처벌하고 있는 개정전 집회 및 시위에 관한 법률 제3조 제1항 제4호, 제14조 제1항은 문언해석상 그 적용범위가 과도하게 광범위하고 불명확하므로, 헌법상 보장된 집회의 자유를 위축시킬 수 있고 법운영당국에 의한 편파적·자의적 법운영집행을 가능하게 함으로써 법치주의와 권력분립주의 및 죄형법정주의에 위배 될 수 있으며 법집행을 받는 자에 대한 평등권 침해가 될 수 있어 기본권 제한의 한계를 넘어서게 되어 위헌의 소지가 있다.…그러나 민주체제의 전복을 시도하는 집회·시위나 공공의 질서에 관한 법익침해의 명백한 위험 있는 집회·시위까지 집회의 자유라는 이름으로 보호하는 것이 헌법이 아닌 것이며, 대중적 집회에는 뜻밖의 자극에 의하여 군중의 흥분을 야기시켜 불특정 다수인의 생명·신체·재산 등에 위해를 줄 위험성이 내재되어 있는 것으로 이를 막자는 데도 위 조문의 취의가 있다고 할 것인즉 위 조문의 합헌적이고 긍정적인 면도 간과 서는 안 될 것이므로, 헌법과의 조화, 다른 보호해야 할 법익과의 조정하에 해석상 긍정적인 면을 살리는 것이 마땅하다.…따라서 위 조문은 각 그 소정행위가 공공의 안녕과 질서에 직접적인 위험을 가할 것이 명백한 경우에 적용된다고 할 것이므로 이러한 해석하에 헌법에 위반되지 아니한다.

⑤ 극히 예외적이지만 저항권 행사의 경우 어느 정도 물리적인 폭력이 용인될 수도 있다.

3. 개별기본권 보호영역의 해석에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 개별기본권의 보호영역은 1차적으로 개별기본권의 해석에 따라 정하여진다.
② 개별기본권 규정에서 보호영역은 객관적이고, 예견가능해야 한다.
③ 국가에서 일정한 급부나 작위를 요구하는 사회적 기본권은 특수성이 인정되므로 자유권적 기본권과 같이 개별 기본권 조항의 해석에 따라 보호영역을 결정해서는 안 된다.
④ 기본권의 보호영역과 제한은 상호간에 밀접한 관계에 있으므로 보호영역이 때로는 제한의 관점에서 더욱 분명하게 결정되기도 한다.
⑤ 기본권의 보호영역은 다른 기본권 및 그 외의 헌법규정과의 체계적인 연관성에 의해서 그 윤곽이 분명해질 수 있다.

[정답] ③

[해설] 국가에서 일정한 급부나 작위를 요구하는 사회적 기본권도 자유권과 같이 개별 기본권 조항의 해석에 따라서 원칙적으로 보호영역이 결정된다.

♣ 요점정리

1. 기본권의 논증체계는 기본권 보호영역의 확정, 제한의 존부확인, 제한의 한계준수 여부(제한의 정당성 판단)의 단계로 나누어 볼 수 있다.

2. 기본권 규범의 구체화는 개별기본권 규정의 문맥 이외에도 그 규정과 관련되는 구체적인 특수성들을 고려하여 해석하는 절차가 필요하다.

3. 헌법상 보호영역이 입법자의 권한에 위임되는 경우도 있다. '재산권의 내용과 한계는 법률로 정하며'(제23조 제1항), '환경권의 내용과 행사에 관하여는 법률로 정한다'(제35조 제1항)고 규정되어 있다. 이런 규정은 입법자에게 기본권의 보호영역을 정하는데 있어서 폭넓은 입법형성권을 부여한다.

4. 기본권은 이를 제한하는 국가권력이 항상 정당성의 근거가 있어야 한다는 점에서 초국가적이지만, 타인과의 공동생활을 전제로 한다는 점에서 초사회적이지는 않다. 그러므로 물리적 폭력행사는 이미 기본권의 보호영역에서 벗어나게 되고, 이를 규제하는 조치는 기본권의 제한이 아니라고 할 수 있다.

5. 기본권의 보호영역과 제한은 상호간에 밀접한 관련이 있다. 기본권의 보호영역이 넓으면 넓을수록 국가에 의한 제한의 가능성이 증가하며, 보호영역이 좁으면 좁을수록 국가에 의한 제한의 가능성이 감소하기 때문에 밀접한 관련이 있다.

제8강 기본권의 제한

♣ 학습목표

우리 헌법 제37조 제2항 전단의 의미를 설명할 수 있다.
기본권 제한의 개념과 유형을 설명할 수 있다.
비례의 원칙을 설명할 수 있다.
기본권의 특별한 제한을 설명할 수 있다.
조약에 의한 기본권 제한을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

헌법유보, 법률유보
처분적 법률
법률명확성의 원칙
소급입법금지 및 신뢰보호
국가안전보장, 질서유지, 공공복리
비례의 원칙
특별권력관계, 국가긴급권, 조약에 의한 기본권 제한

♣ 사전테스트

1. 일반적 헌법유보란 헌법에서 직접 기본권 일반이 헌법적 질서 또는 헌법적 원리에 의하여 제약된다고 명시하는 것으로 우리 헌법은 제37조 제2항이 이에 해당한다.

정답 : X
해설 : 일반적 헌법유보에 대한 설명으로 우리 헌법은 이를 채택하고 있지 않다. 헌법 제37조 제2항은 일반적 법률유보조항이다.

2. 피해의 최소성이란 가장 합리적이고 효율적인 수단을 선택해야 함을 의미한다.

정답 : X
해설 : 현저히 불합리하거나 불공정한 수단의 선택이 아니라면 반드시 피해최소의 원칙에 어긋나는 것은 아니다(헌법재판소 1996. 4. 25. 95헌마331).

3. 긴급명령(헌법 제76조)과 제5공화국 헌법상의 비상조치(제51조)는 동일한 조치로서 그 상황적 전제가 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전상태에서 발동된다.

정답 : X

해설 : 긴급명령의 경우는 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전상태에 발하는 데 반하여, 긴급조치는 천재·지변 또는 중대한 재정·경제상의 위기에 처하거나 국가의 안전을 위협하는 교전상태나 그에 준하는 중대한 비상사태라는 점에 차이가 있다.

♣ 돌발퀴즈

기밀이란 국내에서의 적법한 절차를 거쳐 이미 일반인에게 널리 알려진 공지의 사실이라도 그 내용이 누설되는 경우 국가의 안전에 위험을 초래할 우려가 있는 경우 보호할 실질가치를 갖춘 것이라 할 수 있다.

[정답] X

[해설] 기밀이란 공지의 사실이 아니어야 하고, 누설되는 경우 국가의 안전에 위험을 초래할 우려가 있어 기밀로 보호할 실질가치를 갖춘 것이라야 한다(대법원 1997. 7. 16. 97도985).

♣ 강의내용

1. 헌법규정

우리 헌법은 제37조 제2항 전단에서 “국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며”라고 규정하여 국민의 기본권을 제한하는 경우, 부득이한 경우에 한해서 법률로써만 가능하도록 하고 있다. 이는 헌법이 법률유보의 원칙을 통하여 기본권의 제한을 가능하게 하되, 기본권 제한의 한계를 설정함으로써 국가권력의 기본권 침해로부터 국민의 기본권을 보호하고 있음을 의미한다.

2. 개념

기본권의 제한이라 함은 기본권 규정에 의하여 보장된 결정이나 활동의 자유, 특정행위나 영역에 대한 보호를 축소시킴으로써 기본권으로부터 이끌어낼 수 있는 개인의 법적 지위를 전적으로 또는 특정한 경우에 감소시키는 공권력의 행위를 말한다.

3. 유형

⑴ 헌법 직접적 제한(헌법유보)

헌법에서 직접 기본권을 제한하는 명시적 규정을 두는 것으로 입법자의 입법재량권의 한계를 적시하고, 기본권의 남용을 방지한다.

1) 일반적 헌법유보

헌법에서 직접 기본권 일반이 헌법적 질서 또는 헌법적 원리에 의하여 제약된다고 명시하는 것으로 우리 헌법은 이에 해당하지 않으며, 국민의 기본권 보장에 있어 그다지 좋은 방법은 아니다.

2) 개별적 헌법유보

특정의 개별적 기본권에 대하여 헌법적 질서 또는 특정의 헌법원리에 의하여 제약된다는 명문의 규정을 두는 것으로 우리 헌법상 기본권의 내용에 제한을 가하는 경우로는 정당의 해산에 관한 제8조 제4항, 표현의 자유에 관한 제21조 제4항, 재산권 행사의 공공복리적합성을 규정한 제23조 제2항이 있으며, 기본권의 주체에 대하여 제한을 가하는 경우로는 군인 등에 대한 이중배상 제한을 규정한 제29조 제2항, 근로3권과 관련된 공무원과 주요방위산업체 근로자에 대한 제한을 규정한 제33조 제2항과 제3항이 이에 해당한다.

⑵ 헌법 간접적 제한(법률유보)

헌법이 입법자에게 기본권을 법률에 의하여 제한할 수 있도록 명시적 규정을 두고 있는 것으로 제한의 대상이 일반적인가, 개별적인가에 따라 구분되며, 구체적 내용(목적)에 따라 제한적 유보와 형성적 유보, 구체화적 유보가 있다.

1) 일반적 법률유보

기본권 일반에 대하여 법률로써 제한할 수 있도록 규정한 것으로 우리 헌법 제37조 제2항이 이에 해당한다.

2) 개별적 법률유보

개별적 기본권에 법률유보조항을 두어 특정한 기본권을 법률로써 제한하는 것으로 우리 헌법상 재산권보장에 관한 제23조 제1항, 신체의 자유에 관한 제12조, 소급입법금지 등에 관한 제13조가 이에 해당한다.

3) 제한적 법률유보

기본권의 제한과 관련된 원칙적인 법률유보로써 입법자에게 기본권을 제한하는 기능을 부여한 경우이다. 본래적 의미의 법률유보라고도 하며, 우리 헌법 제12조의 신체의 자유에 관한 규정과 제37조의 제2항이 이에 해당한다. 헌법재판소는 교육제도와 교원의 지위에 관한 규정을 제한적 법률유보로 판시한 바 있다.[119]

4) 형성적 법률유보

입법자에게 기본권의 내용을 구체화하는 권한이 부여된 경우를 말한다. 이는 기본권을 구체화하는 법률을 통하여 비로소 당해 기본권의 내용이나 행사절차가 구체화되도록 하는 것이다. 우리 헌법상의 사회권에 규정되어 있는 법률유보는 대체로 형성적 법률유보에 해당하며, 헌법재판소는 우리 헌법 제23조 제1항을 형성적 법률유보로 판시한바 있다.[120] 또한, 우리 헌법재판소는 절차권적 기본권을 형성적 법률유보로 보고 있다.[121] 헌법상 보장된 자유와 권리를 제한하기 위한 법률유보가 아니므로 제한적 법률유보와는 구별된다.

5) 구체화적 법률유보

기본권 구체화적 법률유보에는 입법자에게 기본권의 내용을 자세하게 규정하거나 기본권의 행사를 규제하는 권한을 유보하는 두 가지 경우가 있을 수 있다. 특히 후자의 경우를 기본권 규제적 법률유보라고도 하며, 독일기본법 제12조 제1항 제2문의 '직업행사는 법률에 의하여 또는 법률에 근거로 규제될 수 있다'는 규정이 이에 속한다고 한다. 우리 헌법상 참정권·청구권에 규정되어 있는 법률유보는 기본권 구체화적 법률유보라 할 수 있다.

---

119) 헌법재판소 2001. 1. 18. 99헌바63, 2009. 4. 30. 2005헌바101, 2013. 11. 28. 2007헌마1189 등.
120) 헌법재판소 1993. 7. 29. 92헌바20.
121) 헌법재판소 1993. 3. 11. 92헌마48.

4. 내용

⑴ 형식

1) 법률

국민의 대표기관인 국회에서 제정한 형식적 의미의 법률을 의미한다. 이는 입법의 수권규정인 동시에 제한규정이기도 하다.

가. 자의적 입법금지

나. 오늘날 법률유보원칙은 단순히 행정작용이 법률에 근거를 두기만 하면 충분한 것이 아니라 국가공동체와 그 구성원에게 기본적이고 중요한 의미를 갖는 영역, 특히 국민의 기본권실현과 관련된 영역에 있어서는 국민의 대표자인 입법자가 기본권의 본질적 사항에 대하여 스스로 결정하여야 한다는 요구까지 포함하는 것으로 파악하고 있다.

다. 법률과 동일한 효력의 긴급명령, 긴급재정경제명령, 국제조약 등의 실질적 의미의 법률은 기본권 제한의 일반원칙에 대한 예외로서 인정된다.

라. 개별적 법률(처분적 법률)의 인정 여부

법률은 일반국민에게 널리 적용되는 것이어야 하므로 개별적 사람이나 사건을 규율하는 법률로써 기본권을 제한하는 것은 원칙적으로 금지된다.

<헌법재판소 1996. 2. 16. 96헌가2, 96헌바7·13 병합> 개별사건법률금지의 원칙이 법률제정에 있어서 입법자가 평등원칙을 준수할 것을 요구하는 것이기 때문에, 특정규범이 개별사건에 해당한다고 하여 곧 바로 위헌을 뜻하는 것은 아니다. 비록 특정법률 또는 법률조항이 단지 하나의 사건만을 규율하려고 한다 하더라도 이러한 차별적 규율이 합리적인 이유로 정당화될 수 있는 경우에는 합헌적일 수 있다. 따라서 개별사건법률의 위헌여부는, 그 형식만으로 가려지는 것이 아니라, 나아가 평등의 원칙이 추구하는 실질적 내용이 정당한지 아닌지를 따져야 비로소 가려진다.

마. 법률 명확성의 원칙

a. 의미

기본권 제한의 경우, 법률은 명확하여야 한다는 것으로 법치국가원리의 한 표현이라고 할 수 있다. 이는 적용대상자가 그 규제내용을 미리 알 수 있도록 분명하게 규정하여 장래의 행동지침으로 삼을 수 있도록 하여야 한다는 것으로 제한되는 기본권의 특정이 필요하다.

<헌법재판소 1998. 4. 30. 95헌가16> 명확성의 원칙이란 기본적으로 최대한이 아닌 최소한의 명확성을 요구하는 것이라고 한다. 곧 법문언의 해석을 통해서, 곧 법관의 보충적인 가치판단을 통해서 그 의미내용을 확인해낼 수 있고, 그러한 보충적 해석이 해석자의 적인 취향에 따라 좌우될 가능성이 없다면 명확성의 원칙에 반한다고 할 수 없다고 한다.

<헌법재판소 2000. 4. 27. 98헌바95> 일반조항의 해석을 위한 판단지침을 내포하고 있어야 할 뿐만 아니라, 그 일반조항자체가 그러한 구체적 예시들을 포괄할 수 있는 의미를 담고 있는 개념이어야 한다.

b. 대상

기본권을 제한하는 모든 입법이며, 특히 형벌의 구성요건에서 중요한 의미를 가진다.

c. 판단기준

ㄱ) 입법목적, 취지에 비추어 건전한 상식과 통상인의 법감정을 통하여 판단하고,

ㄴ) 구체적 사건에서 법관의 합리적 해석이 가능하면 충분하며,

ㄷ) 다른 조항과 연관성, 합리적 해석 가능성, 입법기술상 한계 등을 고려한다.

바. 소급입법의 금지 및 신뢰보호

사. 입법절차의 준수

입법제정절차가 헌법상 일반원칙인 적법절차의 원칙에 반하여서는 안 된다는 것으로 적법절차에는 절차내용의 적법도 포함된다고 본다.

아. 포괄적 위임입법의 금지

위임입법이 현대사회에서는 불가피하나 처벌법규의 경우, 특히 긴급, 필요, 법률로 정할 수 없는 부득이 사정, 구성요건의 예측 가능성, 형벌의 종류 및 상한과 폭을 명백히 규정하여야 한다는 것이다. 그러나 규율대상이 지극히 다양하고 수시로 변화하는 것이라면 다소 완화하여 다른 법률조항과 입법취지, 대강의 예측가능성 고려하여 판단한다. 위임의 구체성과 명확성은 그 규율대상의 종류와 성격에 따라 다르다.

⑵ 목적(국가안전보장, 질서유지, 공공복리)

1) 국가안전보장

국가안전보장이란 외부로부터의 국가의 존립과 안전[122] 그리고 이와 관련되는 내부적 안전과 존립을 보장하는 데 국한된다고 볼 수 있다.[123] 국가안전보장을 위하여 기본권을 제한하는 법률로는 내란죄와 외환죄 등을 규정하고 있는 형법, 국가보안법[124] 등을 들 수 있다.

---

122) <헌법재판소 1990. 4. 2. 89헌가113 - 국가보안법 제7조 제1항과 제5항에 대한결정(한정합헌)> 국가의 존립·안전을 위태롭게 한다 함은 대한민국의 독립을 위협·침해하고 영토를 침략하여 헌법과 법률의 기능 및 헌법기관을 파괴·마비시키는 것으로 외형적인 적화공작 등일 것이다.

123) <헌법재판소 1992. 2. 25. 89헌가104 - 군사기밀보호법 제6조 등에 대한 위헌심판(합헌)> 헌법 제37조 제2항은 '국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다'고 하는 이른바 법률유보조항을 두고 있는바, 국가의 안전보장은 헌법상 중요한 국가적 법익의 하나로서 위의 규정이외에도 헌법 제5조 제2항, 제39조 제1항, 제66조 제2항, 제69조 등이 국가의 안전보장과 관련이 있는 것이다. 헌법 제37조 제2항에서 기본권 제한의 근거로 제시하고 있는 국가의 안전보장의 개념은 국가의 존립·헌법의 기본질서의 유지 등을 포함하는 개념으로서 결국 국가의 독립, 영토의 보전, 헌법과 법률의 기능, 헌법에 의하여 설치된 국가기관의 유지 등의 의미로 이해될 수 있을 것이다.

124) <헌법재판소 1997. 1. 16. 92헌바6 등 병합> 일반적으로 국가기밀은 일반인에게 알려지지 아니한 것, 즉 비공지의 사실(넓은 의미)로서, 국가의 안전에 대한 불이익의 발생을 방지하기 위하여 그것이 적국 또는 반국가 단체에 알려지지 아니하도록 할 필요성, 즉 요비닉성이 있는 동시에, 그것이 누설되는 경우 국가의 안전에 명백한 위험을 초래한다고 볼 만큼의 싱질적 가치가 있는 것, 즉 실질비성을 갖춘 것이어야 한다.

2) 질서유지

질서유지란 내부에 있어서의 국가의 존립과 안전의 보장을 의미한다.[125] 그 밖에도 질서유지의 개념에는 경찰법적 의미의 공공질서가 포함된다.[126] 질서유지를 위해 기본권을 제한하는 법률로는 형법, 집회와시위에관한법률, 민방위기본법, 청소년보호법, 소방기본법, 도로교통법, 경범죄처벌법, 경찰법, 경찰관직무집행법, 풍속영업의 규제에 관한 법률, 화염병사용 등의 처벌에 관한 법률 등이 이에 해당한다.

3) 공공복리

공공복리란 매우 불확정적이고 다의적인 개념이다. 다만 국가안전보장이나 질서유지가 소극적인 개념이라면, 공공복리는 적극적인 개념이라고 보고 있다. 공공복리의 국가성·전체성·일반성을 해석기준으로 볼 수 있다면 공공복리란 사회생활을 영위하는 구성원, 곧 개개 국민의 다수의 실질적 이익으로 정의 될 수 있을 것이다.[127] 공공복리의 내용을 결정하는 것은 궁극에 있어서 사회적 정의의 이념일 수밖에 없다. 추상적인 사회정의의 원칙은 언제나 존재하는 것이지만, 그 구체적 내용은 때와 장소를 초월하여 고정될 수는 없는 것이며, 특정한 사회, 경제, 정치의 조건변화에 따라 변한다. 그러므로 공공복리의 구체적인 내용은 구체적 국가의 헌법질서에 있어서 통설적인 헌법판례에 의하여 구현된다 할 것이다. 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 건축법, 산림법, 도로교통법,[128] 하천법, 항공법, 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 자연재해대책법, 전기통신사업법, 사방사업법, 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 등이 이에 해당한다.[129]

<대법원 1997. 7. 16. 97도985> 현행 국가보안법 제4조 제1항 제2호 (나)목에 정한 기밀을 해석함에 있어서 그 기밀은 정치, 경제, 사회, 문화 등 각 방면에 관하여 반국가단체에 대하여 비밀로 하거나 확인되지 아니함이 대한민국의 이익이 되는 모든 사실, 물건 또는 지식으로서, 그것들이 국내에서의 적법한 절차 등을 거쳐 이미 일반인에게 널리 알려진 공지의 사실, 물건 또는 지식에 속하지 아니한 것이어야 하고, 또 그 내용이 누설되는 경우 국가의 안전에 위험을 초래할 우려가 있어 기밀로 보호할 실질가치를 갖춘 것이어야 한다.

125) 권영성 교수는 “헌법 제37조 제2항의 질서라 함은 자유민주적 기본질서를 포함하는 헌법적 질서는 물론이고 그 밖의 사회적 안녕질서를 의미한다”고 하고 있으며, 김철수 교수는 “광의로 해석하는 경우에는 국가질서와 민주적 기본질서가 포함될 것이며, 협의로 해석하여 국가질서나 민주적 기본질서는 국가의 안전보장과 질서유지를 넓은 의미의 질서유지로 보고 이것을 엄밀하게 구별할 실익은 별반 없다”고 한다.

126) <헌법재판소 1995. 7. 21. 92헌마144 - 서신검열 등 위헌확인(일부인용, 일부각하, 일부기각, 일부한정위헌)> 증거인멸이나 도망을 예방하고 교도소 내의 질서를 유지하여 미결구금제도를 실효성 있게 운영하고 일반사회의 불안을 방지하기 위하여 미결수용자의 서신에 대한 검열은 그 필요성이 인정된다고 할 것이고, 이로 인하여 미결수용자의 통신의 비밀이 일부 제한되는 것은 질서유지 또는 공공복리라는 정당한 목적을 위하여 불가피할 뿐만 아니라 유효적절한 방법에 의한 최소한의 제한으로서 헌법에 위반된다고 할 수 없다.

127) <헌법재판소 1998. 5. 28. 96헌가5 - 기부금품모집금지법 제3조 등 위헌제청(위헌)> 입법자는 공익실현을 위하여 기본권을 제한하는 경우에도 입법목적을 실현하기에 적합한 여러 수단 중에서 되도록 국민의 기본권을 가장 존중하고 기본권을 최소로 침해하는 수단을 선택해야 한다. 기본권을 제한하는 규정은 기본권 행사의 ‘방법’에 관한 규정과 기본권 행사의 ‘여부’에 관한 규정으로 구분할 수 있다. 침해의 최소성의 관점에서, 입법자는 그가 의도하는 공익을 달성하기 위하여 우선 기본권을 보다 적게 제한하는 단계인 기본권 행사의 ‘방법’에 관한 규제로써 공익을 실현할 수 있는가를 시도하고 이러한 방법으로는 공익달성이 어렵다고 판단되는 경우에 비로소 그 다음 단계인 기본권 행사의 ‘여부’에 관한 규제를 선택해야 한다.

128) <헌법재판소 1990. 8. 27. 89헌가118 - 도로교통법 제50조 제2항 등에 관한 위헌심판(한정합헌)> 도로교통법 제50조 제2항, 제111조 제3호는 교통질서유지 및 사회공동체의 상호이익을 보호하는 공공복리를 위한 필요에서 합리적으로 제정된 것이라 할 것이다.

129) 이와 관련하여 헌법재판소는 일정한 범위에서의 토지사용의 제한을 규정한 도시계획법 제21조(헌법

⑶ 대상 : 모든 권리

자유권 이외의 권리는 기본권 절차와 형성의 구체화 의미, 자유권만 대상이라는 견해가 있으나 통설은 모든 자유권과 권리라고 한다.

⑷ 필요 : 과잉금지의 원칙(비례의 원칙)

1) 의의

법의 일반원칙으로 공사법에 널리 통용되고 있다. 헌법적 근거로는 법치국가원리, 헌법 제37조 2항이며, 위헌심사에 있어 판단원칙이다.

2) 내용 : 목적의 정당성, 수단(방법)의 적절성, 피해의 최소성, 법익의 균형성

가. 목적의 정당성

국가안보, 질서유지, 공공복리 외에 추가로 정당한 목적이 필요하며, 제한되는 기본권과 목적간의 균형을 의미한다. 헌법재판소는 국민의 기본권을 제한하는 입법은 그 목적이 헌법과 법률의 체계 내에서 정당성을 인정받을 수 있는 것이어야 할 것을 요구한다.

<헌법재판소 2007. 12. 27. 2004헌마1021 - 의사와 한의사 복수면허를 가진자에게 하나의 의료기관만 운영하도록 제한한 의료법규정> “그 제한의 목적과 수단이 정당하다고 보기 어렵다”고 하여 위헌선언을 하였다.

나. 수단(방법) 적절성

목적을 달성함에 있어서 필요하고, 효과적이며, 목적에 적합한 조치를 의미한다. 반드시 유일한 방법이었을 것을 요하지는 않으나 합리적 판단에 입각해 필요하고 효과적이어야 한다.

<헌법재판소 1997. 8. 21. 94헌가19 등 병합 - 근로기준법 제30조의2 제2항에 대한 헌법소원> “근로자의 퇴직금 전액에 대하여 담보권자에 우선하는 변제수령권을 인정하는 방법은 적절하지 않다”고 판시하였다. <헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13 결정> “이러한 적정의 방법의 수단이 그 목적달성을 위하여 유일무이한 것일 필요는 없다”고 판시하였다.

다. 피해의 최소성

최소 침해를 의미하며, 임의적 규정으로도 가능함에도 구체적 사안의 개별성과 특수성을 고려하여 가능성을 일체 배제하는 필요적 규정을 둔 경우에는 위배가 된다. 그러나 가장 합리적이고 효율적인 수단을 선택할 필요는 없고, 현저히 불합리하거나 불공정한 수단의 선택이 아니라면 반드시 피해최소의 원칙에 어긋나는 것은 아니다.

<헌법재판소 1998. 5. 28. 96헌가5 - 기부금품모집금지법 제3조 등에 대한 위헙제청> “기본권을 제한하는 기본권 제한의 ‘방법’에 관한 규정과 기본권 행사의 ‘여부’에 관한 규정으로 구분할 수 있다. 침해의 최소성의 관점에서, 입법자는 그가 의도하는 공익을 달성하기 위하여 우선 기본권을 보다 적게 제한하는 단계적인 기본권 행사의 ‘방법’에 관한 규제로써 공익을 실현할 수 있는가를 시도하고 이러한 방법으로는 공익달성이 어렵다고 판단되는 경우에 비로소 그 다음 단계인 기본권 행사의 ‘여부’에 관한 규제를 선택해야 한다”고 판시하고 있다

재판소 1998. 12. 24. 89헌마214 등 병합결정), 자동차운행자에게 무과실책임을 지우는 자동차손해배상보장법 제2조 단서 2호(헌법재판소 1998. 5. 28. 96헌가4 병합결정), 국민건강을 위해서 구 약사법상 약사에게 인정된 한약조제권의 제한을 규정한 약사법 부칙 제4조 제2항(헌법재판소 1997. 11. 27. 97헌바10 결정), 주택건설촉진법에 의한 도시재개발사업(헌법재판소 1997. 4. 24. 96헌가3 등 병합결정), 구토지공시및토지등의평가에관한법률의 표준지가공시에 관한 이의신청기간의 제한(헌법재판소 1996. 10. 4. 95헌바11 결정) 등을 공공복리를 위한 것으로 인정하였다.

<헌법재판소 1996. 4. 25. 95헌마331 - 법무사법시행규칙 제35조 제4항 위헌확인(기각)> "완화된 수단이 있다고 하더라도 선택된 제한조치가 입법목적 달성에 유효적절한 수단인 경우 제한조치가 현저히 불합리하거나 불공정하지 않는 한 완화된 수단이 있는 것만 가지고 최소침해의 원칙에 위반된다고 할 수 없다"고 판시하고 있다.

또한, 같은 조치라도 선거사범인 여자수용자에게 유치장에서 하의와 속옷을 무릎까지 내려서 실시한 신체검사는 위헌(헌법재판소 2000. 7. 18. 2000헌마327), 마약류 사범인 구치소 수용자가 교도관 앞에서 항문검사를 받은 신체검사는 합헌(헌법재판소 2006. 6. 29. 2004헌마826)으로 결정하였다.

라. 법익의 균형성

기본권 제한입법에 의하여 보호하려는 이익과 침해되는 사익을 비교형량할 때 공익이 더 크거나 적어도 양자 사이에 균형이 유지되도록 할 것을 요구한다.[130]

5. 특별한 제한

⑴ 특별권력관계

1) 의의

이는 공무원·군인·수형자 등처럼 이른바 '특별권력관계'에 있는 사람들도 일반 국민과 마찬가지로 기본권을 주장할 수 있는 것인지, 아니면 이들의 기본권은 법률에 의하지 않고서도 얼마든지 제한할 수 있는 것인지의 문제이다.

과거에는 특별권력관계에 의한 기본권 제한이 지배적 견해였지만, 현대의 특별권력관계이론에 의하면 기본권은 원칙적으로 배제되는 것이 아니라, 다만 제한될 수 있을 뿐이며, 기본권은 포기·양도할 수 없으며, 기본권 중에는 특별권력관계에 의해서도 제한될 수 없는 기본권(인간으로서의 존엄과 가치, 행복 추구권 등)이 존재한다는 견해에 이르고 있다.

2) 우리 헌법상 특별권력관계

우리 헌법은 이른바 과거의 특별권력관계에 해당되는 공무원의 근무관계(헌법 제7조, 제29조, 제33조 제2항, 제78조), 병역의무관계(헌법 제39조, 제27조 제2항, 제110조), 학생교육관계(헌법 제31조), 수형자복역관계(헌법 제12조, 제13조, 제27조, 제28조) 등을 규정하고 있다.

이러한 특별관계에 있는 자들의 기본권을 법률로써 최소한으로 제한하는 것은 우리 헌법의 전체취지에 어긋나지 않는다.[131] 이들은 국가에 대한 밀접한 관계 때문에 특수한 것으로 보일 뿐 그 본질은 법률에 의한 기본권 제한의 한 유형에 속하므로, 기본권 침해에 대한 사법적 권리수단도 그대로 적용된다.[132]

---

130) 헌법재판소 1999. 4. 29. 96헌바10, 1998. 11. 26. 97헌바31, 1998. 2. 27. 97헌바20 결정 등.

131) <헌법재판소 1999. 2. 25. 97헌바3 결정> 예비역이 병역법에 의하여 병력동원훈련 등을 위하여 소집을 받는 것은 헌법과 법률에 따른 국방의 의무를 이행하는 것이고, 그 동안 군형법의 적용을 받는 것 또한 국방의 의무를 이행하는 중에 범한 군사상의 범죄에 대하여 형벌이라는 제재를 받는 것이다.

132) <헌법재판소 1992. 10. 1. 92헌마68 등 병합결정> 국립대학인 서울대학교는 특정한 국가목적(대학교육)에 제공된 인적·물적 종합시설로서 공법상의 영조물이다. 그리고 서울대학교와 학생과의 관계는 공법상의 영조물이용관계로서 공법관계이며, 병역의무와 공무원근무관계가 결코 기본권의 사각지대가 될 수 없고 기본권의 효력이 미친다.

헌법재판소는 병역복무관계(1989. 10. 27. 89헌마56), 공무원근무관계(1993. 12. 23. 92헌마247), 그리고 수형자복역관계(1998. 8. 27. 96헌마398)가 결코 기본권의 사각지대가 될 수 없고, 기본권의 효력이 미치기 때문에 권리구제가 가능하다고 판시하였다.

예컨대 공무원은 법률에 의하여 표현의 자유가 제한된다(형법 제127조, 국가공무원법 제60조, 정당법 제45조 등). 또한, 공무원은 공직에 입후보하기 위해서는 일정시기까지 사임하여야 한다(공직선거법 제53조). 이 밖에도 특별권력관계에 있는 자들은 여러 법률에 의하여 기본권이 제한된다.[133] 또한, 법률의 구체적인 위임이 있는 경우에는 법규명령에 의하여 기본권이 제한될 수 있다.

<헌법재판소 2003. 11. 27. 2002헌마193 - 군사법원법제242조제1항등위헌확인(위헌)> 헌법 제37조 제2항에 의하면 기본권은 원칙적으로 법률로써만 이를 제한할 수 있다고 할 것이지만, 헌법 제75조에 의하여 법률의 위임이 있고 그 위임이 구체적으로 범위를 정하여 하는 것이라면 대통령령에 의한 기본권의 제한도 가능하다. 그런데 군행형법 제15조 제2항에서 '수용자의 교화 또는 처우상 특히 부적당하다고 인정되는 사유가 없는 한 이를 허가하여야 한다'고 규정하여 면회의 횟수를 제한하지 않는 자유로운 면회를 전제로 하면서, 제6항에서 '면회에의 참여에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다'고 규정함으로써, 면회에의 참여에 관한 사항만을 대통령령으로 정하도록 위임하고 있고 면회의 횟수에 관하여는 전혀 위임한 바가 없다. 따라서 이 사건 시행령규정이 미결수용자의 면회횟수를 매주 2회로 제한하고 있는 것은 법률의 위임 없이 접견교통권을 제한하는 것으로서, 헌법 제37조 제2항 및 제75조에 위반된다.

(2) 국가긴급권 행사에 의한 제한

1) 의의

국가긴급권 행사에 의한 제한은 헌법의 기초가 중대한 위협을 받게 되는 국가긴급상태 또는 국가비상사태가 발생하는 경우에 이를 빠른 시일 내에 정상상태로 돌려놓기 위해서 여러 가지 수단을 마련해 놓고 있다. 여러 가지 수단에는 기본권을 제한하는 조치도 포함된다. 우리 헌법

<헌법재판소 1993. 12. 23. 92헌마24 결정 - 법관전보발령처분에 대한 사건> 경찰공무원을 비롯한 공무원의 근무관계인 이른바 특별권력관계에 있어서도 일반행정관계에 있어서와 마찬가지로 행정청의 위법한 처분 또는 공권력의 행사·불행사 등으로 인하여 권리 또는 법적 이익을 침해당한 자는 행정소송 등에 의하여 그 위법한 처분 등의 취소를 구할 수 있다고 보아야 할 것이다.

<대법원 1982. 7. 2. 80누86 판결> 특별권력관계에 있어서도 위법·부당한 특별권력관계의 발동으로 인하여 권리를 침해당한 자는 그 위법·부당한 처분의 취소를 구할 수 있다.

133) <헌법재판소 2004. 3. 25. 2001헌마710 - 초·중등학교 교원의 정당가입·선거운동의 금지(합헌)> 초·중등학교의 교원 즉 교사는 법령이 정하는 바에 따라 학생을 교육하는 자이고(교육기본법 제9조, 초·중등교육법 제20조 제3항), 반면에 대학원 교원 즉 교수·부교수·조교수와 전임강사는 학생을 교육·지도하고 학문을 연구하되, 학문연구만을 전담할 수 있다(고등교육법 제15조 제2항). 이와 같이 현행 교육법령은 양자의 직무를 달리 규정하고 있다. 물론 대학교수도 학생을 교육하기는 하나 그 주된 직무는 연구기능이므로, 이 점에서 매일 매일을 학생과 함께 호흡하며 수업을 하고 학생을 지도해야 하는 초·중등학교 교원에 비하여 상대적으로 많은 학문연구와 사회활동의 자유가 인정된다(헌법재판소 1993. 7. 29. 91헌마69). 뿐만 아니라 초·중등학교의 교육은 일반적으로 승인된 기초적인 지식의 전달에 중점이 있는데 비하여, 대학의 교육은 학문의 연구·활동과 교수기능을 유기적으로 결합하여 학문의 발전과 피교육자인 대학생들에 대한 교육의 질을 높일 필요성이 있기 때문에 대학교원의 자격기준도 이와 같은 기능을 수행할 수 있는 능력을 갖출 것이 요구된다(헌법재판소 1998. 7. 16. 96헌바 33 등). 그렇다면 초·중등학교의 교원에 대해서는 정당가입과 선거운동의 자유를 금지하면서 대학교원에게는 허용한다 하더라도, 이는 양자간 직무의 본질이나 내용 그리고 근무태양이 다른 점을 고려할 때 합리적인 차별이라고 할 것이므로 청구인이 주장하듯 헌법상의 평등권을 침해한 것이라고 할 수 없다.

은 제76조와 제77조에서 긴급명령 등에 의한 기본권제한과 비상계엄하에서의 기본권제한을 규정하고 있다.

2) 유형

가. 긴급재정·경제명령에 의한 기본권의 제한

헌법 제76조 제1항은 "대통령은 내우·외환·천재·지변 또는 중대한 재정·경제상의 위기에 있어서 국가의 안전보장 또는 공공의 안녕질서를 유지하기 위하여 긴급한 조치가 필요하고 국회의 집회를 기다릴 여유가 없을 때에 한하여 최소한으로 필요한 재정·경제상의 처분을 하거나 법률의 효력을 가지는 명령을 발할 수 있다"고 하여 긴급재정·경제명령권을 규정하고 있다. 긴급재정·경제명령은 긴급재정·경제처분의 효력을 법적으로 보장하려는 데 그 의의가 있다.

긴급재정·경제명령은 그 목적에 있어서 재정·경제상의 위기에 있어서 공공의 안녕질서를 유지하기 위하여 재정·경제상의 최소한도의 필요한 처분을 위한 명령으로써 행해지는 것이므로, 대통령이 긴급재정·경제명령을 발동해서 기본권을 제한하기 위해서는 일정한 요건이 요구된다.[134] 대통령의 긴급재정·경제명령은 내우·외환·천재·지변 또는 중대한 재정·경제상의 위기에 있어 발하는 명령이라는 점에서 비상사태와 차이가 있고,[135] 제한할 수 있는 기본권의 범위는 재산권, 근로3권, 직업의 자유 등과 같은 경제적 기본권과 그에 관련되는 기본권만을 제한할 수 있다. 그에 반하여 긴급명령에 의하여 제한될 수 있는 기본권은 그러한 제한이 없다.

이러한 긴급재정·경제명령이 발동되면 그 명령은 법률의 효력을 가지기 때문에(헌법 제76조 제1항), 기존의 법률을 개정 또는 폐지하는 것도 가능하며, 또 법률과 같이 국민의 재정·경제생활영역을 제한하는 조치를 할 수도 있다. 그러나 긴급재정·경제명령권에 대해서는 사후적으로 국회와 헌법재판소가 통제할 수 있다. 따라서 긴급재정·경제명령은 지체 없이 국회의 소집을 요구하고 국회에 보고하여 그 사후승인을 받아야 한다(사후적 통제). 국회의 승인을 받지 못한 때에는 그 명령은 그때부터 효력을 상실할 뿐만 아니라 그 명령에 의해서 개정·폐지된 법률은 당연히 그 효력을 회복한다(헌법 제76조 제3항·4항).

---

134) <헌법재판소 1996. 2. 9. 93헌마186 - 금융실명거래및비밀보장에관한긴급재정경제명령(대통령긴급재정경제명령 제16호)의 위헌심판> 대통령의 긴급재정경제명령은 국가긴급권의 일종으로서 고도의 정치적 결단에 의하여 발동되는 행위이고 그 결단은 존중하여야 할 필요성이 있는 행위라는 의미에서 이른바 통치행위에 속한다고 할 수 있으나, 통치행위를 포함하여 모든 국가작용은 국민의 기본권적 가치를 실현하기 위한 수단이라는 한계를 반드시 지켜야 하는 것이고, 헌법재판소는 헌법의 수호와 국민의 기본권 보장을 사명으로 하는 국가기관이므로 비록 고도의 정치적 결단에 의하여 행해지는 국가작용이라고 할지라도 그것이 국민의 기본권 침해와 직접 관련되는 경우에는 당연히 헌법재판소의 심판대상이 된다. 긴급재정경제명령은 정상적인 재정운용·경제운용이 불가능한 중대한 재정·경제상의 위기가 현실적으로 발생하여(장래에 있어서 위기가 발생할 우려가 있다는 이유로 사전적·예방적인 경우제외), 긴급한 조치가 필요함에도 국회의 폐회 등으로 국회가 현실적으로 집회될 수 없고 국회의 집회를 기다려서는 그 목적을 달성할 수 없는 경우에 이를 사후적으로 수습함으로써 기존질서를 유지·회복하기 위하여(공공복지 증진·문화향상 들과 같은 적극적 목적 제외) 위기의 직접적 원인의 제거에 필수불가결한 최소의 한도 내에서 헌법이 정한 절차에 따라 행사되어야 한다.

135) 긴급명령은 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전상태에 있어서 발하는 명령이라는 점에서 비상사태와 차이가 있다. 특히 긴급재정경제명령이 긴급명령과 다른 점은 긴급재정경제명령의 발동목적이 재정·경제상의 위기에 있어서 공공의 안녕질서를 유지하기 위한 명령인데 반하여, 긴급명령은 교정상태에 있어서 국가를 보위하기 위한 명령이라는 점에서 그 차이가 있다. 또한 긴급재정경제명령은 국회의 집회를 기다릴 여유가 없을 때 발하는 명령이며, 긴급명령은 국회의 소집이 불가능 한 때 발하는 명령이다. 그 밖에 긴급재정경제명령은 재정·경제상의 최소한도의 필요한 처분을 위한 명령이지만, 긴급명령은 국가를 보위하기 위하여 전반적 조치를 취하기 위한 명령이라는 점에 그 차이가 있다.

나. 긴급명령에 의한 기본권의 제한

헌법 제76조 제2항은 “대통령은 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전상태에 있어서 국가를 보위하기 위하여 긴급한 조치가 필요하고 국회의 집회가 불가능한 때에 한하여 법률의 효력을 가지는 명령을 발할 수 있다”고 하여 긴급명령권을 규정하고 있다.

긴급명령으로 기본권을 제한하기 위해서는 일정한 요건이 필요하다. 긴급명령은 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전상태에 있어서 발하는 명령이라는 점에서 비상사태와 차이가 있고,[136] 제한할 수 있는 기본권의 범위는 기본권 전반에 대하여 제한할 수 있다.

이러한 긴급명령이 발동되면 그 명령은 법률과 같은 효력을 가지기 때문에 기본 법률의 개폐는 물론이고 국민의 기본권을 제한하는 조치를 취할 수 있다.[137] 그러나 긴급명령에 대해서도 사후적으로 국회와 헌법재판소가 통제할 수 있다.[138] 긴급명령은 국회의 사후승인을 받아야 하며(헌법 제76조 제3항), 국회의 승인을 얻지 못한 경우에는 그 명령은 그때부터 효력을 상실한다. 이 경우 그 명령에 의하여 개정 또는 폐지되었던 법률은 그 명령의 승인을 얻지 못한 때부터 당연히 효력을 회복한다(헌법 제76조 제4항).

다. 비상계엄하에서의 기본권의 제한

헌법 제77조 제1항은 “대통령은 전시·사변 또는 이에 준하는 국가비상사태에 있어서 병력으로써 군사상의 필요에 응하거나 공공의 안녕질서를 유지할 필요가 있을 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 계엄을 선포할 수 있다.”고 규정하고 있다.

계엄은 일시적으로나마 군에 의한 통치를 가능하게 한다는 점에서, 헌법규정의 일부조항을 배제할 수 있다는 점에서 가장 강력한 국가긴급권이라 할 수 있다. 비상계엄으로 기본권을 제한하기 위해서는 일정한 요건이 필요하다. 또한 계엄의 본질이 일반 국민에게까지 군정이 확대되고, 민선정부의 의사를 군사령관의 의사로 대신하는 것이므로 계엄의 선포요건은 엄격하게 해석하여야 한다.

이러한 비상계엄이 선포된 때에는 헌법 제77조 제3항을 구체화한 계엄법 제9조 제1항의 규정에 따라 “제포·구금·압수·수색·거주·이전·언론·출판·집회·결사 또는 단체행동에 대하여 특별한 조치”가 행해질 수 있다. 또한 비상계엄하에서는 민간인도 군사법원의 재판을 받으며(헌법 제27조 제2항, 헌법 제110조), 비상계엄하의 군사재판은 일정한 범죄에 한하여 사형선고의 경우를 제외하고는 단심재판이 허용된다(헌법 제110조 제4항).

---

136) 긴급명령(헌법 제76조)과 제5공화국 헌법상의 비상조치(제51조)와는 그 상황적 전제가 긴급명령의 경우는 국가의 안위에 관계되는 중대한 교전상태에 발하는 데 반하여, 긴급조치는 천재·지변 또는 중대한 재정·경제상의 위기에 처하거나 국가의 안전을 위협하는 교전상태나 그에 준하는 중대한 비상사태라는 점에 차이가 있다. 발동기간에 있어서도 긴급명령은 기간에 관하여 아무런 규정을 두고 있지 않은데 반하여, 긴급조치는 목적을 달성할 수 있는 최단기간내로 한정하고 있다. 긴급명령은 국회의 집회가 불가능한 때에만 가능하나, 긴급조치는 국회의 휴·폐회와 관계없이 발동될 수 있다. 또한 긴급명령은 국회가 해제를 요구하거나 건의할 수 있으나, 긴급조치는 국회가 그 해제를 대통령에게 요구할 수 있다. 그 효력면에 있어서도 긴급명령은 오로지 법률적 효력만을 가지는데 그치나, 긴급조치는 법률적 효력뿐만 아니라 헌법적 효력을 가질 수 있다. 그리고 긴급명령은 그 대상을 명시하고 있지 않으나, 긴급조치는 국정전반을 대상으로 하고 국민의 자유와 권리의 잠정적인 정지는 물론, 정부나 법원의 권한에 관한 특별조치도 가능하다.

137) 그러나 이 경우에도 재정·경제명령과 마찬가지로 헌법 제37조 제2항의 일반적 법률유보에 의한 기본권제한의 규범적 한계인 목적상·내용상·방법상의 한계는 반드시 존중되어야만 한다고 할 것이다.

138) 국회는 “불승인·사후법률개정·탄핵소추 등으로 통제”, 헌법재판소는 “위헌법률심판이나 헌법소원에 의해 통제”가 가능하다.

특별한 조치의 내용에 대해서는 계엄법 제9조 제2항에서 “비상계엄지역 안에서는 계엄사령관은 법률이 정하는 바에 의하여 동원 또는 징발할 수 있으며, 필요한 경우에는 군수에 공할 물품의 조사·등록과 반출금지를 명할 수 있다”고 규정하고 있으며, 동조 제3항에서는 “계엄사령관은 부득이한 경우에는 국민의 재산권을 파괴 또는 소훼한 경우에는 정당한 보상을 하여야 한다”고 규정하고 있다.

이러한 비상계엄의 선포는 대통령이 국회에 지체 없이 통고하여야 하며(헌법 제77조 제4항), 국회가 그 재적의원과반수의 찬성으로 계엄의 해제를 요구한 때에는 대통령은 이를 해제하여야 한다(헌법 제77조 제5항).[139]

6. 조약에 의한 기본권의 제한

기본권은 양국가간의 조약이나 다변적인 국제조약에 의해서도 제한될 수 있다. 현재의 국제연합인권규약과 같은 다변조약은 오히려 기본권을 보장하기 위한 것이나, 조약(예를 들면 SOFA 조약)에 의해서도 특정한 기본권은 제한될 수 있다. 국회는 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 조약 또는 입법조항에 관한 조약의 체결·비준에 대한 동의권을 가지고 있으며(헌법 제60조 제1항), 국회의 동의를 얻은 조약은 국내법과 같은 효력을 가지므로 당연히 기본권을 제한할 수 있다. 뿐만 아니라 일반적으로 승인된 국제법규도 국내법과 같은 효력을 가지게 되므로 기본권을 제한할 수 있다(헌법 제6조 제1항). 그러나 조약 및 일반적으로 승인된 국제법규로[140] 인한 기본권은 제한은 국가안전보장·공공복리를 위하여 필요한 경우에 국한된다고 보아야 한다.

♣ 문제풀이

1. 기본권제한의 유형 중 그 성격이 다른 하나는?

① 정당의 해산에 관한 제8조 제4항
② 언론출판이 타인의 명예와 권리를 침해한 경우 피해배상을 규정한 제21조 제4항
③ 재산권행사의 공공복리적합성을 규정한 제23조 제2항
④ 신체의 자유에 관한 제12조 제1항
⑤ 주요방위산업체 근로자에 대한 제한을 규정한 제33조 제3항

[정답] ④
[해설] ①②③⑤는 헌법유보, ④는 법률유보

---

139) 의결정족수와 관련하여 긴급재정경제명령의 경우, 헌법 제49조의 규정에 의해 일반의결정족수를 적용하여 재적의원과반수의 출석과 출석의원과반수의 찬성을 얻도록 하고 있는 데 반하여, 계엄해제요구에는 가중된 의결정족수인 재적의원과반수의 찬성을 필요로 하게 하여(헌법 제77조 제5항), 계엄의 해제를 어렵게 하고 있다.

140) <헌법재판소 1991. 7. 22. 89헌가106 - 사립학교법 제55조, 제58조 제4호에 관한 위헌심판(합헌)> 국제연합의 ‘인권에 관한 세계선언’에 관하여 보면, 이는 그 전문에 나타나 있듯이 ‘인권 및 기본적 자유의 보편적인 종중과 준수의 촉진을 위하여…사회의 각 과 각 기관이 국제연합 가맹국 자신의 국민사이에 또 가맹국 관할하의 지역에 있는 인민들 사이에 기본적인 인권과 자유의 존중을 지도·교육함으로써 촉진하고 또한 그러한 보편적, 효과적인 승인과 준수를 국내적·국제적인 점진적 조치에 따라 확보할 것을 노력하도록, 모든 국민과 모든 나라가 달성하여야 할 공통의 기준’으로 선언하는 의미는 있으나 그 선언내용인 각 조항이 바로 보편적인 법적 구속력을 가지거나 국제법적 효력을 갖는 것으로 볼 것은 아니다.

2. 법률유보에 대한 설명으로 가장 바르지 못한 것은?

① 처분적 법률 중 개별적 사람에 대한 규정은 원칙적으로 금지되나 개별적 사건에 대한 규정은 과거질서에 대한 회복이라는 점에서 원칙적으로 허용된다.

② 오늘날 법률유보는 단순히 행정작용이 법률에 근거를 두기만 하면 충분한 것이 아니라 국가공동체와 구성원에게 기본적이고도 중요한 의미를 갖는 영역에 있어서는 국민의 대표자인 입법자가 본질적인 사항에 대해서 스스로 결정하여야 한다는 요구까지도 내포하고 있다.

③ 입법부도 수권의 범위를 넘어 자의적인 입법을 할 수는 없다.

④ 위임입법은 법률로 정할 수 없는 부득이한 사정, 구성요건의 예측 가능성, 형벌의 종류 및 상한과 폭을 명백히 규정하는 경우 인정될 수 있다.

⑤ 법률은 적용대상자가 규제내용을 미리 알 수 있도록 분명하게 규정하여 행동지침으로 삼을 수 있도록 명확하여야 한다.

[정답] ①

[해설] 처분적 법률은 원칙적으로 금지된다.

3. 과잉금지원칙(비례원칙)에 대한 설명 중 타당하지 않은 것은?

① 법의 일반원칙으로 공사법에 널리 통용되고, 헌법적 근거로는 헌법 제37조 제2항이며, 위헌심사에 있어 판단원칙이다.

② 목적의 정당성이란 제한되는 기본권과 목적간의 균형을 의미하며, 우리 헌법재판소는 국민의 기본권을 제한하는 입법은 그 목적이 헌법과 법률의 체계 내에서 정당성을 인정받을 수 있는 것이어야 할 것을 요구한다고 판시한 바 있다.

③ 수단의 적절성이란 목적을 달성함에 있어서 필요하고, 효과적이며, 목적에 적합한 조치를 의미하는 것으로 목적 달성에 유일한 방법인지의 여부가 합리적 판단의 기준이 된다.

④ 법익의 균형성이란 기본권 제한입법에 의하여 보호하려는 이익과 침해되는 사익을 비교형량할 때 공익이 더 크거나 적어도 양자 사이에 균형이 유지되도록 할 것을 의미한다.

⑤ 피해의 최소성이란 최소침해를 의미하며, 현저히 불합리하거나 불공정한 수단의 선택이 아니라면 피해최소의 원칙에 어긋나는 것이라 단정할 수는 없다.

[정답] ③

[해설] <헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13 결정> 적정의 방법의 수단이 그 목적달성을 위하여 유일무이한 것일 필요는 없다.

♣ 요점정리

1. 기본권의 제한이라 함은 기본권 규정에 의하여 보장된 결정이나 활동의 자유, 특정행위나 영역에 대한 보호를 축소시킴으로써 기본권으로부터 이끌어낼 수 있는 개인의 법적 지위를 전적으로 또는 특정한 경우에 감소시키는 공권력의 행위를 말한다.

2. 목적의 정당성이란 국가안보, 질서유지, 공공복리 외에 추가로 정당한 목적이 필요하며, 제한되는 기본권과 목적간의 균형을 의미하고, 수단의 적절성이란 목적을 달성함에 있어서 효과적이며, 목적에 적합한 조치를 의미하며, 피해의 최소성이란 최소 침해를 의미하며, 법익의

균형성이란 기본권 제한입법에 의하여 보호하려는 이익과 침해되는 사익을 비교형량할 때 공익이 더 크거나 적어도 양자 사이에 균형이 유지되도록 할 것을 의미한다.

3. 현대의 특별권력관계이론에 의하면 기본권은 원칙적으로 배제되는 것이 아니라, 다만 제한될 수 있을 뿐이며, 기본권은 포기·양도할 수 없으며, 기본권 중에는 특별권력관계에 의해서도 제한될 수 없는 기본권(인간으로서의 존엄과 가치, 행복 추구권 등)이 존재한다고 한다.

4. 국가긴급권 행사에 의한 기본권 제한은 헌법의 기초가 중대한 위협을 받게 되는 국가긴급상태 또는 국가비상사태가 발생하는 경우에 이를 빠른 시일 내에 정상상태로 돌려놓기 위해서 행사된다.

5. 국회는 국가나 국민에게 중대한 재정적 부담을 지우는 조약 또는 입법조항에 관한 조약의 체결·비준에 대한 동의권을 가지고 있으며(헌법 제60조 제1항), 국회의 동의를 얻은 조약은 국내법과 같은 효력을 가지므로 당연히 기본권을 제한할 수 있다. 뿐만 아니라 일반적으로 승인된 국제법규도 국내법과 같은 효력을 가지게 되므로 기본권을 제한할 수 있다(헌법 제6조 제1항).

제9강 기본권의 제한의 한계

♣ 학습목표

우리 헌법 제37조 제2항 후단의 의미를 설명할 수 있다.
본질적 내용 침해금지의 원칙을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

목적상의 한계, 방법상의 한계, 내용상의 한계
본질적 내용 침해금지의 원칙

♣ 사전테스트

1. 국가안전보장·질서유지·공공복리 또는 헌법의 수호를 위하여 행해지는 기본권 제한도 목적상의 한계의 범주에 해당한다.

   정답 : O

2. 우리 헌법재판소는 우리 헌법 제37조 제2항에서 과잉금지를 명문으로 인정하고 있다고 판시하면서, 법률이 기본권 제한의 한계를 일탈했는가를 판단하는 데는 언제나 과잉금지의 원칙을 그 기준으로 삼고 있다.

   정답 : O
   해설 : 헌법재판소 1992. 12. 24. 92헌가8

3. 입법자에게 광범위한 입법권이 부여되는 경우에 기본권을 제한하는 법률은 입법자의 재량에 의한다.

   정답 : X
   해설 : 기본권 자체의 본질적 내용이 형해화될 정도의 제한은 금지된다.

♣ 돌발퀴즈

헌법상 기본권의 보장이 인간으로서의 존엄과 가치를 모든 인간의 생활영역에서 실현시키기 위한 것이라면 기본권은 법률로서 제한할 수 있다.

[정답] X
[해설] 헌법상 기본권의 보장이 인간으로서의 존엄과 가치를 모든 인간의 생활영역에서 실현시키기 위한 것이라고 한다면, 인간으로서의 존엄과 가치를 정면으로 침해하는 기본권의 제한은 비록 법률에 의한 것이라 할지라도, 어떠한 경우를 막론하고 허용되어서는 안 된다.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 의의

현행 헌법 제37조 제2항은 형식적 측면에서는 '일반적 법률유보'의 형식을 빌리고 있으나, 내용적 측면에서는 국민의 기본권을 제한하는 법률은 '국가안전보장·질서유지·공공복리'(목적상의 한계), '필요한 경우'(방법상의 한계), '법률로써'(형식상의 한계), '본질적 내용의 침해금지'(내용상의 한계)를 지켜야 한다.

우리 헌법 제37조 제2항의 본질적 내용의 침해금지규정은 4·19혁명 이후에 제3차 헌법개정에서 처음으로 도입되었다. 즉, 제28조 제2항 단서로서 "단 그 제한은 자유와 권리의 본질적인 내용을 훼손하여서는 아니 되며, 언론·출판에 대한 허가나 검열과 집회·결사에 대한 허가를 규정할 수 없다"고 규정하였다. 이는 독일 기본법 제19조 제2항을 모방한 것으로서 5·16쿠데타 이후에도 유지되다가 유신헌법에서는 폐지되었고, 다시 1980년 헌법에서 부활되어 현행 헌법에 이르게 되었다.

기본권의 본질적 내용이 현실적으로 매우 중요한 의미를 가진 최초의 사건은 국가배상청구권에 관련한 1971년 대법원 판결이다.[141] 대법원은 "군인 또는 군속이 공무원의 직무상 불법행위의 피해자인 경우에 그 군인 또는 군속에게 이로 인한 손해배상청구권을 제한 또는 부인하는 국가배상법 제2조 제1항 단서는 헌법 제26조에서 보장된 국민의 기본권인 손해배상청구권을 헌법 제32조 제2항의 질서유지 또는 공공복리를 위하여 제한할 필요성이 없이 제한한 것이고, 헌법 제9조의 평등의 원칙에 반하여 군인 또는 군속인 피해자에 대해서만 그 권리를 부인함으로써 그 권리 자체의 본질적 내용을 침해하였으며, 기본권 제한의 범주를 넘어 권리 그 자체를 박탈하는 규정이므로 이는 헌법 제26조, 제8조, 제9조 및 제32조 제2항에 위반된다 할 것이다"라고 판시하였다.[142]

2. 목적상의 한계

법률유보의 원칙은 궁극적으로는 기본권을 최대한 존중하면서도 헌법에 의해서 보호되고 있는 기타의 법익, 기본원칙, 제도 등을 기본권적인 가치와 전체적·통일적으로 실현시키려는 것이다. 예컨대, 국제평화주의를 헌법상 기본원칙으로 채택하고 있는 우리 헌법질서 내에서 국제평화를 파괴하거나, 침략전쟁을 준비하는 방향의 기본권 행사를 막기 위한 법률을 제정해서 기본권을 제한하는 것은 목적적 한계의 관점에서 허용될 수 있는 일이라고 할 것이다. 이러한 점에서 국가안전보장·질서유지·공공복리 또는 헌법의 수호를 위하여 행해지는 기본권 제한도 목적상의 한계의 범주에 해당한다.

3. 방법상의 한계

기본권 제한의 방법상 한계는 기본권 제한의 정도를 의미하는 것으로서 과잉금지의 원칙(비례의 원칙)을 의미한다. 이러한 방법상의 한계는 실질적으로 법률에 의한 기본권 제한의 가장 핵심적인 한계를 의미한다.[143]

---

141) 대법원 1971. 6. 22. 70다1010.

142) 그러나 이 판결은 군인 군무원의 국가배상청구청구권 그 자체를 박탈한 것이므로 본질적 내용침해임이 분명하나 기본권의 본질적 내용이 무엇인가에 대한 내용은 없었다.

기본권의 제한의 요건을 구비한 경우에도 기본권을 어느 정도까지 제한할 수 있느냐가 문제된다. 기본권은 국가안전보장·질서유지·공공복리를 이유로 제한이 가능하지만 그 제한의 사유가 존재한다고 하여 반드시 제한하여야 하는 것은 아니다. 왜냐하면 필요한 경우에 한하여(필요성의 원칙) 제한할 수 있다고 규정하고 있기 때문이다.

법률에 의한 기본권 제한은 기본권의 제한을 불가피하게 하는 현재의 목적을 달성하기 위해서 필요한 최소한의 범위 내에서만 허용될 뿐 아니라 보호되는 '법익'과 제한되는 기본권 사이에는 합리적이라고 평가할 수 있는 일정한 비례관계(비례원칙)가 성립되어야 한다.

4. 형식상의 한계

형식상의 한계에서 법률은 일반적 법률의 형식으로 제정되어야 한다. 여기서 말하는 일반적 법률이라 함은 불특정 다수인을 대상으로 하는 일반성과 불특정 다수의 경우를 의미하는 추상성의 요건을 충족시키는 법률을 의미한다. 이는 결국 규범수신인의 일반성과 규율대상의 일반성, 즉 기본권 제한 법률이 불특정 다수인을 상대로 하여 불특정 다수의 경우를 규율하는 일반적 법률의 형식으로 제정되어야 함을 의미한다. 왜냐하면 그것이 현대헌법국가의 기본원리인 민주주의, 법치주의(국가), 사회국가의 중요한 핵심적인 내용인 실질적 자유·평등·정의의 실현과 밀접하게 관련되어 있기 때문이다.

일반적이어야 한다는 것은 개별적인 경우나 개별적인 사항을 법률의 내용으로 할 수 없다는 의미이다. 이것은 입법의 형식을 띤 행정처분이나 처분적 법률,[144] 그리고 실질적 재판에 해당하는 사권 침탈법은 원칙적으로 금지됨을 의미이다. 결국 헌법 제37조 제2항 전단에 의거한 기본권을 제한하는 법률은 국회가 제정한 형식적 의미의 법률을 지칭한다.

5. 내용상의 한계

기본권을 제한하는 법률은 제한의 내용적 측면에 있어서도 일정한 한계가 있다. 즉 기본권 제한의 현실적인 필요성이 존재한다고 할지라도 그 제한으로 인하여 그 기본권 자체의 본질적 내용(Wesensgehalt)이 형해화될 정도의 제한은 금지된다는 것이다(본질적 내용 침해금지의 원칙).

헌법상 기본권의 보장이 인간으로서의 존엄과 가치를 모든 인간의 생활영역(정치적·경제적·사회적·문화적)에서 실현시키기 위한 것이라고 한다면, 인간으로서의 존엄과 가치를 정면으로 침해하는 기본권의 제한은 비록 법률에 의한 것이라 할지라도, 어떠한 경우를 막론하고 허용되어

143) 우리 헌법재판소는 우리 헌법 제37조 제2항에서 과잉금지를 명문으로 인정하고 있다고 판시하면서, 법률이 기본권 제한의 한계를 일탈했는가를 판단하는 데는 언제나 과잉금지의 원칙을 그 기준으로 삼아야 한다고 판시한 바 있다(헌법재판소 1992. 12. 24. 92헌가8).

144) 입법자는 정의를 지향하고 형법전이나 민법전처럼 특정구성요건이 성립되면 특정의 법적결과가 발생하는 법률만을 제정하는 것은 아니다. 오히려 입법자는 경제적, 문화적, 사회적 목적을 달성하려 한다. 이러한 목적들을 달성하기 위하여 입법자는 아주 구체적인 사안과 관련하여 특정의, 구체적 계획을 실현시키는 법률을 제정한다. 그러한 법률을 '처분법률'(maßnahmegesetzes)이라 한다. 처분법률의 특징은 구체적인 목적을 가지고 있고, 그 목적이 법률에 규정된 조치에 대하여 논리적으로 우위를 가진다는 점이다. 고전적 의미의 법률이 의도하는 바가 장기적으로 생활영역에 질서를 부여하는 것이라면, 처분법률은 직접적이고 특정된 목적을 추구하며 처분법률에 의하여 내려진 명령이 전적으로 이러한 목적을 지향한다. 고전적 의미의 법률은 그것이 성립하게 된 구체적인 동기와는 무관하게 효력을 가짐에 반하여, 처분법률은 구체적인 목적에 대한 수단인 것이 그 전부다.

서는 안 된다. 이와 같은 관점에서 우리 헌법 제37조 제2항 후단은 “자유와 권리의 본질적 내용은 침해할 수 없다”고 규정하고 있고, 독일기본법 제19조 제2항에서는 “In keinem Falle darf ein Grundrecht in senem Wesensgehalt angetastet werden”[145]이라고 규정하여 내용상의 한계를 명백히 밝히고 있다.

6. 본질적 내용 침해금지의 원칙

(1) 견해의 대립

한태연[146] 교수는 법률의 제한에 의하여 기본권이 제한된 경우에 그 기본권이 그 본래적 기능을 상실한 경우에 본질적 내용의 침해라고 설명하고 있다.

박일경[147] 교수는 제한의 정도가 제한의 필요의 정도와 비례를 잃을 만큼 지나친 경우에 본질적 내용의 침해라고 설명하고 있다. 이는 독일에서의 상대설의 논지와 정확히 일치한다.

안용교[148] 교수는 본질적 내용이란 기본권의 핵이 되는 실체라고 하면서, 이는 법원의 심사에 의하여 확인할 수 있다고 설명하고 있다.

양건[149] 교수는 본질적 내용이란 기본권의 본질적 내용을 이루는 개개 기본권의 토대를 이루는 핵심이라고 하면서, 이러한 본질적 내용의 판단기준은 인간으로서의 존엄에 대한 침해여부에 대해서 개별적 기본권마다 구체적으로 판단되어야 한다고 설명하고 있다.

구병삭[150] 교수는 기본권의 본질적 내용은 각 기본권의 핵심을 의미한다고 하면서, 구체적인 내용은 사법적 판단에 의한다고 설명하고 있다.

계희열[151] 교수는 기본권의 본질적 내용침해금지조항은 경고적 의의를 가질 뿐 이라고 하면서, 기본권의 본질적 내용은 허용된 제한의 가능성이 끝나는 곳에서 시작되며, 제한의 법익과 보호의 법익이 동시에 최적의 실효성을 나타낼 수 있는 경계가 그 한계라고 한다. 그러한 경계는 결국 양법익이 동시에 최대한 실현될 수 있도록 비례적으로 정서하는 것이라고 설명하고 있다.

강태수[152] 교수는 본질적 내용의 독자적인 영역을 미리 확정하는 것은 어렵다고 하면서, 추상적으로 언급해서 기본권의 내적인 핵심 내지는 실체적인 최소한의 영역이 제한되어서 당해 개별기본권의 존재가치가 없는 경우에 본질적 내용이 침해된다고 설명하고 있다.

권영성[153] 교수는 기본권의 본질적 내용이 되는 것은 모든 기본권에 공통된 최소한의 어떤 가치에다가 각 기본권 특유의 어떤 고유가치를 더한 것이라고 설명하고 있다.

김철수[154] 교수는 기본권의 본질적 내용은 개별기본권마다 다르지만, 각 기본권의 근본요소라고 하면서 인간의 존엄과 가치에 관계가 있고, 개별 기본권의 근본요소는 사법기관의 심사에 의해 결정된다고 설명하고 있다.

---

145) 어떠한 경우에도 기본권의 본질적 내용이 침해되어서는 안 된다.
146) 한태연, 「헌법학」, 법문사, 1985, 909면.
147) 박일경, 「제6공화국 신헌법」, 법경출판사, 1990, 215면.
148) 안용교, 「한국헌법」, 고시연구사, 1992, 315~316면.
149) 양건, 「헌법연구」, 법문사, 1995, 390~401면.
150) 구병삭, 「신헌법원론」, 박영사, 1996, 382면.
151) 계희열, 「헌법학」(상), 박영사, 1995, 89~90면.
152) 강태수, “기본권의 보호영역, 제한 및 제한의 한계”, 「한국에서의 기본권이론의 형성과 발전」(허영 박사 화갑기념 논문집), 1997, 143면.
153) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 340면.
154) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 355면.

전광석[155] 교수는 본질적 내용은 인간의 존엄과 가치가 개별기본권들의 개별생활영역에서 보호하는 기능을 수행한다고 하면서, 본질적인 내용침해금지조항은 개별적으로 관찰하여야 한다고 설명하고 있다.

허영[156] 교수는 본질적 내용침해금지조항은 내용상의 한계에 대한 선언적 의미를 갖는다고 하면서, 내용상의 한계는 법률유보의 개념본성적 한계에서 마땅히 나오는 한계라고 설명하고 있다.

홍성방[157] 교수는 기본권의 본질적 내용은 모든 기본권에 공통된 부분과 개별기본권에 특유한 부분, 즉 하나의 기본권을 다른 기본권과 구별지우는 부분으로 구성된다고 하면서, 모든 기본권에 공통된 본질적 내용은 그 기본권에 포함된 인간의 존엄과 가치이며, 각 기본권에 특유한 본질적 내용은 개별기본권마다 다르다고 한다. 이 두 가지는 서로 불가분의 요소를 이루기 때문에 어느 하나를 침해하면 전체로서 그 기본권의 본질적 내용이 침해된다고 한다. 특히 개별기본권의 특유한 본질적 내용과 관련하여 이론과 판례는 각 기본권의 특유한 본질적 내용만을 밝힐 수 있고 또한 그래야 한다고 설명하고 있다.

⑵ 대법원

대법원은 기본권의 본질적 내용침해금지가 기본권 제한의 한계라는 것을 명시적으로 인정하고 있다. “군인복무규율 제38조는 헌법, 국군조직법, 군인사법 및 군인복무규율의 각 규정에 근거하여 군인의 기본권을 제한하고 있는 규정으로 보아야 할 것이며 이는 특수한 신분관계에 있는 군인에 대하여 국방목적 수행상 필요한 군복무에 관한 군율로서 그 규제가 합리성을 결여하였다거나 기본권의 본질적인 내용을 침해하고 있다고 볼 수도 없으므로”[158] 또는 “양심의 자유, 언론·출판 등 표현의 자유, 집회·결사의 자유, 거주·이전의 자유, 통신의 자유, 사상의 자유 등은 헌법이 보장하는 기본적 권리이긴 하나 무제한적인 것이 아니라 헌법 제37조 제2항에 의하여 국가안전보장, 질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에는 그 자유와 권리의 본질적 내용을 침해하지 않는 한도 내에서 제한할 수 있는 것”[159] 또는 “정당활동의 자유를 제한하기 위하여는 헌법 제37조 제2항에 따라 국가안전보장, 질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 법률의 규정에 의하여만 가능하고 이를 제한하는 경우에도 정당활동의 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없는 것”[160]이라고 판시하여 본질적 내용침해금지가 기본권 제한의 한계임을 확인하고 있다. 그러나 대법원판례의 경우 기본권의 본질적 내용침해금지가 무엇인지에 대한 상세한 언급은 하지 않고 있다.[161]

⑶ 헌법재판소

헌법재판소는 기본권의 본질적 내용침해금지규정이 기본권 제한의 한계임을 명시적으로 확인하였다. 나아가 본질적 내용의 의미와 침해여부의 판단기준을 판단하고 있다. “토지재산권의 본질적 내용이라는 것은 토지재산권의 핵이 되는 실질적 요소 내지 근본요소를 뜻하며, 따라서

155) 전광석, 「한국헌법론」, 법문사, 2009. 235면.
156) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 476면.
157) 홍성방, 「헌법학」(상), 박영사, 2010, 425면.
158) 대법원 1991. 4. 23. 90누4839 결정.
159) 대법원 1993. 9. 28. 93도1730 결정.
160) 대법원 1994. 4. 12. 93도2712 결정.
161) 이와 관련하여 대법원 1985. 5. 28. 81도1045 결정의 반대의견(대법관 이정우, 이회창, 오성환의 의견)은 “헌법이 보장한 자유 또는 권리의 본질적인 내용이라 함은 기본권의 근본요소로서 이를 제한하게 되면 기본권이 유명무실하게 되어버리는 그러한 권리의 실체를 가리킨다”고 하여 본질적 내용침해금지의 내용을 밝히고 있다.

재산권의 본질적인 내용을 침해하는 경우라고 하는 것은 그 침해로 사유재산권이 유명무실해지고 사유재산제도가 형해화되어 헌법이 재산권을 보장하는 궁극적인 목적을 달성할 수 없게 되는 지경에 이르는 경우라고 할 것이다"라고[162] 판시한 바 있다.

또한, 헌법재판소는 본질적 내용의 근본요소와 관련하여 "기본권의 본질적 내용은 만약 이를 제한하는 경우에는 기본권 그 자체가 무의미하여지는 경우에 그 본질적인 요소를 말하는 것으로서 이는 개별 기본권마다 다를 수 있을 것이다"라고[163] 판시하여 기본권의 본질적 내용침해 여부를 판단함에 있어 개별 기본권마다 개별적·구체적으로 판단하고 있다.

7. 비례의 원칙과의 관계

비례의 원칙과 본질적 내용침해금지의 관계에 대하여 대법원과 헌법재판소의 판례는 일관되지 못한 경향을 보이고 있다.

대법원의[164] 경우 "생수국내시판금지가 국민의 기본권을 제한하는 것으로서 국가안전보장, 질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 것이 아니거나 또한 필요한 것이라고 하더라도 국민의 자유와 권리를 덜 제한하는 다른 방법으로 그와 같은 목적을 달성할 수 있다든지 위와 같은 제한으로 인하여 국민이 입게 되는 불이익이 그와 같은 제한에 의하여 달성할 수 있는 공익보다 클 경우에는 이와 같은 제한은 비록 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해하는 것이 아니더라도 헌법에 위반되는 것임을 면할 수 없는 것"이라고 하여 본질적 내용침해금지를 비례의 원칙과 구별하기도 하고, "구대통령선거법 제33조 제1항이 선거운동의 정의를 포괄적으로 정의하였지만 제2항에 의하여 특정한 후보자를 위한 득표를 목적으로 한다는 주관적 요소의 개입이 없는 정치적 의견의 개진이나 의사표시를 선거운동의 범주에서 배제하여 제34조에 의한 제한을 받지 아니하도록 함과 동시에 처벌받는 행위의 범위도 합리적으로 정하고 있다고 할 수 있으므로, 위의 제 규정들은 헌법 제12조 제1항, 제13조 제1항에서 보장한 죄형법정주의와 법치주의 및 권력분립의 원칙에 위배된다거나 제21조 제1항에서 보장한 표현의 자유와 제1조 제2항, 제24조, 제25조로부터 도출되는 참정권을 제37조 제2항이 정한 과잉제한 금지의 원칙에 위배하여 제한하고 있다고 할 수 없으며"라고[165] 하여 본질적 내용침해금지와 비례의 원칙을 명확히 구분하지 않는 경우도 있다.

헌법재판소는 비례의 원칙과 본질적 내용침해금지에 대하여 "기본권의 본질적 내용을 침해하였다거나 이를 과도하게 제한한 경우에 해당하지 않으므로"[166] 또는 "과잉금지원칙에 위배되어 본질적 내용을 침해한 것"[167] 혹은 "과잉금지원칙에 반하는 것이라고 아니할 수 없어 기본

---

162) <헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13 - 국토이용관리법 제21조의3 제1항, 제31조의2> 본질적 내용의 침해태양으로 '사유재산제도의 전면부정', '재산권의 무상몰수', '소급입법에 의한 재산권 박탈'
<헌법재판소 1999. 4. 29. 94헌바37 등 병합 - 「토지소유상한에 관한 법률」 제2조 제1호 나목 등> 재산권의 본질적 내용으로 '사적유용성'과 '처분권'
<헌법재판소 2000. 6. 1. 98헌바34 - 공유수면매립법 제26조 제2항>토지의 부당한 침해에 대한 '원상회복청구권'

163) <헌법재판소 2000. 6. 1. 98헌마216 - 「국가유공자예우 및 지원에 관한 법률」 제20조 제2항> 자유와 권리의 보장은 1차적으로 헌법상 개별 기본권규정을 매개로 이루어지지만, 기본권 제한에 있어서 인간의 존엄과 가치를 침해한다거나 기본권 형성에 있어서 최소한의 필요한 보장조차 규정하지 않음으로써 결과적으로 인간의 존엄과 가치를 훼손한다면 헌법 제10조에서 규정한 인간의 존엄과 가치에 위반된다.

164) 대법원 1994. 3. 8. 92누1728 참조.

165) 대법원 1994. 9. 13. 93도1840 참조.

166) 헌법재판소 1995. 2. 23. 91헌마203(교육시행령 제71조 등에 대한 헌법소원); 1996. 6. 26. 96헌마200(공직선거및선거부정방지법 제16조 제3항 위헌확인) 등 참조.

권의 본질적 내용을 침해할 수 없다"라고[168] 하거나, "권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없는 바, 위 제한의 한계로서 과잉금지의 원칙을 적용할 수 있다"[169], "과잉금지원칙에 반하지 않을 뿐 아니라 본질적 내용을 침해하지 못 한다"[170] 등의 판시에서 비례의 원칙과 본질적 내용침해금지를 구별하지 않고 판단하고 있으며, "본질적인 내용의 침해가 없을지라도 비례의 원칙 내지는 과잉금지원칙에 위배되어서는 안 된다"고[171] 하여 양자를 구별하여 판단하고 있기도 하며, "본질적 내용침해금지의 원칙에서 본질적인 내용은 헌법상의 각 기본권마다 가진 특유의 내용이므로, 근로3권의 핵이 되는 실질적 요소 내지 근본요소를 뜻한다고 할 것이며, 따라서 근로3권의 본질적인 내용을 침해하는 경우라고 하는 것은 그 침해로 인하여 근로3권이 유명무실해지고 근로3권이 형해화되어 헌법이 근로3권을 보장하는 궁극적인 목적을 달성할 수 없게 되는 지경에 이르는 경우라고 할 것이다"라고[172] 하여 비례원칙의 언급 없이 본질적 내용만을 판단한 경우도 있다.

그러나 비례의 원칙과 본질적 내용침해금지는 구별하여 따로 판단하는 것이 타당하다고 생각한다. 왜냐하면 첫째, 비례의 원칙은 기본권 외적요소에 의한 법적평가인데 반하여 본질적 내용침해금지는 기본권 내적요소에 의한 평가이기 때문이다.[173] 즉, 형식원리인 비례의 원칙은 구체적 개별기본권과 관련하여 비로소 기본권의 내용과 관련되는데 반하여, 본질적 내용침해금지는 직접적으로 구체적 개별기본권의 내용으로부터 도출된다는 점에서 차이가 있다.

둘째, 기본권의 본질적 내용보장을 비례의 원칙과 동일한 내용으로 파악하는 것은 헌법규정의 의미를 무시하는 것이다.[174] 즉, 제37조 제2항에서는 "국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용은 침해할 수 없다"라고 규정하고 있다. 그러나 입법권자가 헌법에 보장된 기본권이라도 법률로써 제한할 수 있다는 의미로 법률유보를 이해하는 경우, 기본권이 공동화되는 것을 방지할 수 없게 된다. 따라서 기본권 제한의 최후적 한계로서 본질적 내용침해금지가 기능하여야 한다. 즉, 기본권이 입법자를 통하여 공동화되는 것을 방지하려는 헌법제정권자의 의지의 표현을 존중하여야 한다.

셋째, 비례의 원칙과 본질적 내용침해금지를 동일시하는 경우에는 긴급한 목적이 있는 경우에 기본권의 본질적 내용이 황폐화될 수 있다.[175] 즉, 비례의 원칙을 준수한 제한인 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해하는 경우가 발생할 수 있기 때문이다. 예컨대, 본질적 내용침해금지가 제대로 기능하지 못하였던 독일의 나치정권시절에는 가장 경미한 침해를 일으키는 수단이라면 언제든지 또 얼마든지 기본권을 제한할 수 있는 것으로 비례의 원칙을 곡해하여 본질적 내용침해금지를 공허한 개념으로 전락시켰다. 이러한 경우에 비례의 원칙과 본질적 내용침해금지를 동일시하여 판단하는 것은 국민의 기본권 보장에 하등의 도움이 될 수 없다. 따라서 독자적인 기준으로서의 본질적 내용침해금지가 비례의 원칙에 대한 합헌성 판단의 한계로서 기

---

167) 헌법재판소 1995. 2. 23. 93헌가1(건축사법 제28조 제1항 제2호 위헌제청) 참조.
168) 헌법재판소 1992. 4. 28. 90헌바24(특정범죄가중처벌등에관한법률 제5조의3 제2항 제1호에 대한 헌법소원) 참조.
169) 헌법재판소 1989. 9. 8. 88헌가6(국회의원선거법 제33조, 제34조의 위헌심판) 참조.
170) 헌법재판소 2002. 4. 25. 2001헌가27 참조.
171) 헌법재판소 1990. 9. 3. 89헌가95(국세기본법 제35조 제1항 제3호의 위헌심판); 1997. 8. 21. 94헌바19 등 병합(근로기준법 제30조의2 제2항 등 위헌제청); 1999. 6. 24. 98헌바68(구상속세법 제26조 제2항의 위헌소원) 등 참조.
172) 헌법재판소 1990. 9. 3. 89헌가95; 1989. 12. 22. 88헌가13.
173) 김대환, "우리나라 헌법상 과잉금지원칙", 「공법학연구」 제6권 제3호, 한국비교공법학회, 2005. 12, 207~208면.
174) 김대환, "독일에서의 기본권의 본질적 내용보장에 관한 판례분석", 「경성법학」, 경성대학교 법학연구소, 2006, 120면.
175) 김대환, 전게논문(주 33), 212면.

능하여야 한다. 이것이 헌법 제10조에서 규정하고 있는 “국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다”의 규정의 의미내용에 부합할 것이다. 다시 말하면 비례의 원칙으로 한번 심사하고, 본질적 내용침해금지로 재심사하는 것이 국민의 기본권의 효력을 강화하는 최선의 방법일 것이기 때문이다. 따라서 비례의 원칙과 본질적 내용침해금지를 구별하여, 판단에 있어서 의심이 가는 경우에는 본질적 내용의 침해여부를 먼저 판단하고, 침해가 아닌 경우에는 비례의 원칙의 침해여부를 판단하여야 하며, 비례의 원칙의 침해여부를 먼저 심사한 경우에는 원칙의 위배여부를 불문하고 본질적 내용침해여부에 대한 판단을 하여야 한다.[176]

♣ 문제풀이

1. 다음 본질적 내용 침해금지에 대한 설명으로 가장 타당하지 않은 것은?

① 우리 헌법 제37조 제2항 후단은 기본권제한의 한계를 명시하고 있다.
② 본질적 내용 침해금지에 대한 규정은 제2공화국 헌법에 수용되어 계속되다가 유신헌법에서 삭제되었고, 제5공화국 헌법에서 부활되어 현재에 이르고 있다.
③ 본질적 내용 침해금지는 입법자가 기본권을 제한함에 있어서 기본권을 사실상 공동화시키는 것을 방지하는 기능을 한다.
④ 우리 헌법재판소는 본질적 내용 침해금지에 대하여 기본권의 침해로 말미암아 당해 자유나 권리가 유명무실한 것이 되는 것으로서 그 내용은 기본권마다 다르다고 판시한 바 있다.
⑤ 우리 대법원은 군인 및 군무원에 대한 이중배상을 금지한 국가배상법 제2조 제1항 단서에 대하여 권리자체의 본질적인 내용을 침해한다거나 권리자체를 박탈하는 규정에 해당하는 것은 아니라고 판시한 바 있다.

[정답] ⑤

[해설] <대법원 1971. 6. 22. 70다1010> 국가배상법 제2조 제1항 단서는 본질적인 내용을 침해하였으며, 기본권 제한의 범주를 넘어 권리 그 자체를 박탈하는 규정이다.

2. 다음 중 헌법재판소가 헌법에 합치하지 아니하다고 판단한 것은?

① 상고심재판을 받을 권리의 제한
② 토지거래허가제
③ 국산영화의무상영제
④ 납부불성실가산세
⑤ 퇴직금전액에 대한 우선변제수령권

[정답] ⑤

[해설] <헌법재판소 1997. 8. 21. 94헌마19> 퇴직금전액에 대한 우선변제수령권은 질권이나 저당권의 본질적 내용을 침해할 소지가 생기게 되는 것이다.

3. 기본권 제한의 한계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 기본권의 본질적 내용의 보장은 공권력의 기본권 제한으로 인한 기본권의 공동화를 방지하자는 데에 그 취지가 있다.

176) 김대환, 전게논문(주 33), 215~216면.

② 기본권의 본질적인 핵심, 최소한의 내용을 보장한다는 절대설은 그 내용이 인간의 존엄성이라는 점에 대해 일치하고 있다.
③ 기본권의 본질적 내용에 관한 상대설은 이를 비례원칙의 다른 표현으로 이해하기도 한다.
④ 기본권 제한입법의 한계와 관련하여 입법자가 형성의 자유를 넘었는지 여부에 관하여 헌법 제37조 제2항의 '필요한 경우'에 해당하는 가는 비례의 원칙에 의하여 판단하게 된다.
⑤ 헌법재판소는 사형제도에 대한 합헌결정에서 "행위자의 생명과 그 가치가 동일한 하나의 혹은 다수의 생명을 보호하기 위한 불가피한 수단의 선택이라고 볼 수밖에 없으므로 이를 가리켜 비례의 원칙에 반한다고 할 수 없다"는 것을 그 이유로 들었다.

[정답] ②

[해설] 절대설은 기본권을 제한하는 경우에도 절대적으로 침해할 수 없는 핵심영역 내지 근본적 실체가 있다는 입장이고, 상대설은 본질적인 내용은 고정된 것이 아니라 구체적 상황에 따라 법익을 형량하여 그 내용이 상대화될 수 있다는 것이다.

♣ 요점정리

1. 현행 헌법 제37조 제2항은 형식적 측면에서는 '일반적 법률유보'의 형식을 빌리고 있으나, 내용적 측면에서는 국민의 기본권을 제한하는 법률은 '국가안전보장·질서유지·공공복리'(목적상의 한계), '필요한 경우'(방법상의 한계), '법률로써'(형식상의 한계), '본질적 내용의 침해금지'(내용상의 한계)를 지켜야 한다.

2. 기본권의 본질적 내용이 현실적으로 매우 중요한 의미를 가진 최초의 사건은 국가배상청구권에 관련한 1971년 국가배상법 제2조 제1항 단서에 관한 대법원 판결이다. 대법원은 권리 자체의 본질적 내용을 침해하였으며, 기본권 제한의 범주를 넘어 권리 그 자체를 박탈하는 규정이므로 이는 헌법 제26조, 제8조, 제9조 및 제32조 제2항에 위반된다고 판시하였다.

3. 법률유보의 원칙은 궁극적으로는 기본권을 최대한 존중하면서도 헌법에 의해서 보호되고 있는 기타의 법익, 기본원칙, 제도 등을 기본권적인 가치와 전체적·통일적으로 실현시키려는 것이다.

4. 법률에 의한 기본권 제한은 기본권의 제한을 불가피하게 하는 현재의 목적을 달성하기 위해서 필요한 최소한의 범위 내에서만 허용될 뿐 아니라 보호되는 '법익'과 제한되는 기본권 사이에는 합리적이라고 평가할 수 있는 일정한 비례관계(비례원칙)가 성립되어야 한다.

5. 기본권 제한의 현실적인 필요성이 존재한다고 할지라도 그 제한으로 인하여 그 기본권 자체의 본질적 내용이 형해화될 정도의 제한은 금지된다(본질적 내용 침해금지의 원칙).

제10강 인간의 존엄과 가치(1)

♣ 학습목표

인간의 존엄과 가치의 의의를 설명할 수 있다.
우리 헌법 제10조의 의미를 설명할 수 있다.
인간의 존엄과 가치의 법적성격을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

인간의 존엄과 가치
인간의 존엄성 보장 입법례
우리 헌법 제10조의 의미
인간의 존엄과 가치의 법적성격

♣ 사전테스트

1. 인간의 존엄과 가치에 관하여 우리 헌법은 1980년 제8차 개정헌법에서 규정한 이래 현행헌법에 이르고 있다.
   정답 : X
   해설 : 우리 헌법은 1962년 제5차 개정헌법에서 규정한 이래 1980년 제8차 개정헌법에서 행복추구권을 추가하여 현행헌법에 이르고 있다.

2. 인간은 생물학적 의미의 모든 인간을 의미하며, 일정한 요건이나 자격을 요구해서는 안 된다.
   정답 : O
   해설 : 헌법 제10조의 규정은 '모든 인간은 단지 인간이라는 이유만으로 존엄하고 가치가 있다'는 의미로 해석된다.

3. 인간의 존엄과 가치의 주관적인 기본권성을 인정한다고 하여서 개인의 법적 지위가 강화되는 것은 아니다.
   정답 : O
   해설 : 인간의 존엄성은 보편적 절대성이 특징인 반면에 기본권은 제37조 제2항에 의한 제한가능성이 특징이기 때문이다.

♣ 돌발퀴즈

인간의 존엄과 가치가 헌법상의 기본원리라는 점에 대해 견해의 대립이 있다.
[정답] X
[해설] 인간의 존엄과 가치가 헌법상의 기본원리라는 점에서는 대체로 의견이 일치한다.

♣ 강의내용

1. 의의

근대 헌법의 기본원리인 인간의 존엄과 가치는 산업혁명 이후 심화된 빈부갈등과 양차 세계대전으로 인하여 심각한 침해를 받았다. 이러한 이유로 인간의 존엄성에 대한 국가적 보호의 필요성이 대두하였고, 20세기 각국 헌법에 명문화되었다.

이러한 인간의 존엄과 가치를 광의로 파악하면,
⑴ 모든 기본권의 이념적 전제가 되며, 모든 기본권 보장의 목적이 된다.
⑵ 반전체주의 원리, 인간우선의 원리, 국가적·국민적 실천목표, 법의 해석기준, 법의 보완원리, 국가작용의 가치판단기준, 헌법개정금지사항으로서의 의미를 갖는다.

이와는 다르게 인간의 존엄과 가치를 최협의로 파악하면, 인격권으로서 명예권, 성명권, 초상권 및 인격형성권, 인격유지권 등과 관련한 알 권리, 읽을 권리, 들을 권리 그리고 생명권 등이 포함된다.

2. 입법례

근대적 의미에서 볼 때, 인간의 존엄성에 대한 내용은 1789년 프랑스 인권선언에서[177] 유래하였고, 1919년 바이마르 헌법에 수용되었다고 보는 것이 일반적이다. 이외에도 인간의 존엄규정에 영향을 준 것으로는 1933년 포루투갈 헌법 제6조 제3항, 1937년 아일랜드 헌법전문, 1944년 교황 비오 12세의 성탄절 메시지 등이 있다.[178]

---

177) Declaration of the Rights of Man

Approved by the National Assembly of France, August 26, 1789

The representatives of the French people, organized as a National Assembly, believing that the ignorance, neglect, or contempt of the rights of man are the sole cause of public calamities and of the corruption of governments, have determined to set forth in a solemn declaration the natural, unalienable, and sacred rights of man, in order that this declaration, being constantly before all the members of the Social body, shall remind them continually of their rights and duties; in order that the acts of the legislative power, as well as those of the executive power, may be compared at any moment with the objects and purposes of all political institutions and may thus be more respected, and, lastly, in order that the grievances of the citizens, based hereafter upon simple and incontestable principles, shall tend to the maintenance of the constitution and redound to the happiness of all. Therefore the National Assembly recognizes and proclaims, in the presence and under the auspices of the Supreme Being, the following rights of man and of the citizen :

국민 의회를 구성하고 있는 프랑스 인민의 대표자들은 인권에 관한 무지·망각 또는 멸시가 오로지 공공의 불행과 정부 부패의 모든 원인이라는 것에 유의하면서, 하나의 엄숙한 선언을 통하여 인간에게 자연적이고 불가양이며, 신성한 제 권리를 밝히려 결의하거니와, 그 의도하는 바는, 사회공동체의 모든 구성원이 항시 이 선언에 준하여 부단히 그들의 권리와 의무를 상기할 수 있도록 하며, 입법권과 행정권의 제 행위가 수시로 모든 정치제도의 목적과의 비교에서 보다 존중하기 위하여, 시민의 요구가 차후 단순하고 명확한 제 원리에 기초를 둔 것으로서, 언제나 헌법의 유지와 모두의 행복에 이바지할 수 있도록 하는 것이다. 따라서 국민 의회는 지고의 존재 앞에 그 비호 아래 다음과 같은 인간과 시민의 제 권리를 승인하고 선언한다.

국제적 차원에서는 1945년 국제연합헌장, 1948년 세계인권선언, 1966년 국제인권규약(A규약 前文)등이 인간의 존엄성을 명시적으로 규정하였다.

국가적 차원에서는 제2차 세계대전 이후 독일,[179] 일본,[180] 등 인간의 존엄성을 극심하게 침해했던 패전국들을 비롯하여 많은 나라들에서 헌법에 명시적으로 규정하였다.[181]

우리 헌법은 1962년 제5차 개정헌법에서 규정한 이래 1980년 제8차 개정헌법에서 행복추구권을 추가하여 현행헌법에 이르고 있다.

3. 우리 헌법 제10조의 의미

현행헌법은 제10조 전문에서 "모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며"라고 하여 인간의 존엄성을 명시적으로 규정하고 있다. 이는 기본권 보장의 일반원칙으로서 인간의 존엄이라는 윤리적 내지 자연법적 원리를 헌법규범화한 것으로 평가할 수 있다.

이러한 맥락에서 볼 때, 헌법 제10조의 규정은 '모든 인간은 단지 인간이라는 이유만으로 존엄하고 가치가 있다'는 의미로 해석된다. 즉, 헌법의 중심가치는 인간이고, 국가권력은 이를 존중하고, 보호해야 함을 말한다. 여기서 인간은 생물학적 의미의 모든 인간이다.

4. 법적 성격

이는 인간의 존엄과 가치가 헌법이 지향하는 기본이념인지 또는 이 외에도 주관적 권리성을 가지고 있는지의 문제이다.

인간의 존엄과 가치가 헌법상의 기본원리라는 점에서는 대체로 의견의 일치를 보이고 있다.

⑴ 헌법의 기본원리

인간의 존엄성은 다른 '모든 기본권의 이념적 출발점' 또는 '국법질서의 최고 구성원리', '모든 기본권의 가치적 전제' 또는 '최고가치', '최고의 창설원리'가 되는 헌법의 기본원리를 규범화한 것이다. 따라서 주관적인 권리들이나 개인의 지위 또는 구체적인 관련 상황들과는 무관하게 효력을 갖는다.

---

178) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 4면.

179) 독일 기본법 제1조

① 인간의 존엄은 불가침이다. 이를 존중하고 보호하는 것은 국가권력의 의무이다.

② 독일국민은 불가침·불가양의 인권을 세계의 모든 공동체, 평화, 그리고 정의의 기초로서 인정한다.

③ 기본권은 직접효력을 갖는 법으로서 입법, 집행 및 사법을 구속한다.

180) 일본 헌법 제13조

모든 국민은 개인으로서 존중된다. 생명, 자유 및 행복추구에 대한 국민의 권리는 공공의 복지에 반하지 않는 한 입법 기타의 국정에 있어서 최대한 존중하여야 한다.

181) 이탈리아 헌법 제2조, 스페인 헌법 제10조 제1항, 그리스 헌법 제2조 제1항 등이 인간의 존엄에 대해 규정하고 있다.

⑵ 견해의 대립

기본이념 이외에 주관적 권리성을 인정하는 견해와[182] 근본규범이면서 기본권이라는 견해[183], 기본권성을 부인하는 견해[184], 기본권성을 부인하지만 기본원리와 헌법 제37조 1항에서 기본권을 도출할 수 있다는 견해[185], 근본가치로서 헌법이 지향해야 하는 목표라는 견해가[186] 대립하고 있다.

⑶ 검토

1) 주관적인 기본권성을 인정한다고 하여서 개인의 법적 지위가 강화되는 것이 아니라, 오히려 기본권의 체제를 이원화함으로써 법적 불안정성이 야기된다. 즉, 인간의 존엄성은 보편적 절대성이 특징인 반면, 기본권은 제37조 제2항에 의한 제한 가능성이 특징이다.

2) 개별기본권은 제한에 초점을 두고 기본권 제한의 정당성의 근거인 법률유보의 원칙과 과잉금지원칙과의 합치성이 관건인데, 인간존엄성은 그 핵심영역의 결정에 초점이 맞추어진다.

3) 개별기본권으로서 효력형식을 인정하게 되면 인간의 존엄성에서 유일무이한 규범적 특성은 상실된다. 즉, 존엄성은 최고등급을 상실하게 되고, 다른 기본권과 병립하는 하나의 기본권이 된다.

따라서 모든 국민은 인간으로서 존엄하기 때문에 가치를 인정받으며, 이러한 가치를 최고의 가치로서 우리헌법이 지향한다는 의미로 새기는 것이 타당하리라고 본다.

⑷ 헌법재판소

헌법 재판소는 “유죄가 확정되지 아니한 미결수용자에게 재소자용 의류를 입게 하는 것은… 인간으로서의 존엄과 가치에서 유래하는 인격권과 행복추구권, 공정한 재판을 받을 권리를 침해하는 것이다”고[187] 판시하여 인간의 존엄성 규정의 주관적 권리성을 인정한바 있다.

헌법 제10조에서 규정한 인간의 존엄과 가치는 '헌법이념의 핵심'으로 국가는 헌법에 규정된 개별적 기본권을 비롯하여 헌법에 열거되지 아니한 자유와 권리까지도 이를 보장하여야 하며, 이를 통하여 개별 국민이 가지는 인간으로서의 존엄과 가치를 존중하고 확보하여야 한다는 헌법의 기본원리를 선언한 조항이다. 따라서 자유와 권리의 보장은 1차적으로 헌법상 개별적 기본권규정을 매개로 이루어지지만, 기본권제한에 있어서 인간의 존엄과 가치를 침해한다거나 기본권형성에 있어서 최소한의 필요한 보장조차 규정하지 않음으로써 결과적으로 인간으로서의 존엄과 가치를 훼손한다면 헌법 제10조에서 규정한 인간의 존엄과 가치에 위반된다고 할 것이다.[188]

---

182) 헌법재판소 2001. 7. 19. 2000헌마546; 김선택, “출생전 인간생명의 헌법적 보호”, 「헌법논총」 제16집, 2005, 157면; 방승주, 헌법 제10조, 「헌법주석」 Ⅰ, 254면 이하 참조.
183) 김철수, 「헌법학개론」, 503면 이하 참조.
184) 정문식, “독일에서의 인간의 존엄과 생명권의 관계”, 「공법학연구」 제7호 제2호, 274면 이하 참조.
185) 정종섭, 헌법학원론, 2008, 346면; 허영, 「한국헌법론」, 2008, 325면.
186) 홍성방, 「헌법학」(중), 2010, 5면.
187) 헌법재판소 1999. 5. 27. 97헌마137.
188) 헌법재판소 2004. 10. 28. 2002헌마328, 2011. 3. 31. 2009헌마617 등.

♣ 문제풀이

1. 다음 헌법 제10조에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 모든 기본권 보장의 이념적 가치이다.
② 우리 헌법재판소에 따르면 규범적 성격을 가진다.
③ 인간은 결코 타인을 위한 수단이나 객체로 될 수 없다.
④ 국가도 인간을 위해 존재한다.
⑤ 1787년 미국연방헌법에서 최초로 명문화 되었다.

[정답] ⑤
[해설] 1919년 바이마르헌법에서 규정되었다.

2. 우리 헌법 제10조에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 기본권 보장의 일반원칙으로서 인간의 존엄이라는 윤리적 내지 자연법적 원리를 헌법규범화 한 것이다.
② 모든 인간은 단지 인간이라는 이유만으로 존엄하고 가치가 있다는 의미이다.
③ 헌법의 중심가치는 인간이고, 국가권력은 이를 존중하고 보호해야 함을 말한다.
④ 모든 인간에는 자연인, 외국인, 법인이 모두 포함된다.
⑤ 인간은 생물학적 의미의 모든 인간이다.

[정답] ④
[해설] 육체와 정신의 총합체라고 할 수 있는 자연인으로서의 인간을 의미한다.

3. 인간의 존엄과 가치에 반하지 않는 것은?

① 안락사
② 거짓말탐지기사용
③ 노예제
④ 인종차별
⑤ 집단학살

[정답] ②
[해설] <대법원 1979. 5. 2. 79도547> 엄격한 요건하에서 거짓말탐지기를 사용이 가능하다.

♣ 요점정리

1. 근대 헌법의 기본원리인 인간의 존엄과 가치는 산업혁명 이후 심화된 빈부갈등과 양차 세계대전으로 인하여 심각한 침해를 받았다. 이러한 이유로 인간의 존엄성에 대한 국가적 보호의 필요성을 인식하게 되었고, 20세기 각국 헌법에 명문화되기에 이르렀다.

2. 우리 헌법은 1962년 제5차 개정헌법에서 규정한 이래 1980년 제8차 개정헌법에서 행복추구권을 추가하여 현행헌법에 이르고 있다.

3. 헌법 제10조의 규정은 ‘모든 인간은 단지 인간이라는 이유만으로 존엄하고 가치가 있다’는 의미로 해석된다.

4. 인간의 존엄과 가치의 주관적인 기본권성을 인정한다고 하여서 개인의 법적 지위가 강화되는 것이 아니라, 오히려 기본권의 체제를 이원화함으로써 법적 불안정성이 야기된다. 즉, 인간의 존엄성은 보편적 절대성이 특징인 반면, 기본권은 제37조 제2항에 의한 제한 가능성이 특징이기 때문이다.

5. 헌법 재판소는 인간의 존엄성 규정의 주관적 권리성을 인정한바 있다.

제11강 인간의 존엄과 가치(2)

♣ 학습목표

헌법 제10조와 제37조 제1항과의 관계를 설명할 수 있다.
생활보호청구권과 일반적 보호청구권을 설명할 수 있다.
사형제도, 안락사, 낙태문제를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

제37조 제1항과의 관계
생활보호청구권
일반적 보호청구권
사형제도
안락사
낙태

♣ 사전테스트

1. 제10조의 인간의 존엄과 가치의 실현에 요구되는 모든 기본권은 인간의 존엄과 가치에서 도출되고, 제37조 제1항은 제10조에 의하여 인정된 권리를 주의적으로 선언하고 확인한 규정에 불과하다.

정답 : X
해설 : 다수설에 의하면, 제37조 제1항은 제10조의 인간의 존엄과 가치를 누리기 위해 필요한 것임에도 헌법에 규정되지 아니한 모든 자유와 권리를 의미하므로 양 조항은 상호보완관계라고 한다.

2. 우리 헌법은 사형을 금지하고 있다.

정답 : X
해설 : 우리 헌법 제110조 제4항 단서는 사형을 규정하고 있다.

3. 낙태는 태아의 생명권과 인간으로서의 존엄과 가치를 침해하는 것으로 허용될 수 없으나 태아의 생명권과 모(母)의 생명권이 충돌하는 경우에는 낙태가 허용된다.

정답 : X
해설 : 엄격한 요건하에서만 인정된다(모자보건법 제4조 제1항 제5호, 대법원 1985. 6. 11. 84도1958).

♣ 돌발퀴즈

협의의 안락사는 회생의 가망이 없는 불치의 병으로 빈사상태에 빠진 환자에 대하여 본인의 직접적 의사에 의하거나 본인이 무의식인 경우에는 보호자의 의사에 따라 인간다운 죽음을 맞이할 수 있도록 인위적으로 생명을 단축시키는 것을 말한다.

[정답] X
[해설] 존엄사에 대한 설명이다. 협의의 안락사는 회생가능성이 없는 환자의 생명을 의료인이 고통이 없는 방법으로 단절하는 것을 말한다.

♣ 강의내용

1. 제37조 제1항과의 관계

제37조 제1항과 제10조의 관계에 관하여 학설이 대립하고 있다. 김철수 교수는 제10조의 인간의 존엄과 가치의 실현에 요구되는 모든 기본권은 인간의 존엄과 가치에서 도출되고, 제37조 제1항은 제10조에 의하여 인정된 권리를 주의적으로 선언하고 확인한 규정에 불과하며, 권리창설적 규정은 아니라고 한다.

그러나 다수설에 의하면, 제37조 제1항은 제10조의 인간의 존엄과 가치를 누리기 위해 필요한 것임에도 헌법에 규정되지 아니한 모든 자유와 권리를 의미하므로 양 조항은 상호보완관계라고 한다.

2. 최소한의 생활보호청구권과 일반적 보호청구권

인간의 존엄과 가치가 구체적으로 침해될 정도로 경제적으로 열악한 지위에 놓이게 될 때, 헌법 제34조에 의한 구체적 입법이 없다하더라도 제10조에 의해 최소한의 생활보호청구권을 인정할 수 있다.[189]

헌법 제10조 제2문은 국가는 '개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무'를 지기 때문에 국가는 인간의 존엄과 가치를 침해하지 않을 의무를 지고, 이러한 의무는 사회는 물론 다른 개인에 의해 인간의 존엄과 가치가 침해되지 않도록 감시하고, 침해된 경우에는 그 침해를 배제해야 할 의무를 포함한다. 이러한 국가적 보호의무는 개인의 입장에서 보면 보호청구권이 된다. 따라서 이러한 보호청구권은 소구가능한 기본권이자 객관적 헌법규범이다.

3. 생명권과 관련된 구체적 문제

⑴ 사형제도

사형제도와 관련하여 찬반논란이 있으나 우리 헌법 제110조 제4항 단서는 사형을 규정하고 있다. 우리와는 다르게 독일은 기본법 제102조에서 명문으로 사형을 금지하고 있다. 우리 대법

189) 홍성방, 「헌법학」(중), 19면.

원은 우리나라의 실정과 도덕적 감정을 고려해서 질서유지와 공공복리를 위해서 사형은 위헌이 아니라는 입장을 취하고 있고,[190] 헌법재판소도 사형은 최소한 동가치의 다른 생명 또는 공익을 보호하기 위해 불가피한 예외적인 경우에만 적용되므로 합헌이라는 입장을 취하고 있다.[191]

그러나 사형은 인간의 존엄성에 반하는 잔혹한 형벌임이 자명하므로 사형선고를 함에 있어서 매우 신중한 검토가 요청된다.

⑵ 안락사

안락사는 협의의 안락사(적극적 안락사)와 도태적 안락사 및 존엄사로 나누어진다. 협의의 안락사는 회생가능성이 없는 환자의 생명을 의료인이 고통이 없는 방법으로 단절하는 것을 말하고, 도태적 안락사는 사회적으로 생존할 가치가 없다고 인정되는 자에 대한 인위적인 생명단절행위를 가리키며, 존엄사는 회생의 가망이 없는 불치의 병으로 빈사상태에 빠진 환자에 대하여 본인의 직접적 의사에 의하거나 본인이 무의식인 경우에는 보호자의 의사에 따라 인간다운 죽음을 맞이할 수 있도록 인위적으로 생명을 단축시키는 것을 말한다.

대체적으로 협의의 안락사와[192] 도태적 안락사는 살인으로 보아 불허한다고 보고 있으나 존엄사에 대해서는 찬반견해가 대립하고 있다. 인간의 존엄성에 비추어 볼 때, 개인의 생명권은 포기불가능하다고 해석할 수밖에 없다고 생각한다. 다만, 엄격한 요건하에서 본인이 직접적으로 의사를 표명하는 경우에는 본인의 자기결정권을 존중할 필요는 있다고 본다.

⑶ 낙태

생명 및 인간으로서의 존엄과 가치는 연령이나 지적능력과는 무관하므로 태아는 생명권과 인간으로서의 존엄과 가치를 향유한다.[193] 따라서 낙태는 태아의 생명권과 인간으로서의 존엄과 가치를 침해하는 것으로 허용될 수 없다.

그러나 예외적으로 태아의 생명권과 모(母)의 생명권이 충돌하는 경우에는 구체적인 경우를 따져 낙태가 허용되기도 한다.[194]

---

190) 대법원 1992. 8. 14. 92도1086.

191) 헌법재판소 1996. 11. 28. 95헌바1.

192) 우리 대법원은 협의의 안락사를 인정하지 않는다고 판시한 바 있다(대법원 1957. 7. 26. 4290형상126).

193) BVerfGE 39, 1, 41.

194) 모자보건법 제14조 제1항에 의하면 ① 본인 또는 배우자가 대통령령이 정하는 우생학적 또는 유전학적 정신장애나 신체질환이 있는 경우, ② 본인 또는 배우자가 대통령령이 정하는 전염성질환이 있는 경우, ③ 강간 또는 준강간에 의하여 임신된 경우, ④ 법률상 혼인할 수 없는 혈족 또는 인척간에 임신된 경우, ⑤ 임신의 지속이 보건의학적 이유로 모체의 건강을 심히 해하고 있거나 해할 우려가 있는 경우이다.

♣ 문제풀이

1. 다음 생명권에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 외국인도 생명권의 주체가 될 수 있다.
② 국가에 의한 우생학적 단종시술은 허용된다.
③ 우리 헌법은 사형제도를 규정하고 있다.
④ 자신의 생명에 대한 처분권을 타인에게 위임하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.
⑤ 우리 헌법재판소는 사형은 최소한 동가치의 다른 생명 또는 공익을 보호하기 위해 불가피한 예외적인 경우에만 적용되므로 합헌이라고 한다.

[정답] ②
[해설] 우리 헌법 제10조 제2문은 국가적 보호의무를 규정하고 있다.

2. 다음 생명권에 대한 기술 중 바르지 못한 것은?

① 협의의 안락사는 부인된다.
② 생명은 자연과학적 개념에 속한다.
③ 생명권은 자신의 생명에 대한 자유로운 처분권을 의미한다.
④ 생명권은 원칙적으로 국가가 개인의 생명에 관한 결정을 내릴 수 없음을 의미한다.
⑤ 모자보건법은 낙태를 허용할 정당화사유를 규정하고 있다.

[정답] ③
[해설] 생명권은 국가를 포함하는 타인으로부터 생명을 방어하는 방어권, 포기불가성, 국가에 대한 생명보호청구권을 내용으로 한다.

3. 다음 설명 중 바르지 못한 것은?

① 우리 헌법 제110조 제4항 단서는 사형을 규정하고 있다.
② 대법원은 우리나라의 실정과 도덕적 감정을 고려해서 질서유지와 공공복리를 위해서 사형은 위헌이 아니라는 입장을 취하고 있다.
③ 헌법재판소도 사형은 최소한 동가치의 다른 생명 또는 공익을 보호하기 위해 불가피한 예외적인 경우에만 적용되므로 합헌이라는 입장을 취하고 있다.
④ 미국의 경우, 사형을 폐지한 주의 살인 발생건수가 사형을 유지하는 주의 살인 발생건수보다 적다.
⑤ 독일은 기본법 제102조에서 사형을 규정하고 있다.

[정답] ⑤
[해설] 독일기본법 제102조는 명문으로 사형을 금지하고 있다.

♣ 요점정리

1. 다수설에 의하면, 제37조 제1항은 제10조의 인간의 존엄과 가치를 누리기 위해 필요한 것임에도 헌법에 규정되지 아니한 모든 자유와 권리를 의미하므로 양 조항은 상호보완관계라고 한다.

2. 우리 헌법 제110조 제4항 단서는 사형을 규정하고 있고, 대법원은 우리나라의 실정과 도덕적 감정을 고려해서 질서유지와 공공복리를 위해서 사형은 위헌이 아니라고 하고 있으며, 헌법재판소는 사형은 최소한 동가치의 다른 생명 또는 공익을 보호하기 위해 불가피한 예외적인 경우에만 적용되므로 합헌이라는 입장을 취하고 있다.

3. 우리 대법원은 협의의 안락사를 인정하지 않는다고 판시한 바 있다.

4. 낙태는 태아의 생명권과 인간으로서의 존엄과 가치를 침해하는 것으로 허용될 수 없으나 태아의 생명권과 모(母)의 생명권이 충돌하는 경우에 구체적인 경우를 따져 낙태가 허용되기도 한다.

제12강 인간의 존엄과 가치(3)

♣ 학습목표

인간의 존엄과 가치의 보호영역을 설명할 수 있다.
인간의 존엄과 가치의 주체를 설명할 수 있다.
인간의 존엄과 가치의 효력을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

보호영역
국민과 외국인
태아나 배아
사자(死者)

♣ 사전테스트

1. 인간의 존엄성은 특정한 보호영역을 갖지 아니한다.

정답 : O
해설 : 인간존엄성은 자체적으로 특정한 보호영역을 갖지 아니하고, 전체 법질서에 하나의 근본이념을 형성하는 것으로 파악된다.

2. 헌법 제10조 제1문 전단은 국민만이 아니고 외국인에게도 적용된다

정답 : O
해설 : 인간으로서의 존엄과 가치는 모든 인간에게 고유한 가치로 간주되는 인격주체성을 의미하므로 헌법 제10조 제1문 전단은 국민만이 아니고 외국인에게도 적용된다.

3. 인간의 존엄은 헌법질서의 구체화를 위한 기준과 지침으로 작용할 뿐만 아니라 인간의 존엄에 반하는 국가작용을 금지하는 근거가 되기도 한다.

정답 : O

♣ 돌발퀴즈

법규범에 의하여 권리와 의무의 주체가 되는 법인은 인간으로서의 존엄과 가치의 주체가 될 수 없다.

[정답] O
[해설] 인간이란 육체와 정신의 총합체라고 할 수 있는 자연인으로서의 인간을 말한다.

♣ 강의내용

1. 보호영역

존엄의 사전적 의미는 “인물이나 지위 따위가 감히 범할 수 없을 정도로 높고 엄숙함”을 뜻하며, 가치란 중요성이나 쓸모를 의미한다. 인간은 인간 그 자체로서 존엄하고 가치가 있다. 인간은 천부적으로 이성적 존재로서 인격의 주체가 되기 때문에, 개개의 인간은 국가권력의 객체가 아니라 주체로서 국가권력의 구성적 지위를 가지게 되며, 개인의 개인에 대한 관계에서도 일방이 타방의 객체가 아니라 대등한 주체가 된다. 따라서 인간을 동물이나 물건처럼 취급하거나(예컨대, 인신매매, 생체실험 등) 인간을 목적이 아닌 수단으로 전락시키는 것은 인간의 존엄과 가치를 침해하는 것이 된다.

따라서 인간존엄성은 특정한 보호영역을 갖지 아니하고, 전체 법질서에 하나로서 근본이념을 형성하는 것으로 파악된다.

2. 주체

우리 헌법질서가 예정하는 인간상은 “자신이 스스로 선택한 인생관·사회관을 바탕으로 사회공동체 안에서 각자의 생활을 자신의 책임 아래 스스로 결정하고 형성하는 성숙한 민주시민”인바,[195] 이는 사회와 고립된 주관적 개인이나 공동체의 단순한 구성분자가 아니라, 공동체에 관련되고, 공동체에 구속되어 있기는 하지만 그로 인하여 자신의 고유가치를 훼손당하지 아니하고 개인과 공동체의 상호연관 속에서 균형을 잡고 있는 인격체를 의미한다. 따라서 개인의 자율과 창의를 인정함과 동시에 타인과의 올바른 관계를 위한 공동체 규범에 의한 규제를 인정하는 헌법질서가 가장 바람직할 것이다.

인간으로서의 존엄과 가치는 모든 인간에게 고유한 가치로 간주되는 인격주체성을 의미하므로 헌법 제10조 제1문 전단은 국민만이 아니고 외국인에게도 적용된다. 이때의 인간은 자연인만을 의미한다.

(1) 국민과 외국인

존엄과 가치의 주체로서의 인간은 생물학적 의미에서 인간, 즉 모든 인간이다. 우리 학계의 지배적 견해나 헌법재판소는 인간의 존엄과 가치의 주체는 모든 인간으로서 국민은 물론 외국인도 포함한다는 입장이다.[196]

여기에서 말하는 인간이란 육체와 정신의 총합체라고 할 수 있는 자연인으로서의 인간을 말한다고 할 수 있다. 이러한 인간이면 성별, 인종, 피부색을 막론하고, 또한 그가 범죄자나 수형자이든, 아니면 장애자와 노약자이든, 이른 바 살만한 가치가 있는 사람이든, 없는 사람이든 불문하고 인간으로서의 존엄과 가치를 갖는다. 나아가서 미성년자, 정신병자, 범죄인, 기형아 또는 식물인간을 막론하고 인간으로서의 존엄과 가치의 주체가 된다.

다만, 법규범에 의하여 권리와 의무의 주체가 되는 법인은 인간으로서의 존엄과 가치의 주체가 될 수 없다.

---

195) 헌법재판소 2003. 10. 30. 2002헌마518.
196) 헌법재판소 2001. 11. 29. 99헌마494.

⑵ 태아

태아도 인간의 존엄과 가치의 주체가 될 수 있는지에 대하여 독일 연방헌법재판소는 “인간의 존엄성은 이미 태아의 생명에게도 인정되는 것이며, 비로소 태어난 생명에게만 또는 교육에 의하여 인격성이 갖춘 생명에게 부여되는 것이 아니다”고 판시한 바 있다.[197]

⑶ 사자(死者)

사자(死者)가 인간의 존엄과 가치의 주체가 될 수 있는지의 여부는 우선 사자 자신의 존엄이 문제되는지 아니면 그 후손이나 가족들의 명예(인격)권이 문제되는지를 구분하여야 할 것이다. 전자의 문제는 주로 사체(死體)를 산업용(예컨대, 해부, 장기이식 등)과 같은 경우에 예외적으로 이용하는 경우에 문제될 수 있고, 이는 주체성의 문제가 아니라 국가의 보호의무 및 객관적 가치와 관련되고, 이러한 경우에는 인간으로서의 존엄과 가치에 합당하게 모든 과정이 이루어져야 함을 의미한다고 할 수 있다. 후자의 경우는 유족이 사자에 대해 가지는 명예, 추모감정이라고 할 수 있으며, 이러한 명예권은 보호의 대상이 된다.

3. 효력

인간의 존엄이 헌법질서의 형성에 미치는 파급효는 ① 헌법질서를 구체화하고 형성함에 있어서 방향과 기준이 되고, ② 헌법조항과 법령의 의미 등이 문제되는 경우 해석의 기준이 되며, ③ 헌법조항과 법령의 흠결이 문제되는 경우 보완을 위한 기준이 된다.

또한, 인간의 존엄은 헌법질서의 구체화를 위한 기준과 지침으로 작용할 뿐만 아니라 인간의 존엄에 반하는 국가작용을 금지하는 근거가 되기도 한다. 이러한 맥락에서 이야기되는 인간존엄의 통제적 역할은 ① 인간의 존엄은 어떠한 경우에도 국가활동이 침해해서는 안 될 한계가 되고, ② 기본권 제한방향의 한계가 되며, ③ 헌법 개정방향의 한계가 된다.

4. 제한

이는 인간의 존엄과 가치를 어떻게 바라보는가에 따라 다르다. 인간의 존엄과 가치에 대해 주관적 권리성을 인정하는 견해에 의하면, 인간의 존엄과 가치는 우리 헌법 제37조 제2항에 따라 법률로써 제한할 수 있게 될 것이고, 기본원리 또는 근본가치로 보는 견해에 의하면 인간의 존엄과 가치는 제한할 수 없게 될 것이다.

♣ 문제풀이

1. 다음 인간의 존엄과 가치에 관한 기술 중 바르지 못한 것은?

① 존엄과 가치의 주체로서의 인간은 고립적이고 이기적인 인간상이다.

② 사체의 산업용 이용 등의 문제는 인간의 존엄과 가치의 주체성의 문제가 아니라 국가의 보호의무 및 객관적 가치와 관련된다.

---

197) Richter•Schuppert•Bumke, Casebook Verfassungsrecht, 4. Aufl., 2001, 방승주譯, 독일헌법판례해설, 2003, 80면.

③ 인간은 결코 타인을 위한 수단이나 객체가 될 수 없다.
④ 일부 견해에 의하면 인간존엄성은 특정한 보호영역을 갖지 아니하고, 전체 법질서에 하나로서 근본이념을 형성하는 것이다.
⑤ 개인의 개인에 대한 관계에서도 일방이 타방의 객체가 아니라 대등한 주체가 된다.

[정답] ①
[해설] 인간의 고유한 가치를 유지하면서 사회에 구속되며 사회와 일정한 관계를 가지는 인간을 의미한다.

2. 다음 인간의 존엄과 가치에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?
① 헌법질서를 구체화하고 형성함에 있어서 방향과 기준이 된다.
② 헌법조항과 법령의 의미 등이 문제되는 경우 해석의 기준이 된다.
③ 인간의 존엄에 반하는 국가작용을 금지하는 근거가 되기도 한다.
④ 기본권 제한방향의 한계가 된다.
⑤ 헌법 제정방향의 한계가 된다.

[정답] ⑤
[해설] 헌법개정방향의 한계가 된다.

3. 다음 인간의 존엄과 가치에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?
① 기본권의 이념적 기초이고, 기본권의 핵심으로서 우리헌법의 최고의 객관적 규범이다.
② 개인이익우선의 원칙을 명백히 하는 것이다.
③ 국가목적적인 국가를 부인하는 의미를 갖는다.
④ 통치구조의 한계를 명백히 하고 기본권 실현수단으로서의 통치구조의 기능을 보여주는 것이다.
⑤ 기본권 실현의 방법적 기초이고, 헌법개정의 한계에 해당하는 근본규범이다.

[정답] ⑤
[해설] 인간의 존엄과 가치는 기본권 실현의 이념적 기초이다. 방법적 기초는 평등의 원리이다.

♣ 요점정리

1. 인간은 천부적으로 이성적 존재로서 인격의 주체가 되기 때문에, 개개의 인간은 국가권력의 객체가 아니라 주체로서 국가권력의 구성적 지위를 가지게 되며, 개인의 개인에 대한 관계에서도 일방이 타방의 객체가 아니라 대등한 주체가 된다. 따라서 인간을 동물이나 물건처럼 취급하거나(예컨대, 인신매매, 생체실험 등) 인간을 목적이 아닌 수단으로 전락시키는 것은 인간의 존엄과 가치를 침해하는 것이 된다.

2. 우리 헌법질서가 예정하는 인간상은 자신이 스스로 선택한 인생관·사회관을 바탕으로 사회공동체 안에서 각자의 생활을 자신의 책임 아래 스스로 결정하고 형성하는 성숙한 민주시민인바, 이는 사회와 고립된 주관적 개인이나 공동체의 단순한 구성분자가 아니라, 공동체에 관

련되고, 공동체에 구속되어 있기는 하지만 그로 인하여 자신의 고유가치를 훼손당하지 아니하고 개인과 공동체의 상호연관 속에서 균형을 잡고 있는 인격체를 의미한다.

3. 인간이면 성별, 인종, 피부색을 막론하고, 또한 그가 범죄자나 수형자이든, 아니면 장애자와 노약자이든, 이른 바 살만한 가치가 있는 사람이든, 없는 사람이든 불문하고 인간으로서의 존엄과 가치를 갖는다. 나아가서 미성년자, 정신병자, 범죄인, 기형아 또는 식물인간을 막론하고 인간으로서의 존엄과 가치의 주체가 된다.

4. 인간의 존엄과 가치는 헌법질서를 구체화하고 형성함에 있어서 방향과 기준이 되고, 헌법조항과 법령의 의미 등이 문제되는 경우 해석의 기준이 되며, 헌법조항과 법령의 흠결이 문제되는 경우 보완을 위한 기준이 된다.

5. 인간의 존엄과 가치는 어떠한 경우에도 국가활동이 침해해서는 안 될 한계가 되고, 기본권 제한방향의 한계가 되며, 헌법 개정방향의 한계가 된다.

제13강 행복추구권(1)

♣ 학습목표

행복추구권의 연혁을 설명할 수 있다.
행복추구권의 개념을 설명할 수 있다.
행복추구권의 주체를 설명할 수 있다.
행복추구권의 법적성격을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행복추구권의 연혁, 헌법규정, 개념, 주체, 법적성격

♣ 사전테스트

1. 우리 헌법은 1962년 제3공화국 헌법에서 행복추구권을 처음으로 수용하여 현행 헌법에 이르고 있다.

정답 : X
해설 : 우리 헌법은 1980년 제5공화국 헌법에서 행복추구권을 처음으로 수용하였다.

2. 행복추구권은 헌법에 열거되지 아니한 생명권, 신체를 훼손당하지 아니할 권리, 자유로운 활동과 인격발현에 관한 권리(인격권), 평화적 생존권, 휴식권, 수면권, 일조권, 스포츠권 등이 포함된다.

정답 : O

3. 법인은 어떠한 경우에도 행복추구권의 주체성이 인정될 수 없다.

정답 : X
해설 : 우리 헌법재판소는 사죄광고와 관련하여 법인에게 인격권의 주체성을 인정한 바 있다(헌법재판소 1991. 4. 1. 89헌마160).

♣ 돌발퀴즈

우리 헌법재판소는 행복 추구권의 적극적 권리성을 인정하고 있다.

[정답] X
[해설] 자유권적 기본권과 같은 소극적인 권리로 파악하고 있다(헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14).

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

우리 헌법은 제10조 제1문에서 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다”고 하여 인간으로서의 존엄과 가치 외에도 행복추구권을 규정하고 있다.

이 규정은 인간의 생명권·자유권·행복추구권을 인권의 핵심으로 보는 로크(J. Locke : 1632년~1704년)의 사상적 영향을 받은 미국의 버지니아권리장전에서[198] 유래된 것으로 알려져 있다. 그러나 세계 각국의 현행 헌법 중에는 우리 헌법과 일본 헌법(제13조)을 제외하고는 행복추구권을 직접적으로 규정하고 있지는 않다.[199]

우리 헌법은 1980년 제5공화국 헌법에서 행복추구권을 처음으로 수용하여 현행 헌법에 이르고 있다. 1962년 제3공화국 헌법은 제8조에서 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 이를 위하여 국가는 국민의 기본적 인권을 최대한으로 보장할 의무를 진다”고 규정하였다. 그러나 이 규정이 너무 간결하고 추상적이어서 실제 헌법해석이나 입법 및 법제 운영면에 크게 기여하지 못한다는 지적에 따라 1980년 헌법개정 초안작업에서 이 규정에 생명권, 인격권, 행복추구권 등을 추가하여 구체화시킬 필요성이 있다는 의견이 제시되었다.

이에 대하여는 구체화하자는 견해,[200] 법치국가를 추가하자는 견해,[201] 그대로 두자는 견해,[202] 등이[203] 주장되었다. 이러한 논의과정 중 국회(안) 존중이라는 그 당시 사회분위기로 인하여 국회(안)이 채택되어 현행 헌법에 이르고 있다.

---

198) 1776년 버지니아권리장전 제1조는 “생명, 자유, 재산에 대한 권리와 행복, 안전을 추구하는 권리”를 선언하고 있고, 1776년 미국독립선언서 제2절에서는 인간의 천부불가양의 권리로서 “생명, 자유 및 행복을 추구하는 권리”가 있음을 선언하고 있다. 그러나 정작 미연방헌법에는 행복추구권에 규정이 없다.

199) 홍성방, 「헌법학」(중), 2010, 28면.

200) 이러한 견해는 첫째, 이 규정은 근대 헌법사상이 자연법적 이념을 확인하여 헌법의 기본가치라 명시한 것이어서 너무 간결하고 추상적이어서 이 조문이 지닌 본래의 의미가 적절히 인식되지 못해 실제의 헌법해석이나 입법 및 법제 운영에서 크게 기여하지 못하고 있다. 둘째, 국민의 인권보장에의 소망, 인격에의 의지를 참작하고 새로이 변모된 사회상황, 정치상황에서 인권규정의 보완을 꾀할 수 있다. 셋째, 추상적이고 간결한 규정이 의례적, 강령적인 것에 그쳐버리는 것을 시정함과 아울러 기본권의 보장을 보다 실효적이게 할 수 있다고 하였다(법제처, 「헌법연구반보고서」, 1980, 77면 참조.).

201) 이러한 견해는 첫째, 현행 헌법에는 우리나라의 법치국가성에 관한 규정이 없으므로 명시할 필요가 있다. 둘째, 서독기본법과 같이 ‘민주적·사회적 법치국가’를 규정하거나 터키헌법 제10조 제2항과 같이 기본권의 보호와 성격의 일반규정에서 규정할 수도 있다. 따라서 우리 헌법도 기본권 보장의무와 함께 규정할 수 있다고 하였다(법제처, 「헌법연구반보고서」, 1980, 77~78면 참조.).

202) 이러한 견해는 첫째, 개별기본권 조항에서 이를 규정하고 있으므로 굳이 기본원리규정에서 구체화할 필요성이 없다. 둘째, 구체적 규정을 두더라고 실효적 규정이 될 수 없다고 하였다(법제처, 「헌법연구반보고서」, 1980, 78면 참조.).

203) 이외에도 ‘행복을 추구할 권리’를 삽입하자는 공화당안, 현 규정대로 하자는 신민당안, 생명권, 인격권, 행복추구권, 알고 읽고 들을 권리를 추가하고 사회단체나 개인으로부터의 침해금지조항을 신설하자는 6인시안 등이 주장되었다(법제처, 「헌법연구반보고서」, 1980, 78면 참조.).

그러나 헌법규정에 행복추구권을 추가한 것에 대해서는 비판이 가해졌다.[204] 그러나 어찌되었건 행복추구권이 헌법에 규정된 이상 그것은 하나의 헌법규정이고, 헌법적 개념이어서 다른 헌법조항 내지는 다른 기본권과 조화롭게 해석하는 것이 타당하리라고 본다.[205]

2. 개념과 주체

⑴ 개념

행복추구권을 포괄적 기본권으로 이해하게 되면, 그 내용도 다양한 것이 될 수밖에 없다. 따라서 그 구체적인 내용을 남김없이 망라한다는 것은 거의 불가능하다. 즉, 행복이란 매우 다의적이고 주관적이며 상대적인 개념이다. 따라서 일반적으로 행복추구권이란 고통이 없는 상태나 만족감을 느낄 수 있는 상태를 실현하는 권리라 한다.[206]

이러한 행복추구권은 헌법에 열거된 기본권으로서의 행복추구의 수단이 될 수 있는 개별적 기본권 이외에 헌법에 열거되지 아니한 생명권, 신체를 훼손당하지 아니할 권리, 자유로운 활동과 인격발현에 관한 권리(인격권), 평화적 생존권, 휴식권, 수면권, 일조권, 스포츠권 등을 들 수 있다.

그런데 행복추구권이 기본권체계 내에서 어떤 위치를 차지하는가에 대하여 행복 추구권은 자유권적 기본권의 총칙규정이라는 견해와 사회적 기본권의 총칙적 규정이라는 견해가 있으나 자유권적 성격과 사회권적 성격을 공유하는 기본권 전반에 관한 총칙적 규정으로 이해하는 것이 일반적 견해이다.

⑵ 주체

모든 자연인에게 주체성이 인정된다. 법인의 주체성 인정여부는 행복추구권의 내용이 무엇인가에 따라 달라지는데 일반적 행동의 자유가 포함되는 일반적 인격권이 내용이라면 법인에게도 인정될 수 있을 것이다.[207]

---

204) 문홍주 교수는 이론상 명쾌하지 못하며, “제1항에 인간의 존엄과 가치를 규정하고, 제2항에 이를 구체화하는 내용의 기본권, 모든 국민은 생명의 권리, 인격의 권리, 행동자유의 권리 및 행복추구의 권리를 가진다”고 규정하는 것이 타당하다고 하였고, 권영성 교수는 “행복추구권 조항의 신설은 한국 헌법전체체계에 비추어 보거나, 행복추구권의 실체가 애매한 것이라는 점 등을 감안할 때, 인기만을 위한 개헌시안들의 무책임성과 무지의 일면을 드러낸 좋은 일례”라고 하였으며, 허영 교수는 그 불명확성이로 많은 논란을 일으키고 있다고 하면서 “행복추구에 관한 우리 헌법규정은 비교헌법적으로 볼 때 외국에 그 선례가 없는 것은 아니지만 우리 헌법규정 중에서 체계적으로 가장 문제가 있는 규정이다. 너무나 당연한 규정을 선언함으로써 오히려 불필요한 의문만을 생기게 했다”고 하였다. 이외에도 김선택 교수는 “한국 헌법상의 기본권질서에 대한 특별한 성찰없이 이루어진 것으로 보인다”고 하였다. 홍성방 교수는 “새로운 항을 신설하여 인격권을 규정하고, 그 대신 다의적이고 불명확한 행복추구권을 삭제하는 것이 바람직하다”고 하면서도 “행복추구권이 헌법에 규정된 이상 헌법과 기본권의 전체체계와 조화될 수 있는 방향으로 해석하고 그 내용을 명확히 하는 것이 헌법학의 임무”라고 하였다.

205) 홍성방, 「헌법학」(중), 2010, 29~30면 참조.

206) 여기서 행복은 공적·사적인 행복은 물론 물질적·정신적인 행복도 포함하는 개념이라고 한다(홍성방, 「헌법학」(중), 2010, 30면.).

207) 여기서 인격권이란 자신과 분리할 수 없는 인격적 이익의 향유를 의미하는 것으로 우리 헌법재판소는 사죄광고와 관련하여 법인에게 인격권의 주체성을 인정한 바 있다(헌법재판소 1991. 4. 1. 89헌마160).

헌법재판소는 노동조합의 정치자금기부금지를 규정한 노동조합법 제12조 제5호에 대한 헌법소원에서, '이 사건 법률조항은 노동단체가 정당에 정치자금을 기부하는 것을 금지함으로써 청구인이 정당에 정치자금을 기부하는 형태로 정치적 의사를 표현하는 자유를 제한하는 한편, 정치자금의 기부를 통하여 정당에 정치적 영향력을 행사하는 결사의 자유(단체활동의 자유)를 제한하는 규정이므로, 이 사건 법률조항에 의하여 침해된 기본권은 헌법 제33조의 단결권이 아니라 헌법 제21조의 노동조합의 정치활동의 자유, 즉 표현의 자유, 결사의 자유와 일반적인 행동자유권 및 개성의 자유로운 발현권을 그 보장내용으로 하는 행복추구권이라고 보아야 한다'라고 하여 법인인 노동조합이 행복추구권의 주체가 됨을 인정한 바 있다.

3. 법적성격

다수설은 행복추구권을 신체의 자유, 양심의 자유와 같은 자유권으로서 소극적, 방어적 권리이면서도 재판청구권, 노동3권과 같은 적극적 성질의 권리로 이해(양면적 권리설)하나 헌법재판소는 소극적이고 방어적인 성격의 권리(포괄적인 의미의 자유권으로서의 성격)로 이해하고 있다.

⑴ 주관적 공권성

첫째, 행복추구권을 독립된 기본권으로 보지 않고 인간으로서의 존엄과 가치와 행복추구권을 하나의 기본권으로 이해하는 견해에[208] 따르면 10조의 기본권은 포괄적 기본권, 주기본권이고, 헌법 제11조에서 36조는 주기본권의 세분화이며, 제37조 제1항은 주기본권의 존재를 전제한 것이라고 한다.

둘째, 행복추구권의 본질을 포괄적 기본권으로 보아 기본권 전반에 대한 총칙적 규정으로 이해하는 견해에[209] 따르면 행복추구권은 물질적 풍요와 정신적 만족의 동시적 충족이고, 따라서 행복추구권은 포괄적 기본권으로 이해하여 기본권 전반에 관한 총칙적 규정이라는 것이다.[210]

셋째, 행복추구권은 인간의 본능의 문제로 다루어져야 할 사항이기 때문에 처음부터 규범화의 대상이 될 수 없다는 견해에[211] 따르면 모든 국민의 당위적인 삶의 지표를 분명히 밝혀 놓은 것으로 인간의 존엄과 가치가 갖는 윤리규범적 성격과 실천규범적 성격을 강조하는 것이라고 하여 행복추구권의 법규범성을 부정한다.

넷째, 행복추구권의 구체적 기본성을 부정하는 견해에[212] 따르면 행복추구권을 자유권을 위한 일반원칙조항으로 보면서 사회적 기본권을 위한 인간다운 생활을 할 권리(제34조 제1항)와 함께 인간의 존엄과 가치라는 최고의 이념을 지향하는 수단이라고 한다.

다섯째, 행복추구권은 일반적 인격권과 무규정이고 비정형적인 광범한 자유행동권 및 객관적·법적성격을 가지며 제37조 제1항의 헌법에 열거되지 아니한 권리를 인정하는 실질적 기준의 역할을 하는 포괄규범이라고 한다.[213] 이 견해는 앞의 견해들을 다음과 같이 비판하고 있다. 첫째 견해는 인간으로서의 존엄과 가치와 행복추구가 각기 다른 개념이라는 것을 간과했다고 한

208) 김철수, 「헌법학」, 박영사, 2008, 364면 참조.
209) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 361~362면 참조.
210) 이 견해는 인간으로서의 존엄과 가치 이외에 기본권 총칙규정을 두는 것은 불필요한 중복이고, 자유권적 기본권과 사회권적 기본권적 성격을 동시에 가지는 기본권은 행복추구권만이 아니라는 비판이 가해진다(홍성방, 「헌법학」(중), 2010, 34~35면 참조.).
211) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 319면 참조.
212) 김운용, "행복추구권의 해석", 「고시연구」, 1988. 12, 61~64면 참조.
213) 김선택, "행복추구권", 「고시연구」, 1993. 10, 352~359면 참조.

다. 즉, 인간으로서의 존엄과 가치가 인격자의 정태적 존재양상을 보호하는 데(그가 어떻게 있느냐) 반하여, 행복추구권은 그의 동태적 행동양식을 보호한다는(그가 어떻게 행동하느냐) 점에서 구별되어 인간으로서의 존엄과 가치가 '자기보존'이라면 행복추구권은 '자기발현'이라는 것이다. 셋째 견해는 실정헌법조문에 오로지 윤리적인 요청만이 규정되어 있다고 보는 것은 법학의 실존적인 임무인 해석을 다하지 못한 것이 된다고 하였다. 넷째 견해는 기본권 보장의 최고이념으로 인정되는 인간의 존엄과 가치 아래에 그와 구분되는 별도의 자유권 보장이념(행복추구)과 사회적 기본권 보장이념(인간다운 생활을 할 권리)을 인정하는 것은 불필요한 중복이고, 인간으로서의 존엄과 가치와 행복추구권, 인간으로서의 존엄과 가치와 인간다운 생활을 할 권리라는 구분되는 이념들 상호간에 원치 않는 갈등을 야기할 수 있고, 이는 바로 최고이념인 인간의 존엄과 가치의 실현에 장애요소로 작용할 수 있다고 한다.

여섯째, 행복추구권이 인간의 존엄성조항을 구체화할 필요성에서 규정된 것이라는 사실에서 행복추구권은 개별 기본권일 수밖에 없다고 하면서 소극적, 방어적 권리인 동시에 적극적, 능동적 성격을 갖는 복합적 권리라고 한다.[214]

우리 헌법재판소는 "헌법 제10조의 행복추구권은 국민이 행복을 추구하기 위하여 필요한 급부를 국가에게 적극적으로 요구할 수 있는 것은 내용으로 하는 것이 아니라 국민이 행복을 추구하기 위해 활동을 국가의 간섭 없이 자유롭게 할 수 있다는 포괄적인 의미의 자유권으로서의 성격을 가진다"고[215] 판시하여 행복추구권을 독자적인 주권적 기본권의 하나로 파악하면서도 포괄적인 의미의 소극적 자유권으로 보고 있다.

⑵ 자연권성

행복추구권이 자연권임에 대하여는 이는 성질상 자연법상의 권리이기는 하나 헌법 제10조에 규정된 이상 실정권이라는 견해도 있으나 행복추구권은 인간존재에 고유한 인간의 생태적 권리로 보는 것이 다수설이다.

⑶ 포괄적 권리성

행복추구권이 포괄적 권리인가에 대하여는 이는 그 밖의 개별적 기본권과 구별되는 단하나의 독자적인 권리로서 사생활의 비밀과 자유, 환경권 등을 보장하는 것이라는 견해도 있으나 행복추구권은 인간이 행복을 추구하는데 필요한 것이며 헌법에 열거되지 아니한 자유와 권리까지도 그 내용으로 하는 포괄적 기본권으로 이해하여야 할 것이다.

⑷ 적극적 권리성

행복추구권을 포괄적인 주관적 공권으로 볼 경우 그것이 자유권적 기본권을 의미하는 것인지, 아니면 사회적 기본권이나 청구권적 기본권까지도 포괄하는 것인지에 대하여 견해가 대립되는데, 헌법재판소는 국가유공자예우 등에 관한 법률 제9조 본문 위헌제청사건에서 "헌법 제10조의 행복추구권은 국민이 행복을 추구하기 위하여 필요한 급부를 국가에게 적극적으로 요구할 수 있는 것이 아니라, 국민이 행복을 추구하기 위한 활동을 국가의 간섭 없이 자유롭게 할 수 있다는 포괄적인 의미의 자유권으로서의 성격을 가진다"고[216] 판시하여 자유권적 기본권과 같은 소극적인 권리로 파악하고 있다.

---

214) 홍성방, 「헌법학」(중), 2010, 37~38면 참조.
215) 헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14.
216) 헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14.

오늘날 국가는 단순히 국민의 자유를 침해하지 않아야 하는 측면뿐만 아니라, 국민의 자유실현에 적극적으로 개입할 것이 요구되는 바, 단순히 국가가 행복을 추구하기 위한 자유를 침해하지 않는데 그친다면, 행복추구권의 내용의 많은 부분이 현실적 규범력을 잃을 우려가 있으므로, 그 포괄적 권리성에 비추어 최소한의 수준에서 사회적 기본권과 같은 적극적 권리성의 성격도 가진다고 보아야겠다.

♣ 문제풀이

1. 다음 행복추구권의 설명으로 바르지 못한 것은?

① 외국인도 주체성이 인정된다.
② 포괄적기본권이다.
③ 개인의 주관적 권리로서 자연권이다.
④ 버지니아권리장전 최초로 면문화 되었다.
⑤ 우리헌법은 1962년 헌법에서 최초로 규정하였다.

[정답] ⑤
[해설] 우리 헌법은 1980년 제5공화국 헌법에서 행복추구권을 처음으로 수용하였다.

2. 다음 중 행복추구권이 규정되지 않은 것은?

① 1947년 일본헌법
② 1980년 한국헌법
③ 1776년 미국독립선언
④ 1789 프랑스인권선언
⑤ 1776년 버지니아권리장전

[정답] ④

3. 다음 일반적 행동의 자유권에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 행복추구권에는 일반적 행동의 자유권이 포함된다.
② 일반적 행동의 자유권에는 위험한 스포츠를 즐길 권리와 같은 위험한 생활발식으로 살아갈 권리도 포함된다.
③ 일반적 행동의 자유권은 헌법상 개별 기본권이 적용되는 영역과 무관하게 적용된다.
④ 일반적 행동의 자유권은 어떠한 행위를 할 자유와 하지 않을 자유가 포함된다.
⑤ 우리 헌법재판소는 계약의 자유, 음주측정을 강요당하지 아니할 권리, 기부금품모집행위 등에 대하여 일반적 행동의 자유권을 인정한 바 있다.

[정답] ③
[해설] 개별기본권이 적용되지 않는 경우에 한하여 적용된다(헌법재판소 2002. 8. 29. 2001헌가26).

♣ 요점정리

1. 우리 헌법은 제10조 제1문에서 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다”고 하여 인간으로서의 존엄과 가치 외에도 행복추구권을 규정하고 있다.

2. 우리 헌법은 1980년 제5공화국 헌법에서 행복추구권을 처음으로 수용하여 현행 헌법에 이르고 있다.

3. 행복추구권은 헌법에 열거된 기본권으로서의 행복추구의 수단이 될 수 있는 개별적 기본권 이외에 헌법에 열거되지 아니한 생명권, 신체를 훼손당하지 아니할 권리, 자유로운 활동과 인격발현에 관한 권리(인격권), 평화적 생존권, 휴식권, 수면권, 일조권, 스포츠권 등이 포함된다.

4. 우리 헌법재판소는 사죄광고와 관련하여 법인에게 인격권의 주체성을 인정한 바 있다.

5. 헌법재판소는 국가유공자예우 등에 관한 법률 제9조 본문 위헌제청사건에서 “헌법 제10조의 행복추구권은 국민이 행복을 추구하기 위하여 필요한 급부를 국가에게 적극적으로 요구할 수 있는 것이 아니라, 국민이 행복을 추구하기 위한 활동을 국가의 간섭없이 자유롭게 할 수 있다는 포괄적인 의미의 자유권으로서의 성격을 가진다”고 판시하여 자유권적 기본권과 같은 소극적인 권리로 파악하고 있다.

제14강 행복추구권(2)

♣ 학습목표

자유주의적 해석론을 설명할 수 있다.
공화주의적 해석론을 설명할 수 있다.
평등주의적 해석론을 설명할 수 있다.
우리 대법원과 헌법재판소의 판례를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

자유주의, 공화주의, 평등주의
대법원 판례, 헌법재판소 판례

♣ 사전테스트

1. 자유주의적 해석에 따르면, 행복추구권은 국가간섭의 배제와 개인의 자유로운 추구에 있는 것이지 국가에게 뭔가를 적극적으로 요구할 수 있는 것은 아니다.

   정답 : O

2. 공화주의자들은 시민의 참여와 덕을 겨냥하기 때문에 그들에게 행복추구권은 본질적으로 참정권과 연대를 포함하여 확장된 정치적 권리의 성격을 지닌다.

   정답 : O

3. 평등주의는 행복추구권을 사회적 재분배 실현을 위해 국가의 개입을 정당화하고, 국가의 적극적인 의무를 매개로 하여 행복한 삶의 물질적 조건을 구축하려는 권리로 이해하기 때문이다.

   정답 : O

♣ 돌발퀴즈

개명을 엄격하게 제한할 경우 헌법상의 개인의 인격권과 행복추구권을 침해하는 결과를 초래할 우려가 있다.

[정답] O
[해설] 대법원 2005. 11. 16. 2005스26

♣ 강의내용

1. 해석론

⑴ 자유주의

자유주의적 해석에 따르면, 행복추구권은 국가간섭의 배제와 개인의 자유로운 추구에 있는 것이지 국가에게 뭔가를 적극적으로 요구할 수 있는 것은 아니다. 특히 독립선언을 작성한 제퍼슨은 "사람은 누구나 재산을 소유하든 아니든, 부를 축적하든 나누어 주든, 물질적 성공을 택하든 금욕주의를 택하든 한 마디로 그가 좋다고 생각하는 지상과 천상의 구원의 길을 결정함으로써 안락, 위로, 행복, 은총을 추구하는 데에 있어서 그가 선택하는 바대로 행동할 수 있다"고 하였다.[217]

그러므로 "생명, 자유, 행복추구"에서 행복추구는 군더더기일 수밖에 없으며, 행복추구권은 '소극적 자유(negative liberty)'의 표현에 불과하다는 것이다. 따라서 행복추구권은 국가의 적극적 활동에 대한 요구로서 의미를 갖지 못하고, 사적영역에서 개인의 자율과 국가의 규제사이에서 개인의 자율을 옹호하는 방어적 권리에 불과하게 된다. 결국 행복추구권은 사적인 영역에서 개인적 행복을 자유롭게 추구하는 개인의 권리일 뿐이다.[218]

이러한 점에도 불구하고 자유주의적 해석은 행복추구권이 공적인 권위에 의해 침해되는 영역에서 자율을 옹호하는 논리가 될 수 있다는 점에서[219] 가치가 있다.

⑵ 공화주의

공화주의는 자유주의와 사회주의 또는 자유주의와 공동체주의 간의 간극을 해소하는 정치철학으로 등장하였다.[220] 공화주의자들은 전반적으로 개인주의에 불만을 갖고 미국헌법의 기초자들의 사상에 대한 수정주의적 해석을 제시하였다.[221]

공화주의자들이 강조하는 행복은 물질적 쾌락이나 사적행복의 탐닉이 아니라, 공공생활의 적극적 참여와 자치를 의미하며, 결국 사회적 차원의 행복을 의미한다. 이러한 공적차원의 행복은 고전적 공화주의 전통에서 실천하는 삶과 깊이 관련된다. 대표적인 인물인 제퍼슨에게 행복추구는 단순히 물질적인 취득이 아니라 이성적인 삶을 추구하고, 자신의 잠재력을 실현하는 것이다. 따라서 행복은 사적인 영역뿐만 아니라 공적인 영역에서 동시에 추구된다.

제퍼슨은 아리스토텔레스 윤리학에 나오는 관조하는 삶(vita contemplativa)과 실천하는 삶(vita activa)의 구분을 알고 있었으며, 관조하는 삶을 높이 평가하면서도 실천하는 삶의 중요성을 간과하지 않았다.[222]

---

217) Hamowy, Ronald, "Jefferson and the Scottish Enlightenment : A Critique of Garry Wills's Inventing America : Jefferson's Declaration of Independence", William & Mary Quarterly, Vol. 36, 1979, p. 519.

218) Treanor, William Michael, "TAKING TEXT TOO SERIOUSLY : MODERN TEXTUALISM, ORIGINAL MEANING, AND THE CASE OF AMAR'S BILL OF RIGHTS", Michigan Law Review, Vol. 106, 2007, p. 511.

219) Seaton, Liz, "THE DEBATE OVER THE DENIAL OF MARRIAGE RIGHTS AND BENEFITS TO SAME-SEX COUPLES AND THEIR CHILDREN", Margins : Md. L. J. Race, Religion, Gender & Class, Vol. 4, 2004, p. 127.

220) Pettit, Philip, Republicanism : A Theory of Freedom and Government, Oxford University Press, 1997.

221) Matthews, Richard, The Radical Politics of Thomas Jefferson, University Press of Kansas, 1984.

222) Yabrough, Jean M., American Virtue, University Press of Kansas, 1998, p. 16.

제퍼슨의 공적인 행복추구는 결국 사회의 연대를 강화시키고, 어느 세력으로부터도 지배당하지 않고, 오로지 스스로를 지배하는 시민의 이상이 핵심이다. 제퍼슨은 루소와 같은 수준에서 민중을 신뢰하고, 민중의 정치참여에 낙관하였다. 따라서 공화주의자들은 보통 선거권과 적절한 공공교육을 시민적 덕성에 필수로 보았다. 공화주의자들은 시민의 참여와 덕을 겨냥하기 때문에 그들에게 행복추구권은 본질적으로 참정권과 연대를 포함하여 확장된 정치적 권리의 성격을 지닌다.

⑶ 평등주의

평등주의자들은 루소의 사회계약사상을 사회경제질서에 관철시키고자 하였다. 프랑스 혁명과정에서 이러한 급진적 의미의 평등은 실현되지 못하였지만, 공공구제, 사회적 권리 등으로 관철되기도 하였다. 미국의 경우, 독립전쟁에 참여하여 제 몫을 다했지만 빈곤과 부채만 떠안은 제대군인들이 1786년 세이즈(D. Shays)의 지도아래 봉기하여 일종의 계급전쟁을 치렀으나 좌절되었다.

행복에 대한 평등주의적 접근은 복지권 개념을 정립하는 것을 목표로 한다. 독립선언의 행복추구권은 미국헌법에서 사라졌지만, 헌법전문에 '일반적 복지를 증진한다(promote the general welfare)'는 국가목적문구가 추가되었고, 미국 독립 선언상의 행복추구권, 안녕 행복 실현문구(effect their safety & happiness), 헌법전문의 일반적 복지문구, 헌법상 열거되지 않은 권리조항(제9조), 평등조항(제14조)으로부터 복지권을 추론하여 국가의 적극적 의무를 주장하였다. 또한, 평등주의는 독립선언과 헌법조항의 '본래적 의미'로부터 복지권을 추론할 수 있다고 주장하기도 하였지만, 노예제 철폐와 노동운동 등을 통해 '새로운 자유의 탄생'을 주장하기고 하였다.

평등주의자들은 자유주의적 법해석에 반대하고, 객관적 사회정의에 따른 해석을 지지한다. 따라서 자유시장주의적 헌법해석에 대하여 20세기 노동자들의 정치운동, 루스벨트의 네 가지 자유(four freedoms),[223] 제2차 세계대전 이후 흑인민권운동, 국제 인권법의 발달을 복지권의 정치적 기초로 삼고자 하였다. 물론 공화주의가 이상적으로 작동하기 위해서는 시민간의 평등을 이론상 전제하기 때문에 그 범위에서는 공화주의와 평등주의는 보완적이라고 할 수 있다. 전반적으로 공화주의 좌파시각과 평등주의는 양립가능하다. 그러나 평등주의는 빈곤계급의 관점에서 헌법의 의미를 발견하고 실현하고자하기 때문에 공화주의와는 다르다. 평등주의는 행복추구권을 사회적 재분배 실현을 위해 국가의 개입을 정당화하고, 국가의 적극적인 의무를 매개로 하여 행복한 삶의 물질적 조건을 구축하려는 권리로 이해하기 때문이다.

⑷ 대법원

223) 프랭클린 D. 루스벨트가 미국 대통령 집권 당시 1941년 1월 6일에 발표한 것으로 네 가지 자유란 첫째로 언론과 의사 표현의 자유(Freedom of speech and expression), 두 번째로 신앙의 자유(Freedom of worship), 세 번째로 결핍으로부터의 자유(Freedom from want), 네 번째로 공포로부터의 자유(Freedom from fear)을 말한다. 표현의 자유와 신앙의 자유는 종교, 언론 및 출판의 집회 및 청원의 권리를 규정하는 아메리카 합중국 헌법 수정조항 제1조에 나타나 있고, 결핍으로부터의 자유와 공포로부터의 자유는 2차 세계대전 기간과 그 이후에 사상적 측면에서 세계적인 영향을 끼쳤다. 또한, 대서양헌장과 국제연합헌장, 세계인권선언에도 반영되었다. 세계 인권 선언의 전문에는 다음과 같이 네 가지 자유가 직접적으로 명시되어 있다. "…인간이 언론과 신앙의 자유, 그리고 공포와 결핍으로부터의 자유를 누릴 수 있는 세계의 도래가 모든 사람들의 지고한 열망으로서 천명되어 왔으며,…" 또한, 네 가지는 적정한 생활수준을 누릴 권리(right to an adequate standard of living)와 관련된 세계 인권 선언 제25조에 중요한 영향을 미쳤다.

1) 만나고 싶은 사람을 만날 권리, 즉 구속된 피고인 또는 피의자의 타인과의 접견권은 행복추구권의 한 내용이다(대법원 1992. 5. 8. 91누7552).

2) 자신이 먹고 싶은 음식이나 마시고 싶은 음료수를 자유롭게 선택할 권리도 행복추구권의 한 내용이다(대법원 1994. 3. 8. 92누1728).

3) 일시 오락의 정도에 불과한 도박행위도 행복추구권의 한 내용이다(대법원 1983. 3. 22. 82도2151).

4) 이름은 통상 부모에 의해서 일방적으로 결정되어지고 본인이 그 이름에 대하여 불만을 가지거나 그 이름으로 인하여 심각한 고통을 받는 경우에도 개명으로 인하여 사회적 폐단이나 부작용이 발생할 수 있다는 점을 지나치게 강조하여 개명을 엄격하게 제한할 경우 헌법상의 개인의 인격권과 행복추구권을 침해하는 결과를 초래할 우려가 있는 점에서, 개명을 허가할 만한 상당한 이유가 있다고 인정되고, 범죄를 기도 또는 은폐하거나 법령에 따른 각종 제한을 회피하려는 불순한 의도나 목적이 개입되어 있는 등 개명신청권의 남용으로 볼 수 있는 경우가 아니라면, 원칙적으로 개명을 허가함이 상당하다고 하였다. 또한 개명신청인이 신용불량자로 등록되어 있더라도 법령상의 제한을 회피하기 위한 목적에서 개명신청을 하였다거나 다른 불순한 의도나 목적이 개입되어 있는 등 개명신청권의 남용에 해당한다고 볼 만한 사정도 찾아볼 수 없다면 이를 이유로 개명을 불허할 수 없다고 하였다(대법원 2005. 11. 16. 2005스26).

⑸ 헌법재판소

1) 군검찰관의 기소유예처분

무권한의 부당한 일차례 명령에 대한 불복종이 항명죄를 구성함을 전제로 내린 기소유예처분은, 범죄혐의를 벗기 위한 재판을 막는 결과가 되며, 자의적 기소유예처분은 평등권과 행복추구권을 침해한다(헌법재판소 1989. 10. 27. 89헌마56).

2) 재해보상과 보험가입에 관한 법률 제5조 제1항

I) 헌법 제10조의 행복추구권 속에 함축된 일반적 행동자유권과 개성의 자유로운 발현권은 국가안전보장, 질서유지 및 공공복리에 반하지 않는 한 최대한 존중되어야 한다.

II) 법률행위의 영역에 있어서 계약자유의 원칙도 일반적 행동자유권으로부터 파생되는 것으로 모든 4층 이상의 건물에 보험계약체결의 강제는 계약자유의 원칙에 대한 제약인 동시에 헌법상의 일반적 행동자유권의 제한이 된다(헌법재판소 1991. 6. 3. 89헌마204).

3) 국가 유공자 예우에 관한 법률 제9조 본문

헌법 제10조의 행복추구권은 국민이 행복을 추구하기 위하여 필요한 급부를 국가에게 적극적으로 요구할 수 있는 권리가 아니라, 국민이 행복을 추구하기 위한 활동을 국가권력의 간섭없이 자유롭게 할 수 있다는 포괄적인 의미의 자유권으로서의 성격을 가진다(헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14).

4) 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률 제5조 제1항

행복추구권은 개별적·구체적 권리가 아니라 인간의 존엄과 가치의 유지를 위해 필요한 모든 자유와 권리를 내용으로 하는 포괄적 권리이다(헌법재판소 1991. 6. 3. 89헌마204).

5) 가정의례에 관한 법률 제4조 제1항 제1호

결혼식 등의 당사자가 자신을 축하하러 온 하객들에게 주류와 음식을 접대하는 행위는 인류의 오래된 보편적 사회생활의 한 모습으로서 개인의 일반적인 행동의 자유영역에 속하는 행위이므로 이는 헌법 제37조 제1항에 의하여 경시되지 아니하는 기본권이며, 헌법 제10조가 정하고 있는 행복추구권에 포함되는 일반적 행동자유권으로서 보호되어야 할 기본권이다(헌법재판소 1998. 10. 15. 98헌마168).

6) 사죄광고

'사과문', '진사문', 해명서' 등 어떠한 명목의 것이든 관계없이 사죄광고 과정에서는 자연인이든 법인이든 인격의 자유로운 발현을 위해 보호받아야 할 인격권이 무시되고, 국가에 의한 인격의 외형적 변형이 초래되어, 인격형성에 분열이 필연적으로 수반되게 되므로, 헌법에서 보장된 인격의 존엄과 가치 및 그를 바탕으로 하는 인격권에 큰 위해도 된다(헌법재판소 1991. 4. 1. 89헌마160).

7) 민법 제847조 제1항

모든 국민은 그의 존엄한 인격권을 바탕으로 하여 자율적으로 자신의 생활영역을 형성해 나갈 수 있는 권리를 가지는 데, 친생부인의 소의 제척기간을 일률적으로 자의 출생을 안 날로부터 1년으로 규정함으로써 부가 자의 친생자 여부에 대한 의심도 가지기 전에 그 제척기간이 경과하여 결과적으로 부로 하여금 혈연관계가 없는 친자관계를 부인할 수 있는 기회를 극단적으로 제한하고 또 자의 출생 후 1년이 지나서 비로소 그의 자가 아님을 알게 된 부로 하여금 당사자의 의사에 반하여 친생부인권을 상실하게 하는 것이다. 이는 인간이 가지는 보편적 감정에도 반할뿐 아니라 자유로운 의사에 따라 친자관계를 부인하고자 하는 부의 가정생활과 신분관계에서 누려야 할 인격권 및 행복추구권을 침해하고 있는 것이다(헌법재판소 1997. 3. 27. 95헌가14).

8) 간통죄

간통행위를 형사처벌하는 것 자체가 가정 파탄을 막는 기능을 상실하는 등 실효성이 없고, 사회적 인식의 변화로 배우자에 대한 정조의무 못지않게 헌법 제10로부터 파생하는 성적 자기결정권이 보다 중요하다. 따라서 간통죄는 자기결정권과 사생활의 비밀 자유를 침해한다(헌법재판소 2015. 2. 26. 2009헌마17).

⑹ 검토

헌법재판소는 "헌법 제10조의 행복추구권은 국민이 행복을 추구하기 위하여 필요한 급부를 국가에게 적극적으로 요구할 수 있는 권리가 아니라, 국민이 행복을 추구하기 위한 활동을 국가

권력의 간섭 없이 자유롭게 할 수 있다는 포괄적인 의미의 자유권으로서의 성격"을 가진다고 판단하였다.

그러나 행복추구권의 해석론을 감안할 때 한국에서 행복추구권을 현재의 관행과는 다르게 해석해야 할 필요성도 없지 않다. 우리 헌법은 행복추구권을 권리로 규정하고 있기 때문에 행복추구권의 권리성을 부정할 수 없다. 또한, 우리 헌법은 다양한 사회권 규정을 두고 있으며, 국제규약에도 가입했기 때문에 행복추구권의 의미영역을 특수하게 소극적 자유의 맥락에 제한해야 할 이유는 없다. 오히려 다양한 차원에서 행복추구권을 존중하고 보호하고 구현해야 할 국가의 의무를 구체화해야 한다.

행복추구권은 인간존엄과 더불어 최고의 권리조항으로 파악해야 한다. 또한 행복추구권은 행복 개념이 맞닿고 있는 사회적, 문화적, 정치적, 종교적, 경제적 영역에서 구체적인 권리의 모체가 될 수 있다. 행복추구권은 자유주의적 권리로 등장할 때에는 지배적 윤리와 이데올로기에 대항하는 표현권으로서 중요하고, 평등주의자들이 강조하는 생존과 관련해서는 사회적 권리의 지향점으로 역할하며, 공화주의자들이 강조하고 있는 공공영역의 참여와 행복이라는 관점에서는 민주주의를 지향하는 직접행동권의 근거가 될 것이다.

♣ 문제풀이

1. 다음 행복추구권에 대한 설명으로 가장 바르지 못한 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 행복추구권은 독자적인 기본권으로서 주관적 공권성을 인정할 수 있다.
② 행복추구권은 인간의 생래적 권리이므로 자연권성을 인정할 수 있다.
③ 행복추구권은 다른 기본권에 대한 보충적 기본권으로서의 성질을 지닌다.
④ 행복추구권은 포괄적 기본권으로 인정될 수 있다.
⑤ 행복추구권은 국가에게 적극적 급부를 요구할 수 있는 권리이다.

[정답] ⑤
[해설] 포괄적 의미의 자유권으로서 성격을 가진다(헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14).

2. 다음 중 행복추구권이 적용되는 것이라고 보기 어려운 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 스포츠권
② 계약자유권
③ 개명권
④ 휴식권
⑤ 사생활비밀권

[정답] ⑤
[해설] 행복추구권은 보충적 보장기능을 한다. 헌법 제17조가 우선적용된다.

3. 다음 중 행복추구권의 침해에 해당하지 않는 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 가정의례준칙 중 결혼식에서 주류 및 음식물의 접대를 금지하는 것
② 4층 이상의 건물에 무조건 화재보험에 가입시키는 것
③ 희석식 소주의 자도소주구입을 강제하는 것
④ 기부금품모집행위의 허가여부를 행정청의 재량에 위임한 것
⑤ 학교환경위생정화구역내에 노래연습장 설치를 금지하는 것

[정답] ⑤
[해설] 헌법재판소 1999. 7. 22. 98헌마480

♣ 요점정리

1. 자유주의적 해석에 따르면, 행복추구권은 국가간섭의 배제와 개인의 자유로운 추구에 있는 것이지 국가에게 원가를 적극적으로 요구할 수 있는 것은 아니다.

2. 공화주의자들은 시민의 참여와 덕을 겨냥하기 때문에 그들에게 행복추구권은 본질적으로 참정권과 연대를 포함하여 확장된 정치적 권리의 성격을 지닌다.

3. 평등주의는 행복추구권을 사회적 재분배 실현을 위해 국가의 개입을 정당화하고, 국가의 적극적인 의무를 매개로 하여 행복한 삶의 물질적 조건을 구축하려는 권리로 이해하기 때문이다.

4. 헌법재판소는 “헌법 제10조의 행복추구권은 국민이 행복을 추구하기 위하여 필요한 급부를 국가에게 적극적으로 요구할 수 있는 권리가 아니라, 국민이 행복을 추구하기 위한 활동을 국가권력의 간섭 없이 자유롭게 할 수 있다는 포괄적인 의미의 자유권으로서의 성격”을 가진다고 판단하였다.

제15강 행복추구권(3)

♣ 학습목표

행복추구권의 구체적 내용을 설명할 수 있다.
행복추구권의 구체적 적용을 설명할 수 있다.
행복추구권의 효력과 제한을 설명할 수 있다.
행복추구권의 침해와 구제를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

행복추구권의 구체적 내용
행복추구권의 구체적 적용
행복추구권의 효력, 제한, 침해, 구제

♣ 사전테스트

1. 개인영역은 직장, 친지, 가족, 인근에 같이 일상생활하는 생활영역을 말한다.

정답 : X
해설 : 개인영역은 개인적인 생활과 창조적 활동을 전개할 수 있는 정적과 평온의 영역이다.

2. 우리 헌법재판소는 인간의 존엄과 가치의 유지를 위해 필요한 모든 자유와 권리를 말한다고 판시한 바 있다.

정답 : O
해설 : 헌법재판소 1991. 6. 3. 89헌마204.

3. 행복추구권으로부터 도출되는 일반적 행동의 자유권은 무제한한 것이다.

정답 : X
해설 : 행복추구권으로부터 도출되는 일반적 행동의 자유권은 타인의 권리나 도덕률 및 헌법질서를 침해해서는 안 된다는 한계를 가진다(계약자유의 제한 등).

♣ 돌발퀴즈

행복추구권은 대국가적 효력을 가지나 대사인적 효력은 인정되지 않는다.

[정답] X
[해설] 행복추구권은 원칙적으로 모든 국가작용을 구속하는 대국가적 효력을 가지며, 사적영역(개인 대 개인, 개인 대 대기업, 개인 대 언론 등)을 구속하는 대사인적 효력을 가진다.

♣ 강의내용

1. 구체적 내용과 적용

⑴ 내용

일반적 인격권은 세 가지 유형으로 나누어진다.

첫째, 인격의 발전을 목적으로 하는 권리, 즉 행위의 자유와 행동의 자유 등을 중심으로 한다. 이러한 일반적 인격권은 인격의 자유로운 발현의 한 요소를 포함하며, 이 요소는 피보호영역을 존중할 것을 요청하는 권리로서 인격발현의 적극적 요소, 즉 일반적 행동의 자유와는 구별된다.[224]

둘째, 인격에 관한 권리, 즉 생존(Dasein)의 보호, 정신의 보호, 의사의 보호, 감정·정신생활의 보호 등을 내용으로 한다.

셋째, 개성에 대한 권리, 이른바 인격의 영역, 즉 개인적 영역(Individualspäre), 사적영역(Privatsphäre), 비밀영역(Geheimsphäre)의 보호, 생명, 명예, 초상, 개인의 특성(Charakterbild), 대화, 저작, 사생활의 비밀분야(Geheimbereich) 등으로 나누어진다. 여기서 개인영역은 개인적인 생활과 창조적 활동을 전개할 수 있는 정적과 평온의 영역이고, 이는 피해자에게 치욕, 당혹, 고통을 느끼게 하는 개인적 영역을 누설했을 경우에 침해된다. 사적영역은 직장, 친지, 가족, 인근에 같이 일상생활하는 생활영역을 말한다. 비밀영역은 각자가 비밀유지의 이익이 있을 때의 모든 경우를 말한다.[225]

⑵ 적용

행복추구권은 개별기본권에 대한 일반적 기본권으로서 포괄적 기본권(Auffanggrundrecht)이다. 그러나 행복추구권의 내용이 포괄적이라는 것은 그것이 다른 개별기본권의 내용이 구체화되어 있고 특정되어 있는 데 비해 일반적이라는 의미이다. 이에 대하여 우리 헌법재판소는 인간의 존엄과 가치의 유지를 위해 필요한 모든 자유와 권리를 말한다고 판시한 바 있다.[226]

예컨대, 헌법재판소가 검찰관이 명백한 무혐의 불기소처분을 해야 할 사안인데도 경솔하게 범죄의 충분한 혐의가 있다고 보아 기소유예처분을 하면 차라리 공소제기되어 헌법 제27조 소정의 재판을 받을 권리의 행사에 의하여 무죄판결을 받아 완전히 혐의를 벗고 그 혐의사실에 대해서는 앞으로 재론 못하게 하는 길만 막아버리는 결과가 되어 공소를 제기한 것보다 더 불리할 수 있으며, 더 나아가 공소제기에 충분한 혐의가 있다고 인정한 기소유예처분이 유죄판결에 준하는 취급을 받아 법률적·사실적 측면에서 사회생활에 유형·무형의 불이익과 불편을 주는 것이 실상이라면 어느 모로 보아도 혐의 없고 무고함에 의심 없는 사안에 대해 군검찰관이 자의로 기소유예처분에 이른 것은 헌법 제10조 소정의 행복추구권을 침해한 것으로 봄이 상당하다고 판시한 것은 비판의 여지가 있다.

왜냐하면 헌법 제17조의 사생활의 비밀과 자유, 제12조의 신체의 자유와 같이 개별기본권 규정에 광의의 인격권의 내용이 규정되어 있는 경우가 있을 수 있는 데, 그런 경우에는 특별법우선의 원칙(lex specialis derogat lex generalis)에 따라 개별기본권이 적용되고 일반적 인격

---

224) P. Badura, Staatsrecht : Systematische Erläuterungen des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland, 1986, S. 88.

225) 니퍼다이는 인격발현권을 일반적 인격권에 포함시키지 않고, 일반적 인격권의 구체적 내용인 개별적 인권으로서 성명권, 초상권, 명예권, 혈연권, 비밀보호영역, 감정적·정신적 내면생활의 완전성을 존중받을 권리를 들고 있다(H. C. Nipperdey, Die Grundrechte, Bd. 4, 1962, S. 837ff.).

226) 헌법재판소 1991. 6. 3. 89헌마204.

권, 즉 행복추구권은 적용되지 않아야 한다. 따라서 헌법 제10조의 행복추구권은 개별기본권의 규율대상이 아닌 경우에 비로소 적용되어야 한다.[227]

<헌법재판소 2000. 12. 14. 99헌마112> 교육공무원법 제47조 제1항에 대한 위헌확인

행복추구권은 다른 기본권에 대한 보충적 기본권으로서의 성격을 지니므로, 공무담임권이라는 우선적으로 적용되는 기본권이 존재하여 그 침해여부를 판단하는 이상, 행복추구권 침해여부를 판단할 필요는 없다.

<헌법재판소 2002. 8. 29. 2001헌가26> 상호신용금고법 제37조의3 제1항 등 위헌제청

행복추구권은 다른 개별적 기본권이 적용되지 않는 경우에 한하여 보충적으로 적용되는 기본권으로서, 이 사건에서 기본권으로서 결사의 자유나 재산권이 고려되는 경우에는 그 적용이 배제된다.

2. 효력

행복추구권은 원칙적으로 모든 국가작용을 구속하는 대국가적 효력을 가지며, 사적영역(개인 대 개인, 개인 대 대기업, 개인 대 언론 등)을 구속하는 대사인적 효력을 가진다.

3. 제한과 제한의 한계

행복추구권으로부터 도출되는 일반적 행동의 자유권은 타인의 권리나 도덕률 및 헌법질서를 침해해서는 안 된다는 한계를 가진다(계약자유의 제한 등).

타인의 권리라 함은 헌법의 범위 내에서 법질서에 의하여 인정되고 보호받는 권리영역만을 말하고 모든 임의적 이해관계를 뜻하지는 않는다.[228]

도덕률이란 형법이나 민법 제2조 및 제103조에 표현된 성문법상의 도덕률은 물론 불문법상의 도덕률(예컨대 자살)을 포함하며, 건건한 국민정서 또는 공동체의 지배적 사회윤리관이라고도 한다.

헌법질서란 실질적·형식적으로 합헌적인 규범의 전체를 말한다.[229]

<헌법재판소 1995. 7. 21. 94헌바125> 영화법 제26조 등 위헌확인

헌법이 보장하는 행복추구권이 공동체의 이익과 무관하게 무제한의 경제적 이익의 도모를 보장하는 것이라고 볼 수 없다.

<헌법재판소 1997. 7. 17. 95헌가6> 민법 제809조 제1항의 위헌제청

행복추구권이라 할지라도 반사회적 내지 반자연적 행위를 금지하는 규범이나 전통문화로 인식되어 온 국민의 법감정에 반하여 이를 남용할 수 없음을 물론 타인의 행복추구권을 침해하거

227) BVerfGE 5, 52(57); 9, 343; 60, 229.

228) Schmidt-Bleibtreu/Klein, Kommentar zum Grundgesetz, 5. Aufl., 1980, S. 160, Anm. 13. zu Art. 2.

229) 개별기본권 주체들의 행동의 자유는 사회공동생활을 보호하기 위하여 입법자가 일반적으로 추측할 수 있는 인격의 고유성이 손상되지 않는 한계 내에서 설정하고 전제한 제약을 받는다(BVerfGE 50, 256, 262).

나 방해할 수 없음은 너무나 당연하다고 할 것이며 적어도 국민의 의사에 정면으로 반하지 아니하는 한 전통, 관습에 반한 행복추구권을 추구할 수는 없다.

또한, 행복추구권이 반사회적·반국가적인 형태로 나타나는 경우에는 헌법 제37조 제2항에 의하여 제한될 수 있다. 제한되는 경우에도 그 본질적 내용은 제한될 수 없다.

<헌법재판소 1996. 2. 29. 94헌마13> 18세 미만자의 노래연습장출입금지

행복추구권도 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 제한될 수 있는 것이므로 목적의 정당성, 방법의 적정성, 피해의 최소성, 법익의 균형성 등의 요건을 갖추고 있는 위 조항들이 청구인이나 18세 미만의 청소년들의 행복추구권을 침해한 것이라고 할 수 없다.

4. 침해와 구제

⑴ 침해

행복추구권은 국가나 사인에 의하여 침해될 수 있다.

우리 대법원은 여성으로서의 성적 수치심을 자극하는 방법으로 신체적·정신적 고통을 가하는 것,[230] 생수의 국내시판을 불허하는 보사부고시에 대해 행복추구권의 침해로 보았다.[231]

헌법재판소는 범죄혐의가 없음이 명백한 사안에 대하여 군검찰관이 자의적이고 타협적으로 기소유예처분을 하는 경우,[232] 당연히 의심을 갖고 조사해야 할 중요한 사항에 대하여 필요한 조사를 현저히 소홀히 하고, 피의사실을 인정할 수 있는 증거가 될 수 없다는 사실을 인식하고도 자의적인 증거 판단으로 청구인데 대하여 기소유예처분을 한 경우,[233] 18세 미만자의 당구장 출입을 금지한 것,[234] 등에 대해 행복추구권의 침해로 보았다.

⑵ 구제

국가나 사인에 의하여 침해 또는 방해를 받은 때에는 이를 이유로 침해행위배제청구권이나 예방청구권에 의해 구제받을 수 있고, 받은 손해에 대해 손해배상청구도 가능하다.

또한, 청원권, 재판청구권, 헌법소원권 행사 등을 통하여 구제받을 수도 있다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 행복추구권을 침해하는 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 전투경찰에게 대간첩작전 임무 이외에 시위진압을 하도록 명령하는 것
② 학교보건법 소정의 학교환경위생정화구역 안에서 노래연습장을 설치하고 운영하는 것을 금지하는 것
③ 식품영업에 관하여 당국의 허가를 받도록 하는 것
④ 경과실로 인하 실화자에 대한 피해자의 손해배상청구권을 배제하는 것

---

230) 대법원 1988. 1. 29. 86모58.
231) 대법원 1994. 3. 8. 92누1728.
232) 헌법재판소 1989. 10. 27. 89헌마56.
233) 헌법재판소 1993. 3. 11. 92헌마191.
234) 헌법재판소 1993. 5. 13. 92헌마80.

⑤ 미결수용자가 수감되어 있는 동안 재판을 받을 때 사복을 입지 못하게 하고 재소자용 의류를 입게 하는 것

[정답] ⑤

[해설] 헌법재판소 1999. 5. 27. 98헌마137

2. 다음 행복추구권 내지 일반적 행동의 자유권에 관한 설명 중 바르지 못한 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 일반적 행동의 자유권에는 적극적으로 자유롭게 행동을 하는 것은 물론 소극적으로 행동을 하지 않을 자유, 즉 부작위의 자유도 포함된다.

② 구 국가보안법 제9조 제2항에서 규제대상이 되는 편의제공은 법운영당국이 편의제공자가 누구인가에 따라 법규문언 그대로 적용하여 합헌행위까지도 처벌할 경우, 헌법 제10조 소정의 행복추구권에서 파생되는 국민의 일반적 행동의 자유권을 위축시킨다.

③ 주세법 제38조의7 등이 규정한 자도소주구입명령제도는 소주제조업자의 기업의 자유 및 경쟁의 자유를 제한하고, 소비자가 자신의 의사에 따라 자유롭게 상품을 선택하는 것을 제약함으로써 소비자의 행복추구권에서 파생되는 자기결정권도 제한하고 있다.

④ 기부금품모집을 원칙적으로 금지하고 일정한 경우에만 허가할 수 있도록 규정한 기부금품모집금지법 제3조는 기부금품 모집목적을 과도하게 제한함으로써 행복추구권을 침해하는 위헌적인 규정이다.

⑤ 소유권이전등기신청을 의무화하고 그 위반에 대하여 과태료를 부과하도록 한 부동산등기특별조치법 제11조 제1항은 과잉금지원칙에 어긋나게 일반적 행동의 자유권을 제한한 것이다.

[정답] ⑤

[해설] 과잉금지원칙에 위반되지 않는다(헌법재판소 1998. 5. 28. 96헌바83).

3. 다음 중 행복추구권이 침해된 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 탁주의 공급구역제한제도를 규정하는 것

② 18세 미만자의 당구장 출입금지하는 것

③ 주취운전자에게 음주측정에 응할 의무를 지우는 것

④ 학교환경위생정화구역내에 노래연습장의 설치를 금지하는 것

⑤ 요트조종면허제를 규정한 수상레저안전법 조항

[정답] ②

[해설] 헌법재판소는 당구장 경영자에게 당구장 출입문에 18세 미만자에 대한 출입금지표시를 하게 하는 체육시설의설치이용에관한법률 시행규칙에 대해 당구장 경영자의 직업수행의 자유와 당구를 통하여 자신의 소질과 취미를 살리고자 하는 18세 미만자의 행복추구권의 한 내용인 일반적 행동자유권을 침해한다 하여 위헌결정을 하였다(헌재1993.5.13.92헌마80).

♣ 요점정리

1. 우리 헌법재판소는 검찰관이 명백한 무혐의 불기소처분을 해야 할 사안인데도 경솔하게 범죄의 충분한 혐의가 있다고 보아 기소유예처분을 한 것은 헌법 제10조 소정의 행복추구권을 침해한 것으로 봄이 상당하다고 판시한 바 있다.

2. 행복추구권은 다른 기본권에 대한 보충적 기본권으로서의 성격을 지니므로, 공무담임권이라는 우선적으로 적용되는 기본권이 존재하여 그 침해여부를 판단하는 이상, 행복추구권 침해여부를 판단할 필요는 없다.

3. 행복추구권으로부터 도출되는 일반적 행동의 자유권은 타인의 권리나 도덕률 및 헌법질서를 침해해서는 안 된다는 한계를 가진다.

4. 행복추구권이 반사회적·반국가적인 형태로 나타나는 경우에는 헌법 제37조 제2항에 의하여 제한될 수 있다. 제한되는 경우에도 그 본질적 내용은 제한될 수 없다.

5. 국가나 사인에 의하여 침해 또는 방해를 받은 때에는 이를 이유로 침해행위배제청구권이나 예방청구권에 의해 구제받을 수 있고, 받은 손해에 대해 손해배상청구도 가능하며, 청원권, 재판청구권, 헌법소원권 행사 등을 통하여 구제받을 수도 있다.

제16강 평등권(1)

♣ 학습목표

평등원칙의 사상적 전개를 설명할 수 있다.
자유주의, 공리주의, 사회주의 사상의 전개를 설명할 수 있다.
평등원칙의 헌법상 실정화를 설명할 수 있다.
우리 헌법 제11조의 규정체계를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

자유주의, 공리주의, 사회주의
평등원칙의 실정화
우리 헌법 제11조

♣ 사전테스트

1. 평등사상의 연원은 아리스토텔레스로 대변되는 고대 그리스사상과 중세 그리스도교의 '신 앞의 평등'에서 찾아볼 수 있다.

정답 : O

2. 평등원칙을 처음으로 실정화한 헌법문서는 1793년 프랑스헌법 제3조이다.

정답 : X
해설 : 1776년 버지니아 권리장전이 모든 인간은 생래로부터 평등하다는 것을 처음으로 실정화한 헌법문서이다.

3. 평등의 원리가 법 앞의 평등으로 규정된 것은 1793년 프랑스 헌법이다.

정답 : O
해설 : 평등의 원리가 오늘날과 같은 형태, 즉 법 앞의 평등으로 규정된 것은 1793년 프랑스 헌법 제3조에서 처음으로 규정되었다.

♣ 돌발퀴즈

바이마르헌법은 실질적 의미의 평등을 처음으로 규정한 헌법이다

[정답] O
[해설] 바이마르헌법은 사회국가원리에 입각한 실질적 의미의 평등을 처음으로 규정한 헌법으로 이해되고 있다.

♣ 강의내용

1. 사상의 전개

평등사상의 연원은 아리스토텔레스로 대변되는 고대 그리스사상과 중세 그리스도교의 '신 앞의 평등'에서 찾아볼 수 있다. 여기서 '신 앞의 평등'이 봉건사회에 있어서 신분적·계급적 권력지배를 부정하고 인간의 본성에 따른 생래적인 자유와 평등을 주장한 17~18세기의 근대 합리주의적 자연법사상의 영향을 받아 '법 앞의 평등의 원칙'으로 발전하였다.[235]

그러나 근대국가에 있어서 평등의 원칙은 그 출발에 있어서 시민계급의 정치적 해방의 요청에서 모든 특권계급을 철폐할 것을 내용으로 했으며, 항의적·도전적 개념을 의미하였다. 따라서 평등의 원칙은 모든 시민이 국가조직과 통치에 참가해야 하고, 국가기관은 국민을 신분에 따라 차별하지 않는 법률을 제정하여 평등하게 적용해야 한다는 전제가 요구된다.[236]

평등권은 서구 근대사상을 형성한 자유주의사상과 밀접한 관련이 있다. 자연권론과 사회계약론은 초기 자유주의 사회를 형성하였고, 자유주의 법체계에 변형되어서 수용되었으며, 이후 공리주의와 실증주의적 사고와 함께 자유주의 법체계를 확립하였다.

⑴ 자유주의 사상의 전개

홉스는 '자연상태'하의 인간들이 자기보존, 생명의 보호를 위하여 합의를 통해 정치적 권력체를 형성한다고 주장하였다. 여기서 홉스가 제시하는 '자연상태'는 로크의 고전적 자유주의 사상과 롤즈의 정의론에 이론적 바탕이 되었고, 특히 로크는 인간이 자연상태에서 생명의 보호 이외에도 자유와 재산을 보호라는 자연권 보호 사상에 입각해 사회계약론을 구성한다.

자연상태에서 인간의 자유, 생명, 재산에 대한 권리는 자연권으로서 어느 누구도 침해할 수 없는 절대적 위치에 놓여있다. 이러한 고전 자연권 사상과 사회계약론은 인간이 스스로 선택한 계약행위를 통해서 새로운 관계를 현성할 수 있다는 자유주의원리 그 자체를 법원리로 형성하였다.

⑵ 공리주의 사상의 전개

로크가 실정법 이전의 상태에서의 절대적으로 존재하는 생명, 재산, 자유에 대한 권리를 상정하였다면, 자유주의와 함께 서구 사상의 양대 축을 형성하고 있는 공리주의는 권리에 대한 다른 시도를 하고 있다. 즉 공리주의 사상가인 벤담은 아무리 실정법 이전에 존재하는 자연권이라 하더라도 실정법에 의하여 보장받지 못한다면 그 권리가 보장되지 않는다고 한다. 권리의 보장을 위해 실정법이라는 형식이 필요한가에 대한 로크와 벤담 사이에 형식적 차이가 있지만, 두 사상가 모두 개인의 자유 신장을 추구한다는 공통점이 있다.

벤담은 법을 정치적 상부자가 정치적 하위자에게 부과하는 명령으로 규정하는데, 법은 주권자의 명령으로 법은 권위에 바탕을 두고 있다는 것이다.[237] 이러한 법은 제정법에 바탕을 두어야 한다고 하며 법의 개혁은 입법부에 의하여야 한다고 한다. 그는 자연법, 자연권, 실정법 이전에 존재하는 재산권을 전면적으로 거부하고 모든 권리는 실정법에 의해 주어지는 것이라고 주장한다. 즉 법은 자연의 법, 신의 법, 인간의 이성 등에 의해 확인되기 보다는 주권자의 명령

---

235) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 47면.
236) 홍성방, 상게서, 47~48면 참조.
237) Jeremy Bentham, Fragment on Government, Cambridge University Press, 2008, pp. 86~87.

인 실정법에 의해 확인된다는 것이다. 오늘날 고전적 법실증주의를 정립했다고 평가받는 벤담의 사상은 오스틴에게도 큰 영향을 미쳐 영국을 비롯한 서구 법실증주의의 기초가 되었다.[238]

미국에서 자유주의는 영국의 실증주의적 전통과는 다른 방향으로 발전하였다. 1776년 '독립선언서'는 국민들의 생명, 자유, 행복을 추구할 권리, 재산권과 같은 로크가 상정했던 자연권을 상당 부분 포용한 내용들을 받아들여 법은 궁극적으로 이러한 권리들을 보장하기 위해 존재한다는 사상을 반영하고 있다. 미국 헌법도 벤담과 오스틴과 같이 법이 주권자의 명령이라는 사상을 배격하고 독립선언서에서 보호하고자 하던 국민의 자연권 사상을 반영하여 제정된 것이었다. 하지만 자연권 사상을 반영하여 제정되었던 법을 해석하기 위해서 실질적 법해석론이 필요하였고, 미국 법사상에 큰 영향을 미치고 있는 홈즈 판사는 법은 공적 관리들에 의해 만들어지는 것이며 권위에 정초해야 한다고 주장하였다.[239] 영국에서 자유주의는 벤담의 공리주의적 실증주의로 발전하였다면, 미국에서는 자연권의 재확인이라는 형식적 의미에서의 법사상에서 19세기 후반 실증주의에 접근하여 결국 영국과 미국은 거의 유사한 공리주의적 실증주의 사상에 기초해 자유주의 법체계를 형성하게 되었다.

자유주의는 로크적 의미에서의 자연권 사상에 입각한 법형식주의와 벤담적 의미에서 자연권은 실정법에 의한 보장을 필요하다는 법실증주의 모두와 친화적 관계를 가질 수 있다는 점에서 법과 관련해서 그 자체로 다변적인 모습으로 나타날 수 있다는 점에 자유주의의 딜레마가 있다. 그리하여 자유주의는 한편으로는 실정법이 자연권의 재확인이라고 하는 형식적 의미만을 가지는 자유주의 법체계로 나타날 수도 있고, 실정법을 통한 보장이라는 법의 실증성을 보다 강조한 자유주의 법체계로 나타날 수도 있다.영국 헌정사는 왕권을 견제하고 제한하기 위한 투쟁의 역사였고, 이에 따라 '법의 지배'는 왕의 자의적인 권력행사를 제한 할 수 있는 자유와 권리 보장의 지배이념이었다고 할 수 있다. 자유주의 사회에서 '법의 지배'는 법의 중립성, 법의 객관성, 법적 안정성으로 표현되고 이는 곧 개인의 권리 보호로 연결되는 것이다.

평등은 아리스토텔레스가 언급한 바와 같이 정의론의 핵심적인 내용이다. 그리고 실정법 이전의 자연상태에서도 누릴 수 있는 자유권과는 달리, 평등권은 개념필수적으로 제3자의 입장에서 평등한 분배를 할 제3의 권력기구가 필요하다. 그러므로 각 개인이 평등한 대우를 받을 수 있기 위하여 불평등한 계층들이 자의적인 지배를 극복할 수 있는 방법을 모색하게 되고, 이러한 과정에서 자유주의 사상의 발전과정에서 형성된 '법의 지배'원리가 평등권 보장에 필수적인 역할을 하게 되는 것이다.

자유주의 법체계 하에서 평등권은 법에 의해 보장되어 개인의 권리를 보호하게 되고, 평등권 내용 역시 먼저 형식적 평등권의 개념으로 나타나게 된다. 법의 지배원리는 20세기 초까지 법이라는 형식을 통한 지배로 나타났으며, 평등권 역시 법이라는 형식을 통해 보다 확실하게 보장되게 되었다. 그러므로 평등권을 법적으로 보장하는 것은 자유주의적 법사상에서 가장 중요한 의미를 가지게 된 것이다. 이는 벤담식의 공리주의적 실증주의 사상으로 다가갔던 영미법의 법적 전통과도 부합하는 것이라고 할 수 있다.

2. 평등원칙의 헌법상 실정화

1776년 버지니아 권리장전은 모든 인간은 생래로부터 평등하다는 것을 처음으로 실정화한 헌법문서이다. 자연법적 평등을 실정법적으로 선언하는 이러한 전통은 미국 독립선언문과 여러 주의 헌법들, 프랑스 인권선언, 1791년 프랑스 헌법에[240] 계승되었다.

---

238) John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, Prometheus Books, 2000, p. 140.
239) O. W. Holmes, The Path of the Law, Harvard Law Review 10 (1898), p. 457.
240) 제1조 : 인간은 자유로운 존재로서 태어나고 존재하며 권리에 있어서 평등하다.

그러나 평등의 원리가 오늘날과 같은 형태, 즉 법 앞의 평등으로 규정된 것은 1793년 프랑스 헌법 제3조에서 처음으로 규정되었다.[241] 이후, 법 앞의 평등은 19세기 대부분의 헌법에 수용되었다.[242]

근대의 평등원칙이 만인의 평등과 신분적·계급적 인간해방을 내용으로 하는 정치적 평등이 치중하였다면, 오늘날 평등원칙은 정치적 평등 이외에도 사회현실 속에 구체적 불평등을 제거하고, 경제적 약자를 해방시켜 모든 사람에게 인간다운 생활을 할 권리를 보장하여는 경제적 평등의 실현에 주력하고 있다. 바이마르헌법은 사회국가원리에 입각한 실질적 의미의 평등을 처음으로 규정한 헌법으로 이해되고 있다.

오늘날 평등의 문제는 주로 분배적 정의와 관련되고 있고, 분배적 정의는 평등실현을 어떻게 달성할 것인가에 대한 문제라고 할 수 있다.

⑴ 자유주의

자유주의는 개인의 사회공헌도와 그가 받는 대가는 일치해야 하며, 배분은 보이지 않는 손(Invisible Hand)에 의하여 이루어 져야 한다고 한다.[243]

아리스토텔레스(Aristoteles : 기원전 384년~322년)는[244] "배분적 정의는 돈과 명예와 같은 가치를 배분함에 있어서 자질에 따라 평등한 비율로 배분하는 것이며, 자질을 갖추지 못한 자에게는 불평등하게 배분하는 것이라 하면서, 불평등한 자를 공평하게 다루는 것처럼 공정하지 못한 것은 없다"고 주장하였다.[245]

노직(Nozick : 1938년~2002년)은[246] 정의의 자격이론(Entitlement Theory of Justice)을 전개하면서 "자유이외의 어떠한 인위적 재분배도 목적으로 대우받아야 하는 인간의 존엄성을 해치기 쉽다"고 주장하였다.

그러나 자유주의는 사회에 끼친 공헌이나 실적만큼 대우를 받아야 한다는 것에 대한 기준이 없다는 점과 실제 적용에 있어서 개인의 반대급부가 상황에 따라 수정될 수 있음을 해명할 수 없으며,[247] 사회적 무능력자나 심신장애자 또는 노약자 등을 어떻게 대우할 것인가에 대한 논의가 없다는 점에서 비판받았다.[248] 또한, 지나치게 현실옹호적이며, 분배의 문제를 단순히 정부의 간섭을 줄이는 측면에서 해결하려고 했다는 점에서 타당하지 않다고 하겠다.

⑵ 공리주의

공리주의는 '최대다수의 최대행복'으로 집약된다. 즉, 부의 극대화를 통하여 정의를 달성할 수 있다는 것이다. 이러한 공리주의는 영국에서 모든 정치권력을 지주계급이 독점하였던 시대적

---

241) 제3조 : 모든 인간은 본래 그리고 법률 앞에 평등하다.

242) 홍성방, 전게서, 48면.

243) 양영철, "정책이념으로서의 배분적 정의에 관한 연구", 「논문집」 제25권, 제주대학교, 1987, 307면 참조.

244) E. Barker, The Politics of Aristoteles, Oxford University Press, 1946, pp. 362~363.

245) 아리스토텔레스는 배분적 정의와 시정적 정의(Corrective Justice)로 구별하고 있다. 위에서 설명되고 있는 배분적 정의와는 다르게 시정적 정의는 사회·경제적 불평등이 야기 되었을 경우 국가가 이를 평준화시킬 의무가 있고 그것이 정의라고 하였다(자세한 내용은 최명관,『니코마코스 윤리학』, 서광사, 1984, 143~149면 참조.).

246) R. Nozick, Anarchy, State and Utopia, Basic Books, 1974, pp. 42~58.

247) 인간은 근본적으로 상황의 맥락 안에 속하는 존재이다. 즉, 인간의 내면화 된 가치 역시 사회적 배경 안에서 습득되고 발전하며, 정치·윤리·경제 등의 특정한 사정과 배경에 영향을 받을 수밖에 없다는 의미이다(자세한 내용은 이종은, "배분의 문제",「대한정치학회보」제7집 제1호, 대한정치학회, 1999, 268면 참조.).

248) 백원기, 「행정학」, 박영사, 1984, 397~398면 참조.

배경과 시민의 이익은 대표되지 않는다는 사상적 배경을 바탕으로 벤담(Bentham, Jeremy : 1748년~1832년) 등에 의해서 시민의 권력참여와 최대다수의 행복을 추구하는 사상으로 대두되었다. 이외에도 밀(Mill, John Stuart : 1806년~1873년)의 질적 공리주의 사상,[249] 엘베티우스(Helvetius, Claude-Adrien : 1715년~1771년)의 공익론,[250] 등이 대표적이다.

그러나 공리주의는 만족의 총량이 개인들에게 어떻게 분배되는지에 대해 간접적으로만 문제삼고, 한 개인이 자신의 만족을 시간적으로 어떻게 분배할 것인가에 대해서도 간접적으로만 문제 삼고 있으며, 개인들의 차이를 신중하게 다루지 않았다는 점과 정의개념을 단순히 전체 혹은 평균 선의 극대화를 위한 수단으로 파악한다는 점에서 비판받았다.[251] 나아가 욕망과 쾌락의 극대화를 가져오는 제도는 무엇이든지 정의로운 것이 되고, 행복의 최대화라는 결과보다는 그 행복을 계산하는 산출근거에 관련되어 있다는 점에 문제가 있으며, 인간의 기본권을 유린하는 노예제도가 공리주의자들에 의해 정당화 된다는 점에 문제가 있다.[252] 또한, 전체를 위해서는 개인의 권리나 자유를 침해할 수도 있다는 가능성을 열어주었다는 점에서 타당하지 않다고 하겠다.

⑶ 사회주의

사회주의자들은 극대화된 자유가 자본주의의 모순에[253] 의해 빈익빈 부익부를 가속한다고 하면서 평등에 가치를 두고자 하였다.[254]

마르크스(Marx, Karl Heinrich : 1818년~1883년)는[255] "능력에 따라 일하고 필요에 따라 배분되어야 한다"고 주장하였다. 이는 개개인은 생산과정에 기여한 실적에 따라 정당한 배분을 보

---

249) 벤담의 공리주의는 '쾌락'을 삶의 목표로 간주함으로써 인간의 삶을 천박하고 무가치하게 만들었다는 비판이 가해지고 있다. 밀은 이러한 비판에 직면하여 벤담처럼 삶의 궁극적 목표를 행복으로 보면서도 쾌락의 양만을 중시할 것이 아니라 그 질적인 차이도 고려해야 한다고 주장하였다. 예컨대 감각적 쾌락보다는 정신적 쾌락이 더 수준 높은 쾌락이라고 하였다. 그는 정상적인 인간이라면 누구나 질적으로 높고 고상한 쾌락을 더 원할 것이기 때문에 배부른 돼지가 되기보다는 배고픈 인간이 되는 편이 낫고 만족스러운 바보가 되기보다는 불만족스러운 소크라테스가 되는 편이 낫다고 주장하였다. 그리고 그는 인간의 쾌락이 야수의 쾌락과 양적으로뿐만 아니라 질적으로 구별될 수 있다고 하였으며 어떤 종류의 쾌락들이 다른 것들에 비하여 더욱 바람직하고 가치 있다는 사실을 인정하는 것은 공리주의의 원리와 얼마든지 양립 가능하다고 주장하였다. 이러한 점에서 밀은 질적 공리주의의 입장을 대변한 것으로 평가받고 있다(자세한 내용은 Mill, John Stuart, On Liberty, 1859(이극찬譯,「자유론」, 삼성출판사, 1982, 430~431면 참조.).

250) 공익은 항상 덕성의 대상이며, 사회정의는 대다수에게 이익을 가져오는 행위에서 찾을 수 있다는 견해이다(자세한 내용은 양영철, 전게논문, 307~308면 참조.).

251) 자세한 내용은 John Rawls, A Theory of Justice, Harvard University Press, 1999, pp. 21~22.

252) 황경식,「사회정의의 철학적 기초」, 문학과 지성, 1985, 331~332면 참조.

253) 자본주의의 모순에 대하여 G. D. H. Cole, History of Socialist Thought, Macmillan Co. Ltd, 1956, pp. 245~256에서는 "첫째, 자본주의적 사유재산제와 이를 위한 이윤추구, 자유시장 경쟁에 따른 분업의 확대와 임금제 등이 경제적 부의 불평등과 분배를 제도적으로 불가피하게 만들고 이를 정치권력과 국가제도로 강제하게 됨으로써 부의 분배에서 소외된 대다수 노동자계층의 자본주의체제 질서에 대한 반감과 분노가 표출되고, 둘째, 자유방임적 시장윤리와 기업경쟁이 기업의 집중과 구매력의 편중화를 재촉해간 반면 무계획환 생산과다와 구매력 부족이 상승적으로 작용하여 공황과 실업이 주기적으로 반복되는 경제적 불안이 지속됨으로써 자본주의체제 질서의 효용성에 대한 회의가 제기되며, 셋째, 공장분업제에 따른 노동자의 도시집중과 핵가족화, 기계적 공정에 따른 여성과 연소자의 저임금과 혹사, 노동자의 비인간화가 진행됨에 따라 전통적인 사회관습과 문화·제도·인간관계 등이 급속히 붕괴되어 결국 자본주의는 이러한 사회상황을 초래한 주범으로 간주되어 비판"되어 지게 된다고 설명하고 있다.

254) 정기방, "마르크스-레닌주의에 있어서 평등과 효율",「통일논총」10, 동의대학교 통일문제연구소 1997. 10, 102면 참조.

255) K. Marx/F. Engles, Selected Works, Vol. II, Foreign Languages Publishing House, 1955, p. 24.

장한다는 기여 내지 실적의 원칙과 크게 다르며, 모든 사람에게 동등한 분배의 권리를 부여한다는 것을 의미한다.

레닌(Vladimir Ilich Ulyanov : 1870년~1924년)은 마르크스가 인정하였던 과도기적 중간단계에[256] 대하여 사회주의를 계급적 차이가 완전히 소멸되지 않은 과도기적 체제로 규정하고, 그러한 과도기적 체제는 "노동에 비례한 공정한 분배"를 관장하고 노동계급의 이익을 반혁명세력으로부터 보호하는 것을 주요한 임무로 하는 프롤레타리아계급의 국가체제라고 구체화 하였다.[257]

그러나 사회주의는 이론적으로 분배방식에 있어서 분배받은 권리 이상의 생산성을 가진 자가 과연 자기의 노력을 희생하여 다른 사람을 위해서 생산에 계속 전념할 수 있겠는가와 분배받은 권리 이하의 생산성을 가진 자가 분배받은 권리의 일부라도 보답하기 위하여 보다 많은 노력을 기울이게 될 것인가에 대한 의문이 제기되며, 현실적으로 물질적 유인이 결여된 체제에서는 생산성과 효율이 크게 떨어져서 분배해야 할 사회전체의 부의 총량이 감소하였다는 것이 사회주의 국가의 현실이라고 비판받았다.[258]

3. 우리 헌법

우리 헌법은 제11조 제1항 제1문에서 모든 국민은 법 앞에 평등하다고 규정하여 평등원리를 선언하고 있고, 제2문에서 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다고 하여 차별금지사유와 차별금지영역을 예시하고 있다.

제2항에서는 사회적 특수계급을 금지하고, 제3항에서는 영전일대의 원칙을 규정하고 있다. 이외에도 헌법전문은 정치·경제·사회·문화의 모든 영역에 있어서 각인의 기회를 균등히 하고 국민생활의 균등한 향상을 기할 것을 선언하고 있다.

제31조 제1항은 교육의 기회균등, 제32조 제4항은 여자의 근로에 대한 부당한 차별금지, 제36조 제1항은 혼인과 가족생활에 있어서 양성의 평등, 제41조 제1항과 제67조 제1항은 국민의 보통·평등·직접·비밀선거, 제116조 제1항은 선거운동에 대한 균등한 기회보장을 규정하고 있다.

제119조와 제123조는 직접적인 규정은 아니지만 간접적으로 평등을 언급한 규정으로 볼 수 있다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 평등의 원리와 관계가 없는 것은?

① 의무교육의 무상성
② 여자근로자의 특별한 보호
③ 전직 대통령에 대한 예우
④ 군생활에서의 학력에 따른 차별대우
⑤ 선거운동에 대한 균등한 기회보장

---

256) 마르크스는 혁명적 전환기로서의 초기 공산주의에서는 경제구조뿐만 아니라 도덕적, 정신적 측면에서도 자본주의적인 잔재가 사회저변에 남아있기 때문에 노동에 대한 어느 정도의 물질적 유인이 효과적인 생산을 위해서는 불가피하여 '노동에 비례한 반대급부'를 인정하며, 이러한 과도기를 프롤레타리아 독재기간으로 규정하였다. 따라서 능력에 따라 일하고 필요에 따라 분배되는 완전한 공산주의체제가 성취되기 전의 과도기적 중간단계를 인정하고 있다고 평가한다.

257) 정기방, 전게논문, 103~104면 참조.

258) 정기방, 전게논문, 104면 참조.

[정답] ④

[해설] 우리헌법 제11조 1항 제2문

2. 다음 평등권에 대한 기술 중 바르지 못한 것은?

① 모든 국가기관을 구속한다.
② 영전의 수여는 법률에 의한다.
③ 평등권은 성명·종교·신분 등의 사유로 차별되어서는 안 된다.
④ 합리적 근거 있는 차별은 허용된다.
⑤ 사회적 신분에 따른 차별은 평등의 원칙에 어긋나지 않는다.

[정답] ⑤

[해설] 헌법 제11조 1항 제2문

3. 다음 평등에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 평등이란 배분적정의론에 입각하여 모든 인간을 평등하게 처우하되 합리적 이유가 있는 차별을 허용하는 상대적 평등을 의미한다.
② 차별적 취급은 비례원칙에 따라 엄격한 기준에 의해서만 가능하다.
③ 형법상 상습범가중, 누범가중 규정은 일사부재리원칙이나 책임주의에 위배하지 않는다.
④ 형법상 간통죄규정은 헌법에 위반되지 않는다.
⑤ 헌법 11조 1항의 차별금지사유는 예시이며 차별금지영역도 모든 영역을 의미한다.

[정답] ④

[해설] 형법상 간통죄규정은 과잉금지원칙에 위배하여 국민의 성적 자기결정권 및 사생활의 비밀과 자유를 침해하는 것으로 헌법재판소에 의한 위헌결정이 있었다(헌재 2015.2.26.2009 헌바17).

♣ 요점정리

1. 평등사상의 연원은 아리스토텔레스로 대변되는 고대 그리스사상과 중세 그리스도교의 '신 앞의 평등'에서 찾아볼 수 있다.

2. 1776년 버지니아 권리장전은 모든 인간은 생래로부터 평등하다는 것을 처음으로 실정화한 헌법문서이다.

3. 평등의 원리가 법 앞의 평등으로 최초로 규정된 것은 1793년 프랑스 헌법 제3조이다.

4. 우리 헌법은 제11조 제1항 제1문에서 모든 국민은 법 앞에 평등하다고 규정하여 평등원리를 선언하고 있고, 제2문에서 누구든지 성별·종교 또는 사회적 신분에 의하여 정치적·경제적·사회적·문화적 생활의 모든 영역에 있어서 차별을 받지 아니한다고 하여 차별금지사유와 차별금지영역을 예시하고 있다.

5. 우리 헌법 제11조 제2항에서는 사회적 특수계급을 금지하고, 제3항에서는 영전일대의 원칙을 규정하고 있다.

제17강 평등권(2)

♣ 학습목표

평등의 의의를 설명할 수 있다.
평등규정의 법적성격을 설명할 수 있다.
일반적 평등권을 설명할 수 있다.
법 앞의 평등의 주체를 설명할 수 있다.
법 앞의 평등의 내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

평등의 의미
평등규정의 법적성격
평등의 원리
일반적 평등권
법 앞의 평등의 주체, 내용

♣ 사전테스트

1. 평등이란 “권리, 의무, 자격 등이 차별 없이 고르고 한결같음”이라는 사전적 의미에 주목해 본다면, 절대적 평등을 의미하게 된다.

정답 : O
해설 : 이러한 의미에서 평등은 어떤 대상들을 차이를 두어 구별하지 않고 ‘모든 상황에서 동일하게 대우’한다는 의미로 이해될 수 있다.

2. 제11조의 평등규정은 평등의 원리와 일반적 평등권을 동시에 규정한 것으로 이해되고 있다.

정답 : O

3. 평등원칙은 행위규범으로서 입법자에게 객관적으로 같은 것은 같게 다른 것은 다르게 규범의 대상을 실질적으로 평등하게 규율할 것을 요구하고 있다.

정답 : O
해설 : 헌법재판소 1997. 1. 16. 90헌마110.

♣ 돌발퀴즈

평등원칙은 단지 자의적인 입법의 기준만을 의미하게 되므로 입법자의 결정에서 차별을 정당화할 수 있는 합리적인 이유를 찾아볼 수 없는 경우에만 평등원칙의 위반이 된다.

[정답] O
[해설] 헌법재판소 1997. 1. 16. 90헌마110.

♣ 강의내용

1. 평등의 의의 및 법적성격

⑴ 의의

평등은 복잡하고 불명확한 개념이다. 오펜하임(Felix E. Oppenheim)이 지적한대로[259], 그런 모호성의 원천은 실증적(positive) 측면과 규범적(normative) 측면이 존재한다. 사회과학에서 평등 개념은 때로는 사람들이 공통적으로 지녔다고 여겨지는 어떤 특질들을 가리키고 보다 흔히는 사람들이 받거나 받아야 마땅한 어떤 대우들을 가리킨다. 이것은 누구나 잘 아는 문제지만, 실제로 이 두 측면을 엄격하게 구분하는 일은 쉽지 않다.

사람들의 비동일성에 구애되지 않는 평등을 주장하는 사람들은 인간의 변이성을 부정하고, 평등을 동일성과 같다고 전제한다. 그러나 모든 인간은 동일하지 않을 뿐만 아니라 동일할 수도 없다. 규범적 평등은 본질적으로 도덕적 것이다. 우리는 서로 같지 않기 때문에 평등해야 하는 것이 아니라 서로 다름에도 불구하고, 규범적으로 평등해야 한다는 것이다. 스티븐 핑거(Steven Pinker)가 지적한 것처럼 인종, 성, 또는 민족의 근거에서 사람을 차별하는 것은 그들이 통제할 수 없는 특질들에 대해 그들을 벌하는 것이므로 도덕적으로 혐오스럽고 공평하지 못하다. 핑거에 따르면, 규범적으로 모든 사람들이 평등하게 대우를 받을 자격이 있다는 의미이다. 이것은 모든 사람들이 똑같은 도덕적 또는 천부적 권리들을 지녔다는 주장에도 그대로 적용되어야 함을 의미한다.[260]

이러한 평등의 개념은 아주 애매하므로 만족스러운 기준은 없으나 오펜하임에 따르면, 평등주의(egalitarianism)의 전통적 기준들은 ⑴ 불편성(impartiality), ⑵ 모든 사람들에게 평등한 몫(equal shares to all), ⑶ 평등한 사람들에게 평등한 몫(equal shares to equals), ⑷ 비례적 평등(proportional equality), ⑸ 관련이 있는 차이에 상응하는 불평등한 몫(unequal shares corresponding to relevant differences, ⑹ 각계의 자격에 따른 배분(to each according to his desert) 등을 들 수 있다. 그러나 '평등한 사람들에게 평등한 몫'과 '비례적 평등'에 따르면, 모든 규칙들이 평등하고, '관련이 있는 차이에 상응하는 불평등한 몫'과 '각계의 자격에 따른 배분'에 따르면, 어떤 규칙도 정당하다고 판정될 수 있다. 따라서 어떤 기준도 완전한 평등을 만족시키기 어렵다.

따라서 평등이란 "권리, 의무, 자격 등이 차별 없이 고르고 한결같음"이라는 사전적 의미에 주목해 본다면, 평등은 어떤 대상들을 차이를 두어 구별하지 않고 '모든 상황에서 동일하게 대우'한다는 의미로 이해될 수 있다.[261]

---

259) Felix E. Oppenheim, Dimensions Of Freedom : An Analysis, 2012.
260) Steven Pinker, The Blank Slate : The Modern Denial of Human Nature, 2002.
261) 이준일, 「차별금지법」, 고려대학교 출판부, 2007, 18면.

⑵ 법적성격

제11조의 평등규정은 평등의 원리와 일반적 평등권을 동시에 규정한 것으로 이해되고 있다.[262]

<헌법재판소 1989. 1. 25. 88헌가7> 소송촉진 등에 관한 특례법 제6조의 위헌심판

헌법 제11조 제1항은 기회균등 또는 평등의 원칙을 선언하고 있는바 평등의 원칙은 국민의 기본권보장에 관한 우리 헌법의 최고원리로서 국가가 입법을 하거나 법을 해석 및 집행함에 있어 따라야 할 기준인 동시에, 국가에 대하여 합리적 이유 없이 불평등한 대우를 하지 말 것과 평등한 대우를 요구할 수 있는 모든 국민의 권리로서 국민의 기본권 중의 기본권인 것이다.

1) 평등의 원리

평등규정은 모든 국가생활영역과 모든 기본권에 적용되고 보장되고 있다. 즉, 모든 국가생활영역과 모든 기본권은 평등의 원리를 토대로 하고 있다. 평등의 원리는 정의라는 객관적 원리의 표현이며, 우리 법질서의 기본명제라고 할 수 있다.[263]

이와 관련하여 독일연방헌법재판소는 독일기본법 제3조 제1항의 일반적 평등의 원칙은 헌법에 의하여 인정된 초실정적 법 원리이며,[264] 객관적 정의원리의 한 요소이자 기본법을 지배하는 법치국가원리의 한 요소일 뿐만 아니라,[265] 불문의 자명한 헌법원리로서 모든 법영역에 적용된다.[266] 즉, 기본법의 헌법적 기본질서는 자유와 평등의 국가질서라는 지속적 기본가치라는 생각을 기초로 하고 있다.[267] 따라서 인간의 존엄과 자유는 모든 인간에게 귀속하며, 모든 인간은 평등하기 때문에 모든 시민을 평등하게 취급하라는 원리는 자유민주주의에서는 자명한 요청이다.[268] 그러므로 법 앞의 평등은 제3조에 성문화된 헌법이 아니라하더라도 초실정적 법원리에 근거한 헌법질서의 구성부분에 속한다.[269]

이렇듯 국가생활과 법질서에서 가지는 평등의 원리의 불가결성으로 인해 평등의 원리는 우리 법질서 내에서 인간의 존엄과 비슷한 지위를 가진다고 할 수 있다.[270] 따라서 평등의 원리는 모든 국가활동의 척도가 되며, 우리 헌법의 가치체계의 한 지주임과 동시에 전체 법질서의 원칙규범이다. 따라서 헌법의 핵심요소로서 헌법개정이 불가능하다.

또한, 평등의 원리는 헌법재판의 심사기준이 되는 통제규범으로서 자의적인 입법의 금지기준을 의미한다.

<헌법재판소 1997. 1. 16. 90헌마110> 교통사고처리특례법 제14조 등에 대한 헌법소원

평등원칙은 행위규범으로서 입법자에게 객관적으로 같은 것은 같게 다른 것은 다르게 규범의 대상을 실질적으로 평등하게 규율할 것을 요구하고 있다. 그러나 헌법재판소의 심사기준이 되는 통제규범으로서의 평등원칙은 단지 자의적인 입법의 기준만을 의미하게 되므로 헌법재판소는 입법자의 결정에서 차별을 정당화할 수 있는 합리적인 이유를 찾아볼 수 없는 경우에만 평등원칙의 위반을 선언하게 된다. 즉, 헌법에 따른 입법자의 평등실현의무는 헌법재판소에 대

262) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 49면.
263) 홍성방, 상게서, 49면.
264) BVerfGE 1, 208, 243.
265) BVerfGE 21, 353, 373.
266) BVerfGE 35, 263, 272.
267) BVerfGE 2, 12.
268) BVerfGE 5, 205.
269) BVerfGE 1, 233.
270) 홍성방, 전게서, 49~50면 참조.

하여는 단지 자의금지원칙으로 그 의미가 한정축소된다. 따라서 헌법재판소가 행하는 규범에 대한 심사는 그것이 가장 합리적이고 타당한 수단인가에 있지 아니하고 단지 입법자의 정치적 형성이 헌법적 한계 내에 머물고 있는가 하는 것에 국한시켜야 하며, 그럼으로써 입법자의 형성의 자유와 민주국가의 권력분립적 기능질서가 보장될 수 있다.

그러나 엄밀하게 말한다면 평등 자체는 중립적인 개념이다. 평등이라는 중립적인 개념이 의미를 가지기 위해서는 한편으로는 평등이 '무엇에 있어서의 평등', '평등한 무엇'과 같이 어떤 실체와 결합되어야만 한다.[271] 다른 한편으로는 어떤 실체는 평등과 결부되지 않을 때에는 그 의미를 잃게 된다. 즉, 인간의 존엄, 자유, 권리가 보장된다고 하더라고 그것이 평등한 인간의 존엄, 평등한 자유, 평등한 권리가 아닌 한 그러한 보장은 전혀 무의미하게 된다.[272] 따라서 평등의 원리는 우리 헌법상의 모든 보장의 당위적 상태를 규정하며, 인간의 존엄과의 관계에서는 인간의 존엄이라는 헌법의 최고이념을 실현함에 있어서 따라야 할 방법상의 지침을 제공한다.[273]

평등의 원리가 정치적 영역에 적용되는 경우 그것은 민주국가의 구성원리로서 기능하게 된다. 오늘날 평등한 선거권, 평등한 투표권, 평등한 공무담임권 등으로 구체화되는 평등의 원리가 부정된다면 민주적 정치질서의 형성은 불가능하게 된다.[274]

또한, 평등의 원리는 모든 생활영역에서 기회의 균등을 요구할 수 있는 근거가 된다. 특히 현대 사회국가에서는 사회적 평등을 요구하고, 국가적 급부에 평등하게 참여할 수 있는 근거가 된다. 따라서 일반적 평등사상은 적극적·실질적으로 사회적 기본권과 사회국가원리를 표현한다고 할 수 있다.

2) 일반적 평등권

일반적 평등권은 국가권력에 의하여 그의 자연의 평등을 침해받지 않을 것을 내용으로 하는 개인적 공권(방어권)으로서 불평등한 입법에 대하여는 위헌법률심판, 불평등한 행정처분과 재판에 대하여는 행정쟁송과 상소를 할 수 있게 하는 근거조항이 된다. 또한, 평등권에 대한 침해는 헌법소원의 대상이 된다.

<헌법재판소 1992. 7. 23. 91헌마209> 검사의 불기소처분에 대한 헌법소원

검사의 불기소처분이 자의적으로 행사된 경우에 그 피해자는 헌법 제11조에 규정된 평등권과 헌법 제27조 제2항에 규정된 재판절차진술권이 각각 침해되었음을 이유로 헌법소원심판을 청구할 수 있다.

2. 법 앞의 평등의 주체 및 내용

(1) 주체

법 앞에 평등은 자연인뿐만 아니라 법인과 법인격 없는 단체에게도 주체성이 인정된다는 데에 이견이 없다. 이에 대해서는 외국인에게 주체성이 인정되는 가에 대해서는 부정설, 제한적 긍정설, 상황적 제한설 등의 학설이 대립하고 있다. 그러나 외국인의 주체성을 전적으로 부정하

271) 이러한 측면에서 비교대상을 전제로 한다는 점에서 상대적 평등을 의미한다.
272) 이는 절대적 평등을 의미한다.
273) 홍성방, 전게서, 50면.
274) 한태연, 「헌법학」, 법문사, 1985, 912면 참조.

는 견해는 없고, 외국인에게 어떤 근거와 범위에서 평등권이 인정되는 가에 대한 견해의 대립이 있을 뿐이다.

김철수 교수는 평등권은 인간의 권리이므로 외국인에게도 적용되나 국제법의 규정에 따라 호혜주의의 원칙에 의해 약간의 제한이 따르는 경우가 있다고 한다.[275]

권영성 교수는 외국인에게도 원칙적으로 평등의 원칙이 적용되어 주체성이 인정되나 한국국민이 아니고는 누릴 수 없는 정치적 기본권과 같은 공권과 일정한 사법상의 권리는 외국인에게 인정되지 않는다고 한다. 그러나 외국인에 대해서 적용되는 평등조항의 구체적 범위는 국제법과 상호주의원칙에 따라 결정된다고 한다.[276]

허영 교수는 평등권이 기본권 실현의 방법적 기초로서의 의미와 기능을 가지며 기회균등과 자의금지를 내용으로 하는 것이라면 국내거주 외국인도 원칙적으로 평등권의 주체가 된다고 한다. 다만 평등권의 내용과 의미에 관한 구체적인 해석을 통해서 상황에 따라 평등권을 제한하는 것은 가능하다고 한다.[277]

홍성방 교수는 법 앞의 평등은 인간의 존엄이라는 헌법의 최고이념을 실현하기 위한 방법상의 지침을 제공하는 평등의 원리와 국가권력에 의하여 그의 자연의 평등을 침해받지 않는 것을 내용으로 하는 개인적 공권으로서의 성격을 모두 가지고 있으므로 외국인에게 주체성을 인정하여야 한다고 한다. 다만 개별평등권은 호혜주의 원칙에 따라 제한될 수 있다고 한다.[278]

이렇듯 견해들은 전제에 있어서 다소 차이를 보이지만 결론에 있어서는 비슷해 보인다.

⑵ 내용

1) 법의 의미

법 앞에 평등에서 말하는 법은 국회의 의결을 거친 형식적 의미의 법률에 한하는 것이 아니라 실질적 의미의 법을 말한다. 따라서 제11조 제1항의 법은 성문법과 불문법은 물론 자연법까지도 포함한다.

2) 평등의 의미

가. 상대적 평등

오늘날 절대적 평등의 개념은 받아들이기 어렵다. 따라서 상이란 여러 대상이 똑같다고 하는 동일성과 오늘날의 평등의 개념은 다르다. 결국 상이한 여러 대상을 평등하게 취급하는 것은 특정의 표지 또는 특정의 기준에 따라 결정된다.

이러한 측면에서 볼 때, 법 앞의 평등은 상대적 평등을 의미한다. 즉, 법적평등이라고 함은 종교적인 절대적이고 무차별적인 또는 수학적이고 기계적인 절대적 평등을 뜻하는 것이 아니라 사실상의 평등은 평등하게 반대로 사실상의 불평등은 그 특질적 사상에 따라서 불평등하게 법적으로 취급되어야 한다는 상대적 평등을 의미한다.

<대법원 1966. 3. 29. 65누69>

헌법 제9조에서 말하는 법 앞의 평등의 취지는 모든 국민을 절대적으로 평등하게 대우해야 한다는 것은 아니고 불합리한 차별대우를 금지한다는 취지이다.

---

275) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 403면.
276) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 376면.
277) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 323~324면.
278) 홍성방, 전게서, 52~54면 참조.

또한, 상대적 평등의 관념이 불평등한 것을 불평등하게 법적으로 취급한다는 의미는 모든 국가기관에게 사실에 반하여 자의적으로 취급할 것을 금지하는 것을 의미한다. 이는 특수한 사실의 차이를 자의적으로 무시하여 기계적 평등을 실현한다는 것은 오히려 불평등을 강제하는 결과가 되기 때문이다. 따라서 상대적 평등이라는 것은 결국 합리적 차별을 인정한다는 것이다.

<헌법재판소 1989. 5. 24. 89헌가37> 금융기관의 연체대출금에 관한 특별조치법 제5조의 2

헌법 제11조 제1항의 평등의 원칙은 결코 일체의 차별대우를 부정하는 절대적 평등을 의미하는 것이 아니라 법의 적용이나 입법에 있어서 불합리한 조건에 의한 차별을 하여서는 안 된다는 상대적 평등을 의미한다.

<헌법재판소 1990. 6. 25. 89헌마107> 토지수용법 제46조 제2항

헌법이 보장하는 평등의 원칙은 개인의 기본권 신장이나 제도의 개혁에 있어 법적 가치의 상향적 실현을 보편화하기 위한 것이지 불균형의 제거만을 목적으로 한 나머지 하향식 균등까지 수용하고자 하는 것은 결코 아니다.

나. 합리적 차별과 불합리한 차별의 기준

인간존엄성설은 독일연방헌법재판소와[279] 헤세(K. Hesse)[280] 등이 주장하고 있으며, 인간의 존엄이라는 인격주의이념에 적합한가 위반되는가를 차별여부의 판단기준으로 삼아야 한다고 한다.

입법목적설은 미국과 일본의 판례와 라이프홀츠(G. Leibholz)가[281] 주장하고 있으며, 차별이 정당한 입법목적을 달성하기 위하여 불가피하고 또 그것이 사회통념상 적정한 것인가 아닌가를 합리적 차별여부의 판단기준으로 삼아야 한다고 한다.

독일에서는 '자의금지(Willkürverbot)'를[282] 미국에서는 '합리성(Reasonableness)'을[283] 기준으로 들고 있다. 우리 헌법재판소는 합리성과 자의금지,[284] 정의와 형평 등을 그 기준으로 들고, 합리적 차별여부는[285] 인간의 존엄성 존중이라는 헌법의 최고원리와 정당한 입법목적의 달성, 수단의 적정성이라는 세 가지 복합적 요소를 기준으로 판단하고 있다.[286] 또한, 헌법재판소는 통제규범으로서의 평등의 원칙에 대해서는 사법자체적인 태도를 취하고 있으며,[287] 입법자가 평등의 원칙에 위반했는가 여부에 대한 심사를 엄격한 심사적도와 완화된 심사척도로 단계화하고 있다. 이때 엄격한 심사를 한다는 것은 자의금지원칙에 따른 심사, 즉 합리적 이유의 유무를

279) BVerfGE 2, 12.
280) K. Hesse, Der Gleichheitsgrundsatz im Staatsrecht, AöR Bd. 77(1951/1952), S. 167ff.
281) G. Leibholz, Gleichheit vor dem Gesetz, 1. Aufl.(1925), 2. Aufl.(1959), S. 76, 196f.
282) 여기서 자의금지는 이성적인 사물의 본성으로부터 나오는 또는 그 밖에 객관적으로 명백한 근거를 찾을 수 없는 경우, 정의사상을 지향하는 고찰방법에 있어서 규율이 자의적인 것으로 표현될 수밖에 없는 경우라고 한다(BVerfGE 1, 14, 52).
283) 미연방대법원은 '회의적 차별(suspect classification : 인종, 출신국, 종교 등)'이나 '기본적 권익(fundamental interests : 기본적 인권으로서 헌법상 보장되어 있는 권리와 투표권, 항소권, 주간(州間) 통행권 등)에 해당하는 사항은 엄격한 심사기준이 적용된다. 따라서 단순히 입법목적과 차별간에 합리적 관련성만을 요구하는 것이 아니라 입법목적이 긴요한 것이어야 하고 그 목적을 달성하기 위해 그 차별이 필수적이어야 한다. 사회경제적 입법에 대하여는 최소한의 합리성기준을 적용한다. 중간심사기준은 남녀, 적서문제에 있어서 차별을 하는 입법의 합헌여부를 결정함에 있어 그 법이 중요한 통치목적을 증진시키고 있는가, 그러한 차별이 목적수행에 실질적 관련성을 가지는가에 따라 판단한다.
284) 헌법재판소 1993. 7. 29. 89헌마31; 1989. 9. 8. 88헌가6.
285) 헌법재판소 1994. 2. 24. 92헌마43.
286) 헌법재판소 1989. 5. 24. 89헌가37; 1992. 6. 26. 91헌가8.
287) 헌법재판소 1997. 1. 16. 90헌마110.

심사하는 것에 그치지 아니하고 비례성의 원칙에 따른 심사, 즉 차별적 취급의 목적과 수단사이에 엄격한 비례관계가 성립하는지를 기준으로 한 심사를 행함을 의미한다.

<헌법재판소 1999. 12. 23. 98헌바33> 구 국가유공자예우 등에 관한 법률 제70조

평등위반여부를 심사함에 있어 엄격한 심사척도에 의할 것인지, 완화된 심사척도에 의할 것인지는 입법자에게 인정되는 입법형성권의 정도에 따라 달라지게 될 것이다. 차별적 취급으로 인하여 관련 기본권에 대한 중대한 제한을 초래하게 된다면 입법형성권은 축소되어 보다 엄격한 심사척도가 적용되어야 할 것이다. 그런데 가산점제도는 헌법 제25조에 의해 보장된 공무담임권이라는 기본권의 행사에 중대한 제약을 초래하는 것이다. 따라서 가산점제도에 대해서는 엄격한 심사척도가 적용되어야 한다.

<헌법재판소 1999. 12. 23. 98헌마363> 제대군인지원에 관한 법률 제8조 제1항 등

헌법에서 특별히 평등을 요구하고 있는 경우 엄격한 심사척도가 적용될 수 있다. 헌법이 스스로 차별의 근거로 삼아서는 아니 되는 기준을 제시하거나 차별을 금지하고 있는 영역을 제시하고 있다면 그러한 기준을 근거로 한 차별이나 그러한 영역에서의 차별에 대하여 엄격하게 심사하는 것이 정당화된다. 다음으로 차별적 취급으로 인하여 관련 기본권에 중대한 제한을 초래하게 된다면 입법형성권은 축소되어 보다 엄격한 심사척도가 적용되어야 할 것이다.

그 밖에도 어떠한 조치가 자의적이냐(비합리적이냐)는 문제는 그 조치의 주관적 동기를 떠나 객관적으로 그 자의의 실질적 내용을 표준으로 하여야 한다. 뿐만 아니라 어떠한 사태를 평등하게 취급해야 할 것이냐 아니냐의 문제는 그 사태를 측정하는 여러 가지 기준에 있어서 그 기준이 사태에 대한 본질적 기준이냐에 따라 결정하게 된다. 따라서 사태의 측정에 있어서 본질적인 기준이 아닌 다른 기준에 의하여 그 사태를 취급했을 때에는 자의의 개념에 해당된다.[288] 예컨대, 어떠한 사태의 판단에 있어서 인간을 본질적 기준으로 할 때에는 자국인과 외국인의 구별이 없지만, 한국인을 기준으로 할 때에는 자국인과 외국인에 대한 불평등한 취급이 가능해지는 것이다.

결국 법적평등이 상대적 평등을 의미한다는 것은 개인의 연령·성별 또는 직업 기타 특별한 대인관계 등을 고려하여 정의·도덕·합목적성 등의 요청에 따라서 합리적으로 차별하는 것까지를 금지하는 것은 아니다. 이러한 측면에서 볼 때, 정치적 영역에서는 절대적 평등, 사회적·경제적·문화적 영역에서는 상대적 평등이 더 강조될 수 있을 것이다.[289]

다. 역평등과 역차별

역평등(reverse equality)이란 특히 취업과 교육분야에서 유색인과 여성 등 경제적·사회적 약자에 대하여 '우선적 처우(preferential treatment)'나 '적극적 조치(affirmative action)'를 함으로써 실질적 평등을 기하려는 평등의 현대적 경향을 말한다. 예컨대, 과부에게는 재산세를 면제해 주면서 홀아비에게는 이를 면제해 주지 않는 법률을 합헌으로 본 경우가 있다.[290]

그러나 이러한 경우, 상대적으로 백인이나 남성에게 불평등을 초래하는 역차별(reverse discrimination)의 문제를 야기하기도 한다.[291]

---

288) 홍성방, 전게서, 58~59면.
289) 홍성방, 전게서, 59면.
290) Kahn v. Shevin, 416 U. S. 351, 1974.
291) Regents of University of California v. Bakke, 1978.

라. 법정립상의 평등과 법적용상의 평등

우리 헌법은 제10조 제2문의 해석상 기본권이 모든 국가권력을 구속한다는 데에는 이견이 없다. 더 나아가 제11조 제1항 제1문은 모든 국민은 법 앞에 평등하다고 규정하고 있으며, 제111조에서 위헌법률심사제도를 규정하고 있다. 따라서 법 앞의 평등은 입법·행정·사법 등 모든 국가권력을 구속하는 것이며, 법정립에 있어서의 평등(법률의 평등, 법 내용의 평등)과 법적용에 있어서의 평등을 의미한다.[292]

그러나 불법에 있어서의 평등을 의미하지는 않는다. 예컨대, 어떤 형사범도 다른 형사범이 처벌받지 않는다는 것을 근거로 자신에 대한 형벌의 면제를 요구할 수는 없으며, 형벌이 과해질 어떤 행위가 형벌을 받지 않았다고 해서 같은 평가를 받는 행위가 무죄라고 할 수는 없다.[293]

또한, '공정한 기준(gerechte Kreterien)'에 따라 같은 것과 같지 않은 것, 같이 취급할 사항과 다르게 취급하여야 할 사항을 결정하는 것은 입법권자의 형성의 자유에 속한다. 이러한 경우, 입법권자의 형성의 자유는 가능한 존중되어야 한다. 그러나 이러한 입법권자의 형성의 자유는 입법내용이 정의와 형평에 반하거나 자의적으로 이루어져서는 안 된다는 한계가 있다. 예컨대, 입법권자가 평등권을 침해했는지의 여부는 단순히 제정법률의 형식적 요건이나 내용은 물론 법률의 실질적인 내용을 기준으로 판단해야 하기 때문에 법률이 형식면에서는 차별대우를 금지하는 것으로 규정하고 있지만 그 법률의 집행 내지 적용과정에서 차별대우가 불가피하게 되는 경우에는 평등권을 침해한 입법권의 행사가 된다.[294]

<헌법재판소 1992. 4. 28. 90헌바24> 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률 제5조의3 제2항 제1호

우리 헌법이 선언하고 있는 인간의 존엄성과 법 앞의 평등은 행정부나 사법부에 의한 법적용상의 평등만을 의미하는 것이 아니고 입법권자에게 정의와 형평의 원칙에 합당하게 합헌적으로 법률을 제정하도록 하는 것을 명하는 법내용상의 평등을 의미하고 있기 때문에 그 입법내용이 정의와 형평에 반하거나 자의적으로 이루어진 경우에는 평등권 등을 본질적으로 침해한 입법권의 행사로서 위헌성을 면하기 어렵다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 평등의 원칙에 대한 기술로 옳지 않은 것은?

① 평등의 원칙은 국민의 기본권 보장에 관한 헌법의 최고원리인 동시에 국민의 기본권 중의 기본권이다.
② 평등의 원칙은 기회균등 내지 자의금지를 의미한다.
③ 독일에서는 합리성이 미국에서는 자의금지가 기준이 되고 있다.
④ 법의 적용을 받은 모든 인간을 원칙적으로 평등하게 다룰 것을 요구한다.
⑤ 국가는 합리적인 기준에 따라 능력이 허용하는 범위 내에서 법적가치의 상향적 구현을 위한 제도의 단계적 개선을 추진할 수 있다.

[정답] ③
[해설] 독일이 자의금지, 미국이 합리성을 기준으로 하고 있다.

---

292) 헌법재판소 1989. 5. 24. 89헌가37·96 병합.
293) BVerfGE 50, 142, 166.
294) BVerfGE 8, 64.

2. 다음 중 평등의 원칙에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 법 앞의 평등에서 법은 광의의 법을 의미한다.
② 정치적 영역에서는 절대적 평등이 사회적·경제적 영역에서는 상대적 평등이 보다 강조될 수 있다.
③ 인적·신분적 차별금지를 절대적 평등으로 주장하는 것은 근대국가 창설 당시의 혁명적 이데올로기와 일치한다.
④ 평등의 원칙이 법치국가적 구성요소를 의미할 때에는 적극적·구성적 원리를 의미하고, 민주국가적 구성요소를 의미할 때에는 소극적·방어적 원리를 의미한다.
⑤ 평등의 원칙은 개인의 기본권 신장이나 제도의 개혁에 있어 법적가치의 상향적 실현을 보편화하기 위한 것이다.

[정답] ④
[해설] 법치국가에서는 소극적·방어적, 민주국가에서는 적극적·구성적 원리를 의미한다.

3. 다음 법 앞의 평등에 관한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 상대적 평등의 관념에 의해 지배되고, 합리적 차별은 인정된다.
② 외국인도 원칙적으로 평등권의 주체성이 인정될 수 있다.
③ 기본권 실현의 방법적 기초이다.
④ 사실상의 불평등은 특수사정에 따라 불평등하게 취급하는 것이다.
⑤ 불법영역에도 똑같이 적용된다.

[정답] ⑤
[해설] 불법영역에 적용되지 않는다.

♣ 요점정리

1. 우리 헌법 제11조의 평등규정은 평등의 원리와 일반적 평등권을 동시에 규정한 것으로 이해되고 있다.

2. 평등규정은 모든 국가생활영역과 모든 기본권에 적용되고 보장되고 있다. 즉, 모든 국가생활영역과 모든 기본권은 평등의 원리를 토대로 하고 있다. 평등의 원리는 정의라는 객관적 원리의 표현이며, 우리 법질서의 기본명제라고 할 수 있다.

3. 법 앞에 평등은 자연인뿐만 아니라 법인과 법인격 없는 단체에게도 주체성이 인정된다는 데에 이견이 없다.

4. 법 앞에 평등에서 말하는 법은 국회의 의결을 거친 형식적 의미의 법률에 한하는 것이 아니라 실질적 의미의 법을 말한다. 따라서 제11조 제1항의 법은 성문법과 불문법은 물론 자연법까지도 포함한다.

5. 법적평등이 상대적 평등을 의미한다는 것은 개인의 연령·성별 또는 직업 기타 특별한 대인관계 등을 고려하여 정의·도덕·합목적성 등의 요청에 따라서 합리적으로 차별하는 것까지를 금

지하는 것은 아니다. 이러한 측면에서 볼 때, 정치적 영역에서는 절대적 평등, 사회적·경제적·문화적 영역에서는 상대적 평등이 더 강조될 수 있다.

6. 입법권자가 평등권을 침해했는지의 여부는 단순히 제정법률의 형식적 요건이나 내용은 물론 법률의 실질적인 내용을 기준으로 판단해야 한다.

제18강 평등권(3)

♣ 학습목표

차별금지사유를 설명할 수 있다.
차별금지영역을 설명할 수 있다.
평등규정의 효력을 설명할 수 있다.
우리 헌법의 평등원리 구현형태를 설명할 수 있다.
평등원칙의 제한을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

차별금지사유, 차별금지영역
평등규정의 효력
특권제도의 금지
영전일대의 원칙
평등규정의 제한

♣ 사전테스트

1. 평등규정의 적용에 관하여 헌법 제11조 제1항 제2문은 구체적으로 중요한 사항을 예시하고 있는 데, 예시되지 않은 사항은 차별이 가능하다.

   정답 : X
   해설 : 예시에서 빠진 사항이라고 차별해도 좋다는 의미는 아니다.

2. 남자에게만 병역의 의무를 지우는 것, 여성에게만 생리휴가를 주거나 특별히 근로보호를 하는 것은 합리적인 것으로 헌법상 허용된다.

   정답 : O

3. 형법상 신분(상습범, 누범, 업무상 범죄 등)으로 형이 가중되는 경우는 사회적 신분에 따른 차별이 아니다.

   정답 : O
   해설 : 헌법재판소 1995. 2. 23. 93헌바43.

♣ 돌발퀴즈

여성전용직종으로 보이는 전화교환원의 정년을 43세로 제한한 한국전기통신공사의 인사규정은 합리적인 사유가 있는 차별이다.

[정답] X

[해설] 근로기준법 제5조의 남녀차별금지규정에 해당하므로 무효이다(대법원 1988. 12. 27. 85다타657).

♣ 강의내용

1. 적용

⑴ 차별금지사유

평등규정의 적용에 관하여 헌법 제11조 제1항 제2문은 구체적으로 중요한 사항을 예시하고 있다. 그렇다고 예시에서 빠진 사항이라고 차별해도 좋다는 의미는 아니다. 규정에서 빠진 것 중에서 중요한 사항으로는 인습·정치적 신조·학력·출신지역 등이 있으며, 이를 이유로 한 차별은 용납될 수 없다.

1) 성별

성별을 차별금지사유로 삼아서는 안 된다는 것은 구체적으로 남녀평등을 선언한 것이다. 따라서 남녀의 성에 관한 가치판단에 의한 차별은 금지된다. 독일연방헌법재판소는 양성평등은 비록 어떤 규정이 이성적이고 객관적으로 근거지어진 것이라 하더라도 그것이 남성을 특히 우대하는 규정인 한 그러한 규정은 허용될 수 없다고 하였다.[295] 미연방대법원은 남성의 입학을 배제하는 주립간호대학의 입학정책은 평등의 원칙을 위반한 것이라 하였다.[296] 그러나 남녀의 생리·능력에 따른 차이에 따라 차별하는 것은 합리적인 것으로 인정된다. 예컨대, 남자에게만 병역의 의무를 지우는 것, 여성에게만 생리휴가를 주거나 특별히 근로보호를 하는 것은 합리적인 것으로 헌법상 허용된다.

<대법원 1988. 12. 27. 85다타657>

여성전용직종으로 보이는 전화교환원의 정년을 43세로 제한한 한국전기통신공사의 인사규정은 근로기준법 제5조의 남녀차별금지규정에 해당하므로 무효이다.

이러한 여성에 대한 불균형적 상황 또는 차별적 상황의 개선을 위한 여성우대정책은 온건하고, 간접적인 우대정책으로부터 직접적이고 강한 우대정책, 즉 '적극적 평등화조치'(affirmative action)라고 불리는 여성채용 할당제 등 여러 가지가 있을 수 있다.

첫째, 여성지원자의 풀을 확대하되 채용은 능력에 기초하는 방법으로 정부나 기업체는 자격있는 지원자를 가급적 많이 유치하도록 노력한다. 여성관련 신문, 잡지 등 매체에 많은 광고, 홍보물을 싣는다. 여성대학, 여성단체 등을 방문하여 설명회 등을 개최하여 지원자수를 많이 확보한 다음 실제 채용결정 시에는 여성을 남성과 동일한 기준에서 평가한다.

---

295) BVerfGE 15, 337(344).

296) Missisippi University for Women v. Hogan, 1982.

둘째, 동등하게 자격을 갖춘 남녀지원자 중에서 여성에게 우선적 고용의 기회를 부여하는 방법으로 최종채용예정자들 가운데 남녀가 동등한 자격을 갖춘 경우로 보일지라도 실제에 있어서는 각자가 여러 가지 면에서 독특한 장단점을 가질 수 있을 것으로 보여 비교에 어려움이 있겠지만 그러나 최종적 채용기준은 여성이라는 점에 우선순위를 두어야 한다는 것이다.

셋째, 자격이 미달된 여성지원자에게 우선적 고용의 기회를 부여하는 방법으로 적극적인 여성우대조치의 실천방법으로 개별적인 채용의 경우 남성보다 다소 자격이 미달된 경우라 할지라도 별도의 가산점을 부여하여 다소 자격이 상회하는 남성보다 우선적으로 채용을 하는 방법을 말한다.

넷째, 채용비율의 목표설정방법(채용목표제)으로 채용목표는 추구하려는 이상이기 때문에 반드시 절대적으로 달성할 것을 요구하지 않는다. 목표는 비율이나 숫자로 표시될 수가 있다. 예컨대, 정부투자기관이나 공기업은 일정한 비율 또는 숫자만큼 여성근로자를 채용하도록 노력하여야 한다는 목표를 정하고 그 구체적인 실천방법은 자율적인 방법에 따라 탄력적으로 운영한다.

다섯째, 채용비율의 확정 실시방법(채용비율제, 채용할당제, 쿼터제)으로 일정한 기간 내에 채용할 비율이나 숫자를 미리 확정하고 이를 강제적으로 실천하도록 요구하는 것이다. 정부나 기업의 채용 결정 시 여성지원자가 아무리 남성지원자보다 자격이 미달할지라도 주어진 기간 내에 일정 비율, 또는 숫자를 충원하여야 한다는 것이다.

이상의 여성우대정책방안은 순서대로 점차 강화된 방법인데 첫째와 둘째는 소극적 우대방법으로 비교적 논란의 여지가 크지 않겠지만 나머지는 그 순서대로 평등의 원리와 관련하여 논란의 소지가 크다고 할 수 있다.

2) 종교

종교를 차별금지사유로 삼아서는 안 된다는 것은 종교평등을 선언한 것이다. 특정종교의 신앙 또는 신앙의 유무에 의한 차별대우는 인권사에서 예나 지금이나 중대한 문제가 되고 있다. 따라서 종교의 차이에 따른 차별금지가 요청된다. 종교평등은 종교의 자유의 내용이 되기도 한다. 종교를 이유로 한 차별은 이른바 경향기업에서의 근무관계라든가 종교단체에서 운영하는 사립학교에서 문제가 되기도 한다.

3) 사회적 신분

사회적 신분은 출생에 의한 선천적 신분(예컨대, 귀화인, 전과자의 자손, 존·비속 관계[297] 등)뿐만 아니라 후천적으로 사회적 평가를 수반하면서 장기간 차지하고 있는 지위도 포함된다. 예컨대, 귀화인, 전과자, 공무원, 파산자, 노동자, 교원, 농민, 상인, 학생, 변호사[298] 등이 이에 해당한다. 그러나 형법상 신분(상습범, 누범, 업무상 범죄 등)으로 형이 가중되는 경우는 사회적 신분에 따른 차별이 아니다.

<헌법재판소 2002. 3. 28. 2000헌바53> 형법 제259조 제2항 위헌소원

비속의 직계존속에 대한 존경과 사랑은 봉건적 가족제도의 유산이라기보다는 우리 사회윤리의 본질적 구성부분을 이루고 있는 가치로서 특히, 유교적 사상을 기반으로 전통적 문화를 계

297) 배우자 및 직계 존·비속 사이의 부담부 증여에 대한 증여세 과세가액 산정에 있어 수증자가 부담할 채무액을 비공제하는 것은 증여 당사자의 특수한 신분관계가 있다는 이유로 차별한 것이므로 위헌이다 (헌법재판소 1992. 2. 25. 90헌가69).

298) 헌법재판소 1990. 9. 3. 89헌마120.

승·발전시켜 온 우리나라의 경우는 더욱 그러한 것이 현실인 이상 '비속'이라는 지위에 의한 가중처벌의 이유와 정도의 타당성 등에 비추어 차별적 취급에는 합리적 근거가 있다.

<헌법재판소 1995. 2. 23. 93헌바43> 형법 제35조 등 위헌소원

누범을 가중처벌하는 것은 전범에 대한 형벌의 경고적 기능을 무시하고 다시 범죄를 저질렀다는 점에서 비난 가능성이 많고, 누범이 증가하고 있다는 현실에서 사회방위, 범죄의 특별예방 및 일반예방이라는 형벌목적에 비추어 보아 형법 제35조가 누범에 대하여 형을 가중한다고 해서 그것이 인간의 존엄성 존중이라는 헌법의 이념에 반하는 것도 아니며, 누범을 가중하여 처벌하는 것은 사회방위, 범죄의 특별예방 및 일반예방, 더 나아가 사회의 질서유지의 목적을 달성하기 위한 수단이기도 하는 것이므로 이는 합리적 근거 있는 차별이다.

⑵ 차별금지영역

헌법 제11조 제1항 제2문은 차별금지영역으로서 정치적·경제적·사회적·문화적 모든 영역을 규정하고 있다.

정치적 영역에서 차별금지는 참정권의 차별금지(선거권, 피선거권, 공무담임권,[299] 국민투표권[300] 등)를 의미한다.

경제적 영역에서 차별금지는 조세의 부담,[301] 재산의 수용, 기타 고용·임금과 같은 국민의 경제활동에서 차별되지 아니한다는 것을 의미한다.

사회적 영역에서 차별금지는 거주, 이전, 공공시설의 이용 및 혼인과 가정생활 등의 영역에 있어서의 차별금지를 의미한다.[302]

문화적 영역에서 차별금지는 교육을 받을 권리, 학문, 예술, 기타 문화활동 등의 영역에서의 차별금지를 의미한다. 다만, 헌법 제34조 제1항의 규정에 따라 교육에 있어서 능력에 의한 차별은 허용된다.

<헌법재판소 1999. 11. 25. 98헌마55> 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 부칙 제12조

조세평등주의가 요구하는 담세능력에 따른 과세의 원칙(또는 응능부담의 원칙)은 한편으로 동일한 소득은 원칙적으로 동일하게 과세될 것을 요청하며(이른바 '수평적 조세정의'), 다른 한편으로 소득이 다른 사람들 간의 공평한 조세부담의 배분을 요청한다(이른바 '수직적 조세정의').

<헌법재판소 1990. 6. 25. 89헌마107> 토지수용법 제46조 제2항

기준시가에 의한 보상규정은 기준시가 고시지역의 토지소유자와 고시하지 않은 지역의 토지소유자를 차별하는 것은 합리적 이유가 있는 차별이다.

<헌법재판소 1993. 7. 29. 89헌마31> 공권력의 행사로 인한 재산권 침해

국제그룹해체를 위한 공권력의 행사는 법률상 무권한의 자의적인 공권력의 행사였으므로 평등원칙의 파생원칙인 자의금지원칙에 위반된다.

---

299) 헌법재판소 1999. 12. 23. 98헌바33.

300) 투표가치가 평균인구수 편차 33.3% 심사기준(헌법재판소 2001. 10. 25. 2000헌마92).

301) 무소속후보자의 기탁금을 1 : 2로 한 것과 정당후보자에게 정당연설회를 허용하고 2종의 소형인쇄물을 더 배부할 수 있도록 한 것은 평등권에 위반(헌법재판소 1992. 3. 13. 92헌마37·39)된다.

302) 가난한 자의 상소비용 면제거부(Griffin v. Illinois , 1956)와 빈곤으로 인해 변호인을 선임하지 못해 변호인의 변론을 듣지 못한 채 결정되는 것(Douglas v. California, 1963)은 위헌이라는 미연방헌법재판소의 판례가 있다.

<헌법재판소 1989. 5. 24. 89헌가37> 금융기관의 연체대출금에 관한 특별조치법 제5조의2

금융기관인 은행에게는 아무런 제한조건 없이 항고를 허락하면서, 금융기관으로부터 돈을 빌린 자(채무자)에게는 상당금액의 공탁을 명하고 있는 것은 합리적 이유 없이 은행을 우대한 것이다.

<헌법재판소 1989. 1. 25. 88헌가7> 소송촉진 등에 관한 특례법 제6조

국가를 상대로 한 재산권의 청구에 관하여는 가집행선고를 할 수 없다는 규정은 합리적 근거 없이 헌법 제11조의 평등의 원칙을 위배한 것이다.

<헌법재판소 1989. 7. 21. 89헌마38 등> 상속세법 제32조의2

조세평등주의는 헌법 제11조 제1항에 의한 평등의 원칙 또는 차별금지의 원칙의 조세법적 표현이라고 할 수 있다. 따라서 국가는 조세입법을 함에 있어서 조세의 부담이 공평하게 국민들 사이에 배분되도록 법을 제정하여야 할 뿐 아니라 조세법의 해석·적용에 있어서도 모든 국민을 평등하게 취급하여야 할 의무를 진다. 이러한 조세평등주의 이념을 실현하기 위한 법제도의 하나가 바로 국세기본법 제14조에 규정된 실질과세의 원칙이라고 할 수 있다. 또한 이러한 조세평등주의는 정의의 이념에 따라 평등한 것은 평등하게 그리고 불평등한 것은 불평등하게 취급함으로써 조세법의 입법과정이나 집행과정에서 조세정의를 실현하려는 원칙이다.

<헌법재판소 1989. 11. 20. 89헌가102> 변호사법 제10조 제2항

변호사법 제10조는 재직기간에 따른 차별이다.

<헌법재판소 1997. 7. 16. 95헌가6 등> 민법 제807조 제1항

헌법 제36조 제1항은 혼인과 가족생활은 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 성립되고 유지되어야 하며, 국가는 이를 보장한다고 규정하고 있는바, 이는 혼인제도와 가족제도에 관한 헌법원리를 규정한 것으로서 혼인제도와 가족제도는 인간의 존엄성 존중과 민주주의원리에 따라 규정되어야 함을 천명한 것이라 할 수 있다. 따라서 혼인에 있어서도 개인의 존엄과 양성의 본질적 평등의 바탕 위에서 모든 국민은 스스로 혼인을 할 것인가 하지 않을 것인가를 결정할 수 있고 혼인을 함에 있어서도 그 시기는 물론 상대방을 자유로이 선택할 수 있는 것이며, 이러한 결정에 따라 혼인과 가족생활을 유지할 수 있고, 국가는 이를 보장해야 하는 것이다.

<헌법재판소 1990. 10. 8. 89헌마89> 교육공무원법 제11조 제1항

교육공무원법 제11조 제1항은 교사신규채용시 국·공립교육대학 및 사범대학졸업자에게 우선권을 주고 있으므로 위헌이다.

<헌법재판소 1991. 2. 11. 90헌가27> 교육법 제8조의2

중학교 의무교육을 대통령령이 정하는 바에 따라 순차적으로 실시하도록 규정한 교육법 제8조의2는 중학교 의무무상교육을 전면적으로 실시할 때에 따르는 국가의 재정적 부담을 고려한 것이라는 점에서 합리적 근거를 찾을 수 있다.

<헌법재판소 1992. 10. 1. 92헌마68 등> 1994년 서울대학교 신입생선발입시안

서울대학교가 1994년도 신입생선발입시안에서 제2외국어 선택과목 중 일본어를 제외시킨 대신에 모든 고등학교에서 가르치고 있는 한문을 선택과목으로 채택하였을 뿐만 아니라 1994학년도 입학고사요강을 적어도 2년간의 준비기간을 두고 발표하였기 때문에 일본어를 배우고 있는 1·2학년 학생들로 하여금 2·3년 후에 서울대입학시험을 치르는 데 있어서 그다지 지장이 없도

록 배려하고 있으므로 일본어를 입시과목에서 배제하였다고 해서 그것이 교육의 기회균등을 침해한 것은 아니다.

<헌법재판소 1991. 7. 22. 89헌가106> 사립학교법 제55조, 제58조 제1항 제4호
교원의 지위에 관한 규정은 국민적 합의를 배경으로 한 입법기관의 권한에 위임하고 있는 헌법조항에 따라 규정된 것으로서 사립학교교원은 근로3권의 행사에 있어서 일반근로자의 경우와 달리 취급하여야 할 합리적 이유가 있다.

2. 효력

대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력이 인정된다.

<헌법재판소 1989. 7. 14. 89헌마10> 검사의 공소권행사
범죄의 피해자인 고소인은 헌법 제11조 제1항에서 보장된 모든 국민은 평등권에 의하여 국가기관인 검사에 대하여 차별 없는 성실한 직무수행을 요구할 권리와 헌법 제27조 제5항에서 보장된 재판절차진술권이 있으므로, 검사가 어느 고소사건의 수사를 현저히 소홀이 하는 등 잘못 다룬 끝에 불기소 처분하였다면, 이는 검사가 검찰권의 행사에 있어 고소인을 차별대우하여 평등권을 침해하고, 재판절차진술권을 침해한 것이다.

3. 구현형태

⑴ 특권제도의 금지

1) 의미

헌법 제11조 제2항은 사회적 특수계급의 제도는 인정되지 아니하며, 어떠한 형태로도 이를 창설할 수 없다고 하여 특수계급제를 부인하고 있다. 이는 고래의 반상(班常)계급제도를 타파하기 위한 것이다. 그러나 영전에 따르는 연금 등의 보훈제도나 전직 대통령에 대한 예우는 사회적 특수계급제도에 해당하지 않는다.

2) 영전일대의 원칙

헌법 제11조 제3항은 훈장 등의 영전은 이를 받은 자에게만 효력이 있고, 어떠한 특권도 이에 따르지 아니한다고 하여 영전일대의 원칙을 규정하고 있다. 이는 영전의 세습 등을 방지하여 그로 말미암은 특권을 부인하려는 것이다. 따라서 국가유공자의 자손에게 공무원 특별승진을 하게 하거나 처벌을 면제하거나 조세를 감면하는 것은 위헌이 된다. 그러나 훈장에 수반되는 연금이나 유족에 대한 보훈까지 금지하는 것은 아니다. 공무원이 외국정부로부터 영전을 받을 경우에는 대통령의 허가를 얻어야 한다(국가공무원법 제62조).

<헌법재판소 1997. 6. 26. 94헌마52> 국가유공자예우 등에 관한 법률 시행령 제23조
우리 헌법 제11조 제3항은 훈장 등의 영전은 이를 받은 자에게만 효력이 있고 어떠한 특권도 이에 따르지 아니한다고 규정하고 있는바, 이를 같은 조 제1항 및 제2항의 규정과 관련하여

풀이하면 이는 이른바 영전일대의 원칙을 천명한 것으로서 영전의 세습을 금지함으로써 특수계급의 발생을 예방하여는 것이라 볼 수 있다. 따라서 이 법에 의한 독립유공자나 그 유족에게 국가보은적 견지에서 서훈의 등급에 따라 부가연금을 차등지급하는 것은 위헌이 아니다.

⑵ 개별적 평등규정

우리 헌법은 제34조 제1항에서 능력에 따른 교육의 기회균등, 제32조 제4항에서 근로관계에서 여성에 대한 차별금지, 제36조 제1항에서 혼인과 가족생활에서 양성의 평등, 제41조 제1항과 제67조 제1항에서 평등선거의 원칙과 제116조 제1항에서 선거운동의 기회균등보장, 제119조 제2항과 123조 제2항에서 경제적 복지의 평등을 규정하고 있다. 이외에도 헌법전문에서 모든 영역에서 각인의 기회균등을 선언하고 있다.

4. 제한

⑴ 헌법규정에 의한 제한

헌법 스스로가 '법 앞의 평등'에 대한 예외를 규정하거나 개별평등권을 제한한 경우로는 제8조 제3항과 제4항의 정당의 특권, 제84조의 대통령의 형사상 특권, 제44조와 제45조의 국회의원의 불체포특권과 면책특권, 제33조 제2항과 제3항의 공무원과 방위산업체 근로자의 근로3권의 제한, 제29조 제2항의 군인·군무원의 국가배상청구권의 제한, 제27조 제2항의 군사법원에 의한 재판, 제86조 제3항과 제87조 제4항의 현역군인의 문관임용제한, 제32조 제6항의 국가유공자의 우선취업기회보장 등이 있다.

<헌법재판소 1992. 4. 28. 90헌바27> 국가공무원법 제66조

국가공무원법 제66조 제1항이 사실상 노무에 종사하는 공무원에 대해서만 근로3권을 보장하고 그 이외의 공무원에 대하여는 근로3권의 행사를 제한함으로써 일반근로자 또는 사실상 노무에 종사하는 공무원의 경우와 달리 취급하는 것은 헌법 제33조 제2항에 근거를 두고 있을 뿐 아니라 합리적인 이유가 있다.

<헌법재판소 1994. 6. 30. 91헌마161> 국가유공자예우 등에 관한 법률 제4조 등

국가유공자예우 등에 관한 법률 제4조 제1항 제12호 소정의 국가유공자인 공상공무원에 국·공립학교교원만을 포함시키고 사립학교교원을 포함시키지 아니한 것은 보훈대상의 범위·내용 등에 관한 입법자의 입법형성의 자유에 속하는 입법정책문제로서 합리적인 근거와 이유 있는 차별이다.

⑵ 법률규정에 의한 제한

평등규정의 제한과 관련하여 제37조 제2항에 의한 제한은 평등의 원칙에 대한 법률상의 제한이라는 견해와[303] 형식논리적으로는 평등권도 기본권인 만큼 다른 기본권과 마찬가지로 헌법 제37조 제2항에 의하여 법률로써 제한할 수 있으나 평등권은 기본권 실현의 방법적 기초로서의 성격과 기능을 가지므로 제한의 의미와 효과가 다른 기본권과 다르다는 견해가[304] 있다.

---

303) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 380면 참조.
304) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 332~333면 참조.

우리 헌법 제11조에 규정된 '법 앞의 평등'은 평등의 원리와 평등권을 규정하고 있는 것이므로 헌법 제37조의 규정에 의하여 제한되는 것은 평등의 원리가 아니라 평등의 원리가 구체화·세분화된 개별적인 평등권이다. 또한, 평등의 원리는 법률유보의 적용을 받지 않는다.[305] 즉, 법률에 의하여 불평등을 규정하는 것은 그 자체가 이미 평등의 원리의 위배를 의미하기 때문이다.[306]

개별적 평등권이 제한되는 경우로는 공무원법에 규정된 공무원의 정당가입금지, 정치활동제한, 주거지제한이 있고, 군사관계법에 규정된 군인·군무원의 영내거주, 정치활동제한이 있으며, 행형법에 규정된 재소자에 대한 서신검열·교화 등 통신과 신체의 자유에 대한 제한이 있으며, 국가공무원법과 공직선거법 등에 규정된 일정범위의 전과자에 대한 공무담임권제한이 있으며, 출입국관리법에 의한 외국인의 체류와 출국의 제한이 있으며, 교육법에 규정된 피교육자에 대한 평등권제한 등이 있다.

⑶ 긴급명령 등에 의한 제한

평등의 원칙에 대하여 법률유보의 적용이 배제되기 때문에 계엄 또는 비상조치와 같은 국가긴급권이 행사되는 경우에도 평등의 원리만은 그 효력이 정지되지 않는다. 그것은 이러한 경우에도 계엄령에 의한 포고나 비상조치와 같은 조치는 언제나 평등의 원리와 양립될 수 있기 때문이다.[307]

따라서 긴급명령 등에 의하여 제한될 수 있는 것은 헌법 제11조의 평등의 원리가 아니라 평등의 원리가 구체화·세분화된 개별 평등권에 한정된다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 성별에 의한 차별이 아닌 것은?

① 직업자격의 차별
② 사실적·생리적 차별
③ 동성동본금혼
④ 초등학교에서의 남자교사 임용할당제
⑤ 여성근로자에 대한 적극적 보호

[정답] ⑤
[해설] 헌법 제32조 제4항, 근로기준법, 남녀고용평등법 등에서 인정하고 있다.

2. 다음 중 평등원칙에 반하는 것은?

① 소년에 대한 부정기형 선고
② 전과자의 피선거권 제한
③ 전직 대통령의 증언거부특권
④ 정당에 대한 국고보조금의 비례지급
⑤ 여성전화교환원 정년의 43세 제한

---

305) 홍성방, 전게서, 70면.
306) 한태연, 「헌법학」, 법문사, 1985, 918면 참조.
307) 한태연, 전게서, 918면 참조.

[정답] ⑤
[해설] 평등원칙과 관련이 없다.

3. 평등의 원칙과 평등권에 대한 헌법상 제한이 아닌 것은?
① 외국인의 토지 및 주식에 대한 소유제한
② 법관의 징계에 의한 파면금지
③ 대통령의 형사상 특권
④ 주요방위산업체 근로자의 단체행동권 제한
⑤ 군인 등의 국가배상청구권 제한

[정답] ①
[해설] 외국인토지법 등에 의한 제한으로 개별법상의 제한이지 헌법상 제한이 아니다.

♣ 요점정리

1. 평등규정의 적용에 관하여 헌법 제11조 제1항 제2문은 구체적으로 중요한 사항을 예시하고 있다. 규정에서 빠진 것 중에서 중요한 사항으로는 인습·정치적 신조·학력·출신지역 등이 있으며, 이를 이유로 한 차별은 용납될 수 없다.

2. 남자에게만 병역의 의무를 지우는 것, 여성에게만 생리휴가를 주거나 특별히 근로보호를 하는 것은 합리적인 것으로 헌법상 허용된다.

3. 형법상 신분(상습범, 누범, 업무상 범죄 등)으로 형이 가중되는 경우는 사회적 신분에 따른 차별이 아니다.

4. 문화적 영역에서 차별금지는 교육을 받을 권리, 학문, 예술, 기타 문화활동 등의 영역에서의 차별금지를 의미한다. 다만, 헌법 제34조 제1항의 규정에 따라 교육에 있어서 능력에 의한 차별은 허용된다.

5. 영전에 따르는 연금 등의 보훈제도나 전직 대통령에 대한 예우는 사회적 특수계급제도에 해당하지 않는다.

6. 긴급명령 등에 의하여 제한될 수 있는 것은 헌법 제11조의 평등의 원리가 아니라 평등의 원리가 구체화·세분화된 개별 평등권에 한정된다.

제19강 신체의 자유(1)

♣ 학습목표

영국의 역사적 전개를 설명할 수 있다.
미국의 수정헌법을 설명할 수 있다.
프랑스 인권선언을 설명할 수 있다.
우리나라의 역사적 전개를 설명할 수 있다.
신체의 자유의 의의를 설명할 수 있다.
신체의 자유의 법적성격을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

마그나카르타, 권리청원, 권리장전, 인신보호법
미국수정헌법
프랑스 인권선언
우리 헌법의 역사적 전개

♣ 사전테스트

1. 신체의 자유보장은 1215년 영국의 대헌장에서 최초로 보장되었다.
정답 : O
해설 : 대헌장 제36조, 제39조 및 제54조 등에서 신체의 자유를 규정하였다.

2. 미국의 수정헌법 제14조 제1항은 적법절차를 규정하고 있다.
정답 : O
해설 : 어떠한 주도 적법절차(due process of law)에 의하지 아니하고는 어떠한 사람으로부터도 생명, 자유 또는 재산을 박탈할 수 없다고 규정하고 있다.

3. 프랑스 인권선언 제8조는 죄형법정주의를 선언하고 있다.
정답 : O
해설 : 법은 엄격히, 그리고 명백히 필요한 형벌만을 설정해야 하고, 누구도 범죄 이전에 제정·공포되고, 또 합법적으로 적용된 법률에 의하지 아니하고는 처벌될 수 없다고 규정하였다.

♣ 돌발퀴즈

1972년 유신헌법에서 인신의 자유보장은 크게 후퇴하였다.
[정답] O
[해설] 1972년 유신헌법에서는 구속적부심사제의 폐지, 긴급구속요건의 완화, 임의성 없는 자백의 증거능력부정조항의 삭제 등 인신의 자유보장이 크게 후퇴하였다.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

⑴ 연혁

1) 영국

인신의 자유 내지 신체의 자유는 '기본권 보장의 원형'이라고 불리는 1215년 대헌장(Magna Carta)에서 최초로 보장되었다고 보는 것이 일반적이다. 대헌장은 제36조, 제39조 및 제54조 등에서 신체의 자유를 규정하고 있다.

이 후, 1628년 권리청원(Petition of Right) 제3항과 제4항에서는 대헌장과 종래의 법률에서 보장되었던 인신의 자유를 재확인하고, 특히 제5항에서는 인신보호영장(Writ of Habeas Corpus)제도가 규정되었다.

또한, 1679년 인신보호법(Habeas Corpus Act)에서는 권리청원에 규정된 정당한 인신보호영장의 효력이 어떤 방법에 의해 파훼되는가를 실제적으로 규명하여 인신보호영장제도가 실효적으로 보장되기 위한 상세한 방법을 규범화하였다.

그리고 1689년의 권리장전(Bill of Rights)에 이르러 인신의 자유보장은 완성되었다. 이러한 영국에서의 인신보장은 이후 많은 나라에 영향을 주었고 현재는 신체의 자유를 보장하지 않는 헌법은 거의 찾아볼 수 없다.

영국에서는 '국가권력으로부터의 시민의 자유와 권리보호'를 위해 강력한 당사자주의와 배심재판을 통한 시민의 사법통제 등을 구체적인 실천원리로 삼아왔다. 또한, 법과 원칙(law and order)을 중시하는 범죄억제정책을 강력하게 추진하였으며, 경찰의 권한과 재량이 크게 확대되는 등 미국에 비해 효율성 우위의 형사절차가 발달하였다. 이러한 경향은 수사상 체포제도에서도 나타나는데, 체포가능범죄에 대한 구분을 없애고 '합리적 의심'이 있는 경우 폭넓은 체포를 허용하고 있다는 점에 특색이 있다.[308]

2) 미국

영국에서의 인신의 자유보장에 관한 사상은 미국에 수용되어 1776년 버지니아권리장전(Virginia Bill Of Rights), 1787년 미합중국헌법과 그 후의 수정헌법에 영향을 주었다. 수정헌법 제4조는 불합리한 압수와 수색에 대하여 신체, 주거, 서류, 물건의 안전을 확보할 국민의 권리는 침해되어서는 아니 된다. 선서나 확약에 의하여 상당하다고 인정되는 이유가 있어 특별히 수색할 장소와 압수할 물건, 체포·구속할 사람을 특정한 경우를 제외하고는 영장은 발부되어서는 아니 된다고 규정하였다.

수정헌법 제5조(형사 사건에서의 권리)는 누구라도, 대배심에 의한 고발 또는 기소가 있지 아니하는 한 사형에 해당하는 죄 또는 파렴치죄에 관하여 심리를 받지 아니한다. 다만, 육군이나 해군에서 또는 전시나 사변 시 복무 중에 있는 민병대에서 발생한 사건에 관해서는 예외로 한다. 누구라도 동일한 범행으로 생명이나 신체에 대한 위협을 재차 받지 아니하며, 누구라도 정당한 법의 절차에 의하지 아니하고는 생명, 자유 또는 재산을 박탈당하지 아니한다. 또한 정당한 보상 없이, 사유 재산이 공공용으로 수용당하지 아니한다고 규정하였다.

---

308) 중대조직범죄 및 경찰에 관한 법 110조. 다만, 범죄에의 가담 또는 가담하려고 한 의심이 있는 경우와 체포할 필요성에 대한 합리적 근거가 요청된다.

수정헌법 제14조 제1항은 합중국에서 출생하거나 귀화하여 합중국의 통치권에 복종하는 모든 사람은 합중국 및 그 거주하는 주의 시민이다. 어떤 주도 합중국 시민의 특권과 면책권을 박탈하는 법률을 제정하거나 실시할 수 없다. 어떠한 주도 적법절차(due process of law)에 의하지 아니하고는 어떠한 사람으로부터도 생명, 자유 또는 재산을 박탈할 수 없으며, 그 통치권 내에 있는 어떠한 사람에 대하여도 법률에 의한 평등한 보호를 거부하지 못한다고 규정하였다.

미국에서의 인신의 자유는 적법절차가 핵심이다. 미국은 국가권력에 대한 강한 불신과 수사·재판절차에 투영된 인종간의 편향 및 불평등을 시정하는 과정에서 독특한 '헌법적 형사소송론' 전개를 통해 절차적 정의(procedural justice)를 추구하면서도 공공장소에서의 영장 없는 광범위한 체포를 허용하고 있고, 주거에서의 체포는[309] 영장주의를 엄격하게 적용하고 있다.[310] 또한, 영장 없이도 경미범죄의 체포를 폭넓게 허용하고 있지만 경찰의 수사 및 재판단계에서 다양한 보석을 허용함으로써 수사단계에서의 장기간 구금을 방지하고 있다는 점이 특색이다.

3) 프랑스

1789년 프랑스 인권선언은 제7조에서 누구도 법에 의해 규정된 경우, 그리고 법이 정하는 형식에 의하지 아니하고는 소추, 체포 또는 구금될 수 없다. 자의적 명령을 간청하거나 발령·집행하거나 또는 집행시키는 자는 처벌된다. 그러나 법에 의해 소환되거나 체포된 시민은 모두 즉각 순응해야 한다. 이에 저항하는 자는 범죄자가 된다고 규정하였다.

제8조는 법은 엄격히, 그리고 명백히 필요한 형벌만을 설정해야 하고, 누구도 범죄 이전에 제정·공포되고, 또 합법적으로 적용된 법률에 의하지 아니하고는 처벌될 수 없다고 규정하였다.

제9조는 모든 사람은 범죄자로 선고되기까지는 무죄로 추정되는 것이므로, 체포할 수밖에 없다고 판정되더라도 신병을 확보하는 데 불가결하지 않은 모든 강제조치는 법에 의해 준엄하게 제압된다고 규정하였다.

프랑스 인권선언은 죄형법정주의, 무죄추정의 원칙, 강제처분의 합비례성의 원칙이 핵심이다.

4) 우리나라

1948년 건국헌법은 제9조에서 협의의 신체의 자유, 영장주의와 예외, 변호인의뢰권, 구속적부심사권을 규정하였다.

1962년 제3공화국 헌법에서는 인신의 자유보장에 관한 규정이 추가되었다. 제10조 제1항에서 죄형법정주의를 선언하였고, 제2항에서 고문금지와 묵비권, 제3항에서 영장주의와 예외, 제4항에서 변호인의뢰권과 국선변호인제도, 제5항에서 구속적부심사청구권, 제6항에서 자백의 증거능력의 부정을 규정하였다. 제11조에서는 형벌법규불소급과 일사부재리의 규정하였다.

1972년 유신헌법에서는 구속적부심사제의 폐지, 긴급구속요건의 완화, 임의성 없는 자백의 증거능력부정조항의 삭제 등 인신의 자유보장이 크게 후퇴하였다.

---

309) 예컨대 경미범죄, 음주운전 등이 의심되는 자가 자택으로 들어간다고 하더라도 증거인멸의 방지를 위한 목적으로 영장 없이 주거에 진입하는 것은 허용되지 않는다. 다만, 피해자의 신고에 의한 경우, 용의자가 자택에 거주하고 있고, 영장 없는 체포를 허용할 만한 긴급한 사유가 있는 경우에 한해 영장 없이 체포할 수 없다.

310) 법원에서 영장이 발부되기 위해서는 '상당한 이유'가 요청되는데, 이는 수사관이 알고 있는 사실과 상황을 종합한 정보가 합리적인 사람의 판단에서 범죄가 일어났거나 적어도 일어나고 있다고 합리적으로 믿을 만한 경우에 인정되는 것이므로 '단순한 의심'의 정도로는 상당한 이유가 인정되지 않는다.

1980년 헌법에서 제11조 제1항은 죄형법정주의와 적법절차를 선언하였고, 제2항에서 고문금지와 묵비권, 제3항에서 영장주의와 예외, 제4항에서 변호인의뢰권과 국선변호인제도, 제5항에서 구속적부심사제도, 제6항에서 자백의 증거능력·증명력의 제한·부정을 규정하였다. 제12조는 제1항에서 형벌불소급과 일사부재리원칙, 제2항에서 소급입법금지, 제3항에서 연좌제금지를 규정하였다. 제26조는 재판청구권, 제27조는 형사보상청구권을 규정하였다.

현행 헌법의 내용에 대하여는 항을 달리하여 살펴보고자 한다.

⑵ 헌법규정

우리 헌법은 제12조 제1항 제1문에서 모든 국민은 신체의 자유를 가진다고 하여 신체의 자유를 규정하고 있다. 그리고 신체의 자유를 철저히 보장하기 위하여 제12조 제1항 제2문에서부터 제7항에 걸쳐 죄형법정주의(법률유보)와 적법절차의 원리(제1항 제2문), 고문·불리한 진술강요금지(제2항), 사전영장제도(제3항), 변호인의 조력을 받을 권리(제4항), 체포·구속의 이유고지 및 변호인의 조력을 받을 권리의 고지(제5항), 구속적부심사제도(제6항), 자백의 증거능력제한(제7항) 등을 규정하고 있다.

더 나아가서 우리 헌법은 제13조에서 형벌불소급의 원칙과 일사부재리의 원칙(제1항) 및 연좌제의 금지(제3항)를 규정하고 있으며, 재판을 받을 권리와 형사피고인의 무죄추정권(제27조 제1항, 제4항) 그리고 형사보상청구권(제28조)도 보장하고 있다.

2. 의의

신체의 자유란 좁은 의미에서는 법률에 의하지 아니하고는 신체적 행동의 자유를 제한받지 않는 자유, 즉 자의에 의한 체포나 형사소추에 의하여 신체적 구속을 받지 아니하는 것을 내용으로 하는 자유이다. 그러나 이 자유는 생물학적·신체적 의미의 건강과 정신적·영혼적 의미의 건강이라는 의미에서 신체안전의 자유를[311] 포함하는 것으로 넓게 이해된다.[312]

달리 표현하자면 신체안전의 자유는 '신체의 완전성'(die körperliche Integrität)을 훼손당하지 않을 자유로 표현할 수 있으며, 불임으로부터의 자유, 고통으로부터의 자유, 신체의 일부분에 대한 훼손으로부터의 자유, 신체적 건강에 대한 침해로부터의 자유를 포함한다.[313]

---

311) 권영성 교수는 신체를 훼손당하지 아니할 권리를 의미하기 때문에 보건에 관하여 국가의 보호를 받을 권리(제36조 3항)에 우선한다고 한다(권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 392면). 그러나 신체안전의 자유는 일차적으로 소극적으로 신체의 안전성을 침해당하지 않을 권리로 방어권적 기본권이며(자유권), 헌법 제36조 3항의 보건권은 국가에 대하여 건강을 증진시킬 수 있는 여러 가지 조치를 요구하는 적극적 급부청구권(사회권)이다. 그러한 한에서 이 두 기본권 사이에 선후문제는 생기지 않는다고 한다(홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 76면).

312) 다수설은 신체의 자유에는 생명권이 포함된다고 한다(한동섭, 「헌법」, 1971, 127면; 문홍주, 「제6공화국 한국헌법」, 해암사, 1988, 242면; 권영성, 전게서 386면 이하; 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 334면). 그러나 생명권은 인간의 존엄에 전제되는 것이므로 인간의 존엄으로부터 추론하는 것이 합리적일 것이다(홍성방, 전게서, 76면).

313) 독일연방헌법재판소는 기본법 제2조 1항 1문(생명권과 신체를 훼손당하지 않을 권리)에는 고통으로부터의 보호가 포함된다고 한다(BVerfGE 56, 54, 75). 그밖에도 독일에서는 인간실험, 강제거세수술, 강제불임시술, 강제접종과 혈중알콜농도를 검사하기 위한 혈액채취, 행형절차에서의 두발과 수염의 형태변경 등을 신체를 훼손당하지 않을 권리를 침해하는 것으로 보고 있다. 이러한 기준에 비추어 볼 때 행형법 제23조의 수형자의 두발과 수염은 짧게 깎는다는 규정은 위헌의 소지가 있다 하겠다. 그러나 군대에서 머리를 짧게 깎는 것은 신체를 훼손당하지 않을 권리로 보호되지 않는다고 하였다. 또한 신체안전의 자유로부터 체벌을 받지 않을 권리가 학생이나 미성년자에게 보장된다. 따라서 학교에서의 체벌과

헌법재판소도 신체의 자유는 신체의 안전성과 신체활동의 임의성·자율성을 내용으로 보고 한다.

<헌법재판소 1992. 4. 14. 90헌마82>
신체의 자유는 정신적 자유와 더불어 인간존엄과 가치를 구현하기 위한 가장 중요한 기본권적 자유로서 모든 기본권보장의 전제조건이다.

<헌법재판소 1992. 12. 24. 92헌가 8> 형사소송법 제331조 단서규정에 대한 위헌심판
헌법 제12조 1항 전문에서 '모든 국민은 신체의 자유를 가진다'고 규정하여 신체의 자유를 보장하고 있는 것은, 신체의 안전성이 외부로부터의 물리적인 힘이나 정신적인 위협으로부터 침해당하지 않을 자유와 신체활동을 임의적이고 자율적으로 할 수 있는 자유를 말하는 것이다.

우리 헌법이 개별기본권의 맨 앞에서 신체의 자유에 대하여 자세하게 규정하고 있는 것은 신체의 자유가 모든 기본권의 원형이자, 모든 자유의 근원이며, 최소한의 자유이기 때문이다. 신체의 자유가 존재하지 않는 경우, 인간은 끊임없이 위협에 직면하게 된다. 즉, 자의에 의하여 체포되거나 형사소추를 당하지 않을 권리가 보장되지 않는 경우, 그 내용이 정신적인 것이든, 정치적인 것이든 또는 종교적인 것이든 일체의 의사표시나 행동에는 개인적 자유의 상실이라는 값비싼 대가가 뒤따르게 된다. 그렇게 되면 인간은 공포 때문에 입을 다물게 되며, 그 결과 인간의 존엄은 상처를 입게 된다.[314]

3. 법적성격

권영성 교수에 의하면, 신체의 자유는 인간으로서 당연히 누리는 천부적·초국가적 자연권이고, 국가적 안전·질서유지를 위하여 불가피한 경우 최소한의 범위 안에서 제한이 가능한 상대적 자연권이며, 국가에 대한 개인의 소극적·방어적 공권이며, 인간의 권리이므로 외국인도 그 주체가 된다.[315]

이러한 자유권은 국가권력의 침해로부터 개인의 자유영역을 보호하는 데 그 목표가 있었다. 따라서 자유권은 일차적으로 방어권으로서 기능한다. 자유권이 방어권으로 기능한다는 것은 국가의 소극적인 부작위를 요구할 수 있는 권리이지 적극적으로 국가의 작위를 요구할 수 있는 권리가 아니라는 의미이다.

또한, 자유권은 좁은 의미의 기본권, 즉 주관적 공권이며, 객관적인 가치질서로서의 성격도 가지고 있다(양면성).

나아가 헌법에 의한 자유권보장은 국가에 의한 자유권의 창설을 의미하는 것이 아니라 국가가 전국가적 자연권을 확인하고 선언한 것을 의미한다. 즉, 자연권성이 인정된다고 하겠다.

피보호 미성년자에 대한 보호자의 체벌은 그것이 구체적인 경우에 교육목적을 고려할 때 필요불가결의 경우에만 인정된다 할 것이다. 그 밖의 가정폭력은 어떠한 경우에도 신체의 자유를 침해하는 것이라 할 것이다(홍성방, 전게서, 76면).

314) M. Kriele, Einführung in die Staatslehre, 5. Aufl.(1994), S. 133.

315) 권영성, 전게서, 392면 이하 참조.

♣ 문제풀이

1. 다음 신체의 자유에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 법률과 적법절차에 의하지 아니하고는 신체의 완전성과 자율성을 제한·침해당하지 아니하는 자유이다.
② 형의 선고에 의하지 아니하고는 강제노역을 당하지 아니한다.
③ 연좌제의 금지는 1980년 헌법에서 신설되었다.
④ 헌법재판소는 신체의 자유는 신체활동의 안전성을 침해당하지 않을 자유와 신체활동의 임의적이고 자율적으로 할 수 있는 것으로 자유로 보고 있다.
⑤ 구속이유 등 고지제도는 현행 헌법에서 신설되었다.

[정답] ②
[해설] 헌법 제12조 제1항 법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는.

2. 다음 중 신체의 자유와 관련이 없는 것은?

① 마그나카르타
② 미국의 수정헌법
③ 프랑스 인권선언
④ 버지니아 권리장전
⑤ 아일랜드 헌법전문

[정답] ⑤
[해설] 아일랜드 헌법전문은 인간의 존엄성 보장과 관련된다.

3. 다음 자유권적 기본권의 본질에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 자유주의와 개인주의
② 전국가적 인간의 권리
③ 방어적·소극적 권리
④ 입법·행정·사법권을 구속하는 재판규범
⑤ 형성적 법률유보

[정답] ⑤
[해설] 자유권에서의 법률유보는 권리제한적 법률유보를 의미한다.

♣ 요점정리

1. 인신의 자유 내지 신체의 자유는 1215년 영국의 대헌장(Magna Carta)에서 최초로 보장되었다고 보는 것이 일반적이다.

2. 1689년 권리장전의 선포로 국왕이 법률을 무시하고, 자의로 행사하는 특권을 비롯해 의회의 동의 없이 법률의 효력을 완전히 정지시키거나 의회의 특별한 승인 없이 과세하거나 평화시에 상비군을 유지하는 행위가 제한되었다.

3. 미국수정헌법 제14조 제1항은 명시적으로 적법절차의 원칙을 규정하고 있다.

4. 프랑스 인권선언 제8조는 죄형법정주의를 선언하고 있다.

5. 1972년 유신헌법에서는 구속적부심사제의 폐지, 긴급구속요건의 완화, 임의성 없는 자백의 증거능력부정조항의 삭제 등 인신의 자유보장이 크게 후퇴하였다.

6. 자유권은 일차적으로 방어권으로서 국가의 소극적인 부작위를 요구할 수 있는 권리이다. 또한, 자유권은 좁은 의미의 기본권, 즉 주관적 공권이며, 객관적인 가치질서로서의 성격도 가지고 있으며(양면성)며, 자연권성도 가지고 있다.

제20강 신체의 자유(2)

♣ 학습목표

신체의 자유의 주체를 설명할 수 있다.
우리 헌법 제12조의 내용을 설명할 수 있다.
신체의 자유의 효력을 설명할 수 있다.
신체의 자유의 제한과 한계를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

외국인의 주체성
신체의 자유의 효력, 제한, 한계

♣ 사전테스트

1. 신체의 자유는 외국인에게도 주체성이 인정된다.

정답 : O
해설 : 신체의 자유, 주거의 자유, 변호인의 조력을 받을 권리, 재판청구권 등은 성질상 인간의 권리에 해당하여 외국인에게도 기본권 주체성이 인정된다(헌법재판소 2012. 8. 23. 2008헌마430).

2. 외국인에게도 주체성이 인정되는 일정한 기본권에 관하여 불법체류여부에 따라 그 인정 여부가 달라지는 것은 아니다.

정답 : O
해설 : 헌법재판소 2012. 8. 23. 2008헌마430.

3. 헌법 제12조 제1항 제2문은 법률에 의하지 않은 처벌·보안처분·강제노역으로부터의 신체의 자유를 보장하고 있다.

정답 : X
해설 : 법률과 적법한 절차에 의하지 않은 처벌·보안처분·강제노역으로부터의 신체의 자유를 보장하고 있다.

♣ 돌발퀴즈

피의자가 경찰수사단계에서 고문에 의한 자백을 하고, 그 임의성 없는 심리상태가 검사의 피의자 신문시까지 계속되었다고 인정되는 경우에는 피의자 신문시에 자백을 강요한 사실이 없었다 할지라도 검찰자백의 임의성은 부정된다.

[정답] O
[해설] 대법원 1992. 11. 24. 92 도 2409.

♣ 강의내용

1. 주체

신체의 자유는 인간의 권리이므로 자연인(외국인 포함)에 한정되어 주체성이 인정된다. 따라서 신체의 자유나 양심의 자유와 같이 성질상 법인이 누릴 수 없는 권리에 대해서는 법인의 기본권의 주체성은 인정될 수 없다.

<헌법재판소 2001. 11. 29. 99헌마494>
헌법재판소법 제68조 제1항 소정의 헌법소원은 기본권의 주체이어야만 청구할 수 있는데, 단순히 '국민의 권리'가 아니라 '인간의 권리'로 볼 수 있는 기본권에 대해서는 외국인도 기본권의 주체가 될 수 있다.

<헌법재판소 2012. 8. 23. 2008헌마430>
청구인들이 불법체류 중인 외국인들이라 하더라도, 불법체류라는 것은 관련 법령에 의하여 체류자격이 인정되지 않는다는 것일 뿐이므로, '인간의 권리'로서 외국인에게도 주체성이 인정되는 일정한 기본권에 관하여 불법체류여부에 따라 그 인정여부가 달라지는 것은 아니다. 청구인들이 침해받았다고 주장하고 있는 신체의 자유, 주거의 자유, 변호인의 조력을 받을 권리, 재판청구권 등은 성질상 인간의 권리에 해당한다고 볼 수 있으므로, 위 기본권들에 관하여는 청구인들의 기본권 주체성이 인정된다.

2. 내용

우리 헌법 제12조 제1항 제2문은 신체적 행동의 자유의 내용으로서 불법적인 체포·구속·압수·수색·심문·처벌·보안처분·강제노역의 금지를 예시하고 있다. 이는 헌법상의 문언에 따라 법률에 의하지 않은 체포·구속·압수·수색·심문으로부터의 신체의 자유와[316] 법률과 적법한 절차에 의하지 않은 처벌·보안처분·강제노역으로부터의 신체의 자유로 나누어진다.[317]

---

316) 이를 협의의 신체의 자유라 한다(박일경, 「제6공화국 신헌법」, 법경출판사, 1990, 247면).
317) 그러나 헌법 제12조 3항 본문은 체포·구속·압수 또는 수색을 할 때에는 적법한 절차에 따라 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하여야 한다고 규정하고 있기 때문에 체포·구속·압수·수색도 법률과 적법한 절차에 따라야만 한다. 따라서 제12조 제1항 제2문의 '법률에 의하지 아니하고는'이라는 표현과 '법률과 적법한 절차에 의하지 아니하고는'이라는 표현은 실제에 있어서 차이가 없다(홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 77면.

또한, 제12조 제2항 전단에 규정되어 있는 고문을 받지 않을 권리도 신체의 자유에 신체안전의 자유와 신체자율의 자유가 포함된다.

<대법원 1992. 11. 24. 92도2409>
피의자가 경찰수사단계에서 고문에 의한 자백을 하고, 그 임의성 없는 심리상태가 검사의 피의자 신문시까지 계속되었다고 인정되는 경우에는 피의자 신문시에 자백을 강요한 사실이 없었다 할지라도 검찰자백의 임의성은 부정된다.

첫째, 법률에 규정된 경우에만 할 수 있는 신체의 자유에 대한 제한으로는 체포·구속·압수·수색·심문이 있다.

체포라 함은 실력으로 일정기간 동안 신체의 자유를 구속하여 일정한 장소에 인치하는 행위를 말하며, 구속이라 함은 실력으로 일정한 장소에 유치하고, 그 장소 밖으로 나가는 것을 금지함을 말한다. 구속은 구인과 구금을 포함하는 개념이다. 그리고 압수란 소지품을 강제로 취득하는 것을 말하고, 수색이란 사람이나 물건을 발견하기 위하여 신체, 물건 또는 장소에 대하여 행하는 강제적 검색을 말한다. 그러나 본 조항에서 말하는 압수와 수색은 직접 신체에 대한 것만을 의미한다. 가택에 대한 압수·수색은 헌법 제16조의 적용을 받는다.

또한, 심문이란 구두 또는 서면에 의한 사실의 진술, 즉 답변의 강요를 말한다. 따라서 호의적인 답신은 심문에는 포함되지 아니한다. 심문 받지 않을 권리는 신체의 자유의 내용이라기보다는 오히려 침묵의 자유의 내용에 가깝다. 그러나 심문을 위하여 소환을 받고, 출석하는 경우에는 신체의 자유와 간접적인 관계가 있다.

둘째, 법률과 적법한 절차에 따라서만 할 수 있는 신체의 자유에 대한 제한으로는 처벌·보안처분·강제노역이 있다.

처벌이라 함은 형사상의 처벌만을 의미하는 것이 아니라 본인에게 불이익 또는 고통을 주는 일체의 제재를 말한다. 따라서 처벌에는 질서벌(예컨대, 행정상, 민법상, 소송상의 의무의 해태에 대하여 과하는 과태료)과 집행벌(예컨대, 행정상의 의무의 이행을 강제하기 위하여 과하는 벌)도 포함된다.

보안처분이란 사회적으로 위험한 행위를 할 우려가 있는 자를 사회로부터 격리하여 그 위험성을 교정하는 것을 목적으로 하는 범죄예방처분을 말한다. 우리 헌법재판소는 보안관찰법 제2조 등 위헌소원에서 보안처분은 형벌만으로는 행위자의 장래의 재범에 대한 위험성을 제거하기에 충분하지 못한 경우에 사회방위와 행위자의 사회복귀의 목적을 달성하기 위하여 고안된 특별예방적 목적처분으로 헌법은 1972. 12. 27. 개정헌법 이래 보안처분제도를 헌법상의 제도로 수용하여 왔으므로 헌법의 규정에 따라 어떠한 형태의 보안처분제도를 마련하느냐의 문제는 헌법에 위반되지 아니하는 한 오로지 입법권자의 형성의 자유에 속한다고 판시한 바 있다.[318] 구체적으로는 소년법에 의한 보호처분(보호감호, 치료감호, 보호관찰)과 사회보호법에 의한 보호처분, 보안관찰법에 보안관찰처분과 갱생보호법, 마약법, 윤락행위 등 처벌법, 대마관리법, 전염병예방법 등에 의한 보안처분 등이 있다. 소년법에 의한 보호처분과 사회보호법에 의한 보호처분은 위법한 범죄행위를 전제로 하여 법원의 판결로써 결정됨에 반하여, 그 밖의 법에 의한 처분은 범죄행위를 요건으로 하지 아니하고 행정기관이 행정처분의 형식으로 결정한다.

강제노역이란 본인의 의사에 반하는 강제적인 노동력의 제공을 말한다.

318) 헌법재판소 1997. 11. 27. 92헌바28.

<헌법재판소 1989. 7. 14. 88헌가5 등> 사회보호법 제5조의 위헌심판

형벌은 본질적으로 과거의 범죄행위에 대한 윤리적·도덕적·규범적 비난의 체현이므로 반드시 책임을 전제로 하며, 책임의 양을 넘을 수 없는 제약을 받는다. 보안처분, 특히 보호감호처분은 형벌의 이러한 책임종속성으로 인하여 책임능력이 없어서 형벌을 과함이 불가능하거나 책임의 비례에 따른 제약 때문에 형벌만으로는 행위자의 장래의 재범에 대한 위험성을 제거하기에 충분하지 못한 경우에 사회방위와 행위자의 사회복귀의 목적을 달성하기 위하여 특별히 고안된 것이다. 헌법은 1992. 12. 27. 개정헌법이래 보안처분제도를 헌법상의 제도로 수용하여 왔으므로 헌법의 규정에 따라 어떠한 형태의 보안처분제도를 마련하느냐의 문제는 헌법에 위반되지 아니하는 한 오로지 입법권자의 형성의 자유에 속한다. 따라서 보호감호와 형벌은 비록 다 같이 신체의 자유를 박탈하는 수용처분이라는 점에서 집행상 뚜렷한 구분이 되지 않는다고 하더라도 그 본질과 추구하는 목적 및 기능이 전혀 다른 별개의 제도이므로 형벌과 보호감호를 서로 병과하여 선고한다 하여 헌법 제13조 제1항에 정한 이중처벌금지의 원칙에 위반되는 것은 아니다.[319]

3. 효력

신체의 자유는 주관적 권리로서 원칙적으로 모든 국가작용을 구속하는 대국가적 효력을 지니며, 사적영역(개인 대 개인, 개인 대 대기업, 개인 대 언론 등)을 구속하는 경우에는 공서양속, 신의성실 등 사법상의 일반조항을 통하여 간접적으로 적용되는 대사인적 효력을 가진다.

4. 제한과 한계

신체의 자유가 비록 모든 자유의 기초가 되는 기본적이고, 중요한 기본권이기는 하지만 절대적이고, 무제한적인 기본권은 아니어서 여러 가지 방식으로 제한된다. 즉, 신체의 자유는 대통령의 긴급명령(제76조) 또는 비상계엄(제77조 제3항)의 선포로써 제한 될 수 있고, 특별권력관계(예컨대, 공무원·군인·군무원 등)에 있는 사람은 해당 법률에 의해 신체의 자유가 제한된다.

그러나 신체의 자유는 헌법 제37조 제2항의 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우 법률(예컨대, 형법, 형사소송법, 국가보안법 등)에 의하여 일반적으로 제한된다. 그러나 제한이 가해지는 경우라도 신체의 자유의 본질적 내용을 침해할 수는 없다.

<헌법재판소 2002. 7. 18. 2000헌마327> 신체과잉수색행위 위헌확인

신체의 자유는 헌법상 모든 기본권 보장의 종국적 목적이자 기본이념이라 할 수 있는 인간의 존엄과 가치에 밀접하게 관련되어 있으므로 그 침해여부는 헌법 제37조 제2항에 따라 엄격하게 심사되어야 한다. 따라서 수용시설 내의 안전과 질서를 유지하기 위하여 일부 제한이 불가피하더라고 그 본질적인 내용을 침해하거나 목적의 정당성, 방법의 적정성, 피해의 최소성 및 법익의 균형성 등을 의미하는 과잉금지의 원칙에 위배되어서는 아니 되는 것이다.

<헌법재판소 2004. 12. 16. 2002헌마478> 접견불허처분 등 위헌확인

실외운동은 구금되어 있는 수형자의 신체적·정신적 건강유지를 위한 최소한의 기본적 요청이라고 할 수 있는데, 금지처분을 받은 수형자는 일반 독거수용자에 비하여 접견, 서신수발, 전화통화, 집필, 작업, 신문·도서열람, 라디오청취, 텔레비전시청 등이 금지되어(행형법 시행령 제

319) 헌법재판소 1991. 4. 1. 89헌마17 등.

145조 제2항 본문) 외부세계와의 교통이 단절된 상태에 있게 되며, 환기가 잘 안 되는 1평 남짓한 징벌실에 최장 2개월 동안 수용된다는 점을 고려할 때, 금지 수형자에 대하여 일체의 운동을 금지하는 것은 수형자의 신체적 건강뿐만 아니라 정신적 건강을 해칠 위험성이 현저히 높다. 따라서 금지처분을 받은 수형자에 대한 절대적인 운동의 금지는 징벌의 목적을 고려하더라도 그 수단과 방법에 있어서 필요한 최소한도의 범위를 벗어난 것으로서 수형자는 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치 및 신체의 안정성이 훼손당하지 아니할 자유를 포함하는 제12조의 신체의 자유를 침해하는 정도에 이르렀다고 판단된다.

♣ 문제풀이

1. 다음 헌법 제12조 제1항 제2문에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 가택수색은 포함되지 않는다.
② 형사상의 처벌만을 의미한다.
③ 답변의 강요는 금지된다.
④ 위협적인 분위기 속에서 이루어진 수사기관의 임의동행은 불법이다.
⑤ 범죄에 대한 처벌로서의 노역은 강제노역이 아니다.

[정답] ②

[해설] 형사상의 처벌만을 의미하는 것은 아니고, 본인에게 불이익이 또는 고통이 되는 일체의 제재가 포함된다.

2. 다음 중 신체의 자유에서 기본권 주체성이 인정되지 않는 경우는?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)

① 외국인 ② 불법체류 외국인 ③ 법인 ④ 대한민국 국민 ⑤ 주취자

[정답] ③

[해설] 신체의 자유, 주거의 자유, 변호인의 조력을 받을 권리, 재판청구권 등은 성질상 인간의 권리에 해당한다(헌법재판소 2012. 8. 23. 2008헌마430).

3. 다음 신체에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 사회보호법에 의한 보호감호처분은 형벌과 같이 신체의 자유를 박탈하는 수용처분으로서 형벌과 그 집행상 뚜렷한 구분이 되는 것이므로 형벌과 보호감호를 서로 병과하여 선고한다 하여 이중처벌금지의 원칙에 위반되는 것은 아니다.
② 누범을 가중처벌하는 것은 종전의 범죄에 대하여 형벌을 받았음에도 다시 범행을 하였다는 것 때문이므로 헌법이 규정한 일사부재리원칙에 위반되는 것은 아니다.
③ 보호감호처분은 형벌과 같은 차원에서 적법한 절차와 헌법의 죄형법정주의의 원칙에 따라야 하므로 보호감호처분의 요건이 되는 범죄에 관한 소급입법에 의한 보호감호처분은 허용될 수 없다.
④ 보안관찰법상의 보안관찰처분은 헌법 제12조 제1항의 보안처분의 일종으로서 적법절차의 원리가 적용되어야 하므로 보안관찰처분을 개시하기 위해서는 법관의 판단이 필요하다.
⑤ 상습범을 가중처벌하는 것은 종전의 범죄를 다시 처벌하는 것이 아니라 상습성의 위험성 때문에 가중처벌을 목적으로 하는 것이므로 헌법의 일사부재리원칙에 위반되는 것은 아니다.

[정답] ④

[해설] 보안관찰처분에 관한 결정은 보안관찰 심의위원회의 의결을 거쳐 법무부장관이 행한다(보안관찰법 제14조 제1항).

♣ 요점정리

1. 신체의 자유, 주거의 자유, 변호인의 조력을 받을 권리, 재판청구권 등은 성질상 인간의 권리에 해당하여 외국인에게도 기본권 주체성이 인정된다.

2. 법률에 규정된 경우에만 할 수 있는 신체의 자유에 대한 제한으로는 체포·구속·압수·수색·심문이 있다.

3. 법률과 적법한 절차에 의하지 않은 처벌·보안처분·강제노역으로부터의 신체의 자유를 보장하고 있다.

4. 피의자가 경찰수사단계에서 고문에 의한 자백을 하고, 그 임의성 없는 심리상태가 검사의 피의자 신문시까지 계속되었다고 인정되는 경우에는 피의자 신문시에 자백을 강요한 사실이 없었다 할지라도 검찰자백의 임의성은 부정된다.

5. 신체의 자유는 주관적 권리로서 원칙적으로 모든 국가작용을 구속하는 대국가적 효력을 지니며, 사적영역(개인 대 개인, 개인 대 대기업, 개인 대 언론 등)을 구속하는 경우에는 공서양속, 신의성실 등 사법상의 일반조항을 통하여 간접적으로 적용되는 대사인적 효력을 가진다.

제21강 신체의 자유(3)

♣ 학습목표

죄형법정주의원칙을 설명할 수 있다.
적법절차원리를 설명할 수 있다.
사전영장주의를 설명할 수 있다.
구속적부심사제도를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

죄형법정주의
적법절차원리
사전영장주의, 별건체포·구속
구속적부심제도

♣ 사전테스트

1. 죄형법정주의는 신체의 자유를 보장하는 것이다.
정답 : X
해설 : 죄형법정주의는 신체의 자유를 제한하는 징역·금고 이외에 사형·재산형·공민권제한(예컨대, 자격상실과 자격정지)에도 적용된다.

2. 적법절차의 원리는 현행 헌법에서 최초로 규정되었다.
정답 : O
해설 : 우리 헌법은 적법절차원리(제12조 제1항 제2문과 제12조 제3항), 구속이유고지(제12조 제5항), 형사피의자의 형사보상청구권(제28조) 등을 현행 헌법에서 최초로 규정하였다.

3. 우리나라에서 사전영장제도는 헌법제정 이전부터 보장되었다.
정답 : O
해설 : 1948년 군정법령 제176호(형사소송법의 개정)에 의하여 도입되었다. 따라서 헌법제정 이전부터 보장되었다.

♣ 돌발퀴즈

적법절차의 '법'은 형식적 의미의 법률만을 의미한다.
[정답] X
[해설] 법률과 적법한 절차에서 '법률'은 형식적 의미의 법률만을 의미하나 적법절차의 '법'은 실정법 외에도 법의 실질 내지 이념인 정의, 윤리, 사회상규 등을 포함한다.

♣ 강의내용

1. 죄형법정주의

⑴ 헌법규정 및 의의

우리 헌법은 제12조 제1항 제2문과 제13조 제1항 전단에서 '죄형법정주의(nulla poena sine lege)'를 규정하고 있다.

이처럼 헌법이 죄형법정주의를 규정하고 있는 이유는 무엇이 처벌될 행위인가를 국민이 알 수 있도록 예측 가능한 형식으로 미리 규정하도록 하여 개인의 법적 안정성을 보호하고, 성문의 형벌법규체계를 확립하여 국가형벌권의 자의적 행사로부터 개인의 자유와 권리를 보장하기 위한 것이다.[320]

죄형법정주의는 신체의 자유를 보장하는 것으로만 볼 수는 없다. 왜냐하면 죄형법정주의는 신체의 자유를 제한하는 징역·금고 이외에 사형·재산형·공민권제한(예컨대, 자격상실과 자격정지)에도 적용되기 때문이다. 그러나 형벌 중에는 생명형을 제외하고는 징역·금고가 가장 중대하고 또 통상적이기도 하므로 헌법은 신체의 자유권을 규정하는 제12조에서 죄형법정주의를 규정한 것이다.[321]

⑵ 파생원칙

죄형법정주의는 "법률 없으면 범죄 없고, 법률 없으면 형벌 없다"라는 표현으로 요약될 수 있다. 이러한 죄형법정주의는 형벌을 정하는 성문법은 반드시 의회에서 제정된 법률이어야 한다는 형벌법의 법률주의, 형벌에 관하여는 일반적으로 관습법을 배척하고, 성문법의 규정에만 의하게 하는 형법의 성문법주의(관습형법의 금지), 형벌에 관한 규정은 그 법률 제정 이전의 행위에 소급적용할 수 없다는 형법의 '소급법'(ex post facto Law)금지(형벌불소급의 원칙), 법률에 규정이 없는 사항에 대하여 그것과 유사한 성질을 가지는 사항에 관한 법률 또는 법률조항을 적용하는 유추해석금지, 자유형에 대한 선고형의 기간을 재판에서 확정하지 아니하고 행형의 경과에 따라 결정하는 절대적 부정기형의 금지, 명확성의 원칙으로 구성되어 있다.

<헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13> 국토이용관리법 제21조의3 제1항과 제31조의2

죄형법정주의는 범죄와 형벌이 법률로 정하여져야 함을 의미하는 것으로 이러한 죄형법정주의에서 파생되는 명확성의 원칙은 누구나 법률이 처벌하고자 하는 행위가 무엇이며 그에 대한 형벌이 어떠한 것인지를 예견할 수 있고 그에 따라 자신의 행위를 결정지울 수 있도록 구성요건이 명확할 것을 의미하는 것이다. 다소 광범위하고 어느 정도의 범위에서는 법관의 보충적인 해석을 필요로 하는 개념을 사용하여 규정하였다고 하더라도 그 적용단계에서 다의적으로 해석될 우려가 없는 이상 그 점만으로 헌법이 요구하는 명확성의 요구에 배치된다고는 보기 어렵다.

---

320) 헌법재판소 1991. 7. 8. 91헌가4.

321) 박일경, 「제6공화국 신헌법」, 법경출판사, 1990, 252면.

⑶ 문제점

1) 벌칙규정의 위임

죄형법정주의는 벌칙규정이 형식적 의미의 법률일 것을 요구한다. 그러나 개별적이고 구체적인 사항을 모두 법률이 규정할 수는 없는 일이다. 여기에서 벌칙규정의 위임문제가 발생한다.

일반적·포괄적 위임은 형벌법의 법률주의에 위배되기 때문에 원칙적으로 허용되지 않는다. 그러나 모법이 처벌대상이 되는 행위를 규정함에 있어 그 구체적인 원칙을 제시하고 형벌의 종류와 상한과 폭 등에 대한 명확한 기준을 제시하여 위임하는 것은 허용된다.[322]

법률의 위임이 있는 때에는 지방자치단체는 조례위반에 대한 제재로서 벌칙을 정할 수 있으며(지방자치법 제15조 단서), 행정질서벌에 해당하는 과태료는 죄형법정주의의 규율대상이 아니다.[323]

2) 소급입법에 의한 형벌의 강화와 공소시효연장

헌법 제13조 2항은 참정권을 제한하거나 재산권을 박탈하는 소급입법을 금지하고 있다. 죄형법정주의의 정신상 소급입법에 의하여 형벌을 강화하는 것도 금지된다고 보아야 한다.[324] 그러나 공소시효를 연장하는 것은 새롭게 형벌을 과하거나 형벌을 강화하는 것이 아니므로 소급효금지원칙에 반하지 않는다.[325]

2. 적법절차원리

⑴ 헌법규정 및 연혁

우리 헌법은 제12조 제1항 제2문과 제12조 제3항에서 적법절차원리를 보장하고 있다. '적법절차원리'(due process of law)는 영국의 대헌장에서 기원하는 것으로 알려져 있다. 그러나 due process of law라는 표현이 최초로 사용된 것은 1355년의 에드워드 3세의 제정법 제29조에서였다. 그 후, 적법절차원리는 코크(Edward Coke)가 기초한 권리청원을 거쳐 미국수정헌법 제5조(1791년)와 제14조 제1항(1868년)에 수용되었다.

우리 헌법은 적법절차원리, 구속이유고지(제12조 제5항), 형사피의자의 형사보상청구권(제28조) 등을 현행 헌법에서 최초로 규정되었다.

⑵ 의의 및 기능

적법절차원리는 수백 년간에 걸쳐 점진적으로 형성·확대되어 왔으므로 이를 한 마디로 정의하는 것은 매우 어렵다. 그러나 이 원리는 가장 추상적인 의미에서 '자유와 정의의 기본원리'라고 부를 수 있을 것이다.[326]

---

322) 대법원 1972. 9. 12. 72 도 1137; 헌법재판소 1991. 7. 8. 91헌가4; 1997. 5. 29. 94헌바22; 1997. 9. 25. 96헌가16; 1998. 3. 26. 96헌가20; 2007. 7. 26. 2005헌바100; 2007. 7. 26. 2006헌바12 등.

323) 헌법재판소 1998. 5. 28. 96헌바83.

324) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 343면.

325) 헌법재판소 1996. 2. 16. 96헌가2 등; 살인죄에 대한 공소시효 폐지를 골자로 하는 일명 '태완이법(형사소송법 개정안)'이 7월 31일자로 공포·시행 되었다.

326) John Marshall Harlan, Dissenting opinion in Hurtado v. California 110 U. S. 546, 1884.

적법절차의 원리는 공권력에 의한 국민의 자유와 권리침해는 반드시 실체법상 또는 절차법상 합리적이고 정당하다고 인정되는 절차에 의하여야 할 것을 요구한다.[327] 따라서 형식적 의미의 법률에 정한 것이라면 어떠한 내용의 절차에 의하더라도 무방하다는 의미는 아니다.[328]

법률과 적법한 절차에서 '법률'은 형식적 의미의 법률만을 의미한다.[329] 그러나 적법절차의 '법'은 실정법 외에도 법의 실질 내지 이념인 정의, 윤리, 사회상규 등을 포함한다. 절차는 원래 권리의 실질적 내용을 실현하기 위하여 채택하여야 할 수단적·기술적 순서나 방법을 의미하나 적법한 절차에서의 '절차'는 특히 고지·청문·변명 등 방어기회의 제공절차를 말한다. 우리 헌법재판소는 적법절차를 절차의 적법성뿐만 아니라 절차의 적정성까지를 보장하는 것이라고 한다.[330]

미국에서 적법절차조항은 인권보호와 관련하여 행정절차에도 공정한 고지 및 청문절차가 반드시 보장될 것, 헌법상 보장된 국민의 권리가 행정작용에 의해서 침해된 경우에는 그에 대한 사법적 심사가 반드시 이루어질 것, 형사절차에서는 변호인의 도움을 받을 권리, 공판절차에서의 반대신문권 등이 제한당하지 아니할 것, 경찰수사과정에서도 구금기간의 부당하게 장기화되지 않을 것, 적법절차는 단순히 절차적 차원의 적정성만을 요구하는 것이 아니고, 적용된 법률의 내용이 합리적이고 정당한 법이어야 한다는 실체적 차원의 적정성까지를 그 내용으로 한다.[331]

이러한 적법절차의 원리는 모든 국가작용을 지배하는 헌법적 원리라는[332] 점에서 입법작용의 제한원리에 그치는 과잉입법금지와는 구별되며, 법률이 정당성을 가지고 있는가를 판단하는 위헌법률심판의 심사기준이 된다.

⑶ 적용

헌법은 법률과 적법한 절차에 의하여야 할 사항으로 처벌·보안처분·강제노역을 들고 있다. 그러나 처벌·보안처분·강제노역은 예시적인 것에 지나지 않으며, 적법절차에 의하지 아니하고는 신체적·정신적 그리고 재산상 불이익이 되는 일체의 제재를 받지 않는다고 해석하여야 한다. 즉, 적법절차의 원리는 모든 기본권에 적용되며,[333] 형사절차뿐만 아니라 행정절차에도 적용된다.[334] 따라서 적법절차를 위반한 공권력에 대하여는 헌법소원을 제기할 수 있다.[335]

---

327) 적법절차의 내용으로는 개인의 자유와 권리에 영향을 미치는 국가적 행위에 대하여 관계국가기관이 정당한 권한을 가질 것, 입법의 절차는 물론 법률의 내용도 구체적이고 명확할 것, 상대방에게 고지·청문의 기회가 제공될 것, 변호인의 조력을 받을 권리와 유리한 증인의 강제소환 등이 보장될 것, 판정기관이 공정하게 구성될 것, 권리·의무의 판정은 정의의 원칙과 헌법의 기본이념에 합치하고 자의적인 것이 아닐 것 등이 포함된다(Phelps Dodge Corp. v. NLRB, 313 U. S. 177, 1941).

328) 문제된 법률의 실체적 내용이 합리성과 정당성을 갖추고 있는지 여부를 판단하는 기준으로서 적용된다(헌법재판소 1992. 12. 24. 92헌가8).

329) 그러나 국가비상시와 법률의 위임이 있는 경우에는 예외가 있을 수 있다(문홍주, 「제6공화국 한국헌법」, 해암사, 1988, 243면).

330) 헌법재판소 1993. 7. 29. 90헌바35.

331) 허영, 전제서, 339~340면 참조.

332) 헌법 제12조 제3항 본문은 동조 제1항과 함께 적법절차원리의 일반조항에 해당하는 것으로서, 형사절차상의 영역에 한정되지 않고 입법·행정 등 국가의 모든 공권력의 작용에는 절차상의 적법성뿐만 아니라 법률의 실체적 내용도 합리성과 정당성을 갖춘 실체적인 적법성이 있어야 한다는 적법절차의 원칙을 헌법의 기본원리로 명시한 것이다(헌법재판소 1992. 12. 24. 92헌가8).

333) 법률이 정치적 타협에 의하여 국민의 정치적 참여를 부당하게 제한하거나 불합리한 선거법을 제정하는 것은 적법절차의 원칙에 반하고, 각종 선거과정에 있어서 정치적 표현의 자유나 입후보자의 선택의 자유 그리고 입후보자의 자유와 기회균등을 제한하거나 박탈하는 선거법상의 규정까지 당연한 것이라고 하여 임의로 제정하는 것은 적법절차의 원칙에 반 한다(헌법재판소 1989. 9. 8. 88헌가6).

334) 형사사건으로 공소제기된 변호사에 대해 법무부장관이 그 업무의 정지를 명할 수 있게 한 규정은

3. 사전영장주의

⑴ 헌법규정 및 연혁

헌법 제12조 제3항은 사전영장주의를 규정하고 있다. 사전영장제도는 1679년의 '인신보호령' Habeas Corpus Act에서[336] 유래하였다. 우리나라에서 사전영장제도는 1948년 군정법령 제176호(형사소송법의 개정)에 의하여 도입되었다. 따라서 이 제도는 헌법제정 이전부터 보장되었다.

⑵ 의의

사전영장주의란 수사기관이 형사절차와 관련하여 체포·구속·압수·수색 등의 강제처분을 함에 있어 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 사전에 제시하여야 한다는 원칙을 말한다.

원래 인신보호영장은 타인의 인신을 구속하고 있는 자에 대하여 일정한 목적, 즉 구속의 적부를 심사하기 위하여 피구속자의 인신을 법원 또는 법관의 면전에 제출할 것을 명하는 '영장'(writ)이며, 법관 또는 법원은 인신 구속의 이유와 절차의 적부를 심사하고, 만일 그것이 부당한 때에는 즉시 석방하도록 하는 것이다. 따라서 사전영장주의는 체포·구속의 필요성 유무를 공정하고 독립적 지위를 가진 사법기관으로 하여금 판단하게 함으로써 수사기관에 의한 체포·구속의 남용을 방지하려는 데 그 의의가 있다.

피의자 체포와 피고인 구속을 위한 영장의 경우에는 "피의자·피고인의 성명, 주거, 죄명, 공소사실의 요지, 인치구금할 장소, 발부연월일, 유효기간과 그 기간을 경과하면 집행에 착수하지 못하며 영장을 반환하여야 할 취지를 기재"하여야 한다(형사소송법 제75조, 제200조의5). 인신을 체포·구금하기 위하여 영장을 제시할 때에 영장을 집행하는 공무원은 반드시 법관의 영장에 의하여 체포·구금을 받은 자에게 변호인의 조력을 받을 권리가 있고, 인신구속에 관한 적부의 심사를 법원에 청구할 권리를 가진다는 취지를 피구속자에게 고지하여야 한다(제12조 제4항 제1문, 제12조 제5항 제1문).[337] 이렇듯 즉시 변호인의 조력을 받을 권리와 인신구속에 관한 적

징계절차에 있어서와 같이 당해 변호사가 자기에게 유리한 사실을 진술하거나 필요한 증거를 제출할 수 있는 청문의 기회가 보장되지 아니하며, 이러한 의미에서 적법절차가 존중되지 않으므로 위헌이다(헌법재판소 1990. 11. 29. 90헌가48); 법관이 법정에서 직접 신문도 하기 전에 이루어진 증인신문은 피고인에 대해 근거 없는 심증을 갖게 할 우려가 있으므로 이는 결국 법관의 독립성과 적법절차의 원칙을 해치게 되므로 위헌이다(헌법재판소 1996. 12. 26. 94헌바1); 형사처벌이 아닌 불이익처분의 경우에도 적법절차 원칙이 적용된다(헌법재판소 1990. 11. 19. 90헌가48).

335) 자기에게 아무런 책임 없는 사유로 출석하지 못한 피고인에 대하여 별다른 증거조사도 없이 곧바로 유죄판결을 선고할 수 있도록 한 것은 그 절차의 내용이 심히 적정치 못한 경우로서 헌법 제12조 제1항 후문의 적법절차원칙에 반 한다(헌법재판소 1998. 7. 16. 97헌바22).

336) Habeas corpus는 인신(人身)을 법관의 면전에 제출하라(bring the body before the court)라는 뜻을 가진 라틴어이다. 인신보호영장을 규정한 최초의 국회제정법은 1679년의 '인신보호령'(Habeas Corpus Act)이다. 그 후, 그 내용을 보충하는 인신보호법이 1816년, 1862년에 제정되었다. 이들을 통칭하여 '인신보호법'(Habeas Corpus Acts)이라 한다.

337) 우리 형사소송법은 체포·구속의 경우에 피의자·피고인에게 범죄사실의 요지, 구속의 이유와 변호인을 선임할 수 있음을 말하고 변명할 기회를 준 후가 아니면 구속할 수 없게 하고 있다(형사소송법 제200조의 2). 이는 미국의 판결에서 확립된 Miranda원칙(Miranda v. Arizona 383 U. S. 436, 1966)을 받아들인 것이라 볼 수 있다. 또한, 형사소송법은 체포한 피의자를 구속하고자 할 때에는 체포한 때부터 48시간 이내에 구속영장을 청구하여야 하고, 그 기간 내에 구속영장을 청구하지 아니하면 피의자를 즉시 석방하도록 하고 있다(형사소송법 제200조의2 제1항, 제2항, 제5항).

부의 심사를 법원에 청구하는 권리를 체포 또는 구금과 동시에 피구속자에게 인정하기 때문에 인신보호영장제도는 신체의 자유를 보장하는 가장 중추적인 제도라 할 수 있다.[338]

⑶ 예외

현행범인 경우와 장기 3년 이상의 형에 해당하는 죄를 범하고 도피 또는 증거인멸의 염려가 있는 자의 경우(제12조 3항 단서)에는 사전영장주의원칙이 적용되지 않는다. 또한, 비상계엄이 선포된 때에는 영장제도에 대하여 특별한 조치를 할 수 있다(제77조 3항). 그러나 비상계엄하에서 영장주의에 제한을 가하는 경우에도 법관에 의한 영장제도 자체를 전면적으로 배제할 수는 없다.[339]

구체적으로는 피의자의 긴급체포, 현행범 및 준현행범의 체포, 공무소에 대한 조회, 법원의 신체검사, 공판정에서의 인신구속(이상 대인적인 것), 공판정에서의 압수수색, 법원에 의한 검증, 인신구속의 경우 압수·수색·검증, 임의 제출물 등의 압수(이상 대물적인 것)의 경우에는 사전영장주의가 배제된다. 또한, 사전영장주의는 형사사법의 발동에 대한 규정이기 때문에 행정상의 즉시강제수단으로서 강제격리, 강제수용 등의 처분에는 법관의 영장이 필요하지 않다는 것이 통설의 입장이다. 그러나 행정상의 즉시강제의 목적과 형사사법의 목적이 경합할 경우에는 영장주의가 적용되어야 한다.[340]

⑷ 별건체포·구속

별건체포·구속이라 함은 중대한 사건(예컨대, 살인사건)에 관하여 체포 또는 구속영장을 청구할 정도의 증거를 수집할 수 없는 경우, 이미 증거가 수집된 별도의 경미한 사건(예컨대, 폭력사범)으로 체포 또는 구속영장을 발부 받아 체포나 구속을 하는 수사방법을 말한다.

별건체포·구속은 수사의 주목적인 본건(중대사건)에 관한 법관의 사전심사가 회피되어 영장주의의 존재의의를 상실하게 하므로 헌법 제12조 제3항에 위배되고, 체포·구속의 이유가 본건에 관하여 고지되지 아니하므로 헌법 제12조 제5항에 위반되며, 그것이 자백을 얻기 위한 부당한 수단으로 이용된 경우에는 헌법 제12조 제2항의 고문금지조항에 위반되고, 전체적으로 절차가 공정하지 못하고 부당한 것이라는 의미에서 헌법 제12조 제1항 제2문의 적법절차조항에도 위반된다.[341]

4. 구속적부심사제도

⑴ 헌법규정 및 연혁

헌법 제12조 제6항은 체포·구속적부심사제도를 채택하고 있다. 구속적부심사제도는 영미법계통의 인권보장제도의 하나이다. 그 기원은 불확실하나 1215년의 대헌장 이전으로 추측되며, 그 후 1679년에 '인신보호령'(Habeas Corpus Act)에 규정되었고, 이것이 다시 미국헌법에 계승되어 세계 각국의 헌법으로 확대되었다.[342]

---

338) 한동섭, 헌법, 박영사, 1971, 130면 참조.

339) 비상계엄선포 중에도 검사는 영장을 발부할 수 없다. 계엄법 제13조에 규정한 특별조치가 헌법 제9조 2항에 명시한 규정에 위반하여 법관의 영장 없이 체포·구금·수색할 수 있음을 포함한 것이라고 논할 근거가 없다(헌법위원회, 1953. 10. 8, 4286헌위2).

340) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 92면.

341) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 408~409면 참조.

우리나라에는 1948년 사전영장주의와 함께 군정법령 제176호로 도입되었고, 건국헌법에서 채택되었으나 1972년 헌법에서 삭제되었다가 1980년 헌법에서 부활하여 현행 헌법에 이르고 있다.

⑵ 의의

구속적부심사제도는 체포·구속을 받은 피의자 또는 변호인 등이 그 적부의 심사를 법원에 청구할 경우, 법관이 즉시 피의자와 변호인이 출석한 공개법정에서 체포 또는 구속의 이유를 밝히도록 하고, 체포 또는 구속의 이유가 부당하거나 적법한 것이 아닐 때에는 법관이 직권으로 피의자를 석방하는 제도를 말한다.[343]

구속적부심사청구권은 인신보호영장제도의 가장 핵심적 부분으로, 범죄수사 또는 형사소추상의 필요를 이유로 국가권력(특히 행정권)에 의한 인신구속의 남용을 방지하기 위한 것이다. 그와 동시에 체포·구금된 자에게 그 구속의 이유와 절차가 적법한 것이었는가에 대한 여부를 구속과 동시에 법원에 대하여 청구할 수 있도록 하는 의의를 가진다.

⑶ 내용

1) 청구대상과 청구권자

모든 범죄에 대하여 체포 또는 구속된 피의자, 변호인, 법정대리인, 배우자, 직계친족, 형제자매, 호주, 가족, 동거인, 고용주는 체포·구속적부심사권을 행사할 수 있다(형사소송법 제214조의2 제1항). 피고인에게는 심사청구권이 인정되지 아니한다.

2) 심사기관과 심사절차

판사가 1인인 지방법원 지원의 경우를 제외하고는 영장을 발부한 법관은 체포·구속적부심사의 심문·조사·결정에 관여할 수 없다. 또한, 체포·구속심사를 청구 받은 법원은 지체 없이 체포 또는 구속된 피의자를 심문하고 수사관계서류와 증거물을 조사하여 청구가 이유 없다고 인정한 때에는 결정으로써 기각하고, 이유가 있다고 인정한 때에는 결정으로써 체포 또는 구속된 피의자의 석방을 명하여야 한다. 석방된 피의자가 도망하거나 증거를 인멸하는 경우를 제외하고는 동일범죄사실을 이유로 다시 체포하거나 다시 구속할 수 없다(형사소송법 제214조의3).[344]

3) 심사내용

체포·구속적부의 심사는 영장발부의 요식과 절차에 관한 형식적 사항은 물론 체포·구속사유의 타당성과 적법성에 관한 실질적 사항까지를 심사한다. 체포·구속적부 여부의 판단은 적부심사시를 기준으로 한다.[345]

---

342) 문홍주, 전게서, 247면 참조.

343) 형사소송법은 죄증을 인멸할 염려가 있다고 믿을 만한 충분한 이유가 있는 때, 피해자, 당해사건의 재판에 필요한 사실을 알고 있다고 인정되는 자 또는 그 친족의 생명·신체나 재산에 해를 가하거나 가할 염려가 있다고 믿을 만한 충분한 이유가 있는 때(제214조의2 제4항)를 제외하고는 법원으로 하여금 구속된 피의자에 대하여 피의자의 출석을 보증할 만한 보증금의 납입을 조건으로 그 석방을 명하는 결정(보석결정)을 할 수 있게 하고 있다.

344) 법원의 보석결정으로 석방된 피의자도 도망한 때, 죄증을 인멸할 염려가 있는 때, 출석요구에 응하지 아니한 때, 법원이 정한 조건을 위반한 때가 아니면 다시 체포 또는 구속하지 못한다.

345) 권영성, 전게서, 411면 참조.

4) 불복제도

법원의 체포·구속적부심사의 결정에 대하여는 검사나 피의자 모두 항고할 수 없다.

5. 그 밖의 보장

이 밖에도 신체의 자유를 보장하기 위하여 불리한 진술금지(제12조 제2항),[346] 변호인의 조력을 받을 권리,[347] 예외적인 경우의 국선변호인제도(제12조 제4항),[348] 구속이유 등의 고지(제12조 제5항), 자백의 증거능력제한(제12조 제7항),[349] 일사부재리원칙(ne bis in idem, 제13조 제1항 후단),[350][351] 연좌제금지(제13조 제3항),[352] 지체 없이 공개재판을 받을 형사피고인의 권

---

346) 불리한 진술거부권은 묵비권이라고도 하며, 영미법상의 '자기부죄(自己負罪)거부특권'(privilege against self-incrimination)을 규정한 것이라고 할 수 있다. 여기서 불리한 진술이라 함은 ① 유죄판결의 기초가 될 사실과 양형에 있어서 불리하게 될 사실을 말하며, 자기에게 불리한 진술이라 함은 형사피의자 또는 피고인으로서 뿐만 아니라 증인으로서의 진술 중 자기에게 불리한 진술을 포함한다(형사소송법 제148조). 그러나 단순히 자기의 명예와 성실성에 손상을 가져온다든가 또는 행정상의 처분을 받을 우려가 있는 사실에 대해서는 진술거부권이 없다. ② 자기에게 불리한 진술이기 때문에 제3자가 형사상 불리한 것에 대해서는 진술거부권이 없다. 그러나 법률은 공익상 또는 도의상 일정한 친족을 위하여 또는 신의상 일정한 직업에 종사하는 자에 대하여 그 범위를 다소 확대하고 있다(형사소송법 제147~제149조). ③ 진술은 심문에 대한 답변만을 말하고, 서류 등의 제출은 이에 포함되지 않는다. ④ 진술은 형사절차뿐만 아니라 행정절차, 국회에서의 질문 등 모든 심문절차에 적용된다. 불리한 진술거부권은 예컨대, 진술의 강요, 거짓말탐지기의 사용, 법률상의 기록·보고의무의 강제 등에 의하여 침해된다; 증인으로 선서한 이상 진실대로 진술한다면 자신의 범죄를 시인하는 진술을 하는 것이 되고 증인을 거부하는 것은 자기의 범죄를 암시하는 것이 되어 증인에게 사실대로의 진술을 기대할 수 없다고 하더라도 소송법상 이러한 처지의 증인에게는 증인을 거부할 수 있는 권리를 인정하여 위증죄로부터의 탈출구를 마련하고 있는 만큼 적법행위의 기대가능성이 없다고 할 수 없으므로 선서한 증인이 증언거부권을 포기하고 허위의 진술을 하였다면 위증죄의 처벌을 면할 수 없다(대법원 1987. 7. 7. 86도1724)

347) 변호인의 조력이라 함은 변호인의 충분한 조력을 의미한다. 변호인과의 자유로운 접견은 신체의 구속을 당한 사람에게 보장된 변호인의 조력을 받을 권리의 가장 중요한 내용이어서 국가안전보장, 질서유지, 공공복리 등 어떠한 명분으로도 제한될 수 있는 성질의 것이 아니다(헌법재판소 1992. 1. 28. 91헌마111); 다만, 미결수용자와 변호인 사이의 서신으로서 그 비밀을 보장하기 위해서는 첫째, 교도소측에서 상대방이 변호인이라는 사실을 확인할 수 있어야 하고, 둘째, 서신을 통하여 마약 등 소지 금지품의 반입을 도모한다든가 그 내용에 도주·증거인멸·수용시설의 규율과 질서의 파괴 기타 형벌법규에 저촉되는 내용이 기재되어 있다고 의심할 만한 합리적인 이유가 있는 경우가 아니어야 한다(헌법재판소 1995. 7. 21. 92헌마144); 헌법상 변호인과의 접견교통권은 체포 또는 구속을 당한 피의자·피고인에게만 한정되는 신체적 자유에 관한 기본권이고, 변호인의 구속된 피의자·피고인과의 접견교통권은 헌법상 권리라고 말할 수 없으며, 단지 형사소송법 제34조에 의하여 비로소 보장되는 권리임에 그친다(헌법재판소 1991. 7. 8. 89헌마181).

348) 변호인의 조력을 받을 권리가 엄격한 의미에서의 소송절차가 아니고 그 전단계인 수사단계에서도 변호인의 조력을 받을 수 있게 함으로써 피의자의 정당한 권리를 보호하려는 것이라면, 국선변호인제도는 빈곤 기타의 사정으로 변호인을 구할 수 없는 자에게 국가가 변호인을 붙여줌으로써 형사피고인의 정당한 권리를 보호하려는 것이다. 따라서 국선변호인제도는 공소제기 이후의 소송절차에서만 인정된다. 형사소송법 제283조는 국선변호인을 선정하여야 하는 경우로 다음을 들고 있다. ① 피고인이 미성년자인 때 ② 피고인이 70세 이상의 자인 때 ③ 피고인이 농아자인 때 ④ 피고인이 심신장애의 의심 있는 자인 때 ⑤ 피고인이 빈곤 기타 사유로 변호인을 선임할 수 없는 경우로서 피고인의 청구가 있는 때(이상 형사소송법 제33조) ⑥ 사형, 무기 또는 단기 3년 이상의 징역이나 금고에 해당하는 사건의 경우(형사소송법 제282조)이다.

349) 이는 '불법의 과실도 불법'이다(Weeks v. United States 232 U. S. 383, 1914; United States v. Jeffers 342 U. S. 481, 1951; Mapp v. Ohio 367 U. S. 643, 1961).

리(제27조 제3항 제2문), 유죄확정시까지 무죄추정을 받을 형사피고인의 권리(제27조 제4항)[353] 등이 규정되어 있다.

♣ 문제풀이

1. 죄형법정주의에 대한 설명으로 가장 바르지 못한 것은?

① 유추해석의 금지
② 형벌법규의 소급입법의 금지
③ 상대적 부정기형의 금지
④ 관습형법의 금지
⑤ 소급입법의 금지

[정답] ③

[해설] 절대적 부정기형이 금지된다.

2. 다음 적법절차원리에 관한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 미국헌법상 적법절차원리는 절차적 개념에서 실체적 개념으로 확장되었다.
② 적법절차원리는 형사절차에 한정되어 적용된다.
③ 적법절차원리와 법치주의원리는 상호 대체적이며, 보완적이다.
④ 적법절차원리는 헌법의 기본원리이다.
⑤ 적법절차원리는 신체의 자유에서 규정하고 있다.

[정답] ②

[해설] 모든 입법작용 및 행정작용에도 광범위하게 적용된다(헌법재판소 1992. 12. 24. 92헌가8).

---

350) 일사부재리의 원칙은 엄격하게 말하면 영미법에서 말하는 '이중위험'(double jeopardy)의 금지와는 약간 다르다. 일사부재리는 유죄·무죄의 판결 또는 면소의 판결이 있은 다음에는 동일사건에 대하여 다시 공소를 제기하여 심판을 구하지 못하는 것을 말한다. 그에 반하여 이중위험의 금지는 피고인을 동일범죄에 대하여 이중으로 형사절차에 의한 처벌을 받을 위험에 두는 것을 금지하는 것으로서 검사의 상소도 이중위험이 된다. 정당하게 지방법원에서 무죄판결을 받았을 때에는 상소는 인정되지 아니한다. 그러나 피고인이 자신을 유리하게 하기 위하여 상소하는 것은 이 권리를 포기한 것으로 볼 수 있기 때문에 무방하다(문홍주, 전게서 251면 참조).

351) 형벌의 집행을 받은 사람에게 보안관찰처분을 하는 것은 이중처벌이 아니다(헌법재판소 1997. 11. 27. 92헌바28).

352) 연좌제의 금지는 신체의 자유와는 직접적인 관련이 없다. 그러나 자기책임에 따르는 행위가 아닌 본인 이외의 행위로 말미암아 신체의 자유에 대한 불리한 처우를 받는다는 것은 이에 대한 중대한 제한이 될 수 있으므로 신체의 자유보장과 관계가 있는 경우가 많을 것이다(문홍주, 전게서, 252면).

353) 공소제기가 된 피고인이라도 확정판결이 있기까지는 원칙적으로 죄가 없는 자에 준하여 취급하여야 하고 불이익을 입혀서는 안 된다고 할 것으로, 가사 그 불이익을 입힌다 하여도 필요한 최소제한에 그치도록 비례의 원칙이 존중되어야 한다는 것이 헌법 제27조 4항의 무죄추정의 원칙이며, 여기의 불이익에는 형사절차상의 불이익뿐만 아니라 그 밖의 기본권제한과 같은 처분에 의한 불이익도 포함된다고 할 것이다(헌법재판소 1990. 11. 19. 90헌가48).

3. 다음 구속적부심사제도에 관한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 영미법상 인신보호영장제도에서 출발한 것으로 우리나라는 제헌 헌법에서 도입된 이래 현행 헌법에 이르고 있다.

② 우리 헌법은 구속뿐만 아니라 체포영장에 의한 체포의 경우에도 그 적부심사를 법원에 청구할 수 있다.

③ 구속적부심사를 청구할 수 있는 자에는 구속된 피의자, 변호인, 직계친족, 형제자매, 고용주가 포함된다.

④ 현행 법제상 피고인에게는 구속적부심사청구권이 인정되지 않는다.

⑤ 체포·구속적부심사청구는 모든 범죄에 대하여 가능하다.

[정답] ①

[해설] 1948년 사전영장주의와 함께 군정법령 제176호로 도입되었고, 건국헌법에서 채택되었으나 1972년 헌법에서 삭제되었다가 1980년 헌법에서 부활하여 현행 헌법에 이르고 있다.

♣ 요점정리

1. 헌법이 죄형법정주의를 규정하고 있는 이유는 무엇이 처벌될 행위인가를 국민이 알 수 있도록 예측 가능한 형식으로 미리 규정하도록 하여 개인의 법적 안정성을 보호하고, 성문의 형벌법규체계를 확립하여 국가형벌권의 자의적 행사로부터 개인의 자유와 권리를 보장하기 위한 것이다.

2. 우리 헌법은 적법절차원리(제12조 제1항 제2문과 제12조 제3항), 구속이유고지(제12조 제5항), 형사피의자의 형사보상청구권(제28조) 등을 현행 헌법에서 최초로 규정하였다.

3. 법률과 적법한 절차에서 '법률'은 형식적 의미의 법률만을 의미하나 적법절차의 '법'은 실정법 외에도 법의 실질 내지 이념인 정의, 윤리, 사회상규 등을 포함한다.

4. 적법절차의 원리는 모든 기본권에 적용되며, 형사절차뿐만 아니라 행정절차에도 적용된다. 따라서 적법절차를 위반한 공권력에 대하여는 헌법소원을 제기할 수 있다.

5. 사전영장주의는 체포·구속의 필요성 유무를 공정하고 독립적 지위를 가진 사법기관으로 하여금 판단하게 함으로써 수사기관에 의한 체포·구속의 남용을 방지하려는 데 그 의의가 있다.

6. 구속적부심사청구권은 인신보호영장제도의 가장 핵심적 부분으로, 범죄수사 또는 형사소추상의 필요를 이유로 국가권력(특히 행정권)에 의한 인신구속의 남용을 방지하고, 체포·구금된 자에게 그 구속의 이유와 절차가 적법한 것이었는가에 대한 여부를 구속과 동시에 법원에 대하여 청구할 수 있도록 하는 의의를 가진다.

제23강 거주·이전의 자유

♣ 학습목표

거주·이전의 자유에 대하여 설명 할 수 있다.

♣ 학습내용

마그나카르타
베스트팔렌조약
바이마르헌법 제111조
제헌헌법 제10조 및 현행 헌법 제14조
거주·이전의 자유의 의의 및 법적성격
외국인의 주체성, 법인의 주체성
대국가적, 대사인적효력

♣ 사전테스트

1. 거주·이전의 자유는 1867년 독일제국헌법에서 최초로 명문으로 보장되었다.
   정답 : X
   해설 : 거주·이전의 자유는 1919년 바이마르헌법 제111조에서 최초로 명문으로 규정하였다.

2. 우리나라는 거주·이전의 자유를 현행 헌법 제14조에서 최초로 규정하였다.
   정답 : X
   해설 : 제헌 헌법 제10조에서 “모든 국민은 법률에 의하지 아니하고는 거주와 이전의 자유를 제한받지 아니하며 주거의 침입 또는 수색을 받지 아니한다”고 처음 규정하였다.

3. 일정한 국가로의 이주, 해외여행 등을 제한하는 것은 헌법상의 거주·이전의 자유를 제한하는 것이다.
   정답 : X
   해설 : 일정한 국가로의 이주, 해외여행 등을 제한하는 여권법에 의한 외교통상부 장관의 고시로 인하여 청구인들의 거주·이전의 자유가 일부 제한된 점은 인정되지만 그러한 제한이 헌법에 위배되는 것은 아니다(헌법재판소 2008. 6. 26. 2007헌마1366).

♣ 돌발퀴즈

우리나라 국적을 가진 모든 국민은 아무런 제한 없이 거주·이전의 자유를 향유한다.
[정답] X
[해설] 미성년자는 민법 제914조의 친권자의 거소지정권에 의하여 제한을 받고, 수형자, 군인, 공무원 등은 관련 법률에 따라 일정한 제한을 받는다.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

(1) 연혁

국가 이념사에서 거주·이전의 자유의 가장 핵심적 내용은 출국의 자유였다. 누구든지 자신의 자유로운 결정에 따라 국가권력에 복종하여야 한다는 사회계약사상은 자신이 살고 있는 정치체제에 만족하지 않는 자는 그 국가를 떠날 권리를 가져야 한다는 것이다. 예컨대, 푸펜도르프(Samuel Pufendorf)는 신민은 저항권을 가지지 않으나 출국할 권리를 가진다고 하였다.[354]

중세에는 거의 극복할 수 없는 법적·경제적 장애로 인하여 다른 지역이나 다른 나라로의 이주는 방해되었다. 일정한 영주에 예속되어 있지 않은 자라 할지라도 기존의 당국에 상당한 추징세를 치르지 않으면 아니 되었고, 또한 새로운 곳에서 비싼 대가를 물어야 했다.[355]

거주·이전의 자유는 상인에 대하여 이동의 자유를 보장하였던 1215년 영국의 마그나카르타 제13조 및 제41조에서 최초로 규정되었고,[356] 독일에서는 1514년 8월 7일 튀빙거 계약으로 신하에게 자유로운 이동이 출국의 자유와 함께 허용된 바 있으며,[357] 1555년 아우구스 종교화의에서 영주의 신앙고백에 동조(찬성)하지 않는 신민을 위한 이주의 자유가 인정되었고,[358] 1648년 베스트팔렌(Westfalen) 강화조약에서 재확인되었다.[359]

거주·이전의 자유는 처음에는 주로 종교가 문제되었으나 자본주의 영향아래 경제와 관련하여 문제되기 시작하였다. 즉, 거주·이전의 자유는 시민사회를 실현하는 과정에서 경제적 자유로 바뀌게 되었다. 즉, 18세기부터 19세기까지의 변화기를 거쳐 1783년 Baden에서 우선 농노제도와 추징세가 폐지되었고, 다른 지역으로 확산되었다.

또한, 19세기 초에 실시되었던 농민해방은 이주의 자유 발전을 위한 매우 중요한 경계석을 놓았고, 이는 다수 주민이 전에 복속하였던 영지에 대한 법적·경제적 속박의 해체를 의미하였다. 따라서 거주·이전의 자유는 봉건체제 붕괴 후 성립된 절대군주국가 이전에 이미 실현되어 시민혁명에 의한 자본주의사회의 성립에 앞서서 사실상 형성되었다고 할 수 있다.[360] 시민혁명기인 19세기의 근대 입헌주의헌법은 거주·이전의 자유를 반드시 명문으로 보장하지는 않았던 바, 이는 근대 시민사회 성립 및 자본주의 발달의 전제로서 당연시하였기 때문이다.[361]

미국의 1781년 연방규약(Articles of Confederation)은 명문으로 주민의 이전의 자유를 인정하였으나 이 규정이 헌법이나 권리장전에는 포함되지 않았다. 그 이유는 명백하지 않지만 이 권리가 매우 기본적인 것이기 때문에 법문에 명시될 필요가 없었던 것으로 제시되고 있다.[362]

1789년의 프랑스 인권선언에도 거주·이전의 자유에 관한 명문규정은 없었으며, 1793년의 인권선언 제17조 및 1795년 헌법 제355조에 규정된 영업의 자유의 전제조건으로 거주·이전의 자유가 인정되었고, 오늘날 헌법상 명문규정이 없음에도 불구하고 인간의 기본적인 자유로 인정되어 이를 뒷받침하고 그 한계를 정하는 각종 법률이 규정되어 있다.[363]

---

354) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 99면.
355) E. Stein/G. Frank, Staatsrecht, 19. Aufl., Mohr Siebeck, 2004, S. 280.
356) I. v. Munch/Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band 1-2, 4. Aufl., C. H. Beck, 1992, S. 674.
357) Zippelius/Wurtenberger, a. a. O., S. 267.
358) E. Stein/G. Frank, a. a. O., S. 280; I. v. Munch/Kunig, a. a. O., S. 674.
359) 홍성방, 전게서, 99면.
360) 이강혁, "거주·이전의 자유", 「고시연구」 제12권 제8호 1985, 고시연구사, 55~56면 참조.
361) 이강혁, 상게논문, 56면.
362) J. E. Nowak, Constitutional Law, West Group, 1995, p. 927.
363) C. A. Colliard, Les libertes publiques, 6eed., Dalloz, 1982, pp. 311~347.

헌법상 거주·이전의 자유를 최초로 규정한 국가는 독일로서 1849년 프랑크푸르트 헌법초안 제4장 제1조 §133는 “모든 독일국민은 공화국의 모든 장소에서 거소와 주소를 정하고, 모든 종류의 부동산(토지)을 취득하고 이를 처리하며, 모든 생업을 영위하고, 시민권을 획득할 권리를 가진다”고 규정하였고, 1867년 북부독일의 연방에서는 이전의 자유에 대한 단행법이 결의되어 1871년 독일제국법으로 수용되었다.[364] 1919년 바이마르헌법 제111조는 “모든 독일국민은 공화국전체에서 이전의 자유를 향유한다”고 규정하여 최초로 헌법규정에 명문으로 거주·이전의 자유를 인정하였으며, 제2차 대전이후 1946년 일본 헌법, 1948년 이탈리아 헌법, 1949년 독일 기본법 등이 이를 따랐다.[365]

오늘날에는 국제적 차원에서 이전의 자유 보장이 보편화 되고 있고 이를 위한 지역적 기구가 구성되고 있다. 1948년 세계 인권선언 제13조는 ‘일국의 국내의 이전의 자유와 주거의 자유로운 선택의 권리’와 마찬가지로 ‘자기 자신의 국가를 포함하여 모든 나라를 떠나고 자기의 나라로 돌아갈 수 있는 권리’를 선언하고 있고, 1966년 시민적·정치적 권리에 대한 국제인권협약 제12조는 ‘국내와 외국에서 자유로이 활동하고 자기의 주거를 자유로이 선택할 권리’를 수용하여 보장하고 있다.

⑵ 헌법규정

우리나라는 제헌 헌법 제10조에서 “모든 국민은 법률에 의하지 아니하고는 거주와 이전의 자유를 제한 받지 아니하며 주거의 침입 또는 수색을 받지 아니한다”고 처음 규정하였고, 현행 헌법은 제14조에서 “모든 국민은 거주·이전의 자유를 가진다”고 규정하여 모든 국민에게 거주·이전의 자유를 보장하고 있다.

2. 의의 및 법적성격

⑴ 의의

거주·이전의 자유라 함은 국민이 자기가 원하는 모든 장소에 주소나 거소를 설정하고, 체류하거나 이전하며, 그 의사에 반하여 거주 또는 체류의 장소를 이전하지 아니할 자유를 말한다.[366] 모든 사람은 누구나 자신이 원하는 곳을 일시적으로 방문하거나 장기적으로 살기를 원한다. 거주·이전의 자유는 자신의 생활장소를 스스로 선택하고 결정하는 권리이자, 직업, 혼인 및 가족생활 형성, 학문·예술활동을 위한 전제조건이 되는 자유권이다. 현대산업사회는 고도의 이동성에 의존하고 있기 때문에 거주이전의 자유는 매우 중요한 의미를 가진다.

개인의 자유로운 결정에 따라 국가권력에 복종한다는 서구의 통치계약이론에 의하면 거주·이전의 자유 중 가장 중요한 이주의 자유는 자기가 살고 있는 정치체제에 만족하지 않는 경우 ‘발로써 하는 투표권’으로서 그 국가를 떠날 수 있는 권리였고,[367] 자유민주주의국가에 있어서의 이주의 자유 보장은 헌법사적으로 국가가 신민들을 소유물처럼 처리하고 착취대상으로 취급하

364) E. Stein/G. Frank, a. a. O., S. 280.
365) 이강혁, 전게논문. 56면.
366) 국내 학자다수의 견해(김철수, 「학설판례헌법학」(상), 2008, 박영사, 787면; 권영성, 「헌법학원론」, 2006, 법문사, 460면; 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2008, 451면; 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 101~102면; 권형준, “거주·이전의 자유에 관한 연구”, 「법학논총」, 한양대학교 법학연구소, 2008, 1면)이면서 헌법재판소의 태도이다(헌법재판소 2004. 10. 28. 2003헌가18).
367) Zippelius/Wurtenberger, Deutsches Staatsrecht, 31. Aufl., C. H. Beck, 2005, S.267.

는 헌법질서로부터의 전향을 의미하였다.[368] 이주의 자유는 국가가 시민의 정치적인 자율권의 가장 기초적인 부분을 존중하는 최후의 시험대라 할 수 있다.

⑵ 법적성격

1) 소극적 자유권성

거주·이전의 자유는 개인의 주관적 공권으로서 국가의 간섭이나 침해를 받지 않을 소극적인 방해배제청구권이 인정되고 있으나, 적극적인 이행청구권은 포함하지 않는다. 그러므로 국가에 대하여 주거를 마련하여 줄 것을 요구하거나 주거를 마련하기 위한 재정적 뒷받침을 요구하는 청구는 할 수 없다.

2) 사회적·경제적 자유권성

거주·이전의 자유는 사회적·경제적 자유로서의 성격을 지닌다. 거주·이전의 자유는 인간의 사회활동을 가능하게 하기 위한 전제로서 사회적 자유로서의 성격을 지니는 동시에 재산권 보장·직업선택의 자유·영업의 자유와 더불어 자본주의 존립에 불가결한 요소로서 경제적 자유로서의 성격을 지니고 있다. 자본주의 경제질서는 사람과 재화의 자유로운 이동을 전제로 성립하기 때문이다.[369]

3) 민주주의의 본질적 자유권성

거주·이전의 자유는 인신의 자유, 표현의 자유, 인격형성의 기초가 되는 자유 등 민주제를 정착시키기 위한 기초조건과 깊이 관련하고 있는 점에서 민주제의 기초가 되는 인간의 기본적 자유로서의 성격을 지닌다고 할 수 있다.[370]

첫째, 거주·이전의 자유는 널리 인간의 이동의 자유를 보장함으로써 인신의 자유와 밀접하게 관련되고 있다.[371] 인신의 구속은 직접적으로는 인신의 자유의 제약인 동시에 거주·이전의 자유의 제약이기도 하다.

둘째, 거주·이전의 자유는 정신적 자유권과 결합하고 있다. 특히 이동의 자유와 집회의 자유 및 집단행동의 자유와는 지극히 밀접한 관계에 있고, 제한의 방법에 따라서는 이동의 자유의 제약을 통하여 표현의 자유를 실질적으로 억제하는 것도 가능하게 된다.[372]

셋째, 거주·이전의 자유는 개인의 인격형성에 대하여 중요한 의미를 지닌다. 거주·이전의 자유는 인간의 활동영역을 확대하여 자유로운 인간교섭을 가능케 함으로써 개인의 인격 형성·인간적 성장에 기여하기 때문이다.[373]

3. 주체

우리나라 국적을 가진 자연인인 국민은 당연히 거주·이전의 자유를 향유하지만, 미성년자는 기본권능력은 보유하고 있으나, 성년에 이르기까지 민법 제914조의 친권자의 거소지정권에 의하여 제한을 받는다.

---

368) 芦部信喜, 居住·移轉の自由, 法學教室 No. 221, 有斐閣, 1999, 57面.
369) 성낙인, 「헌법학」, 2013, 법문사, 664면.
370) 芦部信喜, 前揭論文, 60面.
371) 이강혁, 전게논문, 57~58면.
372) 芦部信喜, 前揭論文, 60面.
373) 권영성, 전게서, 460~461면 참조.

외국인은 주체에서 제외되어야 할 것이나, 헌법 제6조 제2항은 “외국인은 국제법과 조약이 정하는 바에 의하여 그 지위가 보장된다”고 규정하고 있기 때문에 외국인에게 거주·이전의 자유를 인정할 것인지 여부는 이에 따라야 한다.

일반적으로 외국인의 입국의 자유는 인정되지 않는다. 따라서 외국인이 우리나라에 입국하기 위해서는 출입국관리법에 의하여 입국을 허가하는 입국사증을 요하고 있다. 국제인권규약도 외국인의 타국에의 입국의 자유는 인정하지 않고 있다. 그러므로 외국인의 입국을 허가할 경우 일정한 조건을 부과하는 것도 가능하다.[374] 적법하게 국내에 입국한 외국인은 우리나라에 거주하는 경우이거나 일시적으로 여행하는 경우이거나 당연히 출국의 자유가 보장된다.[375]

한국인과 혼인한 외국인에게 거주·이전의 자유를 보장할 것인가의 문제는 헌법 제36조와 제6조 및 국적법과 관련되는 바, 과거와 달리 현행 국적법은 한국인과 결혼한 외국인에게 당연히 한국국적을 부여하지 않고 있기 때문에 이들에 대한 거주·이전의 자유의 보장문제는 일반 외국인의 경우와 동일하다.

다만, 여기서 한국인과 혼인한 외국인을 추방할 수 있는지에 관하여는 그 추방이 헌법 제36조 제1항에 위반되는 것이 아닌가 하는 문제가 제기될 수 있는 바, 독일 연방헌법재판소는 “결혼과 가족은 국가질서의 특별한 보호를 받는다”고 규정하고 있는 독일기본법 제6조 제1항이 독일인과 혼인한 외국인 배우자의 강제추방(Abschiebung)에 대하여 절대적 장애가 되지는 않으며 독일인 배우자와의 혼인의 보호를 이유로 하는 체류허가 여부는 관계당국의 재량사항이라고 판시하고 있다.[376]

법인이 거주·이전의 자유의 주체가 될 수 있는가 하는 문제에 관하여는 견해가 다를 수 있으나, 거주·이전의 자유는 경제활동의 자유로서의 성격이 강하기 때문에 사법인에 대하여는 그 주체성이 인정된다고 한다.[377] 그러나 공법인에 대하여는 기본권의 반전을 초래하기 때문에 거주·이전의 자유를 인정하기 곤란하다.[378]

외국법인은 외국인에 준하여 입국의 자유는 인정되지 않으나, 입국이 허용된 외국법인의 국내 거주·이전의 자유와 출국의 자유는 당연히 인정된다고 할 것이다.

4. 내용 및 효력

(1) 내용

이러한 거주·이전의 자유에는 국내에서의 거주·이전의 자유뿐 아니라 국외 이주의 자유, 해외여행의 자유 및 귀국의 자유가 포함된다.[379] 또한, 국적이탈·변경의 자유를 내용으로 한다.[380]

---

374) 국제인권규약 제12조 제4항.

375) 김선일, 제12조 거주이전의 자유, 「공익과 인권」 제2권 제2호, 서울대학교 BK21 법학연구단 공익인권법연구센타, 2005. 8, 91~94면 참조.

376) BVerfGE 19, 394(397); 35, 382(408); 51, 384(397).

377) I. v. Munch/Kunig, a. a. O., S. 684.

378) I. v. Munch/Kunig, a. a. O., S. 677.

379) 다만, 아프가니스탄 등 일정한 국가로의 이주, 해외여행 등을 제한하는 여권법에 의한 외교통상부 장관의 고시로 인하여 청구인들의 거주·이전의 자유가 일부 제한된 점은 인정되지만 그러한 제한이 헌법에 위배되는 것은 아니다(헌법재판소 2008. 6. 26. 2007헌마1366).

380) 따라서 현재의 국적을 포기함으로써 국적을 상실하는 경우뿐만 아니라 외국의 국적을 취득함으로써 기존 국적을 상실하는 경우를 포함한다(외국국적취득에 의한 국적 상실에 관하여는 국적법 제15조, 이중국적자의 국적상실에 관하여는 국적법 제10조 제1항 및 제2항, 국적법 제12조 참조).

그러나 무국적의 자유는 인정되지 않고, 따라서 국적은 박탈되지 않으며,[381] 탈세의 목적 또는 병역기피의 목적으로 국적을 변경하는 것은 거주·이전의 자유에서 보호되지 않는다.

주소라 함은 생활의 중심이 되는 곳으로서(민법 제18조) 항구적인 정주의 의사를 가진 장소를 말하며, 반드시 하나이어야 하는 것은 아니다.[382] 주소를 알 수 없으면, 거소를 주소로 본다(민법 제19조).

거소는 일시적으로 체재하는 장소를 말하는 바, 여기서 "체재"라 함은 단지 일시적으로 머무는 것을 의미하는 것으로 그 성립에는 확정적인 기간과 의의가 필요하며,[383] 예컨대, 회의참여를 위해 어떤 곳에 오후마다 머무는 것은 거주·이전의 자유의 보호 하에 속하는 체재라고 할 수 있으나, 쇼핑 또는 산책은 거주·이전의 자유가 아니라 헌법 제10조의 행복추구권에 의하여 보호된다고 보아야 한다.

거주·이전의 자유에 있어서 거주·이전의 목적은 불문하기 때문에 직업 내지 영업을 위한 거주나 단순한 휴양, 방문관광, 여행을 위한 거주·이전도 모두 그 보호대상이 된다. 다만, 일정한 직업을 위한 거주의무의 수행과 같은 경우에는 직업의 자유의 보호영역에 관련된다고 보아야 한다.

이전의 자유에는 자유로운 퇴거, 종전의 장소와 새로운 장소 사이의 길을 선택하는 자유, 일정한 길이나 일정한 방법이 아닌 자유로운 이동이 포함된다. 이전을 위한 이동방법이나 교통수단은 거주·이전의 자유의 보호대상이 아니지만, 이전을 위한 유일한 교통수단의 사용에 대한 방해는 거주·이전의 자유에 대한 침해가 된다.

독일연방헌법재판소는 거주·이전의 자유에 입국의 자유만 포함시키고,[384] 출국의 자유는 제외하고 있다.[385] 그 결과 독일연방헌법재판소는 일반적 행동의 자유를 보장하고 있는 독일 기본법 제2조 제1항에서 출국의 자유의 헌법적 근거를 구하고 있다.[386]

⑵ 효력

거주·이전의 자유는 국가에 대한 방어적 권리로 기능하는 대국가적 효력을 가질 뿐 실행적 권리는 아니며, 개인의 주관적 청구가 없더라도 국가행위에 대한 정책에서 추론될 수 있다. 사인 간에는 간접적으로 적용되는 대사인적 효력을 가진다.[387]

5. 제한 및 한계

⑴ 제한

1) 일반적 제한

거주·이전의 자유는 기본권제한의 일반원칙인 헌법 제37조 제2항에 따라 법률로 제한할 수 있는 바, 그 제한의 목적에 따라 분류하여 보면, 우선 국가안보의 목적을 위한 제한 법률로서 국가보안법, 군사시설보호법, 해군기지법, 공군기지법 등이 있고, 질서유지를 위한 제한 법률로

---

381) 독일기본법 제16조 제1항 : 독일인의 국적은 박탈되지 아니한다. 국적의 상실은 법률에 근거하여서만 행해지고, 이로 인하여 당사자가 무국적이 되지 않는 때에만 당사자의 의사에 반하여 국적이 상실될 수 있다.

382) B. Pieroth/B. Schlink, Grundrechte Staatrecht II, 22. Aufl., C. F. Muller, 2006, S. 198.

383) B. Pieroth/B. Schlink, ibid.

384) BVerfGE 2, 266.

385) BVerfGE 6, 32(34).

386) BVerfGE 6, 32, 34ff.

387) I. v. Munch/Kunig, a. a. O., S. 677.

사회보호법상의 보호처분, 소년법·경찰관 직무집행법상의 보호조치·처분, 보안관찰법상의 처분, 소방법, 민방위기본법 등이 있으며, 공공복리를 위한 제한 법률로는 전염병예방법, 마약법, 결핵예방법, 소방법, 도시계획법 등이 있다.

<헌법재판소 1996. 6. 26. 96헌마200>
선거일 현재 계속하여 90일(현행=60일) 이상 당해 지방자치단체의 관할구역안에 주민등록이 되어 있을 것을 입후보의 요건으로 하는 이 사건 법률조항(공직선거법 제16조 제3항)으로 인하여 거주·이전의 자유가 침해되었다고 할 수는 없다.

2) 민사법상의 제한

거주·이전의 자유는 가족관계에 관한 민사법의 규정에 의하여 제한될 수 있는 바, 민법 제914조에 의한 친권자의 미성년자에 대한 주거지정권, 민법 제826조 제2항의 부부동거의무 등이 이에 속한다.

3) 특수신분에 의한 제한

특수신분을 지닌 국민은 그 신분으로 인하여 일반국민과 달리 거주·이전의 자유가 예외적으로 제한될 수 있다. 예컨대 군인의 영내거주(병역법 제18조 제1항, 군인복무규율 제29조 제1항), 수용자의 거주지 제한(형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률) 등이 이에 속한다.

⑵ 제한의 한계

국가안보 등 목적을 위하여 거주·이전의 자유를 법률로 제한하는 경우에도 그 본질적 내용은 침해할 수 없으며, 따라서 거주·이전의 허가제는 위헌이라고 보아야 한다. 거주·이전의 자유로운 수행을 방해하거나 제약하는 경우 거주·이전의 자유는 침해되게 되는 바, 일부에서는 거주·이전의 자유의 직접적인 침해가 있어야 하고 간접적인 침해로는 충분하지 않다고 하나, 간접적인 침해로도 충분하다고 보아야 한다.

<헌법재판소 1996. 3. 28. 94헌바42> 지방세법 제138조 제1항 제3호 위헌선언
법인의 대도시 내의 부동산등기에 대하여 통상세율의 5배를 규정하고 있다 하더라도 그것이 대도시 내에서 업무용부동산을 취득할 정도의 재정능력을 갖춘 법인의 담세능력을 일반적으로 또는 절대적으로 초과하는 것이 아니어서 직업수행의 자유나 거주·이전의 자유가 형해화할 정도에 이르러 본질적인 내용을 침해한 것은 아니다.

♣ 문제풀이

1. 다음 거주·이전의 자유에 포함되지 않는 것은?

① 해외여행의 자유　② 국적이탈의 자유
③ 거주·이전의 자유　④ 출국의 자유
⑤ 외국인의 입국의 자유

[정답] ⑤
[해설] 외국인의 입국의 자유는 제한된다.

2. 다음 중 거주·이전의 자유에 위배되는 것은?

① 병역미필자의 출국의 자유의 제한
② 법원의 판결에 의해 자국민의 입국거부
③ 군사상 필요에 의한 일정지역의 거주제한
④ 전염병 예방을 위하여 일정지역의 출입제한
⑤ 친권자의 미성년자에 대한 주거지정

[정답] ②
[해설] 입국의 자유는 제한할 수 없다.

3. 다음 거주·이전의 자유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 상대적 자유권이다.
② 법인은 거주·이전의 자유에 의한 보호를 받을 수 있다.
③ 복합적 성격을 가진 기본권이다.
④ 외국인은 일정한 제한을 받는다.
⑤ 무국적의 자유도 포함된다.

[정답] ⑤
[해설] 무국적은 포함되지 않는다.

♣ 요점정리

1. 거주·이전의 자유는 1919년 바이마르헌법 제111조에서 최초로 명문화되었다.

2. 우리나라는 제헌 헌법 제10조에서 “모든 국민은 법률에 의하지 아니하고는 거주와 이전의 자유를 제한받지 아니하며 주거의 침입 또는 수색을 받지 아니한다”고 처음 규정하였다.

3. 거주·이전의 자유라 함은 국민이 자기가 원하는 모든 장소에 주소나 거소를 설정하고, 체류하거나 이전하며, 그 의사에 반하여 거주 또는 체류의 장소를 이전하지 아니할 자유를 말한다.

4. 우리나라 국적을 가진 자연인인 국민은 당연히 거주·이전의 자유를 향유하지만 미성년자는 기본권능력은 보유하고 있으나, 성년에 이르기까지 민법 제914조의 친권자의 거소지정권에 의하여 제한을 받는다.

5. 거주·이전의 자유는 국가에 대한 방어적 권리로 기능하는 대국가적 효력을 가질 뿐 실행적 권리는 아니며, 개인의 주관적 청구가 없더라도 국가행위에 대한 정책에서 추론될 수 있다. 사인 간에는 간접적으로 적용되는 대사인적 효력을 가진다.

6. 선거일 현재 계속하여 90일(현행=60일) 이상 당해 지방자치단체의 관할구역안에 주민등록이 되어 있을 것을 입후보의 요건으로 하는 공직선거법 제16조 제3항은 거주·이전의 자유를 침해하지 않는다.

제24강 직업선택의 자유

♣ 학습목표

직업선택의 자유를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

바이마르헌법 제111조
현행헌법 제15조
직업선택의 자유
직업수행의 자유
직업선택의 주체
직업의 자유와 영업의 자유의 관계
약국판결
단계이론

♣ 사전테스트

1. 직업의 자유를 처음으로 규정한 헌법은 1919년 바이마르헌법이다.
   정답 : O
   해설 : 1919년 바이마르헌법 제111조이다.

2. 우리나라에서 직업의 자유가 헌법상의 명문으로 처음 규정된 것은 제3공화국헌법이었다.
   정답 : O
   해설 : 1962년 제5차 개정헌법(제3공화국 헌법)이다.

3. 직업선택의 자유는 직업수행 내지 행사의 자유까지 포괄하는 직업의 자유를 의미한다고 하고 있다.
   정답 : O
   해설 : 헌법재판소 1997. 3. 13. 94헌마196 등.

♣ 돌발퀴즈

우리 헌법재판소는 직업개념의 3요소로서 생활수단성, 계속성, 공공무해성을 제시하고 있다.

[정답] X

[해설] 우리 헌법재판소는 직업이란 생활의 기본적 수요를 충족시키기 위한 계속적인 활동, 즉 총체적이며 경제적 성질을 가지는 모든 소득활동을 의미하며, 이러한 활동인 한 종류나 성질을 불문한다고 하여 공공무해성의 개념을 제외시키고 있다(헌법재판소 1993. 5. 13. 92헌마80).

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

직업은 인간이 생활을 영위해가기 위해서 행하는 활동이라는 것은 말할 것까지도 없다. 또한, 인간은 직업을 통하여 사회의 존속과 발전에 기여한다. 그뿐만 아니라 인간은 자기를 완성하기 위한 존재이유의 하나로서 직업을 선택한다. 그러나 이와 같은 직업을 인간이 자기의 의사에 따라 결정·선택 하고 종사하게 된 것은 근대 이후이다. 근대 이전에는 사회적 지위, 즉 신분에 의해서 직업이 고정·세습되었고, 특히 각종 동업조합에는 특권이 부여됨으로써 그 조합원 이외의 사람들에게는 영업이 배척되었다. 그러던 것이 근대의 시민사회가 성립되면서 근대적인 소유권제도와 사회적 가치를 기초로 한 자본주의의 경제질서가 확립되자 거주·이전의 자유와 직업의 자유가 필연적으로 인정되기에 이르렀다.

직업의 자유를 최초로 선언한 문서로는 중농학파의 영향을 받아 근로에의 권리와 직업의 자유를 선언한 1776년 2월의 길드(동업조합)폐지에 관한 프랑스 루이14세의 칙령을 들 수 있다. 그러나 직업의 자유를 처음으로 규정한 헌법은 1919년 바이마르헌법 제111조이다.

우리나라의 경우 직업의 자유가 헌법상의 명문으로 규정된 것은 제3공화국헌법이었다. 그 이전에는 직업의 자유가 자유권의 포괄성에 의해서 보장되는 권리라는 설(박일경)과 거주·이전의 자유 중에 포함되는 권리라는 설(한태연)이 주장되어 직업의 자유를 기본권으로 인정해 왔다. 제3공화국헌법과 제4공화국헌법과 제4공화국헌법은 각각 제13조에서 “모든 국민은 직업선택의 자유를 가진다”라고 규정하고 있었다. 제5공화국헌법은 제14조에서 현행헌법은 제15조에서 조문만 바뀌었을 뿐 이전의 헌법과 같은 규정을 두었다.

2. 의의 및 법적성격

(1) 의의

직업이란 생활의 기본적 수요를 충족시키기 위한 계속적 소득활동을 의미하며, 그러한 내용의 활동인 한 그 종류나 성질을 불문한다고 정의하고 있다.[388] 또한, 일반적으로 어떤 활동이 직업으로서 인정되기 위해서는 단순한 취미활동이 아니라 생활의 기초를 형성하고 유지하는데 필요한 활동일 것, 법공동체의 가치관에 의하여 허용되는 활동일 것, 그 활동이 일정기간 계속되는 계속성을 가질 것이 요구된다고 한다.[389]

이와 같이 통상적으로 직업개념의 3요소로서 생활수단성, 계속성, 공공무해성을 들고 있는데[390] 여기에서 이러한 직업개념에 대하여 법적인 허용성이 그 개념요소로서 들어가야 하는가 의문을 갖는 견해가 제시되고 있다. 즉, 공공무해성이 직업의 개념요소의 하나로 인정하게 되면 공공에 유해가 되는 직업활동은 헌법상 직업개념에서 배제된다는 논리가 그것이다. 즉, 이러한 논리를 인정하게 되면 헌법상 규정되어야 할 직업개념이 헌법에 우선하여 법률에 의해서 배제됨으로써 헌법과 법률의 효력우위가 뒤바뀌게 된 것이다 다름없는 논리가 성립하게 된다.

그러나 직업의 개념요소에 공공무해성을 요하는 것으로 하면 공공에 유해한 것으로 평가될 수 있는 매춘행위는 직업으로 볼 수 없게 된다. 즉, 이들 행위가 직업선택의 자유의 보호영역 밖의 행위가 되므로 법률로 이들 행위를 금지하는 것은 전혀 직업선택의 자유를 제한하는 문제

388) 헌법재판소 1993. 5. 13. 92헌마80; 1997. 3. 27. 94헌마196 등.
389) I. v. Munch/P. Kunig, Grundgesetz-Kommentar, Band. Ⅰ-2, 4. Aufl., 1992, S. 706.
390) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 526면; 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 444면.

와 상관이 없게 된다. 우리 헌법재판소는 직업이란 생활의 기본적 수요를 충족시키기 위한 계속적인 활동, 즉 총체적이며 경제적 성질을 가지는 모든 소득활동을 의미하며, 이러한 활동인 한 종류나 성질을 불문한다고 하여 공공무해성의 개념을 제외시키고 있다.[391]

직업선택의 자유는 직업수행 내지 행사의 자유까지 포괄하는 직업의 자유를 의미한다고 하고 있다.[392] 즉, 헌법 제15조의 직업선택의 자유를 자신이 원하는 직업을 자유로이 선택하고 이에 종사하는 등 직업에 관한 종합적이고 포괄적인 자유로 이해하고 있다. 따라서 현행헌법상의 직업선택의 자유는 직업의 자유를 의미한다.

직업선택의 자유에는 원하는 직업내지 직종을 자유롭게 결정할 수 있는 직업결정의 자유, 한번 선택한 직업을 계속해서 가지고 직업의 계속의 자유, 선택한 직업을 버리고 또 다른 직업을 선택하는 '직업포기·변경·이탈의 자유'를 비롯하여 원하는 직업 내지 직종에 종사하는데 필요한 전문지식을 습득하기 위한 직업교육장선택이 직업교육 후의 직업선택과 불가분의 상호 관계를 가지고 있기 때문에 직업교육장선택의 자유도 포함된다.

직업수행의 자유에는 선택한 직업을 영위하면서 사회적·경제적 상호관계를 형성해가는 직업수행의 자유, 선택한 직업을 수행해나가는 방법으로 직장을 구하거나 임의로 직장을 옮기는 등의 직장선택의 자유를 포함되는 것으로 이해할 수 있다. 직장이란 장소적 의미에서 이해하든지 고용주와의 관계에서 보든지 이와 관계없이 구체적인 경우에 직업활동이 수행될 수 있는 장소를 말한다. 이러한 직장선택의 자유란 직장의 선택, 유지, 포기 그리고 직장을 바꿀 수 있는 자유를 말한다.[393]

또한, 직업선택의 자유는 행복추구권의 한 내용인 인격발현권을 구체화한다. 따라서 직업선택의 자유와 행복추구권은 특별법과 일반법의 관계에 놓이게 된다.[394]

⑵ 법적성격

직업의 자유는 자유민주적 헌법질서 내에서 개성신장의 수단으로서 주관적 공권(방어권)으로서 성격을 갖는다. 왜냐하면 직업의 자유는 개인의 삶을 형성해 나가는 한 부분이며, 사유재산제를 기본으로 하는 사회에서 개인이 창의와 능력을 발휘하여 자유로운 인격의 발현을 기하는데 없어서는 안 되는 자유이기 때문이다.[395]

또한, 직업의 자유는 국가의 형성요소로서 객관법적 질서의 성격도 갖는다. 즉, 국가의 사회질서와 경제질서는 국민 개개인이 선택한 직업의 수행에 의하여 형성되기 때문에 직업의 자유는 사회적 시장경제질서의 불가결한 요소로서 객관적 가치질서로서의 기능도 갖는다.[396]

<헌법재판소 1995. 7. 21. 94헌마125> 영화법 제26조 등 위헌확인

직업의 자유는 각자의 생활의 기본적 수요를 충족시키는 방편이 되고 또한 개성신장의 바탕이 된다는 점에서 주관적 공권의 성격이 두드러진 것이기는 하나, 다른 한편으로는 국민 개개인이 선택한 직업의 수행에 의하여 국가의 사회질서와 경제질서가 형성된다는 점에서 사회적 시장경제질서라고 하는 객관적 법질서의 구성요소이기도 하다.

---

391) 헌법재판소 1993. 5. 13. 92헌마80.
392) 헌법재판소 1997. 3. 13. 94헌마196 등.
393) I. v. Munch, Grundgesetz, 1974, S. 398ff.
394) BVerfGE 22, 114(120); 30, 292(334, 355f.).
395) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 107면 참조.
396) 헌법재판소 1989. 11. 20. 89헌가92; 1990. 10. 15. 89헌마178; 1996. 8. 29. 94헌마113; 1997. 4. 24. 95헌마273 등.

3. 주체

통설은 직업선택의 자유를 원칙적으로 자연인인 국민과 사법인에 한정시키고 있다.

이에 대해서 모든 기본권주체는 기본권능력의 범위 내에서 직업의 자유의 주체가 된다고 보는 것이 합리적이라는 소수설도 있다.[397]

외국인의 경우, 호혜주의적 입장에서 변호사법 제6조, 도선법 제6조, 공증인법 제12조, 광업법 제6조 등에서 직업의 자유를 제한받는다.[398]

<헌법재판소 1996. 3. 28. 94헌바42>

법인도 직업수행의 자유(영업의 자유)의 주체가 될 수 있다.

4. 직업의 자유와 영업의 자유의 관계

다수설과 판례는 영업의 자유는 직업수행의 자유의 일환으로 당연히 직업의 자유에 포함된다고 본다.

그에 반하여 소수설은 직업의 자유의 주체가 자연인인 경우에는 영업은 직업의 한 형태이므로 당연히 직업의 자유의 내용으로 간주될 수 있으나 법인이 직업의 자유의 주체인 때에는 법인의 기능상 당연히 영업의 자유를 의미하는 것으로 본다.[399]

그러나 법인은 그 기관에 의하여 행동하며, 기관의 행위는 자연인의 행위와 구별할 수 없기 때문에 영업의 자유는 다수설과 판례의 태도가 설득력이 있다. 다만, 법인은 특정목적을 수행하기 위하여 설립되는 것이라는 속성상 무직업의 자유는 누릴 수 없다고 보아야 한다.[400]

<대법원 1994. 3. 8. 92누1728>

헌법 제15조는 기본적 인권의 하나로서 직업선택의 자유를 보장하고 있는 데, 이 규정에 의하여 보장되는 자유 가운데는 본래 의미에서의 직업선택의 자유뿐만 아니라 선택한 직업에 종사하면서 그 활동의 내용·태양 등에 관하여도 원칙적으로 자유로이 결정할 수 있는 직업활동의 자유도 포함된다.

5. 효력

대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력이 인정된다. 그러나 대법원은 영업상 자유의 대사인적 효력을 일반적으로 인정하지 않는다.

<대법원 1964. 5. 19. 63다915> 일방에게 불리한 계약을 맺은 자의 계약해약권

피고가 사단법인 대한환경위생협회 서울지부 미용분과위원회에서 협정한 요금 및 공휴일을 준수함과 동시에 종업원의 유인고용을 하지 않을 것을 약정하고 위 사항을 위반할 때에는 위약금 10,000원을 원고에게 지급한다는 내용의 약정은 피고의 영업상 활동의 자유를 일방적으로 제함함에 그치는 것이므로 이와 같은 영업상 자유의 제한에 관한 협정을 무기한 허용함은 피고

397) 허영, 전게서, 445면.
398) 홍성방, 전게서, 108면.
399) 허영, 전게서, 445면.
400) 홍성방, 전게서 112면.

의 법률상 지위에 중대한 제한을 주는 것으로서 이와 같은 약정은 제한을 받는 자가 일방적으로 해약할 수 있다.

6. 제한 및 한계

내심의 자유로서의 성격을 갖는 직업결정의 자유를 제외하고는 직업의 자유는 제37조 제2항에 의하여 제한될 수 있다.

구체적으로 국가안전보장을 위하여 방위산업물자 생산자는 지식경제부장관이 정하며(방위산업법 제35조), 화약류의 제조·판매 등에는 허가가 있어야 한다(총포·도검·화약류 등 단속법 제5조, 제7조), 질서유지를 위하여 허가를 받아야 숙박업·음식점영업·목욕탕영업·광업·수산업·은행업·직업소개업·고물상영업 등을 할 수 있으며, 의사·치과의사·간호사·조산사·약사 등은 자격이나 면허가 요구된다.

<대법원 1990. 10. 16. 90도1649>

식품영업에 관하여 당국의 허가를 받도록 규정한 식품위생법 제22조 제1항의 규정이 헌법 제10조의 행복추구권조항, 제11조 제1항의 평등권조항, 제15조의 직업선택의 자유조항에 위배된 규정이라고 할 수 없다.

<헌법재판소 1991. 9. 16. 90헌마231> 한약업사의 허가 및 영업행위에 대한 지역적 제한규정

한약업사의 허가 및 영업행위에 대한 지역적 제한을 가한 내용의 약사법 제37조 제2항은 체계상 한약업사의 지위는 약사가 없는 한지에서 약사업무의 일부를 수행하는 보충적 직종에 속하는 것이므로 한약사가 영업지제한의 규제를 받는 것이 그의 거주이전의 자유 또는 직업선택의 자유를 제한하는 것이거나 평등의 원칙을 위배하는 것은 아니다.

<헌법재판소 1996. 4. 25. 95헌마331> 법무사법 시행규칙 제35조 제4항

법무사의 사무원총수(법무사포함)를 5인 초과할 수 없도록 한 것은 법무사직원의 업무의 공공적 성격이 크며(업무수행의 특수성), 업무수행과 관련하여 부정과 부담이 개입할 가능성이 높은 바, 이와 같은 문제점을 해결하기 위한 수단으로 인원수를 제한한 것이 반드시 적절한 방법이라고 할 수는 없으나 선택된 수단이 현저하게 불합리하고 불평등한 것이 아니라면 입법재량에 속하는 것으로 볼 것이므로 합헌이다.

제한하는 경우에도 비례의 원칙을 준수해야 하며, 직업의 자유의 본질적인 내용을 침해해서는 안 된다.

7. 직업의 자유의 제한에 대한 단계이론

⑴ 개요

독일연방대법원은 '약국결정'에서 심판의 대상된 바이에른 州의 '약국법' 조항을 위헌으로 결정하였다. 구체적으로는 새로운 약국의 개설을 약국에 대한 수요가 있는 경우에 한하여 허가함으로써 소위 객관적 허가요건을 규정하고 있었다. 입법자가 약국개설을 제한한 목적은 국민의

건강유지였다. 입법자는 지나치게 많은 약국이 자유롭게 경쟁하게 되면 법률에 의하여 부과된 의무의 이행해태, 경솔한 의약품판매, 의약품의 소비를 조장하는 의약품광고, 건강을 해치는 의약품 남용현상이 발생 할 것을 우려하였다. 연방헌법재판소는 위와 같은 입법목적을 직업수행에 대한 규율, 의약품생산에 대한 국가의 통제, 광고의 자유 및 매매의 자유에 대한 제한을 통해서 달성할 수 없는지를 검토하였는데, 그 결과 직업의 자유를 보다 적게 제한하는 다른 방법으로도 입법목적을 달성할 수 있다고 판단함으로써 위 심판대상조항에 대하여 위헌결정을 하였다.[401]

동 판결에서 직업의 자유에 대한 제한의 형태를 제한의 강도에 따라 직업행사의 자유에 대한 제한(직업행사에 관한 규정), 주관적 사유 및 객관적 사유에 의한 직업선택의 자유의 제한(직업허가규정)으로 구분하여, 제한의 강도가 높아짐에 따라 입법자의 형성의 자유는 축소되고 직업의 자유에 대한 제한은 보다 엄격한 요건 하에서 정당화된다는 소위 '3단계 이론'을 구성하였다.

1) 제한된 자유영역의 의미에 따른 제한의 허용 정도

일반적으로, 제한되는 자유영역의 의미가 개인의 인격발현에 대하여 크면 클수록 자유권에 대한 보호는 더욱 강화되는 반면, 개인이 직업활동 또는 사회적·경제적 활동 등을 통하여 타인과 사회적 연관관계에 위치함으로써 타인의 자유영역과 접촉하고 충돌할수록 입법자가 타인과 공동체의 이익을 위하여 개인의 자유를 제한하는 것을 보다 수인해야 한다.

마찬가지로 직업의 자유를 제한하는 국가공권력의 조치가 개인의 인격발현에 어느 정도로 영향을 미치는가에 따라 직업의 자유에 대한 제한을 허용하는 정도, 즉 입법자의 형성권이 달라진다. 직업의 자유에 대한 제한이라 하더라도, 직업선택 그 자체에 대한 제한은 직업에서 인생의 과제를 찾으려는 개인의 인격발현의 길을 처음부터 봉쇄하는 것이므로 개인의 자유로운 인격발현에 대한 침해가 중대하다. 그러므로 기본권의 주체가 아무런 영향을 미칠 수 없는 소위 객관적 사유(예컨대, 동일업종에 종사하는 사업자 수의 제한, 수요의 심사)에 의한 직업선택의 자유에 대한 제한은 대단히 중대한 공익에 의하여 정당화되어야 하며 매우 엄격한 요건을 갖춘 예외적인 경우에만 허용된다.

이에 대하여 소위 주관적 사유에 의한 직업선택의 자유에 대한 제한과 직업행사의 자유에 대한 제한은 기본권의 주체가 허가요건의 충족에 스스로 영향을 미칠 수 있거나 아니면 일단 선택한 직업의 행사방법을 제한하는 것이므로, 인격발현에 대한 침해의 정도가 상대적으로 작다고 볼 수 있다. 따라서 이러한 경우, 입법자에 의한 보다 광범위한 규율이 정당화된다.

2) 직업선택의 자유에 대한 제한에 있어서 주관적·객관적 허가요건의 구분

직업선택의 자유에 대한 제한은 직업활동의 허가에 관한 것이므로, '직업허가요건'으로 부르기도 한다.

주관적 허가요건이란 허가여부를 기본권주체의 개인적 특징에 결부시키는 경우로서, 허가요건이 기본권주체의 책임범위 내에 존재한다. 기본권주체의 개인적 특징으로서 그의 책임범위에 귀속될 수 있는 특징이라면, 기본권주체가 요건의 충족여부에 영향을 미칠 수 없는 특징이라 하더라도(예컨대, 연령이나 신장), 주관적 허가요건에 속한다.[402]

이에 대하여 객관적 허가요건이란 허가여부를 기본권주체의 개인적 특성과 무관한 요건에 결부시키는 경우로서, 허가요건이 기본권주체의 책임영역 밖에 존재한다.[403] 주관적 허가요건의 경우, 입법자는 규율하고자 하는 생활관계로부터 스스로 제기되는 요청을 단지 구체화하는 것이

401) BVerfGE 7, 377, 404ff.
402) Sachs, Verfassungsrecht II Grundrechte, 2000, S.416.
403) Breuer, Die staatliche Berufsregelung und Wirtschaftslenkung, in : HStR VI, 1989, §148 Rn. 47.

다. 개인에게는 당해 직업을 정상적으로 수행하기 위하여 사물의 본질상 원칙적으로 수인해야 하는 것만이 주관적 허가요건의 형태로 요구된다.[404] 주관적 허가요건은 사물의 본성, 즉 직업활동의 요청으로부터 스스로 나오는 것이고, 기본권주체가 일반적으로 충족시킬 수 있는 개인적 특성으로 자신의 책임범위 내에 존재하는 것이기 때문에, 직업의 자유의 관점에서도 헌법적으로 큰 의문이 제기되지 않지만, 객관적 허가요건은 직업활동의 요청에 의하여 정당화되지 않으며, 기본권주체가 요건의 충족에 영향을 미칠 가능성이 없다는 점에서 직업의 자유에 대한 보다 강력한 제한에 해당한다. 객관적 허가요건은 직업의 정상적인 수행을 위하여 요구되는 모든 주관적 요건을 충족시킨 사람에 대해서도 자신의 힘으로 극복할 수 없는 진입장벽을 의미한다.

3) 제한의 정당성 요건의 차등화

단계이론에 의하면, 직업선택의 자유는 단지 '중대한 법익'의 보호를 위하여 제한될 수 있다. 직업의 행사를 규율하는 경우, '합리적인 공익상의 이유'만으로도 충분한 반면, 자유로운 직업선택을 입법적으로 제한하는 것은 중대한 공익의 보호를 위하여 반드시 필요한 것이어야 한다. 뿐만 아니라 객관적 직업허가요건의 형태로 직업선택의 자유를 제한하는 경우에는 입법자의 형성권은 다시 제한된다.

이 경우, 직업의 자유에 대한 제한은 중대한 법익에 대한 입증할 수 있는 또는 고도의 개연성이 있는 중대한 위험의 방지를 위하여 불가결한 것이어야 한다.[405]

⑵ 구체적 내용

1) 직업행사의 자유의 제한

'직업행사의 자유에 대한 제한'이란, 직업의 선택을 금지하거나 직업에의 접근 자체를 봉쇄하는 것이 아니라, 일단 선택한 직업을 구체적으로 행사하는 방법에 대하여 제한하는 경우를 말한다.

직업행사의 자유를 제한하는 법률은 '합리적이고 이성적인 공익'에 의하여 정당화되어야 한다.[406] 직업행사규정에서 입법자는 가장 광범위한 제한권한을 가진다. 여기서 기본권의 보호는

---

404) 그러므로 이러한 자유제한은 발생할 수 있는 손해나 위험의 방지를 위한 적합한 수단으로 간주된다. 또한, 주관적 요건이 모든 직업지원자에 대하여 평등하게 적용되고, 모든 지원자가 주관적 요건의 존재를 사전에 알고 있어서 그 요건을 충족시키는 것이 가능한지를 직업선택 전에 판단할 수 있으므로, 이러한 자유제한은 부당하지 않다. 여기서는 정해진 주관적 요건이 직업의 정상적인 수행이라는 목적과 비례관계를 벗어나서는 안 된다는 의미에서 과잉금지원칙이 적용된다(BVerfGE 7, 377, 404ff.).

405) 객관적 허가요건은 기본권의 정신에 정면으로 반한다. 왜냐하면, 심지어 주관적 허가요건을 충족시킴으로써 직업을 사실상 선택한 사람까지도 직업의 허가로 부터 배제될 수 있기 때문이다. 직업교육이 長期的이고 전문적일수록, 즉 직업교육의 선택과 동시에 이미 구체적인 직업이 선택되었다는 것이 명백할수록, 이러한 형태의 자유제한은 보다 중대하게 느껴진다. 게다가, 전문적으로 교육을 받은 지원자가 특정 직업을 행사하는 것이 국민일반에 대하여 어떠한 손해를 초래할 것인지가 명확하지 않기 때문에, 이러한 자유제한과 의도하는 목표 사이의 연관관계가 그 효과에 있어서 충분히 납득할 수 있도록 서술될 수 없는 것이 일반적이다. 그러므로 비합리적인 동기가 침투할 위험이 특히 크다. 무엇보다도 직업에의 진입을 제한하는 것이 '이미 직업을 행사하고 있는 사람들'을 경쟁으로부터 보호하는 데 기여한다는 생각이 들게끔 한다. 그러나 이러한 동기는 결코 직업선택의 자유에 대한 제한을 정당화할 수 없는 동기이다. … 그러므로 이와 같이 중대한 자유제한의 필요성을 입증함에 있어서 특별히 엄격한 요건이 제시되어야 한다(BVerfGE 7, 377, 404ff.).

406) 기본권인 직업행사의 자유를 제한하는 법률이 헌법에 저촉되지 아니하기 위하여는 그 기본권의 침해

합리적인 공익상의 고려에 의하여 정당화되지 않는 법률규정의 방어에 제한된다. 직업행사의 자유에 대한 제한의 예로는 상점이나 식당의 영업시간의 제한과 같은 방법적 제한 및 특정 장소에서의 영업 제한과 같은 장소적 제한 등을 들 수 있다.

2) 주관적인 사유에 의한 직업선택의 자유의 제한

특정 직업이 그 성질상 일정한 전문성이나 기술성 등을 요구하는 경우, 그 직업의 정상적인 수행을 보장하기 위하여 직업선택의 여부를 직업지원자가 스스로 충족시킬 수 있는 일정한 조건, 즉 개인적 특성(일정 연령, 신장, 시력, 신뢰성 등), 능력, 일정한 과정의 이수, 시험의 합격, 일정한 학력이나 경력, 자격 등의 요건에 결부시키는 경우를 말한다. 주관적 허가요건의 특징은 직업을 선택하려는 자가 본인의 노력에 의하여 그 요건을 충족시킬 수 있고, 이로써 그 제한으로부터 벗어날 수 있다는 것이다.

주관적 요건에 의한 직업선택의 자유 제한이 과잉금지원칙의 관점에서 정당화되기 위해서는 주관적 허가요건과 '직업의 정상적인 수행'이라는 목적 사이에 합리적인 관계가 성립해야 한다. 즉, 오늘날 다수의 직업이 그 직업의 정상적인 수행을 위하여 전문성과 특정한 개인적 특성을 요청한다는 상황에 비추어, 주관적 요건의 제한 없이 누구나 직업에 종사할 수 있도록 한다면 직업의 정상적인 수행을 보장할 수 없거나 국민일반에 대한 위험이나 손해가 발생할 우려가 있는 경우, 입법자는 주관적 허가요건을 도입할 수 있다.[407]

주관적 허가요건을 정당화하는 중대한 공익으로는 예컨대, '직업의 정상적인 수행'을 비롯하여 국민건강, 소비자의 보호, 도로교통에서의 안전 등이 고려된다. 주관적 허가요건에 관한 예로는, 일정 직업에 있어서 그 직업의 정상적인 수행을 보장하기 위하여 요구되는 최소한의 요건(예컨대 학력, 경력, 일정 자격요건 등)을 규정하는 각종 자격제도와 면허제도(의사, 약사, 변호사, 변리사, 건축사, 세무사, 공인중개사 등)를 들 수 있다.

3) 객관적 사유에 의한 직업선택의 자유의 제한

가. 객관적 허가요건

이는 직업선택의 여부를 직업을 선택하려는 자의 개인적인 능력이나 자격과는 하등의 관계가 없는 요건에 결부시키는 경우, 즉 개인이 그 요건의 충족에 아무런 영향을 미칠 수 없는 경우를 말한다. 기본권주체의 책임영역 외부에 존재하는 객관적 허가요건은 직업수행에 적합한 지원자의 진입을 차단하는 극단적인 수단으로서 개인의 인격발현에 대한 제한의 정도가 매우 크기 때문에, 엄격한 요건을 갖춘 예외적인 경우에만 허용된다. 즉, '월등하게 중대한 공익'에 대한 '명백하고 현존하는 위험'(입증할 수 있거나 고도의 개연성이 있는 중대한 위험)을 방어하기 위한 경우에 한하여, 기본권의 주체가 자력으로 충족시킬 수 없는 객관적인 사유에 의한 제한이 정당화될 수 있다.[408]

가 합리적이고 이성적인 공익상의 이유로 정당화될 수 있어야 한다(헌법재판소 2002. 9. 19. 2000헌바84 : 법인의 약국개설금지).

407) BVerfGE 7, 377, 407; 이와 유사한 내용으로 일반적으로 직업선택의 자유를 제한함에 있어, 어떤 직업의 수행을 위한 전제요건으로서 일정한 주관적 요건을 갖춘 자에게만 그 직업에 종사할 수 있도록 제한하는 경우에는 이러한 주관적 요건을 갖추도록 요구하는 것이, 누구에게나 제한 없이 그 직업에 종사하도록 방임함으로써 발생할 우려가 있는 공공의 손실과 위험을 방지하기 위한 적절한 수단이고, 그 직업을 희망하는 모든 사람에게 동일하게 적용되어야 하며, 주관적 요건 자체가 그 제한목적과 합리적인 관계가 있어야 한다는 비례의 원칙이 적용되어야 할 것이다(헌법재판소 1995. 6. 29. 90헌바43 : 군법무관의 복무기간).

408) BVerfGE 7, 377, 408.

객관적 허가요건에 속하는 것으로, 국가의 독점, 직업의 금지(예컨대, 윤락행위의 금지 등), 동일 업종에 있어서 사업자 수의 제한이나 수요의 심사 등을 들 수 있다. 예컨대, 시내 택시의 수를 제한하는 경우, '지역 대중운송체계의 생존과 기능의 확보'라는 중대한 공익을 위하여 불가결한 경우에 한하여 정당화될 수 있다.

나. 국가가 일정한 경제활동영역을 스스로 독점하는 경우의 객관적 사유에 의한 허가요건

국가가 특정한 경제활동을 독점하는 경우, 개인은 법적으로 특정 직업을 선택할 수 없게 된다. 단계이론에 의하면, 국가에 의한 독점은 객관적 직업허가요건에 해당하므로, 월등하게 중대한 공익에 대한 명백하고 현존하는 위험을 방지하기 위하여 반드시 필요한 경우에만 정당화될 수 있다.[409]

국가나 지방자치단체의 독점적인 경제활동은 국가재정을 충당할 목적으로 사인을 일정 영역의 경제활동으로부터 배제하는 재정독점(예컨대, 카지노 영업의 독점)과 국가가 공적인 과제를 효율적으로 이행하기 위하여 특정한 경제활동을 독점하는 경우(행정독점)로 크게 나누어 볼 수 있다.

헌법이 명시적으로 국가의 전매사업 등 재정독점을 언급함으로써 스스로 직업선택의 자유에 대한 제한을 허용하는 경우가 아니라면, 재정적인 이유에 근거한 국가의 독점적인 경제활동은 직업선택의 자유를 제한하기 위하여 갖추어야 하는 엄격한 요건을 일반적으로 충족시키지 못하기 때문에 원칙적으로 직업의 자유에 위반된다.[410]

이에 대하여, 공적 과제의 이행을 위한 국가의 독점적 경제활동은 '객관적인 사유에 의한 직업선택의 자유의 제한'으로서 특별히 중요한 공익에 의하여 정당화되어야 한다. 행정독점의 경우 설립당시뿐만 아니라 그 이후에도 객관적 허가요건을 정당화하는 사유가 계속 존재해야 하므로, 행정독점의 지속적인 유지도 중대한 공익의 보호를 위하여 불가결하다는 것이 정기적인 심사를 통하여 입증되어야 한다.[411]

♣ 문제풀이

1. 다음 직업의 자유에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 직업선택의 자유에서 직업은 사람이 살아가는 데 필요한 정신적이고 물질적인 생활의 기본적 수요를 충족시키기 위해 행하는 계속적인 경제적 소득활동이다.
② 직업은 영리적인 것인가 비영리적인 것인가를 묻지 아니하므로 고아원을 경영하는 것도 직업이 된다.
③ 영업은 직업보다 협의의 개념이고, 영업의 자유는 헌법상 명문규정에 의해 보장되고 있다.
④ 직업이기 위해서는 항구적일 필요는 없지만 어느 정도의 계속성은 요구된다.
⑤ 직업선택의 자유에는 개인의 직업적 활동을 하는 장소, 즉 직장을 선택할 자유도 포함된다.

[정답] ③

[해설] 영업은 개인의 생활기초를 이루는 계속적·독립적·수익적 활동으로서 직업보다 좁은 개념이다. 현행 헌법에는 영업의 자유에 관한 명문규정이 없으나 학설과 판례에서 헌법상 보장된 자유로 인정하고 있다.

---

409) Friauf, Die Freiheit des Berufes nach Art. 12 Abs. 1 GG, JA 1984, S.541.
410) Papier, Art.12 GG-Freiheit des Berufs und Grundrecht der Arbeit, DVBl, 1984, S.803.
411) Tettinger, Das Grundrecht der Berufsfreiheit in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, AoR 108, 1983, S.122.

2. 다음 중 직업의 자유에 해당하지 않는 것은?

① 직업결정의 자유
② 전직의 자유
③ 겸직의 자유
④ 무직업의 자유
⑤ 양도·이전의 자유

[정답] ⑤
[해설] 양도·이전의 자유는 재산권의 내용에 해당한다.

3. 다음 직업의 자유에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 소득활동이 아닌 단순한 취미활동은 헌법상의 직업이 아니다.
② 헌법 제15조에서의 직업선택의 자유는 직업수행 내지 행사의 자유까지 포함하는 직업의 자유를 의미한다.
③ 형법상 징역형을 선고 받은 수형자 등의 경우에는 무직업의 자유가 인정되지 않는다.
④ 공법상 법인인 공공단체와 지방자치단체도 일정한 경우에 직업선택의 자유의 주체가 될 수 있다.
⑤ 직업과 관련된 시험절차는 직업의 자유라는 기본권이 효율적으로 보장될 수 있도록 실시한다.

[정답] ④
[해설] 사법인은 당연히 주체가 될 수 있으나 공법인에게는 인정되지 않는다.

♣ 요점정리

1. 직업의 자유를 처음으로 규정한 헌법은 1919년 바이마르헌법 제111조이다.

2. 우리 헌법재판소는 직업이란 생활의 기본적 수요를 충족시키기 위한 계속적인 활동, 즉 총체적이며 경제적 성질을 가지는 모든 소득활동을 의미하며, 이러한 활동인 한 종류나 성질을 불문한다고 하여 공공무해성의 개념을 제외시키고 있다.

3. 직업선택의 자유는 직업수행 내지 행사의 자유까지 포괄하는 직업의 자유를 의미한다고 하고 있다.

4. 직업의 자유는 각자의 생활의 기본적 수요를 충족시키는 방편이 되고 또한 개성신장의 바탕이 된다는 점에서 주관적 공권의 성격이 두드러진 것이기는 하나, 다른 한편으로는 국민 개개인이 선택한 직업의 수행에 의하여 국가의 사회질서와 경제질서가 형성된다는 점에서 사회적 시장경제질서라고 하는 객관적 법질서의 구성요소이기도 하다.

제25강 주거의 자유 및 사생활의 비밀과 자유

♣ 학습목표

주거의 자유를 설명할 수 있다.
사생활의 비밀과 자유를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

주거의 개념
주거의 자유의 법적성격
사생활의 비밀과 자유와의 관계
주거의 자유의 주체
주거의 개념
사생활의 자유의 의미
사생활의 자유의 법적성격
사생활비밀 및 자유의 불가침
자기정보통제권
권리포기이론, 공익이론, 공적인물이론

♣ 사전테스트

1. 주거의 자유가 처음 기본권으로 인정된 것은 영국의 대헌장이다.

정답 : X
해설 : 1776년의 버지니아 권리장전 제10조이다.

2. 1948년의 건국헌법 제10조는 개별적 법률유보하에 거주·이전의 자유와 함께 주거의 자유를 처음으로 규정한 이래 현행 헌법에 이르고 있다.

정답 : X
해설 : 1948년 건국헌법 제10조에서 개별적 법률유보하에 거주·이전의 자유와 함께 주거의 자유를 규정하였고, 1960년 제3차 개헌에서 삭제되었다가 1962년 제5차 개헌에서 거주·이전의 자유에서 독립하여 지금과 같이 별개의 조항에서 규정되어(제14조) 현행 헌법에 이르고 있다.

3. 주거의 자유는 내국인만이 아니라 외국인에게도 주체서이 인정되나 무국적자에게는 인정되지 않는다.

정답 : X

해설 : 주거의 자유의 주체는 내국인만이 아니라 외국인이나 무국적자에게도 인정된다.

♣ 돌발퀴즈

사생활의 비밀과 자유는 현행 헌법 제17조에서 최초로 규정되었다.

[정답] X

[해설] 우리 헌법은 제8차 개정헌법(제5공화국 헌법)에서 처음으로 규정하였고, 현행 헌법 제17조에서 규정하고 있다.

♣ 강의내용

1. 주거의 자유

⑴ 의의 및 연혁

1) 의의

주거의 자유란 인간의 체류와 활동을 위한 사적 공간인 주거에 관하여는 개인의 자유로운 영역으로 인정하여 국가가 공간적으로 이를 침해할 수 없다는 것을 의미한다. 주거의 완전성(Integritat)을 보호하기 위한 것으로 주거의 불가침(Unverletzlichkeit der Wohnung)이라고 불리기도 한다.[412]

주거의 자유는 사생활영역에서 '인간실존의 중점'으로서 또한 '개인의 인격발현을 위한 공간적 영역'으로서 특별한 의의를 갖는다.[413] 주거의 자유는 개인에게 그의 존엄성과 관련하여 또한 그의 자유로운 인격의 발현을 위하여 '기초적 생활공간'을 보장해 준다. 주거의 자유는 개인에게 '은거할 수 있는 영역'(Ruckzugsbereich)을 보장하며, 자신의 거소에서 '조용히 있고'(in Ruhe gelassen zu werden)싶은 인간의 욕구를 확보해 준다. 즉, 주거의 자유는 개인의 인격의 발현과 자주적인 생활형성을 위한 공간적 기초를 보장해 준다.

2) 연혁

개인의 사적인 공간영역의 불가침성은 고대 그리스와 로마시대의 법에서도 인정되었다. 당시에도 주거는 가정의 생활공간일 뿐만 아니라 동시에 제사의 장소였고, 따라서 도피 장소이기도 하였다. 로마법은 국가공권력은 가정의 대문 앞에서 머문다는 법언에서 추측 할 수 있듯이 주거의 불가침을 인정하였다.

게르만법은 가택의 평온(Hausfrieden)이라는 특별한 제도를 만들어내었고, 1215년의 대헌장 제52조는 봉건 영주의 권리로서 방해받지 않을 주거의 권리를 규정하였다. 여기서부터 '내 집은 나의 성(My house is my castle)'이라는 영국의 속담이 연유하며, 이 말은 시민세력이 확대되는 과정에서 점차 보통법적 성질을 갖게 되었다.

---

412) 독일기본법 제13조.

413) 계희열, 「헌법학(中)」(신정판), 박영사, 2004, 399면 참조.

주거의 자유에서 역사적으로 중요한 또 하나의 요소는 군인의 사적 주거에 대한 강제주둔이다. 주거의 자유가 기본권이란 관념이 확립되기 이전에는 군인은 전쟁수행을 위하여 사적 공간을 함부로 징발하거나 혹은 사적 주택이나 공간에 함부로 숙영하고 주둔 생활을 하였다. 이것은 개인으로서는 사적 생활의 평화와 안정을 위협 받는 것으로서 개인이 수용하기에는 너무 고통스러운 것이었다. 따라서 미국 수정헌법 제3조는 “평화시에 군대는 어떠한 주택에도 그 소유자의 승낙을 받지 아니하고는 사영할 수 없다. 전시에 있어서도 법률이 정하는 방법에 의하지 아니하고는 사영할 수 없다”라고 규정하고 있다.

주거의 자유가 처음 기본권으로 인정된 것은 1776년의 버지니아 권리장전(제10조)이었다. 그 후 1776년의 펜실베니아 헌법과 1780년의 매사추세츠헌법에도 유사하게 규정되었다. 미국 연방헌법은 1791년의 수정헌법 제4조에서 주거의 자유를 보장하고 있다. 1831년의 벨기에헌법(제10조), 1849년의 프랑크푸르트헌법(제140조), 1850년의 프로이센헌법(제6조), 바이마르헌법(제115조)등으로 그 역사적 맥락이 이어져 왔고 오늘날에는 거의 모든 헌법이 이를 규정하고 있다.

국제적 차원에서도 세계인권선언 제12조와 시민적 정치적 권리에 관한 국제규약 제17조도 주거의 불가침을 규정하고 있다.

우리 헌법은 1948년 건국헌법 제10조에서 개별적 법률유보하에 거주·이전의 자유와 함께 주거의 자유를 규정하였고, 1960년 제3차 개헌에서 삭제되었다가 1962년 제5차 개헌에서 거주·이전의 자유에서 독립하여 지금과 같이 별개의 조항에서 규정되어(제14조) 현행 헌법에 이르고 있다.

⑵ 법적성격

주거의 자유는 한편으로 주관적 권리로서의 성격을 가지며, 다른 한편으로 객관적 질서의 요소로서의 성격을 갖는다. 즉, 다른 자유권과 마찬가지로 기본권의 이중적 성격을 갖는다. 우선 주거의 자유는 모든 형태의 주거에 대한 국가권력의 침해에 대한 방어권이다. 이 규정은 모든 국가기관에 대한 방어권이며 국가의 위임을 받은 사인에 대해서도 마찬가지이다. 그러나 이 규정은 국가에 대해 적정한 주거공간을 청구할 수 있는 급부청구권적 성격을 갖고 있지는 않다.

또한, 다른 모든 기본권과 마찬가지로 객관적 질서의 기본요소로서의 성격을 가져서 방사효로서의 성격을 갖는다. 즉, 주거의 자유는 인간생활의 모든 질서를 형성하는 기본요소이다. 이로써 모든 국가기관의 행위와 조치는 이 객관적 가치질서를 존중하지 않으면 안 된다.

<대법원 1962. 6. 2. 62아3> 주위토지통행권의 행사를 이유로 한 주거의 자유와 안전침해

주거는 사람으로서의 사적 생활과 평온한 휴식처로서 인간생활에 있어서의 가장 중요한 장소라 아니할 수 없으므로, 우리 헌법은 주거의 자유를 보장하고 형법 기타 법률로써 가사 정당한 권원에 의한 주거가 아니라 하더라도 그 주거로서의 안전을 보호 하였다. 그러므로 민법에서 인정하는 주위토지통행권을 행사함에 있어서도 위와 같은 기본적 인권의 하나인 주거의 자유와 안전은 통행권행사의 이유로써도 침해할 수 없다 할 것이며, 만일 위와 같은 주거의 안전을 침해하지 아니하고서는 통행권을 적법하게 행사할 수 없는 경우라면 차라리 통행권방해에 의한 건물의 철거 기타 장애물의 제거를 요구함은 별 문제로 하더라도 주거를 그대로 인정하면서 통행권행사를 이유로 주거의 자유와 안전을 해할 수는 없다.

⑶ 사생활의 비밀과 자유와의 관계

주거의 자유는 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치 내지 행복추구권에서 나오는 일반적 행동자유권의 구체적 실현형태라고 보아야 한다. 따라서 사적 공간영역과 관련하여 일반적 행동자유권이 문제되는 경우에는 주거의 자유문제로서 다루어야 한다.

우리 헌법은 독일이나 미국헌법 등과는 달리 사생활의 비밀(제17조)과 주거의 자유를 동시에 규정하고 있다. 여기서 양자와의 관계가 문제로 된다. 헌법상의 주거의 자유나 사생활의 비밀도 모두 광의의 프라이버시(privacy)의 개념에 포함시킬 수 있다.

견해의 대립은 있으나 사생활의 비밀은 보다 포괄적인 개념이고, 주거의 자유가 사생활비밀침해의 특별한 형태라고 할 수 있다. 또한, 주거침입개념의 전통적 관념에 비추어 물리적인 공간침해가 있으면 이를 주거의 자유침해로 해석하고, 그렇지 아니하고 단순히 기능상 주거의 평온을 해한 경우에는 사생활침해로 보는 것이 타당하다. 따라서 주거에 직접 신체적으로 진입하거나 혹은 도청기나 기타 물리적 물체를 투입시키는 것은 주거의 자유침해로 보아야 하지만 단순히 망원경으로 엿본다거나 혹은 증폭기 등으로 주거 내 소리를 탐지한다거나 잠복하여 주거에 대한 출입상황을 관찰하는 행위 등은 사생활침해로 해석하여야 할 것이다.

⑷ 주체

주거의 자유의 주체는 모든 자연인이다. 내국인만이 아니라 외국인이나 무국적자에게도 인정된다. 왜냐하면 주거의 자유란 국가를 전제로 하지 않는 인간의 사적 생활을 보장하기 위한 인간의 권리이기 때문이다. 미성년자도 그 주체가 된다.

또한, 법인이나 법인격 없는 사단이나 재단 등 단체에도 그 주체성이 인정할 수 있을 것이냐 하는 문제는 주거의 개념을 단순히 자연인이 개인적으로 체류하는 장소만이 아니라 집단적으로 체류하는 장소도 포함된다고 이해한다면 영업공간 등도 주거개념에 포함될 수 있다.

공법인의 경우에는 주거의 자유의 주체성인 인정되지 않는다. 공법인은 기본권향유의 주체가 아니고 기본권보장의무의 주체이기 때문이다. 예컨대, 공법인의 주체성이 인정된다면 국민의 출입권이 원칙적으로 배제된다고 보아야 하는데, 이것은 국민의 공법인에 대한 접근권을 차단하는 것으로서 타당하지 않다. 다만, 이들 기관도 기본권으로서 주거의 자유가 아니고 업무의 평온성을 보장받기 위하여 법률상 권리로서 주거침입죄의 객체는 된다고 보아야 한다.

주체와 관련하여 구체적인 경우 누가 주거의 자유를 주장할 수 있는 권한을 갖느냐는 원칙적으로 주거재산권에 대한 실체적 권원과 관계없이 주거의 그때그때의 소지자가 주거의 자유를 주장할 수 있다. 예컨대, 타인 소유의 주거 내에 세입자나 임차인이 거주하는 경우, 호텔객실의 투숙객 등의 사람들도 주거의 자유의 보호를 받게 된다.

주거가 부분 또는 공동소유인 경우, 즉 소유관계가 복잡할 경우 민법적인 소유의 서열이 중요한 것이 아니라 사실상의 거주관계가 결정적이다. 가령 주거의 관리자도 만약 그에게 일정한 공간이 사생활형성에 이용되도록 인정되고, 소유주에 대하여 최소한의 처분권이 존재하는 경우 주거의 자유를 주장할 수 있다.

가족의 모든 구성원에게는 주거의 자유를 주장할 수 있는 권한이 있다. 가족과 같은 공동거주자는 공동주거의 일부에 대하여 공동구간에 대하여 부분적으로 이용할 권리가 있다.

업무에 종사하는 사람에게 업무목적으로 개인적으로 맡겨진 작업공간도 업무종사자의 주거의 자유에 의하여 보호된다고 보아야 한다.

⑸ 내용

헌법상의 주거의 개념은 프라이버시(privacy)와 밀접한 관계를 갖고 있으며, 주거란 인간의 체류(거주)와 활동을 위한 장소로 만들어진 누구에게나 출입할 수 있도록 개방되지 않은 모든 사적 공간을 말한다. 여기서 사적공간이란 함부로 발을 들여 놓을 수 없고, 들여다 볼 수 없으며, 엿들을 수 없는 자신만을 위한 공간을 말한다.

주거의 자유가 보장받는 주거는 주거의 소유권이나 이용권 등 주거에 대한 실체적 권원을 전제로 하는 개념이 아니다. 따라서 임차인이 명도판결을 받았더라도 명도가 집행될 때까지는 여전히 주거의 자유를 가진다. 다만, 이 경우에도 집행관이 강제집행을 위하여 거주에 출입하는 경우에는 주거의 자유 보호상 기본권제한에 관한 비례의 원칙 등 헌법적 요건을 갖추어야 한다.[414]

결국 주거란 체류나 작업의 용도를 이용하는 모든 공간, 즉 거주용 주택은 물론 일시 머무르는 셋방, 호텔방 등을 포함한다. 그리고 지하실, 차고, 다락방, 계단 등과 같은 부속공간들과 이에 접속하여 둘러싸고 있는 난간을 포함한다. 이 밖에 캠핑용 자동차, 선박이나 선박의 객실, 텐트, 병원입원실 등도 포함된다. 또한, 사람이 거주하는 건물의 안마당, 경계가 정해진 정원, 울타리로 둘러싸인 인근의 놀이터 등도 주거의 자유에 의해 부수적으로 보호된다.

독일연방헌법재판소는 노동이나 직업 및 영업이 인간의 자아실현(인격의 자유로운 발현)을 위해 갖는 의미를 내세우며 계속적인 판결에서 이를 긍정하였다.[415] 물론 주거의 자유가 적용되는 사업장이나 영업소는 일반에게 출입이 개방되지 않은 곳에 국한된다. 따라서 모든 사람에게 출입이 개방되어 있는 영업장 특히 상점이나 백화점은 영업시간 중에는 주거의 자유의 보호를 받지 못한다.

제16조 제1문의 주거의 자유를 침해받지 아니한다는 것은 주거소지자의 의사에 반하는 침입이나 체류를 금지하는 것을 의미한다. 즉, 동의나 승낙이 없는 경우 누구도 주거에 들어가거나 머무르는 것을 금지한다는 말이다. 다만, 제16조 제2문에 따라 검사의 신청에 의하여 법관이 발부한 영장을 제시하고 주거에 대한 압수나 수색을 할 수 있으며, 법적 근거가 있는 경우 주거의 자유는 제한될 수 있다.

예컨대, 친지집 방문이나 상점에 손님이 들어가는 경우 등은 추정적 승낙이 있는 것이고, 거주자의 동의가 있었다고 하더라도 불법행위를 할 목적으로 들어간 경우에는 진정한 동의가 있었다고 볼 수 없기 때문에 이는 주거의 침입이 되고, 형법상 주거침입죄(제319조)가 성립된다.

⑹ 효력

주거의 자유는 우선 주관적 권리로서 대국가적 효력을 갖는다. 즉, 주거의 자유는 국가권력이 주거에 대해 어떤 형태로든지 간섭하거나 영향력을 행사하거나 또는 침해하는 데 대한 방어권으로서 대국가적 효력을 갖는다. 또한, 주거의 자유는 전체 법질서의 객관적 요소로서 사인에 대하여도 효력을 갖는다. 즉, 주거의 자유규정은 사인상호간의 관계에서도 직접 또는 간접으로 적용되며 사인을 구속한다.

그리고 주거의 자유는 국가의 기본권보장의무상 방사효를 가져서 사인에 의한 주거의 침해에 대하여 국가가 이를 보호할 의무를 부담한다.

---

414) 민사집행법 제5조; BVerfGE 89,1⑿.
415) BVerfGE 32,54(69ff.); 97,228(265f).

⑺ 제한

제37조 제2항에 따라 제한될 수 있다. 구체적으로는 형사소송법 제106조 이하의 대물적 강제처분이나 대인적 강제처분을 위한 경우, 자연재해대책법 제25조의 풍수해가 발생하였거나 발생할 우려가 있는 경우, 전염병예방법 제42조의 전염병예방을 위한 경우, 형사소송법 제119조의 현장검증 등이 있다. 이외에도 우편법 제5조 제1항, 국세징수법 제26조, 근로기준법 제103조 제1항, 경찰관직무집행법 제7조, 소방법 제5조 및 제59조 등에 의해 제한되기도 한다.

이러한 경우에도 영장주의, 비례원칙의 준수, 본질적 내용침해금지 등을 준수해야 한다.

2. 사생활의 비밀과 자유

⑴ 연혁

'프라이버시권'(The Right to Privacy)이라고도 하며, 주로 미국의 판례를 통하여 형성·발전되었다. 원래 영·미의 '보통법'(Common Law)에서는 소극적으로나마 명예훼손이나 불법행위 등과 같은 여러 가지 법적 의제로써 사생활을 보호하였다.

이러한 소극적인 태도에 대하여 1890년 웨런과 브라이스는 정면으로 프라이버시권을 인정할 것을 강조하면서 '혼자 있게 내버려두라는 개인의 일반적 권리'(the more general right of the individual to be let alone)로 정의하였다.[416]

1891년에 뉴욕주 하급법원에서 프라이버시권을 처음으로 인정하였고,[417] 1905년 조지아주 최고법원에서 받아들여졌으며, 이 후 각급법원에 영향을 주었다. 그러다가 1960년 프라이버시권에 대하여 부정적인 논문이 발표되면서,[418] 권리의 존부 및 본질에 관한 논의가 진행되었다. 마침내 1965년 미연방대법원에서 이 권리를 연방수정헌법 제1조(언론·출판의 자유), 제3조(병사사영금지), 제4조(체포·수색·압수금지), 제9조(열거되지 아니한 기본권), 제14조(적법절차) 등에서 추론되는 독립된 권리임이 최초로 확인되었다.[419]

일본은 프라이버시권을 제13조의 생명·자유 및 행복추구권에 포함되는 것으로 본다.[420]

우리 헌법은 제8차 개정헌법(제5공화국 헌법)에서 처음으로 규정하였고, 현행 헌법 제17조에서 규정하고 있다.

⑵ 의의 및 법적성격

1) 의의

전통적 의미에서의 사생활비밀이란 그 자체 비밀성이 있는 정보, 즉 타인에게 공개되는 것을 원하지 않는 사적인 사항으로서 양심영역이나 성적 영역 등 내밀 영역에 관한 사항, 재산상태, 건강상태, 통신비밀 등을 의미한다고 할 수 있다. 그리고 종래에는 이러한 정보에 대한 무단공개를 방지하는 데에 그 초점이 맞추어져 왔다.

---

416) Warren/Brandies, The Right to Privacy, Havard Law Review 193, 1890, p. 193.
417) Mackenzie v. Mineral Spring Co., 18 N. Y. Supp. 240, 1891.
418) Prosser, Privacy, California Law Review, 383, 1960.
419) 피임도구의 사용은 부부사이의 프라이버시권으로 수정헌법 제14조의 보호를 받는다고 판시하였다 (Griswold v. Conneticut 381 U. S. 479).
420) 김효전, "프라이버시의 권리에 관한 판례", 「고시계」, 1982. 5, 57면 이하.

그러나 오늘날 정보화 시대에 있어서는 그 자체 개별적으로는 비밀성이 없는 경우에도 그것이 총체적으로 수집되고 처리될 경우 그 개인의 생활상과 인격상이 적나라하게 드러날 수 있는 처지에 놓이게 되었다. 예컨대 한 개인이 서점에서 책을 사는 행위 자체는 공개된 장소에서의 행위이어서 사생활의 비밀이라고 할 수 없지만 그 개인의 신용카드사용내역 전부를 수집하여 분석한다면 그 사람의 소비행태, 기호, 재산, 건강상태 등까지 낱낱이 알 수 있게 된다. 따라서 오늘날은 그 자체 비밀성이 있는 정보뿐만 아니라 주소 등과 같이 그 자체로서는 중립적이거나 공개된 정보를 포함하여 당해 개인에 관련된 일체의 정보가 함부로 수집, 처리되지 않도록 보호할 필요가 있다고 하게 되었다. 그리하여 사생활비밀의 보호는 현대 정보화 사회에서는 개인정보의 보호를 의미하게 되었다.

따라서 사생활의 비밀과 자유권은 개인이 자기의사에 반하여 사생활의 영역이 관념적으로 침입되거나 공표되지 않는 권리와 자기 또는 자기의 지배하에 있는 자의 정보가 타인에 의하여 취득·개시될 정도를 결정할 수 있는 권리를 의미한다.[421]

또한, 사생활이란 공적생활, 사회생활과 구별되는 개인생활을 의미한다. 이는 원래 타인과의 교제 또는 공적관심에서 물러난 상태, 즉 '은거'(seclusion)를 의미하며, 한 사람의 인격의 성역에 해당된다. 결국, 사생활의 비밀과 자유권은 일반적 인격권 가운데 인격발현권을 제외한 부분(협의의 인격권)과 많은 부분에서 중첩된다. 따라서 헌법 제10조의 행복추구권에 대해서 특별법적 성격을 가진다.[422]

2) 법적성격

초기에는 소극적 권리로 이해되었으나 현재는 적극적인 측면도 함께 강조되고 있다.[423]

<대법원 1998. 7. 24. 96다42789>

개인의 사생활이 타인으로부터 침해되거나 사생활이 함부로 공개되지 아니할 소극적인 권리는 물론, 오늘날 고도의 정보화된 현대사회에서 자신에 대한 정보를 자율적으로 통제할 수 있는 적극적인 권리까지도 보장하려는 데에 그 취지가 있다.

⑶ 구체적 내용

1) 사생활비밀의 불가침

사생활의 비밀에 대한 불가침은 사적사항, 명예나 신용, 인격적 징표가 도청·비밀녹음·비밀촬영·초상도용 등으로 사생활을 본인의 의사에 반하여 파악되는 것과 파악된 사생활의 내용이 공개되는 것을 금지한다는 것을 포함한다.

사생활의 공개는 본인의 자율적인 결정에 맡겨져야 하며, 이를 본인의 의사에 반하여 공개하는 것은 사생활의 비밀에 대한 침해가 된다.

2) 사생활자유의 불가침

사생활의 자유에 대한 불가침은 평온한 사생활의 유지, 자신이 원하는 방식의 사생활을 적극적으로 형성하고 전개하는 것, 사생활의 자율성을 방해 또는 간섭받지 않을 것을 포함한다.

---

421) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 126면.
422) 홍성방, 상게서, 127면.
423) W. M. Beaney, The Right to Privacy and American Law, Law and Contemporary Problems, 1966, p. 254.

<헌법재판소 2001. 8. 30. 99헌바92> 공직선거법 제93조 제1항의 위헌소원

사생활의 자유란 사회공동체의 일반적인 생활규범의 범위 내에서 사생활을 자유롭게 형성해 나가고 그 설계 및 내용에 대해서 외부로부터의 간섭을 받지 아니할 권리이며, 사생활과 관련된 사사로운 자신만의 영역이 본인의 의사에 반해서 타인에게 알려지지 않도록 할 수 있는 권리인 사생활의 비밀과 함께 헌법상 보장되고 있는 것이다.

3) 자기정보통제권

자기에 관한 정보를 누가 어떤 목적으로 보유하고 있으며, 누구에게 정보를 제공했으며, 그 정보가 정확·적절한 것인가 등에 대하여 통제하는 것, 즉 자기정보열람청구권, 자기정보정정청구권, 개인정보사용중지·삭제청구권을 내용으로 한다.

헌법재판소는 자기정보통제권을 개인정보자기결정권이라고 부르면서 이를 독자적인 기본권으로서 헌법에 명시되지 않은 기본권에 해당한다고 한다.

<헌법재판소 1991. 9. 16. 89헌마165> 정정보도청구권과 언론의 자유에 대한 위헌여부

정기간행물의 등록 등에 관한 법률상의 정정보도청구권은 정기간행물의 보도에 의하여 인격권 등의 침해를 받은 자가 반론의 게재를 요구할 수 있는 권리, 즉 이른바 반론권을 뜻하는 것으로서, 헌법상 보장된 인격권·사생활의 비밀과 자유에 그 바탕을 둔 것이며, 나아가 피해자에게 반박의 기회를 허용함으로써 언론보도의 공정성과 객관성을 향상시켜 제도로서의 언론보장을 더욱 충실하게 할 수 있다는 뜻도 함께 지닌다.

<헌법재판소 2005. 5. 26. 99헌마513 등> 주민등록법 제17조의8 등 위헌확인

개인정보자기결정권의 헌법상 근거로는 헌법 제17조의 사생활의 비밀과 자유, 헌법 제10조 제1문의 인간의 존엄과 가치 및 행복추구권에 근거를 둔 일반적 인격권 또는 위 조문들과 동시에 우리 헌법의 자유민주적 기본질서 규정 또는 국민주권원리와 민주주의원리 등을 고려할 수 있으나 개인정보자기결정권으로 보호하려는 내용은 위 각 기본권들 및 헌법원리들 중 일부에 완전히 포섭시키는 것은 불가능하다고 할 것이므로 그 헌법적 근거를 굳이 어느 한두 개에 국한시키는 것은 바람직하지 않는 것으로 보이고, 오히려 개인정보자기결정권은 이들을 이념적 기초로 하는 독자적 기본권으로서 헌법에 명시되지 아니한 기본권이라고 보아야 할 것이다.

우리나라에서도 1995년 1월부터 개인정보의 보호를 위하여 공공기관의 개인정보보호에 관한 법률이 시행되고 있다. 이는 공공기관이 컴퓨터에 의하여 개인정보를 취급함에 있어 준수할 사항들을 규정하고 있으며(제8조~제11조), 공공기관 이외의 개인 또는 단체도 컴퓨터를 사용하여 개인정보를 처리함에 있어 공공기관의 예에 준하여 개인정보를 위한 조치를 강구할 것을 규정하고 있다(제22조).

⑶ 효력

사생활의 비밀과 자유권에 대하여는 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력이 인정된다. 따라서 공권력에 의해서 침해되는 경우, 법률·명령의 위헌심사, 헌법소원, 청원, 손해배상청구, 관계공무원의 징계 등을 통하여 구제받을 수 있다.

사인에 의하여 침해되면 불법행위로 인한 손해배상청구권과 기타 구제조치권이 성립한다. 다만 가족, 친지간에는 합리적인 한도 내에서 예외가 인정된다.

⑷ 한계와 제한

1) 한계

사생활침해의 의도가 없는 경미한 사생활침해에 대해서는 수인해야 한다. 예컨대, 국가가 행정상 반드시 필요한 여러 가지 국민의 신상에 관한 인적사항을 물어보는 것은 사생활에 대한 침해라 할 수 없고, 국민은 이를 수인해야 한다.

국민의 알 권리와 관련하여 사생활의 비밀과 자유가 한계를 가지는 경우가 있다. 이와 간련하여 권리포기이론, 공익이론, 공적인물이론 등이 있다.

권리포기이론은 자살자의 경우와 같이 일정한 조건하에서 사생활의 비밀과 자유를 포기한 것으로 간주한다.

공익이론은 보도적 가치, 교육적 가치, 계몽적 가치 등 공익적 가치가 있는 사실을 알리는 것은 사생활의 비밀과 자유에 대한 침해가 아니라고 한다. 예컨대, 공정한 해설, 범죄인의 체포·구금, 공중의 보건과 안전, 사이비종교, 범죄피해자의 공개 등이 포함된다.

공적인물이론은 연예인, 운동선수, 정치인 등 사회적 유명인의 경우에는 일반인에 비해 사생활이 공개되는 것을 수인해야 할 경우가 많다고 한다.

<헌법재판소 1999. 6. 24. 97헌마265> 불기소처분취소

신문보도의 명예훼손적 표현의 피해자가 공적인물인지 아니면 사인인지, 그 표현이 공적인 관심사안에 관한 것인지 순수한 사적인 영역에 속하는 사안인지의 여부에 따라 헌법적 심사기준에는 차이가 있어야 한다. 객관적으로 국민이 알아야 할 공공성·사회성을 갖춘 사실은 민주제의 토대인 여론형성이나 공개토론에 기여하므로 형사제재로 인하여 이러한 사안의 게재를 주저하게 만들어서는 안 된다.

<대법원 1993. 6. 22. 92도3160>

형사상이나 민사상으로 타인의 명예를 훼손하는 행위를 한 경우에도 그것이 공공의 이해에 관한 사항으로서 그 목적이 오로지 공공의 이익을 위한 것일 때에는 진실한 사실이라는 증명이 있으면 위 행위에 위법성이 없으며, 또한 그 증명이 없더라도 행위자가 그것을 진실이라고 믿을 만한 상당한 이유가 있는 경우에는 위법성이 없다.

2) 제한

사생활의 비밀과 자유는 헌법 제37조 제2항에 따라 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 법률로써 제한될 수 있으며, 대통령의 긴급명령에 의해서도 제한될 수 있다. 그러나 제한하는 경우에도 본질적 내용은 침해할 수 없다.

♣ 문제풀이

1. 다음 사생활의 비밀과 자유에 관한 기술 중 바르지 못한 것은?

① 자신에 관한 정보를 관리·통제할 수 있는 권리도 포함된다.
② 공익차원에서 국민의 알 권리의 대상이 되기도 한다.
③ 정치인·영화배우 등 유명인은 가지지 못한다.
④ 미국에서는 Privacy의 권리로 인정되고 있다.
⑤ 자살자의 경우, 자살로써 자신의 사생활에 관한 비밀을 포기한 것으로 간주한다.

[정답] ③

[해설] 공적인물의 경우 통상인에 비하여 수인해야 할 경우가 많다는 공적인물이론이 적용된다.

2. 다음 주거의 자유에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 일정한 주거에 거주함으로써 그 장소로부터 사생활상의 편익을 얻는 자는 누구나 주거의 자유의 주체가 된다.
② 주거의 자유는 사생활의 비밀과 자유보다 넓은 개념이다.
③ 호텔 객실의 경우, 현실적으로 이용하는 투숙객도 주체성이 인정된다.
④ 주거에 대한 압수수색의 경우에도 원칙적으로 영장주의가 적용된다.
⑤ 아동의 동의를 얻어 주택에 들어가 절도를 한 경우, 주거의 자유의 침해가 된다.

[정답] ②

[해설] 주거의 자유는 사생활의 비밀과 자유보다 좁은 개념이다.

3. 다음 사생활의 자유에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 비방광고로 인한 인격권침해에 대한 사전 구제수단으로서 광고중지청구권이 인정된다.
② 언론매체에서 수술부작용으로 고생하는 사람들에 대한 프로그램을 방영하면서 방송 중 노출되는 사람들의 신분노출을 막기 위한 적절한 조치를 취하지 않았다면 이는 불법행위를 구성한다.
③ 행정법상의 의무위반자의 성명이나 위반사실을 공표하는 것은 허용되지 않는다.
④ 재개발사업에 관한 이해관계인이 공개를 청구한 자료 중 일부에 다른 개인의 인적사항, 재산에 관한 사항 등이 포함되어 있는 경우, 공개를 거부할 수 있다.
⑤ 제3자가 공갈목적을 숨기고 피고인의 동의를 얻어 나체사진을 찍은 경우, 그 사진이 피고인에 대한 간통죄에 있어 반드시 필요한 증거라면 증거능력이 배제되지 않는다.

[정답] ③

[해설] 국가기관이 행정목적 달성을 위해 언론에 보도자료를 제공하는 등 행정상 공표의 방법으로 실명을 공개하여 타인의 명예를 훼손한 경우, 진실의 증명이 없더라도 진실이라고 믿었고 또 그렇게 믿을 만한 상당한 이유가 있다면 위법성이 없다(대법원 1993. 11. 26. 93다18389).

♣ 요점정리

1. 주거의 자유란 인간의 체류와 활동을 위한 사적 공간인 주거에 관하여는 개인의 자유로운 영역으로 인정하여 국가가 공간적으로 이를 침해할 수 없다는 것을 의미한다.

2. 주거의 자유가 처음 기본권으로 인정된 것은 1776년의 버지니아 권리장전 제10조이다.

3. 1948년 건국헌법 제10조에서 개별적 법률유보하에 거주·이전의 자유와 함께 주거의 자유를 규정하였고, 1960년 제3차 개헌에서 삭제되었다가 1962년 제5차 개헌에서 거주·이전의 자유에서 독립하여 지금과 같이 별개의 조항에서 규정되어(제14조) 현행 헌법에 이르고 있다.

4. 사생활의 비밀과 자유권은 개인이 자기의사에 반하여 사생활의 영역이 관념적으로 침입되거나 공표되지 않는 권리와 자기 또는 자기의 지배하에 있는 자의 정보가 타인에 의하여 취득·개시될 정도를 결정할 수 있는 권리를 의미한다.

5. 사생활의 비밀과 자유는 제8차 개정헌법(제5공화국 헌법)에서 처음으로 규정하였고, 현행 헌법 제17조에서 규정하고 있다.

6. 사생활의 자유에 대한 불가침은 평온한 사생활의 유지, 자신이 원하는 방식의 사생활을 적극적으로 형성하고 전개하는 것, 사생활의 자율성을 방해 또는 간섭받지 않을 것을 포함한다.

7. 헌법재판소는 자기정보통제권을 개인정보자기결정권이라고 부르면서 이를 독자적인 기본권으로서 헌법에 명시되지 않은 기본권에 해당한다고 한다.

제26강 통신의 자유

♣ 학습목표

통신의 자유를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

통신의 자유의 연혁, 의의
통신비밀보호법
사생활의 자유
표현의 자유
내심의 자유
통신의 비밀 및 통신의 자유
통신비밀불가침
통신의 자유의 한계

♣ 사전테스트

1. 통신의 자유의 불가침을 최초로 규정한 헌법은 1831년 벨기에 헌법이다.

정답 : X
해설 : 선서의 비밀에 대한 불가침을 최초로 규정한 헌법은 1831년 벨기에 헌법이었으며, 통신의 자유는 1919년 바이마르헌법이 최초로 규정한 것으로 알려져 있다.

2. 통신의 자유는 국가에 의한 침해로부터의 방어권으로서의 성격을 가진다.

정답 : O
해설 : 헌법재판소 2001. 3. 21. 2000헌바25.

3. 통신업무에 종사하는 공무원이 통신물을 통신업무상 필요한 검사의 목적으로 검토하는 것은 통신의 자유의 제한이다.

정답 : X
해설 : 통신업무에 종사하는 공무원이 통신물을 통신업무상 필요한 검사의 목적으로 검토하는 것은 통신의 자유의 제한이 아니며, 통신업무를 취급하다가 우연히 범죄사실을 알게 된 경우에 그 사실을 수사기관에 알리더라도 통신의 자유에 대한 침해가 아니다.

♣ 돌발퀴즈

우리 헌법재판소는 헌법해석상 사생활의 보호영역에서의 통신의 비밀은 제18조에서 제외되는 것으로 보는 것이 타당하다고 한다.

[정답] X

[해설] 우리 헌법재판소는 사생활을 보호하는 영역에서는 헌법 제18조는 사생활 영역에서의 통신의 비밀을 헌법 제17조 보다 강하게 보장하기 위해 따로 정하고 있다고 하여 통신의 자유를 사생활의 자유의 특별규정으로 이해하고 있다.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

선서의 비밀에 대한 불가침을 최초로 규정한 헌법은 1831년 벨기에 헌법이었으며, 1850년의 프로이센 헌법에서 서신의 불가침을 규정했다. 그러나 일반적인 통신의 자유는 1919년 바이마르헌법이 최초로 규정한 것으로 알려져 있다.[424]

이러한 통신의 자유는 제2차 세계대전을 전후하여 각국 헌법과 세계인권선언 등에서 사생활의 비밀에 대한 보호의 일환으로 규정되었다. 우리나라는 건국헌법이래 계속적으로 통신의 자유를 규정하고 있으나 미국과 일본의 헌법에는 통신의 자유에 관한 규정이 없다.

현행 헌법은 제18조에서 모든 국민은 통신의 비밀(Privacy of Correspondence)을 침해받지 아니 한다고 규정하여 통신의 자유를 보장하고 있다.

우리 헌법은 사생활의 비밀과 자유를 보장하는 것과 별도로 통신의 자유를 보장하여 개인의 의사소통의 자유를 보장하고 있다. 개인에게 통신의 자유를 기본권으로 보장하는 것은 과학과 기술의 발달에 기초한 현대 정보사회에서 중요한 의미를 가진다.

현대정보사회의 비약적인 발전으로 개인 간의 의사소통은 획기적으로 변화하였으나 전기통신설비, 도청장비 및 기술 등을 이용한 개인 간의 통신의 자유를 침해하는 문제가 현저하게 증가하고 있다. 따라서 우리 헌법 제18조는 이러한 침해들로부터 개인의 통신의 비밀을 보호하는 기본권보장 차원에서도 중요한 의미를 가진다.

2. 의의 및 법적성격

⑴ 의의

통신의 자유란 개인이나 법인이 그 의사나 정보를 우편물이나 전기통신 등의 수단에 의하여 전달 또는 교환하는 경우에 그 내용이 본인의 의사에 반하여 공개되지 아니할 자유를 의미한다.

넓은 의미에서 본다면, 사생활보호에 속하면서도 정보통신 기술이 비약적으로 발전하면서 전통적인 통신의 비밀에 관한 영역 이외에도 새로운 문제점들이 발생하고 있다. 즉, 전기통신을 이용한 사적통신이 도청·감청 등에 의해 침해되고 있다. 우리나라에서 통신비밀의 보호는 공적 부문에서의 통제가 주로 논의되었으나 1992년 12월 11일 정부 기관장들이 부산의 '초원복집'이

424) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 132면.

라는 음식점에 모여 제14대 대통령 선거에 영향을 미칠 목적으로 지역감정을 부추기자고 모의한 것이 도청에 의해 드러나 문제가 되어 통신비밀보호법이 제정되었다.

이러한 통신의 자유는 사생활의 비밀을 보장하고, 개인의 인격을 보호하며, 사회구성원 사이에 원활한 의사소통이 이루어지도록 하는 역할을 한다.

<대법원 1997. 3. 28. 95도2674>

일반인의 출입이 허용된 음식점이라 하더라도, 영업주의 명시적 또는 추정적 의사에 반하여 들어간 것이라면 주거침입죄가 성립되는바, 기관장들의 조찬모임에서의 대화내용을 도청하기 위한 도청장치를 설치할 목적으로 손님을 가장하여 그 조찬모임 장소인 음식점에 들어간 경우에는 영업주가 그 출입을 허용하지 않았을 것으로 보는 것이 경험칙에 부합하므로 그와 같은 행위는 주거침입죄가 성립한다.

타인의 주거에 침입한 행위가 비록 불법선거운동을 적발하려는 목적으로 이루어진 것이라고 하더라도, 타인의 주거에 도청장치를 설치하는 행위는 그 수단과 방법의 상당성을 결하는 것으로서 정당행위에 해당하지 않는다.

⑵ 법적성격

헌법 제18조는 고전적 자유권을 보장한 것이다. 따라서 국가에 의한 침해로부터의 방어권으로서의 성격을 가진다.[425] 그러나 헌법 제18조에서 통신제도라는 제도적 보장이 함께 구현된 것이라고 보는 견해도 있다.[426] 통신의 자유는 개별적인 경우에 포기할 수 있으며, 행복추구권의 특별규정으로서의 성격을 가진다.

3. 다른 기본권과의 관계

⑴ 사생활의 비밀과 자유

통신의 비밀과 자유는 넓은 의미의 사생활의 비밀과 자유에 포함된다.[427] 개인과 개인이 자유롭게 서로의 의사와 정보를 주고받는 것은 개인의 사적영역에서 이루어지는 보편적인 생활형태의 일부이기 때문이다. 따라서 통신의 비밀과 자유에 대하여 헌법 제18조에서 따로 정하고 있지 않는 경우에는 헌법 제17조의 사생활의 비밀과 자유에 포함되어 보장된다고 할 수 있다.[428]

우리 헌법재판소는 사생활을 보호하는 영역에서는 헌법 제18조는 사생활 영역에서의 통신의 비밀을 헌법 제17조 보다 강하게 보장하기 위해 따로 정하고 있다고[429] 하여 통신의 자유를 사생활의 자유의 특별규정으로 이해하고 있다.

그러나 헌법 제18조를 헌법 제17조의 특별규정이라고 보기 어렵다.[430] 사생활의 보호에서 다른 사생활의 비밀을 보호하는 강도가 통신의 비밀을 보호하는 강도보다 약하다고 할 수 없고, 헌법 제18조는 통신의 비밀을 보호하기 위해 헌법 제17조와 따로 규정하고 있으며, 헌법해석상

425) 헌법재판소 2001. 3. 21. 2000헌바25.
426) 한동섭, 「헌법」, 박영사, 1971, 141면.
427) 성낙인, 「헌법학」, 법문사, 2013, 654면; 정종섭, 「헌법학원론」, 박영사, 2012, 635면.
428) 정종섭, 상게서, 635면.
429) 헌법재판소, 2001. 3. 21. 2000헌바25.
430) 정종섭, 전게서, 631면.

사생활의 보호영역에서의 통신의 비밀은 제18조에서 제외되는 것으로 보는 것이 타당하다고 한다.

<헌법재판소 2004. 11. 25. 2002헌바85>

통신의 자유를 기본권으로서 보장하는 것은 사적영역에 속하는 개인 간의 의사소통을 사생활의 일부로서 보장하겠다는 취지에서 비롯된 것이다. 통신은 기본적으로 개인과 개인 간의 관계를 전제로 하는 것이지만 통신의 수단인 우편이나 전기통신의 운영이 전통적으로 국가독점에서 출발하였기 때문에 통신의 영역은 다른 사생활 영역에 비하여 국가에 의한 침해 가능성이 매우 큰 영역이라 할 수 있고, 이것이 사생활의 비밀과 자유에 포섭될 수 있는 사적영역에 속하는 통신의 자유를 헌법이 별개의 조항을 통해서 기본권으로 보호하고 있는 이유라 할 것이다.

통신이 모든 영역에 걸쳐 중요한 의미를 가지는 오늘날에는 통신의 비밀과 자유는 사생활의 비밀과 자유의 영역을 넘어 각종 생활영역에서 보장되는 모든 종류의 행위의 비밀과 자유를 보장하는 것으로서의 의미를 가진다. 즉, 통신을 통한 영업행위, 학술행위, 종교행위, 정치활동 등을 침해하는 행위는 통신의 비밀과 자유를 침해할 뿐 아니라 영업의 자유, 학문활동의 자유, 종교의 자유, 정치활동의 자유를 침해하는 것이 된다.[431]

⑵ 표현의 자유

통신의 자유는 인간 상호간에 정보와 의견을 전달하고 주고받는 방법인 바, 언론·출판과 같은 의사표현의 자유와 밀접한 관련이 있다. 즉, 의사표현의 자유가 표현행위의 자유를 보장하는 것이라면 통신의 자유는 특정한 상대방을 전제로 하여 상호간에 이루어지는 의사소통의 비밀과 자유를 보장하는 것이다.

⑶ 내심의 자유

통신의 자유는 개인 간의 의사표현이나 정보의 외부적 전달을 보호하려는 것이라는 점에서 양심의 자유, 종교의 자유 등과 같은 내면적 정신활동의 자유와는 구별된다.

4. 주체

자연인과 법인 모두에게 주체성이 인정된다. 즉, 서신 이외의 우편물이나 전기통신을 이용하는 경우에는 개별시민은 우체국이나 전기통신회사에 대하여 통신의 자유를 주장할 수 있고, 개별시민과 우체국 및 전기통신회사는 국가기관에 대해 통신의 자유를 주장할 수 있다.

또한, 서신의 경우에는 수신인과 송신인 모두가 주체가 된다.[432]

그런데 통신의 비밀은 국가기관 상호간에 행해지는 통신의 경우에도 다른 국가기관이나 사인에 의하여 침해되어서는 안 되는 경우가 있는데(예컨대, 최근의 청와대 문건파문), 이러한 경우에는 통신의 자유가 아니라 공무상 행위나 공무상 비밀에 해당한다.

---

431) 정종섭, 전게서, 635~636면 참조.
432) BVerfGE 67, 157(171f.).

5. 내용

통신의 자유란 개인이나 법인이 그 의사나 정보를 우편물이나 전기통신 등의 수단에 의하여 전달 또는 교환하는 경우에 그 내용이 본인의 의사에 반하여 공개되지 아니할 자유를 의미한다. 여기서 통신이라고 함은 신서·전신·전화 기타의 우편물 등 통신기관을 통하여 수수되는 일체의 의사전달수단과 물품을 말한다.

⑴ 통신의 비밀

통신의 비밀에 의해 보호되는 대상은 사적사항이든 공적사항이든 불문하고, 통신행의 그 자체(통신의 안전과 평온)와 수신인과 발신인의 성명·주소, 수신지와 발신지, 수신과 발신 연월일, 통신의 수량·횟수·형태 등 통신에 관한 정보일체가 포함된다.[433]

입법자를 포함한 공무원 및 기타 통신업무를 담당하는 자는 재직 중 직무상 알게 된 비밀을 누설해서는 안 된다(국가공무원법 제60조, 우편법 제3조, 전기통신사업법 제54조, 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 제57조, 형법 제127조 등).

⑵ 통신의 자유

통신의 비밀을 보장하는 것은 통신의 자유를 보장하기 위하여 필연적으로 요구되는 것이다. 따라서 통신의 자유는 통신의 비밀이 침해되지 않는 것을 보장하는 것이 핵심적인 내용이다. 이러한 통신의 자유는 국가가 제공하는 우편이나 각종 통신의 취급에서 거부당하지 않는다는 것을 의미한다.

⑶ 불가침

통신의 비밀의 불가침은 통신의 비밀로 보호되는 일체의 것이 당사자의 의사에 반하여 제3자가 인지하는 것을 금지하는 것을 의미한다. 즉, 당사자의 의사에 반하여 편지, 우편, 전화, 전보, 전신, 이메일 등 개인 간의 통신수단을 개봉하거나 그 내용 등을 열람·청취·누설하는 행위 등을 금지하는 것을 포함하는 것으로 열람금지, 누설금지, 정보금지(통신업무내용을 정보활동의 목적에 제공하거나 제공받으려는 것)로 구분할 수 있다.

⑷ 전기통신도청의 금지

1) 도청의 개념과 종류

도청이라 함은 불법적으로 다른 사람의 전기통신의 내용을 해독하는 것으로 불법적 청취를 의미한다. 도청은 유권기관이 관계 법률에 따라 합법적으로 당사자의 동의 없이 전자장치·기계장치 등을 사용하여 통신의 음향·문언·부호·영상을 청취하거나 공독하여 그 내용을 지득 또는 해득하거나 전기통신의 송·수신을 방해하는 합법적 청취인 감청과는 구별된다.

도청에는 전화도청과 전화와 관계없이 도청기구를 사용하여 대화를 듣거나 녹음하는 경우가 있다. 전자는 통신의 비밀과 관계되고, 후자는 사생활의 비밀과 관련이 있다.

---

433) 정종섭, 전게서, 637~638면 참조.

2) 전기통신의 개념과 도청의 금지

전기통신이란 유선, 무선, 광선 기타의 전자적 방식에 의하여 부호, 문언, 음향 또는 영상을 송신하거나 수신하는 것을 말한다(전기통신기본법 제2조). 누구든지 전기통신사업자가 취급 중에 있는 통신의 비밀을 침해하거나 누설해서는 안 된다(제54조). 다만, 전기통신을 이용하는 자는 공공의 안녕질서 또는 미풍양속을 해하는 내용의 통신을 해서는 안 된다(제53조).

전화에 대한 도청은 금지된다. 누구든지 통신비밀보호법과 형사소송법 또는 순사법원법에 규정에 의하지 아니하고는 우편물의 검열 또는 전기통신의 감청을 하거나 공개되니 아니한 타인 간의 대화를 청취하지 못한다(통신비밀보호법 제3조).

최근 국정원 등 국가기관에 의한 개인에 대한 통신의 비밀 침해문제가 제기되고 있는데, 도청이 헌법상 가능한가의 여부는 대상이 언어라는 비유체물인 점에서 문제가 있으나 오늘날의 전자산업의 발달 등을 감안할 때 통신의 비밀을 침해하는 것이라 하겠다.[434]

3) 전화의 역탐지와 전화번호통보제도의 합헌성

전화에 의한 협박죄의 현행범을 체포하기 위해 발신장소를 역탐지하는 것이나 범인으로부터의 전화를 녹음하는 것과 관련하여 문제되는 바, 전화의 역탐지는 현행범인의 체포를 위하여 필요하기 때문에 허용된다고 보아야 한다.

또한, 전화번호통보(안내)제도는 지나친 모욕과 욕설, 성희롱 등의 전화폭력을 방지하고, 선의의 피해자에 대한 사생활의 평온, 인간으로서의 존엄과 가치 등을 보호할 필요가 있어 수신인의 요구가 있는 때에는 송신인의 전화번호를 수신인게 알려주는 것이 허용된다(통신비밀보호법 제13조).

<대법원 2011. 3. 17. 2006도8839>

통신비밀보호법이 통신비밀의 공개·누설행위를 불법 감청·녹음 등의 행위와 똑같이 처벌대상으로 하고 법정형도 동일하게 규정하고 있는 것은 통신비밀의 침해로 수집된 정보의 내용에 관계없이 정보자체의 사용을 금지함으로써 당초 존재하지 아니하였어야 할 불법의 결과를 용인하지 않겠다는 취지이고, 이는 불법의 결과를 이용하여 이익을 얻는 것을 금지함과 아울러 그러한 행위의 유인마저 없애겠다는 정책적 고려에 기인한 것이다.

<대법원 2012. 10. 25. 2012도4644>

통신비밀보호법상 감청이란 대상이 되는 전기통신의 송·수신과 동시에 이루어지는 경우만을 의미하고 이미 수신이 완료된 전기통신의 내용을 지득하는 등의 행위는 포함되지 않는다.

6. 효력

통신의 자유는 대국가적 효력과 대사인적 효력이 모두 인정된다. 따라서 불법검열에 의하여 취득한 우편물이나 그 내용 및 불법감청에 의하여 취득 또는 채록된 전기통신의 내용은 재판 또는 징계절차에서 증거로 사용할 수 없다(통신비밀보호법 제4조). 또한, 사인이 특히 부당하고 위법하게 타인의 통신의 비밀을 침해하는 경우에는 형법상의 비밀침해죄(제316조)로 처벌받거나 민법상 불법행위책임을 지게 된다.

---

434) 대법원 2011. 3. 17. 2006도8839 참조.

7. 한계 및 제한

⑴ 한계

통신의 자유는 합법적이고 정당한 통신만을 보호한다. 따라서 허가 없이 행해지는 무선통신이나 통신을 통한 범죄행위는 보호받을 수 없다. 따라서 통신업무에 종사하는 공무원이 통신물을 통신업무상 필요한 검사의 목적으로 검토하는 것은 통신의 자유의 제한이 아니며, 통신업무를 취급하다가 우연히 범죄사실을 알게 된 경우에 그 사실을 수사기관에 알리더라도 통신의 자유에 대한 침해가 아니다.[435)]

⑵ 제한

통신의 자유의 제한은 제37조 제2항에 따라 국가안전보장·질서유지·공공복리를 위하여 필요한 경우에 법률로써 제한할 수 있다. 그러나 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수는 없다. 이에 관한 것으로는 형사절차상의 우체물의 압수, 행정적 필요에 따른 우체내용물의 제한, 수형자와의 수신·발신 제한, 통신비밀보호법에 의한 제한, 국가보안법에 의한 제한 등이 있다.

<대법원 1993. 9. 28. 93도1730>

통신의 자유 등은 헌법이 보장하는 권리이긴 하나 무제한한 것이 아니라 헌법 제37조 제2항에 의하여 제한할 수 있는 것이므로 국가보안법 규정의 입법목적과 적용한계를 자유와 권리의 본질적 내용을 침해하지 않는 한도 내에서 이를 제한할 수 있다.

<헌법재판소 1995. 7. 21. 92헌마144> 미결수용자와 변호인 아닌 자 및 변호사와의 서신검열

미결수용자의 일반인에 대한 서신은 그 검열이 필요하고 허용되나 변호인에 대한 서신에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 이를 허용하여서는 안 될 것이다. 그러므로 변호인과의 서신을 검열한 것은 위헌이다. 다만, 미결수용자와 변호인 사이의 서신으로서 그 비밀을 보장하기 위하여는 첫째, 교도소측에서 상대방이 변호인이라는 사실을 확인할 수 있어야 하고, 둘째, 서신을 통하여 마약 등 소지 금지품의 반입을 도모한다든가 그 내용에 도주·증거인멸·수용시성의 규율과 질서의 파괴·기타 형벌법령에 저촉되는 내용이 지재되어 있다고 의심할 만한 합리적인 이유가 있는 경우가 아니어야 한다.

♣ 문제풀이

1. 다음 통신의 자유에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 사인이 통신의 비밀을 침해하는 경우에도 적용된다는 것이 다수설이다.
② 통신의 불가침은 열람금지, 누설금지 그리고 정보금지를 의미한다.
③ 법인격 없는 단체도 주체성이 있다.
④ 엽서 등 봉인되지 아니 한 통신은 보호의 대상이 아니다.
⑤ 타인의 편지에 내용을 첨가하거나 타인의 통화에 끼어들어 참여하는 자도 보호된다.

[정답] ④

[해설] 비밀성의 유무를 불문하고 모든 통신에 인정된다.

435) 홍성방, 전게서, 135면.

2. 다음 통신의 자유에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 부모가 미성년자인 자의 통신을 통제하는 것은 허용된다.
② 공무상 필요에 의해 편지를 검열하였을 경우에는 그 내용을 누설할 수 없다.
③ 형사소추를 위해 통신의 비밀을 침해할 경우에는 영장주의가 적용된다.
④ 우편업무에 종사하다가 퇴직한 자는 재직 중 지득한 타인의 비밀을 누설할 수 없다.
⑤ 전화국 직원이 협박전화의 발신지를 역탐지하는 것은 불가능하다.

[정답] ⑤

[해설] 현행범에 관하여 수사기관 또는 피해자의 요청이 있는 경우 가능하다(통신비밀보호법 제13조).

3. 다음 중 통신의 비밀을 침해하는 것은?

① 전기통신사업자가 수신인의 요구가 있을 때 송신인의 전화번호를 알려주는 것
② 파산관재인이 수령한 우편물을 개봉하는 것
③ 편지 등을 개봉하지 않고 기술적 수단에 의해 그 내용을 알아내는 것
④ 법원이 피고인의 우편물을 압수하는 것
⑤ 교도소장이 수용자가 발송하는 서신을 검열하는 것

[정답] ③

[해설] 형법 제316조 제2항

♣ 요점정리

1. 선서의 비밀에 대한 불가침을 최초로 규정한 헌법은 1831년 벨기에 헌법이었으며, 통신의 자유는 1919년 바이마르헌법이 최초로 규정한 것으로 알려져 있다.

2. 통신의 비밀과 자유는 넓은 의미의 사생활의 비밀과 자유에 포함된다.

3. 우리 헌법재판소는 사생활을 보호하는 영역에서는 헌법 제18조는 사생활 영역에서의 통신의 비밀을 헌법 제17조 보다 강하게 보장하기 위해 따로 정하고 있다고 하여 통신의 자유를 사생활의 자유의 특별규정으로 이해하고 있다.

4. 통신의 자유란 개인이나 법인이 그 의사나 정보를 우편물이나 전기통신 등의 수단에 의하여 전달 또는 교환하는 경우에 그 내용이 본인의 의사에 반하여 공대되지 아니할 자유를 의미한다.

5. 통신의 자유는 합법적이고 정당한 통신만을 보호한다. 따라서 허가 없이 행해지는 무선통신이나 통신을 통한 범죄행위는 보호받을 수 없다.

6. 미결수용자의 일반인에 대한 서신은 그 검열이 필요하고 허용되나 변호인에 대한 서신에 대하여는 특별한 사정이 없는 한 이를 허용하여서는 안 될 것이다. 그러므로 변호인과의 서신을 검열한 것은 위헌이다.

제27강 양심의 자유

♣ 학습목표

양심의 자유를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

바이마르헌법 제135조
헌법 제19조
양심의 자유의 법적성격
일반적 정신적 자유권
표현의 자유
양심의 형성, 결정, 실현의 자유

♣ 사전테스트

1. 우리 건국헌법은 신앙과 양심을 별도로 규정하였다.

정답 : X
해설 : 우리 건국헌법은 신앙과 양심을 동일한 조항에서 규정하였으나 제3공화국 헌법 이후 신앙과 양심을 별도로 규정하였고, 현행 헌법은 제19조에서 규정하고 있다.

2. 미성년자는 언제나 양심의 자유의 제한을 받는다.

정답 : X
해설 : 미성년자가 양심의 자유를 독립적으로 행사할 수 있는 지의 여부는 미성년자의 정신적 성숙도와 부모의 친권을 함께 고려하여 결정될 수 있을 것이다.

3. 양심의 자유는 종교의 자유, 학문·예술의 자유의 전제가 된다.

정답 : O
해설 : 인간의 내심작용을 외부에 발표하는 자유는 언론·출판의 자유이고, 사상·양심의 내용이 학문적 체계 또는 예술적 가치성을 가질 때에는 학문의 자유, 예술의 자유가 되며, 그것이 종교적 성격을 가질 때에는 종교적 자유라고 할 수 있기 때문이다.

♣ 돌발퀴즈

우리 헌법재판소는 양심형성 및 결정의 자유, 양심을 지키는 자유(침묵의 자유, 양심추지의 금지, 양심에 반하는 작위의무로부터의 해방), 양심실현의 자유를 내용으로 보고 있다.

[정답] O
[해설] 헌법재판소 1998. 7. 16. 96헌바35.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

양심의 자유는 역사적으로 볼 때, 주로 종교적인 신앙적 양심을 의미한다.[436] 영국에서 양심의 자유는 발효되지는 못했으나 1647/1649년 영국 인민협약에서 규정되었다.[437]

미국의 경우, 1776년 버지니아헌법 제16조는 양자를 결합하여 규정한 바 있었으나 1791년의 미연방수정헌법은 양심의 자유에 대하여 별도의 규정을 두지 않았다.

독일의 경우에 1850년 프로이센 헌법에서 '신앙과 양심'(Glauben und Gewissen)이 규정되었고, 양심의 자유를 종교의 자유의 하부형태로 보았다.[438] 이 후, 1919년 바이마르헌법 제135조 제1항에서 신앙과 양심의 자유(Glaubens und Gewissensfreiheit) 표제아래 처음으로 독립된 기본권으로 규정되었다.

우리 건국헌법은 신앙과 양심을 동일한 조항에서 규정하였으나 제3공화국 헌법 이후 신앙과 양심을 별도로 규정하였고, 현행 헌법은 제19조에서 모든 국민은 양심의 자유를 가진다고 규정하고 있다.

2. 법적성격

양심의 자유는 일반적으로 종교의 자유, 학문·예술의 자유와 함께 이른바 내심의 자유에 속하며, 행동의 자유에 선행하는 정신적 자유의 모체를 이루고 있다.

그러나 양심의 자유는 종교의 자유, 학문·예술의 자유의 전제가 된다고 볼 수 있다. 즉, 인간의 내심작용을 외부에 발표하는 자유는 언론·출판의 자유이고, 사상·양심의 내용이 학문적 체계 또는 예술적 가치성을 가질 때에는 학문의 자유, 예술의 자유가 되며, 그것이 종교적 성격을 가질 때에는 종교적 자유라고 할 수 있기 때문이다.[439]

따라서 양심의 자유는 정신적 자유의 근원을 이루고, 양심의 형성과 결정 그리고 양심의 실현에 대한 자유권으로서의 성격을 가진다. 뿐만 아니라 양심의 자유는 자유로운 정치과정의 전제가 되며, 민주적 법치국가에 있어 가치상대주의와 세계관적 중립성, 다수결원리, 관용의 원리와 관련하여 국민의 국가의사형성에의 참여의 보장, 사상과 양심의 다양성과 소수자의 보호 등을 위한 전제가 되는 것이므로 객관적 가치질서로서의 성격도 가진다고 할 수 있다.

3. 주체

양심의 자유의 주체는 원칙적으로 자연인에 한정된다. 다만, 미성년자가 양심의 자유를 독립적으로 행사할 수 있는 지의 여부는 미성년자의 정신적 성숙도와 부모의 친권을 함께 고려하여 결정될 수 있을 것이다.

문제는 법인에게도 양심의 자유가 인정될 수 있는 것인가 하는 점이다. 양심이 오직 인간의 자율적 인격에 의한 결정과 연관되는 고도의 인격적 권리이기 때문에 법인에 대해서는 양심의

436) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 137면.
437) R. Zippelius, Bonner Kommentar, 1989, Rndr. 17 zu Art. 4.
438) H. Bethge, Gewissenfreiheit, in : J. Isensee/P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts, Bd. IV, 1989, S. 436ff.
439) 한동섭, 「헌법」, 박영사, 1971, 142면.

자유가 인정되지 않는다고 보는 것이 지배적 견해이다. 그러나 법인에게도 양심의 자유를 인정해야 한다는 견해도 있다.[440]

4. 다른 기본권과의 관계

⑴ 일반적 정신적 자유권

사상과 양심의 자유를 정신활동의 자유로서 일반적 성격을 가진다거나 일체의 정신적 자유의 논리적 전제, 또는 인간내면의 정신적 활동의 자유의 총칙적 규정으로 이해하면,[441] 종교의 자유나 학문의 자유 등과 양심의 자유는 특별법과 일반법의 관계가 된다.

그러나 양심의 자유가 종교의 자유나 학문의 자유 등과 규범영역을 달리 한다고 본다면 때로는 양 기본권의 경합적 관계가 생기는 경우도 있을 수 있으나 언제나 그런 관계가 생기는 것은 아니다. 즉, 양심과 사상, 종교, 학문, 예술 등 인간의 정신작용은 논리적으로 명확하게 구분되는 것이 아닐 뿐 아니라 서로 배척하는 개념도 아니다. 양심은 신앙이나 사상, 학문 등에 기초한 것이 보통이며, 특히 사상, 신앙이나 학문적 견해, 또는 소신이 대외적으로 표현되는 과정에서는 윤리적 문제를 수반할 수 있다. 그런 점에서 양심의 자유와 종교의 자유, 사상의 자유, 학문의 자유 등은 서로 연관되어 있으며, 이들의 엄격한 구별은 사실상 불가능하다.

⑵ 표현의 자유 등

양심의 자유를 내면적 자유로 이해하는 경우, 표현의 자유 등 양심을 대외적으로 표현하고 실행하는 자유와 양심의 자유 사이에 경합관계는 존재하지 아니한다. 그러나 양심의 자유가 양심실현의 자유까지 포함하는 것으로 이해하는 경우 표현의 자유, 직업의 자유, 거주이전의 자유 등과는 경합관계가 생기게 된다.

표현의 자유와의 구별에 관해서 표현의 자유는 의견표현의 범위에 제한이 없음에 반하여 양심의 자유에는 자신의 윤리적 확신에 기초하지 않은 윤리적으로 중립적인 표현은 포함되지 않으며, 표현의 자유에서의 표현은 타인의 의견을 그대로 전달하는 것도 포함되나 양심의 자유는 자신의 고유한 사유에서 유래하여야 한다는 점에서 구별된다.

그러나 양심의 자유 속에는 사상의 자유까지 포함되어 있는 것으로 해석하는 것이 보통이다. 다만, 표현 자체만을 생각하면 표현의 자유에 있어 표현은 양심의 자유에 있어서의 양심표현보다는 넓은 개념이라 할 수 있을 것이고, 그런 점에서 양심의 자유에 있어 양심실현의 자유의 일환으로서 양심의 자유는 표현의 자유에 대한 특별법적 성격을 가진다고 할 수 있다.[442]

---

440) D. Franke, Gewissensfreiheit und Demokratie-Aktuelle Probleme der Gewissensfreiheit, AöR Bd. 114. Heft 1, 1989, S. 18.
441) 홍성방, 전게서, 138면.
442) BVerfGE 32, 98, 107.

5. 의의 및 내용

(1) 의의

양심을 정확하게 개념 정의하기는 어렵다. 독일의 철학자 칸트(Kant : 1724~1804)는 '저 하늘에 반짝이는 별과 가슴 속에서 울려오는 양심의 소리'(der bestirnte Himmel über mir des Moralisch Geistes in mir)라 표현하기도 하였다.

이에 대해 독일연방행정재판소는 양심을 '인간의 내면에 원래부터 존재하는 옳고 그름에 대한 확신과 이로부터 나오는 의무부과, 즉 특정의 행동을 하거나 하지 못하도록 하는 것'이라고[443] 하였고, 독일연방헌법재판소는 '양심상의 결정이란 모든 진지한 윤리적 판단, 즉 선과 악에 대한 판단을 말하며, 개인은 특정상황에서 이 판단에 절대적으로 따를 의무를 진다고 내적으로 체험하기 때문에 심각한 양심상의 갈등 없이 이 판단에 반하는 행동을 할 수 없는 것을 말한다'고[444] 판시하였다.

우리 헌법재판소도 '헌법이 보호하려는 양심은 어떤 일의 옳고 그름을 판단함에 있어서 그렇게 행동하지 아니하고는 자신의 인격적 존재가치가 허물어지고 말 것이라는 강력하고 진지한 마음의 소리이지 막연하고 추상적인 개념으로서의 양심이 아니다'라고 하고 '어쩔 수 없이 음주측정에 응하였다 하여 내면적으로 구축된 인간양심이 왜곡, 굴절된다고 할 수 없다'고 판시한 바 있다.[445]

<헌법재판소 1991. 4. 1. 89헌마160>

여기의 양심이란 세계관, 인생관, 주의, 신조 등은 물론 이에 이르지 아니하여도 보다 널리 개인의 인격 형성에 관계되는 내심에 있어서의 가치적, 윤리적 판단도 포함된다고 볼 것이다.

양심의 자유의 내용과 관련하여서는 협의의(윤리적) 양심설과 광의의(사회적) 양심설이 대립되어 있다. 다수설인 사회적 양심설은 양심의 자유는 내심의 자유이며, 윤리적인 면에 한정시킬 필요가 없다고 한다. 이에 반하여 윤리적 양심설은 양심을 좁게 이해하여 내심의 자유 중 특히 윤리적 성질을 가지는 면에 한정시키고자 한다.[446] 또한, 우리 헌법은 사상과 양심을 모두 인간의 내심작용, 즉 세계관·인생관·주의·신조 등을 의미하는 것으로 보아 양자를 일체로 보고 있다. 따라서 윤리적 확신이 양심의 자유의 본체라고 보는 견해도 있다.[447]

우리 헌법재판소는 윤리적 양심설의 태도를 취하고 있다.[448]

<헌법재판소 1991. 4. 1. 89헌마160> 민법 제764조의 위헌여부

양심이란 세계관·인생관·주의·신조 등은 물론 이에 이르지 아니하여도 보다 널리 개인의 인격형성에 관계되는 내심에 있어서의 가치적·윤리적 판단도 포함된다고 볼 것이다. 그러므로 양심의 자유에 널리 사물의 시시비비나 선악과 같은 윤리적 판단에 국가가 개입해서는 안 되는 내심적 자유는 물론 이와 같은 윤리적 판단은 국가권력에 의하여 외부에 표명하도록 강제 받지 않는 자유, 즉 윤리적 판단사항에 관한 침묵의 자유까지 포괄한다고 할 것이다. 이와 같이 해석

443) BVerwGE 7, 242(246).
444) BVerfGE 12, 45(55); 48 123(173).
445) 헌법재판소 1997. 3. 27. 95헌가14 등.
446) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 378면.
447) 홍성방, 전게서, 140면.
448) 인간의 윤리적 내심영역(헌법재판소 2002. 1. 31. 2001헌바43), 내심에서 우러나오는 윤리적 확신(헌법재판소 2002. 4. 25. 98헌마425) 등의 표현을 쓰고 있다.

하는 것이 다른 나라의 헌법과 달리 양심의 자유를 신앙의 자유와도 구별하고 사상의 자유에 포함시키지 않은 채 별개의 조항으로 독립시킨 우리 헌법의 취지에 부합할 것이다.

⑵ 내용

양심의 자유의 내용에 관해서는 양심형성의 자유와 양심유지의 자유(침묵의 자유, 양심추지의 금지, 양심에 반하는 행위를 강제당하지 않을 자유)를 내용으로 보는 견해,[449] 양심결정의 자유와 침묵의 자유(양심추지의 금지, 양심에 반하는 행위의 금지)를 내용으로 보는 견해,[450] 양심형성 및 결정의 자유, 양심을 지키는 자유(침묵의 자유, 양심추지의 금지, 양심에 반하는 작위의무로부터의 해방), 양심실현의 자유를 내용으로 보는 견해,[451] 양심의 형성(또는 결정)의 자유와 양심의 활동의 자유(양심활동의 소극적 자유 : 침묵의 자유, 양심의 추지금지를 포함하는 양심을 표명하도록 강제당하지 않을 자유)와 양심에 반하는 행동을 당하지 않을 자유, 양심활동의 적극적 자유를 그 내용으로 보는 견해,[452] 양심의 자유는 양심형성(또는 결정)의 자유, 양심유지의 자유를 그 내용으로 하며, 양심유지의 자유는 양심을 언어(침묵의 자유)나 행동(양심추지의 금지)으로 표명하도록 강제당하지 않을 자유 및 양심에 반하는 행동을 강제당하지 않을 자유를 포함한다고 보는 견해가[453] 있다.

우리 헌법재판소는 양심형성 및 결정의 자유, 양심을 지키는 자유(침묵의 자유, 양심추지의 금지, 양심에 반하는 작위의무로부터의 해방), 양심실현의 자유를 내용으로 보고 있다.

<헌법재판소 1998. 7. 16. 96헌바35> 구 국가보안법 제10조 위헌소원

헌법 제19조가 보호하고 있는 양심의 자유는 양심형성의 자유와 양심적 결정의 자유를 포함하는 내심적 자유뿐만 아니라 양심적 결정을 외부로 표현하고 실현할 수 있는 양심실현의 자유를 포함한다고 할 수 있다. 내심적 자유, 즉 양심형성의 자유와 양심결정의 자유는 내심에 머무르는 한 절대적 자유라고 할 수 있지만 양심실현의 자유는 타인의 기본권이나 다른 헌법적 질서와 저촉되는 경우 헌법 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있는 상대적 자유라고 할 수 있다. 그리고 양심실현은 적극적인 작위의 방법으로도 실현될 수 있지만 소극적인 부작위에 의해서도 그 실현이 가능하다 할 것이다.

그런데 이 사건 심판대상 법률조항이 규정한 불고지죄는 국가의 존립과 안전에 저해가 되는 타인의 범행에 관한 객관적 사실을 고지할 의무를 부과할 뿐이고 개인의 세계관·인생관·주의·신조 등이나 내심에 있어서의 윤리적 판단을 그 고지의 대상으로 하는 것은 아니므로 양심의 자유 특히 침묵의 자유를 직접적으로 침해하는 것이라고 볼 수 없을 뿐만 아니라 국가의 존립과 안전에 저해가 되는 죄를 범한 자라는 사실을 알고서도 그것이 본인의 양심이나 사상에 비추어 범죄가 되지 아니한다거나 이를 수사기관 또는 정보기관에 고지하는 것이 양심이나 사상에 어긋난다는 이유로 고지하지 아니하는 것은 결국 부작위에 의한 양심실현, 즉 내심의 의사를 외부에 표현하거나 실현하는 행위가 되는 것이고 이는 이미 순수한 내심의 영역을 벗어난 것이므로 이에 대하여는 필요한 경우 법률에 의한 제한이 가능하다 할 것이다. 그리고 여러 가지 국내의 정세의 변화에도 불구하고 남·북한의 정치·군사적 대결이나 긴장관계가 여전히 존재하고 있는 우리의 현실, 불고지죄가 보호하고자 하는 국가의 존립과 안전이라는 법익의 중요성, 범인의 친족에 대한 형사처벌에 있어서의 특례설정 등 제반사정에 비추어 볼 때, 이 사건 심판대상 법률

449) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 547면 이하.
450) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 452면 이하.
451) 허영, 전게서, 380면 이하.
452) 계희열, 「헌법학」(상), 박영사, 1995, 291면 이하.
453) 홍성방, 전게서, 142~143면.

조항이 양심의 자유를 제한하고 있다하더라도 그것이 헌법 제37조 제2항이 정한 과잉금지의 원칙이나 기본권의 본질적 내용에 대한 침해금지의 원칙에 위반된 것이라고 볼 수 없다.

1) 양심의 형성과 결정의 자유

개인은 윤리적 선악의 판단기준과 인생과 세계에 대한 인식체계를 자유롭게 형성할 수 있다. 이는 국가가 특정 윤리적 기준이나 공식적으로 인정된 특정사상을 결정하고 협박이나 세뇌, 최면이나 심리학적 방법 등에 의해 이를 적극적으로 개인에게 주입, 강요하거나 그와 다른 윤리적 판단기준이나 사상의 형성을 차단하는 것은 허용되지 아니함을 의미한다.

양심결정의 자유는 자신의 양심과 사상에 따라 특정문제에 대한 선악, 옳고 그름, 논리적 타당여부의 판단에 있어서 자유로우며 특정한 결정을 강제당하거나 결정의 방해를 받지 아니함을 의미한다. 이는 이러한 양심상의 결정에 의한 불안이나 공포로부터의 자유를 의미한다. 또한 국가가 진실함과 올바름에 대한 결정을 하는 것을 부인함을 의미하며 사회적 소수자에 대한 관용을 포함한다.

2) 양심실현의 자유

가. 소극적 양심실현의 자유

자신의 사상과 양심을 소극적으로 실현하는 자유로서 자신의 양심을 대외적으로 표현할 것을 강요받지 아니하며 자신의 양심에 반하는 행위를 강요당하지 아니하는 자유를 의미한다.

침묵의 자유는 자신이 어떠한 사상이나 양심을 가지고 있는지를 대외적으로 표현할 것을 강요받지 않는 자유를 의미한다.

양심에 반하는 행위를 강요받지 않을 자유는 자신의 사상이나 양심에 반하는 행위를 강요받지 않을 자유를 말한다. 이와 관련하여 종래 우리나라나 외국의 판례상 문제가 된 사안으로 양심적 반전론이나 국기에 대한 경례거부, 사죄광고 등이 문제된 바 있다.

<대법원은 1992. 9. 14. 92 도 1534>

종교의 교리를 내세워 법률이 규정한 병역의무를 거부하는 것과 같은 이른 바 '양심상의 결정'은 헌법에서 보장한 종교와 양심의 자유에 속하는 것이 아니다.

학력이나 연령, 예체능상의 특기를 이유로 일정병역의무부과대상자를 현역입영이 아닌 공익근무요원으로 복무토록 하면서 신앙이나 양심을 이유로 입영을 거부하는 자에게 형벌로써 이를 강제하는 것은 첫째, 이러한 경우도 공익근무요원으로 평화적 업무에 종사토록 함으로써 신앙과 양심의 자유와 병역의무의 충돌을 조정할 수 있음에도 굳이 현역복무를 강요하는 것은 방법의 적절성도 문제가 있고 최소침해의 원칙에도 반한다.

둘째, 학력과 연령, 예체능상의 특기와 달리 개인의 신앙이나 양심을 병역의무의 이행에 전혀 고려하지 않는 것은 양심의 자유와 종교의 자유의 가치를 지나치게 과소평가하는 것으로 법익의 균형성에도 맞지 않다.

셋째, 양심적 반전론자로 인정되기 위해서는 독일연방헌법재판소의 판결처럼[454] 병역거부에 대한 구속적·무조건적 의무의 존재의 인식에 따라 양심적 고통 없이는 이에 반해 행동할 수 없

454) BVerfGE 12, 45.

는 진실되고, 윤리적인 양심상의 결정이 요구되는 것이며 그런 점에서 이러한 양심상의 결정에 반하는 병역의무의 강제는 가혹한 것이다.

넷째, 양심적 반전론자의 집총병역거부권은 헌법상 최고가치로서 인간의 자유로운 인격과 존엄, 그로부터 나오는 불가침적 인권으로서 양심의 자유에 기초하여 나오는 것이므로 개인의 신앙이나 양심상의 결정에 반하는 병역의무의 강제보다는 대안적 해결방법을 통해 양심상의 고통을 덜 주는 방법을 선택하여야 할 것이다.

사죄광고는 허위사실을 유포하여 타인의 명예를 훼손한 것이 객관적 사실이고 그러한 행위를 한 자가 이를 인정하는 경우라면 자기의 양심을 이유로 사죄광고를 거부하는 것은 엄밀히 말해서 개인의 윤리적 판단에 따라 사죄할 수도 있고 하지 아니할 수도 있는 문제는 아니라고 할 수 있다. 그러나 비록 법원의 확정판결에서 피고가 패소하였다 하더라도 피고가 그 사실을 인정하지 않고 판결을 수용하지 않아 사죄할 의사가 없음에도 사죄광고를 강요하는 것은 그의 도덕적 판단에 배치되는 행위를 강요하는 것으로 양심과 관련된다고 할 것이다.

또한, 피고가 자기의 잘못으로 원고의 명예를 훼손한 사실을 부인하고 있음에도 사죄광고를 강요하는 것은 원고의 감정충족을 위하여 피고의 양심의 자유에 대한 과도한 제한이므로 피고의 패소판결이나 유죄판결의 게재 등으로 그쳐야 할 것이다.

우리 대법원은 국기에 대한 경례를 거부를 거부한 학생에 대한 제적처분은 정당하다고 한 바 있다.[455]

<헌법재판소 1995. 12. 28. 91헌마80>

입법목적과 필요성에 따라 대간첩작전의 수행을 임무로 하는 전투경찰순경을 현역병으로 입영하여 복무중인 군인에서 전임시켜 충원할 수 있도록 한 이 사건법률조항들이 그 자체로서 청구인의 행복추구권 및 양심의 자유를 침해한 것이라 볼 수 없다.

<대법원 1997. 6. 13. 96다56115>

구 사회안전법이 반공정신확립이나 전향의사 여부를 보안처분면제요건 또는 보안처분기간의 갱신여부 판단기준으로 하는 것은 죄를 다시 범할 현저한 위험성의 유무를 판단하기 위한 자료를 수집하기 위한 과정에 불과할 뿐 전향 의사를 강요하는 것은 아니므로 양심의 자유침해라고 볼 수 없다.

나. 적극적 양심실현의 자유

적극적 양심실현의 자유는 자신의 양심에 따라 표현하거나 활동할 수 있는 자유를 의미한다.

<헌법재판소는 1998. 7. 16. 96헌바35>

헌법 제19조가 보호하고 있는 양심의 자유는 양심형성의 자유와 양심결정의 자유를 포함하는 내심적 자유(forum internum)뿐만 아니라 양심적 결정을 외부로 표현하고 실현할 수 있는 양심실현의 자유(forum externum)를 포함한다고 할 수 있다. 그리고 양심실현은 적극적인 작위의 방법으로도 실현될 수 있지만 소극적으로 부작위에 의해서도 그 실현이 가능하다.

이에 반하여 대법원은 보안사의 민간인 정치사찰을 폭로하기 위해 양심선언을 위하여 부대를 빠져나간 경우 군무이탈죄로 처벌한 바 있다.[456]

---

455) 대법원 1976. 4. 27. 75누249.
456) 대법원 1993. 6. 8. 93도766.

6. 효력

양심의 자유는 소극적 권리이므로 국가에 대하여 양심에 반하는 행위를 강요당하지 않고, 특정행위를 하지 못하게 강요 받지 않으며, 그 침해에 대하여 구제를 받을 수 있으나 국가에 대하여 적극적으로 급부를 청구할 수 있는 권리는 아니다. 또한, 간접적 대사인적 효력이 인정된다.

7. 제한 및 한계

양심의 자유를 제한할 수 있는가에 대해서는 양심의 자유의 내용을 내심의 자유에 한정할 것인가, 양심실현의 자유까지 인정할 것이냐에 따라 다르다.

대법원은 헌법이 보장하는 양심의 자유는 정신적인 자유로서 어떠한 사상, 감정을 가지고 있더라도 그것이 내심에 머무르는 한 절대적 자유이므로 제한할 수 없다고 판시한 바 있다.[457]

헌법재판소는 우리헌법도 제19조에서 양심의 자유를 보장하고 있으며, 내심의 의사만으로 범죄가 성립되는 것은 아니라 할 것이다.[458] 그리고 내심적 자유, 즉 양심형성의 자유와 양심결정의 자유는 내심에 머무르는 한 절대적 자유라 할 수 있지만 양심실현의 자유는 타인의 기본권이나 다른 헌법적 질서와 저촉되는 경우 헌법 제37조 제2항에 따라 국가안전보장, 질서유지, 공공복리를 위하여 법률에 의하여 제한될 수 있는 상대적 자유라 할 수 있다고[459] 판시한 바 있다.

양심의 자유의 보장은 인간의 정신적 자율성과 다양성을 보장하기 위한 것이며, 사회적으로 고립된 개인의 양심상의 결정이나 이에 따른 무정부적 행위를 보호하기 위한 것은 아니므로 법적인 자유로서 무제한적, 절대적 자유일 수 없다. 따라서 제37조 제2항과 계엄 및 긴급명령에 따라 제한이 가능하다.

<헌법재판소 1998. 7. 16. 96헌바35>

부작위에 의한 양심실현, 즉 내심의 의사를 외부에 표현하거나 실현하는 행위가 되는 것이고 이는 이미 순수한 내심의 영역을 벗어난 것이므로 이에 대하여는 필요한 경우 법률에 의한 제한이 가능하다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 양심의 자유로서 보호될 가능성이 가장 큰 것은?

① 재판에서의 단순사실에 관한 증언거부
② 기자의 취재원에 관한 묵비권
③ 종교교리에 의한 병역의무의 이행거부
④ 종교적 이유에 의한 방위세 납세거부
⑤ 법원의 사죄광고 명령에 대한 거부

[정답] ⑤

[해설] 헌법재판소 1991. 4. 1. 89헌마160.

---

457) 대법원 1984. 1. 24. 82누163.
458) 헌법재판소 1997. 3. 27. 95헌바50.
459) 헌법재판소 1998. 7. 16. 96헌바35.

2. 다음 양심의 자유에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 1962년 제3공화국헌법부터 독자적 자유권의 하나로 분리하여 규정하고 있다.
② 독일기본법은 양심상의 결정과 충돌하는 법률적 의무에 대한 복종거부권을 인정한다.
③ 우리 헌법에는 사상의 자유를 보장하는 명문규정은 없다.
④ 양심의 자유는 주관적 공권인 동시에 객관적 가치로서의 성격을 가지고 있다.
⑤ 양심의 자유는 다양한 윤리적 가치관이 존중되도록 지원한다.

[정답] ②
[해설] 독일기본법상 이를 인정하는 명문규정은 없다.

3. 다음 헌법 제19조의 양심의 자유에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 헌법 제19조의 양심이란 개인의 인격형성에 관계되는 내심에서의 가치적·윤리적 판단도 포함된다.
② 양심에는 단순한 사실에 관한 지식이나 기술적 지식도 포함된다.
③ 양심은 종교적 확신을 의미하는 신앙보다 넓은 개념이다.
④ 국회의원 또는 법관의 직업적 양심을 의미하는 헌법 제46조 제2항과 제103조에서의 양심과 구별된다.
⑤ 양심결정의 자유와 침묵의 자유를 포함하는 견해가 있다.

[정답] ②
[해설] 단순한 사실에 관한 지식이나 기술적 지식은 포함되지 않는다.

♣ 요점정리

1. 우리 건국헌법은 신앙과 양심을 동일한 조항에서 규정하였으나 제3공화국 헌법 이후 신앙과 양심을 별도로 규정하였고, 현행 헌법은 제19조에서 규정하고 있다.

2. 양심의 자유는 정신적 자유의 근원을 이루고, 양심의 형성과 결정 그리고 양심의 실현에 대한 자유권으로서의 성격을 가지며, 자유로운 정치과정의 전제가 되고, 민주적 법치국가에 있어 객관적 가치질서로서의 성격도 가진다.

3. 양심이란 세계관, 인생관, 주의, 신조 등은 물론 이에 이르지 아니하여도 보다 널리 개인의 인격 형성에 관계되는 내심에 있어서의 가치적, 윤리적 판단도 포함된다고 볼 것이다.

4. 헌법 제19조가 보호하고 있는 양심의 자유는 양심형성의 자유와 양심결정의 자유를 포함하는 내심적 자유(forum internum)뿐만 아니라 양심적 결정을 외부로 표현하고 실현할 수 있는 양심실현의 자유(forum externum)를 포함한다고 할 수 있다. 그리고 양심실현은 적극적인 작위의 방법으로도 실현될 수 있지만 소극적으로 부작위에 의해서도 그 실현이 가능하다.

5. 부작위에 의한 양심실현, 즉 내심의 의사를 외부에 표현하거나 실현하는 행위가 되는 것이고 이는 이미 순수한 내심의 영역을 벗어난 것이므로 이에 대하여는 필요한 경우 법률에 의한 제한이 가능하다.

제28강 언론·출판의 자유

♣ 학습목표

언론·출판의 자유를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

현대적 언론자유의 개념
민주주의 구성원리
의사표현의 자유
알권리
보도의 자유, 취재의 자유, 언론기관접근권
허가제 및 검열제
명확성이론, 이익형량이론, 명백하고 현존하는 위험의 원칙, 우월적 지위의 원칙

♣ 사전테스트

1. 언론·출판의 자유는 자신의 의사를 표현하는 자유만을 보호한다.

정답 : X
해설 : 자기의 사상이나 의견의 자유로운 표명(발표의 자유)과 그것을 전파할 자유(전달의 자유)를 의미한다(헌법재판소 1992. 2. 25. 89헌가104).

2. 언론·출판의 자유는 민주주의와는 무관하다.

정답 : X
해설 : 언론·출판의 자유는 국민의 여론을 형성하는 민주주의 구성원리로서 기능한다. 즉, 개인의 자유로운 인격발전을 이룩하고, 인간의 존엄을 유지시켜 주며, 국민주권을 실현시켜주는 역할을 한다(헌법재판소 1992. 2. 25. 89헌가104).

3. 언론·출판의 자유는 행복추구권에 대해서 일반법적 성격을 가지며, 종교의 자유나 학문의 자유, 예술의 자유에 대해서는 특별법적인 성격을 가진다.

정답 : X
해설 : 행복추구권에 대해서 특별법적인 성격을 가지며, 종교의 자유나 학문의 자유, 예술의 자유에 대해서는 일반법적 성격을 가진다.

♣ 돌발퀴즈

검인정제도는 연구결과를 일반저작물로 출판하는 것을 금지하는 것이다.

[정답] X

[해설] 출판물을 교과서로 사용할 수 없도록 하는 것뿐이므로 출판의 자유를 침해하는 것은 아니다(헌법재판소 1992. 11. 12. 89헌마88).

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

언론·출판의 자유는 영국에서 밀턴(John Milton : 1608~1674)이 1644년 '아레오파기티카'(Areopagitica)를 발표하여, '사상의 공개시장' 또는 '자동조정 작용(the self-righting process)'과 같은 현대적 언론자유의 개념을 개척하였다. 이 후, 군주와 의회의 투쟁을 통하여 1647/49년의 '인민협약'(Agreement of the People)에서 선언되었으나 크롬웰(Richard Cromwell : 1626~1712)에 의해 거부되었고, 1695년 검열법(The Licensing Act)의 폐지로 확보되었다.

또한, 1776년 버지니아권리장전 제12조(언론·출판의 자유를 제한하는 것은 전제적 정부라 할 수 있다), 1791년 미국수정헌법 제1조(연방의회는 언론·출판의 자유를 제한하거나 평온한 집회권, 청원권을 침해하는 법률을 제정할 수 없다)에서 법률로도 제한할 수 없는 절대적 자유권으로 규정하였다.

1789년 프랑스 인권선언 제11조에서는 표현의 '자유를 인간의 가장 귀중한 권리의 하나'로 규정하였다.

우리 헌법은 제21조에서 언론·출판의 자유를 보장하고 있다.

2. 의의 및 기능

⑴ 의의

언론·출판의 자유는 사상·양심 및 지식·경험을 표현하는 자유를 말한다. 따라서 표현의 자유라고도 한다. 이는 양심의 자유, 종교의 자유, 학문과 예술의 자유 등 내심의 자유를 행위로서 외부에 표현하는 자유이기 때문에 '외면적 정신활동의 자유'라고 할 수 있다. 즉, 내심적 정신활동의 연장선상에 있다.

그러나 언론·출판의 자유는 자신의 의사를 표현하는 자유를 보호하려는 데 그치는 것이 아니다. 이는 고립된 개인이 아니라 사회 내에서 개인과 개인의 관계를 연결해 주는 '정신적 의사소통의 자유'(die Freiheit der geistigen Kommunikation)로서 자신의 의사를 타인에게 전달하는 역할을 수행한다.[460]

인간이 인간인 것이 타인과의 관계에서 비롯되는 것이라면, 언론·출판의 자유는 이러한 관계를 가능하게 하는 전제가 된다.

<헌법재판소 1992. 2. 25. 89헌가104> 군사기밀보호법 제6조 등에 대한 위헌심판

460) 프랑스 인권선언 제11조 제1문은 사상과 의견의 자유로운 소통이라고 표현하였다.

의사표현의 자유란 자기의 사상이나 의견의 자유로운 표명(발표의 자유)과 그것을 전파할 자유(전달의 자유)를 의미한다.

⑵ 기능

언론·출판의 자유는 역사적으로는 근대국가의 성립에 있어서 국가권력 내지 군주권력에 대한 제한의 기초이론으로서 자유국가 성립에 커다란 역할을 하였다.

그러나 언론·출판의 자유는 자유민주국가에서는 다른 기능을 수행하고 있다. 민주주의는 국민주권을 핵심으로 하는데, 국민주권은 선거에 의하여 행사되며, 이는 표현의 자유를 전제로 한다. 즉, 민주정치에 있어서 국정에 관한 표현의 자유는 국정을 보고, 듣고, 말하고, 비판하는 자유이기 때문에 민주정치의 생명선으로 여겨지고 있다. 이러한 언론·출판의 자유는 국민의 여론을 형성하는 민주주의 구성원리로서 기능을 한다.

또한, 언론·출판의 자유는 사회 내에서 인간의 인격이 직접적으로 표현된 것이기도 한다.[461]

<헌법재판소 1992. 2. 25. 89헌가104> 군사기밀보호법 제6조 등에 대한 위헌심판

언론·출판의 자유보장은 개인의 자유로운 인격발전을 이룩하고, 인간의 존엄을 유지시켜 주며, 국민주권을 실현시켜주는 역할을 한다.

3. 법적성격 및 주체

⑴ 법적성격

언론·출판의 자유의 법적성격에 대하여 개인적 자유권설, 제도적 보장설이 대립되어 왔다. 그러나 통설은 개인적 자유권과 제도적 보장을 병유하고 있다고 본다. 이러한 언론·출판의 자유는 개인의 주관적 공권임과 동시에 자유언론제도를[462] 보장하고 있다.

그 밖에도 언론·출판의 자유는 근대헌법의 불가결한 요소로서 객관적인 법질서를 의미한다.[463]

또한, 언론·출판의 자유는 행복추구권에 대해서 특별법적인 성격을 가지며, 종교의 자유나 학문의 자유, 예술의 자유에 대해서는 일반법적 성격을 가진다.

⑵ 주체

모든 자연인에게 주체성이 인정되며, 법인에게는 보도의 자유에 대한 주체성이 인정된다.

4. 내용

<헌법재판소 1992. 2. 25. 89헌가104> 공권력에 의한 재산권침해에 대한 헌법소원

표현의 자유는 전통적으로 사상 또는 의견의 자유로운 표명(발표의 자유)과 그것을 전파할 자유(전달의 자유)를 의미하는 것으로서 인간으로서의 존엄과 가치를 유지하고 행복을 추구하며

461) BVerfGE 7, 198(208).
462) BVerfGE 20, 162(175)
463) BVerfGE 7, 198(208).

국민주권을 실현하는 데 필수불가결한 것으로 오늘날 민주국가에서 국민이 갖는 가장 중요한 기본권의 하나로 인식되고 있는 것이다. 그런데 사상 또는 의견의 자유로운 의사의 형성은 충분한 정보에의 접근이 보장됨으로써 비로소 가능한 것이며, 다른 한편으로 자유로운 표명은 (정보의) 자유로운 수용 또는 접수와 불가분의 관계에 있다고 할 것이다. 그러한 의미에서 정보에의 접근·수집·처리의 자유, 즉 알 권리도 표현의 자유에 당연히 포함되는 것이다.

(1) 의사표현의 자유

1) 개념

의사표현의 자유란 사상·양심 및 지식·경험 등과 관련된 자신의 의사를 언론·출판에 의하여 외부에 표현하고, 전달하며, 자신의 의사표명을 통해서 여론형성에 참여할 수 있는 자유를 말한다.

그런데 의사표현의 자유에서 말하는 '의사'의 개념과 관련하여 의사의 개념을 좁게 해석하여 합리적이고 평가적인 사고의 과정을 거친 '평가적 의사'만을 의사로 보려는 평가적 의사설과[464] 단순한 사실의 전달까지도 의사에 포함시키려는 사실전달포함설이[465] 대립되어 있다.

생각건대, 의사를 넓게 해석하는 것이 타당하다고 본다. 첫째, 평가적인 의사와 단순한 사실의 전달을 확연하게 구별하는 것이 쉽지 않다. 둘째, 인식론적 근거에서 '평가를 수반하지 않는' 사실전달이란 존재하지 않는다. 셋째, 어떤 사실에 대한 주장은 일반대중이 공적의사를 형성하는 데 결정적 역할을 한다. 넷째, 의사를 단순한 사실의 전달까지도 포함하는 것으로 이해하여야 의사표현의 자유를 흠결 없이 보호해 줄 수 있다는 것이다.

평가적 의사설을 주장하는 견해는 단순한 사실의 전달은 보도의 자유에 의하여 보호되기 때문에 의사표현의 자유에서는 평가적 의사만을 보호하는 것으로 이해하는 것이 합리적이라고 한다.[466] 그러나 보도기관의 사실전달만을 고려의 대상으로 한정한다면 사인에 의한 사실전달을 보호해 줄 수 없게 된다. 즉, 보도의 자유를 매스컴의 자유로 정의하는 한 사인에 의한 사실전달을 일반적인 의미에서 보도라 부를 수는 없는 것이다.

따라서 진실이 아닌 사실전달, 왜곡된 설명, 사실의 왜곡, 진실이 아닌 보도, 잘못된 인용이[467] 아닌 한 그것이 평가적인 것이든 또는 사실전달이든 의사표현의 자유에 의해 보호되는 것으로 보아야 한다.[468]

2) 언론·출판의 의미

언론이라 함은 구두에 의한 표현, 출판이라 함은 인쇄물에 의한 표현을 의미한다. 표현의 자유는 내심을 외부에 표현하는 자유이므로 언론·출판이라고 할 때의 언론·출판은 사상·양심 및 지식·경험을 표현하는 수단을 모두 포함한다.

미국에서는 '상징적 표현'(symbolic expression)까지 표현의 자유의 내용이 된다고 한다. 여기서 상징적 표현이란 일정한 사상, 의견을 언어와 문서에 의하지 않고, 행동으로 표시하여(예컨대, 경찰관에게 사살된 자의 관을 메고 침묵의 행진을 하는 것) 다른 사람에게 전달하는 것을 말한다.[469]

---

464) BVerfGE 7, 125, 133; 33, 1, 14; 61, 1, 8; 65, 1, 41 등; 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 525면 참조.

465) E. Stein, Staatsrecht, 8. Aufl., 1982, S. 108; 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 159면.

466) 허영, 전게서, 525면.

467) BVerfGE 54, 208(219).

468) 홍성방, 전게서, 159~160면 참조.

469) 미연방대법원에 상징적 표현과 관련된 대표적 사건으로는 O'Brien 사건이 있다. 이는 1966년 3월 31일 베트남 전쟁에 반대하는 표현으로 자신들의 병역등록카드를 법원계단에서 소각한 사건이다. 이외에

<헌법재판소 1992. 11. 12. 89헌마88> 교과서 국정제 및 검·인정제 위헌여부

연구결과를 일반저작물로 출판하는 것 자체는 금지하는 것이 아니고 출판물을 교과서로 사용할 수 없도록 하는 것뿐이므로 출판의 자유를 침해하는 것은 아니다.

<헌법재판소 1993. 5. 13. 91헌바17> 음반에 관한 법률 제3조 등에 대한 헌법소원

언론·출판의 자유의 내용 중 의사표현·전파의 자유에 있어서 의사표현 또는 전파의 매개체는 어떠한 형태이건 가능하며, 그 제한이 없다. 즉, 담화·연설·토론·연극·방송·음악·영화·가요 등과 문서·소설·시가·도화·사진·조각·서화 등 모든 형상의 의사표현 또는 의사전파의 매개체를 포함한다. 그러므로 음반 및 비디오물도 의사형성적 작용을 하는 한 의사의 표현·전파의 형식의 하나로 인정되며, 이러한 작용을 하는 음반 및 비디오물의 제작은 언론·출판의 자유에 의해서도 보호된다.

<헌법재판소 1998. 2. 27. 96헌바2> 옥외광고물관리법 제3조 위헌소원

광고물도 사상·지식·정보 등을 불특정다수인에게 전파하는 것으로서 언론·출판의 자유에 의한 보호대상이 된다.

⑵ 알권리(열독의 자유, 정보의 자유)

1) 의미

'알 권리'(Right to know)는 신문, 방송, TV와 같은 일반적으로 접근할 수 있는 정보원으로부터 의사형성에 필요한 정보를 자유롭게 수집하고, 수집된 정보를 취사·선택할 수 있는 권리를 의미한다.

독일기본법 제5조 제1항 제1문은[470] 알 권리를 명문으로 규정하고 있으나 우리나라에서는 1996년 공공기관의 정보제공에 관한 법률이 제정되어 법률적 차원에서 보장하고 있다.

2) 성격 및 근거와 내용

알 권리는 자유권(정보수집, 취재활동에 대한 침해배제요구)과 청구권(정보공개청구)의 성격을 동시에 가지고 있으며, 그 법적 근거는 헌법 제21조이다.[471] 알 권리는 정보수집권과 정보공개청구권을 내용으로 하며, 구체적인 권리이며, 최대한 보장되어야 한다.

<헌법재판소 1989. 9. 4. 88헌마22> 공권력에 의한 재산권침해에 대한 헌법소원

표현의 자유는 오늘날 민주국가에서 국민이 갖는 가장 중요한 기본권의 하나로 인식되고 있는 것이다. 그런데 사상 또는 의견의 자유로운 표명은 자유로운 의사의 형성을 전제로 하는데, 자유로운 의사의 형성은 충분한 정보에의 접근이 보장됨으로써 비로소 가능한 것이며, 다른 한편으로 자유로운 표명은 자유로운 수용 또는 접수와 불가분의 관계에 있다고 할 것이다. 그러한 의미에서 접근·수집·처리의 자유, 즉 알 권리는 표현의 자유에 당연히 포함되는 것으로 보아야 한다.

고 흑색완장을 차고 단식함으로써 베트남 전쟁을 반대하거나(Tonker v. Des Moines), '징병철회'라고 쓴 상의를 입고 법원복도를 다닌 사건(Cohen v. Califonia) 등이 있다.

470) 누구든지 말, 글 그리고 그림으로써 자유로이 의사를 표현하고 전파하며 일반적으로 접근할 수 있는 정보원으로부터 방해를 받지 않고 정보를 얻을 권리를 가진다.

471) 이와는 다르게 헌법 제10조에서 찾거나(김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 622면) 헌법 제21조 제1항, 제10조, 제34조 제1항 등에서 찾는 견해도 있다(권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 469면).

<헌법재판소 1991. 5. 13. 90헌마133>

정보에의 접근·수집·처리의 자유, 즉 알 권리는 헌법 제21조 소정의 표현의 자유와 표리의 관계에 있으며, 자유권적 성질과 청구권적 성질을 공유하는 것인바, 이러한 알 권리의 실현을 위한 법률이 제정되어 있지 않더라도 그 실현이 불가능한 것은 아니며, 이러한 알 권리에 의하여 사건당사자의 형사확정소송기록에 대한 접근의 자유도 보장되는 것이다.

<헌법재판소 1994. 8. 31. 93헌마174> 지세명기장 열람거부 등 위헌확인

국가 또는 지방자치단체의 기관이 보관하고 있는 문서 등에 관하여 이해관계 있는 국민이 공개를 요구함에도 정당한 이유 없이 이에 응하지 아니하거나 거부하는 것은 국민의 알권리를 침해하는 것이다.

그러나 국가기밀의 경우처럼 정보의 비공개의 공익이 알 권리보다 큰 경우에는 이를 존중하여야 하므로, 알 권리를 근거로 하여 국가기관에게 모든 정보의 공개를 요구할 수는 없다. 그러나 저속한 간행물의 출판을 전면금지시키고 출판사의 등록을 취소시킬 수 있도록 한 것은 성인의 알 권리를 침해하여 위헌이다.[472]

<헌법재판소 1992. 2. 25. 89헌가104> 군사기밀보호법 제6조 등에 대한 위헌심판

군사비밀의 범위는 국민의 표현의 자유 내지 알 권리의 대상영역을 최대한 넓혀줄 수 있도록 필요한 최소한도에 한정되어야 할 것이며, 따라서 군사기밀보호법 제6조, 제7조, 제10조는 동법 제2조 제1항의 군사상의 비밀이 비공지의 사실로서 적법절차에 따라 군사기밀로서의 표지를 갖추고 그 누설이 국가의 안전보장에 명백한 위험을 초래하다고 볼 만큼의 실질가치를 지닌 것으로 인정되는 경우에 한하여 적용된다.

⑶ 보도의 자유

1) 의의 및 법적성격과 주체 및 내용

표현의 자유에는 사고, 판단, 결단에 의한 의사발표의 자유는 물론이고 지득한 사실을 일반에게 보도하는 자유가 포함된다. 보도의 자유는 매스컴의 자유를 말하나 보도는 주로 신문, 통신 기타의 보도기관의 임무이므로 보도의 자유를 신문의 자유라고도 한다.

신문의 자유에는 편집의 자유와 언론기관설립의 자유가 포함된다.

신문의 자유는 일차적으로 제도적 보장으로서의 성격을 가진다. 그러나 이러한 신문의 제도적 보장은 개인의 주관적 권리의 토대가 된다. 따라서 신문에 종사하는 개인들(예컨대, 출판자, 편집인, 편집진, 기자, 경리담당자,[473] 광고담당자[474] 등)은 신문의 자유를 주장할 수 있다.

2) 보도기관의 기능

보도기관은 보도를 통하여 '정보를 제공하는 기능'을 할 뿐만 아니라 사회에서 일어나는 사건들에 대하여 사람들이 의견을 형성할 수 있도록 도와주고 그럼으로써 수많은 개별적인 의견들을 하나의 커다란 의견의 흐름으로 종합시킴으로써 사회의 '통합을 촉진하는 기능'을 한다.

또한, 국가권력의 행사를 감시함으로써 국가에 대해서는 '통제기능'을 행사한다. 이러한 이유로 인해 보도기관은 공공성을 가진다.

---

472) 헌법재판소 1998. 4. 30. 95헌가16.
473) BVerfGE 25, 296(304).
474) BVerfGE 64, 108(114f.).

3) 보도의 자유와 취재의 자유

정확한 내용의 보도를 위해서는 자유로운 취재활동을 전제로 할 것이나 지득한 사실을 전달하는 보도와 적극적으로 사실을 탐지하는 취재는 차원을 달리한다. 따라서 보도의 자유에는 취재의 자유가 당연히 포함되는 것은 아니다. 독일연방헌법재판소는 취재원묵비권을 취재의 자유의 본질적인 내용으로 인정하고 있다.[475]

4) 보도의 자유와 privacy

신문은 공공의 생활과 직접적인 관련이 없는 사생활에 대한 사항에 대하여는 본인의 동의 없이 개입할 수 없는 것이므로 보도의 내용의 수인의 한도를 넘으면 사생활의 침해가 되어 사후 처벌을 받게 된다.[476]

⑷ access권(언론기관접근권)

access권이란 좁은 의미로 자기와 관계 있는 보도에 대한 반론 또는 해명의 기회를 요구할 수 있는 반론권 및 해명권을 의미하며, 넓은 의미로는 자신의 의사표현을 위하여 이용할 수 있는 권리를 말한다.[477]

고전적인 언론의 자유가 국가권력의 부작위를 청구하는 의미에서 자유권이라면, access권은 국가권력의 발동을 요구하고, 그 실현을 적극적으로 요구하는 청구권으로 반론권(반론보도청구권)과 의견광고권이 포함된다.[478]

정기간행물등록 등에 관한 법률 제16조과 방송법 제41조에는 행사방법과 절차 등에 대하여 규정되어 있으며, 언론중재 및 피해구제 등에 관한 법률 제17조에 추후보도의 내용은 청구인의 명예나 권리회복에 필요한 설명 또는 해명이 포함되어야 한다고 규정되어 있다.

5. 효력 및 책임

⑴ 효력

대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력이 인정된다. 그러나 대법원은 대사인적 효력을 부정하고 있다.

<대법원 1997. 7. 11. 95다55900>

사업장 내에서의 기업질서를 유지하기 위하여 사용자의 허가 없이 사업장 내에서 유인물을 배포한 근로자를 징계할 수 있도록 한 취업규칙의 규정이 언론의 자유를 보장한 헌법조항에 위반하여 무효라고 할 수 없다.

⑵ 책임

언론·출판이 타인의 명예나 권리를 침해하는 경우에는 형법상의 명예훼손 등에 의한 형사책임을 져야하며(형법 제310조), 민법상의 불법행위를 구성하여 피해자는 민법 제750조의 손해배상을 청구할 수 있다.

---

475) BVerfGE 8, 5; 10, 118(121); 12. 205(260); 36, 193(204).
476) 헌법재판소 1999. 6. 24. 97헌마265.
477) 허영, 전게서, 533면.
478) 헌법재판소 1991. 9. 16. 89헌마165.

6. 제한

⑴ 법률 및 비상계엄 등에 의한 제한

헌법 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있으며, 신문 등의 자유와 기능보장에 관한 법률, 군사기밀보호법, 군사시설보호법, 방송법, 출판 및 인쇄진흥법 등이 있다. 또한, 긴급명령, 비상계엄 등에 의해 제한될 수 있다.

⑵ 제한기준에 관한 이론

1) 사전제한의 금지

헌법 제21조 제2항은 허가나 검열을 금지하고 있다.[479] 그러나 사후통제는 가능하다. 예컨대, 언론·출판이 타인의 명예나 권리 또는 공중도덕이나 사회윤리를 침해한 경우에는 사후통제가 가능하다. 또한, 등록이나[480] 신고도 사전검열이 아니므로 허용된다. 그 밖에도 수입된 외화, 지나친 외설도서, 불온문서 등은 공중도덕과 사회윤리, 국가이익과 질서유지에 크게 해를 끼칠 염려가 있을 때에 한하여 검열이 용인되고 사후 처벌의 대상이 된다.

2) 사후통제

가. 명확성이론

불명확한 법률문구로 표현의 자유를 제한할 수 없고, 해당 법률조항 등이 막연한 때에는 무효로 한다는 이론이다. 이는 지나치게 막연하고 광범위한 내용을 담고 있는 법률은 법원의 판단을 기다릴 필요도 없이 '문언상 무효'(void on its face)가 된다고 한다(Overbreadth and Vagueness Doctrine).[481]

<헌법재판소 2002. 6. 27. 99헌마480> 전기통신사업법 제53조 등 위헌확인

표현의 자유를 규제하는 입법에 있어서 명확성의 원칙은 특별히 중요한 의미를 지닌다. 무엇이 금지되는 표현인지가 불명확한 경우에 자신이 행하고자 하는 표현이 규제의 대상이 아니라는 확신이 없는 기본권주체는 대체로 규제를 받을 것을 우려해서 표현행위를 스스로 억제할 가능성이 높기 때문에 표현의 자유를 규제하는 법률은 규제되는 표현의 개념을 세밀하고 명확하게 규정할 것이 헌법적으로 요구된다. 그런데 '공공의 안녕질서 또는 미풍양속을 해하는'이라는 불온통신의 개념은 너무나 불명확하고 애매하다. 법집행자의 통상적 해석을 통하여 그 의미내용을 객관적으로 확정하기도 어렵다.

나. 이익형량이론

구체적인 사건에서 표현의 자유를 누리는데서 얻은 개인의 이익과 표현을 제한하는 법률에서 추구하려는 공익을 형량하여 제한하려는 이익의 비중이 클 때, 그 제한을 인정한다는 이론이다.[482] 정신적 자유와 경제적 자유를 구분하여 전자의 우월을 인정하는 이중기준(double standard)론이 전개되고 있다.[483]

---

479) 헌법재판소 1997. 8. 21. 93헌바51 등.
480) 헌법재판소 1998. 4. 30. 95헌가23.
481) Thornhill v. Alabama 301 U. S. 88, 1940.
482) American Communications Association v. Douds, 339 U. S. 1382, 1950.
483) 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률 제5조 제1항의 위헌여부에 관한 헌법소원에서 재판관 변정수, 김양균의 소수의견에서 이를 원용한 바 있다(헌법재판소 1991. 6. 3. 89헌마204).

<헌법재판소 1990. 4. 2. 89헌가113> 국가보안법 제7조에 대한 위헌심판

남북이 막강한 군사력으로 대치하며 긴장상태가 계속되고 있는 마당에서는 완전폐기함에서 오는 국가적 불이익이 폐기함으로써 오는 이익보다는 이익형량상 더 클 것이다.

다. 명백하고 현존하는 위험의 원칙

'명백'이란 표현과 해약 발생 사이에 인과관계가 존재하는 것을 의미하고, '현존'이란 해악발생이 시간적으로 근접한 것을 의미하며, '위험'이란 해악발생의 개연성을 의미한다. 따라서 이 원칙에 의하면 언론자유제한의 합헌성의 기준은 언론자유를 이 이상 '더 허락하면 중대한 해악이 염려될 때', '우려되는 위험이 절박하다고 확신될 때', '방지해야 할 해악이 중대하다고 확신될 때'이다.[484)485)]

라. 우월적 지위의 원칙

표현·사상의 자유는 헌법상의 자유권 중에서 다른 모든 자유의 기반이며 없어서는 안 될 전제조건이므로 이를 제한하면 어떤 자유나 정의도 있을 수 없다고 한다. 따라서 언론·출판의 자유와 종교의 자유는 자유권 가운데 우월한 지위가 인정되며, 그 제한입법은 유효한 사회목적의 실현을 위하여 합리적일 뿐 아니라 압도적인 종국적 판단으로 정당화되어야 비로소 인정된다는 것이다.[486)]

3) 검토

언론·출판의 자유에 관해서는 '명백하고 현존하는 위험의 원칙', '명확성의 원칙', '과잉금지의 원칙'이 중요한 판단기준이 된다고 한다.[487)] 그러나 언론·출판의 자유 역시 헌법 제37조 제2항에 의해 제한이 가능하고, 기본권 제한의 일반원칙을 준수하며, 본질적 내용은 침해할 수 없다고 하는 것으로 충분하다고 할 것이다.[488)]

♣ 문제풀이

1. 다음 언론·출판의 자유에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 모든 사람이 스스로 저술한 책자가 교과서가 될 수 있도록 주장할 권리까지 포함된 것은 아니다.
② 헌법 제21조 제1항의 언론·출판의 자유는 넓은 의미로 이해된다.
③ 국민의 알 권리와 다양한 사상·의견이 교환을 보장하는 언론의 자유는 민주제의 근간이 되는 핵심적 기본권이다.
④ 표현의 자유의 핵심적 내용을 이루는 것으로서 언론·출판의 자유를 통칭하여 언론의 자유라 한다.
⑤ 월남전에 반대하는 표현으로 병역등록카드를 법원계단에서 소각하는 행위와 같은 상징적 표현은 언론·출판의 자유에 의한 보호대상이 아니다.

---

484) Schenck v. U. S., 249 U. S. 47, 1919; Whitney v. California, 274 U. S. 357, 1927.
485) 헌법재판소 1990. 4. 2. 89헌가113; 1990. 6. 25. 90헌가11; 1992. 1. 28. 89헌가8 등.
486) United States v. Carolene Products Co., 304 U. S. 144, 1938.
487) 허영, 전게서, 538면.
488) 홍성방, 전게서 179면.

[정답] ⑤

[해설] 미국에서는 '상징적 표현'(symbolic expression)까지 표현의 자유의 내용이 된다.

2. 다음 중 허가·검열의 금지에 관한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 검열금지의 원칙은 헌법규정에 명시되어 있고 없고를 불문하고 언론의 자유의 본질이다.
② 민사소송법상의 가처분조항에 방영금지가처분을 포함시키더라도 검열금지는 아니다.
③ 방송국설립에 있어서 허가제는 위헌이라는 것이 다수의 견해이다.
④ 게임물 판매업자가 되고자 하는 자로 하여금 문화관광부장관 등에게 등록하도록 요구하는 것은 검열이 아니다.
⑤ 교과서 검인정제도는 검열이 아니다.

[정답] ③

[해설] 위헌이 아니다.

3. 다음 언론·출판의 자유 중 제한을 가장 많이 받는 것은?

① 대중매체설립의 자유
② 취재의 자유
③ 편집의 자유
④ 보도의 자유
⑤ 보급의 자유

[정답] ①

[해설] 정기간행물의 발행에 일정한 시설이 요구되는 등 제한이 있다(정간법과 방송법)

♣ 요점정리

1. 언론·출판의 자유는 자기의 사상이나 의견의 자유로운 표명(발표의 자유)과 그것을 전파할 자유(전달의 자유)를 의미한다.

2. 언론·출판의 자유는 행복추구권에 대해서 특별법적 성격을 가지며, 종교의 자유나 학문의 자유, 예술의 자유에 대해서는 일반법적인 성격을 가진다.

3. 독일은 알 권리를 헌법적 차원에서 보장하고 있으나 우리나라에서는 법률적 차원에서 보장하고 있다.

4. 명확성이론은 불명확한 법률문구로 표현의 자유를 제한할 수 없고, 해당 법률조항 등이 막연한 때에는 무효로 한다는 이론이다. 이는 지나치게 막연하고 광범위한 내용을 담고 있는 법률은 법원의 판단을 기다릴 필요도 없이 '문언상 무효'가 된다고 한다.

5. 명백하고 현존하는 원칙에 따르면, 언론자유제한의 합헌성의 기준은 언론자유를 이 이상 '더 허락하면 중대한 해악이 염려될 때', '우려되는 위험이 절박하다고 확신될 때', '방지해야 할 해악이 중대하다고 확신될 때'이다.

6. 표현·사상의 자유는 헌법상의 자유권 중에서 다른 모든 자유의 기반이며 없어서는 안 될 전제조건이므로 이를 제한하면 어떤 자유나 정의도 있을 수 없다고 한다. 따라서 언론·출판의 자유와 종교의 자유는 자유권 가운데 우월한 지위가 인정되며, 그 제한입법은 유효한 사회목적의 실현을 위하여 합리적일 뿐 아니라 압도적인 종국적 판단으로 정당화되어야 비로소 인정된다는 것이다.

제29강 집회·결사의 자유

♣ 학습목표

집회·결사의 자유를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

집회의 자유의 의의, 기능, 법적성격, 주체
집단적 시위·행진, 연설·토론
우발적 집회와 사전신고제
공법상 강제결사와 소극적 결사

♣ 사전테스트

1. 계엄법상의 계엄당국이 금지하는 정치목적의 집회는 계엄목적 달성을 위하여 최소한으로 정당의 창당 등 정치적 결사를 위한 집회라든가 또는 대통령을 추대하기 위한 집회 등 구체적이고 뚜렷한 정치목적을 위한 집회에 한한다.

   정답 : X
   해설 : 대법원 1982. 10. 26. 82도1861.

2. 1인 시위는 집회 및 시위에 관한 법률상의 시위가 아니다.

   정답 : O
   해설 : 집회 및 시위에 관한 법률 제2조 제2호.

3. 축산업협동조합은 사법상의 결사이다.

   정답 : O
   해설 : 헌법재판소 1996. 4. 25. 92헌바47.

♣ 돌발퀴즈

집회의 자유는 다른 법익의 보호를 위하여 정당화되지 않는 한 집회장소를 항의의 대상으로부터 분리시키는 것을 금지한다.

[정답] O
[해설] 헌법재판소 2003. 10. 30. 2000헌바67.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

집회·결사의 자유가 헌법에 규정되기 시작한 것은 19세기 중엽부터이다. 영국에서는 1871년 노동조합법이 제정됨으로써 노동자의 단결권이 본격적으로 인정되었으며, 미국에서는 남북전쟁 후에 결사의 자유가 보장되기 시작하였다. 독일의 경우에는 1850년 프로이센 헌법이 집회·결사의 자유를 처음으로 규정하였다.

우리 헌법은 제21조 제1항에서 집회·결사의 자유를 보장하고 있고, 제2항에서 집회·결사의 허가제를 금지하고 있다.

2. 집회의 자유

⑴ 의의 및 기능

1) 의의

집회라 함은 일정한 공동목적을 달성하기 위한 다수인의 일시적 회합을 말한다. 따라서 공동목적을 가지지 않은 도로상이나 시장의 군중은 집회에 해당되지 않는다. 집회는 집회장소에 따라 옥내집회와 옥외집회, 집합목적에 따라 정치적 집회와 비정치적 집회, 공개성 여부에 따라 공개집회와 비밀집회가 있다.[489]

집회의 자유는 국민들이 타인과 접촉하고 정보와 의견을 교환하며 공동의 목적을 위하여 집단적으로 의사표현을 할 수 있게 함으로써 개성신장과 아울러 여론형성에 영향을 미칠 수 있게 하여 동화적 통합을 촉진하는 기능을 가지며, 나아가 정치·사회현상에 대한 불만과 비판을 공개적으로 표출케 함으로써 정치적 불만세력을 사회적으로 통합하여 정치적 안정에 기여하는 역할을 한다.[490] 특히 대의민주주의에서 의사표현의 통로가 봉쇄되거나 제한된 소수집단에게 의사표현의 수단을 제공하고 국정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 부여한다는 점에서, 대의기능의 약점을 보완하고 직접민주제적 수단으로 기능하는 특징을 가진다.

<대법원 1982. 10. 26. 82도1861>

계엄법상의 계엄당국이 금지하는 정치목적의 집회는 계엄목적 달성을 위하여 최소한으로 정당의 창당 등 정치적 결사를 위한 집회라든가 또는 대통령을 추대하기 위한 집회 등 구체적이고 뚜렷한 정치목적을 위한 집회에 한한다고 해석할 근거가 없다.

2) 기능

오늘날 집회의 자유는 다음과 같은 기능을 한다.

첫째, 개인의 인격실현과 개성신장을 촉진시키며, 의사표현의 실효성을 증대시킨다.

둘째, 대의기능이 약화된 경우에 직접민주주의의 수단이 될 수 있다.

셋째, 소수의 의견을 국정에 반영함으로써 소수를 보호하는 기능을 한다.[491]

---

489) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 180면.

490) 헌법재판소 2009. 9. 24. 2008헌가25.

491) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 490면; 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 541~542면.

또한, 집회의 자유는 언론매체의 대형화·독점화에 따라 자신의 의사를 효과적으로 표현하기 위한 수단을 상실하고 주로 메시지를 받는 입장에 빠진 일반대중의 의사표현의 자유를 보완하는 기능을 한다.[492]

<헌법재판소 1992. 1. 28. 89헌가8> 국가보안법 제7조 등에 관한 위헌심판

대의민주주의체제에 있어서 집회의 자유는 불만과 비판 등을 공개적으로 표출케 함으로써 오히려 정치적 안정에 기여하는 긍정적 기능을 수행하며, 이와 같은 자유의 향유는 민주정치의 바탕이 되는 건전한 여론표현과 여론형성의 수단인 동시에 대의기능이 약화되었을 때에 소수의 견이 국정반영의 창구로서의 의미를 지님을 간과해서는 안 될 것이다. 그러한 의미에서 사회불안만 우려해서 무조건 집회·시위를 타부시할 것이 아니라 비폭력적이고 질서파괴의 것이 아니면 민주주의의 신장을 위해 위축시켜서는 안 될 기본권으로 보호하여야 할 것이다.

⑵ 법적성격

집회의 자유가 자유권인가 아니면 제도적 보장까지 포함하는 것인가에 대해 견해의 대립이 있다. 집회의 자유는 국가내적 권리이며, 나아가서 민주적 기본질서의 한 구성요건으로서 여론표현과 여론형성의 불가결의 집회제도 자체를 보장한 것으로 보는 견해와[493] 집회의 자유의 보장은 집회란 집단적으로 기본권을 행사하는 것일 뿐 제도가 아니기 때문에 제도적 보장이 아니라고 하는 견해,[494] 다수인의 일시적인 모임인 집회의 경우에는 입법권에 의한 제한의 한계는 문제될 수 있어도 집회 그 자체의 권리가 문제될 수는 없기 때문에 제도가 될 수 없다는 견해,[495] 그리고 집회의 자유는 주관적 공권임과 동시에 객관적 가치질서로서의 성격을 가지나 집회를 제도로 볼 수 없기 때문에 제도적 보장으로서의 성격은 가지지 않는다고 보는 견해가 있다.[496]

⑶ 주체

자연인 외에 법인도 제한된 범위 내에서 주체가 되며, 외국인은 호혜주의의 원칙이 적용된다.

⑷ 내용

1) 의미

집회의 자유는 집회를 개최하는 자유, 진행하는 자유, 참가하는 자유를 내용으로 한다. 또한, 소극적으로 집회를 개최하지 아니할 자유와 집회에 참가하지 아니할 자유가 포함된다. 다만, 법률상 집회의무가 있을 때에는 소극적 자유는 인정되지 아니한다.[497]

<헌법재판소 2003. 10. 30. 2000헌바67 등>

집회의 자유는 일차적으로 국가 공권력의 침해에 대한 방어를 가능하게 하는 기본권으로서 개인이 집회에 참가하는 것을 방해하거나 또는 집회에 참가할 것을 강요하는 국가행위를 금지

492) 홍성방, 전게서, 181면.
493) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 642~642면.
494) 권영성, 전게서, 490면.
495) 허영, 전게서, 542면.
496) 홍성방, 전게서, 182면.
497) 홍성방, 전게서, 182면.

하는 기본권이다. 따라서 집회의 자유는 집회에 참가하지 못하게 하는 국가의 강제를 금지할 뿐 아니라 예컨대 집회장소로의 여행을 방해하거나, 집회장소로부터 귀가하는 것을 방해하거나, 집회참가자에 대한 검문의 방법으로 시간을 지연시킴으로써 집회장소에 접근하는 것을 방해하거나, 국가가 개인의 집회참가행위를 감시하고 그에 관한 정보를 수집함으로써 집회에 참가하고자 하는 자로 하여금 불이익을 두려워하여 미리 집회참가를 포기하도록 집회참가의사를 약화시키는 것 등 집회의 자유행사에 영향을 미치는 모든 조치를 금지한다.

2) 집회의 목적적 요소

헌법재판소에 의하면 일반적으로 집회는, 일정한 장소를 전제로 하여 특정 목적을 가진 다수인이 일시적으로 회합하는 것을 말하는 것으로 일컬어지고 있고, 그 공동의 목적은 '내적인 유대 관계'로 족하다.[498]

헌법재판소는 초기에 집회의 자유를 표현의 자유의 일종으로 보았지만, 그 이후에 '집회의 자유는 공동으로 인격을 발현하기 위하여 타인과 함께 하고자 하는 자유, 즉 타인과의 의견교환을 통하여 공동으로 인격을 발현하는 자유를 보장하는 기본권이자 동시에 국가권력에 의하여 개인이 타인과 사회공동체로부터 고립되는 것으로부터 보호하는 기본권'이라는 점을 분명히 밝혔다.[499] 집회란 '내적인 유대감을 가진 불특정 다수인이 일시적으로 일정한 장소에서 가지는 모임 또는 회합'을 의미한다.[500]

3) 집회의 인적 요건

타인과의 내적인 유대를 요건으로 하는 집회에서 일인집회란 인정될 수 없다. 한 사람만으로는 의사를 표현하거나 일반 언어사용에서 쓰이듯이 시위를 할 수는 있지만 모임을 가질 수가 없다. 예컨대, 관공서 앞에서 피켓을 들고 혼자서 하는 시위는 의사표현의 자유에 속할 수는 있어도 집회의 자유에 관하여 보호될 수는 없다. 집회의 최소인원으로 3인설도 있지만, 2인이면 충분하다고 할 것이다.

일반적으로 사이버 시위 및 집회라고 표현되는 행위는 집회의 자유의 보호영역에 포함되지 않는다.[501] 집회의 자유에서의 모임은 현실 공간속에서의 신체적인 모임을 전제로 하는데, 가상공간에서의 집회는 신체적으로 모이는 것이 아니기 때문이다.

4) 집회의 행태적 요소(평화성)

사람의 생명과 신체 및 물건에 대한 물리적 강제는 모든 기본권의 보호영역에서 벗어난 행위이다. 특히, 옥외집회나 시위는 다수인의 비조직화된 집단성으로 인하여 집회참가자와 비참가자 사이에 폭력이 사용될 위험성이 가장 높은 기본권이다. 약 60여개 국가의 헌법이 집회의 자유에서 '무기 없이 평화적으로' 또는 '평화적으로'란 문구를 명시하고 있는 것은 우연의 산물이 아닌 것이다.[502]

⑸ 개별문제

---

498) 헌법재판소 2009. 5. 28. 2007헌바22; 대법원 1983. 11. 22. 선고 83도2528.

499) 헌법재판소 2003. 10. 30. 2000헌바67.

500) 헌법재판소 2009. 5. 28. 2007헌바22.

501) 사이버 시위에 현행 집시법을 적용하기는 어렵지만, '온라인 집회·시위에 관한 법률'의 제정이나 집시법에 사이버 시위에 관한 장을 신설하자는 의견에 관하여는 정찬모, "사이버 시위의 자유와 법적 규제", 「집회와 시위의 자유」, 사람생각, 2003, 179면.

502) 실정헌법상 처음으로 Massachusetts헌법(1780) 제19조와 New Hampshire헌법(1784) 제31조는 '평화적인 방식(peaceable manner)'에 의한 집회의 권리를 보장하였다. 현재 독일, 그리스, 싱가포르 등은 '무기 없이 평화적으로(friedlich und ohne Waffen)', 미국은 '평화적으로(peaceable)'란 유보조항을 집회의 자유에 부가시키고 있다.

1) 집단적 시위·행진 포함여부

부정설은 헌법에 집단적 시위에 대한 규정이 없으면 포함되지 않는 다고 하며, 다수설인 긍정설은 시위·행진은 움직이는 집회로서 집단적 사상표현의 한 형태에 불과하므로 포함된다고 한다.

집회 및 시위에 관한 법률은 시위를 다수인이 공동목적을 가지고 도로·광장·공원 등 공중이 자유로이 통행할 수 있는 장소를 진행하거나 위력 또는 기세를 보여 불특정다수인의 의견에 영향을 주거나 제압을 가하는 행위라고 하였다(제2조 제2호). 그러나 헌법재판소는 시위를 '이동하는 집회'로[503] 보면서도 '공중이 자유로이 통행할 수 있는 장소'라는 장소적 제한개념은 시위의 개념요소가 아니라고 한다.[504]

2) 연설·토론

다수설과 판례는 언론의 자유로서 보장된다고 하고, 소수설은[505] 집회의 자유는 언론자유의 특별법적 성격을 띠므로 집회의 자유로서 보장된다고 한다.

3) 우발적 집회와 사전신고

우발적 집회란 집회 및 시위에 관한 법률이 요구하는 사전계획과 주체자 없이, 특히 사전신고를 할 수 없는 상황에서 개최된 집회를 말한다. 형식논리적으로는 사전신고가 없는 집회인 이상 그에 대해 해산명령을 발하는 것은 합법적이며, 집회의 자유에 대한 침해가 아니라고 할 수 있을 것이다. 그러나 사전신고제를 마치 허가제와 같은 것으로 운영하는 것은 안 되며, 집회의 자유를 헌법적 차원에서 보장하고 있는 근본취지에 따라 판단하여야 한다.

따라서 목적이 자유민주적 기본질서와 조화될 수 있는 일반적 성질의 것이고, 집회의 방법이 허용된 것이며, 집회의 목적과 방법이 내적인 관련성을 유지하고 합리적인 비례관계에 있는 한 신고된 집회와 마찬가지로 보호하는 것이 집회의 자유를 보장한 헌법정신에 합치될 것이다.[506] 나아가 사전신고가 없었다는 이유로 해산명령을 내리는 것은 집회의 자유의 본질을 침해하는 것이다.[507]

⑹ 효력

대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력이 인정된다.

⑺ 제한

1) 법률에 의한 제한

비상계엄, 특별권력관계에 있는 자, 헌법 제37조 제2항에 따라 제한되며, 형법, 국가보안법, 집회 및 시위에 관한 법률과 화염병 사용 등의 처벌에 관한 법률 등이 있다. 제한하는 경우에도 본질적인 내용은 침해할 수 없다.

---

503) 헌법재판소 1992. 1. 28. 89헌가8.
504) 헌법재판소 1994. 4. 28. 91헌바14.
505) 권영성, 전게서, 491면; 허영, 전게서, 543면.
506) BVerfGE 26, 135(138).
507) 허영, 전게서, 545면.

3. 결사의 자유

⑴ 의의 및 기능

결사라 함은 일정한 공동목적을 위하여 다수인이 계속적인 단체를 조직하는 것을 말한다. 이러한 단체는 가입과 탈퇴의 자유가 인정되는 자발적인 단체를 의미한다. 따라서 공법상의 결사는 포함되지 않는다.

<대법원 1982. 9. 28. 82도2016>
결사라 함은 공동의 목적을 가진 특정 다수인의 임의체적인 계속적 집합체라 할 것이므로 첫째, 결사에 구성원은 2인 이상임을 필요로 하고, 둘째, 결사에는 공동목적이 있어야 하고, 그 공동목적이 있는 이상 그것이 결사조직의 유일한 목적임을 요하지 않고 다른 목적이 있어도 결사임에는 무방하고, 셋째, 결사는 다수인의 임의적 결합이어야 하고, 넷째, 결사는 계속성이 있어야 한다. 그러나 이 계속은 사실상 계속하여 존재함을 요하지 않고 계속시킬 의도하에서 결합된 이상 결사임에는 틀림없다. 이 네 가지 요건을 구비한 결합은 결사인 것으로 구성원이 회합한 사실이 없거나 사칙이 정하여 있지 않거나 간부가 없어도 결사의 성립에는 영향이 없으며, 또 결사의 명칭이나 대표자가 정하여져 있지 아니하여도 무방한 것이라고 풀이된다.

<헌법재판소 1996. 4. 25. 92헌바47> 축산업협동조합법 제199조 제2항의 위헌소원
결사의 자유에서 말하는 결사란 자유의사에 기하여 결합하고 조직화된 의사형성이 가능한 단체를 말하는 것이므로 공법상의 결사는 이에 포함되지 아니한다.

<헌법재판소 1994. 2. 24. 92헌바43> 주택건설촉진법 제3조 제9호의 위헌확인
결사의 자유에 의하여 보호되는 결사의 개념에는 법이 특별한 공공목적에 의하여 구성원의 자격을 정하고 있는 특수단체의 조직활동까지 그에 해당되는 것으로 볼 수 없다.

정당·노동조합·종교단체·학술단체·예술단체 등도 결사의 일종이나 제8조, 제33조, 제20조, 제22조에서 따로 보장하고 있다. 따라서 이들은 원칙적으로 해당 조항의 적용을 받으며, 해당조항에 규정이 없는 사항에 대해서 제21조의 적용을 받는다.
이러한 결사의 자유는 개성신장의 수단으로서의 기능, 사회공동체의 통합기능, 소수자보호기능, 의사형성과 여론형성의 기능을 한다.[508]

⑵ 법적성격

결사의 자유는 자유권적 기본권이면서 민주적인 국법질서를 구성하는 객관적 가치질서로서의 성격을 가진다. 또한, 결사의 자유는 결사를 제도적으로서 보장하는 성격을 가진다.[509]

⑶ 주체

결사의 자유는 개개인이 결사를 조직하는 의미내용일 때에는 개인의 권리를 의미하고, 결사가 존속하는 의미내용일 때에는 단체의 권리를 의미한다. 따라서 결사의 자유는 자연인으로서의

508) 허영, 전게서, 547면.
509) 김철수, 전게서, 643면; 허영, 전게서, 548면.

개인뿐만 아니라 단체, 즉 법인도 주체가 된다. 외국인인 경우에는 호혜주의의 적용을 받는다. 다만, 공무원의 경우에는 정치적인 결사나 노동조합을 구성하는 것이 제한된다.

<대법원 1992. 6. 26. 87누308>
국가공무원으로 하여금 노동운동 등 집단적 행위를 하지 못하도록 규정한 국가공무원법 제66조 제1항 본문은 헌법 제11조 제1항, 제21조 제1항, 제31조 제4항, 제33조 제4항, 제37조 제2항에 위반된다고 볼 수 없다.

⑷ 내용

1) 의미

결사의 자유는 적극적 결사의 자유와 소극적 결사의 자유를 내용으로 한다. 적극적 결사의 자유에는 단체결성의 자유, 단체존속의 자유, 단체활동의 자유, 결사에의 가입·잔류의 자유가 포함된다. 소극적 결사의 자유에는 단체로부터 탈퇴할 자유와 결사에 가입하지 않을 자유가 포함된다.

<대법원 1989. 12. 26. 87누308>
요건을 갖춘 사회단체의 등록신청에 대해서 설립목적 등이 유사한 다른 사회단체가 이미 등록되었다는 이유로 행정관청이 그 등록접수를 거부하는 것은 결사의 자유에 대한 침해이다.

<헌법재판소 1996. 4. 25. 92헌바47> 축산업협동조합법 제99조 제2항에 대한 위헌심판
축협과 중앙회는 양축인의 자주적 협동조직으로서 사법인이며, 조합구역 내에서 동일한 업종을 둘 이상 두지 못하게 한 것은 양축인의 결사의 자유의 본질적 내용을 침해한 것이다.

2) 공법상의 강제결사와 소극적 결사의 자유

다수설과 판례는 공적인 과제를 수행하기 위해 공법상 강제결사를 조직하는 것은 소극적인 결사의 자유에 대한 침해로 볼 수 없다고 한다.[510] 소수설은 공법상의 강제결사에도 한계를 인정하여 직업의 전문성 때문에 강제결사가 필요불가결하고, 결사구성원 사이의 직업적 동질의식을 초래하는 경우에만 인정된다고 한다.[511]

⑸ 효력

결사의 자유에는 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력이 인정된다.

⑹ 한계와 제한

1) 한계

결사의 자유는 국가의 존립을 위태롭게 하거나 헌법 적대적이거나 자유민주적 기본질서에 위반하는 것이어서는 안 된다.

---

510) 헌법재판소 1994. 2. 24. 92헌바43.
511) 허영, 전게서, 550면; 홍성방, 전게서, 190~191면.

<대법원 1990. 10. 12. 90도1744>

비록 한통연(한국민주통일연맹) 주요간부들이 범민족대회참석을 위한 입국이 허가되었다고 해서 위 단체에 대해 국가보안법의 적용을 면제 내지 유보하겠다는 법집행의 관행이 생겨난 것이 아니니 위 단체를 여전히 반국가단체로 볼 수밖에 없다.

2) 제한

결사의 자유는 제37조 제2항에 따라 제한할 수 있다. 그러나 본질적인 내용은 침해할 수 없다. 예컨대, 결사 그 자체를 금지하는 입법조치, 결사조직의 사전허가제를 도입하는 입법조치, 사법상의 강제결사를 허용하는 입법조치 등은 결사의 자유의 본질적인 내용을 침해하는 것이다.[512] 또한, 비상계엄, 특별권력관계에 있는 자에 대해서도 제한될 수 있다.

♣ 문제풀이

1. 다음 집회에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 집회는 일시적 회합이라는 점에서 계속적인 조직인 결사와 구별된다.
② 집회가 성립하기 위해서 반드시 주최자가 있어야 하는 것은 아니다.
③ 노상에서의 우연한 군집은 원칙적으로 집회가 아니다.
④ 집회의 목적은 합법적이며 민주적 질서에 합치되어야 한다.
⑤ 집회의 개념에 집단적 시위·행진은 포함되지 않는다.

[정답] ⑤
[해설] 헌법재판소 1992. 1. 28. 89헌가8.

2. 다음 중 집회의 자유에 속한다고 보기 어려운 것은?

① 집회에 참가하지 않을 자유
② 집회에 참가할 자유
③ 집회에서 진행하는 자유
④ 집회에서 연설·토론할 자유
⑤ 집회를 방해하려는 자의 집회의 자유

[정답] ⑤
[해설] 이러한 자유는 인정될 수 없다.

3. 다음 중 결사의 자유의 내용이 아닌 것은?

① 단체결성의 자유
② 단체존속의 자유
③ 단체에의 가입·탈퇴의 자유
④ 단체활동의 자유
⑤ 공법적 결사에 가입하지 않을 자유

[정답] ⑤
[해설] 의사회, 변호사회, 등에는 가입의 강제가 인정된다.

---

512) 허영, 전게서, 551면.

♣ 요점정리

1. 집회의 자유는 국민들이 타인과 접촉하고 정보와 의견을 교환하며 공동의 목적을 위하여 집단적으로 의사표현을 할 수 있게 함으로써 개성신장과 아울러 여론형성에 영향을 미칠 수 있게 하여 동화적 통합을 촉진하는 기능을 가지며, 나아가 정치·사회현상에 대한 불만과 비판을 공개적으로 표출케 함으로써 정치적 불만세력을 사회적으로 통합하여 정치적 안정에 기여하는 역할을 한다.

2. 대의민주주의에서 의사표현의 통로가 봉쇄되거나 제한된 소수집단에게 의사표현의 수단을 제공하고 국정에 영향을 미칠 수 있는 기회를 부여한다는 점에서, 대의기능의 약점을 보완하고 직접민주제적 수단으로 기능하는 특징을 가진다.

3. 집회에 참가하고자 하는 자로 하여금 불이익을 두려워하여 미리 집회참가를 포기하도록 집회참가의사를 약화시키는 것 등 집회의 자유행사에 영향을 미치는 모든 조치를 금지한다.

4. 결사라 함은 공동의 목적을 가진 특정 다수인의 임의체적인 계속적 집합체라 할 것이므로 첫째, 결사에 구성원은 2인 이상임을 필요로 하고, 둘째, 결사에는 공동목적이 있어야 하고, 그 공동목적이 있는 이상 그것이 결사조직의 유일한 목적임을 요하지 않고 다른 목적이 있어도 결사임에는 무방하고, 셋째, 결사는 다수인의 임의적 결합이어야 하고, 넷째, 결사는 계속성이 있어야 한다. 그러나 이 계속은 사실상 계속하여 존재함을 요하지 않고 계속시킬 의도하에서 결합된 이상 결사임에는 틀림없다.

5. 요건을 갖춘 사회단체의 등록신청에 대해서 설립목적 등이 유사한 다른 사회단체가 이미 등록되었다는 이유로 행정관청이 그 등록접수를 거부하는 것은 결사의 자유에 대한 침해이다.

제30강 학문·예술의 자유

♣ 학습목표

학문·예술의 자유를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

교수의 자유
학문결과발표의 자유
대학의 자유
예술창작의 자유
예술표현의 자유
예술적 집회·결사의 자유
지적재산권보호의무

♣ 사전테스트

1. 학문의 자유는 절대적 기본권이다.

정답 : X
해설 : 학문연구의 자유만 절대적 기본권이다.

2. 현행 헌법은 학문의 자유와 관련하여 대학의 자율성을 규정하고 있다.

정답 : X
해설 : 헌법 제31조 교육을 받을 권리와 관련하여 규정하고 있다.

3. 예술적 비평은 예술의 자유에 의해 보장된다.

정답 : X
해설 : 표현의 자유로서 보호된다.

♣ 돌발퀴즈

명화라 하더라도 경우에 따라서는 음화로 판단될 수 있다.

[정답] O
[해설] 대법원 1970. 10. 30. 70도1879.

♣ 강의내용

1. 헌법규정

우리 헌법 제22조 제1항은 모든 국민은 학문과 예술을 가진다고 규정하고 있고, 제2항에서는 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보호된다고 규정하여 학문의 자유와 예술의 자유, 지적재산권을 보장하고 있다.

2. 학문의 자유

⑴ 연혁 및 취지

1) 연혁

학문의 자유는 서구에서 사상의 자유 또는 언론의 자유와 더불어 또는 그 내용으로서 주장되어 왔다. 학문의 자유가 독립된 자유로 주장된 것은 17세기 영국에서 베이컨(F. Bacon : 1561

~1626)과 밀턴(J. Milton : 1608~1674)에 의해서였다.[513] 특히 밀턴은 그의 저서인 '아레오파기티카'(Areopagitica)에서 언론·출판의 자유 이외에 학문의 자유도 주장하였다.

그러나 학문의 자유가 헌법상 기본권으로 보장된 것은 1848/49년 프랑크푸르트헌법 제152조에서 학문과 학설의 자유를 처음으로 규정한 때부터인 것으로 알려져 있다. 이 후, 바이마르헌법 제142에서 규정되었으며, 현재 대부분의 헌법은 학문의 자유를 규정하고 있다. 지적재산권에 대한 보호규정을 처음으로 규정한 것은 1919년 바이마르헌법 제158조이다.[514]

2) 보장취지

민주국가의 헌법들이 학문의 자유를 보장하고 있는 것은 학문은 창조적인 인간정신의 귀중한 성과로서 문화발전의 선구적 역할을 하며, 학문은 새로운 지식을 개척하는 것이므로 기존지식을 기초로 하는 국가기관으로부터 독립되어야 하고, 학자는 그 방면에 있어서의 특수한 전문가이니 상식적인 국가기관의 판단에 의한 통제로부터 초월해야 하기 때문이다.[515]

⑵ 법적성격 및 주체, 다른 기본권과의 관계

학문의 자유는 개인의 주관적 공권이자 객관적 법질서를 의미하며, 대학의 자치를 제도적으로 보장한 것이다.

또한, 학문의 자유는 자연인과 대학 및 연구단체에 주체성이 인정된다. 그러나 교수의 자유의 주체는 대학이나 고등교육기관에 종사하는 교육자에 한정된다.

<헌법재판소 1992. 10. 1. 92헌마68 등> 1994학년도 신입생선발입시안에 대한 헌법소원

---

513) 밀턴은 그의 저서인 '아레오파기티카'(Areopagitica)에서 언론·출판의 자유 이외에 학문의 자유도 주장하였다.

514) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 192면.

515) 문홍주, 「제6공화국 한국헌법」, 해암사, 1988, 284면; 박일경, 「제6공화국 신헌법」, 법경출판사, 1990, 291면; 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 497면.

교육의 자주성이나 대학의 자율성은 헌법 제22조 제1항이 보장하고 있는 학문의 자유의 확실한 보장수단으로 꼭 필요한 것으로서 이는 대학에게 부여된 헌법상의 기본권이다. 따라서 국립대학인 서울대학교는 다른 국가기관 내지 행정기관과는 달리 공권력의 행사자의 지위와 함께 기본권의 주체라는 점도 중요하게 다루어져야 한다. 여기서 대학의 자율은 대학시설의 관리·운영만이 아니라 학사관리 등 전반적인 것이라야 하므로 연구와 교육의 내용, 그 방법과 대상, 교과과정의 편성, 학생의 선발, 학생의 전형도 자율의 범위에 속해야 하고 따라서 입학시험제도도 자주적으로 마련될 수 있어야 한다.

학문의 자유는 양심의 자유와 사상의 자유를 전제로 하며, 언론·출판의 자유와 집회·결사의 자유에 대해서는 특별법적 규정이다.

⑶ 내용

1) 의미

학문이란 계획과 방법론에 따라 자기책임하에 진리와 진실을 탐구하는 자율적·정신적 활동을 의미한다.[516] 즉, 학문이란 진리탐구를 뜻하며, 진리탐구란 인간의 생활권 내에서 일어나는 실체적 내지 관념적 현상과 그들 사이의 상호관계를 논리적·철학적·실험적 방법으로 분석·정리함으로써 새로운 사실과 진리를 찾아내려는 모든 인간적 노력의 대명사이다.[517]

이러한 학문은 진리와 진실에 대한 탐구과정을 포함한다는 점에서 학문연구의 결과인 지식과는 구별된다.

2) 내용

학문의 자유는 학문연구의 자유, 학문활동의 자유를 내용으로 한다. 여기서 학문연구의 자유는 연구대상의 선택, 연구방법, 연구과정에서의 자유를 포함하며, 학문활동의 자유는 교수(강학 또는 학설)의 자유, 학문연구결과발표의 자유, 학문을 위한 집회·결사의 자유를 포함한다.

광의의 학문의 자유에는 대학의 자유가[518] 포함되나 우리 헌법은 이를 제31조 제4항에서 규정하고 있다.

<대법원 1982. 5. 25. 82도716>

학문의 연구는 기존의 사상 및 가치에 대하여 의문을 제기하고 비판을 가함으로써 이를 개선하거나 새로운 것을 창출하려는 노력이므로 그 연구의 자료가 사회에서 현재 받아들여지고 있는 기존의 사상 및 가치체계와 상반되거나 저촉된다고 하여도 용인되어야 할 것이고, 한편 반공법(폐지) 제4조 제2항의 죄는 목적범으로 위와 같은 경우에 있어서의 그 불법목적의 인정은 엄격한 설명을 요하는 바이니, 대학생이 학문연구를 위하여 시내 일반서점과 대학도서관에서 구입 또는 대출받아 보관한 사실만으로써는 불법목적을 인정할 수는 없다.

<헌법재판소 1992. 11. 12. 89헌마88> 교육법 제157조에 대한 헌법소원

학문의 자유는 진리를 탐구하는 자유를 의미하는 데, 그것은 단순한 진리탐구에 그치지 않고 탐구결과에 대한 발표의 자유(편의상 대학의 교수의 자유와 구분하여 수업의 자유로 한다) 등을 포함하는 것이다. 초·중·고교의 교사는 자신이 연구한 결과를 수업의 자유를 내세워 함부로 학생들에게 여과 없이 전파할 수는 없다고 할 것이다. 나아가 헌법과 법률이 지향하고 있는 자유

516) BVerfGE 35, 79(113).
517) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 397면.
518) 허영, 상게서, 398면.

민주적 기본질서를 침해할 수 없음은 물론 사회상규나 윤리도덕을 일탈할 수 없으며, 가치편향적이거나 반도덕적인 내용의 교육은 할 수 없다.

가. 교수의 자유

교수의 자유는 학문활동의 자유 중에서 가장 핵심적인 자유로 교수의 내용이나 방법 또는 학술적 견해의 표명을 자유롭게 할 수 있는 자유이다.[519] 학문활동의 하나인 교수는 자신의 학문활동을 통하여 획득한 인식을 전수한다는 점에서 단순한 지식의 전달을 내용으로 하는 교육(수업)과는 구별된다. 우리 헌법재판소도 교수의 자유와 수업의 자유가 완전히 동일할 수는 없다고 하였다.[520] 그러나 교수의 자유도 헌법질서 내에서 행해져야 한다.[521]

나. 학문의 결과발표 자유의 보장범위

학문의 연구에 대한 결과발표의 자유와 관련하여 발표내용이 학문연구의 결과인 이상 그것을 발표하는 방법이나 대상·장소 등에 의해서 그 보호의 진지성이 달라진다고 볼 수 없다는 발표내용설과[522] 연구결과발표의 자유는 발표장소와 상황에 따라 강한 정도의 보호를 받느냐 아니면 일반적인 표현의 자유의 보호를 받느냐가 결정된다는 발표대상·장소설이[523] 대립하고 있다.

연구결과의 발표가 학문외적인 요소들 때문에 제약을 받는다면 그것은 이미 학문의 자유에 대한 침해가 될 것이므로 발표내용성이 타당하다고 한다.[524]

다. 학문을 위한 집회·결사의 자유

학문을 위한 집회·결사의 자유는 일반집회·결사의 자유보다 더 많은 보호를 받는다. 따라서 집회 및 시위에 관한 법률 제13조는 학술단체와 학술집회를 규제대상에서 제외시키고 있다.

⑷ 대학의 자유

1) 헌법적 근거

학문의 자유는 연혁적으로는 학원의 자유, 특히 대학의 자치 또는 대학의 자유를 의미하였다.[525] 그러나 오늘날 대학의 자유는 넓게 대학을 중심으로 하는 학문연구기관이 그 기관의 운영에 관한 일을 외부로부터 독립하여 자율적으로 결정할 수 있는 자유를 의미한다.

대학의 자유는 대학에 치외법권적 특권을 보장하려는 것이 아니라 학문의 자유를 보장하기 위해서 대학에 대한 국가권력, 특히 경찰권의 개입을 부득이한 최소한의 경우에 국한시키려는 것이다.[526] 나아가 대학의 자유는 학문의 자유를 실효성 있게 보장하기 위한 수단이다.

---

519) BVerfGE 35, 112f.

520) 헌법재판소 1992. 11. 12. 89헌마88.

521) 독일기본법 제5조 제3항 제2문은 교수의 자유는 헌법에 대한 충성으로부터 벗어나지 못한다고 규정하고 있다.

522) 허영, 전게서, 401면.

523) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 593~594면.

524) 홍성방, 전게서 196면.

525) A. Kötten, Die Freiheit der Wissenschaft und die Selbsverwaltung der Universität, in : Neumann-Nipperdey-Scheuner(Hrsg.), Die Grundrechte, Bd. II, 1954, S. 291ff.

526) 이와 관련하여 일본최고재판소는 동경대학 포포로 극단이 대학의 허가를 받고 연극을 공연하였는데, 4인의 경찰관이 사복차림으로 참석한 것을 학생들이 발견하여 그 중 3인의 경찰관을 감금하고 사과문을 쓰게 하였다가 기소된 사건에서 대학학생이 일반국민 이상으로 학문의 자유를 향유하고 또 대학의 시설을 이용할 수 있는 것은 대학의 교수와 연구자가 가지는 특별한 학문의 자유와 자치의 효과에서 오는 것이다. 대학학생의 집회도 이 범위 안에서 자유와 가치가 인정되는 것으로서 학생의 집회가 진정한 학문적 연구 또는 그 결과가 아니고 실사회의 정치적 활동에 해당하는 행위일 경우에는 대학이 가

우리 헌법상 대학의 자유의 근거규정에 대해서는 헌법 제31조 제4항에서 근거를 찾는 견해와[527] 제22조 제1항에서 근거를 찾는 견해가[528] 있다. 제22조 제1항에서 대학의 자유의 근거를 찾으려는 견해는 그 타당성에도 불구하고 그로부터 헌법 제31조 제4항의 '대학의 자율성'을 '대학의 자치의 근거규정이 아니라 보완규정이라고 이해하는 것'은 설득력이 부족하다. 왜냐하면 대학의 자율성이 대학의 자치의 핵심인 이상 대학의 자유는 헌법 제31조 제4항에서 근거를 찾아야 할 것이기 때문이다.[529]

우리 헌법재판소도 대학의 자유의 근거를 헌법 제31조 제4항에서 찾고 있다. 그러나 입법론적으로는 제6공화국 헌법에서 신설한 제31조 제4항의 '대학의 자율성'은 불필요한 중복이라 할 것이다.[530]

<헌법재판소 1992. 10. 1. 92헌마68 등> 1994학년도 신입생선발입시안에 대한 헌법소원

헌법 제31조 제4항에 규정하고 있는 교육의 자주성, 대학의 자율성보장은 대학에 대한 공권력 등 외부세력의 간섭을 배제하고 대학인 자신이 대학을 자주적으로 운영할 수 있도록 함으로써 대학인으로 하여금 연구과 교육을 자주적으로 운영할 수 있도록 함으로써 대학인으로 하여금 연구와 교육을 자유롭게 하여 진리탐구와 지도적 인격의 도야라는 대학의 기능을 충실히 발휘할 수 있도록 하기 위한 것으로서 이는 학문의 자유의 확실한 보장수단이자 대학에 부여된 헌법상의 기본권이다.

2) 내용

대학의 자유는 대학인사·학사·질서·재정 등 대학운영 전반에 대한 교수회의 자치와 학생회의 자치를 내용으로 한다. 그러나 대학운영 전반에 대한 학생회의 발언권이 존중된다 하더라도 학생은 피교육자의 입장에 있으므로 학생회의 자치는 학생회의 운영, 과외활동의 운영 등에 제한되며, 대학운영 전반에 대한 결정참여권에는 일정한 한계가 있을 수밖에 없다.

<헌법재판소 1998. 7. 16. 96헌바33 등> 사립학교법 제53조의2 제2항 위헌소원 등

대학의 자율은 대학시설의 관리·운영만이 아니라 전반적인 것이라야 하므로 연구과 교육의 내용, 그 방법과 대상, 교과과정의 편성, 학생의 선발과 전형 및 특히 교원의 임면에 관한 사항도 자율의 범위에 속한다.

<헌법재판소 2001. 2. 22. 99헌마613> 세무대학 설치법 폐지법률 위헌확인

국립대학인 세무대학은 공법인으로서 사립대학과 마찬가지로 대학의 자율권이라는 기본권의 보호를 받으므로 세무대학은 국가의 간섭 없이 인사·학사·시설·재정 등 대학과 관련된 사항들을 자주적으로 결정하고 운영할 자유를 갖는다. 그러나 대학의 자율성은 그 보호영역이 원칙적으로 당해 대학 자체의 계속적 존립에까지 미치는 것은 아니다. 즉, 이러한 자율성은 법률의 목적에 의해서 세무대학의 설립과 폐교가 국가의 합리적인 고도의 정책적 결단 그 자체에 의존하고 있는 이상 세무대학의 계속적 존립과 과제수행을 자율성의 내용으로 요구할 수 없다고 할 것이다. 따라서 이 사건 폐지법에 의해서 세무대학을 폐교한다고 해서 세무대학의 자율성이 침해되는 것은 아니다. 국가가 세무대학과 같은 국립대학을 설치·조직·폐지하는 등의 조직권한은 원칙적

지는 특별한 학문의 자유와 자치를 향유하지 못한다고 말하지 않을 수 없다. 또 그 집회가 학생만이 아니고 일반공중의 입장을 허가한 경우는 오히려 공개의 집회로 보아야 할 것이다(일본최고재판소 1963. 5. 22. 형17·4·370).

527) 김철수, 전게서, 596면.

528) 허영, 전게서, 401~402면; 계희열, 「헌법학」(상), 박영사, 1995, 322면; 권영성, 전게서, 498면.

529) 홍성방, 전게서, 197면.

530) 홍성방, 전게서, 197면.

으로 당해 대학에 재직 중인 자들의 기본권에 의해서 제한되지 아니한다. 게다가 이 사건 폐지법(부칙 제4조 제3항)은 세무대학소속 교수·부교수·조교수 및 전임강사의 신분보장에 관하여 교육공무원법의 해당 조항을 준용함으로써 세무대학을 폐지하더라도 교수들의 지속적인 학문활동을 보장하는 등 기존의 권리를 최대한 보장하고 있다. 따라서 이 사건 폐지법에 의한 세무대학의 폐교로 인하여 곧바로 청구인 자신의 진리탐구와 연구발표 및 교수의 자유가 침해되는 것은 아니다.

⑸ 효력

학문의 자유에는 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력이 인정된다.

⑹ 제한

학문연구의 자유는 절대적 자유권에 속한다.

<대법원 1982. 5. 25. 82도716>
헌법상 보장된 학문연구의 자유는 학문연구를 순수한 목적으로 하는 경우에 한하여 인정되는 것도 그것이 불법한 목적을 달성하기 위한 수단으로써 행해지는 경우, 예컨대 구 반공법 제4조 제2항 또는 국가보안법 제7조 제5항에서 규정한 것과 같은 반국가단체 또는 국외공산계열의 활동을 찬양·고무·동조 기타 이롭게 하는 행위를 할 목적으로 학문연구활동을 빙자하여 문서·도서 기타의 표현물을 제작·수입·복사·운반 또는 반포하는 등의 행위를 하는 경우에는 이미 학문의 연구하고 볼 수 없음은 명백하다.

<대법원 1993. 2. 9. 92도1711>
한국사회를 신식민지국가독립자본주의사회로 파악하는 것 자체는 학문적 연구의 결과로서 비록 그 분석방법이 마르크스주의에 입각한 것이라 하여도 이는 헌법이 보장하고 있는 학문의 범주 내에 속하는 것이어서 국가보안법에 저촉되는 것이라고 볼 수 없다. 그러나 반체제독점민주주의혁명론은 우리 헌법상의 자유민주적 기본질서와는 서로 용납되지 아니한다.

그러나 학문의 자유 중 학문연구의 자유를 제외한 나머지 자유는 학문의 자유가 자체 내의 통제력을 상실하고 공공의 안녕질서에 중대한 위해를 끼칠 명백하고 현존하는 위험이 있는 경우에 한해서 헌법 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있다. 그러나 본질적인 내용은 침해할 수 없다.

<대법원 1967. 12. 26. 67다591>
대학의 실험실에서 진리와 가치를 탐구하기 위하여 실험을 하고 그 결과를 발표하는 것이 학문의 자유에 속한다고 하더라도 그 실험결과가 잘못되었는데도 이를 사회에 알려서 선의의 제3자를 해친다면 이는 학문의 범위를 넘어선 것으로 허용될 수 없다.

<대법원 1986. 9. 9. 86도1187> 미문화원 점거농성
헌법상 학문의 자유는 진리의 탐구를 순수한 목적으로 하는 경우에 한하여 보호를 받는 것이므로 반국가단체를 이롭게 할 목적으로 공산주의 혁명이론 및 전술에 관한 내용을 담은 서적을 소지하고 있었다면 그것은 학문의 자유에 대한 한계를 넘은 것이라고 할 것이며, 또 소지한 서적이 국내에서 번역·소개되었다거나 대학에서 부교재로 사용되는 것이라 하여도 마찬가지이다.

3. 예술의 자유

⑴ 연혁 및 의의

예술의 자유는 1919년 바이마르헌법 제142조에서 처음으로 규정되었으며, 학문의 자유와 마찬가지로 국가기관에 의한 예술의 침체·왜곡·창조성의 억압을 방지하려는 데 목적이 있다.

⑵ 법적성격 및 주체, 다른 기본권과의 관계

예술의 자유는 개인의 주관적 공권이자 동시에 객관적 법질서를 의미한다. 또한, 예술의 자유는 개인과 법인이 주체가 된다. 음반제조업자나 출판업자와 같이 예술자와 일반대중을 직접 연결해 주는 자들도 부분적으로 예술의 자유의 주체가 된다.

예술의 자유는 언론·출판의 자유와 집회·결사의 자유에 대해서는 특별법적 규정이다.

⑶ 의미

일반적으로 예술은 미를 추구하는 작용이라고 정의된다. 독일연방헌법재판소는 초기에 메피스토-클라우스만 결정에서 예술적 활동의 본질은 예술가의 인상·견문·체험 등을 일정한 형태언어를 매개로 하여 직접적인 표상으로 나타내는 자유로운 창조적 형성에 있으며 모든 예술적 활동은 논리적으로는 해명할 수 없는 의식적·무의식적 과정의 혼합이다. 예술적 창조에는 직관, 상상 및 예술적 이해가 공동으로 작용한다. 그것은 무엇보다도 전달이 아니라 표현이며, 더욱이 예술가의 인격의 가장 직접적인 표현이다고 하였다.[531]

그러나 그 후, 예술을 일반적으로 개념 정의하는 것은 불가능하다고 태도를 변경하면서,[532] 형식적 예술개념, 개방적 예술개념을 혼용하고 있다.[533]

⑷ 내용

예술의 자유는 예술창작의 자유, 예술표현의 자유, 예술적 집회·결사의 자유를 내용으로 한다. 예술활동에는 고도의 자율성이 요청되기 때문에 예술적 집회·결사의 자유는 일반적인 집회·결사의 자유보다 고도로 보장되어야 한다.

<헌법재판소 1993. 5. 13. 91헌바17> 음반에 관한 법률 제3조 등에 대한 헌법소원

예술의 자유의 내용으로는 일반적으로 예술창작의 자유, 예술표현의 자유, 예술적 집회 및 결사의 자유 등을 들고 있다. 그 중 예술창작의 자유는 예술창작활동을 할 수 있는 자유로운 창작소재, 창작형태 및 창작과정 등에 대한 임의로운 결정권을 포함한 모든 예술창작활동의 자유를 그 내용으로 한다. 따라서 음반 및 비디오물로써 예술창작을 하는 자유도 예술의 자유에 포함된다. 예술표현의 자유는 창작한 예술품을 일반대중에게 전시·공연·보급할 수 있는 자유이다. 예술품보급의 자유와 관련해서 예술품보급을 목적으로 하는 예술출판자 등도 이러한 의미에서의 예술의 자유의 보호를 받는다. 따라서 비디오물을 포함하는 음반제작자도 예술표현의 자유를 향유한다.

---

531) BVerfGE 30, 173(188f.)
532) BVerfGE 67, 213(225).
533) BVerfGE 67, 213(226f.).

따라서 예술인들 스스로에 의한 자발적·임의적·권고적 사전심의 등은 허용되지만 국가기관에 의한 일방적·강제적 사전심의는 금지된다.

<헌법재판소 1996. 10. 4. 93헌가13> 영화법 제12조 등에 대한 위헌제청 및 헌법소원

영화법은 상영하기 전에 공연윤리위원회의 사전심의를 받아야 한다고 규정하고 있고, 공연법은 행정권이 공연윤리위원회의 구성에 지속적인 영향을 미칠 수 있게 하였으므로 공연윤리위원회는 검열기관으로 볼 수밖에 없다.

또한, 영화나 소설 등에서 실명을 표기하여 특정인물의 사생활을 침해하면 명예훼손이 성립하고, 내용이 음란하거나 외설적인 경우는 예술의 자유의 보호대상이 되지 못하여 형법 제243조, 제244조의 음란문서제조죄 등으로 처벌된다.

<대법원 1970. 10. 30. 70도1879>

비록 명화에 실려있는 그림이라 하여도 이를 예술·문학·교육 등 공공의 이익을 위해서 이용하는 것이 아니고, 다른 상품 특히 성냥갑 속에 넣어서 판매할 목적으로 그 카드사진을 복사제조하거나 시중에 판매할 때에는 이를 보는 자에게 성욕을 자극하여 흥분시키는 동시에 일반인의 정상적인 성적정서와 선량한 사회풍기를 해칠 가능성이 있다.

우리 헌법재판소는 '음란'이란 인간존엄 내지 인간성을 왜곡하는 노골적이고 적나라한 성표현으로 오로지 성적흥미에만 호소할 뿐 전체적으로 보아 하등의 문화적, 과학적 또는 정치적 가치를 지니지 않는 것으로서 사회의 건전한 성도덕을 크게 해칠 뿐만 아니라 사상의 경쟁메커니즘에 의해서도 그 해악이 해소되기 어려워 언론·출판의 자유에 의한 보장을 받지 않는 반면, '저속'은 이러한 정도에 이르지 않는 성표현 등을 의미하는 것으로서 헌법적인 보호영역 안에 있다고 한다.[534]

⑸ 효력

예술의 자유는 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력을 가진다.

⑹ 제한

예술창작의 자유는 절대적 자유권에 속한다. 그러나 예술활동을 통하여 민주적 기본질서, 타인의 권리와 명예보호, 재산권 등을 침해해서는 아니되고, 공중도덕이나 사회윤리를 어기는 예술활동은 헌법 제37조 제3항에 따라 제한될 수 있다. 그러나 본질적인 내용은 침해할 수 없다.

4. 지적재산권의 보호

⑴ 헌법규정

헌법 제22조 제2항의 규정에 의하여 저작자·발명가·과학기술자와 예술가의 권리는 법률로써 보장된다. 저작권법, 공업소유권법, 특허법, 영화법, 공연법 등에 의하여 저작권·산업소유권(특

534) 헌법재판소 1998. 4. 30. 95헌가16.

허, 실용신안, 의장, 상표 등), 예술공연권, 제3의 권리(computer software, 반도체 칩, 영업비밀) 등이 보호되고 있다.

<헌법재판소 1993. 11. 25. 92헌마87> 의료기사법시행령 제2조에 대한 헌법소원
과학기술자의 특별보호를 명시한 헌법 제22조 제2항은 과학·기술의 자유롭고 창조적인 연구개발을 촉진하여 이론과 실제 양면에 있어서 그 연구와 소산을 보호함으로써 문화창달을 제고하려는 데 그 목적이 있는 것이다.

⑵ 지적재산권보호의무

엄격하게 말하면 이들 권리는 자유권은 아니다. 그러나 국가가 이들 정신적·문화적·기술적 창작자들의 권리를 법률로써 특리 보장함으로써 문화를 향상시키려는 데 그 의미가 있다. 이와 관련하여 현행 헌법은 제9조에서 전통문화의 계승·발전과 민족문화의 창달에 노력할 국가의 의무를 규정함으로써 문화국가를 지향함을 분명히 하고 있다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 학문의 자유와 관련이 적은 것은?
① 예술의 자유
② 지적소유권
③ 교수의 자유
④ 수업의 자유
⑤ 대학의 자치

[정답] ④
[해설] 교수의 자유는 수업의 자유와 구별된다(헌법재판소 1992. 11. 12. 89헌마88).

2. 다음 중 고도의 헌법적 보장을 받아야 하는 것은?
① 보도의 자유
② 학문연구의 자유
③ 교수의 자유
④ 종교행사의 자유
⑤ 연구결과발표의 자유

[정답] ②
[해설] 학문연구의 자유는 절대적 기본권이다.

3. 다음 예술의 자유에 포함되지 않는 것은?
① 예술 창작의 자유
② 예술 표현의 자유
③ 예술적 집회·결사의 자유
④ 예술 활동의 자유
⑤ 예술적 비판·비평의 자유

[정답] ⑤
[해설] 표현의 자유에서 보호된다.

♣ 요점정리

1. 민주국가의 헌법들이 학문의 자유를 보장하고 있는 것은 학문은창조적인 인간정신의 귀중한 성과로서 문화발전의 선구적 역할을 하며, 학문은 새로운 지식을 개척하는 것이므로 기존지식을 기초로 하는 국가기관으로부터 독립되어야 하고, 학자는 그 방면에 있어서의 특수한 전문가이니 상식적인 국가기관의 판단에 의한 통제로부터 초월해야 하기 때문이다.

2. 대학의 자율은 대학시설의 관리·운영만이 아니라 학사관리 등 전반적인 것이라야 하므로 연구와 교육의 내용, 그 방법과 대상, 교과과정의 편성, 학생의 선발, 학생의 전형도 자율의 범위에 속해야 하고 따라서 입학시험제도도 자주적으로 마련될 수 있어야 한다.

3. 학문의 자유는 학문연구의 자유, 학문활동의 자유를 내용으로 한다. 여기서 학문연구의 자유는 연구대상의 선택, 연구방법, 연구과정에서의 자유를 포함하며, 학문활동의 자유는 교수(강학 또는 학설)의 자유, 학문연구결과발표의 자유, 학문을 위한 집회·결사의 자유를 포함한다.

4. 학문연구의 자유는 절대적 자유권에 속한다.

5. 예술의 자유는 예술창작의 자유, 예술표현의 자유, 예술적 집회·결사의 자유를 내용으로 한다. 예술활동에는 고도의 자율성이 요청되기 때문에 예술적 집회·결사의 자유는 일반적인 집회·결사의 자유보다 고도로 보장되어야 한다.

6. 예술품보급의 자유와 관련해서 예술품보급을 목적으로 하는 예술출판자 등도 이러한 의미에서의 예술의 자유의 보호를 받는다.

7. 예술인들 스스로에 의한 자발적·임의적·권고적 사전심의 등은 허용되지만 국가기관에 의한 일방적·강제적 사전심의는 금지된다.

8. 우리 헌법재판소는 '음란'이란 인간존엄 내지 인간성을 왜곡하는 노골적이고 적나라한 성표현으로 오로지 성적흥미에만 호소할 뿐 전체적으로 보아 하등의 문화적, 과학적 또는 정치적 가치를 지니지 않는 것으로서 사회의 건전한 성도덕을 크게 해칠 뿐만 아니라 사상의 경쟁메커니즘에 의해서도 그 해악이 해소되기 어려워 언론·출판의 자유에 의한 보장을 받지 않는 반면, '저속'은 이러한 정도에 이르지 않는 성표현 등을 의미한는 것으로서 헌법적인 보호영역 안에 있다고 한다.

제31강 재산권

♣ 학습목표

재산권에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

재산권 보장의 연혁
헌법 제23조의 의무의 법적성격
재산권의 주체와 객체
사유재산제도의 보장
소급입법에 의한 재산권침탈금지
진정소급입법과 부진정소급입법
법률주의
재산권행사의 사회적 기속성
재산권의 사회적 기속성의 한계설정에 관한 이론

♣ 사전테스트

1. 헌법 제23조 제2항의 의무는 헌법적 의무이다.
   정답 : O
   해설 : 헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13.

2. 재산권 보장은 개인이 현재 누리고 있는 재산권을 개인의 기본권으로 보장한다는 의미만을 가진다.
   정답 : X
   해설 : 재산권 보장은 개인이 현재 누리고 있는 재산권을 개인의 기본권으로 보장한다는 의미와 개인이 재산권을 향유할 수 있는 법제도로서의 사유재산제도를 보장한다는 이중적 의미를 가지고 있다(헌법재판소 1993. 7. 29. 92헌바20).

3. 헌법 제23조 제2항의 의무는 내재적 제약으로 보아야 한다.
   정답 : X
   해설 : 헌법재판소는 헌법상의 의무로 보고 있다(헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13).

♣ 돌발퀴즈

헌법 제23조 제1항 제2문은 기본권 형성적 법률유보이다.

[정답] O
[해설] 헌법재판소 1993. 7. 29. 92헌바20.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

재산권은 생명·자유와 더불어 고전적·전통적인 자유권적 기본권의 핵심적 내용으로 존중되어 왔다. 즉, 1789년 프랑스 인권선언 제17조와[535] 미연방수정헌법 제5조에서[536] 찾아볼 수 있다.

그러나 이러한 재산권에 대한 절대적 보장은 자본주의의 발전과 더불어 현격한 빈부격차, 빈민문제 등의 사회문제들로 인하여 절대적 보장이념에서 재산권의 공공복리성을 강조하는 방향으로 수정되었다. 즉, 사회문제들을 해결하기 위해 경제영역에서의 자유 방임주의적인 국가에서 적극적인 간섭과 조정을 통해 개입하는 국가의 책무가 요청되었다. 바이마르헌법 제153조 제3항은[537] 이러한 이념을 반영하였다.

우리 헌법은 재산권을 보장하면서도 재산권의 상대성·사회성·의무성을 강조함으로써 자유주의적 자본주의의 수정을 인정하여 재산권의 제약을 상당한 범위에서 허용하고 있다. 우리 헌법재판소도 토지거래허가제에 관한 사건에서 재산권의 성격이 변화함에 따라 오늘날에는 재산권의 사회적 기속성을 강조하는 상대적 권리로 규정되고 있음을 판시한 바 있다.[538]

현행 헌법은 제23조에서 재산권을 규정하여 보장하고 있다. 그 밖에도 제13조 제2항은 소급입법에 의한 재산권박탈금지, 제22조 제2항은 지적소유권인 무체재산권의 보장, 제121조는 농지경자유전의 원칙과 위탁경영의 예외, 122조는 국토의 효율적 이용·개발의무, 제126조는 법률에 의한 사영기업의 국·공유화 경영의 통제·관리를 규정하고 있다.

2. 법적성격

재산권은 자유권적 기본권이자 사유재산제도를 보장한 것이다.[539] 나아가 객관적 가치질서로서의 성격을 함께 가지고 있다. 제도보장의 핵심은 생산수단의 사유로 보아야 한다.[540]

<헌법재판소 1993. 7. 29. 92헌바20> 민법 제245조 제1항에 대한 헌법소원

재산권 보장은 개인이 현재 누리고 있는 재산권을 개인의 기본권으로 보장한다는 의미와 개인이 재산권을 향유할 수 있는 법제도로서의 사유재산제도를 보장한다는 이중적 의미를 가지고 있다. 이러한 재산권에 관한 규정은 민사법질서의 기본구조라고 할 수 있다.

헌법 제23조 제2항의 의무에 대하여 헌법적 의무로 보는 견해,[541] 내재적 제약으로 보는 견해,[542] 헌법에 의한 기본권제한 중 기본권의 내용에 제한을 가하는 것으로 보는 견해[543] 등이 있으나 헌법재판소는 헌법상의 의무로 보고 있다.[544]

---

535) 소유권은 불가침이고 또 신성한 권리로서 명백한 공공의 필요가 있음을 법률이 인정함과 동시에 정당한 사전보장을 조건으로 하지 않는 한 누구도 이를 탈취당하지 아니한다.
536) 법의 정당한 절차에 의하지 아니하고는 생명·자유 또는 재산은 탈취당하지 아니한다. 사유재산은 정당한 보상 없이 공공의 이용에 제공하기 위하여 징수되지 아니한다.
537) 재산권은 의무를 수반하며, 그 행사는 동시에 공공복리를 위하여야 한다.
538) 헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13.
539) BverfGE 24, 367(387); 26, 215(222).
540) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 210.
541) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 565면.
542) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 519면.
543) 홍성방, 전게서, 210면.
544) 헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13.

3. 주체와 객체

⑴ 주체

자연인과 법인 모두가 주체가 되며, 국가와 지방자치단체도 주체가 된다. 그러나 외국인의 경우에는 호혜주의 원칙에 따른다.

⑵ 객체

헌법 제23조 제1항 제2문에 의해 재산권의 내용과 한계는 법률로 정해지며, 재산권의 범위는 시대의 관념에 따라 재산권을 구체화하는 입법작용에 의하여 정하여진다. 즉, 재산권의 절대적 개념은 존재하지 않는다.[545]

그러나 재산권은 공·사법상 경제적 가치가 있는 모든 권리를 포함한다고 이해되며, 그 재산가액의 다과는 문제가 되지 않는다.[546] 따라서 민법상의 소유권, 물권, 채권은 물론 무체재산권과 특별법상의 권리, 영업상의 권리와 공법상의 제 권리(예컨대, 공무원의 봉급청구권, 연금청구권 등),[547] 상속권을 포함한다.

그러나 단순한 기대이익, 반사이익, 단순한 경제적 기회, 우연히 발생한 법적지위 등은 재산권에 속하지 않는다.[548] 지적재산권도 재산권에 속하지만 우리 헌법은 제22조 제2항에서 별도로 규정하고 있다.

<헌법재판소 1992. 6. 26. 90헌바26> 장기간행물의 등록 등에 관한 법률 제10조 제1항

헌법이 보장하고 있는 재산권은 경제적 가치가 있는 모든 공법상·사법상의 권리를 뜻하고, 그 재산가액의 다과를 불문하다. 또 재산권의 보장은 재산권의 자유로운 처분의 보장까지 포함한다.

<헌법재판소 1999. 4. 29. 97헌마333> 공무원연금법 제3조 제2항의 위헌확인

공무원연금법상의 퇴직급여, 유족급여 등 각종 급여를 받을 권리, 즉 연금수급권에는 사회적 기본권의 하나인 사회보장수급권의 성격과 재산권의 성격이 불가분적으로 혼재되어 있으므로 입법자로서는 연금수급권의 구체적 내용을 정함에 있어서 반드시 민법상속의 법리와 순위에 따라야 하는 것이 아니라 공무원연금제도의 목적달성에 맞도록 독자적으로 규율할 수 있다.

<헌법재판소 1996. 8. 29. 95헌바36> 구 산업재해보상보호법 제14조 단서 위헌소원

영리획득의 단순한 기회 내지 기업활동의 사실적·법적 여건은 재산권보장의 대상이 아니다.

---

545) BVerfGE 20, 351(355).
546) 헌법재판소 1992. 6. 26. 90헌바26.
547) 독일연방헌법재판소는 직업공무원제도에 의해 보호된다고 한다(BVerfGE 16, 94, 115). 그러나 독일연방대법원은 재산권으로 본다(BGHZ 6, 270, 278).
548) 헌법재판소 1998. 12. 24. 98헌바30 등.

4. 내용

⑴ 사유재산제도의 보장

헌법 제23조 제1항의 규정은 자유권적 기본권으로서 재산권을 보장하는 동시에 사적 효용성과 재산권의 객체에 대한 원칙적인 처분가능성을 핵심으로 하는[549] 사유재산제를 제도적으로 보장하는 의미를 갖는다. 따라서 입법기관은 재산권의 내용과 한계를 정하는 입법을 함에 있어 사유재산제도를 폐지하거나 부인하는 법률을 제정할 수는 없다.

사유재산제도를 폐지하거나 부인하는 법률은 헌법 제9장 경제편에서 인정된 정책적 필요의 범위를 일탈하여 재산권의 내용과 한계를 규제하는 입법, 즉 상속권의 폐지, 단순한 정치적 이유에 기초한 재산권의 몰수 또는 전반적인 계획경제의 실시 등은 사유재산제와 저촉된다.

<헌법재판소 1997. 12. 24. 96헌가19 등> 구 상속세법 제9조 제1항

헌법 제23조 제1항이 보장하고 있는 사유재산권은 사유재산에 관한 임의적인 이용, 수익, 처분권을 본질로 하기 때문에 사유재산의 처분금지를 내용으로 하는 입법조치는 원칙적으로 재산권에 관한 입법형성권의 한계를 일탈하는 것일 뿐만 아니라 조세의 부과·징수는 국민의 납세의무에 기초하는 것으로서 원칙적으로 재산권의 침해가 되지 않는다고 하더라도 그로 인하여 납세의무자의 사유재산에 관한 이용, 수익, 처분권이 중대한 제약을 받게 되는 경우에는 그것도 재산권의 침해가 될 수 있는 것이다.

⑵ 사유재산권의 보장

헌법이 사유재산권을 보장한다는 것은 재산을 소유하고 상속할 수 있을 뿐만 아니라 재산을 사용·수익·처분할 수 있는 권능을 보장한다는 것을 의미한다. 이러한 의미의 재산권은 국가에 대하여 소극적·방어적 성격을 갖는다. 따라서 국가는 과세권을 행사함에 있어서 법률의 근거와 합리적 이유 없이 국민의 재산권을 함부로 침해할 수 없다.[550] 즉, 조세법률주의를 무시한 국가의 자의적인 과세권행사는 헌법 제23조 제1항에 의하여 보장된 국민의 재산권을 침해하는 것이다.

⑶ 소급입법에 의한 재산권침탈금지

1) 의미

헌법 제13조 제2항은 소급입법에 의한 재산권박탈금지를 규정하여 재산권을 보장하고 있고, 4·19 이후의 부정축재특별처리법이나 5·16 이후의 부정축재처리법 등의 재현을 헌법 자체가 금지하고 있으며, 예외가 없다.[551]

2) 진정소급입법과 부진정소급입법

과거의 사실관계나 법률관계를 규율하기 위한 소급입법에는 진정소급입법과 부진정소급입법이 있다. 진정소급입법은 과거에 완성된 사실 또는 법률관계를 규율대상으로 한다. 부진정소급입법은 이미 과거에 시작하였으나 아직 완성되지 아니하고 진행과정에 있는 사실 또는 법률관계를 규율대상으로 한다.

---

549) BVerfGE 24, 389f.; 31, 240f.
550) 헌법재판소 1992. 12. 24. 90헌바21.
551) 홍성방, 전게서, 213면.

헌법재판소는 진정소급입법을 인정하지 않고 있으나,[552] 부진정소급입법의 경우에는 입법형성권을 중시하여야 할 특단의 사정이 없는 한 새 입법을 하면서 구법관계 내지 구법상의 기대이익을 존중하여야 할 의무가 발생하지 않는다고[553] 한다.

5. 효력

재산권은 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력을 갖는다.

6. 한계 및 제한

⑴ 한계

1) 법률주의

헌법 제23조 제1항 제2문에서 재산권의 내용과 한계를 법률로 정한다고 규정하고 있다. 이 규정을 헌법재판소는 기본권 형성적 법률유보로 보고 있다.[554]

2) 재산권의 사회적 기속성

가. 의미

헌법 제23조 제2항은 재산권 행사는 공공복리에 적합하도록 해야 한다고 규정하고 있다. 여기서 말하는 공공복리는 제37조 제2항의 공공복리와는 다른 의미를 가진다. 즉, 제37조 제2항의 공공복리는 모든 기본권에 대하여 헌법이 일반적으로 유보하고 있는 제약이기 때문에 그 의미내용은 엄격하게 해석되어야 한다.

그에 반하여 제23조 제2항의 공공복리는 특별한 법률에 의한 유보를 의미하기 때문에 그 의미내용은 재산권의 사회성·의무성을 전제로 하는 것으로 정책적 제약까지도 인정하는 것으로 이해된다.[555]

<헌법재판소 1989. 12. 22. 88헌가13> 국토이용관리법 제21조의3 제1항, 제31조의2

재산권행사의 사회적 의무성을 헌법 자체에서 명문화하고 있는 것은 사유재산제도의 보장이 타인과 더불어 살아가야 하는 공동체생활과의 조화와 균형을 남용을 흐트러뜨리지 않는 범위내에서의 보장임을 천명한 것으로서 재산권의 악용 또는 남용으로 인한 사회공동체의 균열과 파괴를 방지하고 실질적인 사회정의를 구현하겠다는 국민적 합의의 표현이라고 할 수 있으며, 사법영역에서도 신의성실의 원칙이라든가 권리남용금지의 원칙, 소유권의 상린관계 등의 형태로 그 정신이 투영되고 있는 것이다.

나. 사회적 기속성 한계설정이론

재산권을 형성하는 내용규정(보호영역)과 제한(공용침해)을 모두 입법자가 결정하므로, 양자를 구분하여서 헌법상 원칙적으로 보상이 필요 없는 내용규정인지 아니면 보상을 하여야 하는 공용침해인지를 명확히 할 필요가 있다.

---

552) 헌법재판소 1989. 9. 30. 97헌바38.
553) 헌법재판소 1989. 3. 17. 88헌마1; 1989. 12. 18. 89헌마32 등.
554) 헌법재판소 1993. 7. 29. 92헌바20.
555) 한동섭, 「헌법」, 박영사, 1971, 169면.

재산권의 내용규정(보호영역)과 제한 사이에는 문턱과 같은 경계만 그어져 있어서 보호영역의 선을 넘으면 보상을 하여야 하는 기본권제한(공용침해)으로 전환된다는 견해를 경계이론(전환이론)이라고 한다.

이에 비하여 양자는 입법자가 사전에 결정하여야 분리된 별개의 제도로서 보호영역의 한계를 넘는 행위는 보상을 하여야 하는 기본권제한이 아니라 원칙적으로 위헌이라고 보는 견해를 분리이론(단절이론)이라고 한다.

ㄱ. 경계이론

경계이론에 의하면 재산권을 형성하는 내용규정(보호영역)과 재산권제한(공용침해)은 별개의 제도가 아니라 재산권규제의 강도에 따라서 상대적으로 구분되는 것이다.[556] 즉, 재산권규제의 강도가 사회적 제약의 범위 내에 있으면 재산권의 내용규정으로서 보상을 필요로 하지 않지만, 사회적 제약을 벗어나는 재산권규제는 보상할 의무가 있는 공용침해이다.

재산권의 내용과 공용침해를 구분하는 기준은 적용되는 사람의 수에 초점을 둔 형식설과 재산권규제의 실질적인 내용에 초점을 둔 실질설로 구분된다. 개별행위설(Einzelakttheorie) 내지는 특별희생설(Sonderopfertheorie)로 대별되는 형식설에 의하면 법률이 불특정 다수인에게 일반적으로 가한 재산권규제는 불평등하게 희생을 가한 것이 아니고 누구에게나 공공복리를 위하여 가해지는 부담이기 때문에 보상을 할 필요가 없다.

재산권규제의 본질성(Wesentlichkeit) 내지 강도 등의 실질적 표준에 의하여 사회적 제약의 한계를 정하고자 하는 실질설에는 보호가치설, 수인한도설, 목적위배설, 사적 효용설, 상황기속성설, 사회적 구속성설 등이 있으나 각기 부분적인 타당성이 인정될 수 있지만 구체적인 문제를 해결하는 완벽한 기준이 되지 못하고 있다.

경계이론에 의하면 사회적 제약을 넘는 공용침해여부를 구체적인 사안에서 법원이 결정하게 되는 데, 이에 의하면 보상을 요하는 재산권규제는 의도적이고, 고권적인 적법한 재산권박탈을 뜻하는 헌법 제23조 제3항의 공용침해의 경우에만 국한되지 않는다. 예컨대, 합법적인 장기간의 도로공사로 인하여 상점주인이 사실상 받는 재산적 손해와 같이 합법적인 행정행위가 초래하는 비의도적·비정형적인 재산권제한인 수용적 침해나 위법한 재산권침해로서 당사자에게 특별한 희생을 초래하는 수용유사적 침해는 결과적으로 헌법 제23조 제3항에 의한 보상을 요하는 공용침해로 파악된다.

ㄴ. 분리이론(단절이론)

독일 연방헌법재판소는 1981년 자갈채취사건 이후로 독일기본법 제14조 제3항의 공용침해와 제14조 제1항 제2문의 내용규정을 헌법적으로 서로 다른 독립된 범주로 분리하는 분리이론을 채택하였다. 입법자가 법제정시에 미리 의도하는 바에 따라서 공용수용과 재산권의 내용규정이 개념적으로 분리된다.

독일의 연방헌법재판소는 재산권의 내용규정을 '입법자가 장래에 있어서 재산권자의 권리와 의무를 일반적·추상적 형식으로 확정하는 것'으로 정의하였다. 이에 비하여 공용침해는 '국가가 구체적인 공적 과제의 이행을 위하여 이미 형성된 구체적인 재산권적 지위를 전면적 또는 부분적인 박탈하는 것'이다.

재산권의 내용규정이 일정한 한계를 벗어났다고 하여도, 법원에 의하여 공용수용으로 전환되는 것이 아니라 단지 위헌인 규정일 뿐이다. 재산권의 내용규정이 사실상 수용적 효과를 가지고 있어도 보상을 하여야 하는 공용침해로 전환될 수 없다.

---

556) 강태수, "분리이론에 의한 재산권체계 및 그 비판에 대한 고찰", 「헌법학연구」 제10권 제2집, 2004. 6, 117면 이하.

ㄷ. 분리이론에 입각한 헌법재판소의 판례

헌법재판소는 1998년 12월에 개발제한구역을 규정한 도시계획법 제21조에 대하여 헌법불합치결정을 내리면서 재산권의 내용규정과 공용침해를 각기 입법자가 사전에 의도한 별개의 독자적인 제도라는 분리이론을 처음으로 채택하였다.[557]

헌법재판소의 결정요지는 첫째, 개발제한구역을 지정하여 그 안에서는 건축물의 건축 등을 할 수 없도록 하고 있는 도시계획법 제21조는 헌법 제23조 제1항 및 제2항에 따라 토지재산권에 관한 권리와 의무를 일반·추상적으로 확정하는 규정으로서 재산권을 형성하는 규정인 동시에 공익적 요청에 따른 재산권의 사회적 제약을 구체화하는 규정이다. 동조항은 제23조 제3항의 재산권의 보호영역을 제한하는 공용침해가 아니며 따라서 원칙적으로 보상을 지급할 필요가 없고 단지 법질서에 의하여 재산권질서를 형성하는 재산권의 내용 및 한계에 해당한다는 것이다.

둘째, 재산권이 인정되고 보호받기 위해서는 입법자에 의한 구체화가 필요하지만, 재산권의 내용을 정하는 경우에도 다른 기본권을 제한하는 입법과 마찬가지로 과잉금지의 원칙(비례의 원칙), 평등의 원칙 등을 준수하고 재산권의 본질적 내용인 사용·수익권과 처분권을 부인하여서는 아니 된다.

셋째, 입법자가 도시계획법 제21조를 통하여 국민의 재산권을 과잉금지의 원칙에 부합하게 합헌적으로 제한하기 위해서는, 수인의 한계를 넘어 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우에는 이를 완화하는 보상규정을 두어야 한다. 재산권의 침해와 공익간의 비례성을 다시 회복하기 위한 방법은 헌법상 반드시 금전보상만을 해야 하는 것은 아니다. 입법자는 지정의 해제 또는 토지매수청구권제도와 같이 금전보상에 갈음하거나 기타 손실을 완화할 수 있는 제도를 보완하는 등 여러 가지 다른 방법을 사용할 수 있다.

우리 헌법재판소는 도시계획법 제21조에 대한 사건 이후에 '택지소유 상한에 관한 법률', 도시계획법 제6조, 자연공원법 제4조에 대한 사건에 이르기까지 분리이론을 견지하고 있지만 헌법재판소의 논지는 부분적으로 논리가 부족한 측면이 있으며, 이는 전통적인 경계이론으로의 회귀를 주장하는 근거가 되고 있다.[558]

<헌법재판소 2011. 10. 25. 2010헌바384> 학교위생시설 정화구역

법률에 의한 일반적 추상적 재산권의 내용규정이 사실상 재산권 제한적인 조치를 수반하는 근거조항이 되더라도, 원칙적으로 보상이 필요 없다.[559]

ㄹ. 검토

재산권에 대한 제한이 개별적인 경우에는 특별희생이론을 기준으로 삼고, 재산권에 대한 제한이 집단적일 때에는 실질적 이론들을 기준으로 삼아 구체적인 경우마다 합리적인 해결을 하는 것이 바람직할 것이다.[560]

---

557) 헌법재판소 1998. 12. 24. 89헌마214 등.

558) 헌법재판소 1999. 4. 29. 94헌바37; 1999. 10. 21. 97헌바26; 2003. 4. 23. 99헌바110; 분리이론 및 헌법재판소의 결정에 대한 비판은 다음 문헌을 참조. 김문현, "재산권의 사회구속성과 공용수용의 체계에 대한 검토", 「공법연구」 제32권 제4호, 2004, 1면 이하; 정하중, "헌법상 재산권보장체계의 경계이론과 분리이론", 「토지보상법연구」 제3집, 2003, 1면 이하; 정연주, "재산권보장과 이익형량", 「공법연구」 제29집 제3호, 2003, 54면 이하; 석종현, "도시계획법과 손실보상", 「공법연구」 제28집 제3호, 2000, 27면 이하.

559) 기존의 여관영업을 하고자 하는 자가 신설되는 학교의 정화구역 안이라는 이유로 여관영업을 하지 못하게 되었다. 그래서 여관업자의 직업수행의 자유를 장소적으로 제한받게 되고, 또한 정화구역 안에서 건물을 소유하거나 여관을 운영하고 있는 자는 소유건물 혹은 여관시설을 여관용도로 사용할 수 없게 됨으로써 건물에 대한 사용·수익권 또는 영업상 권리를 제한받는 측면이 있으므로 동시에 재산권이 제한되고 있다고 하더라도 과도한 기본권의 제한이 아니라는 것이다.

560) 홍성방, 전게서, 218면.

⑵ 제한

1) 법률에 의한 제한

헌법 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있다.

2) 공공필요에 의한 제한

제23조 제3항의 공공필요는 제37조 제2항의 공공복리보다 넓고 적극적인 개념으로 정책적 제약까지도 포함하며 사회정의의 실현을 위한 것까지를 포함한다.[561]

공용수용이란 공익사업 기타 복리목적을 위하여 국가·공공단체 또는 사업주체가 타인의 특정한 재산권을 법률에 근거하여 종국적·강제적으로 취득하는 것을 말한다.

공용사용이란 공익사업 기타 공공목적을 위하여 국가나 지방자치단체 등의 사업주체가 타인의 토지 기타 재산권에 대한 공법상의 사용권을 일시적·강제적으로 취득하고, 상대방은 이를 수인해야 할 의무를 부담하는 것을 말한다.

공용제한이란 공익사업 기타 복리행정상의 목적을 위하여 특정한 재산권에 대하여 과하여지는 공법상의 제한을 말한다. 계획제한, 보전제한, 사업제한, 공물제한, 사용제한 등으로 나누어진다.

공용사용도 공용제한의 일종이지만 사용권의 설정이 주목적이고 재산권에 대한 그 효과에 불과하다는 점에서 구별된다.[562]

또한, 정당한 보상은 완전한 보상을[563] 의미하며, 재산적 가액, 즉 시가에 따른 보상을 의미한다.[564] 보상에 관한 규정은 재산권에 대한 공적제한에 있어서 결부조항 또는 불가분조항이다.[565] 따라서 보상규정이 없거나 부분적으로 인정하지 않는 공적제한은 그 자체가 위헌이다.[566]

문제는 재산권을 제한하는 법률은 존재하여 재산권은 제한되었으나 보상규정이 없는 경우가 없는 경우이다. 다수설은 헌법 제23조 제3항을 직접적용하여 보상을 하여야 한다고 한다. 이외에도 방침규정설,[567] 위헌무효설 등이 있다.

보상의 방법은 금전보상 외에도 현물보상이 가능하지만 수용법 제45조 제5항과 제6항의 채권보상은 논란의 여지가 있다.

3) 긴급명령, 긴급재정·경제명령처분의 의한 제한

7. 제한의 한계

재산권의 본질적인 내용인 사용·수익권과 처분권을 부인해서는 안 되며, 비례의 원칙을 준수해야 한다. 또한, 사유재산제의 전면부정, 재산권의 무상몰수, 소급입법에 의한 재산권의 박탈 등이 재산권의 본질적 침해가 된다.[568]

---

561) 문홍주, 전게서, 293면.
562) 헌법재판소 1998. 12. 24. 89헌마214 등.
563) 헌법재판소 1990. 6. 25. 89헌마107.
564) 헌법재판소 1993. 7. 29. 92헌바20.
565) BVerfGE 45, 63(75f.).
566) 헌법재판소 1998. 12. 24. 89헌마214 등.
567) 대법원 1976. 10. 12. 76다1443.
568) 헌법재판소 1998. 12. 24. 89헌마214; 1989. 12. 22. 88헌가13 등.

♣ 문제풀이

1. 다음 재산권에 관한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 사적유용성 및 그에 대한 원칙적 처분권을 내포하는 재산적 가치 있는 구체적 권리로서 재산가액의 다과는 불문한다.
② 단순한 이익이나 재화의 획득에 관한 기회 또는 기업활동의 사실적·법적 여건 등은 대상이 아니다.
③ 우리 헌법이 소유권 대신 재산권이라 함은 그 보장의 광범성을 의미한다.
④ 약사의 한약조제권은 재산권에 속한다.
⑤ 관행어업권은 물권에 유사한 권리로서 재산권에 속한다.

[정답] ④
[해설] 법률에 의해 약사에게 인정된 권능에 불과하다(헌법재판소 1997. 11. 27. 97헌바10).

2. 다음 중 재산권으로 보기 어려운 것은?

① 군인연금법상 퇴역연금수급권
② 공무원연금법상의 퇴직급여와 유족급여
③ 정당한 지목을 등록함으로써 토지소유자가 얻는 이익
④ 토지수용법상 또는 공용용지의 취득 및 손실보상에 관한 특례법상 환매권
⑤ 국민건강보험법상의 의료보험조합의 적립금

[정답] ⑤
[해설] 헌법재판소 2000. 6. 29. 99헌마289.

3. 다음 중 헌법상 재산권의 보장에 비추어 바르지 못한 것은?

① 사기업의 예외적 국유화
② 외국인에 대한 토지소유의 제한
③ 토지소유에 상한제를 도입하는 것
④ 국가긴급권에 의한 재산권의 소급적 제한
⑤ 공공필요에 의한 재산권의 제한

[정답] ④
[해설] 허용되지 않는다(헌법 제13조 제2항, 제76조).

♣ 요점정리

1. 우리 헌법은 재산권을 보장하면서도 재산권의 상대성·사회성·의무성을 강조함으로써 자유주의적 자본주의의 수정을 인정하여 재산권의 제약을 상당한 범위에서 허용하고 있다.

2. 헌법이 사유재산권을 보장한다는 것은 재산을 소유하고 상속할 수 있을 뿐만 아니라 재산을 사용·수익·처분할 수 있는 권능을 보장한다는 것을 의미한다.

3. 정당한 보상은 완전한 보상을 의미하며, 재산적 가액, 즉 시가에 따른 보상을 의미한다. 보상에 관한 규정은 재산권에 대한 공적제한에 있어서 결부조항 또는 불가분조항이다.

4. 재산권의 본질적인 내용인 사용·수익권과 처분권을 부인해서는 안 되며, 비례의 원칙을 준수해야 한다. 또한, 사유재산제의 전면부정, 재산권의 무상몰수, 소급입법에 의한 재산권의 박탈 등이 재산권의 본질적 침해가 된다.

제32강 사회적 기본권 일반론

♣ 학습목표

우리 헌법의 규정과 역사적 전개를 설명할 수 있다.
사회권의 의미를 설명할 수 있다.
사회적 권리와 사회주의적 권리를 구별하여 설명할 수 있다.
사회적 기본권의 법적성격을 설명할 수 있다.
사회권과 자유권의 관계에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

'사회적' 의미
사회적 권리와 사회주의적 권리
프로그램적, 추상적, 구체적 권리설
사회적 기본권 목록
사회권과 자유권의 관계

♣ 사전테스트

1. 우리 헌법상의 사회적 기본권규정들은 언제나 국가의 개입을 요청할 수 있다는 의미이다.
정답 : X
해설 : 개인들의 생활을 해결하지 못하는 경우에 비로소 국가의 개입을 요청할 수 있다는 보충성의 원리에 입각하고 있다.

2. 인권사적인 측면에서 볼 때, 사회권은 제3세대 인권이다.
정답 : X
해설 : 사회권은 제2세대 인권이다. 제3세대 인권은 연대권이다.

3. 우리 헌법재판소는 구체적 권리설을 따르고 있다.
정답 : X
해설 : 우리 헌법재판소는 '입법의 방향', '구체적 권리' 등 다양한 결정을 내리고 있다.

♣ 돌발퀴즈

구체적 권리설에 따르는 경우에는 사회적 기본권을 설명하는 데 어려움이 없다.

[정답] X
[해설] 구체적 권리설에 의하더라도 사회적 기본권의 특성상 모든 것이 다 해결될 수는 없다.

♣ 강의내용

1. 헌법규정과 역사적 전개

⑴ 헌법규정

우리 헌법 제31조에서부터 제36조에 걸쳐 교육을 받을 권리, 근로의 권리, 근로자의 노동3권, 인간다운 생활을 할 권리, 환경권, 보건권 등을 규정하여 사회적 기본권을 보장하고 있다. 이러한 사회적 기본권은 사회권적 기본권 또는 사회권이라 부르기도 하며, 학자에 따라서는 생존권적 기본권,[569] 또는 생활권적 기본권이라고도[570] 한다.

우리 헌법상의 사회적 기본권규정들은 모든 국민에게 교육을 받을 권리를 보장함으로써 시작에 있어서 평등을 보장하고, 그런 후에 근로의 권리를 보장함으로써 국민 스스로가 자신의 기본적인 생활상의 필요를 해결하게 하며, 그러고 나서도 이러한 권리들만으로 자신들의 생활을 해결하지 못하는 경우에 비로소 국가의 개입을 요청할 수 있다는 보충성의 원리에 입각하고 있다.

⑵ 역사적 전개

인권사적인 측면에서 볼 때, 사회권은 제2세대 인권을 이루며, 이러한 사회권이 헌법문서상으로는 1793년 6월 24일 자코뱅당 헌법초안 제21조, 제22조에서 근로의 권리, 공적 구호청구권 및 교육을 받을 권리가 처음으로 규정되었다. 그러나 포괄적으로 사회적 기본권을 규정한 헌법은 1919년 바이마르헌법으로 알려져 있다.[571]

우리나라에서는 1948년 제헌헌법에서 다양한 사회적 기본권을 규정하여(제16조 이하), 이들 사회적 기본권을 보장하고, 개인의 사회적 상황을 배려하며, 또 사회경제적 통합이 실현되어야 한다는 점을 명확히 선언하였다.[572]

그러나 사회적 기본권은 이후 1980년대 후반에 이르기까지 헌법적 권위를 갖지는 못했다.[573] 왜냐하면 헌법이 일반적으로 규범력을 갖지 못했기 때문이다. 즉, 정치질서는 독자적인 기준에 따라 운영되었고, 헌법은 정치적 필요에 의하여 쉽게 파괴 혹은 개정되었기 때문이다. 나아가 자의적인 헌법운영의 단서를 헌법 자체에 직접 삽입하기도 하였다. 예컨대, 1954년과 1969년 대통령의 중임에 관한 헌법개정, 1972년 헌법의 사전적·예방적 비상조치의 가능성(1972년 헌법 제53조 제1항), 그리고 이에 대한 사법적 심사의 배제(1972년 헌법 제53조 제4항), 심지어 법원의 사법심사에 의하여 위헌으로[574] 결정된 법률 조항이 헌법에 삽입되기도 하였다(1972년 헌법 제26조 제2항).[575]

그러다가 1980년대 후반 이후 우리 사회에서 진행된 민주화의 요청이 거세짐에 따라 사회경제적 동질성을 조성하는 분위기가 자연스럽게 조성되었고,[576] 사회적 기본권이 전체 헌법질서와

---

569) 박일경, 「제6공화국 신헌법」, 법경출판사, 1990, 315면; 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 667면.

570) 문홍주, 「제6공화국 한국헌법」, 해암사, 1988, 295면.

571) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 226면.

572) 국회도서관, 「헌법제정회의록(제헌의회)」 헌정사자료 제1집, 1967, 102~103면 참조.

573) 이흥재, “사회보장법 형성의 풍토적 특징 - ‘전문집단 헌신’ 구도 속의 ‘국민저항과 집권층 대응’의 정치적 산물”, 「법학」 제52권 제3호, 2011, 381~414면 참조.

574) 대법원 1971. 6. 22. 70다1010.

575) 당시 취해진 비상조치는 이후 헌법재판 및 법원의 판결을 통하여 위헌으로 결정되었다. 헌법재판소 1994. 6. 30. 92헌가18; 2013. 3. 21. 2010헌바132; 대법원 2012. 12. 16. 2010도5986 등 참조.

576) 전광석, “헌법과 국민통합”, 「법제연구」 제30호, 2006, 20~28면 참조.

연관성을 갖게 되었다. 따라서 사회적 기본권은 전체 헌법질서에 구조화되었고, 사회적 기본권의 실현을 위하여 형성된 법률관계가 재산권 및 신뢰보호와 같은 법치국가원리의 요소, 사회국가원리, 경제민주화 등과 연관되어 이해되기 시작했다.[577]

2. 의의

⑴ 개념

1) '사회적'이란 용어의 개념

사회권을 한마디로 정의하기는 힘들다. 왜냐하면 사회권(=사회적 권리)이란 말 중에서 '사회적'(sozial)이라는 형용사를 어떻게 이해해야 할 것인가에 따라서 그 의미가 달라지기 때문이다. 그러나 일반적으로 사회적이라는 말을 궁핍, 불합리한 복지수준의 차이 및 그를 통하여 야기되는 종속에 대한 항의라는 의미를 가진다. 즉, '사회적'이란 "모든 인간에게 그 존엄에 적합한 생활을 보장하기 위해 복지수준의 차이를 조정하고 그로부터 야기된 종속을 완화하고 제거하는 방향의"라는 의미를 갖으며, 결국 "궁핍으로부터의 자유로운"이라고 해석할 수 있을 것이다.[578]

2) 사회적 기본권의 개념

사회권은 인권의 활성화를 위해서 경제적·사회적·문화적 조건을 창출해 줄 것을 국가에 대하여 적극적으로 요구할 수 있는 권리를 의미한다.[579]

그리고 이러한 조건은 국가의 급부에 의존하기 때문에 사회권은 개인이 국가에 대하여 특정한 급부를 요구하는 직접적인 청구권으로 이해된다. 또한, 그러한 국가의 급부는 고도의 경제적 성격을 가지기 때문에 사회권은 경제적 권리이기도 한다. 뿐만 아니라 이러한 권리는 국가에 대하여 적극적인 급부를 요구할 수 있거나 또는 그러한 국가적 급부에 참여할 수 있는 개인의 적극적 지위에서 발생하기 때문에 사회적 참여권이라고도[580] 한다.

⑵ 현대적 의미

오늘날 자유권과 사회권은 국가에 대한 개인의 관계를 규정하는 중추적 개념이다. 즉, 사회권의 문제는 인간의 존엄과 불가분적으로 결합되어 있는 자유권의 문제라고도 할 수 있다. 이는 사회권에서 문제되고 있는 것은 자유권을 현실화할 수 있는 외적조건과 전제에 대한 것이라는 의미이다.

예컨대, 어떤 사람이 항상 타인의 자비를 구해야 하고, 언제나 타인의 자비에 의탁하여 생활을 영위해야 한다면 그 사람은 자유롭지 못할 뿐만 아니라 존엄하다고 할 수도 없다. 따라서 한 사람의 자유가 다른 사람의 자유와 함께 성립하지 않으면 안 되는 것이며, 자유는 모든 인간을 위해서 존재해야 한다는 것이다.

결국 오늘날 사회적 기본권이라고 하는 것은 국가의 국민에 대한 생활배려라고 할 수 있다. 즉, 모든 국민의 실질적 자유와 평등의 확보를 위한 빈곤의 퇴치, 부의 재분배와 같은 사회구조의 문제를 해결하고, 나아가 국가 내부구조의 개선을 위한 국가의 적극적인 노력을 요구하고 있는 것이다. 따라서 사회적 기본권은 국가에게 사회를 경제적으로 진보시키고, 국민들의 생존가능성을 개선할 것을 요청하고 있다고 할 수 있다.

---

577) 전광석, "신뢰보호와 소급입법금지의 원칙", 헌법재판 주요선례연구, 2012, 319~329면 참조.
578) 홍성방, 전게서, 231면.
579) 경제적·사회적·문화적 권리에 관한 국제협약.
580) 홍성방, "사회적 참여권, 「고시계」, 1986. 9, 88~98면 참조.

3. 사회적 권리와 사회주의적 권리의 무관계성(無關係性)

⑴ 사회적 실현

사회적 권리는 인권의 활성화를 위해서 사회적·경제적·문화적 전제요건을 마련해야 한다는 의미에서 '사회적 실현'(soziale Realisation)에 속한다. 바리온(Hans Barion : 1899~1973)에 따르면 사회적 실현에는 공적인 상태를 사회적 관점에서 변경하려는 모든 노력과 시도가 포함된다고 한다. 즉, 사회적 실현에는 모든 유형의 사회주의뿐만 아니라 그리스도교의 사회운동, 금세기 초 커다란 영향력을 행사했던 사회정책단체 및 제2차 바티칸공의회의 사회이론까지가 포함된다.[581]

또한, 사회적 정의의 실현이라는 외견적인 목표의 동일성에도 불구하고 사회적 실현은 두 개의 상이한 방향으로 나누어진다. 하나는 의회민주주의를 고수하면서 사회개혁을 추구하는 것이고, 다른 하나는 현재의 체계 내에서 진정한 개혁이 불가능하기 때문에 이를 타파하여야 한다는 것이다.

⑵ 사회적 권리(=사회권)

사회권은 자유로운 그러나 동시에 사회적인(또는 사교적인) 인간을 전제로 한다. 따라서 우리는 '사회적'(sozial)이라는 용어를 사용할 때, 같은 사회, 즉 개인이 이기적인 위험성과 그로 인한 비효율성이 사회정책과 경제정책을 통하여 서서히 변화되나 개인의 주도권이라는 기반이 고수되는 사회를 전제한다.[582] 그렇기 때문에 사회권에는 자유권이 절대주의의 정치적 그리고 법적 세계에 도입되었을 때 자유권의 이념이 가졌던 것과 같은 혁명적 열정이 결여되어 있다.[583]

⑶ 사회주의적 권리

사회주의적 권리는 인간을 유개념(類槪念)으로 파악하고,[584] 이러한 특성에 맞는 행동영역만을 부여한다. 이러한 측면에서 마르크스(Karl Marx : 1818~1883)의 인권에 대한 이해는 부정적인 것이었다.[585] 그는 공공을 생각하지 않는, 공공과는 분리되고 소외된 시민사회의 이기적인 인간들이 인권선언을 요구하였고, 그러한 요구가 인권선언에 담겼다고 생각했다. 따라서 마르크스의 관심은 소외의[586] 해소, 즉 노동자들의 소외의 해소에 집중된다.

결국 마르크스에 따르면, 진정한 인간이란 노동자이고, 사회주의적 질서에 있어서는 공장노동자 계급이 권리와 의무의 주체가 되어야 한다는 것이다. 이렇듯 마르크스는 인간을 집단적이고, 계급적인 존재로 파악하기 때문에 인간의 자유를 부정한다. 이러한 사회주의에서 사회주의적 기본권은 국가와 사회의 결정으로부터 자유로운 개인이 마음대로 처분할 수 있는 법적지위

---

581) Hans Barion, Vorbestimmung über den Wohlfahrtstaat, DÖV 1970, S. 15ff.
582) P. Badura, Auftrag und Grenzen der Verwaltung im sozialen Rechtstaat, DÖV 1968, S. 446ff.
583) 자유권이 권력과의 투쟁을 통한 '쟁취'의 산물이었다면, 사회권은 불평등, 빈부격차 등의 사회문제를 조절하기 위한 견제와 균형을 위한 '조정'의 산물이기 때문일 것이다.
584) W. Abendroth, Thesen zum Problem des maxistischen Menschenbildes im wissenschaftlichen Zeitalter, in : Festchrift für Adolf Arndt zum 65. Geburtstag, 1969, S. 13ff.
585) H. Klenner, Die marxistische Menschenrechtskonzeption, in : Dimension des Rechts. Gedächtnisschrift für René Marcic, Bd. 2, 1974, S. 793ff.
586) Fr. Müller, Entfremdung. Folgeprobleme der anthropologischen Begründung der Staatstheorie bei Rousseau, Hegel, Marx, 2. Aufl., 1985.

가 아니라 사회주의적 인격의 발전에 필요한 사회주의적으로 조직된 사회의 목적과 필요를 지향하는 법적보장일 뿐이다.[587]

따라서 사회주의적 인권의 이해는 비현실적인 것이며, 동시에 인권경시를 은폐하거나 정당화하려는 기도를 포함하고 있고, 역사적·경제적·정치적 사건을 그릇되게 해석하는 해석공식을 만들어 사람들의 시선을 현실로부터 차단시킴으로써 노동자들을 이데올로기의 포로가 되게 할 뿐이다.[588]

이러한 사실은 개인적 이익과 집단적 이익의 일치성과 권리와 의무의 일치성을 주장하는 사회주의자들의 기본권에 대한 이해에서 두르러진다.[589]

첫째, 개인적 이익과 집단적 이익이 일치한다고 파악함으로써 원래는 노동자들의 권리로서의 기본권은 국가로부터 자유라는 사실이 부인되게 된다. 그러나 개인적 이익과 집단적 이익을 동일시 할 수는 없으며, 결국 이러한 관점은 권력자들에게 매우 유용한 지배논리가 될 뿐이다. 즉, 집단적 이익을 위해 개인적 이익을 부인하는 정당화 근거가 된다.

둘째, 국가가 국민에게 아무것도 해 주는 일이 없이 국민에게 의무만을 부과시키는 것을 정당화한다. 따라서 사회주의국가의 헌법들에 규정되어 있던 수많은 사회권들은 단지 개인적 보호영역에 국가가 간섭하는 것을 정당화시키는 구실로서만 사용된다.

결국 사회주의국가의 헌법들에 규정되어 있는 기본권들은 결코 진정한 기본권일 수가 없다.[590]

⑷ 사회적 권리와 사회주의적 권리의 무관계성

'사회적'(sozial)이라는 용어는 '사회주의적'(sozialistisch) 이념의 특수한 경우가 아니다.[591] 사회적 권리와 사회주의적 권리 사이에는 공통된 점이라곤 전혀 없다. 사회적 권리는 개인적 자유의 경제적·문화적 조건을 정치과정에 끌어들여 그것을 정치문제화시킴으로써 국가가 보장하도록 한다. 그리고 이러한 조건들이 전적으로 정치체제에 일임되어 있지 않다는 점에서 사회주의적 권리에 대한 사회적 권리의 본질적 차이이기도 하다.

즉, 사회적 권리는 자유와 재산에 대한 절대성과 불가침성을 사회기속성의 측면에서 어느 정도 수정하였지만, 여전히 생산수단의 사유제를 견지하고, 국가가 일자리와 복지 및 사회보장을 위하여 급부하고, 분배하지 않으면 안 되는 사회질서의 헌법범위 내에서의 보장을 의미한다.[592]

4. 법적성격

⑴ 견해의 대립

프로그램규정설은 헌법상의 사회적 기본권이란 사법상의 권리와 같은 구체적인 법적권리가 아니라 단지 입법방침을 규정한 프로그램적인 의미만을 가지는 것이라고 한다. 따라서 사회적 기본권은 선언적인 것이며, 구체적인 권리내용의 형성은 입법정책상의 문제이고, 그것을 실시하는 것은 국가의 자유재량이어서 국민은 사회적 기본권규정만으로는 국가에게 급부를 청구할 수

587) P. Badura, Das Prinzip der sozialen Grundrechte und Verwirklichung im Recht der BRD, Der Staat Bd. 14, 1975, S. 17ff.
588) M. Kriele, Menschenrechte Zwischen Ost und West, 1977, S. 19ff.
589) H. Klenner, Studien über die Grundrechte, 1964, S. 48ff.(78ff.).
590) 홍성방, 전게서, 233~234면 참조.
591) P. Badura, a. a. O., S. 447.
592) P. Badura, a. a. O., S. 21f.

없다는 것이다. 또한, 헌법에 규정된 사회적 기본권은 재판규범도 아니어서 이를 법원에 청구할 수도 없다. 결국, 사회적 기본권은 장래에 국가에 의해 구체적 입법이 행해질 것이 예정된다는 의미를 가질 뿐이다.

추상적 권리설에 따르면 '권리를 가진다'라고 하는 헌법상의 규정으로부터 사회적 기본권을 프로그램으로 보는 것은 부당하다고 한다. 따라서 사회적 기본권은 국민이 추상적으로 생존을 보호받을 수 있음을 규정할 뿐이고, 사회적 기본권의 구체적 내용에 관하여는 아무런 규정이 없기 때문에 사회적 기본권 규정이 구체적인 법적권리로 행사될 수 있기 위해서는 그 법적인 구체성, 즉 권리주체의 확정, 법익의 존재, 청구방법 등이 명확히 되지 않으면 안 되는데, 실현수단·방법 등에 관하여 구체적인 절차에 관한 규정이 없기 때문에 구체적 권리가 아닌 추상적 권리라고 한다. 결국, 사회적 기본권을 행사하기 위해서는 헌법상의 규정을 구체화하는 법률이 제정되어야만 한다.

구체적 권리설은 사회적 기본권이란 그 역사적 배경과 자연법적인 측면 또한 헌법의 규범논리적 구조에서 연역하여 사회적 기본권 규정은 실정법적인 법규이고, 현실적인 청구권이 인정되는 구체적 권리라고 한다. 따라서 사회적 기본권은 그 기본권 내용에 맞는 구체적 입법의 제정을 입법권에 의무지우고 그에 따른 예산조치를 하도록 입법권과 행정권에 의무지우며 그 의무의 불이행에 대한 국가의 부작위에 대한 위헌성을 법원에 청구할 수 있는 현실적·구체적 권리라고 한다.[593]

원칙모델에 따른 권리설에 따르면 사회적 기본권의 규범구조를 개인에게 주관적 권리를 부여하는 규범인가 아니면 국가에게 객관적인 의무를 부과하는 규범인가, 구속적 규범인가 아니면 비구속적 규범인가, 권리와 의무를 확정적으로 부여하는가 아니면 잠정적으로 부여하는가라는 기준에 따라 형량을 통하여 구속적 규범과 비구속적 규범으로 이분한 후 이를 다시 여덟 가지로 분류하고, 모든 사회적 기본권은 일단은 잠정적으로 개인에게 주관적 권리를 부여하지만 이 권리는 형량을 거친 후에야 비로소 확정적인 권리가 될 수 있다고 한다. 즉, 사회적 기본권은 권리성을 갖지만 곧바로 확정되는 것이 아니라 여러 가지 요소들을 형량하여 다양한 정도로 실현될 수 있다고 한다.[594]

⑵ 헌법재판소

우리 헌법재판소는 교육을 받을 권리를 '직접 행정권과 사법권을 구속하는 것이 아니라 입법의 방향만을 지시하는 것'이라 한 바 있으며,[595] '인간의 존엄에 상응하는 생활에 최소한의 물질적 생활의 유지에 필요한'이라는 조건부이지만 인간다운 생활을 할 권리의 구체적 권리성을 인정하면서도 원칙적으로 법률을 구체화할 때 비로소 인정되는 법률적 권리라고 판시한 바 있으며,[596] 인간다운 생활을 할 권리의 통제규범성, 재판규범성을 인정하면서 모든 국가기관을 구속하지만, 그 기속의 의미는 적극적·형성적 활동을 하는 입법 또는 행정부의 경우와 헌법재판에 의한 사법적 통제기능을 하는 헌법재판소에 있어서 동일하지 않다고 판시한 바 있다.[597]

---

593) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 686~687면; 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 593~594면.

594) 정태호, "원리로서의 사회적 기본권 : R. Alexy의 원리모델을 중심으로", 「정경식박사 화갑기념논문집」, 1997, 238~242면 참조; 계희열, 「헌법학」(상), 박영사, 1995, 627면.

595) 헌법재판소 1991. 2. 11. 90헌가27.

596) 헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14.

597) 헌법재판소 1997. 5. 29. 94헌마33.

⑶ 검토

어떤 권리가 헌법에 규정된 이상 그것을 법적 구속력이 없는 정치적·도의적 선언이나 지침으로 볼 수는 없다. 따라서 사회적 기본권을 프로그램규정으로 볼 수는 없다.

또한, 사회적 기본권의 규범내용이 불명확하기 때문에 그것을 구체화하는 법률의 제정을 기다려 비로소 구체적으로 국민이 향유할 수 있는 권리로 된다는 추상적 권리설도 헌법재판제도가 확립되어 공권력의 행사 또는 불행사에 대하여 기본권이 침해된 경우 헌법소원을 청구할 수 있게 된 현재로선 타당하지 않다.

그리고 원칙모델에 따른 권리설은 설정된 기준에서 어느 것이 우선하는지, 어떤 이유에서 채택되었는지, 어떤 기본권이 강한 보호를 받는지 또는 약한 보호를 받는지가 불분명하고, 해석자마다 달리 해석할 가능성이 있다는 문제점이 있다.[598]

따라서 구체적 권리설이 타당하며, 국내의 다수설적인 견해이다.[599] 즉, 헌법재판소가 공권력의 불행사에 대하여 헌법소원을 인용한 경우, 피청구인은 결정취지에 따라 새로운 처분을 하도록 규정하고 있기 때문에 국가는 생존권침해의 인용결정이 있는 때에는 입법을 해야 할 의무를 진다.

그러나 구체적 권리설에 의하더라도 사회적 기본권의 특성상 모든 것이 다 해결될 수는 없다. 예컨대, 근로의 권리는 오직 일자리를 보장함으로써만 해결될 수 있는데, 헌법재판소가 결정으로 근로의 권리의 침해라고 선언한다고 한들 일자리 자체는 마련해 줄 수가 없는 것이다. 이것이 실효를 가지려면 헌법재판소가 특정인에게 특정직업을 만들어 주라는 결정을 해야 하는데, 이것은 입법부 내지 행정부의 의무일지언정 사법부의 권한은 아니다. 결국 근로의 권리는 입법부 및 행정부의 의무이행의 결과이지 소송의 대상이 될 수는 없다. 또한, 이러한 의무이행이 완수되고 있는가의 문제 역시 법원에서 판단하기 어렵다. 왜냐하면 국가의 예산을 어떻게 사용할 것인가, 무엇을 우선할 것인가는 입법부와 행정부의 권한영역에 속하는 것이어서 사법부가 이를 판단하는 것은 권력분립의 원칙에 반하는 결과를 초래하기 때문이다.

5. 사회적 기본권 목록

사회권의 발전과정을 역사적으로 개관하면 초기에 빈부격차 등의 사회문제의 해결에서부터 시작해서 오늘날 환경에 이르기까지 점차 확대되어 사회권의 범위가 지속적으로 확장되어 왔음을 알 수 있다. 또한, 국가의 보호에서 시작하여 국가에 의한 생활의 보장이라는 형태로 확장되었다.[600] 예컨대, 환경파괴를 경험해보지 못한 이전의 세대들에게는 깨끗하고 쾌적한 환경에 대한 권리란 상상할 수 없었을 것이기 때문이다.

보호를 받는 개인의 입장에서 본다면 사회권은 국가에 의하여 보장되는 인간의 존엄에 적합한 생활에 대한 권리일 것이고, 국가에 대하여 요청되는 행위의 관점에서 본다면 사회권은 최광의의 사회정책의 지도원리를 의미하게 될 것이다.[601]

따라서 사회권 목록은 그 보호방향에 따라 분류된다. 이미 존재하는 또는 앞으로 보장이 요구되는 사회권은 근로의 권리, 사회보장을 받을 권리, 사회적·문화적 발전권, 깨끗한 환경에 대한 권리 등으로 구분할 수 있다.[602]

---

598) 김철수, 전게서, 685면; 정태호, 전게논문, 252~253면 참조.
599) 김철수, 전게서, 686~687면; 권영성, 전게서, 593~594면; 홍성방, 전게서, 238~244면참조.
600) P. Badura, a. a. O., S. 21f.
601) P. Badura, a. a. O., S. 23f.
602) P. Badura, Ibid.

첫째, 근로의 권리는 직장에 관란 권리, 적절하게 보장된 근로조건에 대한 권리(정의의 요청에 적합한 임금과 충분한 휴식과 휴가를 포함하는 의미), 국가에 대한 노동력 보호청구권, 부녀자·청소년 및 장애인의 보호 및 배려청구권, 직업자문·실업구제·완전고용정책 및 실업자 보호청구권, 기업경영에 대한 노사공동결정권, 자유로운 직업선택과 행사권, 단체교섭과 단체행동을 포함하는 단결권 등이다.

둘째, 사회보장을 받을 권리에는 노령, 장애, 질병, 사고, 직업병, 임신 및 가족부양에서 오는 경제적 부담에 대하여 사회로부터 부조 받을 권리, 질병의 예방과 의사에 의한 치료를 청구할 권리, 필요하고 특히 곤궁한 상태에 처했을 때 부조 받을 권리, 적당한 주거에서 생활할 권리 등이다.

셋째, 사회적·문화적 발전권에 속하는 것으로는 교육을 받을 권리와 평생교육권, 교육장소를 자유롭게 선택할 권리, 교육기관에 불평등한 대우를 받지 않고 평등하게 참여할 수 있는 권리 및 교육제도에 있어서의 기회균등권 등이 있다.

넷째, 깨끗한 환경에 대한 권리는 국가뿐만 아니라 개인도 수범자가 될 수 있다는 점에서 전통적인 사회권과는 구별된다. 또한, 국가에 대하여 깨끗한 환경을 파괴하지 말라는 의미에서 자유권에서 볼 수 있는 방어권적 성격도 가지고 있다.

이러한 권리 이외에도 아직 완결되지 않은 따라서 앞으로 확대될 수 있는 경제적·사회적·문화적 부분에서의 발전을 보장한다는 의미에서 사회권은 의미가 있다.

6. 사회권과 자유권의 상관관계

사회권과 자유권의 상관관계에 대해서는 자유권은 금지를 사회권은 명령을 의미하기 때문에 사회권은 논리구조상 자유권과는 전적으로 모순되며, 따라서 결합될 가능성은 부정된다고 보는 견해가 있다.[603] 그러나 이는 자유와 평등을 대립적 구조로 간주하는 것과 같이 타당하지 않다. 즉, 사회권의 문제는 인간의 존엄과 불가분적으로 결합되어 있는 자유권의 문제라 할 수 있기 때문이다. 예컨대, 자유로워야 노력을 통해 풍요로워질 수 있으며, 풍요로워야 보다 자유로워질 수 있기 때문이다.

자유권과 사회권을 모순이 아닌 긴장관계로 이해하는 견해는 사회권은 그것이 침해될 때 개인이 그 배제를 청구할 수 있는 진정한 기본권이 아니라 사실에 있어서는 '민주적 지위권'(demokratische Statusrechte), 즉 그때그때마다 정의의 범주 내에서 국가에 의하여 법률에 따라 허용되는, 보장되지 않는 참여권이라고 한다. 그렇기 때문에 자유권과 사회권은 긴장관계가 성립하게 된다는 것이다.[604] 이러한 긴장관계는 사회권이 동시에 자유를 제한하고 구체적 의무를 부과하는 것일 수 있으며, 참여하지 않는 제3자에 대해서도 마찬가지라고 한다.

사회권과 자유권을 결합시키는 문제는 사회권과 자유권의 대립에 대한 문제가 아니라 부자유를 극복하는 과정에서 양자를 조화시키는 문제이다. 따라서 자유권이냐 사회권이냐의 양자택일의 문제가 아니라 자유와 평등을 얼마만큼 보장하면 양자를 극대화시킬 수 있는가의 문제이다.[605]

603) C. Schmitt, Verfassungslehre, 1928, S. 123.
604) G. Leibholz, Strukturprobleme der modern Demokretie, 1964, S. 130f.
605) M. Kriele, a. a. O., S. 134.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 사회권을 최초로 명문화한 것은?

① 바울헌법 ② 바이마르헌법 ③ 벨기에헌법 ④ 프로이센헌법 ⑤ 프랑크푸르트헌법

[정답] ②

[해설] 1919년 바이마르 헌법을 최초로 보는 것이 일반적이다.

2. 다음 입법상의 조치가 필요한 기본권은?

① 양심의 자유 ② 표현의 자유 ③ 신체의 자유 ④ 집회의 자유 ⑤ 사회보장을 받을 권리

[정답] ⑤

[해설] 사회적 기본권은 입법상의 조치가 요구된다.

3. 현행 헌법상 국가의 의무가 아닌 것은?

① 모성보호 ② 재해예방노력 ③ 쾌적한 주거생활조성 ④ 완전고용실현 ⑤ 환경보전

[정답] ④

[해설] 완전고용은 규정하고 있지 않다.

♣ 요점정리

1. 우리 헌법상의 사회적 기본권규정들은 보충성의 원리에 입각하고 있다.

2. 우리 헌법재판소는 사회적 기본권에 대하여 '입법의 방향', '구체적 권리' 등 다양한 결정을 내리고 있다.

3. 구체적 권리설에 의하더라도 사회적 기본권의 특성상 모든 것이 다 해결될 수는 없다. 예컨대, 근로의 권리는 오직 일자리를 보장함으로써만 해결될 수 있는데, 헌법재판소가 결정으로 근로의 권리의 침해라고 선언한다고 한들 일자리 자체는 마련해 줄 수가 없다.

4. 사회권과 자유권을 결합시키는 문제는 사회권과 자유권의 대립에 대한 문제가 아니라 부자유를 극복하는 과정에서 양자를 조화시키는 문제이다.

제33강 교육을 받을 권리

♣ 학습목표

교육을 받을 권리에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

수업권, 수학권
교육을 받을 권리의 법적성격
교육을 받을 권리의 주체 및 효력
교육을 받을 권리의 소극적·적극적 측면
사회적 참여권
의무교육의 제도적 보장
교육에 관한 원칙규범

♣ 사전테스트

1. 교육을 받을 권리는 생존권적 기본권으로서 이는 직접 행정권과 사법권을 구속하는 것이 아니라 입법의 방향만을 지시하는 것이고, 따라서 의무교육의 무상에 관한 규정도 사법권을 구속하는 재판규범이 될 수 없다.
   정답 : O
   해설 : 헌법재판소 1991. 2. 11. 90헌가27.

2. 교육을 받을 권리는 합리적인 차별 없이 교육을 받을 권리를 제한하지 아니함과 동시에 국가가 모든 국민에게 균등한 교육을 받게 하고 특히 경제적 약자가 실질적인 평등교육을 받을 수 있도록 적극적 정책을 실현해야 한다는 것이다.
   정답 : O
   해설 : 헌법재판소 1994. 2. 4. 93헌마192.

3. 교사의 수업권은 국민의 수학권 보다 우선하여 보호된다.
   정답 : X
   해설 : 수학권이 우선한다(헌법재판소 1992. 11. 12. 89헌마88).

♣ 돌발퀴즈

중등교육의 경우에는 법률에서 중등교육을 의무교육으로서 시행하도록 규정하기 전에는 헌법상의 권리로서 보장되는 것은 아니다.

[정답] O
[해설] 헌법재판소 1991. 2. 11. 90헌가27.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

교육을 받을 권리는 비록 초안에 그치기는 하였지만 강의청구권의 형태로 1793년의 자코뱅 헌법에서 처음으로 규정되었다.[606] 또한 초등학교에서 무료로 교육을 받을 권리는 1849년 프랑크푸르트헌법 제157조에서 처음으로 명문화된 것으로 알려져 있다. 그러나 교육과 학교에 대하여 풍부한 조항을 두어 일반적인 교육을 받을 권리를 보장한 최초의 헌법은 1919년 바이마르 헌법보아야 한다.[607]

우리 헌법은 제31조 제1항에서 교육을 받을 권리를 규정하고 있으며, 제2항에서 초등교육 등을 받게 할 의무, 제3항에서 의무교육무상주의, 제4항에서 교육의 자주성·전문성·정치적 중립성 및 대학의 자율성, 제5항에서 국가의 평생교육진흥의무, 제6에서 교육에 관한 기본적 사항의 법정주의를 규정하고 있다.

2. 의의 및 법적성격

⑴ 의의

칸트(Immanuel Kant : 1724~1804)는 "오직 인간만이 교육을 필요로 하는 유일한 피조물이다"라고[608] 표현하여 교육의 중요성을 언급하였다. 또한, 교육은 특별히 마련된 제도적 시스템 안에서 이루어지는 행위이다.

첫째, 교육행위는 '상호작용'의 메커니즘을 가진다. 즉, 교육은 '가르치는 행위'와 '배우는 행위'가 상호 결합되어가는 과정을 의미한다. 그러나 교육행위는 그것을 '받는 자'를 배제하고 성립할 수 없으므로, 교육은 원칙적으로 그것을 '받는 자'를 중심에 둔 상호작용의 메커니즘이다.

둘째, 교육은 '의도성·계획성·가치지향성'을 가진다. 즉, 교육행위는 무계획적이고 의미 없는 행동과 구별되는 개념으로서 특정한 가치를 지향하는 의도적이고 계획적인 행위이다.

셋째, 교육은 '전승과 계승'의 과정이다. 즉, 교육은 어느 정도 확립된 지식과 가치의 전승을 전제하므로, 새로운 지식과 진리의 탐구를 본질로 하는 학문의 개념과는 구별된다.

넷째, 교육은 '체계적'이고 '조직적'인 형식을 갖추기를 기대한다. 물론 교육은 가정에서부터 출발하여 왔지만, 역사적으로 학교라는 체계적이고 형식화된 제도를 통해 보다 효과적으로 이루어져 왔음은 주지의 사실이다. '제도로서 교육'을 배제시킨 채 '행위로서 교육'에만 집중할 수 없는 이유가 여기에 있다.

교육을 받을 권리는 인간다운 생활의 전제가 된다. 즉, 인간은 교육을 통하여 자신의 이상을 실현시키고 자신의 인격을 개발할 수 있을 뿐만 아니라 생계를 꾸려나갈 수 있기 때문이다.

그리고 교육을 받을 권리는 자유, 평등 그리고 민주주의와 같은 헌법의 기본이념들을 실현시키기 위한 전제가 된다. 즉, 이러한 이념들을 실현하는 일은 정치적·사회적인 자각과 식견을 배양함으로써만 가능하며, 그것은 어느 정도 교육을 받은 개인을 전제로 한다.

또한, 교육을 받을 권리는 일차적으로 부모를 통해 보장되며, 부모가 이를 이행하지 않을 경우 이차적으로 국가 등을 통해 보장된다. 다시 말해 성장도상에 놓여있는 미성숙한 자녀는 그가 성장·발달하는 각 단계마다 반드시 충족되어야 할 욕구가 있고, 그것이 충족되었을 때 다음 단

606) B. Pieroth/B. Schlink, Grundrecht. Staatsrecht Ⅱ, 1985, S. 9.
607) 바이마르헌법 제142~150조.
608) "Der Mensch ist das einzige Geschopf, daserzogen werden muss."

계의 성장으로 진행된다는 점을 고려한다면, 이러한 욕구충족을 위한 교육급부의 일차적인 책임은 부모에게 있음이 분명하다. 그리하여 이를 충족하기 위한 실현조건으로서 특히 미성숙한 자의 권리, 즉 교육을 받을 권리가 보장되며 이것은 일차적으로 부모에게 주장할 수 있어야 한다. 그러나 부모의 급부 이행의 의사부재 내지 능력의 부족 등 특단의 사유가 발생하는 경우 국가 내지 사인이 이를 강제하거나 대신할 수 있어야 한다.

<헌법재판소 1990. 10. 8. 89헌마89> 교육공무원법 제11조 제1항

교육은 국민 전체의 지적 수준을 높여 이를 바탕으로보다 살기 좋은 나라를 이룩하고자 함에도 있으나, 본질적으로 국민 개개인의 개성을 개발·발전시켜 생활능력을 증진케 함으로써 그들로 하여금 인간다운 생활을 누릴 수 있도록 하기 위한 것이다.

<헌법재판소 1991. 7. 22. 89헌가106> 사립학교법 제55조 제58조 제1항 제4호

우리 헌법은 전문과 제1장 총강에서 대한민국이 자유롭고 문화적인 민주복지국가를 이룩하여 항구적인 세계평화와 인류공영에 이바지함을 그 이념으로 하고 있음을 밝히고 있다. 이러한 헌법이념의 실현은 국민 각자의 자각과 노력이 뒷받침되어야 비로소 가능한 것이므로 궁극에는 교육의 힘에 의존할 수밖에 없는 것이다. 헌법이념을 실현하는 기능을 가진 교육은 그 목적이 국민 개개인의 타고나 저마다의 소질을 개발하여 인격을 완성하게 하고, 자립하여 생활할 수 있는 능력을 증진시킴으로써 그들로 하여금 인간다운 생활을 누릴 수 있도록 함과 아울러 평화적이고 민주적인 국가 및 사회의 형성자로서 세계평화와 인류공영에 이바지하도록 함에 있다.

<헌법재판소 1992. 11. 12. 89헌마88> 교육법 제157조

학교교육에 있어서 교사의 가르치는 권리를 수업권이라고 한다면 그것은 자연법적으로는 학부모에게 속하는 자녀에 대한 교육권을 선택받은 것이고, 실정법상으로는 공교육의 책임이 있는 국가의 위임에 의한 것이다. 그것은 교사의 지위에서 생기는 학생에 대한 일차적인 교육상의 직무권한이지만, 학생의 수학권은 실현을 위하여 인정되는 것으로서 양자는 상호협력관계에 있다고 하겠으나, 수학권은 헌법상 보장된 기본권의 하나로서 보다 존중되어야 하며, 그것이 왜곡되지 않고 올바로 행사할 수 있게 하기 위한 범위 내에서 수업권도 어느 정도의 범위 내에서 제약을 받지 않으면 안 될 것이다. 교사의 수업권은 그것이 헌법상 보장되는 기본권이라고 할 수 있느냐에 대해서는 이를 부정적으로 보는 견해가 많으며, 설사 헌법상 보장되고 있는 학문의 자유 또는 교육을 받을 권리의 규정에서 교사의 수업권이 파생되는 것으로 해석하여 기본권에 준하는 것으로 간주하더라도 수업권을 내세워 수학권을 침해할 수는 없으며 국민의 수학권의 보장을 위하여 교사의 수업권은 일정한 범위 내에서 제약을 받을 수밖에 없다.

<헌법재판소 1994. 2. 24. 93헌마192> 교육법 제96조 제1항

교육을 받을 권리는 첫째, 교육을 통해 개인의 잠재적인 능력을 개발시켜줌으로써 인간다운 문화생활과 직업생활을 할 수 있는 기초를 마련해주고, 둘째, 문화적이고 지적인 사회풍토를 조성하고 문화창조의 바탕을 마련함으로써 헌법이 추구하는 문화국가를 촉진시키고, 셋째, 합리적이고 계속적인 교육을 통해서 민주주의가 필요로 하는 민주시민의 윤리적 생활철학을 어렸을 때부터 습성화시킴으로써 헌법이 추구하는 민주주의의 토착화에 이바지 하고, 넷째, 능력에 따른 균등한 교육을 통해서 직업생활과 경제생활의 영역에서 실질적인 평등을 실현시킴으로써 헌법이 추구하는 사회국가, 복지국가의 이념을 실현한다는 의의와 기능을 가지고 있다.

<헌법재판소 1999. 3. 25. 97헌마130> 지방교육자치에 관한 법률 제44조의2 제2항

교육을 받을 권리는 통상 국가에 의한 교육조건의 개선·정비와 교육기회의 균등한 보장을 적극적으로 요구할 수 있는 권리로 이해되고 있다. 수학권의 보장은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며 행복을 추구하고 인간다운 생활을 영위하는데 필수적인 조건이자 대전제이다.

<헌법재판소 2000. 4. 27. 98헌가16 등> 학원의 설립·운영에 관한 법률 제22조 제1항 제1호

교육을 받을 권리란 모든 국민에게 저마다의 능력에 따른 교육이 가능하도록 그에 필요한 설비와 제도를 마련해야 할 국가의 과제와 아울러 이를 넘어 사회적·경제적 약자도 능력에 따른 실질적 평등교육을 받을 수 있도록 적극적인 정책을 실현해야 할 국가의 의무를 뜻한다.

⑵ 법적성격

교육을 받을 권리는 교육의 기회균등, 즉 개별 평등권이라는 견해와 교육에 대한 적극적인 청구권이라는 견해,[609] 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리는 개별 평등권으로서의 성격과 교육에 대한 적극적 청구권의 성격을 모두 가진다고 보아야 하며, 또한 교육을 받을 권리는 객관적 가치질서로서의 성격도 아울러 가진다는 견해가 있다.[610]

우리 헌법재판소는 교육을 받을 권리를 프로그램규정으로 보고 있는가 하면 적극적 평등권이라고 하는 판례도 있다.

<헌법재판소 1991. 2. 11. 90헌가27> 교육법 제96조 제1항

교육을 받을 권리는 생존권적 기본권으로서 이는 직접 행정권과 사법권을 구속하는 것이 아니라 입법의 방향만을 지시하는 것이고, 따라서 의무교육의 무상에 관한 규정도 사법권을 구속하는 재판규범이 될 수 없다.

<헌법재판소 1994. 2. 4. 93헌마192> 교육법 제96조 제1항

교육을 받을 권리는 합리적인 차별 없이 교육을 받을 권리를 제한하지 아니함과 동시에 국가가 모든 국민에게 균등한 교육을 받게 하고 특히 경제적 약자가 실질적인 평등교육을 받을 수 있도록 적극적 정책을 실현해야 한다는 것이다.

3. 주체 및 효력

⑴ 주체

교육을 받을 권리는 어린이뿐 아니라 대학생도 그 주체가 되며, 일반시민도 평생교육의 향유자로서 교육을 받을 권리의 주체가 된다.[611] 그러나 교육을 받을 권리의 성격상 자연인에게만 보장되고, 법인에게는 인정되지 않는다. 또한, 적법한 절차를 밟아 입국한 외국인도 교육을 받을 권리의 주체가 된다.

---

609) 박일경, 「제6공화국 신헌법」, 법경출판사, 1990, 323면; 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 706면.

610) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 413~414면; 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 250~251면.

611) 헌법재판소 1995. 2. 23. 91헌마204.

⑵ 효력

교육을 받을 권리는 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력을 가진다.

4. 내용

⑴ 의미

초등학교교육은 의무교육이기 때문에 헌법 제31조 제1항의 교육을 받을 권리는 초등학교 이외에서 교육을 받을 권리를 의미한다. 또한, 교육은 여러 형태가 가능하지만 학교교육이 가장 조직적이고 효과적이며 일반적이기 때문에 주로 학교교육을 의미한다.

그러나 교육은 학교나 기타 교육기관에서도 이루어진다. 따라서 정규적인 학교교육 외에 사회교육·직업교육·노인교육 등 평생교육이 이루어지고 있다. 헌법은 이러한 사정을 감안하여 국가에 평생교육을 진흥시킬 의무를 부과하고 평생교육제도를 학교교육제도와 함께 법률로 정하게 하고 있다(제31조 제5항, 제6항). 따라서 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률, 특수교육진흥법, 평생교육법, 독학에 의한 학위취득에 관한 법률, 학점인정 등에 관한 법률 등이 마련되어 있다.

또한, 교육을 받을 권리는 소극적인 측면과 적극적인 측면이 있다. 교육을 받을 권리의 소극적인 측면은 교육기관에 입학하는 데 자의적인 제한을 금지하는 것, 즉 입학의 기회균등을 말한다. 예컨대, 입학시험 등과 같은 자의적인 제한이 아닌 제한은 위헌이 아니다. 이와 관련하여 초·중등학교의 학군제, 내신제,[612] 학생생활기록부[613] 등이 문제된 바 있으나 헌법재판소는 모두 균등하게 교육을 받을 권리에 대한 침해가 아니라고 하였다.

교육을 받을 권리의 소극적 측면과 관련하여 학교장의 징계권, 특히 퇴학은 학생을 학교에서 퇴출하는 것으로 교육을 받을 권리에 있어서의 기회균등을 부정하는 것이며, 퇴학의 결정은 자유재량행위가 아니다. 또한, 초등학교의 수학은 의무교육이므로 초등학교에서의 퇴학은 법적으로 허용되지 않는다.

<헌법재판소 1995. 2. 23. 91헌마204> 교육법시행령 제71조 등

거주지를 기준으로 중·고등학교의 입학을 제한하고 있는 것은 과열된 입시경쟁으로 말미암아 발생하는 부작용을 방지하는 것이므로 자녀를 교육시킬 학부모의 학교선택권의 본질적 내용을 침해하는 것은 아니다.

교육을 받을 권리의 적극적 측면은 국민이 능력에 따라 교육을 향유할 수 있는 국가에 대한 청구권이라 할 수 있다. 능력은 재능, 신체적 적합성과 같은 것이고, 교육의 전제조건과 관계없는 재산상태를 포함하지 않는다. 오히려 경제적 약자에 대해 구체적으로 학비를 제공하는 보장이 필요하다 하겠다.[614]

<헌법재판소 1991. 2. 11. 90헌가27> 교육법 제8조의2

초등교육 이외에 어느 범위의 교육을 의무교육으로 할 것인가에 대한 결정은 입법자에게 위임되어 있다. 초등교육은 헌법상의 권리라고 볼 수 있으나, 중등교육의 경우에는 법률에서 중등

612) 헌법재판소 1996. 4. 25. 94헌마119.
613) 헌법재판소 1997. 7. 16. 97헌마38.
614) 문홍주, 「제6공화국 한국헌법」, 해암사, 1988, 304면.

교육을 의무교육으로서 시행하도록 규정하기 전에는 헌법상의 권리로서 보장되는 것은 아니다. 중등교육은 법률로 구체적으로 규정할 때에 비로소 헌법상의 권리로서 구체화되는 것이다.

<대법원 1983. 6. 28. 83누193>
대학입학지원자가 모집정원에 미달한 경우라도 대학이 정한 수학능력이 없는 자에 대하여 불합격처분을 한 것은 교육법 제111조 제1항에 위반되지 아니하여 무효라고 할 수 없다.

⑵ 참여권

1) 교육의 기회균등

이는 교육의 기회균등과 관련하여 모든 교육시설에 균등하게 참여할 것을 요구할 수 있는 교육청구권 또는 교육참여권이 인정될 수 있는가와 관련된다. 이에 대해 교육의 기회균등은 마땅히 교육시설에 균등하게 참여할 수 있는 권리를 포함하는 것으로 보는 것이 옳다는 견해가 있다.[615] 그러나 참여권이론은 독일기본법에서 사회적 기본권을 기본권목록에 수용하지 않아 생기는 문제를 해결하기 위해 주장된 것으로 우리 헌법은 사회적 기본권을 폭 넓게 규정하고 있기 때문에 참여권이론을 원용할 여지가 거의 없다고 보아야 한다.[616]

2) 사회적 참여권

사회적 참여권이론은 독일연방헌법재판소가 대학입학정원을 제한하는 것이 합헌인가여부에 대해서 판단하면서 수용한 이론이다. 이는 전통적으로 기본권이란 국가에 대한 방어권이라는 개념에서 벗어나 방어권적 성격과 참여권적 성격의 '기본권 이원성'(zwei Dimensionalität der Grundgesete)을 인정한 것이었다. 참여권은 개인이 사회에 대하여 합리적으로 요구해야 한다는 의미에서 가능성의 유보하에 있으며, 이때 합리적인 것이 무엇인가의 척도는 국가예산에 있어서 다른 요구와 전체경제의 균형을 고려해야만 하는 입법자가 일차적으로 판단한다는 것이다.[617]
따라서 참여권이론에 의하면 기본권은 기본권적 자유의 실현을 위하여 요구되는 사회적 전제조건을 창조할 국가의 의무까지를 포함한다. 왜냐하면 자유권은 그것을 주장할 수 있는 실질적인 전제조건이 없다면 무가치하므로[618] 개인은 국가적 급부와 국가에 의해 창설된 여러 제도에 참여할 청구권을 갖게 된다.[619]

5. 의무교육의 제도적 보장

⑴ 의미

우리 헌법 제31조 제2항은 모든 국민은 그 보호하는 자녀에게 적어도 초등교육과 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무를 진다고 규정하였고, 제3항에서 의무교육은 무상으로 한다고 규정하여 의무교육을 제도적으로 보장하고 있다. 그러므로 헌법이 보장하는 내용의 의무교육제도를 통상의 법률에 의해 폐지할 수는 없다.

---

615) 허영, 전게서, 416면.
616) 홍성방, 전게서, 254~255면.
617) 이 판결에 대해서는 계희열, "대학입학정원제한판결", 「판례연구」 제1집, 고려대학교 법학연구소, 1982.
618) BVerfGE 33, 303(331).
619) BVerfGE 33, 303(330ff.).

<헌법재판소 1991. 2. 11. 90헌가27> 교육법 제8조의2

헌법이 요구하고 있는 것은 입법자가 학교제도의 핵심적 사항의 하나인 의무교육의 실시여부 및 그 연한을 스스로 결정해야 한다는 것일 뿐이다. 따라서 헌법 제31조 제2항 소정의 법률은 형식적 의미의 법률뿐만 아니라 그러한 법률의 위임에 근거하여 제정된 대통령령도 포함하는 실질적 의미의 법률로 해석하여야 한다.

<헌법재판소 1995. 2. 23. 91헌마204>

부모는 아직 성숙하지 못하고 인격을 닦는 초·중·고등학생인 자녀를 교육시킬 교육권을 가지고 있으며, 그 교육권의 내용 중 하나로서 자녀를 교육시킬 학교선택권이 인정된다.

<헌법재판소 1992. 11. 12. 89헌마88>

학교교육에서 교사의 가르치는 권리는 자연법적으로는 학부모에게 속하는 자녀에 대한 교육권을 신탁 받은 것이고, 실정법상으로는 공교육의 책임이 있는 국가의 위임에 의한 것이다.

<헌법재판소 2000. 4. 27. 98헌가16>

부모의 자녀교육권은 자녀의 행복이라는 관점에서 보장되는 것이며, 자녀의 행복이 부모의 교육에 있어서 그 방향을 결정하는 지침이 된다. 부모는 자녀의 교육에 관하여 전반적인 계획을 세우고 자신의 인생관·사회관·교육관에 따라 자녀의 교육을 자유롭게 형성할 권리를 가지며, 부모의 교육권은 다른 교육 주체와의 관계에서 원칙적인 우위를 가진다. 한편, 자녀의 교육에 관한 부모의 권리와 의무는 서로 불가분 관계에 있고 자녀교육권의 본질을 결정하는 구성요소이기 때문에 부모의 자녀교육권은 부모가 자녀교육에 대한 책임을 어떠한 방법으로 이행할 것인가에 관하여 자유롭게 결정할 수 있는 권리로서 교육의 목표와 수단에 관한 결정권을 뜻한다. 즉, 부모는 어떠한 방향으로 자녀의 인격이 형성되어야 하는가에 관한 목표를 정하고, 자녀의 개인적 성향과 능력, 정신적·신체적 발달상황 등을 고려하여 교육목적을 달성하기에 적합한 교육수단을 선택할 권리를 가진다. 부모의 이러한 일차적인 결정권은 누구보다도 부모가 자녀의 이익을 가장 잘 보호할 수 있다는 사고에서 기인하는 것이다.

<헌법재판소 2005. 3. 31. 2003헌가20> 구 학교용지확보에 관한 특례법 제2조 제2호 등

의무교육에 필요한 학교시설은 국가의 일반적 과제이고, 학교용지는 의무교육을 시행하기 위한 물적 기반으로서 필수조건임은 말할 필요도 없으므로 이를 달성하기 위한 비용은 국가의 일반재정으로 충당하여야 한다. 따라서 적어도 의무교육은 일반재정이 아닌 부담금과 같은 별도의 재정수단을 동원하여 특정한 집단으로부터 그 비용을 징수하여 충당하는 것은 의무교육의 무상성을 선언한 헌법에 반한다.

⑵ 주체

의무교육에 있어서 교육의무의 주체는 학령아동의 친권자 또는 후견인이 된다. 보호자의 적령아동을 취학하게 하는 의무는 적령아동의 신고와 초등교육과 법률이 정하는 교육에 필요한 최소한의 협조의무로 해석된다.[620] 그러나 외국인이 학령아동을 보호하고 있는 경우, 교육의무의 주체가 된다고는 할 수 없다. 즉, 자발적으로 우리의 의무교육을 받게 하기를 원할 경우에 거부할 이유는 없겠지만 그렇지 않은 경우에 강제할 수는 없기 때문이다. 또한 의무교육은 공민교육이기 때문이다.[621]

620) 한동섭, 「헌법」, 박영사, 1971, 139면.
621) 홍성방, 전게서, 260면.

⑶ 무상의 범위

무상의무교육에서의 무상의 범위는 견해의 대립에도 불구하고 수업료, 교재, 학용품까지를 무상으로 한다는 취학필요비용무상설이 다수설이다.

<헌법재판소 1991. 2. 11. 90헌가27> 교육법 제8조의2

우리 헌법 제31조 제3항은 초등교육에 관하여는 직접적인 효력규정으로서 개인이 국가에 대하여 입학금·수업료 등을 면제받을 수 있는 헌법상의 권리라고 볼 수 있다. 헌법 제31조 제6항의 취지는 교육에 관한 기본정책 또는 기본방침을 최소한 국회가 입법절차를 거쳐 제정한 법률로 규정함으로써 국민의 교육을 받을 권리가 행정기관에 의하여 자의적으로 무시되거나 침해당하지 않도록 하고, 교육의 자주성과 중립성도 유지하려는 것이나, 반면 교육제도에 관한 기본방침을 제외한 나머지 세부적인 사항까지 반드시 형식적 의미의 법률만으로 정하여야 하는 것은 아니다.

<헌법재판소 2000.4. 27. 98헌가16 등>학원의 설립·운영에 관한 법률 제22조 제1항 제1호

헌법 제31조 제6항은 학교교육 및 평생교육을 포함한 교육제도와 그 운영, 교육재정 및 교원의 지위에 관한 기본 적인 사항은 법률로 정한다고 함으로써 학교교육에 관한 국가의 권한과 책임을 규정하고 있다. 이는 국가에게 학교제도를 통한 교육을 시행하도록 위임하였고, 이로써 국가는 학교제도에 관한 포괄적인 규율권한과 자녀에 대한 학교교육의 책임을 부여받았다.

6. 교육에 관한 원칙규범

교육의 기회균등·자주성·정치적 중립성은 교육제도에 있어서 원칙규범이다(제31조 제1항, 제4항). 그러므로 교육제도에 관한 입법이 이 원칙규범에 위배할 때에는 무효이다(제31조 제6항).

♣ 문제풀이

1. 다음 중 국가의 평생교육 진흥과 관계가 없는 것은?

① 학교교육 ② 직업교육 ③ 노인교육 ④ 사회교육 ⑤ 재택교육

[정답] ①

[해설] 정규적인 학교교육 이외의 교육

2. 다음 교육을 받을 권리의 설명 중 바르지 못한 것은?

① 수학권 또는 수업권이라고도 한다.
② 교육의무는 학령아동을 공립학교에 취학시킬 의무이다.
③ 교원의 정치적 활동은 원칙적으로 금지된다.
④ 합리적인 범위 내에서 교과목의 차이를 둘 수 있다
⑤ 헌법이 보장하는 내용의 의무교육제도를 법률로 폐지할 수는 없다.

[정답] ②

[해설] 교육의무는 학령아동을 공립학교 또는 사립학교에 취학시킬 의무이다.

3. 다음 중 헌법상 교육의 권리와 관련하여 거리가 먼 것은?

① 의무교육의 무상성
② 국가의 평생교육진흥의무
③ 대학의 정치적 중립
④ 교육의 전문성
⑤ 교원지위의 법정주의

[정답] ③
[해설] 교육의 정치적 중립이다(제31조 제4항).

♣ 요점정리

1. 교육을 받을 권리는 생존권적 기본권으로서 이는 직접 행정권과 사법권을 구속하는 것이 아니라 입법의 방향만을 지시하는 것이고, 따라서 의무교육의 무상에 관한 규정도 사법권을 구속하는 재판규범이 될 수 없다.

2. 교육을 받을 권리는 합리적인 차별 없이 교육을 받을 권리를 제한하지 아니함과 동시에 국가가 모든 국민에게 균등한 교육을 받게 하고 특히 경제적 약자가 실질적인 평등교육을 받을 수 있도록 적극적 정책을 실현해야 한다는 것이다.

3. 교사의 수업권을 내세워 수학권을 침해할 수는 없으며, 국민의 수학권의 보장을 위하여 교사의 수업권은 일정한 범위 내에서 제약을 받을 수밖에 없다.

4. 중등교육은 법률로 구체적으로 규정할 때에 비로소 헌법상의 권리로서 구체화되는 것이다.

5. 의무교육은 일반재정이 아닌 부담금과 같은 별도의 재정수단을 동원하여 특정한 집단으로부터 그 비용을 징수하여 충당하는 것은 의무교육의 무상성을 선언한 헌법에 반한다.

6. 우리 헌법 제31조 제3항은 초등교육에 관하여는 직접적인 효력규정으로서 개인이 국가에 대하여 입학금·수업료 등을 면제받을 수 있는 헌법상의 권리라고 볼 수 있다.

제34강 근로의 권리

♣ 학습목표

근로의 권리에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

근로의 권리의 의의, 기능, 법적성격
근로의 권리의 본질적 내용
국가의 고용증진의무
해고의 자유제한
적정임금의 보장, 최저임금제실시, 동일노동에 대한 동일임금의 원칙
근로조건 법정주의, 여자와 연소자 근로의 특별대우, 국가유공자 등의 근로기회우선보장

♣ 사전테스트

1. 근로의 권리는 근로자가 자신의 의사와 능력에 따라 근로의 종류·내용·장소 등을 선택하여 근로관계를 형성하고, 타인의 방해를 받지 않고 근로관계를 계속 유지하며, 근로의 기회를 얻지 못한 경우에는 국가에 대하여 근로의 기회를 제공하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리를 말한다.

   정답 : O
   해설 : 헌법재판소 2008. 9. 25. 2005헌마586.

2. 근로의 권리는 '일할 자리에 관한 권리'와 '일할 환경에 관한 권리'가 포함된다.

   정답 : O
   해설 : 헌법재판소 2007. 8. 30. 2004헌마670.

3. 근로의 권리의 본질적 내용은 근로기회제공청구권이다.

   정답 : O
   해설 : 이에 대해서는 이견 없이 의견이 일치되고 있다.

♣ 돌발퀴즈

근로조건을 법정함에 있어 기준이 되는 것은 인간의 존엄성을 보장이다.

[정답] O
[해설] 헌법재판소 1999. 9. 16. 98헌마310.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

자연법사상은 모든 사람은 자유롭고 평등하다는 관념 아래, 개인이 자유롭게 노동을 하는 것을 국가권력이 침해해서는 안 된다고 하였고, 이러한 사회적 배경 속에서 근로권은 신체의 자유와 이동의 자유를 포함한 근로의 자유를 의미하게 되었다. 애초 근로권은 자유권적 기본권의 일종으로 인식되었고, 프랑스 인권선언을 거쳐 근로가 하나의 권리로서 주장될 수 있다는 선언을 통해 기본권적 개념으로 인식되었다.

근로의 권리는 1793년 6월 자코뱅헌법에서 처음 등장한 것으로 알려져 있다. 그러나 자코뱅헌법에 규정된 근로의 권리는 현실적으로는 아무것도 보장해주지 않는 프로그램에 지나지 않을 뿐만 아니라 같은 해 7월 상실되었기 때문에 헌법사적 의미는 그렇게 크지 않다. 따라서 근로의 권리를 헌법에 규정한 것은 1919년 바이마르헌법 제163조 제2항이라고 할 수 있다.[622]

우리 헌법은 건국헌법에서부터 계속하여 근로의 권리를 보장하였다.[623] 적정임금·국가유공자 등의 우선취업은 제8차 개정헌법에서 신설되었으며, 최저임금·여자근로자차별금지·연소자특별보호는 현행 헌법에서 신설되었다.

현행 헌법은 제32조 제1항 제1문에서 근로의 권리를 보장하고, 제2문에서 국가의 고용증진·적정임금의 보장노력·최저임금제, 제2항에서 근로의 의무, 제3항에서 근로조건의 법정주의, 제4항과 제5항에서 여자와 연소자의 근로에 대한 보호, 제6항에서 국가유공자 등에 대한 우선적 근로기회부여를 규정하고 있다.

2. 의의 및 기능

근로 또는 노동은 주인의 부속물로서 취급된 노예가 아닌 온전한 인격체로서 인간이 일정한 목적을 갖고 행하는 정신적, 육체적 행위나 활동을 말한다. 헌법의 근로권과 노동법에서 보호대상 또는 규율대상으로 삼는 근로 또는 노동은 생활수단을 목적으로 행하여지는 활동이다. 따라서 경제적 활동에 속하지 않은 활동(여가, 취미활동 등)은 보호 또는 규율대상으로 삼는 근로에 포함되지 않는다고 보아야 할 것이다. 결국 근로는 인간으로서 생존을 위한 목적으로 이루어지는 경제활동이다.

---

622) 바이마르 헌법 제163조 제2항 : 모든 독일 국민에게는 경제적 노동에 의하여 생활자료를 구할 수 있는 기회가 부여된다. 적정한 근로의 기회가 부여되지 아니하는 자에 대해서는 필요한 생계비를 지급한다.

623) 유진오 전문위원은 모든 국민은 근로의 권리와 의무를 가진다고 하는 것을 규정한 근본정신은 근로를 모든 국민의 의무로 삼는 동시에 근로를 하고 싶으나, 근로를 할 자리가 없어서 근로를 하지 못하는 사람에게 직장을 제공하도록 하자는 것이며, 근로를 중요시한다는 정신을 제17조에서 나타낸 것이라고 밝혔다. 제17조에 의해서 창설되는 근로의 권리와 의무는 헌법상의 권리와 의무라고 설명하고 있으나, 이어서 이 헌법상의 권리와 의무를 실제 생활에서 구체적으로 주장하기 위해서는 반드시 이것을 구체화하는 법률이 제정되어야 한다고 설명하고 있다. 제정될 법률로서 실업문제에 관한 것이라든지 근로자의 직장에 관한 문제라든지 또는 국민에게 근로의 의무를 과할 것인지 등의 내용이 구체화될 것이라고 밝혔다. 즉 이 헌법상의 권리와 의무를 도의적인 권리와 의무라고 할 수는 없으나, 이것으로서 곧 구체적인 권리와 의무는 창설되는 것이 아니라고 해석한다고 하는 것으로 보아 추상적 권리로 보고 있는 것으로 보인다.

헌법상의 근로의 권리는 넓게 이해하는 방법과 좁게 이해하는 방법이 있다. 넓은 의미의 근로의 권리는 근로에 관한 모든 권리를 의미하며, 좁은 의미의 근로의 권리는 근로의 기회에 대한 청구권으로 이해되고 있다.[624]

근로의 권리의 개념과 관련해서 헌법재판소는 근로자가 자신의 의사와 능력에 따라 근로의 종류·내용·장소 등을 선택하여 근로관계를 형성하고, 타인의 방해를 받지 않고 근로관계를 계속 유지하며, 근로의 기회를 얻지 못한 경우에는 국가에 대하여 근로의 기회를 제공하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리를 말한다고 판시한 바 있다.[625]

이러한 근로의 권리는 생활의 기본적인 수요를 충족시킬 수 있는 생활수단을 확보해 주고 나아가 인격의 자유로운 발현과 인간의 존엄성을 보장해주는 기본권이다. 그러나 근로권은 사회적 기본권으로서 국가에 대하여 직접 일자리(직장)를 청구하거나 일자리에 갈음하는 생계비의 지급청구권을 의미하는 것이 아니라, 고용증진을 위한 사회적·경제적 정책을 요구할 수 있는 권리에 그친다.[626]

근로의 권리는 자주적으로 근로관계를 형성하며, 타인의 방해를 받음 없이 근로관계를 유지할 수 있는 권리이며, 국가에게 적극적인 정책이나 조치를 취할 것을 요구할 수 있는 권리를 말한다. 오늘날 근로권의 보장은 생계수단 보장뿐만 아니라, 자아실현의 수단으로서도 중요한 의미를 가지며, 국가입장에서도 국민의 건전한 노동이 경제 질서의 근간을 이루는 역할을 한다는 점에서 근로권 보장의 의의를 확대할 수 있다. 결국 근로권은 역사적, 사회적 변화에 맞춰 재해석되고 변화 발전하여 왔으며, 이를 반영한 입법을 통해 구체화되고 구현된다고 할 수 있다.

이러한 근로의 권리는 첫째, 국민으로 하여금 근로를 통하여 생활의 기본적 수요를 스스로 충족하게 하고, 둘째, 근로를 통하여 개성과 자주적 인간성을 제고하고 함양하게 하며, 셋째, 근로의 상품화를 허용함으로써 자본주의경제의 이념적 기초를 제공하며, 넷째, 국가의 고용정책·노동정책·사회정책의 원칙적인 방향지표로서의 기능을 한다.[627]

3. 법적성격

자유권적 기본권은 국가의 간섭이나 침해를 받지 아니하는 소극적 방어적 권리를 말하는 반면, 사회권적 기본권은 인간다운 생활을 보장하기 위한 권리로서, 국가로부터 적극적인 급부를 요청할 수 있는 기본권을 말한다.

근로의 권리와 관련하여 자유권적 기본권으로 보는 견해는 근로의 종류와 내용, 장소, 형태 등을 자유로이 선택하고, 이를 행하는 자유로서 근로의 권리를 이해하며, 이러한 자유보장이 근로권의 보장을 의미한다고 본다. 이는 근로권의 본질적 내용을 국가에 의해 취업을 방해받지 아니할 권리로 보며, 일종의 방어권적 성질의 소극적 권리로 이해한다. 그러나 이 견해는 근로자가 국가를 상대로 근로의 기회를 제공해 줄 것을 요구한다거나 국가가 근로의 기회를 제공 또는 보장한다는 의미를 설명하지 못한다. 또한 헌법의 기본권체계상 근로권이 사회권적 기본권에 위치하고 있고 자유권과 분리되어 있다는 측면에서도 받아들이기 어렵다.

반면, 대부분의 견해는 오늘날 헌법상의 근로권을 사회권적 기본권의 속성을 갖는다는 입장을 취하고 있다. 김철수 교수는 근로의 권리의 발생배경과 헌법규정상의 워치를 근거로 사회권이라고 하고 있으며,[628] 권영성 교수는 본질은 사회적 기본권성에 있지만, 근로의 권리는 자유권성과 사회권성을 아울러 가지고 있다고 하고 있으며,[629] 허영 교수는 근로의 권리의 내용을

624) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 478면.
625) 헌법재판소 2008. 9. 25. 2005헌마586.
626) 헌법재판소 2002. 11. 28. 2001헌바50.
627) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 618면.
628) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 719~720면.

‘일할 자리에 관한 권리’와 ‘일할 환경에 관한 권리’로 보고 전자는 복합적인 권리로 후자는 생활권적 성질의 구체적 권리라 하고 있으며,[630] 홍성방 교수는 근로의 권리는 사회적 기본권은 입법위임규정으로서 제32조 제1항 제1문으로부터 근로의 기회에 대한 청구권을 도출할 수는 없고,[631] 다만 국가에 의해 근로의 기회를 박탈당하지 않을 자유권적 측면이 함께 있다는 것을 부정할 수 없다고 하였다.[632]

우리 헌법재판소는 근로의 권리는 내용을 ‘일할 자리에 관한 권리’와 ‘일할 환경에 관한 권리’으로 파악하면서, 후자는 인간의 존엄성에 대한 침해를 방어하기 위한 자유권적 기본권의 성격도 갖고 있어 건강한 작업환경, 일에 대한 정당한 보수, 합리적인 근로조건의 보장 등을 요구할 수 있는 권리 등을 포함한다고 보고 있다. 또한, 근로의 권리의 구체적인 내용에 따라, 국가에 대하여 고용증진을 위한 사회적·경제적 정책을 요구할 수 있는 권리는 사회권적기본권으로서 보고 있지만, 자본주의 경제 질서 하에서 근로자가 기본적 생활수단을 확보하고 인간의 존엄성을 보장받기 위하여 최소한의 근로조건을 요구할 수 있는 권리는 자유권적 기본권의 성격도 아울러 가지고 있다고 보고 있다. 즉, 기본적으로 사회권적 기본권으로 보고 있지만, 일할 환경에 관한 권리에 있어서는 복합적인 법적 성격을 인정하고 있다.[633]

근로의 권리는 기본적으로 국가권력으로부터 자유로운 근로활동을 방해받지 않을 근로의 자유에서 출발하였다. 그러나 오늘날 근로의 권리는 국가의 기능이 과거 자유방임에서 적극적 보장과 보호로 변화하였다는 점에서 국가로부터의 소극적이고 방어적인 보장만을 의미한다고 보는 것은 한계가 있을 수밖에 없다.

4. 주체

근로의 권리의 주체는 주로 생산수단을 소유하지 못한 근로자에 한정되며, 근로의 권리의 본질적 내용은 근로기회의 제공요구로 이해한다면 1차적으로 근로자 가운데서도 실업상태에 있는 미취업근로자라고 할 수 있다.[634] 외국인은 근로의 권리의 주체가 아니나 근로의 권리가 인간의 권리인 이상 외국인에게 근로의 권리를 부정할 근거는 없다. 따라서 외국인은 호혜주의 원칙에 따라 인정할 수도 있을 것이다.[635]

우리 헌법재판소도 외국인의 근로의 권리 주체성에 대해 근로자가 기본적 생활수단을 확보하고 인간의 존엄성을 보장받기 위해 최소한의 근로조건을 요구할 수 있는 권리는 자유권적 기본권의 성격도 아울러 가지므로 외국인에게도 주체성을 인정함이 타당하다고 판시한 바 있다.[636]

5. 내용

⑴ 본질적 내용

근로의 권리의 본질적 내용이 근로기회제공청구권이라는 데에는 의견이 일치되어 있다.

---

629) 권영성, 전게서, 618면.
630) 허영, 전게서, 480~481면.
631) 헌법재판소 2002. 11. 28. 2011헌바50.
632) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 265~266면.
633) 헌법재판소 2007. 8. 30. 2004헌마670.
634) 권영성, 전게서, 620면.
635) 홍성방, 전게서, 267면.
636) 헌법재판소 2002. 11. 28. 2001헌바50; 2007. 8. 30. 2004헌마670 등.

그런데 근로의 권리의 내용과 관련하여 헌법재판소는 근로의 권리가 '일할 자리에 관한 권리'만이 아니라 '일할 환경에 관한 권리'도 함께 내포하고 있는 바, 후자는 인간의 존엄성에 대한 침해를 방어하기 위한 자유권적 기본권의 성격도 갖고 있어 건강한 작업환경, 일에 대한 정당한 보수, 합리적인 근로조건의 보장 등을 요구할 수 있는 권리 등을 포함한다고 판시한 바 있다.[637] 근로의 권리의 내용에 대해서 학자에 따라서 다양한 표현을 사용하고 있지만, 크게 '일할 자리에 관한 권리'와 '일할 환경에 관한 권리'로 나누어볼 수 있을 것이다.

그러나 근로의 권리의 이 둘 관계는 상호유기적인 관계로 파악하여야 한다. 왜냐하면 고용관계의 변화에 따라 고용, 실업, 재취업이 연속적으로 나타나며, 취업상태에서도 양호한 일자리의 요구와 이직, 양호한 일자리로의 개선 등은 일할 자리와 일할 환경에 관한 권리를 명확하게 구분하기 어려운 측면이 있기 때문이다.

이러한 근로의 권리와 관련하여서는 생계비지급 및 직업훈련 등 일할 자리(근로의 기회)의 제공을 어느 범위까지 인정할 것인가의 문제가 있다. 이는 자본주의 사회에서 모든 국민에게 일할 자리를 제공하는 것은 현실적으로 불가능하며, 불가능한 경우에 이에 갈음하여 국민에게 생계비 지급청구권을 인정할 것인가 하는 문제로 귀결되는데, 이는 근로의 권리의 보장범위가 어디까지인가 하는 문제이기도 하다.

우리 헌법 제32조는 1919년 독일 바이마르헌법 제163조와는 달리 명문상 생계보장에 대한 규정을 두고 있지 않다. 다만, 고용보험법에서 일정한 수급요건을 갖춘 실업자에게 실업급여를 청구할 권리를 보장하고 있다. 헌법 제32조 제1항 제1문의 근로의 권리는 국가의 급부이행이 전제되는 전형적인 사회권적 성격을 가지고 있다. 다만, 그 구체적인 실현에 있어서 경제적, 사회적 상황을 감안한 입법·정책에 의해 이루어지는 것이라 할 수 있다.

따라서 실업급여의 경우에도 근로의 의사와 능력이 있는 자가 일시적 실업상태에 있어서 근로의 기회를 제공받기 전까지 소득보전의 차원에서 생계비가 지급된다는 점 등에서 근로의 권리에 어느 정도의 규범적 근거가 있다고 보아야 할 것이다.

⑵ 국가의 고용증진 의무

헌법 제32조 제1항 제2문 전단은 국가가 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용 증진에 노력하여야 할 의무를 규정하고 있다. 이에 따라 국가는 근로자의 고용을 증진할 입법은 물론, 고용확대, 실업대책 등에 관한 정책을 수립하고 추진해야 할 의무가 있다.

여기서 '사회적 방법'이라 함은 사회정책에 의한 고용 증진을 말하며, '경제적 방법'이라 함은 경제정책에 의한 고용기회의 확대를 말한다. 국가는 이러한 방법을 통하여 일반근로자가 사기업 또는 공공기업에 취업하여 완전고용상태가 실현될 수 있도록 노력하여야 하는 것이다.

고용증진의 의미는 단순히 근로의 기회 제공, 일자리의 창출보다는 넓은 의미에서 보다 나은 환경 또는 수준에서 일을 할 수 있는 기회를 제공하는 것까지 포함하는 것으로 해석하는 것이 타당하다. 특히 사회적·경제적 방법으로 제시하였는데 이는 사회·경제적 상황과 밀접하게 관련되어 있기 때문에 고려해야 할 요소이며, 이러한 고려 요소를 참작하여 입법 및 정책적 수단을 통하여 고용증진의 보장을 위하여 노력하여야 한다.

이는 고용증진을 보장하기 위한 입법·정책적 조치를 취하도록 노력하여야 한다는 의미이므로 국가의 광범위한 입법재량의 한계를 설정한 것으로 볼 수 있다. 이에 따라 국민의 취업기회를 제공하기 위하여 고용정책기본법, 직업안정법, 근로자직업능력개발법, 고용보험법 등이 있고, 여성의 취업보장을 위해 남녀고용평등과 일·가정양립 지원에 관한 법률이 있으며, 고령자 및 장애인의 직업재활 및 고용기회 확대를 위한 고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진법률, 장애인고용촉진 및 직업재활법 등이 제정·시행되고 있다.

---

637) 헌법재판소 2007. 8. 30. 2004헌마670.

⑶ 해고의 자유제한

해고는 사용자의 일방적 의사표시로 근로관계가 종료되는 것을 말한다. 그런데 이를 제한하는 것은 사용자의 계약의 자유, 영업의 자유, 재산권 보호와의 충돌문제가 발생한다. 이와 관련하여 헌법재판소는 헌법 제15조 직업의 자유, 제32조 근로의 권리, 사회국가원리 등에 근거하여 실업방지 및 부당한 해고로부터 근로자를 보호하고 있다.[638]

⑷ 적정임금의 보장, 최저임금제실시, 동일노동에 대한 동일임금의 원칙

헌법 제32조 제1항 제2문은 국가의 적정임금의 보장노력, 최저임금제의 시행을 규정하고 있다. '적정임금'이라 함은 근로자와 그 가족이 존엄한 인간으로서 건강하고 문화적인 생활을 영위하는 데 필요한 정도의 임금수준을 의미한다. 이에 따라 근로기준법은 임금의 개념, 지급방법 및 임금지급의 보장을 규정하고 있다.

근로자는 근로의 반대급부인 임금을 통해 가족의 생계를 꾸리게 되는데, 근로자는 사용자와의 관계에서 경제적·사회적 약자의 지위에 놓일 수밖에 없기 때문에 헌법상 근로권 규정에서 국가에게 적정한 임금을 보장할 의무를 부여하고 있는 것이다. 그러나 적정임금의 산정과 보장에 있어서는 고려해야 하는 여러 다양한 요소들이 있고 현실적 여건에 따라 달라질 수 있기 때문에 '적정임금'을 정하는 것은 대단히 어렵다. 따라서 '적정임금'은 기본적으로 존엄한 인간으로서 건강하고 문화적 생활을 영위하는 데 필요한 정도로 이해할 경우 적정임금의 보장에 반하는 입법정책은 헌법의 근로의 권리에 반하는 것으로 보아야 한다.

그리고 국가는 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다고 규정하고 있다. 최저임금제도란 국가가 근로자가 받는 임금의 최저한도를 설정하고 사용자로 하여금 이를 준수하도록 법으로 강제하는 제도이다.

또한, 동일노동에 대한 동일임금의 원칙은 제32조 제4항과 근로기준법 제5조, 남녀고용평등법 제6조의2 제1항에서 규정하고 있으며, 고용과 임금, 근로조건에서 부당한 차별을 금지하는 것이다.

⑸ 근로조건 법정주의, 여자와 연소자 근로의 특별대우, 국가유공자 등의 근로기회우선보장

근로조건 법정주의는 근로조건에 관하여 법률이 최저한의 제한을 설정한다는 의미로 해석되며, 이 규정은 계약자유의 원칙에 대한 수정을 예정하고 있다. 즉, 근로조건이나 계약의 내용을 당사자들이 자유롭게 결정하는 것이 원칙이나 사실상의 교섭력에 차이로 인해 근로권이 침해되었다는 사실에 기인한 것이다.[639] 이때, '근로조건'은 임금과 그 지불방법, 취업시간과 휴식시간, 안전시설과 위생시설, 재해보상 등 근로계약에 의하여 근로자가 근로를 제공하고 임금을 수령하는데 관한 조건들을 말한다.[640] 근로조건을 법정함에 있어 기준이 되는 것은 '인간의 존엄성을 보장'이고, '인간의 존엄성 보장'은 근로조건의 법정의 기준 내지 수준의 판단지표로서 기능을 한다. 이때 '인간의 존엄성을 보장하는 근로조건의 기준을 설정하는 것'은 입법자의 입법재량 범위에 속한다.[641] 헌법재판소는 '인간의 존엄성에 관한 판단기준'은 사회 경제적 상황에 따라 변화하는 상대적 성격을 띠기 때문에 그에 상응하는 근로조건에 관한 기준도 시대상황에 부합하게 탄력적으로 구체화하도록 법률에 유보한 것이라고 판시하였다.[642]

---

638) 헌법재판소 2002. 11. 28. 2001헌바50.

639) 근로기준법이 정한 기준에 미치지 못하는 근로조건을 정한 근로계약은 그 부분에 한하여 무효로 한다. 무효로 된 부분은 근로기준법이 정한 기준에 의한다.

640) 헌법재판소 2003. 7. 24. 2002헌바51.

641) 헌법재판소 1999. 9. 16. 98헌마310.

여성근로는 모성 및 신체적, 생리적 특성으로 인하여 특별한 보호가 필요하고, 연소근로자에 대한 사회적 보호의 필요성에 따른 사회 정책적 고려가 반영된 것이다. 이를 근거로 근로기준법 제5장에서 여성 및 연소근로자 보호에 관한별도의 규정을 두고 있고, 남녀고용평등 및 일·가정 양립지원 정책에 관한 법률을 규정하여 남녀의 균등한 처우와 여성근로자의 모성보호 등의 규정을 두고 있다.

또한, 근로의 기회에서 국가유공자 등의 우선적 보호와 관련하여 국가유공자에게 가산점을 주는 방식은 헌법 제32조 제6항에 근거하여 법률로 정할 수 있고, 국가유공자의 가족에게 가산점을 주는 방식은 헌법 제32조 제6항에 해당하지는 않지만 입법정책상 허용되어 합헌이다. 그렇지만 국가유공자의 가족에게 10%이상의 가산점을 주는 것은 지나친 차별이므로 헌법에 합치되지 아니한다.[643]

6. 효력 및 제한

⑴ 효력

근로의 권리는 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력을 가진다. 한편, 제32조 제4항과 제5항의 경우 사용자에게 직접효력이 미치는 가에 대해서는 긍정설과[644] 부정설이 있다.[645]

여성근로자와 연소근로자는 육체적·생리적·사회적으로 약자인 것이 보통이며, 따라서 이들을 사용자로부터 보호하기 위해 헌법에 규정을 둔 이상 직접효력을 미친다고 해석하는 것이 합리적일 것이다.[646]

⑵ 제한

근로의 권리는 자유권적 측면에서 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있고, 사회권적 측면에서 국가안전보장과 질서유지를 위해 필요한 경우에 법률로써 제한될 수 있다.[647] 공공복리를 위해서는 제한 될 수 없다. 왜냐하면 근로보호 자체가 공공복리에 속하기 때문이다.[648]

♣ 문제풀이

1. 다음 중 근로의 권리의 주체에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 국가내적 사회정책적 권리로서 그 주체는 국민이다.
② 자연인만의 권리로서 법인은 인정되지 않는다.
③ 외국인은 개별 법률이 있어도 주장할 수 없다.
④ 방송국의 위탁직 징수원도 근로자이다.
⑤ 제1차적 주체는 실업상태에 있는 미취업근로자이다.

---

642) 헌법재판소 2003. 7. 24. 2002헌바51.
643) 헌법재판소 2006. 2. 23. 2004헌마675 등.
644) 권영성, 전게서, 625면.
645) 허영, 전게서, 484면.
646) 홍성방, 전게서, 272면.
647) 권영성, 전게서, 626면.
648) 김철수, 전게서, 725면.

[정답] ③

[해설] 상호주의 원칙상 인정되거나 개별 법률에서 인정하는 경우, 주체성이 인정된다.

2. 다음 근로의 권리에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 헌법상 근로자보호조항을 노동헌법이라고 하고, 근로기본권 내지 근로활동권이 핵심이다.
② 근로기본권은 근로의 권리와 근로3권을 총칭하는 개념이다.
③ 근로기본권은 자유권적 기본권으로의 성격보다는 사회권적 기본권으로서의 측면이 보다 강하다.
④ 근로의 권리가 처음 등장한 것은 1793 자코뱅헌법이지만 이를 사회적 기본권의 하나로 규정한 것은 1919년 바이마르헌법이 최초이다.
⑤ 헌법의 근로기본권에 관한 규정은 근로자의 인간다운 존엄성을 보장하도록 하기 위한 것이다.

[정답] ⑤

[해설]

3. 다음 근로의 권리에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 근로는 근로자가 사용자로부터 임금을 받는 대가로 그에게 제공하는 육체적·정신적 활동을 말한다.
② 현행 한국헌법은 근로의 권리와 관련하여 생활비의 보장을 규정하고 있다.
③ 고용·인력정책을 경제·산업·교육정책 등과 연계하여 종합적이고 체계적으로 추진하기 위하여 고용정책기본법이 제정·시행되고 있다.
④ 근로자가 적정임금을 받기 위하여 법원에 적정임금을 청구할 수는 없다.
⑤ 근로능력의 상실자는 근로자로 보기 어렵다.

[정답] ③

[해설] 규정되어 있지 않다. 바이마르헌법 제163조 제2항에서 규정하고 있다.

♣ 요점정리

1. 근로의 권리는 근로자가 자신의 의사와 능력에 따라 근로의 종류·내용·장소 등을 선택하여 근로관계를 형성하고, 타인의 방해를 받지 않고 근로관계를 계속 유지하며, 근로의 기회를 얻지 못한 경우에는 국가에 대하여 근로의 기회를 제공하여 줄 것을 요구할 수 있는 권리를 말한다.

2. 근로의 권리는 내용을 '일할 자리에 관한 권리'와 '일할 환경에 관한 권리'가 포함되며, 후자는 인간의 존엄성에 대한 침해를 방어하기 위한 자유권적 기본권의 성격도 갖고 있어 건강한 작업환경, 일에 대한 정당한 보수, 합리적인 근로조건의 보장 등을 요구할 수 있는 권리 등을 포함한다.

3. 고용증진의 사회적 방법이라 함은 사회정책에 의한 고용 증진을 말하며, 경제적 방법이라 함은 경제정책에 의한 고용기회의 확대를 말한다.

4. 적정임금이라 함은 근로자와 그 가족이 존엄한 인간으로서 건강하고 문화적인 생활을 영위하는 데 필요한 정도의 임금수준을 의미한다.

5. 근로조건 법정주의는 근로조건에 관하여 법률이 최저한의 제한을 설정한다는 의미로 해석되며, 이 규정은 계약자유의 원칙에 대한 수정을 예정하고 있다. 즉, 근로조건이나 계약의 내용을 당사자들이 자유롭게 결정하는 것이 원칙이나 사실상의 교섭력에 차이로 인해 근로권이 침해되었다는 사실에 기인한다.

제35강 노동3권

♣ 학습목표

노동3권에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

노동3권의 법적성격, 주체
단결권, 단체교섭권, 단체행동권
노동3권의 효력, 제한

♣ 사전테스트

1. 우리 헌법상의 근로자에 외국인 근로자도 포함될 수 있다.

정답 : O
해설 : 대법원 1993. 11. 26. 93구16774.

2. 우리 헌법재판소는 자유권으로서의 성격보다는 생존권 내지 사회권으로서의 측면이 보다 강한 것으로 권리의 실질적 보장을 위해서는 국가의 적극적인 개입과 뒷받침이 요구된다고 판시한 바 있다.

정답 : O
해설 : 헌법재판소 1991. 7. 22. 89헌가106.

3. Union Shop협정은 노동조합의 단결을 강화하기 위한 강제의 한 수단으로서 근로자가 대표성을 갖춘 노동조합의 조합원이 될 것을 '고용조건'으로 하고 있는 것이므로 단체협약에 Union Shop협정에 따라 근로자는 노동조합의 조합원이어야만 된다는 규정이 있는 경우에는 다른 명문의 규정이 없더라도 사용자는 노동조합에서 탈퇴한 근로자를 해고할 의무가 있다.

정답 : O
해설 : 대법원 1998. 3. 24. 96누16070; 2002. 10. 25. 2000다23815.

♣ 돌발퀴즈

근로자들이 정당하게 단체행동권을 행사하는 경우에는 사용자는 근로자들에게 임금을 지급하여야 한다.

[정답] X
[해설] 대법원 1995. 12. 21. 94다2671.

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

역사적으로 자본주의 사회에서 노동기본권의 주체로서 노동자는 노동이라는 상품의 소유자를 의미한다. 상품의 소유자라는 점에서 노동자도 역시 자본가와 대등한 위치에 있는 시민이다. 그러나 노동자가 개별적으로 행동하는 한 거래능력에 한계가 있으므로 이윤 극대화를 노리는 자본(사용자)에 대항하기가 쉽지 않다. 따라서 노동자는 단결을 통해 거래능력의 취약성을 극복하고 단체의 협상력을 제고하지 않을 수 없으며, 국가 역시 노동시장의 자유방임으로 인한 사회적 불안정을 방지하기 위해서라도 노동자의 단결활동을 진정한 의미의 권리로 인정하고 법률로써 보장할 필요성이 있다.

이러한 노동기본권은 통상 3단계를 거쳐 확립된다. 첫 번째는 단결권이 금지 내지 부인된 단계로서 노동자의 단결이나 노동조합이 시민법적 자유의 대립물로 생각되며, 시기적으로 시민혁명에서 산업혁명에 이르기까지의 시기이다.

두 번째는 결사의 자유화 단계로서 단결금지가 철폐되고, 시민적 자유를 토대로 단체활동이 국가의 형벌권으로부터 해방되며, 노동정책에 있어서도 노동력 거래를 노사의 자유로운 단체교섭에 일임하고 국가는 이에 개입하지 않는 자유방임정책을 취한다. 다만 여자, 아동 등 노동착취의 대상이 되기 쉬운 노동자에 대해서만 예외적으로 노동보호법 제정(노동입법)을 통해 개입하는 것이 원칙이었다. 시기적으로는 영국의 경우 1824년과 1825년의 노동조합법, 프랑스의 경우 1864년 헌법, 독일의 경우 1869년의 영업조례, 미국의 1842년 판례법 등이 이에 해당한다.

세 번째는 적극적 보장의 단계로서 독점단계 이후의 자본주의 경제의 변모와 이에 따른 노사관계의 변화를 계기로 단순한 시민적 기본권과 구별되는, 이른바 노동기본권이 적극적으로 용인되는 시기이다. 즉 노동자의 단결활동을 진정한 의미의 권리로 인정하고 필요한 법률상의 보호를 보장하기 시작했다. 시기적으로는 영국의 경우 1871년 노동조합법과 1906년의 노동쟁의법, 프랑스의 경우 1884년과 1936~37년 인민전선 당시의 여러 입법, 독일의 경우 1919년 바이마르헌법과 1949년 서독기본법, 미국의 경우 1935년 와그너법 등이다. 그리고 이 시기에는 노동조건을 보호하기 위한 통일적인 노동법 영역이 등장한다.[649]

우리나라의 경우, 일제치하 1920년 초에 일본자본의 유입과 함께 노동조합운동이 시작되었으며, 일본식민정권의 탄압으로 잠복기를 거치게 된다. 1945년 해방 후 우익(대한노총)과 좌익(조선노동조합전국평의회)으로 분열되어 혼란기를 겪었으며, 1953년 노동법이 제정되었다. 이후, 1963년 노동관계법이 개정되어 노동운동의 새로운 계기가 마련되는 듯 했으나 1970년대 고도경제성장과 국가안보주의에 묶여 침제기를 겪게 된다. 이후 1987년 6월 29일 이른바 민주화선언 이후 노동운동의 민주화가 추진되었다.[650]

근로자의 노동3권을 처음으로 규정한 헌법문서는 1919년 바이마르헌법 제159조라고 알려져 있는데, 근로조건과 경제조건을 향상시키기 위한 적극적 단결권의 의미에서 단결의 자유를 보호하였다.

우리헌법은 건국헌법에서부터 노동3권을 법률의 범위 내에서 보장했을 뿐만 아니라 그 당시로서는 매우 파격적인 노동자의 이익분배균점권까지 규정하였다. 그 후, 제5차 개정헌법은 법률유보조항과 노동자의 이익분배균점권을 삭제하였고, 제7차 개정헌법에서는 법률유보조항이 부활되었으며, 제8차 개정헌법은 단체행동권에 대하여 법률유보조항을 두었고, 제9차 개정헌법은 단체행동권에 대한 법률유보를 삭제하였다.

---

649) 김유성, 「노동법 II」, 법문사, 2001, 47~50면 참조.
650) 김형배, 「노동법」 제19판, 박영사, 2010, 721~722면 참조.

현행 헌법 제33조 제1항은 근로자의 노동3권을 보장하고 있다. 헌법이 노동3권을 규정한 취지는 사용자와의 근로계약에서 근로자의 생존권·근로권을 확보하기 위하여 유효한 구체적 권리수단을 보장하기 위한 것이다.[651]

2. 법적성격 및 주체

(1) 법적성격

노동3권이 어떤 성질을 가지는가에 대해서는 자유권설, 사회적 기본권설,[652] 혼합권설 등이 있다. 이 중, 자유권적 성격과 사회권적 성격을 동시에 가진다는 혼합권설이 다수설과 판례의 입장이다.[653]

1) 자유권설

근로자의 노동3권은 일종의 자유권적인 성질의 권리라고 하는 주장이다. 노동3권은 자유권에 속하는 집회·결사의 자유의 특수형태에 지나지 않기 때문에 일종의 자유권적인 성질의 것이며 '근로자가 국가로부터 단결 내지 단체행동을 이유로 제재를 받지 않는 것을 주요 내용' 으로 하기 때문에 자유권이라고 한다. 이 견해에 따르면 노동3권은 '국가적 간섭·방해·제재로부터의 자유'를 그 본질로 하게 된다.[654]

2) 생존권설

생존권설에 의하면 근로자의 노동3권은 국가에 대해서 노동3권의 보장을 적극적으로 요구할 수 있는 생존권적 성질의 권리라고 한다. 즉, 노동3권은 근로자의 생존권을 무엇보다도 노동관계의 장에서 실현하려는 것이며, 근로자의 인간생활 전반을 규정대상으로 하는 것이 아니고 노동관계와 관련된 측면에서 종속노동 내지 노동의 종속성을 자각한 근로자가 생존을 유지하기 위한 수단으로서 인정된 것이라 한다. 이러한 노동3권의 생존권적 주장은 어디까지나 수단적 의미나 지위에서이고 노동3권 자체가 바로 생존권인 것은 아니다. 근로자의 인간다운 생활을 보장하기 위해서 단결이라는 특수한 중간과정을 갖는다는 의미이다. 왜냐하면 노동3권이 보장되거나 실현된다고 해서 근로자의 생존권이 바로 또는 자동적으로 확보되는 것은 아니고, 노동3권만으로는 충분치 못할 경우가 얼마든지 있을 수 있기 때문이다.[655] 이러한 생존권설은 자유보다도 물질 그리고 과정보다도 결과를 중시 여긴다. 왜냐하면 역사적으로 생존권은 시민적 자유권의 보완 내지 수정으로서 대두되었고, 자본주의 사회에서 근로자가 인간다운 생활을 하기 위해서는 무엇보다도 임금이라는 결과에 중점을 둘 수밖에 없기 때문이다.

3) 혼합권설

혼합권설에 의하면 노동3권은 자유권으로서의 성질과 생존권으로서의 성질을 함께 가지는 일종의 혼합권적인 성질의 권리라고 한다. 즉 노동3권의 행사로 인해서 야기될 수도 있는 형사책임을 물을 수 없다는 점에서는 '국가로부터의 자유'라는 자유권적인 성질을 갖는다고 볼 수 있지만, 생존을 방해하고 침해하는 사용자등의 행위에 대해서 국가에게 그 적극적인 개입과 대책을 요구할 수 있다는 점에서는 생존권적인 성질을 갖는다고 한다.[656]

---

651) 헌법재판소 1993. 3. 11. 92헌바33; 1998. 2. 27. 94헌마13 등.
652) 문홍주, 「제6공화국 한국헌법」, 해암사, 1988, 309면.
653) 헌법재판소 1991. 7. 22. 89헌가106; 1998. 2. 27. 94헌바13 등.
654) 박일경, 「제6공화국 신헌법」, 법경출판사, 1990, 287면.
655) 이영희, 노동기본권의 이론과 실제, 까치사, 1990, 107쪽.

4) 헌법재판소

자유권으로서의 성격보다는 생존권 내지 사회권으로서의 측면이 보다 강한 것으로 권리의 실질적 보장을 위해서는 국가의 적극적인 개입과 뒷받침이 요구된다고 판시한 바 있으며,[657] 근로자는 노동조합과 같은 근로자단체의 결성을 통하여 집단으로 사용자에 대항함으로써 사용자와 대등한 세력을 이루어 근로조건의 형성에 영향을 미칠 수 있는 기회를 가지게 되므로 이러한 의미에서 근로3권은 사회적 보호기능을 담당하는 자유권 또는 사회권적 성격을 띤 자유권이라고도 판시한 바 있다.[658]

5) 검토

노동3권은 역사적인 기능에서 그리고 근로의 권리와 밀접한 관련을 가진다는 점과 그것이 경제적·사회적 발전을 보장한다는 점에서 사회권과 밀접한 관계를 가진다. 따라서 노동3권은 '사회적 보호기능을 담당하고 있는 자유권' 또는 '사회권적 성격을 띤 자유권'이라 보는 것이 타당하다.[659]

⑵ 주체

노동3권의 주체는 근로자이다. 근로자의 인간상을 나타내는 현실의 근로자상은 계급으로서 인간이다. 즉, 계급은 자본소유자와 노동소유자를 분리하고 그로 인하여 양자는 생활상태의 차이를 가지게 되었다. 종속성은 자본소유자와 노동소유자의 분리와 이로 인하여 나타난 결과에서 발생한다. 구체적으로는 자본에 대한 노동의 종속성이며 자본가에 대한 근로자의 종속성이라고 할 수 있다.

따라서 우리 헌법상의 근로자란 직업의 종류를 불문하고 사용자와 피용자의 관계에서 근로를 제공하고, 그 대가로서 임금·급료 기타 이에 준하는 수입으로 생활을 하는 자를 의미한다. 근로자에는 근로자, 실업 중에 있는 근로자, 해고의 효력을 다투고 있는 자, 외국인 근로자,[660] 법률이 정하는 공무원,[661] 등이 포함된다. 특히, 단체교섭의 주체는 근로자 개인이 아니라 근로자 단체이다.

그러나 사용자와 자신의 재산으로 생업을 영위하는 자(자영농, 소작인, 어민, 소상공자, 개인택시운전사 등) 및 자유직업종사자는 근로자에 포함되지 않는다.

3. 내용

⑴ 단결권

1) 의의 및 요건

헌법 제33조 제1항의 단결권은 근로자가 단체교섭을 행하기 위한 목적으로 자주적인 근로자단체를 조직하는 권리를 말한다. 이러한 단결권은 개별근로자 뿐만 아니라 노동자 단체도 향유주체이며, 이를 헌법상 조합 혹은 헌법상 단결체(이하 헌법상 조합)라 한다.[662] 헌법상 조합은

656) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 728~729면; 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 629면; 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 486~487면; 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 274~275면.
657) 헌법재판소 1991. 7. 22. 89헌가106.
658) 헌법재판소 1998. 2. 27. 94헌바13 등.
659) 홍성방, 전게서, 275면.
660) 대법원 1993. 11. 26. 93구16774.
661) 국가공무원법 제66조에 규정된 '사실상 노무에 종사하는 공무원'을 의미한다.
662) 김유성, 전게서, 68면.

헌법이 보장하는 단결활동에 관한 면책효과, 노동3권의 침해에 대한 사법구제 등의 일정한 법적 보호를 받으나 노조법 제7조에서 규정하고 있는 특별한 보호는 인정되지 않는다.[663]

이러한 근로자 단체는 근로자의 계속적인 단체로서 노동조합인 것이 원칙이나 일시적인 단체(쟁의단)도 포함되며, 근로자의 단체는 조직면에서 자주조직·독립성보장·반대방향의 이해관계자의 참여금지·단체협약의 내용을 조직내부에서 관철시킬 수 있는 대의조직 등의 요건을 갖출 것이 요청된다.[664] 근로자의 단결권은 개인적·집단적·적극적인 단결권을 포함하며, 결사의 자유에 대한 특별규정으로서의 성질도 가진다.[665]

2) 소극적 단결권

단결권에 소극적인 단결권이 포함되는가에 대해서는 학설의 대립이 있으나 소극적 단결권에는 개인의 자유를 보장하는 순기능과 노동조합의 단결을 약화시키는 역기능이 있으므로 노동조합의 단결을 약화시키지 않으며, 개인의 자유가 침해되지 않는 범위 내에서 보호되는 것이 타당하리라고 본다.[666]

3) Union Shop협정

노동조합이 노동자의 가입을 강제하여 조직강제, 즉 Union Shop협정을 체결하는 것과 관련하여 대법원은 "구 노동조합법(1996. 12. 31. 법률 제5244호로 폐지되기 이전의 것) 제39조 제2호 단서 소정의 조항, 이른바 Union Shop협정은 노동조합의 단결을 강화하기 위한 강제의 한 수단으로서 근로자가 대표성을 갖춘 노동조합의 조합원이 될 것을 '고용조건'으로 하고 있는 것이므로 단체협약에 Union Shop협정에 따라 근로자는 노동조합의 조합원이어야만 된다는 규정이 있는 경우에는 다른 명문의 규정이 없더라도 사용자는 노동조합에서 탈퇴한 근로자를 해고할 의무가 있다"고 판시하여 그 유효성을 인정하고 있다.[667]

헌법재판소도 노동조합의 적극적 단결권은 근로자 개인의 단결하지 않을 자유보다 중시 된다고 할 것이어서 노동조합에 적극적 단결권(조직강제권)을 부여한다고 하여 이를 두고 곧바로 근로자의 단결하지 않을 자유의 본질적인 내용을 침해하는 것으로 단정할 수 없다.[668]

⑵ 단체교섭권

1) 의의

단체교섭권이란 근로자 단체, 즉 노동조합이 그 대표자 또는 조합이 위임하는 자를 통하여 사용자(또는 사용자단체)와 근로조건에 관한 교섭을 하고 단체협약(노동협약)을 체결하는 권리를 말한다.[669] 이러한 단체교섭권은 노동3권 중 가장 핵심이 되는 권리이다. 왜냐하면 단체교섭을 하기 위하여 근로자는 단결권을 가지며, 단체교섭에서 근로자에게 유리한 근로조건을 실현하기 위하여 단체행동권을 필요로 하기 때문이다.[670]

---

663) 이는 노조법 제7조에서 말하는 노동조합과는 달리 '근로조건의 향상을 위하여', '자주적'으로 설립되었으나 설립신고증을 교부받지 못한 경우를 의미한다(임종률, 「노동법」 제9판, 박영사, 2011, 62면).

664) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 276~277면; 이와는 다르게 근로자의 헌법상 단결체는 해석상 자주성·목적성·단결성이 요구된다고 설명되기도 한다(이영희, "노동조합의 설립신고제도의 문제",「노동법학」창간호, 한국노동법학회, 1987, 86~88면 참조.).

665) 홍성방, 전게서, 276~277면 참조.

666) 홍성방, 전게서, 277~278면 참조.

667) 대법원 1998. 3. 24. 96누16070; 대법원 2002. 10. 25. 2000다23815.

668) 헌법재판소 2005. 11. 24. 2002헌바95·96, 2003헌바9 등.

669) 헌법재판소 1998. 2. 27. 94헌바13; 대법원 1998. 1. 20. 97도588.

670) 홍성방, 전게서, 279면.

이러한 단체교섭은 노사관계의 기준을 정함으로써 사업장의 질서를 확립하고 일정한 기간 동안 평화롭게 안정된 분위기 속에서 일할 수 있도록 함으로써 산업평화를 보장해 주는 기능을 담당한다.

2) 대상

단체교섭은 근로조건의 유지 또는 개선을 목적으로 하는 것이므로 근로조건과 무관한 사항은 단체교섭의 대상에서 제외된다. 따라서 사용자가 독점적으로 보유하는 경영권,[671] 인사권 및 이윤 취득권에 속하는 사항은 원칙적으로 단체교섭의 대상이 될 수 없다. 그러나 근로자들의 근로조건이나 지위에 직접 관련되거나 중대한 영향을 미치는 사항에 대해서는 단체교섭이 이루어질 수 있다.[672]

3) 유형

가. 기업별교섭

기업별로 조직된 노동조합과 사용자의 단체교섭형태이다. 우리나라의 전형적인 교섭방식이며, 일본과 미국에서도 많이 행하여지는 방식이다. 기업별교섭은 해당기업의 특수성을 잘 알고 있는 당사자가 자신들의 근로조건을 결정한다는 장점이 있다. 그러나 교섭력의 차이 때문에 소외 받는 근로자계층이 많고, 업종, 직종, 산업 등 공통된 분야나 전체 근로자의 권익을 향상시키는 데에는 한계가 있다.

나. 통일교섭

전국 또는 지역단위로 구성된 산업별 또는 직종별 노동조합과 사용자의 단체교섭방식이다. 산업별 연합단체노조가 기업별노조의 위임을 받아 사용자와 교섭하는 것도 포함된다. 공무원노조, 교원노조 등의 교섭방식에 이에 속하나, 산업별로 사용자단체가 구성되어 있지 못한 우리나라에서는 활성화되지 못하고 있다.

다. 대각선교섭

산업별·지역별·직종별 단위노조가 개별기업의 사용자와의 단체교섭하는 방식이다. 대각선교섭은 노동조합에 대응하는 사용자단체가 없거나 이러한 사용자단체가 있더라도 각 기업에 특별한 사정이 있을 때 사용되며, 미국에서 사용되는 방식이다.

라. 공동교섭

기업별단위노조가 상급단체와 공동으로 개별기업의 사용자와 교섭하는 방식이며, 택시노조에서 활용되고 있다.

마. 집단교섭

기업별단위노조가 공동으로 사용자집단과 교섭하는 방식이며, 연합교섭 또는 집합교섭이라고도 한다.

4) 단체교섭과 단체협약

사용자측은[673] 단체교섭에 성의 있게 응해야 하며, 정당한 이유 없이 단체교섭을 거부하면 부당노동행위가 성립된다(노동조합 및 노동관계조정법 제81조 제3호). 단체교섭이 성공하면 단

671) 중앙노동위원회 1989. 2. 10. 88부노250.
672) 서울민사지방법원 1991. 9. 12. 90가합5721.
673) 국가도 사용자측에 포함된다(대법원 2008. 9. 11. 2006다40935).

체협약이 체결되어 보호받고, 단체교섭이 결렬되면 조정·중재를 거쳐 단체행동의 전제가 된다. 단체교섭권의 정당한 행사에 대해서는 민사상·형사상 책임이 면제된다.

⑶ 단체행동권

1) 개념 및 유형, 생산관리의 허용여부

단체행동권이란 사용자에 대하여 쟁의행위를 할 수 있는 권리이다. 여기서 쟁위행위란 동맹파업, 태업, 불매운동(보이콧), 감시행위(피케팅), 시위운동 기타 근로관계 당사자가 그 주장을 관철할 목적으로 행하는 행위로서 업무의 정당한 운영을 저해하는 것을 말한다.

그 밖에도 쟁의행위의 유형으로서 생산관리가 있다. 생산관리에 대해서는 사유재산제도와 정면으로 배치되므로 인정하지 않는 견해와[674] 재산권 및 경제질서에 관한 헌법규정과의 규범조화가 가능한 범위 내에서만 허용될 수 있다는 견해가[675] 있다.

인정하지 않는 견해가 다수설이나 생산관리를 엄격한 요건하에서 인정하는 것이 단체행동권의 취지에 비추어 타당하다고 본다.[676]

<대법원 1996. 1. 26. 95도1959>

근로자의 쟁의행위의 정당성은 첫째, 그 주체가 단체교섭의 주체로 될 수 있는 자이어야 하고, 둘째, 그 목적이 근로조건의 향상을 위한 노사 간의 자치적 교섭을 조성하는 데 있어야 하며, 셋째, 사용자가 근로자의 근로조건 개선에 관한 구체적인 요구에 대하여 단체교섭을 거부하였을 때 개시하되 특별한 사정이 없는 한 조합원의 찬성결정 및 노동쟁의 발생신고 등 절차를 거쳐야 하는 한편, 넷째, 그 수단과 방법이 사용자의 재산권과 조화를 이루어야 할 것은 물론 폭력의 행사에 해당되지 아니하여야 하는 여러 조건을 모두 구비하여야 한다.

<대법원 1997. 10. 10. 97누4951>

사용자와 근로자 사이의 근로계약관계에 있어서 근로자의 대우에 관하여 정한 조건인 근로조건 이외의 사항에 관한 분쟁이 아니어서 구 노동쟁의조정법(1996. 12. 31. 법률 제5244호로 폐지되기 전의 것) 제2조의 노동쟁의하고 할 수 없고, 특별한 사정이 없는 한 이러한 사항은 중재대상이 되지 않는다.

<헌법재판소 1990. 1. 15. 89헌가103>

노동쟁의조정법 제13조의2가 규정한 제3자 개입금지는 헌법이 인정하는 근로3권의 범위를 넘어 분쟁해결의 자주성을 침해하는 행위를 규제하기 위한 입법일 뿐, 근로자가 단순한 상담·조력을 받는 것을 금지하는 것은 아니므로, 근로3권을 제한하는 것이라고 볼 수 없다. 제3자 개입금지조항은 근로자측으로의 개입뿐만 아니라 사용자측으로의 개입에 대하여도 규정하고 있으므로 근로자와 사용자를 실질적으로 차별하는 불합리한 규정이라 볼 수 없다.

2) 형사책임의 면제

단체행동권의 행사는 국가에 의하여 형사책임을 추급당하지 않고, 사용자에 의하여 민사상 불법행위책임을 추급당하지 아니한다. 또한, 단체행동권의 행사로 인한 무노동에는 임금이 지급되지 않는 것이 원칙이다.

그러나 쟁의행위가 정당성의 한계를 벗어날 때에는 근로자는 형법 제314조의 업무방해죄 등 형사책임을 면할 수 없다.

---

674) 김철수, 전게서, 736면; 권영성, 전게서, 638면.
675) 허영, 전게서, 494면.
676) 홍성방, 전게서, 280면.

<대법원 1992. 9. 22. 92도1855>

쟁의행위는 근로자가 소극적으로 노무제공을 거부하거나 정지하는 행위만이 아니라 적극적으로 주장을 관철하기 위하여 업무의 정상적인 운영을 저해하는 행위까지 포함하는 것이므로 쟁의행위의 본질상 사용자의 정상업무가 저해되는 경우가 있음은 부득이한 것으로서 사용자는 이를 수인할 의무가 있으나 이러한 근로자의 쟁의행위가 정당성의 한계를 벗어날 때에는 근로자는 업무방해죄 등 형사상의 책임을 면할 수 없다.

<대법원 1995. 12. 21. 94다2671>

임금이란 근로의 대가로서 근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수를 의미하므로 현실의 근로제공을 전제로 하지 않고 단순히 근로자의 지위에 기하여 발생한다는 생활보장적 임금이란 있을 수 없다.

3) 한계

단체행동권의 행사는 그 성질상 필연적으로 다른 법익을 침해하게 마련이다. 따라서 단체행동권의 한계가 문제된다. 단체행동권의 행사에는 목적상의 한계로서 사회적 정의의 원칙에 입각하여 근로조건의 향상을 위해서만 행사되어야 한다는 한계가 있다. 즉, 단체행동권의 행사는 근로조건의 유지·개선을 위한 경제적인 목적을 위한 것으로서 사용자와 피용자의 관계에 국한되어야 한다.

<헌법재판소 2004. 7. 15. 2003헌마878>

전교조 조합원들이 다수 조합원들과 함께 집단 연가서를 제출한 후 수업을 하지 않고 무단결근 내지 무단 조퇴를 한 채 교육인적자원부가 추진하고 있는 교육행정정보시스템(NEIS) 반대집회에 참석하는 등 쟁의행위는 NEIS의 시행을 저지하기 위한 목적으로 이루어진 것인바 청구인들의 행위는 직접적으로는 물론 간접적으로도 근로조건의 결정에 관한 주장을 관철할 목적으로 한 쟁의행위라고 볼 수 없다.

따라서 순수한 정치적 파업은 인정되지 않는다. 그러나 최저임금법의 제정이나 노동관계법의 개폐 등과 같은 산업적 정치파업은 허용된다. 그 밖에도 단체행동권의 행사에는 방법상의 한계로서 비폭력적·비파괴적 방법을 사용하여야 하며, 절차상의 한계로서 최후수단으로서만 행사할 수 있다는 한계가 있다.[677]

4) 직장폐쇄

근로자의 단체행동에 대하여 사용자는 직장폐쇄(노동조합 및 노동관계조정법 제46조)를 할 수 있는가에 대하여 위헌설과[678] 합헌설이[679] 대립된다.

사용자가 근로자의 단체행동에 대하여 최후의 불가피한 경우에 직장폐쇄로 맞서는 것은 사용자의 재산권행사로 인정된다고 본다.[680]

---

677) 홍성방, 전게서, 281~282면 참조.
678) 김철수, 전게서, 735면.
679) 권영성, 전게서, 636면.
680) 홍성방, 전게서, 282면.

5. 효력 및 제한

⑴ 효력

노동3권은 대국가적 효력을 가진다. 따라서 근로자는 국가기관에 대하여 적극적인 조치를 요구할 수 있으며(적극적 효력), 근로자의 단결·단체교섭의 요구 또는 쟁의행위 등이 국가권력에 의해 금지·처벌되어서는 안 된다(소극적 효력).

노동3권의 대사인적 효력은 간접적인 대사인적 효력만을 인정하는 견해가[681] 있으나 노동3권은 직접적 제3자효를 갖는다고 보아야 한다. 왜냐하면 사회적 권력이 부분영역에 대하여 거대한 경제적 또는 사회적 압력을 행사하여 사실상 국가 자신과 마찬가지로 작용하고 침해하는 경우에는 예외적으로 기본권규범은 직접 구속력을 가지지 않으면 안 되기 때문이다.[682]

⑵ 제한

헌법에 의한 제한으로 제33조 제2항에 의하여 공무원의 노동3권은 제한된다. 그러나 2005. 1. 27. 공무원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률이 제정되어 6급 이하의 일반직공무원 및 이에 상당하는 연구 또는 특수기술직렬의 일반직공무워, 특정직공무원 중 6급 이하의 일반직공무원에 상당하는 외무행정·외무정보관리직공무원, 기능직공무원, 6급 이하의 일반직공무원에 상당하는 별정직공무원 및 계약직공무원, 고용직공무원은 원칙적으로 노동조합에 가입할 수 있고, 단체교섭도 행사할 수 있다(제6조 제1항). 또한, 1999년 1월 교원의 노동조합설립 및 운영 등에 관한 법률이 제정되어 교원의 단결권과 단체교섭권이 보장되었다. 그리고 주요방위산업체종사자는 법률이 정하는 바에 의하여 단체행동권을 제한하거나 인정하지 않을 수 있다.

법률에 의한 제한은 헌법 제37조 제2항에 따라 제한할 수 있다. 그러나 제한하는 경우에도 본질적인 내용은 침해할 수 없다. 또한, 제77조 제3항에 따라 비상계엄에 의해 제한될 수 있다.

<헌법재판소 1996. 12. 26. 90헌바19 등>

노동기본권은 어떤 제약도 허용되지 아니한 절대적인 권리가 아니라 질서유지나 공공복리라는 관점에서 당연 그 내재적인 제약이 있으며 그 제한은 노동기본권보장의 필요와 국민생활 전체의 이익을 유지·증진할 필요를 비교·형량하여 양자가 적정한 균형을 유지하는 선에서 결정된다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 우리 헌법이 보호하는 근로자에 속한다고 보기 어려운 것은?

① 실업 중인 근로자
② 해고의 효력을 다투고 있는 자
③ 외국인 근로자
④ 법률이 정하는 공무원
⑤ 택시운전사

[정답] ⑤

---

681) 허영, 전게서, 490~491면.
682) BVerfGE 25, 256(263f.).

[해설] 사용자와 자신의 재산으로 생업을 영위하는 자(자영농, 소작인, 어민, 소상공자, 개인택시운전사 등) 및 자유직업종사자는 근로자에 포함되지 않는다.

2. 다음 단결권과 결사의 자유에 관한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 결사의 자유는 자유권의 일종이나 단결권은 사회권의 일종이다.
② 결사의 자유나 단결권은 모두 모든 사람의 권리이다.
③ 결사의 자유는 소극적으로 국가에 의해 다수인의 집단행동이 제한·금지당하지 않는 것을 내용으로 하나 단결권은 주로 적극적 단결권이 보호대상이다.
④ 결사의 자유는 일반적인 자유를 의미하나 단결권은 근로계약의 제도적 전제로서의 객관적인 경제질서를 의미한다.
⑤ 헌법 제33조 제1항과 제21조 제1항은 특별법과 일반법의 관계에 있다.

[정답] ②
[해설] 결사의 자유는 모든 사람의 권리이나 단결권은 사용자를 제외한 근로자만의 권리이다.

3. 다음 중 노동조합 및 노동관계조정법이 규정하는 쟁의행위에 해당하지 않는 것은?

① 파업 ② 태업 ③ 직장폐쇄 ④ 생산관리
⑤ 기타 노동관계 당사자가 그 주장을 관철할 목적으로 행하는 행위

[정답] ④
[해설] 사유재산제, 사적소유권과 모순되는 것으로 허용되지 않는다.

♣ 요점정리

1. 우리 헌법상의 근로자란 직업의 종류를 불문하고 사용자와 피용자의 관계에서 근로를 제공하고, 그 대가로서 임금·급료 기타 이에 준하는 수입으로 생활을 하는 자를 의미한다. 근로자에는 근로자, 실업 중에 있는 근로자, 해고의 효력을 다투고 있는 자, 외국인 근로자, 법률이 정하는 공무원, 등이 포함된다.

2. Union Shop협정은 노동조합의 단결을 강화하기 위한 강제의 한 수단으로서 근로자가 대표성을 갖춘 노동조합의 조합원이 될 것을 '고용조건'으로 하고 있는 것이므로 단체협약에 Union Shop협정에 따라 근로자는 노동조합의 조합원이어야만 된다는 규정이 있는 경우에는 다른 명문의 규정이 없더라도 사용자는 노동조합에서 탈퇴한 근로자를 해고할 의무가 있다.

3. 단체교섭은 근로조건의 유지 또는 개선을 목적으로 하는 것이므로 근로조건과 무관한 사항은 단체교섭의 대상에서 제외된다. 따라서 사용자가 독점적으로 보유하는 경영권, 인사권 및 이윤 취득권에 속하는 사항은 단체교섭의 대상이 될 수 없다.

4. 임금이란 근로의 대가로서 근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수를 의미하므로 현실의 근로제공을 전제로 하지 않고 단순히 근로자의 지위에 기하여 발생한다는 생활보장적 임금이란 있을 수 없다.

제36강 인간다운 생활을 할 권리

♣ 학습목표

인간다운 생활을 할 권리를 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

인간다운 생활을 할 권리의 법적성격, 주체
사회보장을 받을 권리, 생활보호를 받을 권리
재해예방과 위험으로부터의 보호

♣ 사전테스트

1. 우리 헌법재판소는 인간다운 생활을 할 권리는 언제나 추상적 권리일 뿐이라고 한다.

정답 : X
해설 : 최소한의 물질적 생활을 요구할 수 있는 권리는 구체적 권리라고 보고 있다.

2. 인간다운 생활을 할 권리는 인간의 존엄에 상응하는 생활에 필요한 최소한의 물질적인 생활의 유지에 필요한 급부를 요구할 수 있는 구체적인 권리를 직접 도출될 수 있으며, 직접 급부를 내용으로 하는 구체적인 권리를 발생케 한다.

정답 : X
해설 : 직접 급부를 내용으로 하는 구체적인 권리를 발생케 한다고는 볼 수 없다(헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14).

3. 헌법재판소는 인간다운 생활을 한 권리는 행위규범으로 모든 국가기관을 구속한다고 보고 있다.

정답 : X
해설 : 입법부나 행정부에 대하여는 행위규범으로, 헌법재판에 있어서는 통제규범으로 작용한다(헌법재판소 1997. 5. 29. 94헌마33).

♣ 돌발퀴즈

정부가 수익률이 다소 떨어지는 기금운영방법을 선택했다면 연금가입자의 장래의 연금수급권(재산권)과 인간다운 생활을 침해하는 것이다.

[정답] X

[해설] 수익률이 다소 떨어져도 장기적인 안정성에서 충분한 보장이 있는 기금운영방법을 선택했다고 해서 연금가입자의 장래의 연금수급권(재산권)과 인간다운 생활을 침해하는 것은 아니다(헌법재판소 1996. 10. 4. 96헌가6).

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

인간다운 생활을 할 권리는 1919년 바이마르헌법 제151조에서[683] 처음으로 규정된 것으로 알려져 있다. 우리나라는 1962년(제5차 개정) 헌법에서부터 인간다운 생활을 할 권리를 규정하였으며, 1988년(제9차 개정 또는 현행) 헌법에서 여자의 복지·권익향상·노인·청소년의 복지향상·신체장애자의 보호, 재해예방·국민보호 등을 규정하였다.

헌법에서 보장하는 인간다운 생활권을 구체화하는 기본법으로는 1996년부터 시행중인 사회보장기본법을 들 수 있다. 사회보장법은 2012년 전부개정(시행 2013. 1. 27.)이 되었는데, 출산, 양육을 사회보장의 내용으로 포함하고 있는 점이 매우 중요한 개정 내용 중 하나이다. 이는 ILO의 사회보장개념을 수용한 것이며, 출산, 양육에 대한 사회적 책임을 위한 법적 근거를 제공하는 점에서 큰 의의가 있다.

또한, 1962년부터 시행되어 왔던 생활보호법을 대체하고 1999년부터 시행중인 국민기초생활보장법은 생활이 어려운 사람에게 필요한 급여를 실시하여 이들의 최저생활을 보장하고 자활을 돕는 것을 목적으로 제정되었으며, 2012년 개정되었다. 동법에 따라 급여는 수급자가 자신의 생활의 유지·향상을 위하여 그의 소득, 재산, 근로능력 등을 활용하여 최대한 노력하는 것을 전제로 이를 보충·발전시키는 것을 기본원칙으로 하고 있다. 그리고 급여의 기준으로 급여가 건강하고 문화적인 최저생활을 유지할 수 있는 것이어야 함을 법 제4조에서 밝히고 있다.

우리 헌법 제34조 제1항은 인간다운 생활을 할 권리를 보장하고, 제2항에서 국가의 사회보장·사회복지 증진의무, 제3항에서 국가의 여자에 대한 복지와 권익향상노력, 제4항에서 국가의 노인과 청소년복지 향상의무, 제5항에서 생활무능력자에 대한 국가보호, 제6항에서 국가의 재해예방의무를 규정하고 있다.

2. 법적성격 및 주체

(1) 법적성격

인간다운 생활을 할 권리의 법적성격에 대해서는 주생존권적 기본권으로서 인간다운 생활을 할 비용에 대해서 급부를 요구할 수 있는 급부청구권으로 보는 견해,[684] 불완전하지만 구체적 권리라는 견해,[685] 사회국가실현의 국가적 의무를 내포하는 국민의 구체적 권리로서 그 구체적인 내용은 생활무능력자의 국가에 대한 보호청구권과 각종 보호청구권이라는 견해,[686] 입법위임

683) 바이마르헌법 제151조 제1문 : 경제생활의 질서는 모든 사람의 인간다운 생활을 보장하려는 목적과 함께 정의의 제 원칙에 상응하지 않으면 안 된다.
684) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 693면.
685) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 603면.
686) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 502면.

규정으로 보면서 생활무능력자의 생계비청구권은 인간다운 생활을 할 권리의 최소한의 내용으로서 구체적 권리라는 견해가[687] 있다.

우리 헌법재판소는 인간다운 생활을 할 권리는 최소한의 물질적 생활을 요구할 수 있는 권리로 그러한 범위 내에서 구체적 권리라고 한다. 또한, 인간다운 생활을 할 권리는 모든 국가기관을 구속하지만 그 기속의 의미는 입법부와 행정부에 대해서는 행위규범으로서 작용하는 데 반하여 헌법재판소에 대해서는 통제규범으로서 작용한다고 한다.

<헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14> 국가유공자예우 등에 관한 법률 제9조

인간다운 생활을 할 권리로부터 인간의 존엄에 상응하는 생활에 필요한 최소한의 물질적인 생활의 유지에 필요한 급부를 요구할 수 있는 구체적인 권리가 상황에 따라서는 직접 도출될 수 있다고 할 수는 있어도, 동 기본권이 직접 그 이상의 급부를 내용으로 하는 구체적인 권리를 발생케 한다고는 볼 수 없다고 할 것이다. 이러한 구체적인 권리는 국가가 재정형편 등 여러 가지 상황들을 종합적으로 감안하여 법률을 통하여 구체화할 때 비로소 인정되는 법률적인 권리라 할 것이다.

<헌법재판소 1997. 5. 29. 94헌마33> 1994년 생계보호기준 위헌확인

입법부나 행정부에 대하여는 국민소득, 국가의 재정능력과 정책 등을 고려하여 가능한 범위 안에서 최대한으로 모든 국민이 물질적인 최저생활을 넘어서 인간의 존엄성에 맞는 건강하고 문화적인 생활을 누릴 수 있도록 하여야 한다는 행위의 지침, 즉 행위규범으로서 작용하지만, 헌법재판에 있어서는 다른 국가기관, 즉 입법부나 행정부가 국민으로 하여금 인간다운 생활을 영위하도록 하기 위하여 객관적으로 필요한 최소한의 조치를 취할 의무를 다하였는지를 기준으로 국가기관의 행위의 합헌성을 심사하여야 한다는 통제규범으로 작용하는 것이다.

⑵ 주체

다수설은 국민에게만 주체성을 인정하고, 외국인에게는 주체성을 인정하지 않는다. 그러나 호혜주의원칙에 따라 결정될 문제라고 보는 견해도 있다.[688]

3. 내용

⑴ 의의 및 기능

1) 의의

인간다운 생활을 할 권리는 기본권의 역사에서 일반적인 자유권과 평등권에 비해 비교적 최근에 발전된 기본권이고, 여러 사회적 제반사정에 의해 영향을 받기 쉬운 기본권이기도 한다.

인간다운 생활이란 개인과 그의 가족에게 건강과 행복, 특히 의식주, 의료 및 필요한 사회적 시설을 확보하기에 충분한 생활로[689] 정의할 수 있다. 이러한 인간다운 생활의 수준은 일정한 시점에서 객관적으로 확정할 수 있다. 이 때, 주의해야 할 것은 국가예산이 그것에 충분한가가 아니라 인간다운 생활이 오히려 국가세입의 계산에 지도적인 역할을 해야 한다는 것이다.[690] 그

687) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 288면.
688) 홍성방, 상게서 288면.
689) 세계인권선언 제25조 제1항.
690) 권영성, 전게서, 604면.

러나 현실적으로는 여러 가지 제약 때문에 인간다운 생활을 할 권리는 최저생존수준에 머무를 수밖에 없을 것이다.

이러한 측면에서 볼 때, 인간다운 생활을 할 권리는 인간의 존엄성에 상응하는 건강하고 문화적인 생활을 할 권리를 의미하며, 헌법 제34조 제1항은 헌법 제10조의 인간의 존엄과 가치를 실현하기 위한 사회권적 총칙규정이라고 할 수 있다.

2) 기능

인간다운 생활을 할 권리에 대한 헌법규정은 사회입법의 근본규범으로서 사회적 권리의 이념적 출발점·사회적 권리의 핵·사회적 권리에 대한 일반규정으로서의 기능을 한다. 즉, 이러한 인간다운 생활을 할 권리는 인간존엄성을 실현시키기 위한 전제·기초가 되고, 경제질서의 가치지표로서의 의의를 갖으며, 사회국가 실현의 국가적 의무를 제시하는 기능을 한다.[691]

<헌법재판소 1999. 12. 23. 98헌바33> 구 국가유공자예우 등에 관한 법률 제70조 등

인간다운 생활을 할 권리는 신체장애자의 권리 등 여타 사회적 기본권에 관한 헌법규범들의 이념적인 목표를 제시하고 있는 동시에 국민이 인간적 생존의 최소한을 확보하는 데 있어서 필요한 최소한의 재화를 국가에게 요구할 수 있는 권리를 내용으로 하고 있다. 국가가 신체장애자 등을 보호할 의무도, 신체장애로 인하여 인간적 생존의 최소한을 확보하는 데 어려움이 있는 국민을 보호할 대책을 세울 의무를 부과함으로써 결국 인간다운 생활을 할 권리의 실현을 위한 수단적인 성격을 갖는다고 할 것이다.

⑵ 사회보장을 받을 권리

1) 내용

헌법 제34조 제2항은 제32조 제1항의 권리가 실현될 수 있도록 사회보장과 사회복지의 증진을 위하여 국가가 노력해야 할 의무를 규정하고 있다. 그에 따라 국민은 국가의 적극적 관여에 따른 사회보장을 받을 권리를 가진다.

<헌법재판소 1994. 2. 24. 92헌마43> 주택건설촉진법 제3조 제9호 위헌확인

주택조합(지역조합과 직장조합)의 조합원자격을 무주택자로 한정하고 있는 주택건설촉진법 제3조 제9호는 우리 헌법이 전문에서 천명한 사회국가, 복지국가, 문화국가의 이념과 그 구현을 위한 사회적 기본권조항인 헌법 제34조 제1항·제2항, 제35조 제3항의 규정에 의하여 국가에게 부과된 사회보장의무의 이행과 국민의 주거확보에 관한 정책시행을 위한 정당한 고려하에서 이루어진 것으로서 조합원자격에서 유주택자를 배제하였다고 해서 그것이 인간의 존엄성이라는 헌법이념에 반하는 것도 아니고 우선 무주택자를 해소하겠다는 주택건설촉진법의 목적달성을 위하여 적정한 수단이기도 하므로 이는 합리적 근거가 있는 차별이어서 헌법의 평등이념에 반하지 아니하고 그에 합치된 것이며, 헌법 제37조 제2항의 기본권 제한의 과잉금지의 원칙에도 저촉되지 아니한다.

사회보장과 사회복지란 일반적으로 국가가 국민의 생활보장을 위하여 급부하는 모든 것을 지칭한다. 그러한 것에는 사회보험제도의 도입, 국가를 통한 경제질서의 조정과 통제, 조세정책을 통한 사회개선이 있다. 이러한 것들 중에서 가장 대표적인 것으로는 사회보험제도를 들 수 있다.

691) 허영, 전게서, 501~502면.

사회보험이란 보험당사자인 국가 또는 공공단체가 특정의 손실 또는 손해를 보상하거나 일정한 금액을 지급하거나 또는 기타 특정의 보험급부를 수여하는 제도를 말한다. 사회보험의 주요유형에는 의료보험·상해보험·폐질 및 양로보험·실업보험·퇴직연금보험 등이 있다.

그 밖에도 국민은 양로원·고아원·보육시설·조산원·무료시설 등의 사회구호시설의 혜택을 받을 권리를 가진다.

<헌법재판소 1996. 10. 4. 96헌가6> 공공자금관리기금법 제5조 제2항, 국민연금법 제84조 제3항 등 위헌제청

국가는 법적요건을 갖춘 수급권자에게 법정의 급여를 지급할 책임과 의무를 진다. 따라서 국가는 안정성·수익성·공공성 등을 고려한 합리적 재량에 의해 연금기금을 관리·운용할 수 있는 것이지 반드시 가입자의 희망에 따라 운용해야 하는 것은 아니다. 그런데 정부가 수익률이 다소 떨어져도 장기적인 안정성에서 충분한 보장이 있는 기금운영방법을 선택했다고 해서 연금가입자의 장래의 연금수급권(재산권)과 인간다운 생활을 침해하는 것은 아니다.

<헌법재판소 1994. 6. 30. 92헌가9> 군인연금법 제21조 제5항 위헌제청

군인연금법상 퇴역연금은 군인이 장기간 충실히 복무한 공로에 대한 공적 보상으로서 지급된다고 하는 은혜적 성질을 갖는 한편 퇴역연금 중 기여금에 상당한 부분만은 봉급연불적인 성질을 갖고 있을 뿐만 아니라 군인이 부담하는 기여금은 군인인 기간 동안 및 퇴직 후에 있어서의 공적 재해보험의 성질이 있고, 국고의 부담금은 군인과 그 가족을 위한 사회보험부담금으로서의 성질이 있다 할 것이므로 결국 퇴역연금은 퇴역군인의 생활을 보장하기 위한 사회보험 내지 사회보장, 사회복지적인 성질도 함께 갖는다. 따라서 군인연금법 제21조 제5항 제2호에 해당하는 기관으로부터 보수 기타 급여를 지급받는 경우 어느 정도 퇴역연금의 지급을 제한할 것인가는 입법자가 사회정책적 고려, 국가의 재정 및 기금의 상황 등 여러 가지 사정을 참작하여 폭넓게 그의 형성재량으로 결정할 수밖에 없는 것이긴 하지만 퇴역연금은 봉급연불적 성질도 있으므로 적어도 그 범위 안에서 퇴역연금의 지급정지는 기본권 제한의 한계를 정한 헌법의 규정에 따라야 한다.

헌법재판소는 이러한 헌법상의 사회보장을 받을 권리도 그에 관한 수급요건, 수급자의 범위, 수급액 등 구체적인 사항이 법률에 규정됨으로써 비로소 구체적인 법적권리로 형성되는 권리라고 본다.[692]

2) 구체화 법률

사회보장기본법을 필두로 의료보호법, 생활보호법, 재해구호법, 군인보호법, 영유아보호법, 모자복지법, 모자보건법, 아동복지법, 노인복지법, 장애인복지법, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 등이 제정되어 시행되고 있다.

2013. 1. 27.부터 시행되고 있는 개정 사회보장기본법은 여러 가지 점에서 중요한 변화를 꾀하고 있는데, 이는 변화된 기본이념 규정에서 잘 드러난다. 구법에서는 사회보장의 기본이념을 모든 국민이 인간다운 생활을 할 수 있도록 최저생활을 보장하고 국민 개개인이 생활의 수준을 향상시킬 수 있도록 제도와 여건을 조성하여, 그 시행에 있어 형평과 효율의 조화를 기함으로써 복지사회를 실현하는 것으로 삼고 있었다.

개정된 사회보장기본법 제2조는 사회보장은 모든 국민이 다양한 사회적 위험으로부터 벗어나 행복하고 인간다운 생활을 향유할 수 있도록 자립을 지원하며, 사회참여·자아실현에 필요한 제도와 여건을 조성하여 사회통합과 행복한 복지사회를 실현하는 것을 기본 이념으로 한다고

692) 헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14; 2003. 7. 24. 2002헌바51 등.

규정하면서 사회보장이 자립지원과 사회통합과 행복한 복지사회를 실현을 기본이념으로 함을 밝히고 있다.

또한, 제3조 정의규정의 각호1의 규정의 변화도 큰 의미가 있다. 구법상의 규정은 사회보장이란 질병, 장애, 노령, 실업, 사망 등의 사회적 위험으로부터 모든 국민을 보호하고 빈곤을 해소하며 국민 생활의 질을 향상시키기 위하여 제공되는 사회보험, 공공부조, 사회복지서비스 및 관련복지제도를 말한다고 되어있다.

개정된 규정은 '사회보장'이란 출산, 양육, 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤 및 사망 등의 사회적 위험으로부터 모든 국민을 보호하고 국민 삶의 질을 향상시키는 데 필요한 소득·서비스를 보장하는 사회보험, 공공부조, 사회서비스를 말한다고 하고 있다. 이로써 출산, 양육을 사회적 위험으로 포함하여 보호하도록 하고 있고, 출산과 양육을 사회공동의 책임으로서 대처해야 할 중요한 공적, 사회적 문제로 파악하였다. 즉, 개정된 사회보장기본법에서 입법자는 사회적 위험의 개념 속에 출산과 양육을 포함시킴으로써 사회보장 전체 영역에서 출산과 양육이 단순히 개인의 문제, 사적 영역에서의 문제가 아닌 공공성을 갖는 문제로서 사회와 국가가 함께 대처해야 하는 문제임을 인정하였으며, 이를 위한 명시적 법적 근거를 갖추게 되었다는 점에서 큰 의미가 있다.

또한, 사회복지서비스와 관련 복지제도를 사회서비스로 포괄하여 확대하며, 기본욕구와 특수욕구를 고려하여 소득·서비스를 보장하는 맞춤형 사회보장제도인 평생사회안전망의 개념을 도입함으로써 복지사회 실현의 토대를 마련하였다는 점에서 의의가 있다.

⑶ 생활보호를 받을 권리

1) 내용

헌법 제34조 제5항은 생활능력이 없는 국민에 대한 국가의 보호의무를 규정하고 있다. 따라서 생활능력이 없는 국민은 생활보호를 받을 권리를 가진다.

생활무능력자의 생활보호청구권은 인간다운 생활의 실현을 위한 최소한의 조건이다. 이러한 의미에서 생활무능력자의 생활보호청구권은 사회적 권리의 핵심이자 출발점이 된다. 여기서 생활무능력자라 함은 신체장애, 질병, 노령 기타의 사유로 일할 능력이 없는 자를 의미한다. 실업자는 헌법 제34조 제5항의 의미에서 생활무능력자가 아니다.

2) 구체화 법률들

국민기초생활보호법, 의료급여법, 장애인복지법, 노인복지법, 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률 등이 제정되어 시행되고 있다. 이들 법에 의한 보호청구권은 구체적·개별적 권리이다.[693] 생활보호기준은 입법부와 행정부의 광범위한 재량사항에 속한다.

국민기초생활보호법상의 급여는 생계급여, 주거급여, 의료급여(따로 법률에서 정하도록 위임), 교육급여, 해산급여(解産給與), 장제급여, 자활급여가 있다(제7조 제1항).

<헌법재판소 1997. 5. 29. 94헌마33> 1994 생계보호기준 위헌확인

모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가지며 국가는 생활능력 없는 국민을 보호할 의무가 있다는 헌법의 규정은 입법부와 행정부에 대하여는 국민소득, 국가의 재정능력과 정책 등을 고려하여 가능한 범위 안에서 최대한으로 모든 국민이 물질적인 최저생활을 넘어서 인간의 존엄성에 맞는 건강하고 문화적인 생활을 누릴 수 있도록 하여야 한다는 행위의 지침, 즉 행위규범으로서 작용한다. 그러나 헌법재판에 있어서는 다른 국가기관, 즉 입법부나 행정부가 국민으로 하여금 인간다운 생활을 영위하도록 하기 위하여 객관적으로 필요한 최소한의 조치를 취할

693) 헌법재판소 1997. 5. 29. 94헌마33.

의무를 다하였는지의 여부를 기준으로 국가기관의 행위의 합헌성을 심사하여야 한다는 통제규범으로 작용한다. 그러므로 국가가 인간다운 생활을 보장하기 위한 헌법적인 의무를 다하였는지의 여부가 사법적 심사의 대상이 된 경우에는 국가가 생계보호에 관한 입법을 전혀 하지 아니하였다든가 그 내용이 현저히 불합리하여 헌법상 용인될 수 있는 재량의 범위를 명백히 일탈한 경우에 한하여 헌법에 위반된다고 할 수 있다.

국가가 행하는 생계보호의 수준이 그 재량의 범위를 명백히 일탈하였는지의 여부, 즉 인간다운 생활을 보장하기 위한 객관적 내용의 최소한을 보장하고 있는지의 여부는 생활보호법에 의한 생계보호급여만을 가지고 판단하여서는 아니 되고, 그 외의 법령에 의거하여 국가가 생계보호를 위하여 지급하는 각종 급여나 각종 부담금의 감면 등을 총괄한 수준을 가지고 판단하여야 한다. 그런데 1994년도를 기준으로 생활보호대상자에 대한 생계보호급여와 그 밖의 각존 급여 및 각종 부담감면의 액수를 고려할 때, 이 사건 생계보호기준이 청구인들의 인간다운 생활을 보장하기 위하여 국가가 실현해야 할 객관적 내용의 최소한도의 보장에도 이르지 못하였다거나 헌법상 용인될 수 있는 재량의 범위를 명백히 일탈하였다고 보기 어렵다. 따라서 비록 위와 같은 생계보호의 수준이 일반 최저생계비에 못 미친다고 하더라도 그 사실만으로 곧 그것이 헌법에 위반된다거나 청구인들의 행복추구권이나 인간다운 생활을 할 권리를 침해한 것이라고는 볼 수 없다.

⑷ 재해예방과 위험으로부터의 보호에 관한 권리

헌법 제34조 제6항은 국가에게 재해를 예방하고, 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다는 의무를 부과하고 있다. 이를 위하여 재난 및 안전관리 기본법과 재해구호법이 제정되어 시행되고 있다.

4. 효력 및 제한

인간다운 생활을 할 권리는 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력이 인정된다.

인간다운 생활을 할 권리는 이론상으로는 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있다. 그러나 이때 공공복리를 위하여는 제한될 수 없다. 왜냐하면 인간다운 생활을 할 권리 자체가 공공복리의 내용이기 때문이다.[694] 그러나 생활무능력자의 권리는 인간다운 생활을 할 권리의 본질적 내용이므로 제한될 수 없다.

5. 침해와 구제

인간다운 생활을 할 권리의 침해에 대해서는 위헌법률심사, 헌법소원, 위헌·위법명령심사(이상 적극적 침해), 의무불이행심판청구, 부작위위법확인소송(이상 소극적 침해)이 가능하다.

694) 허영, 전게서, 505면.

♣ 문제풀이

1. 다음 인간다운 생활을 할 권리에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 인간의 존엄성에 상응하고 건강하고 문화적인 최저생활을 말한다.
② 추상적이고 상대적인 개념으로서 그 나라의 문화발달, 역사적·사회적·경제적 여건에 따라 어느 정도 달라질 수 있다.
③ 헌법재판소는 인간다운 생활을 할 권리를 추상적 권리로만 보고 있다.
④ 수준을 결정함에 결코 예산의 유무에 의해 좌우될 것이 아니라 예산편성을 지도하고 지배하여야 한다.
⑤ 생물학적 최저생존수준조차 확보되지 못하는 상태가 방치되는 것은 용납될 수 없다.

[정답] ③

[해설] 최소한의 물질적인 생활의 유지에 필요한 급부를 요구할 수 있는 구체적 권리도 보기도 한다(헌법재판소 1995. 7. 21. 93헌가14).

2. 다음 중 인간다운 생활을 할 권리의 보호를 위한 국가의 의무로 보기 어려운 것은?

① 쾌적한 주거생활의 조성의무
② 노인복지정책의 실시의무
③ 여자의 복지와 권익의 향상의무
④ 재해의 예방의무
⑤ 청소년의 복지향상을 위한 정책의 실시의무

[정답] ①

[해설] 헌법 제35조 제3항에서 규정하고 있다.

3. 다음 사회보장에 관한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 구 생활보호법에 근거하여 보건복지부장관이 정한 생계보호기준에 따라 행해지는 생계보호는 사회보험의 전형적인 형태이다.
② 국가의 직접적 실현에는 일정한 한계가 있으므로 간접적 실현방법도 강구되어야 한다.
③ 국가는 사회 내에서 사회적 정의의 수호자로서의 적극국가·사회국가이다.
④ 사회보장의 실현을 위하여 필요한 경우, 국가는 사인에게 사회적 급부의 일부를 부과할 수도 있다.
⑤ 사회보장의 구체적 수준을 결정하는 입법부 또는 입법에 의하여 다시 위임을 받는 행정부 등 해당기관의 광범위한 재량에 맡겨져 있다.

[정답] ①

[해설] 사회부조의 한 형태이다(헌법재판소 1995. 5. 29. 94헌마33).

♣ 요점정리

1. 우리 헌법재판소는 인간다운 생활을 할 권리는 최소한의 물질적 생활을 요구할 수 있는 권리로 그러한 범위 내에서 구체적 권리라고 한다.

2. 이러한 구체적인 권리는 국가가 재정형편 등 여러 가지 상황들을 종합적으로 감안하여 법률을 통하여 구체화할 때 비로소 인정되는 법률적인 권리라 할 것이다.

3. 인간다운 생활을 할 권리는 입법부나 행정부에 대하여는 행위규범으로서 작용하지만, 헌법재판에 있어서는 통제규범으로 작용한다.

4. 정부가 수익률이 다소 떨어져도 장기적인 안정성에서 충분한 보장이 있는 기금운영방법을 선택했다고 해서 연금가입자의 장래의 연금수급권(재산권)과 인간다운 생활을 침해하는 것은 아니다.

5. 비록 생계보호의 수준이 일반 최저생계비에 못 미친다고 하더라도 그 사실만으로 곧 그것이 헌법에 위반된다거나 청구인들의 행복추구권이나 인간다운 생활을 할 권리를 침해한 것은 아니다.

제37강 환경권 등

♣ 학습목표

환경권에 대해 설명할 수 있다.
혼인과 가족제도에 대해 설명할 수 있다.
모성보호에 대해 설명할 수 있다.
보건권에 대해 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

환경권의 연혁 및 헌법규정, 법적성격 및 주체, 내용, 효력
혼인과 가족제도, 모성보호
국민의 보건권

♣ 사전테스트

1. 우리 헌법은 현행 헌법에서 최초로 환경권을 규정하였다.

정답 : X
해설 : 제8차 개정헌법 제88조에서 규정하였다.

2. 국가는 환경정책의 실현을 위한 재원마련과 환경침해적 행위를 억제하고 환경보전에 적합한 행위를 유도하기 위한 수단으로 수질개선부담금과 같은 환경부담금을 부과·징수할 수 있다.

정답 : O
해설 : 헌법재판소 1998. 12. 24. 98헌가1

3. 치과 전문의 자격시험을 실시하지 않는 것은 국민의 보건권을 침해한다.

정답 : X
해설 : 헌법재판소 1998. 7. 16. 96헌마246

♣ 돌발퀴즈

국민건강보험에 강제로 가입하게 하여 보험료를 부과하는 것은 공법상의 단체에 강제로 가입하지 아니할 자유와 정당한 사유 없는 금전의 납부를 강제당하지 않을 재산권에 대한 제한이다.

[정답] X
[해설] 헌법재판소 2003. 10. 30. 2000헌마801.

♣ 강의내용

1. 환경권

⑴ 연혁 및 헌법규정

1970년 3월 이른바 '동경선언'에서 인간은 누구나 건강이나 복지를 침해하는 요인에 화를 입지 아니할 환경을 향유하는 권리와 장래의 세대에게 현재의 세대가 물려줄 유산인 자연미를 포함한 자연자원을 보존하는 권리를 기본적 인권의 하나로서 가진다고 하는 원칙을 법체계 내에 확립할 것을 우리는 요청하는 결의를 하였다. 이러한 동경선언이 가장 최초로 환경권을 권리로서 주장한 것으로 알려져 있다.

그 후, 1972년 6월에 스웨덴의 스톡홀름에서 개최된 유엔인간환경회의에서 통과된 '인간환경선언'의 원칙에서는 좀 완화된 형태로 규정되었다. 인간은 품위 있고 행복한 생활을 가능하게 하는 환경 속에서 자유, 평등 그리고 적당한 생활조건을 향유할 기본적 권리를 가지며, 현 세대 및 다음 세대를 위하여 환경을 보호, 개선할 엄숙한 책임을 진다고 하면서 인간의 환경권이 기본적 권리의 하나임을 확인하였다.

우리나라에서 환경이라는 주제가 문제되기 시작한 것은 1970년대 초반부터이다. 즉, 1960년대 이후 산업화과정에서 환경이 대규모로 파괴되어 수질오염, 공기오염 등이 사회적으로 커다란 문제를 발생시켰고, 법적차원의 문제로 대두되었다. 이러한 문제들의 인식을 통하여 1980년 8월 15일 제8차 개정헌법 제88조에서는 모든 국민은 깨끗한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 환경을 위하여 노력하여야 한다고 규정하였다. 이는 환경권을 헌법상 권리로서 헌법에 명문화시킨 것으로 환경권을 승인하는 가장 강력한 방안의 하나라고 할 수 있다.[695]

현행 헌법은 제35조 제1항에서 건강하고 쾌적한 환경에서 생활, 제2항에서 환경권의 내용과 한계에 관하여는 법률로 정한다는 것, 제3항에서 쾌적한 주거생활에 대한 국가의 노력을 규정하고 있다.

⑵ 법적성격 및 주체

1) 법적성격

환경권의 법적성격에 관해서는 환경권을 생존권적 기본권에 포함되면서도 자유권적 성격과 생존권적 성격을 아울러 가지는 것으로 보는 견해,[696] 환경권은 총합적 기본권이지만 주된 성격은 사회적 기본권이라고 보는 견해,[697] 환경권은 기본권의 전제조건을 보장하는 기본권으로서의 성질과 기본권의 헌법적 한계로서의 성질을 함께 가지고 있는 종합적인 기본권이라고 하면서 윤리적 인격체로서의 인간의 당연한 생활질서로서의 성질과 법률제도의 보장이라는 제도적 보장의 성질도 함께 내포하고 있다고 보는 견해,[698] 환경권은 국가와 국민을 수범자로 하면 부분적으로 방어권적 성격을 동시에 가지고 있는 사회적 기본권이라고 보는 견해가[699] 있다.

우리 헌법재판소는 환경권에 관한 규정만으로는 그 보호대상이 환경권의 내용과 범위, 권리의 주체가 되는 권리자의 범위 등이 명확하지 못하여 이 규정이 개개의 국민에게 직접으로 구체적인 사법상의 권리를 부여한 것이라고 보기는 어렵고, 사법상의 권리로서의 환경권이 인정되

695) 홍성방, 「헌법학」, 박영사, 2010, 294면.
696) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 753면.
697) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 646면.
698) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 428면.
699) 홍성방, 전게서, 299면.

려면 그에 관한 명문의 법률규정이 있거나 관계법령의 규정 취지나 조리에 비추어 권리의 주체, 대상, 내용, 행사방법 등이 구체적으로 정립될 수 있어야 할 것이라고 판시한 바 있다.[700]

2) 주체

환경권의 주체는 원칙적으로 자연인에 한정되며, 법인의 경우 주체성이 부인된다.

환경권의 주체와 관련하여 미래세대, 즉 아직 태어나지 않은 세대에게 환경보호청구권을 인정할 것인가라는 문제가 부분적으로 논의되고 있다. 이는 자연환경은 인류가 생존할 수 있는 전제조건을 이룬다는 점에서 중요한 의미를 가진다.[701]

그러나 이는 미래세대가 직접 보호청구권을 행사할 수 있다는 의미는 아니다. 즉, 국가는 현재 살고 있는 사람들을 보호해야 할 의무가 있는 것처럼 장래에 살게 될 세대를 보호할 의무가 있다는 것이다. 따라서 현재 살고 있는 우리는 오늘 발생시킨 위험에 대하여 후세대를 보호할 의무가 있기에 깨끗한 환경을 물려줄 수 있도록 노력해야 할 것이다.[702]

<대법원 2007. 6. 28. 2004다54282>

조망이익이 법적인 보호의 대상이 되기 위해서는 어느 토지나 건물의 소유자가 종전부터 향유하고 있던 경관이나 조망이 그에게 하나의 생활이익으로서의 가치를 가지고 있다고 객관적으로 인정된다면 법적인 보호의 대상이 될 수 있는 것인 바, 이와 같은 조망이익은 원칙적으로 특정의 장소가 그 장소로부터 외부를 조망함에 있어 특별한 가치를 가지고 있고, 그와 같은 조망이익의 향유를 하나의 중요한 목적으로 하여 그 장소에 건물이 건축된 경우에 인정된다.

<대법원 2008. 4. 17. 2006다35865>

토지의 소유자 등이 종전부터 향유하던 일조 이익이 객관적인 생활이익으로서 가치가 있다고 인정되면 법적인 보호의 대상이 될 수 있는데, 일반적으로 해당 토지 소유자의 수인한도를 넘게 되면 그 건축행위는 정당한 권리행사의 범위를 벗어나 사법상 위법한 가해행위로 평가된다.

⑶ 내용

1) 개념

환경권은 헌법 제35조 제1항의 건강하고 쾌적한 환경이라는 부분의 '건강하고 쾌적한'이라는 표현을 어떻게 이해하는가에 따라 '좋은 환경을 향유할 권리',[703] '건강한 환경 속에서 생활할 권리 또는 인간다운 생활을 할 수 있는 권리',[704] '인간다운 환경 속에서 생존할 수 있는 권리',[705] '좋은 환경을 향유하고 또한 이것을 지배할 수 있는 권리, 즉 인간이 건강한 생활을 유지하고 쾌적한 생활을 향유하는 권리',[706] '오염되거나 불결한 환경으로 말미암아 건강을 훼손당하거나 훼손당할 위험에 놓인 자가 오염되거나 불결한 환경에 대하여 책임이 있는 공권력이나 제3자에 대하여 그 원인을 예방 또는 배제하여 주도록 요구할 수 있는 권리',[707] '건강하고 쾌

700) 헌법재판소 1995. 5. 23. 94마2218.
701) 홍성방, "환경권의 해석과 관련된 몇 가지 문제점", 「고시연구」, 1996. 3, 67면 이하 참조.
702) 홍성방, 전게서, 300면.
703) 구연창, "환경과 사상", 「법과 공해」, 한국교수회, 1974, 356면.
704) 문홍주, "환경권 서설(상)", 「고시연구」, 1977, 8면; 안용교, "환경권의 법리", 「건국대학교 학술지」 제25집 Ⅰ, 1981, 182면.
705) 김철수, 전게서, 752면.
706) 구병삭, 「헌법학원론」, 박영사, 1988, 583면.

적한 환경에서 공해 없는 생활을 누릴 수 있는 권리',[708] 등으로 의미는 비슷하난 여러 가지 표현으로 정의하고 있다.

이러한 환경의 개념에 대해서는 자연환경만을 의미한다는 견해(협의설),[709] 자연환경과 생활환경을 포함한다는 견해,[710] 자연환경 속에서 살 권리, 즉 자연적인 청정한 대기에 관한 권리, 깨끗한 물에 관한 권리뿐만 아니라 보다 좋은 사회적 환경에서 살 권리, 즉 교육권, 의료권, 도로·공원이용권 등도 포함된다는 견해(광의설),[711] 자연환경과 문화적 유산을 의미한다는 견해[712] 등이 있다.

2) 내용

환경권의 내용에 대해서 견해의 대립이 있으나 환경권의 개념을 '자연환경'으로 한정하면, 환경부담과 환경위험을 회피하고 최소화하기 위한 조건의 총체,[713] 즉 자연적 생활기반을 복구·유지·개선하고 피해를 회피하거나 제거하며 자연자원을 보호하는 것을 목적으로 하는 조치의 총체에[714] 대한 권리를 내용으로 한다고 할 수 있다.

또한, 환경권의 성격을 사회권적 성격과 자유권적 성격을 병유하는 것으로 보면, 결국 환경권은 이러한 조치를 국가에 대하여 요구할 수 있는 권리(사회권적 측면)와 국가(또는 국민)가 자연환경을 파괴하거나 이러한 조치에 대하여 방해를 할 때 그것을 배제할 수 있는 청구권(자유권적 측면)을 그 내용으로 한다고 할 것이다. 전자를 환경복구·유지·개선청구권, 후자를 환경침해배제청구권이라고 표현할 수 있을 것이다.[715]

<헌법재판소 1998. 12. 24. 98헌가1> 구 먹는물 관리법 제28조 제1항 위헌제청

헌법 제35조 제1항·제3항은 환경정책에 관한 국가적 규제와 조정을 뒷받침하는 헌법적 근거가 되며, 국가는 환경정책의 실현을 위한 재원마련과 환경침해적 행위를 억제하고 환경보전에 적합한 행위를 유도하기 위한 수단으로 수질개선부담금과 같은 환경부담금을 부과·징수하는 방법을 선택할 수 있는 것이다.

⑷ 효력과 제한

1) 효력

환경권은 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력을 가진다. 환경권의 직접적 대사인적 효력을 인정하는 견해도[716] 있으나 헌법의 규정에서 직접 사법상의 환경권이 나오는 것이 아니라는 다수설과 판례가 타당하다.[717]

---

707) 권영성, 전게서, 644면.
708) 허영, 전게서, 425면.
709) 홍성방, 전게서, 302면; 허영, 전게서, 418면.
710) 권영성, 전게서, 647면.
711) 김철수, 전게서, 755면; 구병삭, 전게서, 584면; 유경춘·김운용, "환경보전에 관련된 공법상의 문제", 「강원법학」 제1권, 1985, 221면.
712) 김영훈, "환경권과 공법상 구제", 「법학논총」, 숭전대학교 법학연구소, 1985, 21면.
713) W. Hoppe/M. Beckmann, Umweltrecht, 1989, S. 15.
714) R. Stober, Umweltschutzprinzip und Umweltgrundrecht, JZ, 1988, S. 426ff.
715) 홍성방, 전게서 303~304면.
716) 권영성, 전게서, 651면.
717) 대법원 1995. 5. 23. 94마2218.

2) 제한

환경권은 절대적 권리가 아니므로 헌법 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있다. 그러나 환경은 일단 파괴되면 그 회복에 엄청난 시일과 비용이 소요된다는 점을 감안할 때 그 제한에는 극히 신중을 기해야 한다.

또한, 환경권은 합리적인 이유가 있고, 경미한 침해인 때에는 이를 수인하고 감수하여야 한다. 그렇다고 해서 생명·건장에 별로 영향을 미치지 않는 환경침해가 하더라도 무조건 수인해야 하는 것은 아니다. 왜냐하면 환경권의 본질적인 내용은 제한할 수 없으며, 비례의 원칙에 위반한 침해는 환경권의 본질적 내용에 대한 침해가 되기 때문이다.

⑸ 침해와 구제

환경권은 국가권력과 국민(특히 사기업)에 의해 침해될 수 있다. 국가권력에 의해 침해된 경우에는 국가에 대한 청원권의 행사, 행정소송의 제기, 헌법소원, 국가배상청구 등에 의해 구제받을 수 있다. 또한, 행정청의 인·허가의 취소 또는 무효확인을 구하는 행정소송을 제기할 수 있는 것이다. 사인에 의해 침해된 경우에는 손해배상의 청구의 방법이 있다.

그러나 환경침해에 대한 권리구제에도 불구하고 소의 이익 내지 원고적격, 인과관계입증 등의 어려움이 있으므로 환경산업의 육성·발전에 사전적·예방적 권리보호가 강조된다.

이와 병행하여 환경파괴라고 하는 새로운 기본권 침해에 대응한 새로운 적극적인 이론 구성이 요청된다.

2. 혼인·가족·모성보호·보건에 관한 권리

⑴ 연혁 및 헌법규정

혼인과 가족생활에 관한 보호·모성보호·보건권은 1919년 바이마르헌법 제119조에서 최초로 규정되었다. 우리 헌법은 건국헌법 제20조에서 규정하였으며, 제5차 개정헌법에서 혼인의 남녀평등권이 삭제되었다가 제8차 개정헌법에서 개인의 존엄과 양성평등규정을 규정하였으며, 제9차 개정헌법에서 모성보호규정과 국가보호의무 등을 추가하였다.

현행 헌법 제36조는 제1항에서 혼인과 가족생활, 제2항에서 모성보호, 제3항에서 보건권을 규정하고 있다.

⑵ 혼인과 가족제도

1) 법적성격

혼인과 가족제도의 법적성격에 대하여 원칙규범과 제도보장과 자유권과 생존권이 결합된 것으로 보는 견해,[718] 헌법원리를 선언한 원칙규범과 제도보장과 방어권의 성격을 동시에 가진 것으로 보는 견해,[719] 문화민족의 이념을 실현시키는 헌법적 결단이기 때문에 제36조 제1항의 법적성격에 대한 논쟁은 무용한 것이라는 견해,[720] 혼인과 가족생활에 대한 가치결단적 원칙규범

718) 김철수, 전게서, 745~746면.
719) 권영성, 전게서, 266면.
720) 허영, 전게서, 164~165면.

이자 제도보장인 동시에 새로운 혼인관계를 맺을 것을 기본권적으로 보호하고 있다는 견해가[721] 있다.

우리 헌법재판소는 혼인제도와 가족제도에 관한 헌법원리를 규정한 것으로 혼인제도와 가족제도는 인간의 존엄성존중과 민주주의원리에 따라 규정되어야 함을 천명한 것이라 볼 수 있다고 판시한 바 있고,[722] 소극적으로는 국가권력의 부당한 침해에 대한 개인의 주관적 방어권으로서 국가권력이 혼인과 가정이라는 사적인 영역을 침해하는 것을 금지하면서 적극적으로는 혼인과 가정을 제3자 등으로부터 보호해야 할 뿐만 아니라 개인의 존엄과 양성의 평등을 바탕으로 성립되고 유지되는 혼인·가족제도를 실현해야 할 국가의 과제를 부과하고 있다고 판시한 바 있으며,[723] 헌법 제36조 제1항은 혼인과 가족에 관련되는 공법 및 사법의 모든 영역에 영향을 미치는 합헌원리 내지 원칙규범으로서의 성격도 가지는데 이는 적극적으로 적절한 조치를 통해서 혼인과 가족을 지원하고 제삼자에 의한 침해 앞에서 혼인과 가족을 보호해야 할 국가의 과제를 포함하며, 소극적으로는 불이익을 야기하는 제한조치를 통해서 혼인과 가족을 차별하는 것을 금지해야 할 국가의 의무를 포함한다고 판시한 바 있으며,[724] 가족제도에 관한 전통·전통문화란 적어도 그것이 가족제도에 관한 헌법이념인 개인의 존엄과 양성의 평등에 반하는 것이어서는 안 된다는 한계가 도출되므로 전래의 어떤 가족제도가 헌법 제36조 제1항이 요구하는 개인의 존엄과 양성평등에 반한다면 헌법 제9조를 근거로 그 헌법적 정당성을 주장할 수 없다고 판시한 바 있다.[725]

2) 주체 및 내용

혼인할 자유는 전 국가적 자연권으로서 국민과 외국인 그리고 무국적자를 포함하는 모든 자연인에게 주체성이 인정된다.

제36조 제1항은 일부일처제의 제도적 보장과 개인의 존엄과 양성의 평등에 기초한 혼인할 자유와 부부평등을 내용으로 하는 가족제도의 보장을 그 내용으로 한다.

3) 효력 및 제한

혼인할 자유는 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력이 인정된다.

헌법 제36조 제1항에서 다른 법적성격 외에도 결혼할 자유를 추론할 수 있다면 이제 이 자유권은 개별적인 법률유보가 규정되지 않은 이른바 절대적 기본권이라는 의미가 된다. 그럼에도 불구하고 혼인할 자유는 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 행사되어야 하기 때문에 절대적 기본권이라고 할 수는 없다. 즉, 개인의 존엄과 양성의 평등, 결혼 당사자의 자율적인 의사결정 및 인륜에 반하는 중혼(민법 제810조), 축첩, 인신매매적 결혼, 약취·유인적 결혼 등은 금지된다.

뿐만 아니라 합리적인 근거에서 혼인의 자유를 제한 또는 금지하는 것도 위헌이라고 할 수 없다. 예컨대, 미성년자와 금치산자의 혼인에 부모나 후견인의 도의를 얻도록 하는 것(민법 제808조)과 일정한 범위 내의 근친혼을 금지하는 것(민법 제809조 제2항) 등이 있다.

721) 홍성방, 전게서, 314~315면.
722) 헌법재판소, 1997. 7. 16. 95헌가6 등.
723) 헌법재판소 2000. 4. 27. 98헌가16 등.
724) 헌법재판소 2002. 8. 29. 2001헌바82.
725) 헌법재판소 2005. 2. 3. 2001헌가9 등.

⑶ 모성보호

1) 의미

헌법 제36조 제2항은 모성보호를 위한 국가의 노력의무를 규정하고 있다. 그러나 모성, 즉 자녀를 가진 여성은 이러한 국가적 노력의무에 대응하여 모성의 건강뿐만 아니라 모성이 2세를 출산하고[726] 양육하는 데 필요한 경제적·사회적 여건을 조성해 줄 것을 국가에 청구할 수 있다.

2) 구체적 법률

모자보건법은 모성의 생명과 건강을 보호할 것을 규정하고 있고, 모·부자복지법은 모자가정의 생활안정과 복리증진을 도모할 것을 규정하고 있다.

⑷ 보건권

1) 개념

우리 헌법 제36조 제3항은 국민보건에 관한 국가의 보호의무를 규정하고 있다. 이 규정을 근거로 국민은 국가에 대하여 자신과 가족의 건강의 보호를 받을 권리 및 이를 위한 적극적인 보건행정의 실시를 요청할 수 있는 권리를 가진다. 이를 보건권이라고 한다.

2) 법적성격

보건권의 법적성격에 대하여 생존권이라고 보는 견해,[727] 자유권적 성격과 사회권적 성격을 가지지만 주된 성격은 사회적 기본권으로 보는 견해,[728] 국가의 의무를 수반하는 국민의 권리라고 보는 견해가[729] 있다.

<헌법재판소 1998. 7. 16. 96헌마246> 전문의 자격시험 불실시 위헌확인

헌법은 모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다고 규정하고 있는바(제36조 제3항), 이를 보건에 관한 권리 또는 보건권이라 부르고, 국가에 대하여 건강한 생활을 침해하지 않도록 요구할 수 있을 뿐만 아니라 보건을 유지하도록 국가에 대해 적극적으로 요구할 수 있는 권리로 이해한다 하더라도 치과전문의 제도를 시행하고 있지 않기 때문에 청구인을 포함한 국민의 보건권이 현재 침해당하고 있다고 보기는 어렵다.

3) 주체

자연인인 국민이 보건권의 주체가 된다는 데에는 의문이 없다. 보건권의 성질상 법인은 주체가 될 수 없다. 또한, 외국인의 보건권 주체성에 대하여 다수설은 원칙적으로 부정한다.

4) 내용

국가에 의한 건강의 침해금지라는 소극적 내용과 국가에 대하여 국민의 위생과 건강을 유지하는 데 필요한 시설이나 환경을 요구하는 적극적 내용을 가진다.[730]

이러한 보건권을 구체화하는 법률로는 보건의료기본법, 국민건강증진법, 국민건강보험법 등이 있다.

---

726) 헌법재판소 1997. 12. 2.95헌마390.
727) 김철수, 전게서, 750면.
728) 권영성, 전게서, 655면; 홍성방, 전게서, 318면.
729) 허영, 전게서, 423면.
730) 헌법재판소 1998. 7. 16. 96헌다246.

<헌법재판소 2003. 10. 30. 2000헌마801> 국민건강보험법 제62조 제3항 등 위헌확인

건강보험의 문제를 시장경제의 원리에 따라 사보험에 맡기면 상대적으로 질병발생위험이 높거나 소득수준이 낮은 사람들은 보험에 가입하는 것이 매우 어렵거나 불가능하게 되어 국가가 소득수준이나 질병위험도에 관계없이 모든 국민에게 동질의 의료보장을 제공하고자 하는 목적을 달성할 수 없으므로 국민건강보험법 제5조, 제31조 제1항·제2항, 제62조 제1항·제3항·제4항은 원칙적으로 전국민을 강제로 보험에 가입시키고 경제적 능력에 비례하여 보험료를 납부하도록 함으로써 의료보장과 동시에 소득재분배 효과를 얻고자 하는 것이다. 이와 같이 국가가 국민을 강제로 건강보험에 가입시키고 경제적 능력에 따라 보험료를 납부하도록 하는 것은 행복추구권으로부터 파생되는 일반적 행동의 자유의 하나인 공법상의 단체에 강제로 가입하지 아니할 자유와 정당한 사유 없는 금전의 납부를 강제당하지 않을 재산권에 대한 제한이 되지만 이러한 제한은 정당한 국가목적을 달성하기 위하여 부득이한 것이고, 가입강제와 보험료의 차등부과로 인하여 달성되는 공익은 그로 인하여 침해되는 사익에 비하여 월등히 크다고 할 수 있으므로 헌법상 행복추구권이나 재산권을 침해한다고 볼 수 없다.

5) 효력과 제한

보건권은 대국가적 효력과 간접적 대사인적 효력을 가진다.

보건권은 제37조 제2항에 의해 제한될 수 있다. 그러나 공공복리를 위해서는 보건권을 제한할 수 없다. 왜냐하면 보건권 스스로가 공공복리의 내용에 속하기 때문이다. 또한, 어떠한 경우에도 본질적 내용은 제한해서는 안 되며, 비례의 원칙을 준수해야 한다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 환경권에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 환경 그 자체는 권리의 대상이 될 수 없다.
② 환경권은 법인에게 인정되지 않는다는 것이 다수설의 입장이다.
③ 헌법 제35조 제1항은 광고물이나 게시시설로부터 환경권이 침해받지 아니할 것을 포함한다.
④ 생활환경조성청구권을 인정하는 견해에 의하면 환경정책의 결정에 참여할 수 있는 권리도 인정된다.
⑤ 국가는 환경정책 실현을 위한 재원마련과 환경침해적 행위를 억제하고 환경보전에 적합한 행위를 유도하기 위한 수단으로 환경부담금을 부과·징수하는 방법을 선택할 수 있다.

[정답] ④
[해설] 환경정책에 참여할 권리가 나오지 않는다.

2. 다음 중 환경보호의 기본원칙에 해당한다고 볼 수 없는 것은?

① 사전배려의 원칙 ② 원인자책임의 원칙 ③ 규제완화의 원칙
④ 존속보장의 원칙 ⑤ 협동의 원칙

[정답] ③
[해설] 규제를 완화하는 것은 환경보호와는 무관하다.

3. 다음 모성보호에 관한 기술 중 바르지 못한 것은?

① 국가의 모성보호의 의무와 모성의 국가적 보호를 받을 권리를 규정하고 있다.
② 모성은 생리·임신·출산·양육 등의 기능으로 이해되어야 하며, 이러한 모성의 보호를 받을 주체는 모든 여성이다.
③ 모성의 보호는 반드시 모성의 건강보호에 한정되는 것이 아니라 그 밖의 인간다운 생활을 위한 사회보장·근로보호 등까지 포괄하는 의미이다.
④ 보건복지부장관은 우생학적 또는 유전학적 정신장애나 신체질환의 유전 또는 전염의 방지를 위해 의사를 지정하여 불임수술을 명령할 수 있다.
⑤ 모성의 보호는 그 정도에 있어 단순한 차별의 철폐에 있는 것이 아니라 적극적인 보호에 있다.

[정답] ④
[해설] 인권침해 논란으로 삭제된 규정이다.

♣ 요점정리

1. 1980년 8월 15일 제8차 개정헌법 제88조에서는 모든 국민은 깨끗한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 환경을 위하여 노력하여야 한다고 규정하였다.

2. 국가는 환경정책의 실현을 위한 재원마련과 환경침해적 행위를 억제하고 환경보전에 적합한 행위를 유도하기 위한 수단으로 수질개선부담금과 같은 환경부담금을 부과·징수하는 방법을 선택할 수 있는 것이다.

3. 헌법 제36조 제1항은 혼인과 가족에 관련되는 공법 및 사법의 모든 영역에 영향을 미치는 합헌원리 내지 원칙규범으로서의 성격을 가지며, 적극적으로 적절한 조치를 통해서 혼인과 가족을 지원하고 제삼자에 의한 침해 앞에서 혼인과 가족을 보호해야 할 국가의 과제를 포함하며, 소극적으로는 불이익을 야기하는 제한조치를 통해서 혼인과 가족을 차별하는 것을 금지해야 할 국가의 의무를 포함한다.

4. 치과전문의 제도를 시행하고 있지 않기 때문에 국민의 보건권이 현재 침해당하고 있다고 보기는 어렵다.

5. 국가가 국민을 강제로 건강보험에 가입시키고 경제적 능력에 따라 보험료를 납부하도록 하는 것은 정당한 국가목적을 달성하기 위하여 부득이한 것이다.

제38강 참정권적 기본권 일반론

♣ 학습목표

참정권적 기본권에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

참정권의 개념, 기능, 법적성격, 주체
선거권, 공무담임권, 광의의 국민투표권
국민표결(협의의 국민투표), 국민소환, 국민발안
참정권의 효력, 제한

♣ 사전테스트

1. 참정권은 자연법상의 권리이다.

정답 : X
해설 : 실정법상의 권리이다.

2. 선거연령은 헌법에서 규정하고 있다.

정답 : X
해설 : 헌법의 위임에 따라 공직선거법 등 법률에서 규정하고 있다.

3. 우리 헌법은 선거권에 대해 개별적 법률유보를 두고 있다.

정답 : O
해설 : 헌법 제24조

♣ 돌발퀴즈

우리나라는 대의제를 보완하기 위해 국민투표, 국민발안, 국민소환을 채택하고 있다.

[정답] X
[해설] 현행 헌법은 공무원선거권(제24조), 공무담임권(제25조), 협의의 국민투표권(제72, 제130조)을 규정하고 있고, 주민발안제는 지방자치법 제15조에서 이를 규정하고 있다.

♣ 강의내용

1. 개념 및 기능

⑴ 개념

참정권은 국민이 국가의 구성원으로서 국가권력의 창설과 국가의 권력행사과정에 참여함으로써 자신의 정치적 견해를 국정에 반영할 수 있는 권리이다. 달리 표현하면 참정권은 피치자인 국민이 치자의 입장에서 공무원을 선거하고 공무를 담임하는 권리이다. 참정권을 정치권이라고 부르는 학자도 있다.[731]

⑵ 기능

참정권은 오늘날의 민주정치에 있어서는 국민이 국가권력의 창설과 국가의사의 형성과정에 참여하거나 국가기관을 구성하고 국가권력행사를 통제 내지 견제하는 기능을 하며, 그를 통하여 국가권력에 정당성을 부여한다. 또한, 현실적인 정치사안에 대한 국민의 다양한 의사가 선거와 국민투표 등을 통하여 구체적인 모습으로 나타나기 때문에 참정권은 국민의 정치적 공감대를 형성하기 위하여 필수적인 수단이라고 할 수 있다. 따라서 참정권은 민주정치에서 필수적인 민주적·정치적 권리이며, 개별적인 국민의 능동적인 공권이다. 참정권은 국민주권의 표현이다.

2. 법적성격

국내 다수설은 참정권을 전 국가적 자연권이 아닌 국가내적 권리로 보는데 의견이 일치되어 있다. 그러나 참정권이 권리만을 내용으로 하느냐 또는 권리와 동시에 의무를 포함하느냐에 대해서는 권리설과 권리·의무병존설이 대립하고 있다.

권리설은 다시 판단주의적 입장과 종합주의적 입장으로 나누어진다. 판단주의적 입장은 참정권은 일종의 제한적이고 상대적인 권리에 불과하고 천부적 성질은 없으며 국가기관으로서의 국민을 의제하고 이 국가기관에 참가할 수 있는 권리를 참정권으로 본다. 종합주의적 입장은 참정권은 국가권력을 창설하고 국가권력이 정당성을 부여하는 민주시민의 정치적인 기본권으로서 국가를 향한 권리로서의 성격을 지닌다고 본다.

그에 반하여 권리·의무병존설은 참정권은 개개의 국민이 국가에 대하여 능동적 발언권을 가지는 것을 내용으로 한다는 점에서는 국민 각자의 권리로서의 성격을 갖지만 참정권에는 국가의 이익을 위해 이를 적절하게 행사할 도의적·윤리적 의무가 수반된다고 본다. 다수설은 참정권을 권리이자 의무로 보고 있다.

기본권은 인권에서 유래한 것이며, 인권이 헌법에 수용된 것을 기본권이라는 입장에 의하면, 참정권도 전국가적 자연권을 헌법에 실정화한 것에 해당한다. 즉, 참정권도 인권과는 관계없이 헌법에 의하여 비로소 창설된 권리가 아니며, 다만 헌법제정권자가 여러 가지 사정을 고려하여 원칙적으로 국민인 자만이 그것을 행사할 수 있도록 그 주체를 한정한 것으로 해석하는 것이 타당하다고 한다.

참정권이 권리 이외에 법적의무를 포함하고 있는가 하는 문제는 우리 헌법의 어디에도 선거에 참여가 강제되고 있지 않은 점으로 보아 이를 부정할 수밖에 없다.[732] 그러나 참정권이 법적

731) 문홍주, 「제6공화국 한국헌법」, 해암사, 1988, 319면; 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 510면.

의무를 포함하고 있지 않다는 것은 기권자에 대하여 제재를 가하는 것을 금지하는 것일 뿐, 참정권을 국가의 이익을 위하여 적절하게 행사할 도의적 의무까지를 부인하는 것으로 해석할 수는 없을 것이다. 또한, 참정권은 국가권력에 창설적·정당성부여적 기능 때문에 객관적 가치질서로서의 성질도 함께 가지고 있다.[733]

3. 주체

(1) 국민

참정권은 원칙적으로 국민에게만 주체성이 인정된다. 그러나 국민이 참정권을 행사하려면 일정한 연령에 달하여야 한다.

현행 헌법은 제24조에서 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다고 규정하여 선거연령을 법률에 위임하고 있고, 이 규정을 규체화한 각종 선거법은 만19세로 선거권자를 정하고 있다(공직선거법 제15조).

또한, 헌법 제25조는 공무담임권에 대해서도 법률로 정하도록 하고 있다. 이에 따라 공직선거법은 국회의원과 지방의회의원 및 지방자치단체의 장은 18세 이상, 대통령은 40세 이상으로 피선거권연령을 정하고 있다(공직선거법 제16조).

공무원의 경우에도 헌법 제25조에 따라 개별공무원 관계 법률에서 연령 등에 대하여 제한을 둘 수 있다.

<헌법재판소 1997. 6. 26. 96헌마89> 공직선거 및 선거부정방지법 제15조 위헌확인

입법자가 공직선거 및 선거부정방지법에서 민법상의 성년인 20세 이상으로 선거권연령을 합의한 것은 미성년자의 정신적·신체적 자율성의 불충분 이외에도 교육적 측면에서 예견되는 부작용과 일상생활 여건상 독자적으로 정치적인 판단을 할 수 있는 능력에 대한 의문 등을 고려한 것이다. 선거권과 공무담임권의 연령을 어떻게 규정할 것인가는 입법자가 입법목적 달성을 위한 선택의 문제이고 입법자가 선택한 수단이 현저하게 불합리하고, 불공정한 것이 아닌 한 재량에 속하는 것인바, 선거권연령을 공무담임권의 연령인 18세와 달리 20세로 규정한 것은 입법부에 주어진 합리적인 재량의 범위를 벗어날 것으로 볼 수 없다.

소수의견 : 대한민국 수립 이래 지속적으로 향상해 온 국민의 교육수준, 국가와 사회의 민주화, 그 사이의 엄청난 국가경제의 발전 및 국민의 경제·문화수준의 향상, 현실적으로 보장되는 언론의 자유와 언론매체의 발달 등을 종합적으로 고려한다면 이미 18~19세 연령층의 국민은 스스로 정치판단을 할 최소한의 능력이 있다고 보아야 한다. 다만, 우리는 입법자가 정치의 민주화가 본격적으로 시작된 90년대에 들어와서야 비로소 선거연령에 관한 문제를 인식할 수 있었고, 아직 변화한 현실에 적응한 시간적인 여유도 갖지 못하였으므로 선거연령을 20세로 규정하는 이 사건 법률조항은 아직 헌법에 위반되는 것으로 판단되지 아니한다. 그러나 입법자는 이러한 변화를 고려하여 보통선거원칙에 보다 부합되고 또한 장래에 있어서 그에 대한 위반을 배제할 수 있는 합리적인 해결책을 노력해야 한다.

732) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 829면.
733) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 508면.

⑵ 법인과 외국인의 주체성

1) 법인

법인이 참정권의 주체가 되는가의 문제에 대해서는 참정권은 자연인의 권리이므로 법인에게는 참정권이 인정되지 않는다는 견해,[734] 정당에 대해서는 정치적 기본권을 인정할 수 있다는 견해,[735] 법인은 사법인이든 공법인이든 생활공동체의 구성부분임에 틀림없고 개개의 인간이 동화되고 통합되어 가는 과정에서 형성될 수 있는 동화적 통합의 형식인 동시에 수단이라고 볼 수 있기 때문에 정치적으로 가치적인 동질성 집단이라고 볼 수 있는 정당이 동화적 통합의 과정인 동시에 수단이기 때문에 마땅히 기본권의 주체가 되어야 한다면 법인도 같은 차원에서 기본권주체성을 인정하는 것이 타당하다는 견해,[736] 일차적으로는 자연인에게만 귀속되며, 예외적으로 법인을 구성하는 구성원인 자연인의 기본권행사를 용이하게 해주고, 촉진시켜 주는 한에서만 법인에게 기본권 주체성이 인정된다고 보는 견해가[737] 있다.

그러나 정당을 포함하여 법인에게 참정권의 주체성을 인정하는 것은 타당하지 않다고 한다. 왜냐하면 예외적으로 법인에게 참정권의 주체성을 인정하는 경우라 하더라도 개인에게 참정권(선거권)을 인정하면서 법인에게도 참정권(선거권)을 인정한다면 그것은 법인의 구성원에게는 자연으로서 또 법인의 구성원으로서 이중으로 참정권(선거권)을 인정하는 결과가 되어 평등의 원리에 반하게 될 것이기 때문이다.[738]

2) 외국인

참정권은 국민의 권리이기 때문에 외국인에게는 주체성이 인정되지 않는다는 것이 국내의 다수의 견해이다.[739]

그러나 참정권도 전국가적 자연권이 헌법에 수용된 것이라고 보는 견해에 의하면, 일정한 조건을 갖춘 장기체류 외국인에게는 호혜주의적 입장에서 단계적으로 선거권을 부여하는 것이 이론적으로나 국제적인 추세에도[740] 부합할 것이다.

스웨덴은 1976년 9월 선거부터, 덴마크는 1978년 3월 선거부터 3년 이상 거주한 외국인에게 지방의회 선거에서 선거권·피선거권이 부여되었고, 1983년 네델란드 헌법은 네델란드에 주소가 있고 네델란드에서 요구되는 선거법상의 요건을 충족하는 외국인에 대해서 선거원·피선거권을 법률에 의해서 부여할 수 있도록 했다. 또한, 스페인헌법 제13조 제2항은 호혜주의원칙에 따라 외국인에게 선거권·피선거권을 부여하고 있고, 유럽은 Maastricht조약에 의해 EU시민에게는 EU 각국의 지방선거권이 개방되었다.

이와 관련하여 국회는 2005. 8. 4. 공직선거법을 개정하여 출입국관리법 제10조(체류자격)의 규정에 따른 영주의 체류자격 취득일 후 3년이 경과한 19세 이상의 외국인으로서 제37조 제1항의 선거인명부 작성기준일 현재 출입국관리법 제34조(외국인등록표 등의 작성 및 관리)의 규정에 따라 당해 지방자치단체의 의회의원 및 단체장의 선거권을 부여하였다.(제12조 제2항 제2호).

734) 김철수, 전게서, 829면.
735) 권영성, 전게서, 309면.
736) 허영, 전게서, 235면.
737) 홍성방, 「헌버학」(중), 박영사, 2010, 325면.
738) 홍성방, 상게서, 325면.
739) 김철수, 전게서, 829면; 권영성, 전게서, 304면; 허영, 전게서, 234면.
740) BVerfGE 89, 155, 171f.; 41, 9, 11f.

4. 내용 및 분류

⑴ 내용

참정권은 선거권, 공무담임권, 광의의 국민투표권을 내용으로 한다. 광의의 국민투표, 즉 국민이 직접 국정에 참여할 수 있는 제도에는 국민표결(협의의 국민투표), 국민소환(국민파견), 국민발안(국민입법)이 있다.

우리 헌정사상 국민투표제도는 1954년 11월 29일 제2차 개헌에 의하여 제7조의2에 주권의 제약·영토의 변경 등 중대한 사항에 대하여 국민투표를 규정함으로써 처음 도입되었다.

<제2차개헌 제7조의2>

① 대한민국의 주권의 제약 또는 영토의 변경을 가져올 국가안위에 관한 중대사항은 국회의 가결을 거친 후에 국민투표에 부하여 민의원 선거권자 3분지 2이상의 투표와 유효투표 3분지 2 이상의 찬성을 얻어야 한다.

② 전항의 국민투표의 발의는 국회의 가결이 있은 후 1개월 이내에 민의원의원 선거권자 50만인 이상의 찬성으로써 한다. 국민투표에서 찬성을 얻지 못할 때에는 제1항의 국회의 가결사항은 소급하여 효력을 상실한다.

③ 국민투표의 절차에 관한 사항은 법률로써 정한다.

국민발안제도는 1962년 헌법에서 채택된 바 있다. 제119조의 제2항에서 헌법개정의 제안은 국회의원선거권자 50만인 이상의 찬성으로서 한다고 규정하였다. 그러나 국민소환제도는 아직까지 채택된 바 없다.[741] 현행 헌법은 공무원선거권(제24조), 공무담임권(제25조), 협의의 국민투표권(제72, 제130조)을 규정하고 있다.

1) 국민투표권

<헌법재판소 2014. 7. 24. 2009헌마256> 재외선거인 선거권 및 국민투표권

헌법 제72조의 중요정책 국민투표와 헌법 제130조의 헌법개정안 국민투표는 대의기관인 국회와 대통령의 의사결정에 대한 국민의 승인절차에 해당한다. 대의기관의 선출주체가 곧 대의기관의 의사결정에 대한 승인주체가 되는 것은 당연한 논리적 귀결이다. 재외선거인은 대의기관을 선출할 권리가 있는 국민으로서 대의기관의 의사결정에 대해 승인할 권리가 있고, 국민투표권자에는 재외선거인이 포함된다고 보아야 한다. 또한, 국민투표는 선거와 달리 국민이 직접 국가의 정치에 참여하는 절차이므로, 국민투표권은 대한민국 국민의 자격이 있는 사람에게 반드시 인정되어야 하는 권리이다. 이처럼 국민의 본질적 지위에서 도출되는 국민투표권을 추상적 위험 내지 선거기술상의 사유로 배제하는 것은 헌법이 부여한 참정권을 사실상 박탈한 것과 다름없다. 따라서 국민투표법 조항은 재외선거인인 나머지 청구인들의 국민투표권을 침해한다. 만약 국민

741) 현재 주민소환제는 인정되고 있다. 주민소환제도는 지방자치단체의 장 및 지방의회 의원의 위법·부당한 행위, 직권 남용 등의 통제와 지방자치에 관한 주민의 직접참여의 확대 및 지방행정의 민주성·책임성의 제고를 목적으로 한다. 주민소환에 관한 법률은 2006년 5월 24일 제정되어 2007년 7월부터 시행되었다. 제주특별자치도에서의 주민소환은 제주특별자치도설치 및 국제자유도시조성을 위한 특별법에 의해 규율된다. 2009년까지 주민소환투표는 2번 실시되었다. 2007년 12월 12일경기도 하남시에서 지역 단체장이 주민들의 동의 없이 광역 장사시설 유치를 발표하였다는 이유로 주민소환 투표가 실시되었는데, 법률에서 정한 33.3%에 미달되는 31.3%의 투표율로 무산되었다. 또한 2009년 8월 6일 해군기지 건설과 관련한 제주특별자치도지사에 대한 주민소환 투표가 실시되었으나 투표율 11%로 무산된 바 있다.

투표법 조항이 위헌으로 선언되어 즉시 효력을 상실하면 국민투표를 실시하고자 하여도 투표인명부를 작성할 수 없게 되므로, 입법자가 국민투표법조항을 개선할 때까지 일정기간 국민투표법조항을 잠정적으로 적용할 필요가 있다. 또한 국민투표의 절차상 기술적인 측면과 국민투표의 공정성확보의 측면에서 해결되어야 할 많은 문제들이 존재한다. 입법자는 이러한 문제에 대한 충분한 논의를 거쳐 재외국민투표제도를 형성하여야 하고, 재외선거인에게 국민투표권을 부여하는 구체적인 방안은 입법자의 입법형성의 범위 내에 있다. 그러므로 국민투표권조항에 대하여 헌법불합치결정을 선고하되, 다만 입법자의 개선입법이 있을 때까지 계속적용을 명하기로 한다. 입법자는 늦어도 2015. 12. 31.까지 개선입법을 하여야 한다.

2) 국민소환

선거에 의하여 선출된 대표 중에서 유권자들이 부적격하다고 생각하는 자를 임기가 끝나기 전에 국민투표에 의하여 파면시키는 제도이다. Recall, 국민파면이라고도 한다.

고대그리스에서 유래되어 오늘날에는 스위스의 몇 개 주, 일본의 지방자치단체 등에서 채택하고 있다. 이 제도는 국민이 선임하였기 때문에 해임도 같은 방법으로 하여야 한다는 데 그 이론적 근거를 두고 있으나 오늘날의 선거인구의 폭발, 정치적 무관심, 행정기능의 확대 등으로 인해서 그 의미를 상실하고 있다. 한국에서는 자유당 말기에 국회의원의 소환문제가 논의된 사례가 있었으나 제도화되지는 못하였다.

3) 국민발안

직접민주주의의 한 형태로서 선거권자들이 연대 서명을 통해 중요 법률이나 조례의 제·개정안, 헌법개정안, 헌장수정안 등을 행정부나 입법부에 요구할 수 있는 제도를 말한다. Initiative 또는 국민입법이라고 하며, 적용 범위에 따라 국민 발안제와 주민 발안제로 부르기도 한다.

이러한 발안제는 1891년에 스위스 연방 공화국의 연방헌법에서 처음 규정되었다. 이 후, 1777년에 미합중국의 조지아주 헌법에서 등장하였으며, 1922년에 아일랜드 자유국의 헌법에서도 등장하였고, 에스토니아의 1920년 헌법에서 부분적으로 규정되기도 하였다.

우리나라에서는 1954년 제2차 개헌에서, 헌법개정에 대하여 국회의원선거권자 50만인 이상의 찬성으로 제안할 수 있게 하는 국민 발안제가 채택되었으나 사실상 사문화된 조항이라 판단되어 1972년 제7차 개헌(또는 유신 개헌)에서 폐지되었다. 그러나 이후 1999년 8월 31일 지방자치법을 개정하면서 '지방자치단체의 국회의원선거권자는 만20세 이상의 주민 총수의 20분의 1의 범위 안에서 대통령령이 정하는 20세 이상의 주민 수 이상의 연서로 당해지방자치단체의 장에게 조례의 제정이나 개폐를 청구할 수 있다'는 내용을 담은 '조례의 제정과 개폐 청구' 항목(제13조의3)을 신설하여 주민 발안제의 근거를 마련하였다. 그 후, 2008년 지방자치법 제15조에서 이를 규정하고 있다.

⑵ 분류

참정권은 국민이 국가의 의사형성에 참여하는 방법에 따라 직접적 참정권(국민발안, 국민투표, 국민소환)과 간접적 참정권(선거권, 공무담임권)으로 분류할 수 있다.

5. 효력과 제한

⑴ 효력

참정권은 대국가적 효력을 가진다. 다수설에 따르면 공무담임권과 소급입법에 의한 참정권의 제한은 대사인적 효력이 부정되며, 그 이외의 참정권은 직접적 대사인적 효력이 인정된다.

⑵ 제한

참정권이 헌법에 의하여 제한되는 경우는 헌법 제67조 제4항에서 대통령의 피선거권을 제한하고 있는 경우이며, 법률에 의해 제한되는 경우는 헌법 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있다. 그러나 참정권의 본질적인 내용은 침해할 수 없고, 비례의 원칙은 준수되어야 한다.

선거권과 피선거권을 제한하는 법률로는 공직선거법(제18조, 제19조)과 국민투표법(제9조) 등이 있다.

<헌법재판소 1997. 12. 24. 97헌마16> 공직선거 및 선거부정방지법 제18조 제3항 위헌확인

선거권과 피선거권은 민주정치에 있어서 주권자인 국민이 국정에 참여하는 필수적인 수단으로서 가장 중요한 기본권에 해당하므로 그 제한은 불가피한 최소한에 그쳐야 하며, 제한여부나 제한기간 등은 선거범죄의 죄질과 가벌성의 정도에 부합되어야 한다.

참정권에는 기본권 제한적 법률유보 외에도 기본권 구체화적 법률유보가 규정되어 있다. 즉, 입법자에게는 참정권의 내용을 자세하게 규정할 수 있는 권한이 부여되어 있다. 따라서 입법자는 참정권을 구체화하는 과정에서 참정권이 제한되는 일이 없도록 각별한 주의를 기울일 것이 요청된다. 이러한 주의의무를 다하지 않아 국민의 참정권이 제한되는 경우, 그러한 법률은 위헌임을 면하기 어렵다.

우리 헌법재판소는 공직선거에 입후보하는 데 과도한 기탁금을 내도록 하여 경제력이 약한 계층의 참정권을 제한한 법률조항을 위헌으로 판시한 바 있으며,[742] 선거운동원이 아닌 사람의 선거운동을 금지한 구 대통령선거법을 참정권을 구체화하는 과정에서 참정권을 제한한 것으로 보아 위헌선언 한 바 있다.[743] 그러나 여론조사결과의 공표를 금지하는 공직선거법 제108조에 대해서 전면적으로 금지하는 것은 표현의 자유 및 과잉금지원칙에 반하고, 자유로운 선거권의 행사를 제한하게 된다고 하면서도, 다만 선거의 과열과 무질서를 막기 위해 선거일 1주일이나 3~4일 전부터의 공표금지는 합리적인 제한으로 허용될 수 있다고 판시하였다.[744]

♣ 문제풀이

1. 다음 참정권에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 민주국가에서 참정권은 언론·출판의 자유와 함께 국민주권원리를 실천하고 국가의 정치적 질서를 형성하는 기능을 한다.
② 참정권을 가진 유권자로서의 국민은 정치적 통일체에 있어서의 국민을 전제로 한다.
③ 참정권은 권리인 동시에 의무로서의 성격도 가지고 있다.

---

742) 헌법재판소 1989. 9. 8. 88가6; 1991. 3. 11. 91헌마21; 2001. 7. 19. 2000헌마91 등.
743) 헌법재판소 1994. 7. 29. 93헌가4 등.
744) 헌법재판소 1998. 5. 28. 97헌마177 등.

④ 국가를 국민의 정치적 통일체라고 하는 경우의 국민은 주권보유자로서의 국민을 말한다.
⑤ 참정권은 국가적 조직에 속한 시민의 권리를 말한다.

[정답] ④
[해설] 주권행사자로서의 유권적 시민을 의미한다.

2. 다음 국민발안제에 대한 설명 중 바르지 못한 것은?
① 국민이 직접 헌법개정이나 법률의 제·개정에 있어 그 안을 제안할 수 있는 권리이다.
② 통상은 법률안에 대한 국민발안을 말하고, 국민이 직접 법률안의 조문까지 작성하는 경우와 국민이 의회에 일정한 내용의 법률안을 작성을 요구하는 경우가 있다.
③ 어떠한 의안의 제안이 곧 국민투표에 부의되는 직접발안과 의회의 의결 후에 그 제안이 국민투표에 부의되는 간접발안이 있다.
④ 건국헌법에서 최초로 헌법개정에 대한 국민발안제를 채택한 바 있다.
⑤ 국민발안은 자칫하면 조잡한 법안을 등장시킬 우려가 있다.

[정답] ④
[해설] 제2차 개정헌법 제7조의 2

3. 다음 중 우리 헌법상 인정되지 않는 것은?(다툼이 있는 경우 판례에 의함)
① 대형국책사업을 주민투표법의 대상에서 제외하는 것
② 제대군인이 공무원채용시험 등에 응시한 때에 가산점을 주도록 하는 것
③ 선거사무소 또는 선거연락소 외에는 후보자를 위한 유사기관의 설치를 금지하는 것
④ 피선거권이 제한되는 벌금액의 차이를 두는 것
⑤ 일정한 형에 집행 중에 있는 자에게 선거권과 피선거권을 부여하지 않는 것

[정답] ②
[해설] 헌법재판소 1999. 12. 23. 98헌바33.

♣ 요점정리

1. 참정권은 국민이 국가의 구성원으로서 국가권력의 창설과 국가의 권력행사과정에 참여함으로써 자신의 정치적 견해를 국정에 반영할 수 있는 권리이다.

2. 참정권은 오늘날의 민주정치에 있어서는 국민이 국가권력의 창설과 국가의사의 형성과정에 참여하거나 국가기관을 구성하고 국가권력행사를 통제 내지 견제하는 기능을 하며, 그를 통하여 국가권력에 정당성을 부여한다.

3. 참정권은 원칙적으로 국민에게만 주체성이 인정된다. 그러나 국민이 참정권을 행사하려면 일정한 연령에 달하여야 한다.

4. 현행 헌법은 공무원선거권(제24조), 공무담임권(제25조), 협의의 국민투표권(제72, 제130조)을 규정하고 있고, 주민발안제는 지방자치법 제15조에서 이를 규정하고 있다.

5. 여론조사결과의 공표를 금지하는 공직선거법 제108조에 대해서 전면적으로 금지하는 것은 표현의 자유 및 과잉금지원칙에 반하고, 자유로운 선거권의 행사를 제한하게 된다고 하면서도, 다만 선거의 과열과 무질서를 막기 위해 선거일 1주일이나 3~4일 전부터의 공표금지는 합리적인 제한으로 허용된다고 한다.

제39강 선거권

♣ 학습목표

선거권에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

선거권의 연혁
선거의 의의
보통선거, 평등선거, 직접선거, 비밀선거, 자유선거
선거권의 의의
공직선거법
선거권결격사유

♣ 사전테스트

1. 우리 헌법에는 보통·평등·직접·비밀·자유선거의 원칙이 명시되어 있다.

정답 : X
해설 : 우리 헌법은 자유선거의 원칙을 명시적으로 규정하고 있지 않다.

2. 평등선거란 성별·재산·학력·직업·종교 또는 사회적 신분 등을 근거로 선거권을 제한하는 것은 인정되지 않는다는 것이다.

정답 : X
해설 : 보통선거에 대한 설명이다.

3. 보통선거란 모든 선거참여자가 여러 가지 대안 가운데서 자유롭게 선택할 수 있도록 자유로운 정당의 설립과 활동을 비롯한 정치적 자유권이 보장될 것을 요구한다.

정답 : X
해설 : 평등선거에 대한 설명이다.

♣ 돌발퀴즈

민주주의 국가에서는 어떠한 경우에도 선거권의 행사를 정지시키는 것은 허용될 수 없다.

[정답] X
[해설] 수형자의 선거권은 제한될 수 있다(헌법재판소 2004. 3. 25. 2002헌마411).

♣ 강의내용

1. 연혁 및 헌법규정

근대적 선거가 실시되면서 바로 모든 사람들이 선거권을 가진 것은 아니었다. 18세기 이전에는 성인 남성인구 중 재산, 신분, 인종에 따라 선거권이 제한되어 있었고, 차츰 일정수준 이상의 재산 소유자로부터 시작하여 중산층, 상층노동자, 성인남성, 그리고 마지막에는 성인여성까지 선거권을 가진 자의 범위가 확대되었다.

영국은 1838년에서 1848년 사이 노동자층을 중심으로 한 민중운동인 '차티스트 운동'을 통해 부유한 사람에게 한정 되었던 선거권이 점차노동자, 농민에게 확대되었고, 모든 성인남녀에게 선거권이 인정된 보통선거제는 1928년이 되어서야 인정되었다.

미국은 19세기 초에 노예제 폐지운동이 일어나면서 여성선거권 쟁취투쟁이 시작되어 1920년에 이르러서야 헌법 개정을 통해 여성이 남성과 동등하게 선거권을 행사 할 수 있게 되었다. 이처럼 세계 여러 나라에서 오늘날과 같은 보통선거제도가 확립된 것은 시민들이 선거권 획득을 위하여 끊임없이 투쟁한 결과이다. 선거권 확대를 위해 투쟁해 온 역사는 바로 정치참여가 확대되는 과정이었으며, 정치참여 확대의 과정은 곧 민주주의 정치가 발전하고 확산되는 역사였다.

선거권을 처음으로 규정한 헌법문서는 국민주권원리를 처음으로 채택한 1791년 프랑스헌법으로 알려져 있다. 당시 헌법 제1장 제2절 제2조에서는 투표일 현재 만25세이며 1년 이상 프랑스에 주소를 가진 자로서 어느 집의 하인이 아니고 매년 비교육노동자의 3일분 임금에 해당하는 직접세를 납부한 남자만을 투표권자로 규정하였다.

따라서 오늘날과 같은 형태의 보통선거권은 만20세 이상의 독일인에게 보통·평등·직접·비밀선거에 참여할 수 있는 권리를 부여한 바이마르헌법 제22조와 그를 구체화한 1920년 4월 27일의 제국선거법에 의하여 확립되었다고 할 수 있다. 스위스의 경우에는 1971년에야 비로소 여자에게 선거권이 인정되었다.

우리 헌법 제24조는 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다고 규정하고 있다. 그 밖에도 헌법 제41조 제1항은 국회는 국민의 보통·평등·직접·비밀선거에 의하여 선출된 국회의원으로 구성한다고 하고 있고, 제67조 제1항은 대통령은 국민의 보통·평등·직접·비밀선거에 의하여 선출된다고 하고 있으며, 제118조 제2항은 지방의회의 조직·권한·의원선거와 지방자치단체의 장의 선임방법 기타 지방자치단체의 조직과 운영에 관한 사항은 법률로 정한다고 규정하고 있다.

이러한 선거권은 나라에 따라 기본권에서 규정하기도 하고, 통치구조에서 규정하기도 한다. 예컨대, 프랑스 5공화국 헌법은 제2조에서, 스위스헌법과 독일기본법은 연방의회에 관한 부분에서, 이탈리아헌법과 캐나다헌법은 시민의 권리에서, 미국헌법은 수정헌법 제15조와 제19조에서 흑인과 여성의 투표권만 규정하고 있으나 수정헌법 제1조에서 보장된다고 보며, 투표세와 같은 것은 평등권의 침해로 보고 있다.[745]

745) Harper v. Virginia Board of Elections, 383 U. S. 664, 1966.

2. 선거의 의의 및 선거의 원칙

⑴ 선거의 의의

선거란 대표자나 기관을 선임하는 행위를 말한다. 오늘날과 같이 대부분의 민주국가가 대의민주제를 채택하고 있는 경우에는 국민의 대표기관이 미리 정해진 시간적 간격을 두고 정기적으로 국민에 의하여 선출되는 것은 매우 중요한 의미를 가진다. 대의민주제에서 선거를 통하여 주권자인 국민은 자신의 주권을 행사하며, 이에 의해 정치지도자는 민주적 정당성을 얻게 된다. 즉, 선거를 통하여 한편으로는 정치지도자는 정당화되고 권위를 부여받으며, 다른 한편으로는 치자와 피치자 사이에 동질성이 창출된다고 하겠다.[746]

<헌법재판소 1989. 9. 8. 88헌가6> 국회의원선거법 제33조, 제34조의 위헌심판

주권자인 국민은 선거를 통하여 직접적으로 국가기관의 구성원을 선출하고 간접적으로 여하한 정부를 원하느냐에 관한 국민의 의사를 표시한다. 이러한 정치행위를 참정권이라 하고, 이를 모아 집합적인 총의로 최종결정을 하는 것을 헌법상 주권의 행사하고 한다. 민주주의의 기본적 가치라고 할 수 있는 주권재민의 원리(제1조)가 현실적인 제도로 구체적으로 현출되는 것이 선거제도 이고 선거법이다. 민주주의의 존립에 가장 중요한 문제는 선거에 달려 있고 선거와 관련되어 정치적·법률적 문제가 제기된다. 국민은 오직 선거에 의해서만 국정에 참가하는 것이며 선거를 통하여 여론정치가 행해지므로 민주정치에 있어서 선거는 가장 중요한 국가적 행사의 하나이며 국법질서의 기초가 된다. 선거법의 제정과 개정에도 국민주권과 국민대표제의 본질은 침해되거나 제한할 수 없다는 한계가 설정되는 것이다. 국회의원선거법에 규정되어 있는 선거제도의 여하는 민주주의의 사활의 문제이고 국민의 정치적 생존권에 관계되는 문제이며 자유민주주의의 기본질서와 법치주의를 구현하는 근본이다.

<헌법재판소 1996. 8. 29. 96헌마99> 공직선거 및 선거부정방지법 제48조 등 위헌확인

대의제 민주주의에 바탕을 둔 우리 헌법의 통치구조에서 선거제도는 국민의 주권행사 내지 참정권행사의 과정으로서 국가권력의 창출과 국가 내에서 행사되는 모든 권력의 정당성을 국민의 정치적인 합의에 근거하게 하는 통치구조의 조직원리이다.

<헌법재판소 2003. 9. 25. 2003헌마106> 공직선거 및 선거부정방지법 제53조 제3항

민주국가에서의 국민주권의 원리는 무엇보다도 대의기관의 선출을 의미하는 선거와 일정사항에 대한 국민의 직접적 결단을 의미하는 국민투표에 의하여 실현된다. 특히 선거는 오늘날의 대의민주주의에서 주권자인 국민이 주권을 행사할 수 있는 가장 의미 있는 수단이며, 모든 국민이 선거권과 피선거권을 가지며 균등하게 선거에 참여할 기회를 가진다는 것을 민주국가에서 국가권력의 민주적 정당성을 담보하는 불가결의 전제이다.

그렇기 때문에 선거행위에서 국민의 의사가 굴절 없이 행사될 수 있게끔 여러 가지 제도가 구비되는 것이 필요하다. 이를 위하여 오늘날의 민주적 헌법에서는 언론·출판·집회·결사의 자유가 보장되어 있으며, 정당활동의 자유와 정당의 기회균등과 같은 정당제도가 확립되어 있고, 보통·평등·직접·비밀선거의 원칙이 명시되어 있다.

746) 홍성방, 「헌법학」(상), 박영사, 2013, 150면.

<헌법재판소 1991. 3. 11. 91헌마21> 지방의회선거법 제36조 제1항에 대한 헌법소원

오늘날 입헌 민주국가에서는 대의제도에 의한 통치가 불가피한 것으로서 선거야 말로 국민의 의사를 체계적으로 결집하고, 수렴하며, 구체화하는 방법으로 국민의 정치적 의사를 형성하는 가장 합리적인 절차이며, 따라서 국민의 의사가 얼마나 굴절 없이 정당하게 반영되느냐의 여부가 통치권의 정통성과 정당성을 담보하는 생명이라고 할 수 있다. 그러므로 선거제도를 지배하는 보통·평등·직접·비밀선거의 네 가지 원칙(헌법 제41조 제1항, 제67조 제1항)이 실질적으로 얼마나 잘 보장되느냐가 선거제도의 성패를 가름하는 갈림길이 되는 것이다.

<헌법재판소 2001. 7. 19. 2000헌마91> 공직선거법 제146조 제2항, 제56조, 제189조

선거는 주권자인 국민이 그 주권을 행사하는 통로이므로 선거제도는 첫째, 국민의 의사를 제대로 반영하고, 둘째, 국민의 자유로운 선택을 보장하여야 하고, 셋째, 정당의 공직선거 후보자의 결정과정이 민주적이어야 하며, 그렇지 않으면 민주주의원리 나아가 국민주권의 원리에 부합한다고 볼 수 없다.

오늘날 정당국가적 민주주의에서는 선거는 대표자의 선출이라는 의미 이외에도 정당정책에 대한 국민투표적 성격, 즉 가능한 여러 정부 가운데서 하나를 선택한다는 의미에서 정부선택적 국민투표의 성격을 가진 것으로 평가되고 있다.

⑵ 선거의 원칙

우리 헌법은 제41조 제1항, 제67조 제1항에서 선거의 원칙으로서 보통·평등·직접·비밀선거를 규정하고 있다. 또한, 우리 헌법은 자유선거의 원칙을 명시적으로 규정하고 있지 않으나 우리 헌법 어디에도 선거에 참여가 강제되고 있지 않은 점으로 보아 자유선거의 원칙이 전제되어 있는 것으로 보아야 한다.[747]

1) 보통선거

보통선거란 제한선거에 대한 개념으로 일정연령에 달한 모든 국민에게 선거권이 인정되는 선거를 말한다. 따라서 성별·재산·학력·직업·종교 또는 사회적 신분 등을 근거로 선거권을 제한하는 것은 인정되지 않는다. 그러나 선거권의 부여를 일정한 연령과 같은 합리적 사유와 결부시키거나 선거인명부에 등록하게 하는 등의 정당한 형식적 전제요건에 결부시키거나 선거법위반자 등과 같이 엄격한 합리적 요건하에서 선거권을 제한하는 것은 가능하다. 이러한 의미에서 보통선거는 일반적 평등원리가 선거에서 구체화된 경우라 할 수 있다.[748] 또한, 보통선거의 원칙은 피선거권에도 적용된다.[749]

<헌법재판소 1999. 5. 27. 98헌마214> 공직선거 및 선거부정방지법 제52조 제3항 등

민주주의는 참정권의 주체와 국가권력의 지배를 받는 국민이 되도록 일치할 것을 요청한다. 국민의 참정권에 대한 이러한 민주주의적 요청의 결과가 바로 보통선거의 원칙이다. 즉, 원칙적으로 모든 국민이 균등하게 선거에 참여할 것을 요청하는 보통·평등선거의 원칙은 국민의 자기지배를 의미하는 국민주권의 원리에 입각한 민주국가를 실현하기 위한 필수적 요건이다. 원칙적

747) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 207면; 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 723면; 계희열, 「헌법학」(상), 박영사, 1995, 291면; 홍성방, 전게서, 156면.

748) 허영, 전게서, 720면.

749) 과도한 기탁금과 관련하여 보통·평등선거의 위배된다고 판시한 바 있다(헌법재판소 1989. 9. 8. 88헌가6).

으로 모든 국민이 선거권과 피선거권을 가진다는 것은 바로 국민의 자기지배를 의미하는 민주국가에의 최대한의 접근을 의미하기 때문이다.

<헌법재판소 2001. 6. 28. 2000헌마111> 공직선거 및 선거부정선거방지법 제15조 제1항

보통선거제도는 일정한 연령에 이르지 못한 국민에 대하여 선거권을 제한하는 것을 당연한 전제로 삼고 있고, 헌법 제24조에서 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 선거권을 가진다고 규정함으로써 선거권연령의 구분을 입법자에게 위임하고 있으므로 보통선거에서 선거연령을 몇 세로 정할 것인가의 문제는 입법자가 그 나라의 역사, 전통과 문화, 국민의 의식수준, 교육적 요소, 미성년자의 신체적·정신적 자율성, 정치적·사회적 영향 등 여러 가지 사항을 종합하여 결정하는 것으로서 이는 입법자가 입법목적 달성을 위한 선택의 문제이고 입법자가 선택한 수단이 현저하게 불합리하고 불공정한 것이 아닌 한 재량에 속하는 것이다.

<헌법재판소 2007. 6. 28. 2004헌마644> 공직선거 및 선거부정방지법 제15조 제2항 등

선거권의 제한은 불가피하게 요청되는 개별적·구체적 사유가 존재함이 명백할 경우에만 정당화될 수 있고, 막연하고 추상적인 위험이나 국가의 노력에 의해 극복될 수 있는 기술상의 어려움이나 장애 등을 사유로 그 제한이 정당화될 수 없다. 단지 주민등록이 되어 있는지 여부에 따라 선거인명부에 오를 자격을 결정하여 그에 따라 선거권 행사여부가 결정되도록 함으로써 엄연히 대한민국의 국민임에도 불구하고 주민등록법상 주민등록을 할 수 없는 재외국민의 선거권 행사를 전면적으로 부정하고 있는 것은 어떠한 정당한 목적도 찾기 어려우므로 헌법 제37조 제2항에 위반하여 재외국민의 선거권과 평등권을 침해하고 보통선거원칙에도 위반된다.

2) 평등선거

평등선거란 차등선거 또는 불평등선거에 대한 반대개념으로서 모든 선거권자가 행사하는 투표가 동등한 계산가치와 동등한 결과가치를 가지는 선거를 말한다. 뿐만 아니라 평등선거의 원리는 모든 선거참여자가 여러 가지 대안 가운데서 자유롭게 선택할 수 있도록 자유로운 정당의 설립과 활동을 비롯한 정치적 자유권이 보장될 것을 요구하며, 국가의 공권력이 선거전에 편파적으로 개입하거나 간섭하는 것을 허용하지 않는다.[750]

<헌법재판소 1995. 12. 27. 95헌마224 등> 공직선거 및 선거부정방지법 별표1

평등선거의 원칙은 평등의 원칙이 선거제도에 적용된 것으로서 투표의 수적평등, 즉 복수투표제 등을 부인하고 모든 선거인에게 1인 1표를 인정함을 의미할 뿐만 아니라 투표의 성과가치의 평등, 즉 1표의 투표가치가 대표자 선정이라는 선거의 결과에 대하여 기여한 정도에 있어서도 평등하여야 함을 의미한다.

그러나 평등선거와 관련하여 선거구획정과 선거구인구의 불균형문제가 있다.

<헌법재판소 2001. 10. 25. 2000헌마92 등> 인구수편차에 대한 위헌확인

인구편차의 허용한계에 관한 다양한 견해 중 현시점에서 선택가능한 방안으로 상하 33.33% 편차(이 경우 상한인구소와 하한인구수의 비율은 2 : 1)를 기준으로 하는 방안 또는 상하 50% 편차(이 경우 상한인구수와 하한인구수의 비율은 3 : 1)가 고려될 수 있다. 그런데 상하 33.33% 편차 기준에 의할 때 행정구역 및 국회의원정수를 비롯한 인구비례의 원칙 이외의 요소를 고려함에 있어 적지 않은 난점이 예상된다. 또 우리 재판소가 선거구 획정에 따른 선거구간 인구편

750) 정당후보와 무소속후보의 차별하는 것을 위헌으로 판시한 바 있다(헌법재판소 1992. 3. 13. 92헌마37). 그러나 비정당단체의 선거운동금지를 합헌으로 판시하였다(헌법재판소 1995. 5. 25. 95헌마105).

차의 문제를 다루기 시작한 지가 겨우 5년여가 지나 현재의 시점에서 너무 이상에 치우친 나머지 현실적인 문제를 전적으로 도외시하기는 어렵다. 따라서 이번에는 평균인구수 기준 사항 50%의 편차를 기준으로 위헌여부를 판단하기로 한다. 그러나 앞으로 상당한 기간이 지난 후에는 인구편차가 33.33% 또는 그 미만의 기준에 따라 위헌여부를 판단하여야 할 것이다.

3) 직접선거

직접선거란 간접선거에 대한 반대개념으로 선거되는 대표자가 결정적으로 선거인에 의하여, 즉 투표를 통하여 그리고 투표시에 확정되는 것이 보장되는 선거를 말한다. 따라서 어떤 기관이 사후적으로 개입함으로써 그 기관의 재량에 따라 선거결과가 좌우되는 것은 직접선거가 아니다.[751]

<헌법재판소 2001. 7. 19. 2000헌마91 등> 공직선거 및 선거부정방지법 제146조 제2항 등

직접선거의 원칙은 선거결과가 선거권자의 투표에 의하여 직접 결정될 것을 요구하는 원칙이다. 국회의원선거와 관련하여 보면, 국회의원 선출이나 정당의 의석획득이 중간선거인이나 정당 등에 의하여 이루어지지 않고 선거권자의 의사에 따라 직접 이루어져야 함을 의미한다. 역사적으로 직접선거의 원칙은 중간선거인의 부정을 의미하였고, 다수대표제하에서는 이러한 의미만으로 충분하다고 할 수 있다. 그러나 비례대표제하에서 선거결과의 결정에는 정당의 의석배분이 필수적인 요소를 이룬다. 그러므로 비례대표제를 채택하는 한 직접선거의 원칙은 의원의 선출뿐만 아니라 정당의 비례적인 의석확보도 선거권자의 투표에 의하여 직접 결정될 것을 요구하는 것이다.

그러나 선상투표는 선거권자가 직접 의사결정을 하고 단지 그 송부만이 모사전송 시스템에 의하여 이루어지는 것이므로 직접선거의 원칙에 위배되지 않는다.[752]

4) 비밀선거

비밀선거란 공개선거에 대한 개념으로 선거인이 누구에게 선거했는지를 제3자가 알 수 없도록 하는 선거를 말한다. 비밀선거의 원칙은 선거인이 외부로부터의 강제나 압력을 받지 않는 자유롭고 공정한 선거를 보장하기 위한 것이다. 이러한 비밀선거는 투표용지, 기표소, 투표함 등을 사전에 철저하게 준비함으로써만 가능하기 때문에 그 성패는 많은 부분 선거준비와 선거업무조직에 달려있다. 그러한 의미에서 일반행정기관과 선거업무담당기관은 분리·독립되는 것이 바람직하다.[753]

5) 자유선거

자유선거란 강제선거에 대한 개념으로 선거인이 선거권을 자유롭게 행사할 수 있는 선거를 말한다. 자유선거는 비밀선거가 전제될 때에만 가능하다. 자유선거는 선거의 내용뿐 아니라 선거에 참여여부까지도 선거권자에게 일임되는 선거의 원칙이므로 기권자에 대하에 제재를 가하는 것은 금지된다. 따라서 대통령후보자 및 그 가족이나 공식선거운동원이 아닌 일반국민에게 일체의 선거운동을 금하고 있는 구 대통령선거법 제36조 제1항은 국민의 선거운동의 자유를 전면적으로 박탈하는 것으로서 헌법에 규정된 국민의 참정권의 본질적 내용을 침해하여 위헌이다.[754]

---

751) BVerfGE 3, 45(49); 7, 63(68); 47, 253(279).
752) 헌법재판소 2007. 6. 28. 2005헌마772.
753) 허영, 전게서, 723면.
754) 헌법재판소 1994. 7. 29. 93헌가4 등.

<헌법재판소 1994. 7. 29. 93헌가4> 구 대통령선거법 제36조 제1항 등

자유선거의 원칙은 비록 우리 헌법에 명시되지 않았지만 민주국가의 선거제도에 내재하는 법원리인 것으로서 국민주권의 원리, 의회민주주의의 원리 및 참정권에 관한 규정에서 근거를 찾을 수 있다. 이러한 자유선거의 원칙은 선거의 전 과정에 요구되는 선거권자의 의사형성의 자유와 의사실현의 자유를 말하고, 구체적으로는 투표의 자유, 입후보의 자유, 나아가 선거운동의 자유를 뜻한다.

3. 의의

선거권이란 선거에 참여할 수 있는 권리를 말한다. 누가 선거권을 가지는가의 문제는 오늘날 민주주의국가에서는 매우 중요한 문제이다. 왜냐하면 오늘날에는 국민주권의 원칙이 확립되어 있으면서도 국민이 모든 경우에 스스로 주권을 행사하는 것이 아니라 주권행사가 국민대표에 위임되어 있는 간접민주정이 채택되고 있기 때문이다.

<헌법재판소 1991. 3. 11. 91헌마21> 지방의회의원선거법 제36조 제1항

오늘날 입헌민주국가에서는 대의제도에 의한 통치가 불가피한 것으로 선거야말로 국민의 의사를 체계적으로 결집하고 수집하고 구체화하는 방법으로 국민의 정치적 의사를 형성하는 가장 합리적인 절차이며, 따라서 국민의 의사가 얼마나 굴절없이 정당하게 반영되느냐의 여부가 통치권의 정통성과 정당성을 담보하는 핵심이면 생명이다.

<헌법재판소 2004. 3. 25. 2002헌마411> 공직선거 및 선거부정방지법 제18조 위헌확인

선거일 현재 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 종료되지 아니한 자는 선거권이 없다고 규정하고 있는 것은 국가공동체의 구성으로서 부담하고 있는 납세·병역·준법 기타 필요한 사회적 책무를 이행하지 아니하고 오히려 그 의무에 반하여 공동체의 안전을 파괴하고, 다른 구성원들의 생명·신체·재산을 위협한 사람들에 대한 사회적 제재로서 일정한 기간 구금을 명하고 구금시설인 교도소 등의 질서와 수형자의 교화를 위하여 필요한 제한을 가하는 한편, 선거권의 행사를 위하여 필요한 정보의 제공이 현실적으로 어려운 수형자에게 그 기간 동안 공민권의 행사를 정지시키는 것은 형벌집행의 실효성확보와 선거의 공정성을 위하여 입법자가 그 일을 추구할 수 있는 것으로서 입법목적의 정당성이나 방법의 적정성을 충족시킨다.

4. 법적성격 및 내용

⑴ 법적성격

선거권의 법적성격과 관련하여 선거권은 천부의 권리로서 불가양·불가침의 자연권이라고 하는 자연권설(근대자연법론자), 선거권을 선거기관으로서 국민의 기능이라고 보는 공무설(법실증주의자), 선거권을 주관적 권리로서의 주권의 구성권·운용권으로 주권의 소재와 행사를 결정하는 가장 중요한 권리로 이해하는 권리설(국민주권주의자), 선거권을 개인의 권한이 아니라 국가기관의 선임행위인 선거에 참가하는 선거인단의 권한으로 보는 권한설(옐리네크), 선거를 국가를 위한 공무의 성질과 공법에 의하여 보장된 주관적 권리로서의 성격을 동시에 가지는 것으로 이해하는 이원설 등의 견해가 있다. 이원설의 견해가 국내 다수설의 입장이다.

우리 헌법재판소는 참정권을 불가침의 기본권으로 이해하는가 하면,[755] 구체적 권리성을 부정하기도 한다.[756] 또한, 법률상의 권리라고 판시한 바 있다.[757]

<헌법재판소 1989. 9. 8. 88헌가6> 국회의원선거법 제33조, 제34조의 위헌심판

국민이 국정에 참여하는 참정권은 국민주권의 상징적 표현으로서 국민의 가장 중요한 기본적 권리의 하나이며 다른 기본권에 대하여 우월적 지위를 가진다. 따라서 이러한 국민주권이 현실적으로 행사될 때에는 국민 개인이 가지는 불가침의 기본권으로 보장된다.

<헌법재판소 1998. 10. 29. 96헌마186> 국회구성권 등 위헌확인

국회의원을 보통·평등·직접·비밀선거에 의하여 국민의 대표자를 선출하는 권리에 그치며, 개인에게 헌법상 보장되는 구체적 권리라고는 할 수 없다.

<헌법재판소 2004. 3. 25. 2002헌마411> 공직선거법 제18조 위헌확인

우리 헌법 아래에서 선거권도 법률이 정하는 바에 의하여 보장되는 것이므로 입법형성권을 갖고 있는 입법자가 선거법을 제정하는 경우에 헌법에 명시된 선거제도의 원칙을 존중하는 가운데 구체적으로 어떠한 입법목적의 달성을 위하여 어떠한 방법을 선택할 것인가는 그것이 현저하게 불합리하고 불공정한 것이 아닌 한 입법자의 재량역역에 속한다.

선거권은 전국가적 자연권인 인권이 헌법에 실정화된 것으로 개인의 공권인 동시에 공무로 이해하는 하는 것이 타당할 것이다. 또한, 선거권의 행사는 법적의무는 아니나 윤리적·도의적 의무로 보는 것이 타당하다.[758]

⑵ 내용

우리 헌법과 법률에 규정된 국민의 선거권에는 헌법 제67조 대통령선거권, 헌법 제41조의 국회의원선거권, 헌법 제119조와 공직선거법 제15조의 지방의회의원과 지방자치단체장의 선거권 등이 있다. 이들 선거에서 선거권을 행사하기 위해서는 만19세 이상이라는 요건과 선거인명부에 등재라는 요건을 충족하여야 하며, 특히 지방선거에서는 관할구역 안에 주민등록이 되어 있을 것(공직선거법 제15조 제2항)이라는 거주요건을 충족하여야 한다.

5. 제한

선거권은 결격사유가 있으면 행사할 수 없다. 결격사유에 대해서는 공직선거법 제18조에서 금치산선고를 받은 자, 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 집행이 종료되지 아니하거나 그 집행을 받지 아니하기로 확정되지 아니한 자, 선거범으로 100만원 이상의 벌금형의 선고를 받은 후 5년 또는 형의 집행유예의 선고를 받고 그 형이 확정된 후 10년을 경과하지 아니하거나 징역형의 선고를 받고 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 또는 그 형의 집행이 종료되거나 면제된 후 10년을 경과하지 아니한 자, 법원의 판결에 의하여 선거권이 정지 또는 상실된 자는 선거권을 행사할 수 없다.

---

755) 헌법재판소 1989. 9. 8. 88헌가6.
756) 헌법재판소 1998. 10. 29. 96헌마186.
757) 헌법재판소 2004. 3. 25. 2002헌마411.
758) 홍성방, 전게서, 331~332면.

그러나 선거사범의 경우를 제외하고는 형사책임과 주권자의 권리는 별개의 것이기 때문에 선거권을 인정하는 것이 헌법의 정신에 합치된다는 견해가 있다.[759]

<헌법재판소 1997. 12. 24. 97헌마16>

선거권과 피선거권은 민주정치에 있어서 주권자인 국민이 국정에 참여는 필수적인 수단으로서 가장 중요한 기본권에 해당하므로 그 제한은 불가피한 최소한에 그쳐야 하며, 제한여부나 제한기간 등은 선거범죄의 죄질과 가벌성의 정도에 부합되어야 한다.

♣ 문제풀이

1. 다음 선거의 기본원칙에 대한 설명으로 올바르지 못한 것은?

① 보통선거란 일정연령에 달한 모든 국민에게 선거권이 인정되는 것이다.
② 직접선거란 선출되는 대표자가 국민의 투표를 통하여 투표시에 확정되는 것이다.
③ 평등선거란 성별, 재산, 학력, 직업, 종교 또는 사회적 신분 등을 근거로 선거권을 차별하는 것을 인정하지 않는다는 것이다.
④ 비밀선거란 선거인이 누구에게 선거했는지를 제3자가 알 수 없도록 하는 것이다.
⑤ 자유선거란 선거인이 선거권을 자유롭게 행사할 수 있는 것이다.

[정답] ③
[해설] 보통선거에 대한 설명이다.

2. 다음 내용 중 선거권에 위배되는 것이 아닌 것은?

① 선거범에게 영구적으로 선거권을 박탈하는 것
② 근로능력이 없는 자에게 선거권을 부여하지 않는 것
③ 피선거권을 일정한 신분이 있는 자에게 부여하는 것
④ 선거권 연령을 만18세로 규정하는 것
⑤ 공무원의 선거권을 제한하는 것

[정답] ④
[해설] 입법재량사항으로 하향이 가능하다.

3. 다음 선거권에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 선거권이 있는 자는 모두 피선거권이 있다.
② 선거권은 오로지 법률에 의해서만 인정된다.
③ 선거권은 공무원을 선정하는 것으로 오직 국민에게만 인정된다.
④ 선거범에게 선거권을 일정기간 제한하는 것은 가능하다.
⑤ 금고이상의 형을 선고받은 자에게도 선거권이 인정된다.

[정답] ④
[해설] 공직선거법 제18조

759) 김철수, 전게서, 836면; 권영성, 전게서 547면; 허영, 전게서, 512~513면; 계희열, 전게서, 276면; 홍성방, 전게서, 333면.

♣ 요점정리

1. 대의민주제에서 선거를 통하여 주권자인 국민은 자신의 주권을 행사하며, 이에 의해 정치지도자는 민주적 정당성을 얻게 된다.

2. 오늘날의 민주적 헌법에서는 언론·출판·집회·결사의 자유가 보장되어 있으며, 정당활동의 자유와 정당의 기회균등과 같은 정당제도가 확립되어 있고, 우리 헌법은 보통·평등·직접·비밀선거의 원칙을 명시적으로 규정하고 있다.

3. 보통선거란 제한선거에 대한 개념으로 일정연령에 달한 모든 국민에게 선거권이 인정되는 선거를 말한다. 따라서 성별·재산·학력·직업·종교 또는 사회적 신분 등을 근거로 선거권을 제한하는 것은 인정되지 않는다.

4. 평등선거란 차등선거 또는 불평등선거에 대한 반대개념으로서 모든 선거권자가 행사하는 투표가 동등한 계산가치와 동등한 결과가치를 가지는 선거를 말한다.

5. 선거권의 행사를 위하여 필요한 정보의 제공이 현실적으로 어려운 수형자에게 그 기간 동안 공민권의 행사를 정지시키는 것은 형벌집행의 실효성확보와 선거의 공정성을 위하여 입법자가 그 일을 추구할 수 있는 것으로서 입법목적의 정당성이나 방법의 적정성을 충족시킨다.

제40강 공무담임권과 국민투표권

♣ 학습목표

공무담임권에 대하여 설명할 수 있다.
국민투표권에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

공무담임권, 피선거권
공직취임권, 직업공무원제도
플레비지트, 래퍼랜덤
국민투표, 주민투표

♣ 사전테스트

1. 선거범으로 형벌을 받은 자에 대하여 일정기간 피선거권을 정지하는 규정 자체는 이중처벌의 원칙에 반한다.

정답 : X
해설 : 선거의 공정을 확보함과 동시에 본인의 반성을 촉구하기 위한 법적조치이다.

2. 피선거권을 누구에게 어떤 조건으로 부여할 것인지는 헌법에 의해 정해진다.

정답 : X
해설 : 피선거권을 누구에게 어떤 조건으로 부여할 것인지는 입법형성권의 범위 내에서 스스로 정할 사항이다(헌법재판소 2005. 4. 28. 2004헌마219).

3. 다른 선거에서는 소선구제를 채택하면서 기초의원 선거에서만 중선거구제를 채택하였다고 하여 자치구·시·군의 지방자치제도나 지방의회제도의 본질을 훼손한다.

정답 : X
해설 : 지방자치제도나 지방의회제도의 본질을 훼손한다고 볼 수 없다(헌법재판소 2007. 11. 29. 2005헌마977).

♣ 돌발퀴즈

현행 법률에 의할 경우, 90일의 거주요건은 당해 지방자치단체의 여러 사정을 이해하고 주민과 연대감 내지 일체감을 형성할 수 있는 최소한의 기간으로서 지방자치행정의 민주성과 능률성을 높이기 위해서 적합하고 필요한 수단이다.

[정답] X
[해설] 현행 60일(공직선거법 제16조 제3항).

♣ 강의내용

1. 공무담임권

⑴ 헌법규정 및 법률규정

우리 헌법 제25조는 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 공무담임권을 가진다고 규정하고 있다. 헌법 이외에도 대통령·국회의원·지방자치단체장 및 의회의원의 선거에 관한 법률인 공직선거 및 선거부정방지법, 국가공무원법, 지방공무원법 등에서 피선거권 내지 공무담임에 관해서 자격요건과 연령요건 및 결격사유 등을 규정하고 있다. 또한, 각종 공무원임용법령에서 공무원의 자격요건과 임용요건 등을 규정하고 있다.

⑵ 개념 및 법적성격

1) 개념

공무담임권은 일체의 공무를 담당할 수 있는 권리를 말한다. 공무를 담당하기 위해서는 법률이 정하는 바에 의하여 선거에서 당선되거나 임명에 필요한 자격을 구비하거나 선발시험 등에 합격하여야 한다. 따라서 공무담임권은 피선거권보다 넓은 개념이다. 그러나 피선거권은 공무담임권 중 가장 중요한 것이라 할 수 있다.

2) 법적성격

피선거인을 선거인단에 의하여 선출되었을 때 이를 승낙하고 공무원으로 될 수 있는 자격에 불과하다고 보는 자격설과 피선거권을 입후보와 당선을 조건으로 하여 공무원이 될 수 있는 헌법상의 기본적 권리라고 보는 권리설이 대립하고 있다. 권리설이 국내 다수설의 입장이다.

⑶ 내용

1) 피선거권의 의미

피선거권이란 선거에 의하여 대통령, 국회의원, 지방자치단체의 장 또는 의원으로 선출될 수 있는 자격을 말한다. 피선거권도 선거권과 마찬가지로 성별·종교·사회적 신분·재산 등에 의하여 차별되어서는 안 된다. 그러나 피선거권은 공무를 수행할 수 있는 능력과 결부되어 있기 때문에 선거권보다 엄격한 요건을 요구하는 것이 일반적이다. 우리 현행 공직선거법도 피선거권과 관련하여 선거권보다 연령제한의 폭을 높이고 결격사유도 확대하고 있다(제16조). 또한, 헌법에서도 겸직금지를 규정하여 피선거권을 제한하고 있다(헌법 제43조, 제83조).

<헌법재판소 1994. 7. 29. 93헌마23> 지방의회의원선거법 제12조 제3호 위헌확인

선거범으로 형벌을 받은 자에 대하여 일정기간 피선거권을 정지하는 규정 자체는 이로써 선거의 공정을 확보함과 동시에 본인의 반성을 촉구하기 위한 법적조치로서 국민의 기본권인 공무담임권과 평등권을 합리적 이유 없이 자의적으로 제한하는 위헌규정이라 할 수 없다.

<헌법재판소 2005. 4. 28. 2004헌마219> 공직선거법 제16조 제2항 위헌확인

국회의원으로 당선될 권리로서 피선거권을 누구에게 어떤 조건으로 부여할 것인지는 입법자가 그의 입법형성권의 범위 내에서 스스로 정할 사항이지만 이때에도 헌법이 피선거권을 비롯

한 공무담임권을 기본권으로 보장하는 취지와 대의민주주의 통치질서에서 선거가 가지는 의미와 기능이 충분히 고려되어야 한다는 헌법적인 한계가 있다.

<헌법재판소 2008. 1. 17. 2004헌마41> 공직선거 및 선거부정방지법 제19조 제1호 등
선거범으로 100만원 이상의 벌금형을 선고받아 확정되면 5년 동안 피선거권이 제한되도록 하는 공직선거법 규정은 과잉금지원칙에 위배하여 공무담임권을 제한하고 있다고 할 수 없다.

2) 피선거권의 내용

가. 내용

A. 대통령

헌법 제67조 제4항에서 피선거권을 규정하고 있고, 제5항에서 선거에 관한 사항은 법률로 정한다고 규정하고 있다. 따라서 대통령 피선거권은 국회의원 피선거권이 있고, 선거일 현재 5년 이상 국내에 거주하고 있는 40세에 달한 후보자에 대한 직선제, 상대적 다수대표제에 의한 선거를 원칙으로 하고 있다(공직선거법 제16조 제1항, 제187조 제1항).

대통령 후보가 1인인 때에는 선거권자 총수의 3분의 1이상 득표하여야 하며(헌법 제67조 제3항), 대통령 선거에서 최고득표자가 2인 이상인 때에는 중앙선거관리위원회의 통보에 의하여 국회는 그 재적의원과반수가 출석한 공개회의에서 결선투표를 하고 다수표를 얻은 자를 당선인으로 결정한다(헌법 제67조 제2항).

B. 국회의원

헌법 제41조 제3항에서 선거에 관한 사항은 법률로 정하도록 규정하고 있고, 공직선거법 제16조 제2항과 제19조에서 만25세가 된 일정한 결격 사유가 없는 후보자에 대하여 규정하고 있으며, 다수대표제와 비례대표제를 혼합하고 있다. 즉, 지역구는 소선거구제와 다수대표제를 전국구에서는 비례대표제를 채택하고 있다. 이와 관련하여 선거구획정문제와 비례대표제에 대한 문제가 제기되어 왔다.[760]

<헌법재판소 2001. 10. 25. 2000헌마92 등> 공직선거 및 선거부정방지법 별표1
선거구획정에 관하여 국회의 광범위한 재량이 인정되지만 그 재량에는 평등선거의 실현이라는 헌법적 요청에 의하여 일정한 한계가 있을 수밖에 없는바 첫째, 선거구획정에 있어서 인구비례원칙에 의한 투표가치의 평등은 헌법적 요청으로서 다른 요소에 비하여 기본적이고 일차적인 기준이기 때문에 합리적 이유 없이 투표가치의 평등을 침해하는 선거구획정은 자의적인 것으로서 헌법에 위반된다는 것이고, 둘째, 특정지역의 선거인들이 자의적인 선거구획정으로 인하여 정치과정에 참여할 기회를 잃게 되었거나 그들이 지지하는 후보자가 당선될 가능성을 의도적으로 박탈당하고 있음이 입증되어 특정지역의 선거인들에 대하여 차별하고자 하는 국가권력의 의도와 그 집단에 대한 실질적인 차별효과가 명백히 드러난 경우, 즉 게리멘더링에 해당하는 경우에는 그 선거구획정은 입법재량의 한계를 벗어난 것으로 헌법에 위반된다.

또한, 헌법재판소는 비례대표 국회의원의석의 배분방식을 규정하고 있는 공직선거법에 대하여 첫째, 정당명부에 대한 투표가 따로 없어 정당의 명부작성행위가 최종적·결정적인 의의를 지니므로 직접선거의 원칙에 위배되고, 둘째, 무소속후보자들에게 투표하는 유권자들로서는 자신의 의사에 반하여 투표가치의 불평등을 강요당하게 되어 평등선거의 원칙에 위배되고, 셋째, 정

760) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 739~740면; 계희열, 「헌법학」(상), 박영사, 1995, 297면.

당명부식 비례대표제를 실시하면서도 별도의 정당투표를 허용하지 않는 것은 헌법에 위반되고, 1인 1표제를 채택하고 있는 공직선거법 제146조 제2항과 지역구선거에서 표출된 유권자의 의사를 그대로 정당에 대한 지지의사로 의제하여 비례대표의석을 배분하도록 하고 있는 동법 제189조 제1항은 선거에 있어서 국민의 의사를 제대로 반영하고 국민의 자유로운 선택권 등을 보장할 것을 요구하는 민주주의원리에 부합하지 않는다고 판시한 바 있다.[761]

이에 따라 2002년 3월 7일 공직선거법 제146조 제2항을 개정하였고, 지방선거의 경우 2002년 6월 13일 선거부터, 국회의원 선거의 경우 2004년 4월 15일 총선부터 1인 2표제 정당명부식 비례대표제가 도입되었다.

C. 지방의회의원과 지방자치단체의 장

지방의회의원과 지방자치단체의 장으로 선출되기 위해서는 선거일 현재 60일 이상 그 지방자치단체의 관할구역 안에 주민등록이 되어 있는 주민으로서 만25세 이상 국민이어야 한다(공직선거법 제16조 제3항). 지방의회의원선거에서는 중선거구제와 다수대표제(제190조), 비례대표제(제190조의2)가 병용되고 있다. 지방자치단체의 장의 경우에는 주민의 직선에 의한 상대적 다수대표제가 채택되어 있다(제191조).

<헌법재판소 2007. 11. 29. 2005헌마977> 공직선거법 제23조 제1항 등 위헌확인

다른 선거에서는 소선구제를 채택하면서 기초의원 선거에서만 중선거구제를 채택하였다고 하여 자치구·시·군의 지방자치제도나 지방의회제도의 본질을 훼손한다고 볼 수 없다.

<헌법재판소 1996. 6. 26. 96헌마200> 공직선거 및 선거부정방지법 제16조 제3항

90일(현행 60일)의 거주요건은 당해 지방자치단체의 여러 사정을 이해하고 주민과 연대감 내지 일체감을 형성할 수 있는 최소한의 기간으로서 지방자치행정의 민주성과 능률성을 높이기 위해서 적합하고 필요한 수단일 뿐 아니라 공무담임권의 제한정도도 실현하려는 공익에 비한다면 경미하기 때문에 과잉금지의 원칙에 위배된다거나 공무담임권의 본질적 내용을 침해한다고 볼 수 없다.

<헌법재판소 1995. 3. 23. 95헌마53> 공직선거 및 선거부정방지법 제53조 제1항 위헌확인

공무원으로서 공직선거의 후보자가 되려고 하는 자는 선거일 전 90일까지 그 직을 그만두도록 한 것은 선거의 공정성과 공직의 직무전념성을 보장함과 아울러 이른바 포말후보의 난립을 방지하기 위한 것으로서 그 필요성과 합리성이 인정되며, 그것이 공무담임권의 본질적 내용을 침해하였다거나 과잉금지의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.

3) 공직취임권

선거직 이외의 공직에 취임할 수 있는 공직취임권에 대해서는 국가공무원법, 교육공무원법, 국회법, 법원조직법, 헌법재판소법 등에 그 임용조건과 자격기준 등이 규정되어 있다. 또한, 공무원, 군무원 등에 대한 연령제한이 폐지되어 정년에 달한 연령에 이르지 않는 경우 자유롭게 응시할 수 있다.

즉, 응시상한연령은 2009년도부터 시행되는 5, 7, 9급 공채시험부터 폐지되었고(공무원임용시험령 개정, 2008.10.20.), 군무원도 2015년도부터 만60세 이하면 응시할 수 있다. 그러나 경찰, 국정원 등 일부에서 응시상한연령을 유지하고 있다.

761) 헌법재판소 2001. 7. 19. 2000헌마91 등.

⑷ 제한

1) 피선거권의 제한

대통령, 국회의원, 지방의회의원 및 지방자치단체의 장에 대한 피선거권은 공직선거법 제19조에 의해 금치산선고를 받은 자, 선거범으로 100만원 이상의 벌금형의 선고를 받고 그 형이 확정된 후 5년 또는 형의 집행유예의 선고를 받고 그 형이 확정된 후 10년을 경과하지 아니하거나 징역형의 선고를 받고 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 또는 그 형의 집행이 종료되거나 면제된 후 10년을 경과하지 아니한 자, 법원의 판결에 의하여 선거권이 정지 또는 상실된 자, 금고 이상의 형의 선고를 받고 그 형이 실효되지 아니한 자, 법원의 판결 또는 다른 법률에 의하여 피선거권이 정지 또는 상실된 자는 피선거권이 제한된다.

2) 공직취임권의 제한

선거직 이외의 공직에 취임할 수 있는 공직취임권의 제한과 관련하여 헌법재판소는 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예의 기간이 완료된 날로부터 2년을 경과하지 아니한 자를 공무원결격 및 당연퇴직사유로 하고 있는 국가공무원법 제69조 중 제33조 제1항 제4호 및 지방공무원법 제31조 제4호와 자격정지 이상의 선고유예판결을 받은 경우 당연퇴직을 규정한 경찰공무원법 제21조, 제7조 제2항 제5호를 합헌으로 판시한 바 있으며,[762] 공무원정년제도에 대해서도 입법정책의 문제로 보아 합헌으로 판시한 바 있다.[763]

또한, 군필자에 대한 가산점제도에 대하서는 위헌을[764] 국가유공자와 그 유족 등 취업보호대상자에 대한 가산점제도에 대해서는 합헌으로 판시한 바 있다.[765]

<헌법재판소 1997. 11. 27. 95헌마14 등> 국가공무원법 제69조 등

금고 이상의 형에 대한 집행유예판결에 내포된 사회적 비난가능성과 공무원에게는 직무의 성질상 고도의 윤리성이 요구된다는 점을 함께 고려하여 공무원에게 가해지는 신분상 불이익과 보호하려는 공익을 비교할 때 입법자의 재량을 일탈하여 직업선택의 자유나 공무담임권, 평등권, 행복추구권, 재산권 등을 침해하는 위헌의 법률조항이라고 볼 수 없다.

<헌법재판소 1999. 12. 23. 98헌바33> 구 국가유공자예우 등에 관한 법률 제70조 등

공무담임권도 헌법 제37조 제2항에 의해 제한될 수 있으나 그 경우에도 이를 불공평하게 또는 과도하게 침해하거나 본질적인 내용을 침해하여서는 아니 된다. 선거직공직과 달리 직업공무원에게는 정치적 중립성과 더불어 효율적으로 업무를 수행할 수 있는 능력이 요구되므로 직업공무원으로의 공직취임권에 관하여 규율함에 있어서는 임용희망자의 능력·전문성·적성·품성을 기준으로 하는 이른바 능력주의 또는 성과주의를 바탕으로 하여야 한다. 공무원 등의 채용시험에 있어서 제대군인들을 위한 가산점제도는 능력주의와 무관한 불합리한 기준으로 여성과 장애인 등의 공직취임권을 지나치게 제약하는 것으로서 헌법 제25조에 위배되고, 이로 인하여 청구인들의 공무담임권이 침해된다.

762) 헌법재판소 1998. 4. 30. 96헌마7 등.
763) 헌법재판소 1997. 3. 27. 96헌바86 등.
764) 헌법재판소 1999. 12. 13. 98헌바33.
765) 헌법재판소 2001. 2. 22. 2000헌마25.

2. 국민투표권

⑴ 연혁 및 헌법규정

국민투표는 1802년 나폴레옹에 의하여 플레비지트(신임투표)의 형태로 처음 실시된 것으로 알려져 있고, 래퍼랜덤은 스위스에서 유래한 것으로 알려져 있다.[766] 우리나라에서는 1969년 10월 17일과 1975년 2월 12일 행해진 헌법개정안에 대한 국민투표가 플레비지트로서의 성격을 갖는다.

우리 헌법은 제72조에서 대통령은 필요하다고 인정할 때에는 외교·국방·통일 기타 국가안위에 관한 중요정책을 국민투표에 붙일 수 있다고 하고, 제130조 제2항은 헌법개정안은 국회가 의결한 후 30일 이내에 국민투표에 붙여 국회의원선거권자 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성을 얻어야 한다고 하여 협의의 국민투표권을 규정하고 있다.

⑵ 개념 및 유형

협의의 국민투표권, 즉 국민표결권은 국민이 중요한 법안이나 정책을 국민투표로서 결정하는 권리를 말한다. 국민표결에는 래퍼랜덤(협의의 국민표결)과 플레비지트(국민결정)가 있다. 래퍼랜덤은 입법과정 등에 국민이 참여하는 것으로 헌법에 규정된 절차에 따른 국민투표를 말한다.

이에 반해 플레비지트는 정치적 결단에 국민이 참여하는 것으로 헌법에 규정이 없음에도 또는 헌법의 규정을 무시하는 국민투표를 말한다. 일반적으로 플레비지트는 신임투표적 성격이 강하며, 우리 헌법상 인정되지 않는다.

이러한 국민표결은 국민주권의 사상에 충실한 것처럼 보이지만 실제로는 독재를 정당화하는 수단으로 악용될 수 있는 소지가 많다는 점에서 인정하기 어렵다.[767]

⑶ 내용

1) 현행헌법상 국민투표권

현행헌법상 국민투표권은 대통령이 중요정책을 국민투표에 회부하는 경우(제72조)와 헌법개정의 경우(제130조 제2항)의 두 가지가 있다.

중요정책에 대한 국민투표는 대통령의 판단에 따른 임의적인 것이며, 헌법개정안에 대한 국민투표는 필수적인 사항이라는 점에서 차이가 있다.

또한, 중요정책에 대한 국민투표의 방식으로 헌법개정을 위한 국민투표는 실시할 수 없다. 왜냐하면 외교·국방·통일 기타 국가안위에 관한 중요정책에 헌법개정은 포함되지 않을 뿐만 아니라 헌법개정을 위한 국민투표는 헌법적 절차에 따라 반드시 먼저 국회의 의결을 거쳐야 하기 때문이다.

이와 같은 이유에서 국민투표에 의한 법률제정도 허용되지 않는다고 보아야 한다.[768] 또한, 중요정책에 대한 국민투표에 대하여는 의결정족수에 관한 규정이 없지만 헌법개정안에 대한 국민투표의 의결정족수가 준용되어야 할 것이다.[769]

---

766) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 544면.
767) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 335~336면.
768) 홍성방, 상게서, 338면.
769) 권영성, 전게서, 545면.

2) 주민투표제

헌법에 규정된 제도는 아니지만 지방자치법 제13조의2는 지방자치단체의 장은 지방자치단체의 폐지·분합 또는 주민에게 과도한 부담을 주거나 중대한 영향을 미치는 지방자치단체의 주요 결정사항 등에 대하여는 주민의 의사를 물을 수 있도록 하는 주민투표제를 규정하고 있다.

<헌법재판소 2001. 6. 28. 2000헌마735> 입법부작위 위헌확인

우리 헌법은 법률이 정하는 바에 따른 선거권과 공무담임권 및 국가안위에 관한 중요정책과 헌법개정에 대한 국민투표권만을 보장하고 있다. 따라서 지방자치법 제13조의2에서 규정한 주민투표권은 성질상 선거권, 공무담임권, 국민투표권과 전혀 다른 것이어서 이를 법률이 보장하는 참정권이라고 할 수 있을지언정 헌법이 보장하는 참정권이라고 할 수는 없다.

⑷ 결격사유 및 제한과 한계

국민투표법은 만19세 미만자(제7조)와 투표일 현재 공직선거법 제18조의 규정에 따라 선거권이 없는 자(제9조)에게는 국민투표권을 인정하기 않고 있다.

이러한 국민투표권은 헌법 제37조 제2항에 따라 제한 될 수 있으나 본질적인 내용은 침해할 수 없다.

♣ 문제풀이

1. 다음 국민투표에 관한 설명 중 바르지 못한 것은?

① 레퍼랜덤은 대체로 헌법상 제도화되어 있는 헌법규범적인 것으로 국민이 일정한 중요사항을 국민투표로써 최종적으로 확정하는 방식이다.
② 플레비지트는 대체로 헌법상 제도화되어 있지 않은 헌법현실적인 것으로 독재지배를 정당화시키는 위장수단으로 이용되는 경우가 많다.
③ 헌법개정안에 대한 국민투표가 필수적 국민투표라면 중요정책에 대한 국민투표는 임의적 국민투표이다.
④ 우리 헌정사상 신임적 국민투표는 실시된 바 없다.
⑤ 바이마르헌법에는 국민이 의회제정의 법률에 대하여 국민투표로서 존폐여부를 결정할 수 있는 제도가 인정되었다.

[정답] ④

[해설] 1967년 10월 17일 3선개헌과 1975년 2월 12일 유신헌법개헌에 대한 신임투표가 행해진 바 있다.

2. 다음 설명 중 바르지 못한 것은?

① 선거권 연령은 건국헌법부터 제2차 개헌까지는 만21세 이상이었다.
② 법률의 범위를 벗어난 시민단체의 운동은 민사상, 형사상 책임을 면할 수 없다.
③ 선거권 연령은 핵심적인 헌법사항으로 이를 법률로 정할 수 없다.
④ 공무담임권은 국민의 권리이지 의무는 아니다.
⑤ 소급입법에 의하여 참정권은 제한을 받지 않는다.

[정답] ③

[해설] 법률에서 정한다(헌법 제24조).

3. 선거권 또는 피선거권에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 선거일 현재 5년 이상 국내에 거주하고 있는 만40세 이상의 국민은 대통령의 피선거권이 있고, 이 경우 공무로 외국에 파견된 기간과 국내에 주소를 두고 일정기간 외국에 체류한 기간은 국내 거주기간으로 본다.
② 만25세 이상의 국민은 국회의원 피선거권이 있다.
③ 피선거자의 연령은 후보등록일 현재를 기준으로 산정한다.
④ 금치산선고를 받은 사람은 선거권이 없다.
⑤ 선거범으로서 징역형의 선고를 받고 그 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 10년을 경과하지 아니한 자는 국회의원 피선거권은 물론 선거권도 없다.

[정답] ③
[해설] 선거일 현재를 기준으로 한다(공직선거법 제17조).

♣ 요점정리

1. 피선거권도 선거권과 마찬가지로 성별·종교·사회적 신분·재산 등에 의하여 차별되어서는 안되나 피선거권은 공무를 수행할 수 있는 능력과 결부되어 있기 때문에 선거권보다 엄격한 요건을 요구하는 것이 일반적이다.

2. 선거범으로 형벌을 받은 자에 대하여 일정기간 피선거권을 정지하는 규정 자체는 이로써 선거의 공정을 확보함과 동시에 본인의 반성을 촉구하기 위한 법적조치로서 국민의 기본권인 공무담임권과 평등권을 합리적 이유 없이 자의적으로 제한하는 위헌규정이라 할 수 없다.

3. 국회의원으로 당선될 권리로서 피선거권을 누구에게 어떤 조건으로 부여할 것인지는 입법자가 그의 입법형성권의 범위 내에서 스스로 정할 사항이지만 이때에도 헌법이 피선거권을 비롯한 공무담임권을 기본권으로 보장하는 취지와 대의민주주의 통치질서에서 선거가 가지는 의미와 기능이 충분히 고려되어야 한다는 헌법적인 한계가 있다.

4. 금고 이상의 형에 대한 집행유예판결에 내포된 사회적 비난가능성과 공무원에게는 직무의 성질상 고도의 윤리성이 요구된다는 점을 함께 고려하여 공무원에게 가해지는 신분상 불이익과 보호하려는 공익을 비교할 때 입법자의 재량을 일탈하여 직업선택의 자유나 공무담임권, 평등권, 행복추구권, 재산권 등을 침해하는 위헌의 법률조항이라고 볼 수 없다.

5. 협의의 국민투표권, 즉 국민표결권은 국민이 중요한 법안이나 정책을 국민투표로서 결정하는 권리를 말한다. 국민표결에는 래퍼랜덤(협의의 국민표결)과 플레비지트(국민결정)가 있다. 래퍼랜덤은 입법과정 등에 국민이 참여하는 것으로 헌법에 규정된 절차에 따른 국민투표를 말한다.

6. 우리 헌법은 법률이 정하는 바에 따른 선거권과 공무담임권 및 국가안위에 관한 중요정책과 헌법개정에 대한 국민투표권만을 보장하고 있다. 따라서 지방자치법 제13조의2에서 규정한 주민투표권은 성질상 선거권, 공무담임권, 국민투표권과 전혀 다른 것이어서 이를 법률이 보장하는 참정권이라고 할 수 있을지언정 헌법이 보장하는 참정권이라고 할 수는 없다.

제41강 청구권적 기본권 일반론 및 청원권

♣ 학습목표

청구권적 기본권을 설명할 수 있다.
청원권을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

청구권적 기본권의 개념, 용어
청구권적 기본권의 특성, 법적성격
청구권적 기본권의 주체, 효력
청원권의 개념, 기능, 주체, 기관
청원사항, 금지사항
청원행사방법 및 절차
국회법상 청원

♣ 사전테스트

1. 국민의 청원에 대하여 국가는 재결할 의무를 진다.
   정답 : X
   해설 : 수리의무, 심사의무, 통지의무가 있으나 재결의무는 없다.

2. 청원은 구술로도 가능하다.
   정답 : X
   해설 : 문서로만 할 수 있다(청원법 제6조).

3. 청원한 내용이 해당 관서의 소관에 속하지 아니하는 때에는 접수하는 때에는 처리할 수 없다.
   정답 : X
   해설 : 소관사무가 아닌 사항을 접수한 때에는 처분관서로 이송해야 한다(청원법 제9조).

♣ 돌발퀴즈

공무원은 직무와 관련된 것을 청원하거나 집단적 청원을 할 수 있다.
[정답] X
[해설] 공무원은 성실한 복무의무에 저촉되지 않는 한 청원가능하나 직무와 관련된 청원과 집단적 청원은 할 수 없다.

♣ 강의내용

1. 일반론

⑴ 헌법규정

우리 헌법은 제26조 청원권, 제27조 재판청구권, 제28조 형사보상청구권, 제29조 국가에 대한 손해배상청구권, 제30조 범죄피해자구조청구권을 규정하고 있다.

이외에도 제107조 제1항 위헌법률심사권, 제111조 제1항 제5호 헌법소원청구권, 제12조 제6항 구속적부심사청구권, 제23조 제3항 손실보상청구권 등이 규정되어 있다.

⑵ 개념 및 용어

청구권적 기본권은 국민이 적극적으로 국가에 대하여 특정한 행위를 요구한다든가 국가의 보호를 요청한다든가 하는 주관적 공권을 말하며, 청구의 대상이 되는 국가적 행위는 입법·사법·행정과 같은 국가적 작용일 수도 있고 경제적 급부일 수도 있다.

이러한 청구권적 기본권은[770] 기본권보장을 위한 기본권 또는 절차적기본권이라고도 한다.[771] 또한, 사회권적 기본권과 기본권보장을 위한 기본권을 통칭하는 개념으로 수익권이라는 용어를 사용하기도 하고,[772] 생활영역에 따라 기본권을 분류할 것을 주장하면서 재판을 받을 권리와 형사보상청구권은 인신권 중 인신보호를 위한 사법절차적 기본권으로, 청원권은 정치·사회생활영역의 보호로, 국가배상청구권과 범죄피해자보호청구권은 권리구제을 위한 기본권으로 나누어 설명하는 견해도 있다.[773]

그러나 청구권적 기본권과 수익권이라는 용어는 첫째, 경제적·물질적 급부를 주된 목적으로 하는 사회적 기본권과 혼동을 가져올 염려가 있으며,[774] 둘째, 기본권 보장을 위한 기본권은 권리 자체가 목적이 아니라 다른 권리나 이익을 확보하는 것이 목적이기 때문에 청구권적 기본권이라는 용어나 수익권이라는 명칭을 사용하거나 생활영역에 따라 더욱 세분하기보다는 기본권보장을 위한 기본권이라는 명칭을 사용하는 것이 본질에 더욱 적합하다고 한다.[775]

이에 대하여 권리보호청구권이나 구제권적 기본권, 권리보장 또는 확보하기 위한 기본권이란 용어들은 기본권이 침해된 경우에 이에 대한 사후구제를 요구하는 권리인 점을 강조한 것으로서 사전에 권리보호를 청구할 수 있는 성격을 경시한 느낌이 없지 않다고 할 것이다. 특히, 사후적 권리구제뿐 아니라 사전에 국가에게 보호를 청구할 수 있는 권리인 청원권의 경우를 보면 더욱 그러하다고 하여 청구권적 기본권이라는 용어가 타당하다고 한다.[776] 용어의 혼란을 줄이기 위해 일반적인 용어인 청구권적 기본권으로 통칭하고자 한다.

---

770) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 761면 이하; 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 550면 이하.
771) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 340면.
772) 박일경, 「제6공화국 신헌법」, 법경출판사, 1990, 305~306면.
773) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 350면 이하.
774) 고전적 수익권과 생존권적 기본권은 그 유래와 내용이 전혀 다르다(문홍주, 「제6공화국 한국헌법」, 해암사, 1988, 327~328면).
775) 홍성방, 전게서, 340~341면.
776) 김철수, 전게서, 761~762면.

⑶ 특성과 법적성격

1) 특성

청구권적 기본권은 다른 기본권들이 실체법적 권리인데 반해서 이러한 실체법적 권리들을 실현시키기 위한 절차적인 권리라는 점에 그 특성이 있다.

이러한 청구권적 기본권은 다른 기본권과 차이가 있는데, 구체적으로 첫째, 자유권적 기본권이 '국가로부터의 자유'를 의미하는 소극적 성질을 가지는 데 반하여, 기본권보장을 위한 기본권은 '국가에 대한 청구'를 내용으로 하는 적극적 성질을 가진다.

둘째, 사회권적 기본권은 사회적 문제를 해결하기 위해서 비교적 늦게 등장한 것에 반하여 청구권적 기본권은 자유권과 더불어 기본권 보장사에서 가장 오래된 기본권 중의 하나이다. 또한, 사회권적 기본권은 입법 등의 조치가 있어야 비로소 효력을 가지지만, 청구권적 기본권은 헌법규정에 의해서 직접 효력이 발생한다.[777]

셋째, 참정권적 기본권은 능동적 권리인 데 반하여, 청구권적 기본권은 국가에 대하여 일정한 국가적 행위를 요구할 수 있는 적극적 권리이다.

2) 법적성격

청구권적 기본권은 주관적 공권이자 동시에 객관적 가치질서로서의 성격을 가진다. 다수설은 청구권적 기본권을 원칙적으로 헌법에 의해 실정적으로 인정되는 국가내적인 시민의 권리라고 한다.[778]

그러나 청구권적 기본권도 자연권이 헌법에 실정화된 것으로 실체법적 기본권이 자연권에서 유래하였다면 그를 보장하기 위한 절차적 기본권도 자연권에서 유래한 것으로 보는 것이 논리적으로 일관된다고 한다.[779]

⑷ 주체 및 효력

1) 주체

청구권적 기본권은 다른 기본권이 침해된 경우에 그 회복 또는 구제를 위한 권리이다. 따라서 기본권의 주체가 될 수 있는 자는 누구나 기본권 보장을 위한 기본권의 주체성이 인정되며, 자연인인 이상 국민과 외국인을 불문하고 그 주체성이 인정된다.

사법인은 물론 공법인에게도 널리 그 주체성이 인정될 수 있다. 공법인에게 청구권적 기본권의 주체성이 인정되는 것은 그것이 개인적 권리가 아닌 객관적 절차원칙을 포함하고 있기 때문이다.[780]

2) 효력

청구권적 기본권에는 대국가적 효력이 인정된다. 그러나 청구권적 기본권은 대국가적 권리이므로 원칙적으로 대사인적 효력은 부정된다.

---

777) 김철수, 전게서, 762면. 그러나 이에 대하여 행사절차에 관한 구체적인 입법이 있을 경우에 비로소 행사할 수 있는 불완전한 의미의 구체적 권리라고 한다(권영성, 전게서, 550면).
778) 김철수, 전게서, 762면.
779) 홍성방, 전게서, 342면.
780) BVerfGE 21, 373.

⑸ 제한

청구권적 기본권은 헌법에 의해 직접 제한되는 경우가 있는데, 제29조 제2항에 의해 군인·군무원·경찰공무원 기타 법률이 정하는 공무원은 손해배상청구권이 제한되고, 제27조 제2항과 제110조 제4항에 따라 군사법원에 의한 재판을 받아야 하는 경우에는 재판청구권이 제한된다. 그리고 제76조에 따라 대통령의 긴급명령에 의하여 제한될 수 있고, 제77조 제3항에 의해 비상계엄이 선포된 경우에는 법원의 권한에 관한 특별조치에 의해 제한될 수 있다(계엄법 제10조).

또한, 헌법 제37조 제2항에 따라 법률에 의해 제한될 수 있다. 그러나 제한하는 경우에도 본질적인 내용은 침해할 수 없다.

2. 청원권

⑴ 연혁 및 헌법규정

청원권은 봉건주의사회에서 군주의 자의적 권력행사에 의하여 국민의 이익이 침범되는 것을 구제하기 위한 수단으로 발달하였다.

특히 영국에서는 전통적으로 '국왕은 오류를 범할 수 없다'(The King can do no wrong)는 원칙으로부터 국왕의 행위에 대하여 소송으로 다툴 수는 없고, 보통법의 원칙상 청원의 형식이 에드워드 1세 때부터 인정되었다. 역사적으로는 1215년 대헌장이 청원권을 최초로 용인한 사례로 볼 수 있다. 그 후, 영국의회는 정부예산을 승인하는 조건으로 불만의 구제를 위한 청원의 관행을 발전시켰고, 1689년 권리장전은 청원을 국민의 권리로 규정함과 더불어 청원을 이유로 한 구금이나 소추를 불법으로 규정하였다. 그러나 국왕의 불법행위가 인정되고 이에 대한 소송이 허용된 것은 1947년 국왕소추법이 제정되고 나서 부터이다.

미국에서는 수정헌법 제1조가 평화적인 집회의 권리와 불만구제를 위한 정부에의 권리를 규정하였으며, 독일은 프랑크푸르트헌법 제159조에서 청원권을 규정하였다.

우리나라에서는 1963년 2월 26일 제정된 청원법에 의하여 청원을 할 수 있는 사항은 피해의 구제, 공무원의 비위의 시정 또는 공무원에 대한 징계나 처벌의 요구, 법률·명령 또는 규칙의 제정·개정·폐지의 요구, 공공의 제도 또는 시설의 운영, 기타 공공기관의 권한에 속하는 사항 등으로 하고 있는데, 이는 한정적인 것이 아니라 예시적인 것으로서 재판에 간섭하는 것, 국가의 원수를 모독하는 것 등이 아니면 국가기관에 속하는 모든 권한에 대하여 청원을 할 수 있다.

우리 헌법은 제26조 제1항에서 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가기관에 문서로 청원할 권리를 가진다고 하고, 제2항에서 국가는 청원에 대하여 심사할 의무를 진다고 하여 청원권을 명시적으로 규정하고 있다. 또한, 헌법 제89조 제15호는 정부에 제출 또는 회부된 정부의 정책에 관계되는 청원의 심사는 국무회의의 심의를 거치도록 규정하고 있다.

⑵ 개념 및 기능

1) 개념

청원권은 국민이 국가기관에 대하여 문서로 의견이나 희망을 표시할 수 있는 권리이다.

<헌법재판소 2004. 5. 27. 2003헌마851> 군인연금법개정 청원에 대한 부작위 위헌소원

헌법 제26조와 청원법의 규정에 의할 때, 헌법상 보장된 청원권은 공권력과의 관계에서 일어나는 여러 가지 이해관계, 의견, 희망 등에 관하여 적법한 청원을 한 모든 국민에게 국가기관

이 청원을 수리·심사하여 그 결과를 통지할 것을 요구할 수 있는 권리를 말하므로 청원서를 접수한 국가기관은 이를 수리·심사하여 그 결과를 통지하여야 할 헌법에서 유래하는 작위의무를 지고 있고, 이에 상응하는 청원인에게는 청원에 대하여 위와 같은 적정한 처리를 할 것을 요구할 수 있는 권리가 있다.

2) 기능

청원권은 권리구제수단과 의사소통수단으로 기능하며, 즉 청원은 자유를 행사함에 있어 중요하고, 청원은 의사소통의 수단으로 봉사하고 사상이나 의견의 개인 간의 제휴를 위한 고전적 수단으로 기능하며, 개별 서명자의 견해를 확산시키는 효과적이면서도 평화적인 방법이라고도 한다.[781] 또한, 간접민주제·대의제의 결함을 보완하는 수단의 하나로(일종의 국민발안) 직접민주정적 기능을 행하여 왔다.

그러나 오늘날 사법적인 권리구제절차가 정비되고, 보통선거제도에 의하여 참정권이 보장되었으며, 표현의 자유가 확보됨으로써 청원권의 기능은 여러 가지 면에서 많이 퇴색되었다. 그럼에도 불구하고 청원권은 여전히 비정규적이고 가장 일반적인 기본권 보호수단으로서 기능하고 있다는 점만은 부인할 수 없다.[782] 즉, 직접적인 대국가적 의사표명수단, 국민의 유대강화기능, 국회의 국정통제지원기능, 비정규적인 권리구제수단의 기능을 가진다.

⑶ 법적성격

청원권의 법적성격을 청구권으로 보는 견해,[783] 자유권과 청구권의 이중적 성격을 가졌다고 보는 견해,[784] 자유권적 성격·청구권적 성격·기본권 보장적 성격을 함께 가졌다고 보아 복합적으로 보는 견해,[785] 등의 견해가 있다.

우리 헌법재판소는 청원권을 의견이나 희망을 진술하여 국가가 이를 수리·심사할 것을 청구할 수 있는 적극적인 청구권적 기본권으로 보고 있다.

<헌법재판소 1994. 2. 24. 93헌마213 등> 종교시설용지 공급처분취소 등

헌법상 보장된 청원권은 공권력과의 관계에서 일어나는 여러 가지 이해관계, 의견, 희망 등에 관하여 적법한 청원을 한 모든 국민에게 국가기관이 청원을 수리할 뿐만 아니라 이를 심사하여 청원자에게 그 처리결과를 통지할 것을 요구할 수 있는 권리이다.

청원권은 역사적으로 자유권의 형태로 시작되었다. 그리고 이러한 요소가 아직까지도 남아 있음을 부인할 수는 없다. 또한, 청원권은 국민이 표시한 의견이나 희망에 대하여 국가가 이를 수리·심사할 것을 요청하는 측면이 있다는 것도 부인할 수 없다. 따라서 청원권은 자유권과 청구권의 이중적 성격을 가진다고 본다.[786]

781) Brown v. Glines, 444 U. S. 348, 1980.
782) 허영, 전게서, 516~517면.
783) 김철수, 전게서, 766면.
784) 권영성, 전게서, 552면; 홍성방, 전게서, 345~346면.
785) 허영, 전게서, 518면.
786) BVerfGE 13, 150.

⑷ 주체와 객체

1) 주체

자연인과 사법인에게 주체성이 인정된다. 또한, 외국인에게도 주체성이 인정된다.[787] 다만, 사실상 노무에 종사하는 공무원을 제외하고는 공무원·군인 등의 경우, 그 직무에 관련된 청원이나 집단적 청원에 대해서는 합리적인 제한을 할 수 있을 것이다(국가공무원법 제66조 제1항).

수형자는 집단적인 청원은 할 수 없지만 처우에 대하여 불복이 있을 때에는 법무부장관 또는 순회점검공무원에게 청원할 수 있다(행형법 제6조).

2) 객체

헌법은 청원제출 대상기관을 국가기관이라고만 하고 있다. 그러나 헌법을 구체화한 청원법은 청원제출 대상기관을 국가기관, 지방자치단체와 그 소속기관, 법령에 의하여 행정권한을 가지고 있거나 행정권한을 위임 또는 위탁받은 법인·단체 또는 그 기관이나 개인으로 규정하고 있다(제3조).

⑸ 내용

1) 청원사항과 금지사항

가. 청원사항

헌법은 청원사항에 대하여 아무런 규정을 두고 있지 않다. 헌법을 구체화한 청원법은 중요한 청원사항으로 피해의 구제, 공무원의 비위의 시정 또는 공무원에 대한 징계나 처벌의 요구, 법률·명령·규칙의 제정·개정·폐지, 공공의 제도 또는 시설의 운영, 기타 공공기관의 권한에 속하는 사항 등을(제4조) 예시적으로 열거하고 있다.

나. 금지사항

청원사항은 원칙적으로 제한이 없으나 첫째, 감사·수사·재판·행정심판·조정·중재 등 다른 법령에 의한 조사·불복 또는 구제절차가 진행 중인 때, 둘째, 허위의 사실로 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계처분을 받게 하거나 국가기관 등을 중상모략하는 사항인 때, 셋째, 사인 간의 권리관계 또는 개인의 사생활에 관한 사항인 때, 넷째, 청원인의 성명·주소 등이 불분명하거나 청원내용이 불명확한 때에는 청원은 수리되지 않는다(제5조).

그리고 동일내용의 청원서를 동일기관에 2개 이상 또는 2개 기관 이상에 제출하는 것도 금지된다(이중청원의 금지). 청원서를 접수한 관서가 이 사실을 발견한 때에는 후에 접수한 청원서는 이를 취급하지 않는다(제8조).

또한, 청원은 타인을 모해할 목적으로 허위의 사실을 적시하여 제출해서는 안 되며(제11조), 이를 위반한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처해진다(제13조).

---

787) 독일기본법 제17조는 누구든지 단독으로 또는 다른 사람과 공동으로 문서로써 관할기관과 의회에 청원 또는 소원을 할 권리를 가진다고 하여 청원권이 인권임을 분명히 하고 있다. 또한, 다른 기본권에서는 외국인의 기본권 주체성이 국내거주 외국인에 한정되는 것이 보통임에 반하여 청원권의 경우, 국외거주 외국인에게도 그 주체성을 인정한 바도 있다(OVG Münster, NJW 1979, S. 281).

2) 행사요건

청원은 국민의 권리 또는 이익이 침범되었을 때에만 할 수 있는 것이 아니고, 침범될 우려가 있을 때에도 할 수 있다. 즉, 청원은 사전·사후를 불문한다.

3) 행사방법 및 절차

가. 형식

청원은 반드시 문서로 하여야 한다. 그 이유는 청원을 평온하게 하기 위한 것이다. 청원서에는 청원인의 성명·주소·직업을 기재하고 청원의 이유와 취지를 명시하여야 하며, 공동청원의 경우에는 3인 이하의 대표자를 선임해서 청원서에 표시해야 한다(제6조).

그런데 청원이 반드시 문서로 행사되어야 한다는 것에 대해서는 청원권이 비정규직·일반적 권리보호수단으로서의 기능을 다할 수 있기 위해서는 구두청원을 인정하거나 옴부즈만제도를 도입해서 보완할 수 있다는 견해도 있다.[788]

나. 제출

청원서는 청원사항을 관장하는 기관에 제출하고, 청원서를 접수한 기관이 청원사항이 그 기관이 관장하는 사항이 아니라고 인정할 때에는 그 청원사항을 관장하는 기관에 청원서를 이송하고 이를 청원인에게 통지하여야 한다(제7조). 이는 청원의 제도적 가치를 증대시키기 위한 것이다.

4) 효과

국가기관은 청원을 접수·심사·처리하고 특별한 사유가 없는 한 90일 이내에 그 처리결과를 청원인에게 통지하여야 한다(제9조 제1항, 제2항). 그러나 재결할 의무는 없다. 또한, 청원을 한 국민은 청원을 하였다는 이유로 차별대우를 받거나 불이익을 받지 않는다(제12조).

<헌법재판소 1994. 2. 24. 93헌마213 등> 종교시설 용지공급 처분취소 등

청원에 대하여 수리, 심사하여 그 처리결과를 청원인 등에게 통지하였다면 이로써 당해 국가기관은 헌법 및 청원법상의 의무이행을 필한 것이라 할 것이고, 비록 처리내용이 청원인 등이 기대하는 바에 미치지 않는다고 하더라도 더 이상 헌법소원의 대상이 되는 공권력의 행사 내지 불행사라고는 볼 수 없다.

<헌법재판소 2000. 6. 1. 2000헌마18> 입법부작위 위헌확인

청원에 대한 심사 및 통지의무는 재판청구권 및 기타 준사법적인 구제청구와 그 성질을 달리한다. 따라서 이러한 의무는 청원을 수리한 국가기관이 이를 성실, 공정, 신속히 심사·처리하여 그 결과를 청원인에게 통지하는 이상의 의무를 요구하는 것은 아니다.

<대법원 1990. 5. 25. 90누1458>

헌법 제26조 제1항의 규정에 의한 청원권은 국민이 국가기관에 대하여 어떤 사항에 관한 의견이나 희망을 진술할 권리로서 단순히 그 사항에 대한 국가기관의 선처를 촉구하는 데 불과한 것이므로 같은 조 제2항에 의하여 국가가 청원에 대하여 심사할 의무를 지고 청원법 제9조 제4항에 의하여 주관관서가 그 심사처리결과를 청원인에게 통지할 의무를 지고 있더라도 청원을

788) P. Kastari, Die Institution des Ombudsman im skadinavischen Recht, JöR Bd. 21, 1972, S. 219ff.

수리한 국가기관은 이를 성실, 공정, 신속히 심사·처리하여 그 결과를 청원인에게 통지하는 이상의 법률상 의무를 지는 것은 아니라고 할 것이다.

⑹ 효력 및 제한

1) 효력

청원권은 대국가적 기본권이기 때문에 대국가적 효력만을 가진다.

2) 제한

청원권은 대통령의 긴급명령(제76조) 또는 비상계엄(제77조 제3항)이 선포된 경우 제한될 수 있다. 또한 특별권력관계에 있는 사람은 특별관계의 설정목적에 부합하는 범위 내에서 해당법률에 의해 청원권이 제한된다.

또한, 헌법 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있으나 본질적 내용은 침해할 수 없다. 예컨대, 청원서의 수리·심사를 원칙적으로 거부하는 입법조치는 청원권의 본질적 내용의 침해가 될 것이다.

⑺ 국회청원(국회법 제123~126조)

국회청원을 하고자 하는 자는 의원의 소개를 얻어 청원서를 제출하여야 하고, 의장은 청원서를 접수한 후, 그 청원요지서를 작성하여 각 의원들에게 배부함과 동시에 그 청원을 소관위원회에 회부하여 심사하게 한다. 위원회는 청원심사 후 의결로써 청원을 본회의에 회부할 것을 결정할 수 있으며, 본회의에 회부하지 않기로 한 청원에 대해서는 의장이 이를 청원인에게 통지하여야 한다.

또한, 국회가 채택한 청원으로서 정부에서 처리함이 타당하다고 인정되는 청원은 의견서를 첨부하여 정부에 이송하며, 이 경우 정부는 그 처리결과를 지체없이 국회에 보고하여야 한다.

그러나 국회청원의 경우에도 재판에 간섭하거나 국가기관을 모독하는 청원은 접수하지 않으며, 위원회는 청원을 담당하게 하기 위하여 청원소위원회를 두어야 한다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 청원권의 행사에 관한 절차와 처리에 있어서 옳지 않은 것은?

① 재판에 간섭하는 것은 허용되지 않는다.
② 관서라 함은 모든 국가기관 또는 공공단체의 기관을 말한다.
③ 공공의 제도 또는 시설의 운영에 관하여 청원할 수 있다.
④ 허위로 타인으로 하여금 형사처분 또는 징계를 받게 하는 사항은 허용되지 않는다.
⑤ 구술로써 받은 청원은 이를 수리한 뒤 문서로 증명하여 준다.

[정답] ⑤
[해설] 청원은 문서로써 한다(청원법 제6조).

2. 다음 청원권에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 청원권은 법인에게는 인정되지 않는다.
② 청원을 받은 국가기관은 청원의 결과를 청원인에게 통지하여야 한다.

③ 국민은 자신과 직접 이해관계가 없는 사항에 대해서도 청원할 수 있다.
④ 공무원에 대한 징계나 처벌도 그 대상이 된다.
⑤ 청원을 한 국민은 청원을 하였다는 이유로 차별대우를 받거나 불이익을 받지 않는다.

[정답] ①
[해설] 자연인과 사법인에게 인정된다.

3. 다음 중 국회법상 청원에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?
① 의원의 소개를 얻어 청원서를 제출하여야 한다.
② 의장은 청원서를 접수한 후 소관위원회에 회부하여 심사하게 한다.
③ 국가기관을 모독하는 것은 접수하지 않는다.
④ 정부에서 처리함이 타당하다고 인정되는 청원은 채택할 수 없다.
⑤ 재판에 간섭하는 내용은 접수하지 않는다.

[정답] ④
[해설] 의견서를 첨부하여 정부에 이송한다.

♣ 요점정리

1. 청원은 문서로서 한다.

2. 소관사무가 아닌 사항을 접수한 때에는 처분관서로 이송해야 한다.

3. 청원권은 공권력과의 관계에서 일어나는 여러 가지 이해관계, 의견, 희망 등에 관하여 적법한 청원을 한 모든 국민에게 국가기관이 청원을 수리할 뿐만 아니라 이를 심사하여 청원자에게 그 처리결과를 통지할 것을 요구할 수 있는 권리이다.

4. 공무원은 성실한 복무의무에 저촉되지 않는 한 청원가능하나 직무와 관련된 청원과 집단적 청원은 할 수 없다.

5. 청원에 대하여 국가기관은 수리의무, 심사의무, 통지의무를 부담하나 재결의무는 없다.

제42강 재판청구권 등

♣ 학습목표

재판청구권의 개념 및 내용을 설명할 수 있다.
형사보상청구권의 개념 및 내용을 설명할 수 있다.
국가배상청구권의 개념 및 내용을 설명할 수 있다.
범죄피해자구조청구권의 개념 및 내용을 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

헌법과 법률이 정한 법관에 의한 재판
신속재판, 공정재판, 공개재판
형사보상청구권
국가배상청구권
공무원, 직무, 불법행위, 손해발생, 상당인과관계
범죄피해자청구권

♣ 사전테스트

1. 대법원에 재판을 받을 권리는 헌법상 명문규정이 있다.

정답 : X
해설 : 명문규정이 없어 긍정설과 부정설이 대립하고 있다.

2. 형사보상청구권은 압류가 가능하다.

정답 : X
해설 : 공권이므로 압류가 불가능하다.

3. 과실범에 의해 피해를 입은 경우에도 범죄피해자구조청구권을 청구할 수 있다.

정답 : X
해설 : 정당행위, 정당방위, 과실범에 의한 피해는 보상받을 수 없다(제2조).

♣ 돌발퀴즈

법원은 국가안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해할 염려가 있을 때에는 심리와 선고를 공개하지 않을 수도 있다.

[정답] X
[해설] 국가안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해할 염려가 있을 때에는 심리에 한하여 공개하지 않을 수도 있으나(제109조) 판결은 반드시 공개해야 한다.

♣ 강의내용

1. 재판청구권

⑴ 연혁 및 헌법규정

재판청구권은 1215년 영국의 대헌장에서 배심제도의 형태로 규정되기 시작하였으나 법률에 의한 법관에 의하여 재판을 받을 권리는 1791년 프랑스헌법에서 처음으로 규정되었으며, 그 후, 여러 나라의 헌법에 계수되었다. 1791년 미국의 수정헌법 제6조는 공정한 배심과 신속한 재판을 받을 권리를 규정하였다. 우리 헌법은 형사피고인의 무죄추정권은 제8차 개정헌법에서 규정하였고, 형사피해자의 재판상진술권은 현행 헌법에서 신설되었다.

현행 헌법 제27조는 제1항 법관에 의하여 법률에 의한 재판을 받을 권리, 제2항 군사재판의 예외, 제3항 신속한 재판과 공개재판, 제4항 무죄추청, 제5항 재판절차진술권을 규정하여 재판청구권을 보장하고 있다.

⑵ 의의

재판청구권이란 행정부의 자의적인 판단을 배제하고 독립된 법원에서 신분이 보장된 법관에 의해 적법한 절차에 따른 공정한 재판을 받을 권리를 말한다.

헌법상에 규정되어 있는 기본권이 실질적인 것이 되려면 그에 대한 보장책이 철저하게 마련되어 있어야 한다. 그러한 보장책 가운데에는 형사절차적 보장과 사법절차적 보장이 있으며, 그 중에서도 가장 대표적이고 결정적인 것이 재판청구권이다.

⑶ 법적성격

이에는 청구권설,[789] 청구권과 자유권이라는 이중적 성격을 가진다고 보는 설,[790] 청구권과 절차적 기본권의 성격을 가지는 것으로 보는 설[791] 등의 견해가 있다.

그러나 재판청구권은 국가에 대하여 재판을 청구하는 것을 내용으로 하는 청구권적 기본권으로 다른 기본권을 보장하고 관철하는 기능을 한다. 또한, 재판청구권은 사법제도의 근거규정으로서의 지위를 가지며, 포기할 수 없는 권리이다.[792]

⑷ 주체

재판청구권은 기본권의 주체가 될 수 있는 자라면 누구에게나 그 주체성이 인정된다. 그리고 사법인은 물론 공법인에게도 주체성이 인정된다.[793]

⑸ 내용

<헌법재판소 1995. 9. 28. 92헌가11 등> 특허법 제186조 제1항 등 위헌제청

---

789) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 772면; 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 351면.
790) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 555면.
791) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 551면.
792) 홍성방, 전게서, 351면; 대법원 1961. 11. 2. 4294행상6.
793) 헌법재판소 1991. 9. 16. 89헌마165.

법관에 의한 재판을 받을 권리를 보장한다고 함은 결국 법관이 사실을 확정하고 법률을 해석·적용하는 재판을 받을 권리를 보장한다는 뜻이다. 따라서 그와 같은 법관에 의한 사실확정과 법률의 해석적용의 기회에 접근하기 어렵도록 제약이나 장벽을 쌓아서는 아니 된다. 만일 그러한 보장이 제대로 이루어지지 아니한다면 헌법상 보장된 재판을 받을 권리의 본질적 내용이 침해된다.

<헌법재판소 1998. 12. 24. 94헌바46> 형사소송법 제279조 등 위헌소원

재판청구권은 재판절차를 규율하는 법률과 재판에서 적용될 실체적 법률이 모두 합헌적이어야 한다는 의미에서 법률에 의한 재판을 받을 권리뿐만 아니라 비밀재판을 배제하고 일반 국민의 감시하에서 심리와 판결을 받음으로써 공정한 재판을 받을 권리를 포함하고 있다.

1) 재판을 받을 권리

가. 유형

재판이라 함은 구체적 사건에 관하여 사실의 확정과 그에 대한 법률의 해석적용을 그 본질적인 내용으로 하는 일련의 과정이다.[794] 여기에는 민사·형사·행정·헌법재판이 있다.

나. 요건

재판을 청구할 자격이 있는 자가 법적판단을 구하기에 적합한 사건에 관하여 소를 제기할 이익이 있는 경우라야 한다. 즉, 당사자적격·권리보호사건·소의 이익이라는 요건을 갖추어야 한다.

다. 대법원의 재판을 받을 권리

우리 헌법 제27조는 상고심, 즉 대법원에서 재판을 받을 권리에 대해서는 명문의 규정을 두고 있지 않다. 이에 대해 대법원에서 재판받을 권리를 부여하고 있다는 견해와[795] 그렇지 않다는 견해가 있다.[796]

우리 대법원과 헌법재판소는 헌법 제27조는 상고문제를 법률에 위임하고 있기 때문에 모든 사건에 대하여 대법원의 재판을 받을 권리를 보장하는 것은 아니라고 한다.[797] 그러나 개별입법이 상소권을 전면적으로 인정하지 않는 것은 상소권을 본질적으로 침해하는 것이다.

헌법은 법원의 조직을 대법원과 각급법원으로 하고 있고(제101조 제2항), 헌법상의 명문규정은 없지만 우리 헌법이 예외적으로 비상계엄하에서 군사제한을 일정한 경우에 단심으로 할 수 있도록 하면서도 사형을 선고하는 경우에는 예외를 둔 것(제110조 제4항)과 특별법원인 군사법원의 상고심을 대법원으로 하고 있는 것(제110조 제2항)도 원칙적으로 대법원에서 재판을 받을 권리를 가진다는 것을 의미한다고 한다.[798]

라. 군사재판을 받지 아니할 권리

군인 또는 군무원이 아닌 국민은 대한민국의 영역 안에서는 중대한 군사상 기밀·초병·초소·유독음식물공급·포로·군용물에 관한 죄 중 법률이 정한 경우와 비상계엄이 선포된 경우를 제외하고는 군사법원의 재판을 받지 아니한다(제27조 제2항).

---

794) 헌법재판소 1995. 9. 28. 92헌가11.
795) 김철수, 전게서, 782면; 허영, 전게서, 359면; 홍성방, 전게서, 356면.
796) 권영성, 전게서, 557면; 계희열, 「헌법학」(상), 박영사, 1995, 558면.
797) 대법원 1989. 12. 24. 89다카55 등; 헌법재판소 1997. 10. 30. 97헌바37 등.
798) 홍성방, 전게서, 356면.

2) 헌법과 법률이 정한 법관에 의한 재판을 받을 권리

가. 헌법과 법률이 정한 법관

이는 첫째, 헌법 제101조 제3항에 따라 제정된 법원조직법 제41조와 제42조에서 규정하고 있는 자격이 있어야 하고, 둘째, 헌법 제104조와 법원조직법 제41조가 규정한 절차에 따라 적법하게 임명되어야 하며, 셋째, 헌법 제105조와 제106조에 따라 임기·정년·신분이 보장되어야 하며, 넷째, 헌법 제103조에 따라 헌법과 법률에 의하여 그 양심에 따라 독립하여 심판할 수 있어야 하고, 다섯째, 법원의 구성과 관할 및 그 사무분배 등에 관한 법률의 규정에 의하여 권한이 있어야 하며, 여섯째, 제척 기타의 사유로 법률상 당해 재판에 관여하는 것이 금지되지 아니하여야 한다.[799]

나. 헌법과 법률이 정한 법관에 의한 재판을 받을 권리

요건을 갖추지 않은 자에 의한 재판이라고 하더라도 헌법에 정한 예외가 있거나(군사재판), 불복할 경우에 정규법원에 정식재판을 청구할 길이 열려 있는(약식절차, 통고처분, 행정기관에 의한 재결 또는 결정) 경우에는 헌법과 법률에 법관에 의한 재판을 받을 권리가 침해된 것이라고 보기는 어렵다. 다만, 헌법과 법률에 정한 법관이 아닌 배심원이 사실심뿐만 아니라 법률심에까지 관여한다면 위헌이 될 것이다.

<헌법재판소 2002. 2. 28. 2001헌가18> 변호사법 제100조 제4항 등 위헌제청

대한변호사협회 변호사징계위원회나 법무부 변호사징계위원회의 징계에 관한 결정은 비록 그 징계위원 중 일부로 법관이 참여한다고 하더라도 이를 헌법과 법률이 정한 법관에 의한 재판이라고 볼 수 없다.

3) 법률에 의한 재판을 받을 권리

법률에 의한 재판이라 함은 합헌적인 실체법과 절차법에 따라 행해지는 재판을 말한다.[800] 법률의 범위는 재판의 유형에 따라 다르다. 형사재판의 경우 형식적 의미의 법률에 한정되나,[801] 민사재판이나 행정재판의 실체법은 모든 성문법과 관습법·조리와 같은 불문법을 포함하고, 절차법은 형식적 의미의 법률에 의하여야 한다. 다만, 제108조에 따른 대법원규칙과 제113조 제2항에 따른 헌법재판소규칙은 예외가 된다.

4) 신속한 공개재판을 받을 권리

가. 신속한 재판을 받을 권리

모든 국민은 신속한 재판을 받을 권리를 가진다(제27조 제3항 제1문). 신속한 재판을 받을 권리는 일차적으로는 피고인의 이익을 보호하고 부차적으로는 실체적 진실발견, 소송경제, 재판에 대한 국민의 신뢰와 형벌목적의 달성과 같은 공공의 이익과도 관계를 가지는 기본권이다. 여기서 신속한 재판이란 지연되지 않는 재판을 말한다. 그러나 어떤 경우에 재판이 지연되었는가는 사건의 내용, 심리의 곤란여부, 지연의 원인과 정도, 피고인에 대한 불리한 영향 등을 종합적으로 판단하여야 한다.[802]

---

799) 헌법재판소 1992. 6. 26. 90헌바25.
800) 헌법재판소 1993. 7. 29. 90헌바35.
801) 헌법재판소 1994. 11. 27. 94헌마60.
802) 헌법재판소 1995. 11. 30. 92헌마44; 1999. 9. 16. 98헌마75; 2007. 3. 29. 2004헌바93 등.

<헌법재판소 1993. 11. 25. 92헌마169> 재판의 지연 위헌확인

재판이 지연된 까닭이 재판부 구성원의 변경, 재판의 전제성과 관련된 본안심리의 필요성, 청구인에 송달불능 등인 경우에는 법원이 재판을 특별히 지연시킨 것이 아니다.

나. 공개재판을 받을 권리

공개재판이란 재판의 공정성을 확보하기 위하여 재판의 심리와 판결을 이해관계가 없는 제3자에게도 공개하는 재판을 말한다. 우리 헌법은 형사피고인에게만 공개재판을 받을 권리를 보장하고 있다(제27조 제3항 제2문). 그러나 공개재판을 받을 권리는 일반국민의 권리이기도 하다는 데 학설은 일치되어 있다. 다만, 국가안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해할 염려가 있을 때에는 심리에 한하여 공개하지 않을 수도 있으나(제109조 단서) 판결은 반드시 공개해야 한다(제109조 제1문).

<대법원 1990. 6. 8. 90도646> 재판의 지연

법원이 법정규모·질서유지·심리의 원활한 진행 등을 고려하여 방청을 희망하는 피고인들의 가족·친지 기타 일반국민에게 미리 방청권을 발행하게 하고 그 소지자에 한하여 방청을 허용하는 등의 방법으로 방청인의 수를 제한하는 조치를 취하는 것이 공개재판의 취지에 반하는 것은 아니다.

5) 공정한 재판을 받을 권리

공정한 재판이란 정당한 재판을 말한다. 즉, 정당한 재판이란 신속하고 공개된 법정의 법관의 면전에서 당사자주의와 구두변론주의가 보장되어 있는 재판을 말한다. 따라서 순수한 소송사건에서 권리·의무의 종국적 확정은 공개법정에서 대심구조에 의하여야 한다.[803]

그러나 비송사건절차, 가사소송절차, 파산절차 등과 같이 실제적 권리·의무의 존재를 전제로 하여 법원이 후견적·감독적 입장과 합목적성의 견지에서 재량권을 행사하여 사인 간의 법률관계의 내용을 구체적으로 형성하는 경우에는 임의적 구두변론주의를 택한다 하더라도 그것만으로 정당한 재판을 받을 권리를 침해하는 것은 아니다.

6) 형사피해자의 재판상 진술권

형사피해자는 문제된 범죄행위로 말미암아 법률상 불이익을 받게 되는 자이다. 형사피해자는 당해사건의 재판절차에 증인으로 출석하여 자신이 입은 피해의 내용과 사건에 관하여 의견을 진술할 수 있다. 제27조 제5항의 형사피해자는 모든 범죄행위로 인한 피해자이기 때문에 생명과 신체에 대하여 피해를 입은 헌법 제30조의 범죄피해자보다 넓은 개념이다.[804]

이러한 것을 인정하는 것은 형사소추권을 검사에게 독점시키고 있는 현행 기소독점주의의 형사소송체계 아래에서 형사피해자로 하여금 당해 사건의 형사재판절차에 참여할 수 있는 청문의 기회를 부여함으로써 형사사법의 절차적 적정성을 확보하기 위한 것이다.[805]

⑹ 효력

대국가적 효력이 있다.

---

803) 헌법재판소 1996. 12. 26. 94헌바1.
804) 헌법재판소 1993. 3. 11. 92헌마48; 1995. 7. 21. 94헌마136 등.
805) 헌법재판소 2003. 9. 25. 2002헌마533.

⑺ 제한 및 한계

1) 일반적 제한

헌법은 국회의 자율권을 존중하는 취지에서 국회에서 행한 국회의원에 대한 자격심사와 징계 및 제명처분에 대해서는 법원에 제소할 수 없도록 하고 있다(제64조 제4항). 또한, 헌법 제37조 제2항에 따라 제한될 수 있다. 그러나 본질적인 내용은 침해할 수 없다. 즉, 법관에 의하여 적어도 한 차례의 사실확정과 법률의 해석작용의 기회가 보장될 것과 그 접근기회가 사실상 가능할 것은 재판청구권의 본질적 내용에 속하므로 제한 될 수 없다.[806]

재판청구권을 제한하는 법률로는 법원조직법, 헌법재판소법, 민사소송법, 형사소송법, 행정소송법, 군사법원법, 소액사건심판법 등이 있다.

2) 특별한 제한

군인과 군무원은 일반법원이 아닌 군사법원에 의한 재판을 받는다(제110조). 또한, 비상사태시 법원의 권한에 대하여 특별한 조치를 하는 경우 국민의 재판청구권이 제한될 수 있다. 특히, 비상계엄하에서는 일반국민도 군사법원의 재판을 받아야 하며, 상소까지 제한당하는 경우가 있다(제27조 제2항, 제77조 제3항, 제110조 제3항).

2. 형사보상청구권

⑴ 연혁 및 헌법규정

형사보상청구권은 1849년 프랑크푸르트헌법에서 처음으로 규정된 것으로 알려져 있다. 우리 헌법은 형사피고인에 대한 보상은 건국헌법에서부터 규정하였고, 형사피의자에 대한 보상은 현행 헌법에서 신설하였다.

우리 헌법 제28조는 형사피의자 또는 형사피고인으로서 구금되었던 자가 법률이 정하는 불기소처분을 받거나 무죄판결을 받은 때에는 법률이 정하는 바에 의하여 국가에 정당한 보상을 청구할 수 있다고 하여 형사보상청구권을 규정하고 있다.

⑵ 개념

형사보상청구권이란 형사피의자나 형사피고인으로 구금되었던 자가 불기소처분이나 무죄판결을 받은 경우 그가 입은 정신적·물질적 손실을 국가에 대해 청구할 수 있는 권리를 말한다.

⑶ 법적성격

직접적 효력규정설이 다수설이다.[807] 그러나 헌법 제28조는 법률이 정하는 불기소처분이라고 정하고 있으므로 형사보상청구의 구체적인 대상과 내용 및 절차는 법률이 정하는 바에 따른다.[808]

---

806) 헌법재판소 1992. 6. 26. 90헌바25; 1993. 7. 29. 90헌바35; 1995. 9. 28. 92헌가11 등.
807) 김철수, 전게서, 805면; 권영성, 전게서, 581면; 허영, 전게서, 360면; 계희열, 전게서, 601면.
808) 홍성방, 전게서, 367면.

⑷ 주체

형사피고인, 형사피의자, 그 상속인 및 외국인이 주체가 된다. 법인은 성질상 주체가 될 수 없다.

⑸ 내용

성립요건으로는 첫째, 형사피의자 또는 형사피고인으로서 미결구금, 형집행으로 구금이 되었을 것을 요한다. 그러나 불구속으로 조사를 받거나 기소된 자는 형사보상을 청구할 수 없다. 둘째, 형사피의자인 경우는 법률이 정하는 불기소처분을 받아야 한다. 이때의 불기소처분은 협의의 불기소처분, 즉 무혐의, 범죄불성립, 공소권 없음의 경우에 한정되고, 기소유예나 기소중지처분은 제외된다(형사보상법 제26조).

셋째, 형사피고인인 경우는 무죄판결(무죄·면소·공소기각)을 받아야 한다.

넷째, 형사보상책임은 무과실 결과책임이므로 관계기관의 고의나 과실을 필요로 하지 않는다.

정당한 보상을 의미하며, 형사보상청구권자가 입은 손실액의 완전한 보상이어야 한다. 형사피의자의 경우는 검사의 불기소처분 후 1년 이내 그 검사가 소속된 지방검찰청의 피의자보상심의회에 청구를 하여야 하며, 불복은 법무부장관의 재결을 거쳐 행정소송을 제기할 수 있다.

형사피고인의 경우에는 무죄판결을 받은 후 1년 이내에 무죄판결을 한 법원에 청구하여야 한다. 보상청구에 대해서는 법원합의부에서 재판한다. 불복할 수는 없으나 기각결정에 대해서는 즉시 항고할 수 있다.

3. 국가배상청구권

⑴ 연혁 및 헌법규정

공무원의 직무행위로 인한 손해에 대하여 국가 또는 공공단체가 책임을 지는가 하는 문제는 국가에 따라 다르다. 독일에서는 1919년 바이마르헌법 제131조에서 국가대위책임을 인정하였고, 프랑스에서는 1873년 블랑코사건에서 국가의 책임을 인정하였다. 영국에서는 1947년 국왕소추법에서, 미국의 경우에는 1946년 연방불법행위배상청구법에서 일정한 범위 내의 국가책임을 인정하고 있다. 우리나라는 건국헌법 이래 국가배상청구권을 인정하고 있다.

현행 헌법 제29조 제1항은 공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가 또는 공공단체에 정당한 배상을 청구할 수 있다. 이 경우 공무원 자신의 책임은 면제되지 아니한다. 제2항은 군인·군무원·경찰공무원 기타 법률이 정하는 자가 전투·훈련 등 직무집행과 관련하여 받은 손해에 대하여는 법률이 정하는 보상 외에 국가 또는 공공단체에 공무원의 직무상 불법행위로 인한 배상은 청구할 수 없다고 규정하여 국가배상법이 제정·시행되고 있다.

⑵ 의의

국가배상청구권이란 국민이 공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 경우에 국가 또는 공공단체에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있는 권리이다. 이는 정의·공평의 이념에 따라 국가에게도 불법행위의 책임을 인정하는 것이며(국가무책임사상), 공무원 개인의 책임만으로 충분한

손해배상을 기대하기 어렵기 때문에 인정되는 것으로,[809] 법치주의의 원리를 구현하기 위하여 인정된 기본권이다.[810]

⑶ 법적성격

대법원은 국가배상법을 사법으로 보고 국가배상에 관한 소송을 민사소송의 절차에 따르도록 하고 있다.[811] 헌법재판소는 헌법상 국가배상청구권에 관한 규정은 단순한 재산권보장만을 의미하는 것은 아니고 국가배상청구권을 청구권적 기본권으로 보장하고 있는 것이다고 판시한 바 있다.[812]

그러나 '법률이 정하는 바에 의하여'란 구체적인 기준과 방법을 규정한다는 의미일 뿐이고,[813] 청구권자체는 헌법에서 직접도출된다고 보아 직접 국가배상을 청구할 수 있어야 하고,[814] 누구든지 국가 또는 공공단체에 그 불법행위로 인한 손해 전부의 배상을 청구할 수 있는 기본권을 보장한 것이며,[815] 헌법규정에 의해서 직접효력이 인정되는 헌법상의 주관적 공권이며,[816] 국가배상법이 권리의 양도성 등을 제한하고 있기 때문에 국가배상청구권을 공권이라고 한다.

⑷ 주체와 객체

1) 주체

원칙적으로 자연인인 국민과 법인에게 주체성이 인정된다. 외국인의 경우에는 호혜주의 원칙에 따라 주체성이 인정된다(국가배상법 제7조). 군인과 군무원에세는 이중배상이 금지된다(제29조 제2항).

2) 객체

국가와 공공단체, 즉 국가기관, 지방자치단체, 공공조합, 영조물법인 등이다. 그러나 외국공관원은 국가기관이 아니므로 국가는 외국공관원의 불법행위에 대하여 책임을 지지 않는다.[817]

⑸ 내용

국가배상청구권이 성립하기 위해서는 공무원의 직무상의 불법행위로 손해가 발생하여야 한다(헌법 제29조 제2항, 국가배상법 제2조 제1항). 이러한 국가배상책임에 대해서는 대법원은 공무원의 위법행위가 고의나 중과실에 기한 경우에는 기관의 행위로 볼 수 없으므로 대위책임이나 경과실에 의한 경우에는 자기책임으로 본다는 중간설을 따르고 있다.[818] 그러나 다수설은 국가의 배상책임은 국가가 공무원의 책임을 대신지는 것이 아니라 기관의 행위를 통해 지는 자기책임이라고 한다.

---

809) 김철수, 전게서, 809면.
810) 권영성, 전게서, 566면.
811) 대법원 1972. 10. 10. 69다701.
812) 헌법재판소 1997. 2. 20. 96헌바24.
813) 허영, 전게서, 554면.
814) 김철수, 전게서, 810면; 대법원 1971. 6. 22. 70다1010.
815) 김철수, 전게서, 811면.
816) 허영, 전게서, 556면.
817) 대법원 1997. 4. 25. 96다16940.
818) 대법원 1996. 2. 15. 95다38677 등.

1) 공무원

최광의의 공무원으로 널리 공무를 위탁받아 이에 종사하는 모든 자를 말한다. 예컨대, 소집중인 향토예비군, 시청소방차운전수, 철도건널목간수, 철도차장, 소방원, 통장, 집달관 등은 공무원으로 보나 의용소방대원, 시영버스운전수, 자원봉사자는 공무원이 아니라고 한다.[819]

<헌법재판소 1989. 7. 28. 89헌마61> 국가배상법 제2조에 관한 헌법소원
6. 25 사변시 적과 교전 중에 포탄을 맞아 부상한 청구인은 공무원의 불법행위로 손해를 받은 국민에 해당될 수 없다.

2) 직무상의 행위

권력행위 외에 관리행위까지를 포함하는 것이 통설과 판례의 입장이다.[820] 또한, 직무를 집행함에 당하여의 의미는 주관적 의사와 관계없이 외관을 객관적으로 관찰하여 직무행위의 여부를 판단하려는 객관설이 통설과 판례의 입장이다.[821]

3) 불법행위

고의·과실에 의하여 법령에 위반한 행위를 말한다. 여기서 행위는 작위·부작위·행위의 지체가 포함되며, 법령은 법률, 명령, 관습법을 불문한다. 고의·과실의 입증책임은 피해자에게 있다.[822]

4) 타인에 대한 손해의 발생

손해는 재산적·정신적·소극적·적극적 손해를 모두 포함하며, 가해자인 공무원 이외의 타인에게 발생하여야 한다. 손해와 불법행위사이에는 상당인과관계가 있어야 한다.[823]

⑹ 제한

헌법 제29조 제2항에 의해 제한될 수 있고, 헌법 제37조 제2항에 의해 제한될 수 있다. 그러나 본질적인 내용은 침해할 수 없다. 예컨대, 국가배상책임을 전면적으로 부인하는 입법이나 배상기준을 지나치게 낮게 규정하는 입법은[824] 국가배상청구권의 본질적 내용을 침해하는 것으로 재고되어야 할 것이다.

4. 범죄피해자구조청구권

⑴ 연혁 및 헌법규정

범죄피해자가 입은 손해에 대하여 1929년과 1936년에 멕시코와 쿠바에서 범죄피해자보상제도가 입법화 된 바 있지만 큰 영향을 주지는 못하였다가 1963년 뉴질랜드에서 제정된 형사재해보상법이 범죄피해자구조제도에 큰 영향을 주었다. 우리 헌법은 현행 헌법에서 범죄피해자 청구권을 신설하였고, 1988년 7월 1일부터 범죄피해자구조법이 시행되고 있다.

---

819) 대법원 1970. 5. 26. 70다471 등.
820) 대법원 2001. 1. 5. 98다39060 등.
821) 대법원 2001. 1. 5. 98다39060 등.
822) 대법원 1997. 6. 13. 96다56115 등.
823) 대법원 1970. 3. 24. 70다152 등.
824) 철도법 제4장, 우편법 제5장, 우편물운송법 제1저, 공중전기통신사업법 제90조 등은 배상책임의 범위를 상당히 제한하고 있다.

우리 헌법 제30조는 범죄피해자청구권을 규정하고 있다.

⑵ 개념

범죄피해자는 가해자에게 민법상 불법행위에 기한 손해배상을 청구하거나 형사배상명령 제도(소송촉진 등에 관한 특례법 제25조 제1항) 등을 통해 손해배상을 청구할 수 있다. 형사배상명령 제도란 형사사건의 피해자가 별도로 민사상의 손해배상을 청구하지 않고 형사 공판절차에서 피고인에게 유죄판결을 선고할 경우 법원이 직권 또는 신청에 의하여 피고사건의 범죄행위로 인한 손해의 배상을 명령하여 다시 민사재판을 하는 2중의 수고를 덜 목적으로 만들어진 제도이다.

그러나 이와 같은 제도는 범죄가해자가 불명 또는 도주하거나, 수중에 재산이 전혀 없어 피해배상의 자력이 없는 경우에는 의미가 없는 제도이다. 따라서 국가는 생명 또는 신체를 해치는 범죄로 인해 사망·장해·중상해를 입은 피해자가 범죄로 인한 손해의 전부 또는 일부를 배상받지 못한 경우 피해자에게 지급하는 보전적 성격의 금원을 지급하는데 이것이 범죄피해자구조금이다(범죄피해자보호법 제16조 및 제32조).

⑶ 법적성격

우리 헌법재판소는 범죄로부터 국민을 보호해야 할 국가의 의무는 범죄행위로 인해 피해를 받은 국민에 대하여 국가가 적극적인 구조행위까지 하도록 규정하여 피해자의 기본권을 생존권적 기본권의 차원으로 인정한 것이라 판시한 바 있다.[825]

⑷ 주체

헌법 제29조는 '타인의 범죄로 인하여 생명·신체에 대한 피해를 받은 국민'으로 규정하고 있다.

⑸ 내용

1) 타인의 범죄행위로 인한 피해의 발생

첫째, 범죄피해자구조청구권이 성립하려면 우선 "타인의 범죄행위"로 인해 "생명·신체에 피해"가 발생하여야 한다(범죄피해자보호법 제1조).

둘째, "타인의 범죄행위"란 대한민국의 영역 안이나 대한민국의 영역 밖에 있는 대한민국의 선박 항공기 안에서(속지주의+기국주의) 사람의 생명이나 신체를 해치는 행위로서 살인·상해·폭행 등의 행위를 의미한다. 다만 형법 제20조의 정당행위와 제21조의 정당방위, 과실에 의한 행위는 제외된다.

셋째, "생명·신체에 피해"란 사망하거나 장해 또는 중상해를 입은 경우를 말한다(범죄피해자보호법 제3조 제4호). 생명과 신체에 입은 피해만 구조되므로 재산이 손괴되어 발생한 손해 등은 구조의 대상에서 제외된다. 또한, 장해 또는 중상해를 입은 경우를 말하므로 완치가 되는 상해의 경우에도 구조의 대상이 아니다.

825) 헌법재판소 1989. 4. 17. 88헌마3.

2) 범죄피해의 전부 또는 일부를 배상받지 못할 것

범죄피해자구조청구권은 구조피해자가 피해의 전부 또는 일부를 배상받지 못하는 경우에 발생하는 권리이다. 과거 개정 전 법률에서는 "가해자의 불명 또는 무자력으로 피해자가 피해의 전부 또는 일부를 배상받지 못하는 경우"에 범죄피해자구조청구권을 인정하였으나 최근 개정된 법률은 "가해자의 불명 또는 무자력"이라는 구 조항의 내용을 삭제하여 범죄피해자 구조의 범위를 확대하였다.

3) 제외사유에 해당하지 않을 것

범죄행위 당시 구조피해자와 가해자 사이에 친족관계(부부, 직계혈족, 4촌 이내의 친족, 동거친족)인 경우에는 구조금을 지급하지 않는다(범죄피해자보호법 제19조 제1항). 이외의 친족관계가 있는 경우에는 구조금의 일부가 감액된다(범죄피해자보호법 제19조 제2항).

⑹ 효력

대국가적 효력을 가진다.

⑺ 제한

헌법 제37조 제2항에 따라 제한할 수 있다. 그러나 본질적인 내용은 침해할 수 없다. 예컨대, 국가구조책임을 부인하는 입법은 본질적인 내용의 침해가 된다.

♣ 문제풀이

1. 다음 중 반드시 재판청구권에 속한다고 볼 수 없는 것은?

① 형사피해자의 재판상 진술권
② 대법원의 재판을 받을 권리
③ 신속한 공개재판을 받을 권리
④ 법률에 의한 재판을 받을 권리
⑤ 헌법과 법률이 정한 법관에 의한 재판을 받을 권리

[정답] ②
[해설] 헌법재판소 1997. 10. 30. 97헌바37 등.

2. 다음 중 형사보상청구권에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 피고인보상의 성립요건으로서의 무죄판결은 당해 절차에 의한 무죄판결의 경우만을 의미한다.
② 우리 헌법에서는 국가배상제도와 따로 규정하여 정당한 보상을 강조한다.
③ 무죄판결의 경우에도 형사미성년자 또는 심신장애자의 행위라는 이유로 무죄판결이 행해진 경우에 법원은 재량에 의하여 보상청구의 전부 또는 일부를 기각할 수 있다.
④ 형사보상책임은 관계기관의 고의나 과실을 요하지 않는다.
⑤ 원칙적으로 외국인도 주체성이 인정된다.

[정답] ①
[해설] 재심, 비상상고에 의한 무죄판결을 포함한다(제1조 제1항).

3. 다음 중 국가배상법상의 공무원에 해당하지 않는 자는?
① 소집중인 예비군 ② 교통할아버지 ③ 별정우체국장 ④ 시청소차 운전사
⑤ 전기통신공사직원

[정답] ⑤
[해설] 공공단체 중 공공조합 및 영조물법인의 구성원은 공무원에 포함되지 않는다.

♣ 요점정리

1. 법원은 국가안전보장 또는 안녕질서를 방해하거나 선량한 풍속을 해할 염려가 있을 때에는 심리에 한하여 공개하지 않을 수도 있다.

2. 재판청구권은 재판절차를 규율하는 법률과 재판에서 적용될 실체적 법률이 모두 합헌적이어야 한다는 의미에서 법률에 의한 재판을 받을 권리뿐만 아니라 비밀재판을 배제하고 일반국민의 감시하에서 심리와 판결을 받음으로써 공정한 재판을 받을 권리를 포함하고 있다.

3. 형사재판의 경우 형식적 의미의 법률에 한정되나, 민사재판이나 행정재판의 실체법은 모든 성문법과 관습법·조리와 같은 불문법을 포함하고, 절차법은 형식적 의미의 법률에 의하여야 한다. 다만, 제108조에 따른 대법원규칙과 제113조 제2항에 따른 헌법재판소규칙은 예외가 된다.

4. 국가배상청구권이란 국민이 공무원의 직무상 불법행위로 손해를 받은 경우에 국가 또는 공공단체에 대하여 손해의 배상을 청구할 수 있는 권리이다. 이는 정의·공평의 이념에 따라 국가에게도 불법행위의 책임을 인정하는 것이며(국가무책임사상), 공무원 개인의 책임만으로 충분한 손해배상을 기대하기 어렵기 때문에 인정되는 것으로,[826] 법치주의의 원리를 구현하기 위하여 인정된 기본권이다.

5. 직무란 권력행위 외에 관리행위까지를 포함하는 것이고, 직무를 집행함에 당하여의 의미는 주관적 의사와 관계없이 외관을 객관적으로 관찰하여 직무행위의 여부를 판단하려는 것이다.

6. 국가는 생명 또는 신체를 해치는 범죄로 인해 사망·장해·중상해를 입은 피해자가 범죄로 인한 손해의 전부 또는 일부를 배상받지 못한 경우 피해자에게 지급하는 보전적 성격의 금원을 지급하는데 이것이 범죄피해자구조금이다.

826) 김철수, 전게서, 809면.

제43강 국민의 기본의무

♣ 학습목표

국민의 기본의무에 대하여 설명할 수 있다.

♣ 학습내용

국민의 기본의무의 개념 및 연혁
전국가적 의무, 실정법상 의무
직접적 효력, 선언적 효력
진정의무와 부진정의무
인간의 의무와 국민의 의무
선험적 의무와 비선험적 의무
고전적 의무와 현대적 의무
기본권과 기본의무의 충돌 및 경합
납세의 의무, 국방의 의무, 근로의 의무, 환경보전의무
교육을 받게 할 의무, 재산권행사의 공공복리적합의무

♣ 사전테스트

1. 우리 헌법은 헌법과 법률의 준수의무·국가수호의무에 대해서 규정하고 있다.

정답 : X
해설 : 헌법과 법률의 준수의무·국가수호의무에 대해서는 명시적인 규정은 없지만 법치국가적 민주주의의 요청에 따라 인정될 수 있다.

2. 우리 헌법 제31조 제1항의 교육을 받게 할 의무는 부진정의무에 해당한다.

정답 : X
해설 : 우리 헌법 제31조 제1항의 교육을 받게 할 의무는 진정의무에 해당한다. 제23조가 부진정의무에 해당한다.

3. 우리 헌법상 납세의 의무는 인간의 의무이다.

정답 : X
해설 : 모든 외국인에게 적용되지 않고, 국내에 재산을 가지고 있거나 조세의 대상이 되는 행위를 하는 경우에만 납세의 의무가 있으므로 납세의 의무는 국민의 의무에 해당한다.

♣ 돌발퀴즈

사용료나 수수료의 징수, 전매수입, 공채수입 등은 조세에 해당한다.

[정답] X

[해설] 일정한 반대급부를 내용으로 하는 사용료나 수수료의 징수, 전매수입, 공채수입 등은 조세에 해당되지 않는다(헌법재판소 1991. 11. 25. 91헌가6).

♣ 강의내용

1. 의의

(1) 연혁

기본의무에 선행하는 인간의 자연적 의무라는 개념은 근대 계몽주의의 산물이다. 계몽주의시대의 국가 사상가들은 국가공동체는 권리와 의무로 구성된 것으로 생각하였다. 특히, 자연법이론가들은 시민 상호 간의 평화유지의무, 사회적으로 권위 있는 기관에 의하여 제정·공포된 법률의 준수의무 등과 같은 인간의 자연적 의무에 대하여 언급하였다.[827]

그러나 기본권과 기본의무라는 용어를 사용하면서 체계상 대응되는 것으로 이해한 이는 페더(Johann Georg Heinrich Feder : 1740년~1821년)였다.[828] 그는 기본의무를 원초적인 법적평등으로부터 개인의 무제한적인 소극적 의무로 이해하여 한 사람이 자연상태의 권리를 주장함에 있어 타인의 생명을 해치거나 타인의 발전을 방해하거나 타인을 중상하거나 기만해서는 안 되는 의무로 보았다. 따라서 그가 사용한 기본의무는 동시대의 사람들이 시민의 의무와는 정반대의 의미로 사용한 인간의 의무 또는 자연적 의무에 대응된다.[829]

한편, 공동체를 이성법적으로 이해하는 견해에 따르면 '본래의 의무'(ursprüngliche Pflicht)는 기본적 자유권의 내재적 한계와 동일한 개념이다.

그러나 인간의 자연적 의무가 국민의 법적의무로 된 것은 근대국가의 등장과 함께였다. 근대국가 이전에는 국왕은 법률규정의 유무와 관계없이 납세를 강제함으로써 국민의 재산권을 부당하게 침해하였고 또 자의적으로 국민의 신체를 구속하여 병역과 부역을 강제하기도 하였다. 그 후, 영국은 1628년 권리청원에서 국왕의 이러한 자의적인 조세징수나 강제적인 징병을 억제하기 위하여 의회의 승인에 의한 과세와 징병의 원칙이 확립되었다.

1776년 버지니아 권리장전과 1789년 프랑스 인권선언을 선언했던 이들은 인간에게는 기본적인 사회적·정치적 의무가 있다는 것을 자명한 것으로 보았다. 따라서 그들은 여러 헌법문서에서 사람들이 생명과 자유와 재산을 보호받을 권리를 가진다면 그러한 권리를 가진 사람들은 그 권리를 보호하는 기관에서 소요되는 비용을 부담해야 한다고 선언하였고 그러한 의무는 인권선언에 포함되기도 하였다. 이러한 의무들은 시민인 인간에게 부과된 의무로서 모든 사람의 평등한 자유를 확보하기 위하여 없어서는 안 될 개인적 권리들의 내재적 자기제한(제약)으로 이해되지 않고, 공동체의 부과된 의무로 이해되었다. 그 결과, 18세기 초 헌법문서에는 기본권 이외에도 충성의 의무, 국방의 의무, 납세의 의무, 재산양도의 의무 등이 규정되기 시작하였다. 이러한 의무들을 고전적 기본의무라 한다.[830]

---

827) Th. Maunz/R. Zipeelius, Deutsches Staatsrecht, 25. Aufl., 1983, S. 173.

828) J. G. H. Feder, Lehrbuch der praktischen Philosophie, 1771.

829) H. Hofmann, Grundpflichten und Grundrechte, in : Isensee/Kirchhof(Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Bd. V, 1992, S. 321ff.

830) 홍성방, 「헌법학」(중), 박영사, 2010, 390면.

그러나 그러한 국민의 의무가 헌법규범화된 것은 1789년 프랑스 인권선언과 프랑스 인권선언의 내용을 그대로 받아들인 1791년의 프랑스 헌법 제13조에서 간접적으로 납세의 의무를 규정한 것이 처음이라고 할 수 있다.[831] 그리고 1795년 프랑스 헌법은 '인간과 시민의 권리·의무의 선언'을 규정하여 사회의 방위의무, 법률에의 복종의무 등의 내용으로 구성된 9개조의 의무목록을 규정하였다.

1919년 바이마르헌법은 종래의 납세의무와 병역의무 이외에도 새로운 의무에 대하여 자세한 규정을 두어 국가의 사회적 성격을 강조하고, '자유의 개인주의원칙'을 수정한 최초의 헌법으로 알려져 있다.[832] 이 후, 독일기본법은 부분적으로 기본의무를 규정하고 있다.[833]

우리 헌법은 국민의 기본의무로서 제23조 제2항 재산권행사의 공공복리적합의무, 제31조 제2항 교육을 받게 할 의무, 제32조 제2항 근로의 의무, 제35조 제1항 환경보전의 의무, 제38조 납세의 의무, 제39조 제1항 국방의 의무를 규정하고 있다. 그러나 우리 헌법은 헌법과 법률의 준수의무·국가수호의무에 대해서는 명시적으로 규정하고 있지는 않으나 인정되는 것으로 보고 있다.[834]

⑵ 개념

의무(Obligatio, Officium)는 권리에 반대되는 개념이다. 의무는 객관적 법질서에 근거를 두며, 명령을 이행하거나 금지를 존중할 구속력을 가지는 요청을 의미한다. 권리가 '해도 된다'(dürfen) 또는 '할 수 있다'(können)라는 형태임에 반하여, 의무는 '하여야 한다'(sollen)의 형태로 표현된다. 또한, 권리와 의무는 밀접한 관계가 있으나(예컨대, 채권과 채무, 기본권과 수인의무 등), 그렇다고 의무가 반드시 권리를 전제로 하는 것은 아니다(예컨대, 국방의 의무 등). 그러나 권리가 존재하고 실효성을 가지기 위해서는 법공동체의 기관이 권리를 보장할 의무가 전제되지 않으면 안 된다.[835]

법의 영역에서 의무를 이행을 요구하기 위해서는 그에 해당하는 법적근거가 있어야 한다. 그렇다고 법이 실정법 이전의 인간생활과 법규범 이외의 다른 규범과 무관하다는 것은 아니다(예컨대, 법과 도덕, 법과 사회상규, 법과 종교 등). 왜냐하면 개개의 법적의무들은 궁극적으로는 인간을 인격으로 대우하는 데 그 근거를 가지고 있기 때문이다(예컨대, 가족의 화목, 친구와의 우정, 연인과의 사랑 등과 인간의 존엄과 가치). 이에 대하여 헤겔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel : 1770년~1831년)은 '법적명령은 하나의 인격을 다른 인격과 마찬가지로 존중하라는 것이다'고 한 바 있다.[836]

법적의무의 구속성은 의무자의 내적동의에 따라 좌우되는 것이 아니다. 법적의무의 구속성은 법질서가 가지는 객관적 효력에 근거를 두고 있는 것이다. 달리 말하면, 법적의무의 이행은 합법성의 한도 내에 그칠 수밖에 없다. 그러나 법이 존엄과 자유를 통하여 특징지어지는 인간의

---

831) 1791년 프랑스 헌법 제13조 : 병력을 유지하고 행정비용을 감당하기 위해서는 일반적인 조세가 필수적이다. 조세는 국민의 재산상황을 고려하여 모든 국민에게 평등하게 부담시켜야 한다.

832) 바이마르헌법은 제120조의 양친의 자녀 교육의무, 제132조의 명예직활동을 받아들일 의무, 제133조의 병역의무, 제134조의 공적부담을 할 의무, 제145조의 취학의무, 제153조의 재산권의 공공복리 적합의무, 제163조의 근로의 의무, 제155조 제3항의 토지를 경작하고 충분히 이용할 의무·토지에 대한 노동 또는 자본의 투입 없이 생긴 지가의 상승을 전체를 위하여 이용할 의무 등을 규정하였다.

833) 독일기본법 제5조 제3항 제2문은 교수의 자유는 헌법에 대한 충성으로부터 벗어나지 못한다, 제14조 제2항은 재산권의 행사는 의무를 수반하고 그 행사는 공공복리에 봉사하여야 한다, 제12a 제1항은 만 18세 이상의 남자에게는 군대, 연방국경수비대 또는 민방위대에 복무할 의무를 지울 수 있다 등이 있다.

834) 허영, 「한국헌법론」, 박영사, 2009, 561면; 홍성방, 전게서, 392면.

835) 홍성방, 전게서, 388면.

836) G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 5. Aufl., 1995, §36.

인격성에 근거를 두고 있는 한, 법적의무를 오로지 타율적 강제의무라고 생각하는 것은 아마도 법실증주의의 잘못이라고 할 수 있을 것이다. 따라서 우리가 법적의무를 이행하는 것은 그것이 동시에 윤리적인 요청이기 때문이며(법은 최소한의 도덕), 법은 자유로운 윤리적 의무이행에 반드시 필요한 조건이라고 할 수 있다(심리적 강제).

따라서 국민의 기본의무란 국민의 기본권에 대응하는 개념으로 국민이 국가구성원으로서 부담하는 여러 의무 가운데서 특히 헌법이 규정하고 있는 의무,[837] 즉 국가에 대한 국민의 헌법적 의무(헌법에 의하여 요청된 공공복리에 대한 기여의무)를 말한다.[838] 그러므로 개별법상의 의무는 기본의무가 아니다.[839] 이러한 기본의무의 개념은 자연적 의무에서 시민적 의무로 변천하였다.

2. 법적성격

국민의 기본의무가 전 국가적 의무인지 실정법상 의무인지 견해가 나누어져 있다. 그러나 국민의 기본의무를 전 국가적 의무로 보는 경우 그것은 무제한의 의무를 의무하고, 이는 헌법과 법치국가의 원리의 위반이 된다. 따라서 기본의무라고 하는 것은 국가공동체를 형성하고 유지하기 위한 국민의 실정법상의 의무에 지나지 않는다고 보는 견해가 일반적이다.[840]

또한, 직접적인 효력을 갖는 것인지 선언적 효력만을 갖는 것인지에 대해서도 견해가 나누어져 있다. 그러나 기본의무는 프로그램적 성격과 원칙규범으로서의 성격 및 입법위임규정으로서의 성격을 가진다고 보아야 한다.[841] 왜냐하면 첫째, 헌법에 기본의무가 있다고 해서 기본의무가 곧바로 현실화되는 것은 아니어서 자동집행력을 갖지 못하며, 기본의무가 법적으로 강제될 수 있는 의무가 되기 위해서는 전적으로 입법자에 의한 구체적입 입법이 필요하다. 따라서 기본의무는 입법자가 구체화 입법을 하지 않으면 '불완전한 법'에 지나지 않는다.

둘째, 기본의무는 원칙규범으로서의 성격을 가진다. 즉, 기본의무는 그 의무를 구체화한다는 의미에서 의회가 법률규정을 의무적으로 정립할 것을 내용으로 하는 원칙을 선언하고 있다. 구체적으로는 교육의 의무와 병역의 의무가 있다.

셋째, 기본의무는 입법위임규정으로서의 성격을 가진다. 즉, 헌법상의 프로그램을 현실화시키는 것은 전적으로 입법자에게 위임되어 있긴 하나 기본의무가 공동체의 이익을 제도화시키고 있는 경우(예컨대, 기본권분야에서 권리를 해석하고 적용하는 원칙을 제공하는 경우) 입법화가 필수적인 것은 아니다. 그러나 그렇다고 해서 기본의무의 구체적입법이 없는 상황에서 정부나 법원에서 법적구속력을 가진 법률의 하위규범에 의해 기본의무를 구체화할 수 있다는 것을 의미하지는 않는다. 왜냐하면 기본의무의 존재를 인정하는 것은 기본권을 모든 국가기관에 의하여 실현될 수 있는 사회의무성의 유보하에 두는 것을 부정하기 때문이며, 대의민주제적 헌법하에서 개개인의 자유와 의무를 호혜주의 원칙과 모든 이의 평등한 자유의 원칙에 따라 조정하는 것은 입법자의 임무이기 때문이다.[842]

---

837) Th. Schramm, Staatsrecht, Bd. III, 3. Aufl., 1985, S. 17.
838) V. Götz, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, VVDStRL Heft 41, 1983, S. 7ff.
839) C. Gusy, Grundpflichten und Grundgesetz, JZ, 1982, S. 657ff.
840) 홍성방, 전게서, 392면.
841) 홍성방, 젠게서, 392면.
842) H. Hofmann, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, in : VVDStRL Heft 41, 1983, S. 42ff.(77).

3. 유형 및 특징

⑴ 유형

1) 진정의무와 부진정의무

진정의무는 헌법이 직접적으로 특정의 법적결과를 언급하고 있는 의무를 말하고, 입법자는 헌법의 범주 내에서 구체화시킬 수 있을 뿐이다. 예컨대, 우리 헌법 제31조 제1항의 교육을 받게 할 의무가 이에 속한다. 따라서 헌법유보라 한다.

부진정의무는 헌법이 직접적으로 특정의 법적결과를 언급하고 있지 않는 의무를 말하고, 입법자는 입법을 통하여 내용과 한계를 구체화시킬 권한을 갖는다. 예컨대, 우리 헌법 제23조는 재산권규정이 이에 속한다. 따라서 법률유보라 한다.

2) 인간의 의무와 국민의 의무

헌법의 의무적용이 인간을 대상으로 하는 것을 인간의 의무라 한다. 예컨대, 독일기본법 제12조a 제1항 만18세 이상의 남자에게는 군대, 연방국경수비대 또는 민방위대에 복무할 의무를 진다는 규정이 이에 속한다. 그러나 이는 강학상의 해석일 뿐이고, 실제에 있어서는 인간의 권리라고 보기 어려우며 오히려 국민의 권리에 속한다고 할 수 있다.

헌법의 의무적용이 국민을 대상으로 하는 것을 국민의 의무라 한다. 예컨대, 우리 헌법상의 납세, 병역의무 등이 포함된다.

3) 선험적 의무와 비선험적 의무

선험적 의무는 헌법이 규정하고 있는 의무이다. 따라서 우리 헌법에서 규정하고 있는 의무는 모두 여기에 해당한다.

비선험적 의무는 헌법과 법률에 규정되어 있지 않더라도 인정될 수 있는 의무이다. 예컨대, 헌법과 법률의 준수의무·국가수호의무에 대해서는 명시적인 규정은 없지만 법치국가적 민주주의의 요청에 따라 인정될 수 있다.

4) 고전적 의무와 현대적 의무

고전적 의무는 공화정적 시민의 의무라는 의미에서 본래의 헌법적 기본의무를 의미한다. 예컨대, 법률에 복종할 의무, 병역의 의무, 납세의 의무 및 재산양도의 의무가 이에 해당하고, 이러한 의무는 개인적 권리의 제한이 아니라 공동체에 대한 실정적 의무부여를 의미한다.

현대적 의무는 바이마르헌법에서부터 규정되기 시작한 의무를 말하며, 교육의 의무, 환경보전의 의무, 재산권행사의 공공복리적합의무 등이 이에 속한다.

⑵ 특징

고전적 의무는 국가권력의 남용을 억제하고, 국가권력의 발동을 제한한다는 의미에서 소극적이고 방어권이었으나 오늘날에는 주권자인 국민이 스스로 국가의 존립과 안전을 위하여 병력을 유지하고, 국가의 재정을 위하여 조세를 납부한다는 적극적 의미도 가지고 있다.

그리고 현대적 의무는 권리와 의무가 혼합된 형태를 띠고 있으며, 사회국가·문화국가·환경국가이념을 구현한다는 의미를 가지고 있다. 또한, 정치적 통일체로서 국가에의 적극적인 참여와 구성이라는 측면에서도 의미를 가진다고 할 수 있다.[843]

4. 수범자 및 효력

⑴ 수범자

국가는 영토고권(영토, 영공, 영해)을 가지고 있으므로 그 영토 내에 거주하고 있는 모든 사람, 즉 국민, 외국인 및 무국적자에게 의무를 부과할 수 있다. 따라서 외국인이 어떤 나라의 영토 내에서 영리행위를 하거나 재산을 보유하고 있다면 납세의무의 주체가 된다. 또한, 사법상의 법인의 경우, 물적·금전적 급부의무를 진다는 점에서 기본의무가 인정된다.

⑵ 효력

기본의무는 원칙적으로 대국가적 효력을 가진다. 또한, 제한된 의미에서 대사인적, 즉 제3자적 효력을 가진다. 예컨대, 노동과 관련된 명예직 공무수행을 하는 사인은 노동자를 채용하고 있는 기업주의 협력이 필요하다는 의미에서 제3자적 효력을 갖는다.

5. 기본권과의 충돌 및 경합

⑴ 충돌

기본의무를 현실적인 것으로 만들기 위해서는 법률의 구체화가 필요한데, 그러한 과정에서 기본권과 기본의무가 충돌하는 경우가 있을 수 있다. 예컨대, 양심의 자유와 병역의 의무의 충돌이 이에 속한다. 이에 대해서는 법익형량, 권리우선설, 의무우선설, 대칭관계설 등 많은 견해의 대립이 있다.

이에 대해 우리 대법원은 헌법상 기본권의 행사가 국가공동체 내에서 타인과의 공동생활을 가능하게 하고 다른 헌법적 가치 및 국가의 법질서를 위태롭게 하지 않는 범위 내에서 이루어져야 한다는 것은 양심의 자유를 포함한 모든 기본권 행사의 원칙적인 한계이므로, '양심 실현의 자유도 결국 그 제한을 정당화할 헌법적 법익이 존재하는 경우에는 헌법 제37조 제2항에 따라 법률에 의하여 제한될 수 있는 상대적 자유'라고 판시하여 법익형량설의 입장을 취하고 있다.[844]

우리 헌법재판소도 양심의 자유는 매우 중요한 기본권이지만, 법질서에 대한 복종을 거부할 수 있는 권리가 아니라 '국가공동체가 감당할 수 있는 범위 내에서 양심을 보호해 줄 것을 국가로부터 요구하는 권리'라고 하거나 병역법으로 인해 양심적 병역거부자의 양심의 자유가 제한된다면서도 국가안보 및 병역의무의 형평성이라는 공익을 실현하고자 하는 것으로 입법 목적의 정당성과 수단성의 적합성이 인정된다고 하여 대체복무제를 허용하더라도 공익 달성에 아무런 지장이 없다는 판단을 쉽사리 내릴 수 없다며 최소침해원칙에 위반되지 않고 법익균형성 또한 갖추고 있다고 판시하여 법익형량설의 입장을 취하고 있다.[845]

---

843) 허영, 전게서, 570면.
844) 대법원 2004. 7. 15. 2004도2965 등.

그러나 대법관 이강국은 반대의견에서 피고인에게 병역법상의 형벌법규의 기속력이 미치지 않는다고 할 수는 없겠지만, 그렇다고 하여 절대적이고도 진지한 종교적 양심의 결정에 따라 병역의무를 거부한 피고인에게 국가의 가장 강력한 제재 수단인 형벌을 가하게 된다면 그것은, 피고인의 인간으로서의 존엄성을 심각하게 침해하는 결과가 될 것이고 형벌 부과의 주요 근거인 행위자의 책임과의 균형적인 비례관계를 과도하게 일탈한 과잉조치가 될 것이며, 또한, 피고인에 대한 형벌은 그 정도에 상관없이 범죄에 대한 응징과 예방, 피고인의 교육 등 그 어떠한 관점에서도 형벌의 본래적 목적을 충족할 수 없음이 명백해 보이고, 특히 보편적 가치관을 반영한 집총병역의무와 종교적 양심의 명령 사이의 갈등으로 인한 심각한 정신적 압박 상황에서 절박하고도 무조건적인 종교적 양심의 명령에 따른 피고인에게는 실정 병역법에 합치하는 적법한 행위를 할 가능성을 기대하기가 매우 어렵다고 보인다. 따라서 피고인과 같은 경우에는 국가의 형벌권이 한 발 양보함으로써 개인의 양심의 자유가 보다 더 존중되고 보장되도록 하는 것이 상당하다 할 것이어서 피고인에게는 범죄의 성립요건인 책임성을 인정할 수 없다고 보아야 하고, 이러한 점에서 피고인에게는 병역법 제88조 제1항의 적용을 배제할 '정당한 사유'가 존재한다고 한 바 있다.

또한, 헌법재판관 이강국과 송두환은 한정위헌의견에서 헌법상의 기본권과 헌법상의 국민의 의무 등 헌법적 가치가 상호 충돌하고 대립하는 경우에는 어느 하나의 가치만을 선택하여 나머지 가치를 희생시켜서는 안 되고, 충돌하는 가치를 모두 최대한 실현시킬 수 있는 규범조화적 해석원칙을 사용해야 한다. 양심의 자유와 국방의 의무라는 헌법적 가치가 상호 충돌하고 있는 이 사건 법률조항의 문제도 이와 같은 규범조화적 해석의 원칙에 의하여 해결해야 한다. 따라서 이 사건 법률조항의 '정당한 사유'는 진지하고 절박한 양심을 결정한 사람들의 양심의 자유와 국방의 의무라는 헌법적 가치가 비례적으로 가장 잘 조화되고 실현될 수 있는 조화점을 찾도록 해석하여야 한다. 하지만 헌법재판소와 대법원 판례는 이 사건 법률조항의 '정당한 사유'에는 종교적 양심상의 결정에 의하여 병역을 거부한 행위는 포함되지 아니한다고 해석하고 있는데, 그 결과 절대적이고 진지한 양심의 결정에 따라 병역의무를 거부한 청구인들에게 국가의 가장 강력한 제재수단인 형벌이, 그것도 최소한 1년 6개월 이상의 징역형이라고 하는 무거운 형벌이 부과되고 있다. 이는 인간으로서의 존엄과 가치를 심각하게 침해하는 것이고, 나아가 형벌부과의 주요근거인 행위와 책임과의 균형적인 비례관계를 과도하게 일탈한 과잉조치이다. 양심적 병역거부자들에 대한 대체복무제를 운영하고 있는 많은 나라들의 경험을 살펴보면, 대체복무제가 도입될 경우 사이비 양심적 병역거부자가 급증할 것이라고 하는 우려가 정확한 것이 아니라는 점을 알 수 있다. 엄격한 사전심사와 사후관리를 통하여 진정한 양심적 병역거부자와 그렇지 못한 자를 가려낼 수 있도록 대체복무제도를 설계하고 운영한다면 이들의 양심의 자유 뿐 아니라 국가안보, 자유민주주의의 확립과 발전에도 도움이 될 것이다. 결국, 이 사건 법률조항 본문 중 '정당한 사유'에, 양심에 따른 병역거부를 포함하지 않는 것으로 해석하는 한 헌법에 위반된다고 한 바 있다.

⑵ 경합

경합은 이중국적과 같이 한 사람이 이중적으로 납세와 병역의무를 부담하고 있는 경우에 성립하는 데, 이를 해결하기 위해 기본권서열이론이나 이익형량 등의 방법이 제시되고 있다. 그러나 국제법에서는 만국평등의 원칙이 지배하고 있어 어느 국가가 다른 국가에 대해 우선권을 가지고 있다고 할 수 없으므로 국제실무에서는 이러한 과중된 의무이행을 협정에 의하여 완화시키고 있다고 한다.[846]

---

845) 헌법재판소 2011. 8. 30. 2008헌가22 등.
846) 홍성방, 전게서, 400면.

6. 개별적 기본의무

⑴ 납세의 의무(제38조)

1) 연혁 및 헌법규정

납세의 의무는 1789년 프랑스 인권선언을 그대로 수용한 1791년 프랑스 헌법에서 최초로 규정되었다. 우리 헌법은 제38조에서 납세의 의무를 규정하고 있다.

2) 법적성격 및 주체

가. 법적성격

납세의 의무는 자의적 과세로부터 재산권을 침해당하지 아니한다는 소극적 성격과 국민이 주권자로서 스스로 국가공동체의 재정력을 부담한다는 적극적 성격을 가지고 있다.

나. 주체

납세의 의무의 주체는 국민이고, 자연인과 법인이 포함된다. 또한, 외국인이라도 국내에 재산을 가지고 있거나 조세의 대상이 되는 행위를 할 때에는 납세의 의무를 진다. 다만, 외국공관 등 치외법권이 있는 경우나 조약에 특별한 규정이 있는 납세의 의무가 면제된다.

3) 내용

납세란 조세의 납부를 의미하고, 여기서 조세란 반대급부 없이 국가가 부과하는 일체의 강제적·일방적인 경제적 부담을 말한다.[847] 그렇기 때문에 조세는 근거를 제시하여 국민의 정치적·심리적 저항을 완화시키고, 공공경비의 배분기준이 설정되도록 해야 한다. 또한, 일정한 반대급부를 내용으로 하는 사용료나 수수료의 징수, 전매수입, 공채수입 등은 조세에 해당되지 않는다.

납세의 의무는 가장 기본적인 의무이나 납세의 의무는 국민의 재산권에 대한 일종의 제한이기 때문에 헌법 제11조에 의거 국민의 담세능력에 따라 공평하게 부과되어야 하고(조세공평주의), 국회가 제정한 형식적 의미의 법률에 따라서만 부과할 수 있다(조세법률주의, 헌법 제59조). 여기서 조세법률주의는 과세요건이 법률로 명확히 규정되어야 할 뿐만 아니라 조세법의 목적이나 내용이 기본권보장이라는 헌법이념과 헌법상의 원칙들에 합치할 것을 요구한다.[848]

납세의무를 구체화하는 법률로는 국세기본법과 국세징수법 등이 있다.

⑵ 국방의 의무(제39조)

1) 법적성격

국방의 의무는 법률에 의하지 아니하고는 국방의 의무를 부과하지 못하게 하여 국민의 신체의 자유를 보장하는 소극적 측면과 주권자인 국민이 국토를 보위하여 국가를 보존하려는 적극적 측면을 병유하고 있는 의무이다. 이러한 국방의 의무는 타인에 의한 대체이행이 불가능한 일신전속적인 성격을 가진 의무이다.

---

847) 헌법재판소 1991. 11. 25. 91헌가6.
848) 헌법재판소 1998. 12. 24. 97헌바33 등.

2) 내용

가. 개념

국방의 의무는 외국 또는 외적의 침략에 대하여 국가의 독립을 유지하고 영토를 보전하기 위한 국가방위의 의무를 말한다.

<대법원 1995. 2. 28. 94누7713>

병역의무는 국가수호를 위해 전국민에게 과하여진 헌법상의 의무로서 그 의무를 부과함에 있어서는 형평을 유지하여야 함을 물론 그 면탈을 방지하도록 하여야 할 공익적 필요성이 매우 크다.

나. 범위

이러한 국방의 의무는 병역제공의무만을 의미한다고 보는 협의설과 직접적인 병역제공의무 이외에도 방공·방첩·전시근무 등 국방에 필요한 모든 의무를 포함한다고 보는 광의설이 있다. 광의설로 파악하는 것이 일반적이며, 우리 헌법재판소도 병역의 의무를 광의로 해석하여 전투경찰대원으로 복무하는 것도 병역의무이행의 일환이라 판시한 바 있다.[849]

다. 법률주의

국방의 의무는 법률이 정하는 바에 의하여만 부과되어야 한다. 이를 구체화하는 법률로는 병역법, 향토예비군설치법, 민방위기본법, 전시근로동원법 등이 있다.

라. 병역의무 이행으로 인한 불이익처우금지

우리 헌법 제39조 제2항은 불이익처우금지를 규정하고 있다. 우리 헌법재판소는 군법무관이었던 자가 전역 후 변호사개업을 함에 있어서 개업지를 제한한 변호사법 제10조 제2항을 헌법 제39조 제2항에 위반된다고 판시한 바 있다.[850] 그러나 전투경찰대원으로 전임(차출)되는 것은 헌법 제39조 제2항에 위반되지 않는다고 한 바 있다.[851]

3) 주체

국방의 의무는 모든 국민이 주체가 된다. 직접적인 병력제공의무는 병역법 제2조에 따라 남자인 국민만이 주체가 되며, 그 의무주체는 연령에 따라 그 범위가 제한된다. 간접적인 병력형성의무는 남녀를 가리지 않고 모든 국민이 부담하며, 방공의 의무는 외국인을 포함한 모든 자연인이 주체가 된다.[852]

<헌법재판소 2002. 11. 28. 2002헌바45> 구 병역법 제71조 제1항 단서 위헌소원

국방의 의무는 외부적대세력의 직·간접적인 침략행위로부터 국가의 독립을 유지하고 영토를 보전하기 위한 의무로서 현대전이 고도의 과학기술과 정보를 요구하고 국민전체의 협력을 필요로 하는 이른바 총력전이 점에 비추어 직접적인 병력형성의무만을 가리키는 것이 아니라 간접적인 병역형성의무 및 병력형성 이후 군의 작전명령에 복종하고 협력해야 할 의무도 포함된다. 직접적인 병력형성의무는 입법자가 국가의 안보상황, 재정능력 등의 여러 가지 사정을 고려하여 국가의 독립을 유지하고 영토를 보전함에 필요한 범위 내에서 결정할 사항이고, 예외적으로 국

849) 헌법재판소 1995. 12. 28. 91헌마80.
850) 헌법재판소 1989. 11. 20. 89헌바102.
851) 헌법재판소 1999. 12. 23. 98헌마363.
852) 권영성, 「헌법학원론」, 법문사, 2009, 663면.

가의 안위에 관계되는 중대한 교전상태 등의 경우에는 대통령이 헌법 제76조 제2항에 근거하여 법률의 효력을 가지는 긴급명령을 통하여 결정할 수도 있다.

⑶ 교육을 받게 할 의무(제31조 제2항)

1) 의의

교육을 받게 할 의무란 친권자나 후견인이 보호하는 자녀에게 적어도 초등교육과 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무를 말한다. 이는 제31조 제1항의 교육을 받게 할 권리의 실효적 보장을 위한 것으로 모든 국민으로 하여금 생존에 필요한 최소한의 교양과 능력을 함양하게 하는 측면과 문화국가이념을 실현하기 위한 다음 세대를 위한 교육이라는 측면도 가지고 있다.

2) 법적성격

법적의무설이 일반적인 견해이며, 교육기본법과 초·중등교육법은 초등학교에 취학시킬 의무를 이행하지 않은 보호자가 의무이행의 독려를 받고도 이행하지 않은 경우에 100만원 이하의 과태료로 처한다(제68조).

3) 주체

의무교육은 공민교육으로 우리나라 국민인 학령아동의 친권자 또는 후견인이다. 보호자의 적령아동을 취학하게 할 의무는 적령아동의 신고와 초등교육과 법률이 정하는 교육이 필요한 최소한의 협조의무를 말한다.[853]

⑷ 근로의 의무(제32조 제2항)

1) 의의

국민이 노동을 통하여 국가의 부를 증식하는 데 기여할 의무를 말한다. 근로의 의무는 인간다운 생활보장의 법률상의 전제로서의 의의를 가진다. 여기서 근로는 육체적·정신적 노동을 포함하는 넓은 의미의 근로를 의미한다.

2) 법적성격

근로의 의무는 근로의 능력이 있음에도 불구하고 근로하지 않는 자에 대해서 가해지는 윤리적·도의적인 비난이며 근로의 의무는 근로의 강제를 뜻할 수는 없으나 제32조 제2항 제2문에 의해 특정한 경우 근로의 의무의 내용과 조건을 법률로 정한 때에만 법적의무가 되고, 이때에도 선택적 이행을 제시할 필요가 있다는 윤리적 의무설이 일반적인 견해이다.[854]

이는 인간으로서의 존엄과 가치가 존중되고(제10조), 강제노역이 금지되며(제12조 제1항), 사회재산제가 보장되는(제23조 제1항) 우리 헌법하에서는 근로의 의무는 제32조 제2항 제2문의 경우를 제외하고는[855] 윤리적·도의적 의무로 이해함이 타당하다.

---

853) 한동섭, 「헌법」, 박영사, 1971, 139면.

854) 김철수, 「헌법학」(상), 박영사, 2008, 856면; 권영성, 전게서, 668면; 허영, 전게서, 577면; 홍성방, 전게서, 407면.

855) 이 경우에도 그 내용을 법률로써 규정하되, 국가비상시에만 예외적으로 허용되고, 대체이행이 허용되어야 하며, 의무불이행에 대한 제재도 금전벌에 그쳐야 한다(권영성, 전게서, 668면).

⑸ 환경보전의무(제35조 제1항 후단)

1) 법적성격

법적의무설이 일반적 견해이며, 환경보전의무는 권리대응적 성격이 강한 의무이다.[856]

2) 주체

이는 인류의 의무로써, 모든 자연인과 법인이 포함된다.

3) 내용

환경을 오염시키지 않을 의무, 공해방지시설을 할 의무 등을 내용으로 한다. 개인 또는 기업이 환경을 오염시키거나 공해방지시설을 해태한 경우에는 국민은 그 배제를 청구할 수 있고, 국가도 그에 대한 제재를 가할 수 있다. 이러한 의무들에 대해서는 환경정책기본법, 자연환경보전법, 해양오염방지법, 수질환경보전법, 대기환경보전법, 환경개선비용부담법 등에서 규율하고 있다.

⑹ 재산권행사의 공공복리적합성(제23조 제2항)

1) 법적성격

이에 대해서는 단순한 윤리적 의무라고 보는 윤리적 의무설, 헌법적 의무이며 법률로써 강제할 수 있다고 보는 법적 의무설, 재산권 자체에 필연적으로 수반되는 제약성을 명문화한 것으로 보는 헌법원리설이 대립하고 있다. 그러나 헌법에 의한 재산권 제한 내지 재산권의 사회적 기속성, 재산권의 헌법적 한계로 보는 것이 타당할 것이다.[857]

2) 내용

가. 공공복리의 의미

제23조 제2항의 의미는 제37조 제2항의 공공복리와는 다르다. 제37조 제2항의 공공복리는 모든 기본권에 대하여 헌법이 일반적으로 유보하고 있는 제약이기 때문에 그 의미내용은 엄격하게 해석되어야 한다. 그에 반하여 제23조 제2항의 공공복리는 특별한 법률에 의한 유보를 의미하므로 재산권의 사회성·의무성을 전제로 하는 것으로 정책적 제약까지도 인정하는 것이다.[858] 우리 대법원은 공공복리적합의무의 범위 내에서는 보상이 요구되지 않는다고 한다.[859]

그러나 헌법재판소는 개발제한구역제도 자체는 합헌이나 그로인해 토지소유자에게 사회적 제약을 넘는 가혹한 부담이 발생하는 예외적인 경우에 대하여 보상규정을 두지 않은 것은 위헌이라고 판시한 바 있다.[860]

나. 공공복리적합의무

이는 토지를 적극적으로 이용·개발할 의무, 재산권을 남용하지 않을 의무 등이 있다. 헌법은 국토의 이용·개발과 보전을 위하여 법률로써 개간을 명하고, 토지소유권과 묘지의 면적 등을 법률로써 제한할 수 있도록 하고 있다. 이에 대하여 민법은 권리남용을 금지하고 있고(제2조), 재

856) 홍성방, 전게서, 408면.
857) 허영, 전게서, 579면; 홍성방, 전게서, 409면.
858) 한동섭, 전게서, 169면.
859) 대법원 1996. 6. 28. 94다54511.
860) 이른바 경계이론(헌법재판소 1998. 12. 24. 89헌마214).

산권행사의 공공복리적합의무를 구체화하는 법률로는 농지법, 농어촌정비법, 국토이용관리법 등이 있다.

♣ 문제풀이

1. 다음 국민의 의무에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 국민의 의무규정은 모든 국가기관을 구속할 수 있는 직접적 효력을 가진다.
② 환경권 및 근로의 권리는 권리인 동시에 의무이기도 한다.
③ 헌법과 법률의 준수의무는 법치국가적 민주주의의 요청에 따라 인정될 수 있다.
④ 헌법이 정한 의무는 면제에 정당한 이유가 있고 평등의 원칙 등에 반하지 않는 경우 위헌이라고 할 수 없다.
⑤ 헌법이 규정하고 있는 것 이외에는 법률로 어떠한 의무도 부과할 수 없다.

[정답] ⑤
[해설] 기본권을 침해하지 않는 범위 내에서 법률로 부과할 수 있다.

2. 다음 중 납세의 의무에서 말하는 조세에 해당하는 것은?

① 사용료 ② 전매수입 ③ 주세 ④ 수수료 ⑤ 공채수입

[정답] ③
[해설] 조세란 재정조달 목적으로 반대급부 없이 일반국민에게 강제적으로 부과·징수하는 과징금을 의미한다(헌법재판소 1991. 11. 25. 91헌가6).

3. 다음 국방의 의무에 대한 설명으로 바르지 못한 것은?

① 근대국가에서 국방의 의무는 주권개념에 대응하는 의무로서 모든 국민이 주체이다.
② 국방의 의무에는 침략전쟁을 위한 병력형성의 의무는 포함되지 않는다.
③ 국방의 의무를 부과할 때는 법률에 의한다.
④ 국방의 의무는 납세의 의무처럼 타인에 의한 대체적 이행이 가능하다.
⑤ 국방의 의무에는 직접적인 병력제공의무 이외에도 간접적인 병력형성의무까지 포함된다.

[정답] ④
[해설] 국방의 의무는 일신전속적인 의무이므로 대체적 이행이 불가능하다.

♣ 요점정리

1. 헌법과 법률의 준수의무·국가수호의무에 대해서는 명시적인 규정은 없지만 법치국가적 민주주의의 요청에 따라 인정될 수 있다.

2. 진정의무는 헌법이 직접적으로 특정의 법적결과를 언급하고 있는 의무를 말하고, 부진정의무는 헌법이 직접적으로 특정의 법적결과를 언급하고 있지 않는 의무를 말한다.

3. 바이마르헌법 이전의 교육의 의무는 취학의 의무가 아니라 수업에의 강제를 의미하는 교수의 무를 의미하므로 오늘날 교육의 의무와 그 의미가 다르다. 따라서 교육의 의무는 현대적 의무에 해당한다.

4. 고전적 의무는 국가권력의 남용을 억제하고, 국가권력의 발동을 제한한다는 의미에서 소극적이고 방어권이었으나 오늘날에는 주권자인 국민이 스스로 국가의 존립과 안전을 위하여 병력을 유지하고, 국가의 재정을 위하여 조세를 납부한다는 적극적 의미도 가지고 있다.

5. 기본의무를 현실적인 것으로 만들기 위해서는 법률의 구체화가 필요한데, 그러한 과정에서 기본권과 기본의무가 충돌하는 경우가 있을 수 있다. 예컨대, 양심의 자유와 병역의 의무의 충돌이 이에 속한다.

6. 일정한 반대급부를 내용으로 하는 사용료나 수수료의 징수, 전매수입, 공채수입 등은 조세에 해당되지 않는다.

7. 국방의 의무는 납세의 의무와는 달리 일신전속적인 의무이므로 대체적 이행이 불가능하다.